yetkin®
BİLİMSEL YAYINLAR

BORÇLAR HUKUKU BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU BORÇLAR HUKUKU

Prof. Dr. Fahrettin ARAL
Prof. Dr. Hasan AYRANCI

BORÇLAR HUKUKU
Özel Borç İlişkileri

Prof. Dr. Fahrettin ARAL
Prof. Dr. Hasan AYRANCI

BORÇLAR HUKUKU

Özel Borç İlişkileri

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş
Tıpkı 12. BASKI

YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.
Strasburg Caddesi No: 31/A [illegible] ANKARA
Tel: 0 (312) 231 42 34 (35) [illegible] 229 87 85
Şube: Abide-i Hürriyet Cad. N[illegible]şli/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 234 50 56 (57) Fax: Faks: 0 (212) 234 50 58
http://www.yetkin.com.tr e-posta: yetkin@yetkin.com.tr

ISBN 978-605-05-0476-7

9 786050 504767

YETKİN

YETKİN YAYINLARI®

Prof. Dr. Fahrettin ARAL
A.Ü. Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
A.Ü. Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

BORÇLAR HUKUKU
Özel Borç İlişkileri

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ
Tıpkı 12. Baskı

Ankara 2019

BORÇLAR HUKUKU
Özel Borç İlişkileri

YETKİN YAYINLARI

ÖDEMELİ İSTEME VE GENEL DAĞITIM

YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.
Strasburg Caddesi No: 31/A 06430 Sıhhiye / ANKARA
Tel : 0 (312) 231 42 34 (35) – 232 03 43 Faks: 229 87 85
Şube: Abide-i Hürriyet Cad. No: 158 34381 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 234 50 56 (57) Pbx Faks: 0 (212) 234 50 58
e-mail: yetkin@yetkin.com.tr http://www.yetkin.com.tr
Yayınevi Sertifika No: 13974

Yayın Kodu: ISBN 978-605-05-0476-7

© Yetkin Yayınları 2019

Dizgi: YETKİN Elektronik Yayımcılık Sistemleri
Baskı: YETKİN BASIMEVİ
Kâzım Karabekir Caddesi No: 95/7-8-10
Tel: 0 (312) 341 00 06 06060 ANKARA
Matbaa Sertifika No: 13989

12. BASKIYA ÖNSÖZ

Hukuk Bilimi dinamik bir ilişkiler bütününü incelemektedir. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkilerinin 10. baskısının yayınlanmasından sonra hukuk yaşamında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Bu süre zarfında çıkarılması öngörülen yönetmelikler uzun sayılmayacak bir gecikmeyle yürürlüğe sokulabilmiştir. Bu yönetmelik hükümleri 11. basıda kitaba işlenmiştir.

Taşınmaz satışı sonucu doğuran sözleşmelerden taşınmaz satış vaadi, opsiyon, alım, geri alım ve önalım sözleşmeleri inceleme konusu yapılmıştır.

Bunun dışında esere mümkün olduğunca Yargıtay içtihatları ilave edilmiştir. Böylece kitabın bütününe hâkim olan soyut ve genel anlatımın bir ölçüde somutlaşması ve hukuk uygulamasının esere yansıması temin edilmiştir.

Kitabın pek çok bölümüne, yeni bilgiler girilmiştir. Bazı düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Bu baskı vesilesiyle Hocam Prof. Dr. Fahrettin Aral'ı artan bir özlemle rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Kavaklıdere, Eylül 2019
Prof. Dr. Hasan AYRANCI

10. BASKIYA ÖNSÖZ

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkilerinin 9. baskısının yayınlanmasından sonra önemli bazı kanunlar yürürlüğe girmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çalışma alanımız açısından bunlar arasında en önemlisi sayılabilir. Günlük hayatta tüketici sözleşmelerinin çokluğu ve yaygınlığı karşısında bu ilişkilere uygulanacak hükümleri içeren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun asgari ölçüde de olsa bilinmesi zarureti bulunmaktadır. Bu bakımdan kitaba bazı ilaveler yapılmıştır.

Milletlerarası Mal Satışına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ise yaklaşık 80 ülkenin imzasıyla önemli bir hukuk kaynağı haline gelmiştir. Bu bakımdan Antlaşmada yer alan hükümler ilgili konuların altında değerlendirilmiştir.

Ticari İşlemlerde Geç Ödemelerle Mücadeleye ilişkin 29 Haziran 2000 Tarih ve 2000/35/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'ne uygun olarak çıkarılan Türk Ticaret Kanunun ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin 1530/2'nci maddesi de bu baskıda inceleme konusu yapılmıştır. Zira, düzenleme para borçlarında temerrüde ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin önemli kurallar içermektedir.

Kitabın pek çok bölümüne, yeterli olmamakla birlikte, yeni bilgiler girilmiştir. Bazı düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Bu baskı vesilesiyle Hocam Prof. Dr. Fahrettin Aral'ı rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Ankara, Eylül 2014
Prof. Dr. Hasan AYRANCI

9. BASKIYA ÖNSÖZ

Muhterem Hocamız Fahrettin Aral ebediyete intikal etti. Büyük bir insan ve hukukçu olarak hatıralarda iz bıraktı. Bizler için hatıradan çok öte bir yakın, bir akraba, bir dost ve Hoca idi. Sadece hukukun derinliklerini ve inceliklerini değil topyekün bir hayatı öğrendik ondan.

Geriye eserlerini, bir duygu ve düşünce sistemini nihayet bizleri bıraktı...

Son anlarına kadar bilimsel tecessüs ve inanç içinde yaşadı; öyle ki en yeni ve ciddi konuları bizimle tezekkür etmek istedi.

Sağlığında elinizdeki eseri bana vermiş ve incelememi arzu etmişti. İrtihalinden sonra bazı eksik bölümleri tamamlayarak ve kısmî ilaveler yaparak eseri bu son haline getirmeye çalıştım. Ancak asıl iş bugünden itibaren yapılacaklardır.

Önemli bir sorumluluktur bu. Ancak tek tesellimiz Hocamız Prof. Dr. Fahrettin Aral'ın bu eserinde yaşayacak olmasıdır.

Ankara, Eylül 2012
Prof. Dr. Hasan Ayrancı

8. BASKIYA ÖNSÖZ

Yedinci baskısı geçen yıl yapılan bu kitap, Borçlar Hukukunun özel borç ilişkileri çerçevesinde incelenen sözleşmelerin önemli bir kısmını ihtiva etmektedir.

Önceki baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri, yeni yayınlar ve özellikle yeni yargı kararları bu baskıya işlenmiş bulunmaktadır.

Yazım işini ve düzeltmeleri büyük bir titizlikle gerçekleştiren Serap Özer ve kitabın basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi sahipleri Ziya Gülkök ve Muharrem Başer beyefendilere teşekkür ederim.

Ankara, Eylül 2010
Prof. Dr. Fahrettin Aral

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 37
BİBLİYOGRAFYA 39
GİRİŞ 47

§ 1. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE BORÇLAR KANUNUN'DA DÜZENLENEN SÖZLEŞME TİPLERİ 47
I. Özel borç ilişkileri 47
II. Borçlar Kanunu'nda özel hüküm – genel hüküm ilişkisi 48
1. Münhasır uygulama 49
2. Kuralların birlikte uygulanması 50
3. Kuralların yarışması 50
III. Aslî edim yükümünün muhtevasına göre sözleşmelerin tasnifi 50
1. Temlik borcu doğuran sözleşmeler 51
2. Kullandırma sözleşmeleri 51
3. İş görme sözleşmeleri 51
4. Saklama sözleşmeleri 51
5. Teminat sözleşmesi 51
6. Sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler 51
7. İrat sözleşmeleri 52
8. Şirket sözleşmeleri 52

§ 2. KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELER (ATİPİK VEYA İSİMSİZ SÖZLEŞMELER) 53
I. Kavram 53
II. Dogmatik temelleri 53
III. Çeşitleri 56
1. Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler 56
2. Karma sözleşmeler 57
a) Tanımı 57
b) Çeşitleri 58
aa) Kombine sözleşmeler 58
bb) Çifte tipli sözleşmeler 58
cc) Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler 59

dd) Kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler .. 59
3. Bileşik sözleşmeler 60
IV. Hukuk kurallarının uygulanması 61
1. Genel olarak 61
2. İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması 62
a) Karma sözleşmelerin tamamlanması 62
aa) Soğurma (imtisas) teorisi 62
bb) Kıyas yoluyla uygulama 63
cc) Terkip (kombinezon) teorisi 63
dd) Yaratma teorisi 63
b) Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmelerin tamamlanması 64
c) Bileşik sözleşmelerin tamamlanması 64

BİRİNCİ KISIM
TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR SATIŞI

§ 3. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, KURULMASI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU 65
I. Tanımı 65
II. Türleri 66
III. Kurulması 67
1. Semenin belirlenebilir olması 68
2. Satılanın belirlenebilir olması 69
IV. Hukukî niteliği 69
1. Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir 69
2. Satış sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir 70
3. Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir 70
4. Satış sözleşmesi ani edimleri ihtiva eden bir sözleşmedir 71
5. Satış sözleşmesi illî (sebebe bağlı) bir sözleşmedir 72
V. Konusu 72
1. Eşya 73
2. Hak ve alacaklar 74
3. Ekonomik bir fayda 75

4. Gelecekteki eşya ve haklar 76
5. Üçüncü şahıslara ait şeyler ve haklar 76
§ 4. TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ 77
I. Konusu 77
1. Taşınmaz satışının konusu 78
2. TBK m. 209 anlamında taşınır satışının konusu 78
II. Şekli 81
§ 5. TAŞINIR SATIŞINDA YARAR VE HASARIN GEÇMESİ 83
I. Hasarın geçmesi 83
1. Hasar ve hasarın geçmesi kavramları 83
a) Hasar kavramı 83
b) Hasarın geçmesi kavramı 84
2. Hasarın geçtiği an 85
a) Kural 85
b) İstisnalar 86
aa) Kanundan doğan istisnalar 86
bb) Durumun gereğinden doğan istisnalar 86
cc) Sözleşmeden doğan istisnalar 87
c) Mesafe satışlarında 87
II. Yararın geçmesi 88
§ 6. SATICININ BORÇLARI 89
I. Satıcının aslî borçları 89
1. Satılanın zilyetliğini geçirme borcu 89
a) Zilyetliğin geçirilmesi kavramı 89
b) İfa yeri 90
c) Devir masrafları 90
d) Taşıma masrafları 91
2. Satılanın mülkiyetini geçirme borcu 92
II. Diğer borçlar 93
1. Yan hükümler 93
2. Koruma yükümleri 94
III. Satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesi 94
1. Genel hükümler 94
2. Özel hükümler 95

§ 7. SATICININ TEMERRÜDÜ 96
I. Satıcının temerrüdünün sonuçları 96
1. Kural 96
2. İstisna: Zilyetliğin devri için belirli süre öngörülen ticari satışlar 96
II. Ticarî satışlarda 97
1. Ticarî satış kavramı 97
2. TBK m. 212/II'de öngörülen karineler 98
a) Kesin vadeli sözleşme karinesi 98
b) Alıcının olumlu zararının tazminini talep ettiği karinesi 99
c) Zilyetliğin devri için belirli vade öngörülen ticarî satışlarda farklı düzenlemenin gerekçesi 101
III. Satıcının temerrüdünde Zararın hesabı 101
a) Genel olarak 101
b) İkame alım halinde zararın somut hesaplanması 102
c) Zararın soyut olarak hesaplanması 103
IV. Satıcının teslim borcunu ifada kısmî temerrüdü 104
1. Bir defada ifa edilmesi gereken teslim borcunun kısmen yerine getirilmiş olması 104
2. Ard arda teslimli satışda satıcının temerrüdü 105

§ 8. SATICININ SATILANIN ZAPTINDAN SORUMLULUĞU 107
I. Kavram 107
II. Zapttan sorumluluk hükümlerinin uygulama alanı 108
1. Alıcının eşya hukukuna ait korumadan yararlanamaması 108
a) Alıcının iyiniyetli olması 108
b) Alıcının kötü niyetli olması 109
2. Eşya hukuku dışında uygulama alanı 109
III. Zapttan doğan sorumluluğun şartları 109
1. Satılanın alıcıya teslimi 109
2. Satış sözleşmesinin kurulduğu anda zaptı sağlayan bir hakkın bulunması 109
3. Alıcının zapt tehlikesini satış sözleşmesinin kurulduğu anda bilmemesi 110
4. Satılanın zaptı 110
5. Zaptın isbat edilmesi 111
a) Zaptın bir mahkeme hükmüyle gerçekleşmesi 111

b) Mahkeme kararı olmaksızın satılanın üçüncü kişiye verilmesi .. 112
IV. Zaptın hükümleri 112
1. Tam zapt halinde 112
a) Sözleşmenin kendiliğinden ortadan kalkması 112
b) Satış bedelinin iadesi 112
c) Alıcının tazminat talepleri 113
aa) Kusursuz sorumluluk esasına göre 113
aaa) Satılan üzerinde alıcının yaptığı masraflar 113
bbb) Mahkeme masrafları 113
ccc) Alıcının doğrudan doğruya zararları 113
bb) Kusur sorumluluğu 114
2. Kısmî zapt halinde 114
V. Sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması 115

§ 9. SATICININ SATILANIN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU 116
I. Tanımı 116
II. Hukukî niteliği 116
1. Çeşit satışında 116
2. Parça satışında 116
III. Satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartları 117
1. Hasarın geçtiği anda satılan ayıplı olmalıdır 117
a) Ayıp kavramı 117
aa) Maddî ayıp 118
bb) Ekonomik ayıp 119
cc) Hukukî ayıp 119
b) Bildirilen (vaad edilen) vasıfların bulunmaması 119
c) Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği bir vasfın bulunmaması 122
d) Satılanın hasarın geçtiği anda ayıplı olması 123
2. Alıcının ayıbı bilmemesi gerekir 123
3. Alıcı ayıbı kabul etmemiş olmalıdır 125
4. Ayıptan doğan sorumluluk sözleşmeyle kaldırılmamış olmalıdır ... 126
IV. Ayıba karşı sorumluluktan doğan taleplerin ileri sürülmesinin şartları (şeklî şartlar) 126
1. Genel olarak 126

2. Gözden geçirme (muayene) külfeti ... 128
a) Gözden geçirmenin tarzı ve kapsamı ... 129
b) Gözden geçirme yeri ... 130
c) Gözden geçirmenin yapılacağı zaman ... 130
d) Gözden geçirme masrafları ... 131
3. Bildirme (ihbar) külfeti ... 132
4. Gözden geçirme (muayene) ve bildirimin (ihbarın) yapılmamasının sonuçları ... 133
5. Mesafe satışlarında alıcının yükümleri ... 134
a) Şartları ... 134
aa) Bir mesâfe satışı bulunmalıdır ... 134
bb) Satıcının devir yerinde bir temsilcisi bulunmamalıdır ... 135
cc) Alıcı, kendisine devredilen satış konusunu ifa olarak kabul etmemelidir ... 135
b) Sonuçları ... 135
aa) Satılanı koruma (muhafaza) yükümü) ... 135
bb) Satılanın durumunu tesbit ettirme ... 136
cc) Satma yetkisi ve yükümü ... 136
V. Ayıba karşı tekeffülden alıcı lehine doğan seçimlik haklar ... 136
1. Seçim hakkının kapsamı ... 136
2. Seçim hakkının hukukî niteliği ... 137
3. Seçim hakkının kullanılması ve tükenmesi ... 139
4. Seçim hakkının sınırlanması ... 140
a) Konu yönünden ... 140
aa) Dönme hakkının sınırlanması ... 140
bb) Bedelin indirilmesi hakkının sınırlandırılması ... 143
b) Zaman yönünden ... 143
VI. Dönme (Wandelung) ... 143
1. Kavram ... 143
2. Hukukî sonuçları ... 144
a) Genel olarak ... 144
b) Alıcının borçları ... 144
aa) Satılanın iadesi borcu ... 144
bb) Semerelerin iadesi borcu ... 145
c) Satıcının borçları ... 145

aa) Bedeli iade ve masrafları ödeme borcu 145
bb) Tazminat ödeme borcu 146
aaa) Genel olarak 146
bbb) TBK m. 229/I, b. I ve II'nin sınırları 146
ccc) TBK m. 229/I, b. 3 gereğince tazmin edilecek doğrudan doğruya zarar 147
ddd) BK m. 229/II gereğince tazmin edilecek dolaylı (diğer) zararlar 148
VII. Bedelin indirilmesi davası 149
VIII. Ayıplı eşyanın değiştirilmesini talep hakkı 152
1. Alıcının hakkı 152
2. Satıcının değiştirme hakkı 153
IX. Zamanaşımı 154
X. Ücretsiz onarım isteme hakkı 158
XI. Ayıptan doğan sorumluluğun sözleşmeyle sınırlandırılması veya kaldırılması 159
1. Genel olarak 159
2. Yorumlanması 159
3. Kanunî sınırları 160
XII. Ayıptan doğan sorumluluk ile Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerindeki diğer hukukî imkânlar arasındaki ilişki 161
1. Genel olarak 161
2. Ayıptan doğan sorumluluk ile hata sebebiyle iptal arasındaki ilişki 161
3. Ayıptan doğan sorumluluk ile hile arasındaki ilişki 163
4. Ayıptan doğan sorumluluk ile haksız fiil arasındaki ilişki 164
5. Ayıptan doğan sorumluluğun gereği gibi ifa etmeme (kötü ifa) ile ilişkisi 165

§ 10. ALICININ BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ 167
I. Bedeli ödeme borcu 167
1. Genel olarak 167
2. Bedelin miktarı 168
a) Bedelin tayin edilmemiş olması 168
b) Satılanın ağırlığına göre bedelin hesabı 168
3. İfa yeri 168
4. İfa zamanı 168

5. Bedele faiz ödenmesi 169
6. Alıcının bedeli ödemede temerrüdü 169
a) Genel olarak 169
b) Temerrüdün sonuçları 169
aa) Peşin ve ön ödemeli satışlarda 170
bb) Veresiye satışlarda 170
cc) Ticari İşletmeler arasında mal ve hizmet sağlaması amacıyla yapılan sözleşmelerde temerrüt ve sonuçları (TTK m. 1530) 172
aaa) Temerrüt anı 172
bbb) Temerrüt faizi 174
dd) Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasında (CISG= Viyana Satış Sözleşmesi) temerrüt 177
c) Satıcının zararının hesabı 179
aa) Genel olarak 179
bb) Zararın somut olarak hesabı 179
cc) Zararın soyut olarak hesabı 180
II. Satılanı devralma borcu 180
1. Kavram ve hukukî niteliği 180
2. Şartları 182
3. Devralma borcunun yerine getirilmemesi 183
III. Alıcının diğer yükümleri 183

İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

§ 11. TAŞINMAZ SATIŞI 185
I. Tanımı ve konusu 185
II. Şekli 186
1. Şeklin kapsamı 187
a) Objektif esaslı noktalar 187
b) Sübjektif esaslı noktalar 188
2. Şekle uymamanın sonuçları 189
III. Ayıptan ve zapttan sorumluluk 190
1. Ayıptan doğan sorumluluk 190
a) Taşınmazın yüz ölçümü eksiklerine karşı tekeffül borcu 190

b) Zamanaşımı süresi 191
2. Zapttan doğan sorumluluk 192
IV. Yarar ve hasarın geçişi 192
§ 12. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 193
I. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 193
1. Tanımı ve hukuki niteliği 193
2. Şekli 195
3. Hüküm ve sonuçları 196
4. Tapu kütüğüne şerhi ve sona ermesi 197
II. Sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım sözleşmeleri 199
1. Genel Olarak Opsiyon Hakkı 199
2. Alım (İştira) Sözleşmesi 202
3. Sözleşmeden doğan önalım hakkı 203
a) Genel olarak 203
b) Kanundan doğan önalım hakkı 203
c) Sözleşmeden doğan önalım hakkının tanımı ve konusu 204
d) Şekli 207
e) Hakkın şerhi 207
f) Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılmasının koşulları 209
aa) Satış sözleşmesinin ya da satışa eşdeğer bir işlemin yapılmış olması 209
bb) Satış işleminin ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemin gerçekleştiğinin önalım hakkı sahibine bildirilmesi 209
cc) Önalım hakkının süresinde kullanılmış olması 210
dd) Önalım hakkından feragat edilmemiş olması 211
ee) Önalım hakkının dava yolu ile kullanılması 212
g) Önalım hakkının ileri sürülememesi, devri, mirasla intikali ve sona ermesi 213
4. Geri alım (vefa) sözleşmesi 214
a) Tanım ve konusu 214
b) Şerhi 216
c) Geri alım hakkının kullanılmasının sonuçları 217
§ 13. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ 218
I. Örnek üzerine satış 218

II. Beğenme koşuluyla satış 218
1. Tanımı 218
2. Hükümleri 218
3. Deneme veya gözden geçirme 219
a) Deneme ve gözden geçirmenin satıcı yanında yapılması 219
b) Deneme ve gözden geçirmenin alıcı yanında yapılması 219
III. Kısmi ödemeli satışlar 219
1. Taksitle Satışlar 219
a) Tanımı 219
b) Taksitle satış sözleşmesinin kurulması (şekli ve içeriği) 220
c) Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması 221
d) Tarafların hak ve borçları 221
aa) Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 221
bb) Alıcının def'ileri 221
cc) Satış bedelinin tamamen ödenmesi 222
e) Alıcının temerrüdü 222
aa) Satıcının seçimlik hakkı 222
bb) Sözleşmeden dönme 223
cc) Hakimin müdahalesi 223
f) Yetkili mahkeme ve tahkim 224
g) Taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulama alanı 224
2. Ön ödemeli taksitle satışlar 224
a) Tanımı, şekli ve içeriği 224
b) Tarafların hak ve borçları 225
aa) Ön ödemelerin süresi 225
bb) Ön ödemelerin teminatı 226
cc) Alıcının malın devrini isteme hakkı 226
dd) Satış bedelinin ödenmesi 226
ee) Satış bedelinin belirlenmesi 227
c) Sözleşmenin sona ermesi 227
aa) Cayma hakkı 227
bb) Sözleşme süresinin dolması 227
cc) Alıcının temerrüdü halinde satıcının sözleşmeden dönmesi 228
IV. Açık arttırma yoluyla Satış 228

1. Tanımı ve çeşitleri 228
a) Tanım 228
b) Çeşitleri 228
aa) Cebrî artırma 228
bb) İsteğe bağlı artırmalar 228
aaa) İsteğe bağlı özel artırma 229
bbb) İsteğe bağlı açık artırma 229
2. Sözleşmenin kurulması 229
3. Hükümleri 229
a) Arttırmaya katılanın bağlandığı an 229
aa) Genel olarak 229
bb) Taşınmazların açık arttırma yoluyla satışında 230
b) İhale bedelinin ödenmesi 230
c) Mülkiyetin geçişi 230
d) Zapttan ve ayıptan sorumluluk 230
e) İhalenin iptali 231
V. İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri ile mesafeli sözleşmeler 231
1. İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri 231
2. Mesafeli sözleşmeler 233

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

§ 14. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ, UNSURLARI VE ŞEKLİ 235
I. Tanımı ve niteliği 235
II. Unsurları 235
1. Bağışlama sözleşmesi 236
a) Kurulması 236
b) Tarafların ehliyeti 236
aa) Bağışlayanın fiil ehliyeti 236
bb) Bağışlananın ehliyeti 237
2. Sağlararası bir kazandırma 238
3. İvazsızlık (karşı edimin bulunmaması) 240
III. Şekli 240
1. Elden Bağışlama 240
2. Bağışlama taahhüdü 241

§ 15. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ 243
I. Koşullu bağışlama 243
II. Mükellefiyetli (Yüklemeli) bağışlama 243
III. Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama 245
IV. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 247

§ 16. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ 249
I. Bağışlayanın borçları 249
1. Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu 249
2. Kötü ifa halinde sorumluluk 249
3. Zapttan ve ayıptan doğan sorumluluk 250
II. Bağışlamanın geri alınması 250
1. Genel olarak 250
2. Yerine getirilmiş bağışlamanın geri alınması 250
3. Bağışlama taahhüdünün geri alınması ve ifadan kaçınma 251
4. Geri alma hakkının kullanılma süresi ve mirasçılara geçmesi 251
5. Bağışlama taahhüdünün kendiliğinden sona ermesi 252

İKİNCİ KISIM
KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM
ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİ

§ 17. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN
ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SİSTEMİ 253

§ 18. ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI 256
I. Tanımı 256
II. Hukuki niteliği 256
III. Unsurları 257
1. Tarafların anlaşması 257
2. Bir şeyin kullanılmasının devri 257
a) Kira konusu bir şey 257
b) Kiralananın kullanılmasının devri 258
3. Kira parası 258

§ 19. KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE SÜRESİ 261
I. Kira sözleşmesinin tarafları 261

1. Kiralayan 261
2. Kiracı 262
II. Kira sözleşmesinin şekli 264
III. Kira sözleşmesinin süresi 264
1. Genel hükümlere tâbi kiralarda 264
a) Belirli süreli kira sözleşmesi 264
b) Belirsiz süreli kira sözleşmesi 266
2. Konut ve çatılı işyeri kiralarında 266
IV. Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı ve kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler 267
1. Genel olarak 267
2. Konut kavramı 268
3. Çatılı işyeri kavramı 268
4. Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler 268

§ 20. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 271
I. Kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına elverişli şekilde teslim ve bu halde bulundurma borcu 271
1. Teslim borcu 271
2. Kiralananı sözleşme süresince öngörülen kullanma amacına uygun halde bulundurma borcu 272
II. Ayıptan doğan sorumluluk 272
1. Esasa ilişkin şartlar 273
a) Kiralanan ayıplı olmalıdır 273
b) Kiracı ayıbı bilmemelidir 274
c) Kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir sözleşme kaydı bulunmamalıdır 275
2. Kiracının ayıptan doğan hakları kullanmasına ilişkin (şeklî) şartlar 276
3. Kiraya Verenin Ayıptan Doğan Sorumluğunun Hükümleri 276
a) Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 277
b) Kiralananın teslimden sonraki ayıplarından sorumluluk 279
aa) Ayıbın giderilmesini (tamirini) isteme hakkı 279
aaa) Kiracının kiraya veren hesabına ayıbı giderme (tamir) hakkı 281
bbb) Kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi 282
bb) Fesih hakkı 283

cc) Kira bedelinin indirilmesi 284
dd) Tazminat talebi 285
III. Kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumlu olması 285
1. Kiraya verenin zapttan sorumluluğu 285
2. Kiralananın kira sözleşmesinin kurulmasından ve kiracıya tesliminden sonra temliki 286
a) Genel olarak 286
b) Kira sözleşmesinin devrinin sonuçları 287
aa) Kiracı ile üçüncü kişi/ yeni malik arasındaki ilişki 287
bb) Kiracı ile eski malik/ kiraya veren arasındaki ilişki 288
c) Kiralananın kamulaştırılması 288
3. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması 289
4. Tapu siciline şerh 289
IV. Vergi ve yan giderlere katılma borcu 290
1. Vergileri ödeme borcu 290
2. Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu 290

§ 21. KİRACININ BORÇLARI 291
I. Kiralananın kullanılmasına ilişkin borçları 291
1. Kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu 291
2. Komşulara saygı gösterme borcu 293
3. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 295
4. Kiracının ayıpları kiraya verene bildirme borcu 295
5. Kiracının ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 295
6. Kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanım giderlerini ödeme borcu 295
7. Kiracının yukarıda açıklanan borçlarını yerine getirmemesinin sonuçları 295
II. Kira bedelini ödeme borcu 296
1. İfa zamanı ve yeri 297
2. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin tesbiti 298
a) Kira bedelinin tesbitinde izlenecek esaslar 298
b) Tesbit davası açma süresi ve verilecek kararın etkisi 300
3. Kira sözleşmesinin uyarlanması 300
4. Kiralananın kullanılmaması sebebiyle kira bedelinin ödenmesi 312

a) Kullanmanın mümkün olmaması halinde kira bedelinin ödenmesi 312
b) Kiralananın sözleşmenin sona ermesinden önce geri verilmesi 312
5. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kiracının güvence vermesi 312
6. Takas hakkından önceden feragat yasağı 313
7. Kira parasının ödenmemesinin teminatı: kiraya verenin hapis hakkı 313
a) Hapis hakkının konusu 313
b) Hapis hakkının temin ettiği alacaklar 314
c) Kullanılması 314
8. Kiralananı geri verme borcu 315
a) Genel Olarak 315
b) Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları kiracıya bildirme borcu 315
III. Alt kira, kullanım hakkının devri ve kira ilişkisinin devri 316
1. Alt kira ve kullanım hakkının devri 316
2. Kira ilişkisinin devri 317
a) Genel olarak 317
b) Şartları 317
c) Sonuçları 318
§ 22. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 319
I. Borçlar Kanunu'nun kiraya ilişkin genel hükümlerine (TBK m. 299- 338) göre sona erme sebepleri 319
1. Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması 319
2. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi (TBK m. 328- 330) 320
a) Genel olarak 320
b) Fesih bildiriminin şartları 320
aa) Maddi şartlar 320
bb) Fesih dönemlerine ve bildirim sürelerine uyulması 321
c) Şekli 322
3. Kiraya verenin kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcunun ihlal etmesi sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi 322

4. Kiracının temerrüdü 322
a) Genel olarak 323
b) Şartları 323
c) Sonuçları 324
5. Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshi 324
6. Kiracının iflası 326
7. Kiracının ölümü 326
II. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi 326
1. Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine göre sona erme 326
2. Kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona ermesi 327
a) Belirli süreli kira sözleşmelerinde 327
b) Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde 327
c) Şekli 327
d) Aile konutunda 327
e) Kiracının ölümünde sözleşmenin devamı 328
3. Tahliye davası açma yoluyla 328
a) Tahliye davası açma sebeplerinin sınırlılığı 328
b) Tahliye davası süresinin uzaması 328
c) Yeniden kiralama yasağı 328
4. Tahliye sebepleri 329
a) Kiraya verenin konut veya işyeri ihtiyacı (gereksinimi) sebebiyle tahliye davası açması 329
aa) Kiraya verenin kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kiralananı konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacının olması 329
bb) Kiralananın konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacının gerçek olması 331
cc) Dava açma süresi 331
dd) Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle dava açması 332
b) Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi 332
aa) Kiralananın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya imar amacıyla esaslı surette onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi 332
bb) Yapılacak onarım, genişletme veya değişiklik işleri esnasında binanın içinde oturmanın veya çalışmanın mümkün olmaması 333

cc) İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve imar mevzuatına göre mahalline uygulanmasının mümkün olması 333
dd) Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılması 333
c) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü 333
aa) Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve tahliyenin hangi tarihte yapılacağını göstermelidir 334
bb) Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesi kurulduktan sonra verilmelidir 334
cc) Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından yapılmalıdır ..334
dd) Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talep edilmelidir 335
d) İki haklı ihtar sebebiyle tahliye 335
aa) Kira bedelini ödememeden dolayı kiracıya haklı ihtar yapılmış olması 335
bb) İhtarın yazılı olması ve ödenmeyen kira miktarları ile bunların ait olduğu vadenin gösterilmesi 336
cc) Bir kira yılı içinde iki haklı ihtarın yapılmış olması 336
dd) Kira süresinin sona ermesini takip eden bir ay içinde tahliye davası açılması 336
e) Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması (TBK m. 352/ III) 336
aa) Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin maliki bulunduğu bir konutun bulunması 336
bb) Konutun aynı şehir veya belediye sınırları içinde olması 337
cc) Konutun kiracının kullanmasına elverişli olması gerekir 338
dd) Kiraya verenin kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli bir konutu bulunduğunu bilmemesi 338
ee) Kira süresinin sona ermesini takip eden bir ay içinde tahliye davası açılması 338

İKİNCİ BÖLÜM
ÖDÜNÇ VERME SÖZLEŞMELERİ

§ 23. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ 339

I. Tanımı, hukuki niteliği ve unsurları 339
1. Tanımı 339
2. Hukukî niteliği 339
3. Unsurları 339
a) Bir şeyin (veya hakkın) kullanılmasının devri 339
b) Kullanmanın devrinin karşılıksız olması 340
II. Tarafların Borçları 341
1. Ödünç verenin borçları 341
a) Kullanım ödüncü konusu şeyi teslim borcu 341
b) Kullanım ödüncü alanın yaptığı olağanüstü masrafları ödeme borcu 341
2. Kullanım ödüncü alanın borçları 342
a) Kullanım ödüncü verilen şeyi sözleşmeye uygun olarak kullanma borcu 342
b) Kullanım ödüncü verilen şeyin olağan masraflarına katlanma borcu 342
c) Geri verme borcu 343
III. Sona ermesi 343
1. Sözleşmeyle öngörülen sürenin dolması 343
2. Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih beyanı 344
3. Kullanım ödüncü alanın sözleşmeyi ihlâl etmesi 344
4. Kullanım ödüncü verenin âcil veya öngörülmeyen ihtiyacı 344
5. Kullanım ödüncü alanın ölümü 344

§ 24. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ 345
I. Tanımı ve hukukî niteliği 345
1. Tanımı 345
2. Hukukî niteliği 345
II. Unsurları 346
1. Ödünç verilebilecek bir miktar para veya bir mislî şey 346
2. Ödünç konusunun mülkiyetinin ödünç alana geçirilmesi taahhüdü 346
3. Ödünç alanın aynı miktar ve nitelikte aynı cinsten şeyleri verme taahhüdü 346
4. Faiz ödeme borcu 347
a) Genel olarak 347
b) Faizin miktarı 347

aa) Âdi tüketim ödüncünde faiz oranı 347
bb) Ticari tüketim ödüncünde faiz oranı 347
cc) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tâbi tüketim ödüncü sözleşmelerinde 348
c) Faize faiz yürütülmesi (mürekkep faiz) 349
III. Tüketim ödüncü sözleşmesinin benzeri işlemlerden ayırdedilmesi 349
1. Usulsüz tevdi ve tüketim ödüncü 349
2. Banka tasarruf hesabı ve tüketim ödüncü 350
3. Kredi açma sözleşmesi ve tüketim ödüncü 351
4. Kara katılmalı ödünç ve tüketim ödüncü 352
IV. Tüketim ödüncü sözleşmesinde tarafların borçları 352
1. Ödünç verenin borçları 352
a) Ödünç konusunun mülkiyetini geçirme ve teslim borcu 352
aa) Zamanaşımı Süresi 353
bb) Ödünç alanın borç ödemekten aczi halinde ödünç verenin korunması 354
b) Ödünç verenin ayıba ve zapta karşı tekeffül borcu 354
c) TKHK m. 4/3'e göre Tüketici Kredileri 354
2. Ödünç alanın borçları 355
a) Ödünç konusunu şeyi kabul borcu 355
b) Ödünç konusunu iade borcu 355
c) Faiz ödeme borcu 356
V. Tüketim ödüncü sözleşmesinin sona ermesi 357
1. Sürenin sona ermesi 357
2. Fesih bildirimi 357
3. Ödünç alanın vadeden önce ödemede bulunması 358

ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ

§ 25. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI 359
I. Tanımı 359
II. Hukukî niteliği ve özellikleri 359

1. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir...359
2. Eser sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir...360
3. Eser sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi doğurmaz...360
III. Unsurları...361
1. Bir eser meydana getirme...361
a) Eser kavramı...361
b) Meydana getirme kavramı...365
aa) Yeni bir eser meydana getirme...365
bb) Mevcut bir eser üzerinde gerçekleşen çalışma sonuçları...365
cc) İnsan vücudu üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçları...366
2. Bedel ödeme borcu...366
3. Taraflar arasında anlaşma...366
a) Genel olarak...366
b) Sözleşmenin şekli...367

§ 26. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI...369
I. Eser meydana getirme borcu...369
1. Genel olarak...369
2. Eseri şahsen meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma borcu...369
a) Kural...369
b) Yüklenicinin eseri başkasına (alt yükleniciye) yaptırma yetkisi...371
aa) Yüklenicinin işi başkasına yaptırma yetkisi ve alt yüklenici kavramı...371
bb) Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki...373
cc) Asıl işsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki...373
dd) İlk yüklenicinin, alt yüklenicinin davranışlarından dolayı, asıl işsahibine karşı sorumluluğu...374
2. Eserin meydana getirilmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlama borcu...375
3. Malzemelerin sağlanması borcu...377
a) Genel olarak...377
b) Malzemelerin yüklenici tarafından sağlanması...378
c) Malzemelerin işsahibi tarafından sağlanması...379
aa) Malzemeleri özenle kullanma, hesap verme ve artan kısımları iade borcu...380

bb) İhbar yükümü (BK m. 472/III) 380
4. Yüklenicinin özen ve sadakat borcu 380
a) Genel olarak 380
b) Yüklenicinin göstermek zorunda olduğu başlıca özen yükümleri 382
c) Özen yükümünün ihlalinin sonuçları 383
aa) Genel olarak 383
bb) TBK m. 473/II'de öngörülen hukukî imkânların kullanılması, özellikle işin başkasına yaptırılması 384
aaa) Şartları 384
bbb) Sonuçları 386
5. İşe zamanında başlama ve devam borcu 390
a) Dönme hakkının şartları 391
aa) İşe zamanında başlamama 391
bb) İşin icrasının sözleşmeye aykırı olarak geciktirilmesi 391
cc) Gecikmenin eserin kararlaştırılan tarihte tamamlanmasına engel olacak derecede olması 391
dd) Yüklenicinin gecikmesini haklı kılan bir sebebin bulunmaması 391
b) Dönmenin sonuçları 392
II. Eseri teslim borcu 393
1. Genel olarak 393
2. Teslim borcunun ifa zamanı 394
3. Mülkiyetin işsahibine geçirilmesi 395
4. Teslim borcunu ifada temerrüt ve bunun sonuçları 395
a) Teslim borcunu ifada temerrüdün şartları 395
b) Teslim borcunu ifada temerrüdün sonuçları 396
aa) Genel olarak 396
bb) Aynen ifadan vazgeçip müsbet zararın tazmini 396
cc) Sözleşmeden dönme 396
c) İfa zamanına uyulmaması halinde cezaî şart ödenmesinin kararlaştırılması 398
III. Yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu 400
1. Ayıptan doğan sorumluluğun şartları 400
a) Ayıplı bir eser teslim edilmiş olmalıdır 400
b) Ayıp işsahibine yüklenmemelidir 400

aa) Genel olarak 400
bb) Şartları 401
aaa) Eserdeki ayıp işsahibinin talimatından veya ona isnadı kabil bir sebepten ileri gelmelidir 401
bbb) Yüklenici uyarma ve aydınlatma yükümünü yerine getirmiş olmalıdır 402
ccc) Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı veya ona isnad edilebilen sebep arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır 402
c) İş sahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır 403
d) İş sahibi gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getirmiş olmalıdır 403
aa) Gözden geçirme (muayene) külfeti 403
bb) Ayıbı bildirme külfeti 404
2. Ayıptan doğan haklar 406
a) Genel olarak 406
b) Sözleşmeden dönme hakkı 406
aa) Özel şartlar 406
bb) Dönmenin sonuçları 407
c) Bedelin indirilmesi hakkı 408
d) Eserin bedelsiz onarılmasını talep hakkı 409
e) Tazminat talep etme hakkı 411
3. Ayıptan doğan hakların tabi olduğu zamanaşımı 412
4. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'la Getirilen Özel Sorumluluk 412
§ 27. ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 414
I. Genel olarak 414
II. Bedel ödeme borcu 414
1. Genel olarak 414
2. Götürü (sabit) bedel 415
a) Kavram 415
b) Çeşitleri 415
aa) Toptan götürü (Sabit) bedel (Pauschalpreis) 415
bb) Sabit birim fiatlarla belirlenen bedel (Einheitspreis) 416
c) Götürü (sabit) bedelli sözleşmelerde olağanüstü haller dolayısıyla sözleşmenin uyarlanması 416

aa) Genel olarak 416
bb) Şartları 417
aaa) Önceden tahmin edilemeyen veya öngörülüp de iki tarafın gerçekleşmeyeceğini kabul ettikleri olağanüstü hallerin ortaya çıkmış olması 417
bbb) Ortaya çıkan olağanüstü hallerin eserin tesbit edilen sabit (götürü) bedelle tamamlanmasını engellemesi veya aşırı derecede güçleştirmesi 418
ccc) Olağanüstü hallerin ortaya çıkması yükleniciye isnad edilmemelidir 418
ddd) Taraflar fesih veya bedelin artırılması yoluna başvurulmayacağını kararlaştırmamış olmalıdır 419
cc) Sonuçları 419
3. Değere göre bedel 419
4. Bedelin önceden kararlaştırılmamış olması 420
5. Bedel borcunun ifa zamanı, temerrüt ve sonuçları 422
§ 28. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 423
I. Yaklaşık bedelin (keşif bedeli) aşırı ölçüde aşılması sebebiyle sözleşmeden dönme 423
1. Genel olarak 423
2. Şartları 423
a) Yaklaşık bedel tahmini olarak tesbit edilmiş olmalıdır 423
b) Yaklaşık bedel aşırı ölçüde aşılmış olmalıdır 423
c) Yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmasına işsahibi sebep olmamalıdır 424
3. Sonuçları 424
II. Yüklenicinin zararını tamamen tazmin suretiyle fesih 424
III. Eserin yok olması imkân 427
1. Umulmayan bir olay sebebiyle eserin yok olması 427
a) Genel olarak 427
b) Şartları 427
aa) Eser kısmen veya tamamen yok olmalıdır 427
bb) Eser umulmayan bir olay sonunda yok olmalıdır 427
cc) Eser teslim edilmemiş olmalıdır 427

dd) İş sahibi mütemerrit olmamalıdır 428
c) Sonuçları 428
2. İş sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması 429
a) Şartları 430
aa) Eserin tamamlanması imkânsız olmalıdır 430
bb) İmkânsızlık işsahibinin şahsında veya tehlike alanında gerçekleşen umulmayan bir halden doğmalıdır 430
b) Sonuçları 431
aa) Sözleşmenin ileriye etkili olarak sona ermesi 431
bb) Yüklenicinin ileri sürebileceği talepler 431
3. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 432
a) Genel olarak 432
b) Şartları 432
aa) Eser sözleşmesi yüklenicinin kişisel özellikleri gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır 432
bb) İşin bitirilmesi yüklenicinin ölümü veya kusuru olmaksızın işi yapmaktan aciz kalması dolayısıyla mümkün olmamalıdır 432
c) Sonuçları 433

İKİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

§ 29. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, KURULMASI VE KAPSAMI 434
I. Tanımı ve özellikleri 434
1. Tanımı 434
2. Özellikleri 435
II. Unsurları 435
1. Bir işin görülmesi veya işlemin yapılması 435
2. İşin başkasının menfaatine yapılması 437
3. Vekilin edim sonucundan değil, edim fiilinden sorumlu olması ve bağımsız olarak iş görmesi 438
4. Ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığında iş görme 438
III. Vekâlete ilişkin hükümlerin tâli olarak uygulanması 439
IV. Vekâlet ve temsil yetkisi 441
V. Kurulması 441
VI. Vekâletin kapsamı 444

1. Vekâletin kapsamının belirlenmesi 444
2. Hukukî fiillere ilişkin vekâletin kapsamı ve temsil yetkisi 445
3. Özel temsil yetkisini gerektiren haller 446

§ 30. VEKİLİN BORÇLARI 447
I. Sadakat ve özen borcu 447
1. Sadakat borcu 447
2. Özen borcu 448
II. İşi şahsen ifa borcu 450
1. Genel olarak 450
2. Vekilin yerine başkasını koymasının çeşitleri 451
a) Alt vekâlet 451
b) İkame vekâlet (Ersatzauftrag) 451
3. İşin görülmesinin başkasına gördürülmesinde vekilin sorumluluğu 452
III. Vekâlet verenin talimatına uygun olarak hareket yükümü 453
1. Vekâlet verenin talimat hakkının niteliği ve kapsamı 453
2. Talimata uymamanın sonuçları 454
IV. Hesap verme borcu 455
V. İade borcu 455
1. Genel olarak 455
2. Hakların devri 456
a) TBK m. 509'un uygulanma şartları 456
b) Sonuçları 456

§ 31. MÜVEKKİLİN BORÇLARI 458
I. Ücret ödeme borcu 458
II. Vekil tarafından yapılan masrafları ve verilen avansları ödeme borcu 458
III. Vekili vekâlet veren hesabına yüklendiği borçtan kurtarma yükümü 459
IV. Vekilin uğradığı zararı tazmin borcu 459

§ 32. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 461
I. Tek taraflı sona erdirme Azil ve istifa 461
1. Hukukî niteliği ve kullanılması 461
2. TBK m. 512/c. 1 hükmünün emredici nitelikte olup olmadığı 461

3. Sonuçları 462
II. Vekâlet sözleşmesinin taraflardan birinin ölümü, ehliyetsizliği veya iflâsı sebebiyle sona ermesi 463

DÖRDÜNCÜ KISIM
ŞAHSÎ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KEFALET SÖZLEŞMESİ

§ 33. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI 465
I. Tanımı 465
II. Hukukî niteliği 466
1. Kefilin borcu fer'i (bağımlı) borçtur 466
a) Genel olarak 466
b) Fer'iliğin sonuçları 466
c) İstisnaları 468
2. Kefilin borcu tâli (ikinci derecede) borçtur 468
3. Kefaletin ivazsızlığı 469
III. Benzer sözleşmelerden farkları 469
1. Garanti sözleşmesinden farkı 469
2. Müteselsil borçluluk ve borca katılmadan farkları 471
3. Avalden farkları 472
4. Kefalete ilişkin bazı hükümlerin kişisel güvence sağlayan diğer işlemlere uygulanması 472

§ 34. KEFALETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 474
I. Geçerli bir asıl borcun bulunması 474
1. Genel olarak 474
2. İptal edilebilir bir borca kefalet 475
3. Bu haklardan önceden feragat 476
II. Kefalette şekil 477
III. Eşin rızası 478

§ 35. KEFALETİN ÇEŞİTLERİ 480
I. Âdi kefalet 480
1. Genel olarak 480
2. Tartışma def'i 480

a) Asıl borçlunun iflas etmesi veya borçluya konkardato mehli verilmiş olması 481
b) Borçlu hakkındaki takibin semeresiz kalması 482
c) Asıl borçlu hakkında Türkiye'de takibin imkânsız olması veya önemli ölçüde güçleşmesi 482
3. Rehnin paraya çevrilmesi def'i 482
II. Müteselsil kefalet 483
III. Toplu Kefalet (cautionnement plural; pluralite des cautions) 485
1. Bağımsız kefalet (Nebenbürgschaft; cautionnement indépendant) 485
2. Kısmi kefalet (Teilbürgschaf) 485
3. Birlikte kefalet (Mitbürgschaft; cautionnement conjoint) 485
a) Adi birlikte kefalet 486
b) Müteselsil birlikte kefalet 487
4. Kefile kefalet 488
IV. Rücua ve açığa (zarara) kefalet 488
1. Rücua kefalet 488
2. Açığa (zarara) kefalet 488

§ 36. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 489
I. Kefilin sorumlu olduğu azami tutar 489
II. Kefilin sorumlu olduğu alacaklar 489
1. Asıl borç 490
2. Asıl borçlunun kusur veya temerrüdünün kanuni sonuçları 490
3. Dava ve takip masrafları 490
4. Akdî faizler 491

§ 37. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ 493
I. Kefilin alacaklıya karşı savunma imkânları (def'iler) 493
1. Genel olarak 493
2. Asıl borç ilişkisine ait savunma imkânları 493
a) Asıl borcun doğumuna ilişkin olanlar 494
b) Asıl borcun kapsamı ve hükümlerine ilişkin olanlar 494
c) Asıl borcun sona ermesine ilişkin olanlar 494
3. Kefalet sözleşmesine ait savunma imkânları 496
II. Alacaklının yükümleri ve külfetleri 496

1. Borçlunun anaparayı veya faizi ödememesi ya da iflası halinde masaya başvurma ve kefile ihbar yükümü 496
2. Ödemeyi kabul külfeti 497
3. Teminatları ve isbat vasıtalarını saklama ve kefile nakil ve tevdi yükümü 498

§ 38. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ 499
I. Kefilin ödemeyi ihbar yükümü 499
II. Kefilin asıl borçludan teminat verilmesini veya borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 499
III. Kefilin rücu hakkı 500
1. Genel olarak 500
2. Şartları 501
a) Geçerli bir kefalet sözleşmesi bulunmalıdır 501
b) Kefil alacaklıya olan borcunu ifa etmelidir 502
c) Asıl borç muaccel olmalıdır 502

§ 39. KEFALETİN SONA ERMESİ 503
I. Asıl borca bağlı sona erme sebepleri 503
1. Genel olarak 503
2. Tecdit (borcun yenilenmesi) 503
3. Dış borç üstlenme 504
II. Kefalet sözleşmesine özgü sona erme sebepleri 504
1. Belirli süreli kefaletin sona ermesi 504
2. Süresiz kefaletin sona ermesi 504
3. Gerçek kişinin verdiği kefaletin on yıl sonra sona ermesi 504
4. Kefaletten dönme 505
5. Çalışanlara kefalet verilmesi halinde özel sona erme hali 505
6. Alacaklının ödemeyi kabulden kaçınması 505
7. Kefalete ilişkin hükümlerin uygulama alanı 505

KISALTMALAR

ABD	: Ankara Barosu Dergisi
AJP	: Aktuelle Juristische Praxis
Art.	: Artikel
Aufl.	: Auflage
Bd.	: Band
BGB	: deutsches Bürgerliches Gesetzbuch
BGE	: EntscheindungenEntscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BİGŞ	: Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
Bk	: Bakınız
BK	: Borçlar Kanunu
BlZR	: Blaetter für zürchericshe Rechtsprechung
CCF	: Code civil français
CISG	: Milletlerarası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması
CO	: Code des Obligations
dn.	: dipnot
E.	: Esas.
eBK	: 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu
Erw.	: Erwaegung
f.	: Fıkra
FG	: Festgabe
FJS	: Fiches juridiques suisses
FS	: Festschrift
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
HUMK	: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İİK	: İcra ve İflâs Kanunu
JdT	: Journal des Tribunaux
K.	: Karar
Karş.	: Karşılaştırınız
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname

m.	: Madde
OR	: Obligationenrecht
recht	: Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis
S.	: Sayı
Sem.Jud.	: Semaine Judiciaire
sh.	: Sayfa
SJZ	: Schweizerische Juristen-Zeitung
SPR	: Schweizerisches Privatrecht
TBK	: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TK	: 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu
TKHK	: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
vd.	: Ve devamı
Yarg.	: Yargıtay
Yasa	: Yasa Hukuk Dergisi
YİGŞ	: Yapım İşleri Genel Şartnamesi
YKD	: Yargıtay Kararları Dergisi
ZBJV	: Zeitschrift des bernischen Juristenverein
ZSR	: Zeitschrift für Schweizerisches Recht.

BİBLİYOGRAFYA

Akıntürk, T : Satış Aktinde Hasarın İntikali, Ankara 1966.

Altaş, H. : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998.

Ansay, T : Türk Borçlar Kanununa göre taksitle satışlar, Ankara 1954.

Aral, F. : Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994.

Aral, F : Kötü İfa, Ankara 1985.

Arkan, S. : Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 1997.

Ayrancı, H. : Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Kefalet Sözleşmesinde İfanın Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.53, S.2, Y. 2004, sh. 95 vd. (Ayrancı, Şekil Şartı).

Ayrancı, H. : Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi ve Cari Hesaba Kefalet, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX. S. 1-2, Y. 2005, sh. 107 vd. (Ayrancı, Cari Hesaba Kefalet).

Ayrancı, H. : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003 (Ayrancı, Sözleşmenin Devri).

Ayrancı, H. : Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010 (Ayrancı, Enerji Sözleşmeleri).

Ayrancı, H. : Ön Sözleşme, Ankara 2006 (Ayrancı, Ön Sözleşme).

Baehler, K. : Das Verhälnis von Sachgewährleistungs und allgemeinen Leistungsrecht, Basel 2005.

Baudenbacher/Spiegel : Die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts zum Verhaeltnis von Sachmaengelgewaehrleistung und allgemeinen Rechtsbehelfen des Käufers, FS Pedrazzini, Bern 1990, sh. 229 vd.

Beck, E. : Das neue Bürgschaftsrecht, Zürich 1942.

Becker, H. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV; Obligationenrecht II. Abt., Art. 184-551 OR, Bern 1934.

Bilge, N. : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

Bischoff, : Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zürich 1983.

Bucher, E. : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2.Aufl., Zürich 1988.

Bucher, E. : Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 1988.

Burcuoğlu, H. : Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasaya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993.

Burcuoğlu, H. : Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İstanbul 1995.

Buz, V. : Eser sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması, İ. Öztrak'a Armağan, Ankara 1994, sh. 23 vd.

Buz, V. : Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Bühler, T. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Obligationenrecht, Der Werkvertrag, Art. 363-379, Zürich 1998.

Cavin, P. : Traité de droit privé suisse, T. VII/I, Vente, échange et donation, Fribourg 1978.

Cerutti, R. : Der Untervertrag, Freiburg 1990.

Chaix, F. : Le contrat de sous-traitânce en droit suisse, Basel/Frankfurt 1995.

Chavanne, S : Le retard dans l'execution des travaux de construction, Basel/Frankfurt 1993.

Corboz, B. : Les défauts de la chose louée, Sem Jud. 1979, sh. 129 vd.

Çenberci, M. : Gayrimenkul Satış Vaadi, Ankara 1996.

Dalamanlı, L. : Gayrimenkul Satış Vaadi, 1986.

Derendinger, P. : Die Nicht-und die nichtrichtige Erfüllüng des Einfachen Auftrags, Freiburg 1990.

Dessemontet, F. : Les contrats de service, ZSR 106/1987 II, sh. 95 vd.

Dohm, J. : Les garanties bancaires dans le commerce international, Bern 1986.

Dürr, C. : Werkvertrag und Auftrag, Vıra 1983.

Engel, P. : Contrats de droit suisse, Bern 2000.

Eren, F. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2006.

Eren, F. : İnşaat sözleşmeleri, Ankara 1996, sh. 45 vd.

Erkan, V. U. : Türk Medeni Kanunu'nda Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması, İÜHFD, c. 5, s. 1, 2014 (269-294)

Ertaş, Ş. : Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Esener/Güven : Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Faust, F. : Zinsen bei Zahlungsverzug, Rabelsz, Bd. 68 (2004), s. 518 vd.

Fellmann, W. : Kommentar zum Schweizerischen Privat recht, Bd. IV, Der einfache Auftrag, Bern 1992.

Fischer,W. : Der Unmittelbare und der mittelbare Schaden im Kaufrecht, Zürich 1985.

Furrer, R. : Beitrag zur Lehre der Gewaehrleistung im Vertragsrecht, Zürich 1973.

Gauch, P. : Der Werkvertrag, Zürich 1996.

Gauch, P. : Der Rücktritt des Bestellers von Werkvertrag, Festschrift H. Locher, Düsseldorf 1990, sh. 35 vd.

Gauch/Schluep : Schweizerisches Obligationenrecht Bd. I-II Zürich 2003.

Gautschi, G. : Berner Kommentar, Bd.IV, Das Obligaitionenrecht, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR Bern 1967; Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, Bern 1971.

Giger, H. : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, Z. Abt., 1. Teibd. Kauf und Tausch-Die Schenkung, 1. Abschnitt, Allgemeine Bestim-

mungen-Der Fahrniskauf, Art. 184-215 OR, Bern 1979.

Ginter, Petra : Verhaeltnis der sachgewaehrleistung nach Art. 197 ff. OR zu den Rechtsbehelfen in Art. 97 ff. OR, Zurich 2005.

Giovanoli, S. : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, 2. Abt., Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 7. Teilband, Art. 492-529 OR, Bern 1978.

Grassinger, G.E. : Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkânları, İstanbul 1996.

Guggenheim, D. : Les contrats de la pratique bancaire suisse, Genève 2000.

Guhl/Koller/Schnyder/
Druey : Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000.

Hofstetter, J. : Der Auftrag und die Geschaeftsführung ohne Auftrag, SPR VII/2, Basel und Stuttgart 1979.

Honsell, H. : Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 6. Aufl., Bern 2001.

Honsel/Vogt/Wiegand
(Herg) : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, art. 1-529 OR, Basel und Frankfurt, 2. Aufl., 1997 (OR-Yazar adı).

İnceoğlu, M. : Taksitle Satışlarda Tüketicinin Korunması İstanbul 1998.

Jaeger, T. : Die Haftung des Verkäufer für die Mangel, Zürich 1911.

Karahasan, M.R. : İnşaat, İmar, İhale Hukuku C.I-II-III. İstanbul 1997.

Karahasan, M.R. : Türk Borçlar Hukuku, C.1-6, İstanbul 1992

Katz, H.P. : Sachmaengel beim Kauf von Kunstgegenstaenden und Antiquitaeten, Zürich 1973.

Keller/Fischer : Mechanismus der Gefaehrtragung des Käufers, in: Mélanges Paul Piotet, Bern 1990, sh. 137-150.

Keller/Schobi : Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. I, Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts,3. Aufl., Basel/Frankfurt am Main 1988.

Keller/Siehr : Kaufrecht, 3. Aufl., Zurich 1995.

Klauser, P. : Die Werkvertragliche Maengelhaftung und ihr Verhaeltnis zu den allgemeinen Nichterfüllung, Zürich 1973

Kleiner, B : Bankgrantie, 4. Aufl., Zürich 1990.

Knoepfler/Guinand, : Mandat FJS 1984.

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Borçlar Hukuku, 3.Bası, İstanbul (Baskısı devam ediyor).

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, Doktora Tezi, İstanbul 1959.

Koller, A. : Die Haftung für den Erfüllungsgehilfen, Zürich 1980.

Koller, Jo. : Der Untergang des Werkes nach Art. 376 OR, Winterthur 1983.

Kramer, M. : Berner Kommentar, Bd. VI, Obligationenrecht, Art. 1-18 OR, Bern 1966; Art. 19-20 OR, Bern 1991.

Kuntalp, E. : Ard Arda Teslimli Satış Akdi, Ankara 1968.

Larenz, K. : Lehrbuch des Schuldrechts, Bd.I Allgemeiner Teil, 12. Aufl., München 1979; Bd. II, Besonderer Teil, 11 Aufl., München 1976.

Larenz/Wolf : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8.Auflage, München 1997 (Larenz/Wolf (1997): 9. Auflage, Münschen 2004 (Larenz/Wolf (2004).

Lemp, P. : Schadenersatz Wegen Nichterfüllung als Folge des Schuldnerverzuges, Bern 1939.

Lenzingen-Gadient, A. : Mangel und Sicherungsrechte des Bauhern im Werkvertrag, Zürich 1994.

Lerch/Tuason : Die Bürgschaft im Schweizerischen Recht, Zürich 1996.

Leuenberger, C. : Dienstleistungsvertraege, ZSR 1987 II, sh. 1 vd.

Lüthi, R.	:	Die Rechtsnatur und Stellung der Sachgewaehrleistungspflicht, Bern 1955.
Meier-Hayaz, A.	:	Gesetzlich nicht geregelte Vertraege, SJK N. 1134-1135.
Merz, H.	:	Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, SPR VI/I, Basel 1984.
Merz, H.	:	Vertrag und Vertragsschluss 2. Aufl., Freiburg 1992.
Münchener Kommentar	:	Münchener Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, Schuldrecht, Rebmann/ Säcker (Hrsg.), München 1993 ve sonraki yıllar
Neuenschwander, M.	:	Die Schlechterfullüng, Bern 1971.
Niklaus, J.	:	Das Recht auf Ersatzvornahme gemaess Art. 366 Abs.ZOR Bern 1999.
Oğuzman/Seliçi/Oktay	:	Eşya Hukuku, İstanbul 2006.
Oser/Schönenberger	:	Zürcher Kommentar, Bd. V, Obligationenrecht, Teil 1-3, Zürich 1929, 1936 ve 1946.
Pedrazzini, M.	:	Le contrat d'entreprise, Fribourg 1985.
Peyer, J.	:	Der Widerruf im Schweizerishen Auftragsrecht, Zürich 1974.
Reisoğlu, S.	:	Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992.
Reymond, C.	:	Le bail à loyer, Fribourg 1978.
Schenker, F.	:	Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzuges, Freiburg 1988.
Scherrer, E.	:	Nebenunternehmer beim Bauen, Freiburg 1993.
Schluep, W.	:	Innominatvertraege, SPR VII/2, Basel/ Stuttgart 1979.
Schmid, E.	:	Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Art. 253-274 OR, Zürich 1970.
Schönle, H.	:	Zürcher Kommentar, Bd. V, Obligationenrech, Teilband V/2a, Kauf und Schenkung (Art. 184-191), Zürich 1993.

Schubiger, A.	: Verhältnis der Sachgewahrleistung zu den Folgen der Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung, Bern 1957.
Scyboz, G.	: Le contrat de garantie et le coutionnement, Fribourg 1979.
Seliçi, Ö.	: İnşaat sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978.
Serozan, R.	: Sözleşmeden dönme, İstanbul 1975.
Serozan/Arpacı/Hatemi	: Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, İstanbul 1992.
Soergel, H. T.	: Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 12.Aufl., Stuttgart Berlin Köln Mainz 1987 ve sonrası (SOERGEL/..).
Spirig, Eugen	: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme, erste Lieferung, Art.164-174 OR, Zürich 1993.
Spiro, K.	: Die Begrenzung privater Rechte durch Verjaehrungs und Fatalfristen, Bd.I-II, Bern 1975.
Spiro, K.	: Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984.
Stanislas,G.	: Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genéve 1979.
Stüber, B.	: Der Vorvertrag zur Aktiengesellschaft, Zürich 1973.
Tandoğan, H.	: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri C.I/1, 5.bası İstanbul 1985; C.I/2, Ankara 1985; C.II, Ankara 1987.
Tunaboylu, M.	: Önalım Davaları, Ankara 2008.
Tercier, P.	: La partie spéciale du Code des Obligations, Zürich 1987
Tercier/Favre	: Les contrats spécilux, 4. èdition, Zürich 2009.
Tobler, H.	: der Schutz des Bürgen gegenüber dem Gläubiger, Bern 1926.

Tunaboylu, M. : Kira Akdinin Feshi ve Tahliye Davaları, Ankara 1995.

Uygur, T. : İnşaat Hukuk, C.I-II, Ankara 1998.

Uygur, T. : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, c.4, Ankara 2002,

von Tuhr/Peter : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Bd. I, Zurich 1979.

von Tuhr/Escher : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Bd II, Zürich 1974.

Weber, R. : Praxis zum Auftragsrecht, Bern 1990.

Weber, R. : Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, Art. 68-96 OR, Bern 1983.

Werro, F. : Le mandât et ses effets, Fribourg 1993.

Yavuz, C. : Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 1996.

Zevkliler, A. : Borçlar Hukuk, Özel Borç İlişkileri, Ankara 2004.

Zevkliler, A. : Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004.

GİRİŞ

§ 1. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME TİPLERİ

I. Özel borç ilişkileri

Borçlar Hukuku kişiler arasındaki borçlar hukuku ilişkilerini düzenlemektedir. Bu ilişki haksız fiilden, sözleşmeden veya sebepsiz zenginleşmeden doğabilmektedir. Sayılan sebepler dışında örneğin vekâletsiz iş görme de bir borç kaynağı olarak görülmektedir. Sözleşmeden doğan borç ilişkileri kural olarak Türk Borçlar Kanununda yer almaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiştir. TBK nun 1-206. maddesi Birinci Kısım, Genel Hükümler başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kısım sözleşmenin kurulması ile başlamakta sözleşmeye katılma ile sona ermektedir.

Yeni Borçlar Kanunu'nun 207. maddeyle başlayan ikinci kısmının başlığı, "Özel Borç İlişkileri" şeklinde düzenlenmiştir. Eski Borçlar Kanunu'nun 182. madde ile başlayan ikinci kısmının başlığı "Akdin muhtelif nevileri" şeklindeydi. Bu sebeple yapılan değişikliği olumlu olarak değerlendirmek gerekir. Zira Borçlar Kanunu'nun ikinci kısmında sözleşme niteliği taşımayan "vekâletsiz işgörme (TBK m. 526-531)", "ticari temsilcilik ve ticari vekâlet (TBK m. 547- 554)" ve "havale (TBK m. 555- 560)" gibi hukuki kurumlar da düzenlenmiştir.

Diğer yandan, Borçlar Kanunu dışında da özel borç ilişkileri düzenlenebilmektedir. Örneğin Türk Ticaret Kanununda cari hesap sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, acentelik sözleşmesi gibi borç ilişkileri düzenlenmektedir.

Bir sözleşmenin kanunda düzenlenmemiş olması, bu sözleşmeyi kanunda düzenlenenlere göre zayıf veya ikincil bir duruma düşürmez. Bu durum sadece kanun koyucunun günlük hayatta sık kullanılan sözleşmeleri öncelikle düzenlenmek istemesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında sosyal koruma normları nedeniyle kanun koyucu

bazı sözleşme türlerini düzenlemektedir. Sosyal koruma normları taraflardan birinin kamu düzeni genel ahlak veya zayıfların korunması ilkesine uygun olarak korunması zorunluluğunun bulunduğu halleri ifade etmektedir. Örneğin çatılı konut ve işyerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracının, iş sözleşmelerinde işçinin, tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerde tüketicinin korunması ihtiyacı sözleşmelerin kanun koyucu tarafından düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır[1].

İrade özerkliği kişinin hukuki ilişkilerini hukuk düzeni sınırları içinde serbestçe belirleme hakkı olarak tanımlanmaktadır. İrade serbestisi ekonomik serbesti, dernek kurma hakkı, mülkiyet hakkı, vasiyet yapma özgürlüğü yanında sözleşme serbestisini de içermektedir[2].

II. Borçlar Kanunu'nda özel hüküm-genel hüküm ilişkisi

Borçlar Kanunu'nun 1. maddeyle başlayan birinci kısmının başlığı "Genel Hükümler"dir. Genel Hükümler, Borçlar Kanunu'nun 1-206. maddelerinden ibarettir. Burada borç kaynağı olarak sözleşmeler, haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme düzenlenmiştir.

Borçlar Hukukunun genel hükümleri, sözleşmelerin tamamına ve diğer hukuki işlemlere uygulanan genel nitelikli hükümleri içermektedir. Bu hükümler kanundan doğan borç ilişkilerine, sözleşme dışı sorumluluğa, sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

Genel hükümler önemli soyutlamalarla vaz edilmiş bir bölümdür. Sözleşmenin tarafların birbirine uygun irade beyanları ile kurulması, sözleşmenin ifa ile sona ermesi şarta bağlı borçların hüküm ve sonuç

---

1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicinin korunması amacıyla kapsamında bulunan sözleşmelere ilişkin temel ilkeler belirlemiş (m. 4), sözleşmelerdeki haksız şartları (m. 5), ayıplı mal (m. 9-12) ve hizmetler ile buna bağlanan hüküm ve sonuçları (m. 13-16) hükme bağlamış, tüketici sözleşmelerinden taksitle satış (m. 17-21), tüketici kredisi sözleşmesi ve bağlı kredileri (m. 22-31), konut finansman sözleşmesi (m. 32-39), ön ödemeli konut satış sözleşmesi (m. 40-46), diğer tüketici sözleşmelerinden işyeri dışında kurulan sözleşmeleri (m. 47), mesafeli sözleşmeleri (m.48-49), devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (m.50), paket tur sözleşmeleri (m. 51), abonelik sözleşmeleri ve süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarını (m. 52-53) düzenlemiştir.

2 **Honsell**, 10.

doğurması gibi konularda tüm sözleşmelere uygulanabilecek hükümler getirilmiştir[3].

Genel hükümler tarihsel açıdan bakıldığında sözleşme türlerine ilişkin hükümlerden 19. YY da geliştirilmiştir. Bu bakımdan temel sözleşme karakteri satıştır[4]. Satış sözleşmesi ani edimli bir borç ilişkisidir. Bu nedenle ve tarihsel nedenlerle Borçlar Kanununda sürekli borç ilişkilerini ön görerek genel hükümler vaz edilmemiştir. Benzer şekilde yenilik doğuran haklar bilinmemektedir[5] Sürekli borç ilişkileri sadece kendi türleri bakımından kira ve iş sözleşmeleri bölümünde düzenleme konusu yapılmıştır. Türk Borçlar Kanununun genel bölümünde sadece iki madde ile düzenlenmiştir. Bu durum borçlar hukukunun genel hükümlerinde sürekli borç ilişkilerinin göz ardı edildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Nihayet Türk Borçlar Kanunu sürekli borç ilişkilerini bazı açılardan düzenlemiştir: Örneğin borçlunun temerrüdünde seçimlik haklar bahsinde 126. madde kaleme alınmıştır. Buna göre alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi sözleşmeyi feshetmek suretiyle sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle uğradığı zararların tazminini isteyebilmektedir. TBK m.138'de ise sürekli borç ilişkilerinde borçlunun dönme yerine kural olarak fesih hakkını kullanma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.

Özel hükümler ile genel hükümlerin ilişkisinde iki ihtimalle karşılaşılır. Bunlardan birincisi, aynı meselenin iki kural tarafından düzenlenmesi (genel hüküm-özel hüküm), diğeri ise sadece bir kural tarafından düzenlenmesidir. İkinci ihtimalde konuyu düzenleyen tek kural uygulanır. Birinci ihtimalde ise, ilgili hükümleri yorumlayarak bir sonuca varmak gerekir. Bu hususta başlıca üç durum ortaya çıkabilir[6].

1. Münhasır uygulama

Lex specialis derogat generali prensibi gereğince özel hükümler genel hükümlerin uygulanmasını önler; taraflar ancak özel hükümlere dayanabilirler. Bu durum özellikle iki hükmün çatışması halinde söz konusu olur.

---

3 **Honsell**, 6.

4 **Honsell**, 6.

5 Bkz. **Ayrancı**, Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), 128 ve dipnot 80 (aynı yer).

6 **Tercier**, N. 250 vd.

Örneğin taşınır satışında hasarın intikalini düzenleyen TBKm. 208/I hükmü ifa imkânsızlığını düzenleyen TBK m. 136. madde uygulamasını engellemektedir.

Sonraki kanun önceki kanun uygulamasının da burada yapılması gerekir. Özel hüküm genel hükümden sonra düzenlenmişse münhasır uygulama daha açık bir hale gelir. Buna karşılık genel hüküm özel hükümden sonra ortaya çıkmışsa bir yorum sorunu ortaya çıkar. Bu durumda genel hükmün özel hükmü kaldırma amacı ile çıkarılıp çıkarılmadığına bakılır. Genel hüküm özel hükmü kaldırma amacı ve niteliği taşımamakta iken konuyu genel olarak düzenlemek amaç ve niteliğine sahip ise yine özel hüküm uygulanır. Genel ve özel hükümler Türk Borçlar Kanununda olduğu gibi aynı anda vaz edilmişse bu durum ayrıca yorum gerektirir.

2. Kuralların birlikte uygulanması *(Collision)*

Bu halde, özel ve genel hükümler birlikte uygulanır. Taraflar kuralların her ikisine de uymakla yükümlüdür. Eser sözleşmesinde TBK m. 473 gereğince dönme hakkının kullanılması, TBK m. 123 uyarınca mehil tayinini gerektirir; kusur karinesine ilişkin TBK m. 112 hükmü, eserdeki ayıptan yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde işsahibinin tazminat talebini düzenleyen TBK m. 475 gereğince istenecek tazminatta da uygulanır; alıcı, satıcının ayıptan sorumlu olduğu hallerde alıcının tazminat talebini düzenleyen TBK m. 227/I gereğince, bedelin indirilmesi ile birlikte satıcının kusuru varsa borcun ifa edilmemesini düzenleyen TBK m.112'ye göre tazminat talep edebilir.

3. Kuralların yarışması *(Konkrenz)*

Bu takdirde genel ve özel hükümler alternatif olarak uygulanır. Taraflar, şartlar gerçekleştiği takdirde, bu kurallardan istediklerinin uygulanmasını talep edebilirler. Meselâ, alıcı ayıba karşı tekeffül hükümleri (TBK m. 219/I) yerine hata hükümlerine (TBK m. 32) başvurabilir.

III. Aslî edim yükümünün muhtevasına göre sözleşmelerin tasnifi

Borçlar Kanunu'nun özel hükümlerinde yer alan sözleşme tipleri bu kritere göre düzenlenmiştir.

1. Temlik borcu doğuran sözleşmeler

Bu sözleşmelerle taraflardan biri diğerine bir hakkın kesin olarak devrini taahhüt eder. Sözleşmenin kurulmasıyla sadece bir devir borcu doğar; hakkın nakli için ayrıca bir tasarruf işlemine ihtiyaç vardır. Meselâ, satış, trampa ve bağışlama.

2. Kullandırma sözleşmeleri

Bu sözleşmeler bir şey veya hakkın kullanılmasının geçici olarak devri amacıyla kurulur. Kullandırma ivaz karşılığında ise, kira; ivazsız ise, kullanım ödüncü söz konusu olur.

Adi kira, ürün (hasılat) kirası, ariyet (kullanım ödüncü) kullandırma sözleşmelerinin en önemli örneklerindendir.

3. İşgörme sözleşmeleri

Bu sözleşmelerde taraflardan birinin edimini bir işgörme, bir beşeri faaliyet teşkil eder. Hizmet, vekâlet sözleşmeleri bu gruba girer. Bu sözleşmelerde edim fiili-edim sonucu ayırımı önem taşır.

Diğer vekâlet işlemleri kapsamında tellallık ve komisyonculuk iş görme sözleşmelerinden sayılabilir.

4. Saklama sözleşmeleri

Bu sözleşmeler bir şeyin saklanması edimini ihtiva ederler. Vedia (emanet), usulsüz tevdi, ardiye, otelci ve hancıya tevdi sözleşmeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.

5. Teminat sözleşmesi

Bu sözleşmelerin konusu, bir borcun ifasını temin, bir tehlikenin üstlenilmesi veya bir sonucun taahhüdüdür: Kefalet ve garanti. Yakın zamanda uygulaması sıkça görülen escrow sözleşmeleri[7]. Teminat sözleşmelerine örnek verilebilir.

6. Sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler

Bu sözleşmelerde, taraflardan biri diğerine belirli bir şartın gerçekleşmesi halinde bir edimde bulunmayı taahhüt eder: Kumar ve bahis, sigortalar.

---

[7] Bkz. Stefan **Eisenhut**, Escrow- Verhaeltnisse, Basel 2009.

7. İrat sözleşmeleri

Bununla taraflardan biri diğerine bir iratta (periyodik, dönemli ödeme, örneğin aylık, yıllık haftalık ödemeler gibi) bulunmayı taahhüt eder: Kaydı hayatla irat ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri.

8. Şirket sözleşmeleri

Bu sözleşmelerle iki veya daha çok kimse ortak bir amaca erişmek için emek ve servetlerini birleştirmeyi borçlanırlar. Bunlardan âdi şirket Borçlar Kanunu'nda, ticaret şirketleri Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir.

§ 2. KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELER (ATİPİK VEYA İSİMSİZ SÖZLEŞMELER)

I. Kavram

Borçlar Kanunu'nun özel hükümlerinde ve özel kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler bulunmaktadır. Bu sözleşmelere isimsiz veya atipik sözleşmeler denilmektedir[1]. Kanun koyucunun bunları düzenlememiş olması, düzenleme ihtiyacı duymamasından veya hiç tanımamış, yani varlığından habersiz olmasından ileri gelmektedir[2].

Kanunun bir sözleşmeyi sadece ismen zikretmiş olması, onun isimli sözleşme sayılmasını gerektirmez. Bu tür sözleşmelere örnek olarak, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması (MK m. 500-556) irtifak sözleşmesi (MK m. 781), taşınmaz rehin sözleşmesi (MK. m. 781), şerh sözleşmesi (MK m. 1009) ve ön sözleşme (TBK m. 29) gösterilmektedir[3]. Ayrıca örneğin enerji satış sözleşmeleri, sözleşmenin devri sözleşmesi vb.

II. Dogmatik temelleri

Taraflar, TBK m. 26'da öngörülen "sözleşme özgürlüğü", özellikle "tip özgürlüğü" ilkesine dayanarak, kanunda düzenlenmemiş olan ve ticarî hayatın pratik zaruretlerinden kaynaklanan isimsiz sözleşmeler kurabilirler[4]. Borçlar hukukunda, aile, miras ve eşya hukuklarından

---

1 **Schluep**, sh. 770; OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184, N. 5; **Bucher**, sh. 25; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184, N. 26; **Engel**, sh. 676; **Tercier**, FS Schluep, sh. 45. **Kramer**'e göre (Art. 19-20, N. 57), atipik sözleşmeler deyimini, isimsiz sözleşmeler veya kendine özgü sözleşmeler deyimleriyle eş anlamda kullanmamak gerekir. Zira atipik sözleşmeler, esas itibariyle, kanunla düzenlenmiş sözleşme kategorisine dahil edilmekle beraber, kanunla düzenlenen ana modele tekabül etmeyen özellikler ihtiva eder.

2 **Engel**, sh. 676; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 26.

3 OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N.5; **Engel**, sh. 677-678.

4 **Engel** sh. 676; **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1134, sh. 2; **Kramer**, Art. 19-20, N. 50; **Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N.1; TV Servisleri Band Paylaşımlı Transponder Kira Sözleşmesinin (Uydu Sözleşmesi) HGK 2011/11-693 E. 2012/88 K. – Kazancı İçtihat Bankası (Kazancı)-; TV Servisleri Band Paylaşımlı Transponder Kira Sözleşmesinin (Uydu Sözleşmesi) atipik karakteri hakkında bkz. aynı karar.

farklı olarak, tarafların yapabilecekleri sözleşmeler kanunen önceden belirlenmiş tiplerle sınırlı (numerus clausus) değildir; Borçlar Kanunu'ndaki hükümler, büyük çoğunluğu itibariyle emredici değil, yedek hukuk kuralları niteliği taşırlar[5].

İrade özerkliği ilkesinin sonucu olan sözleşme özgürlüğü, tarafların, hukukî ilişkilerini emredici kurallar çerçevesinde, istedikleri gibi düzenlemelerini ifade eder[6]. Zira, konun koyucunun düzenlediği sözleşme tipleri kimi zaman yetersiz kalmaktadır.

Sözleşme özgürlüğü ilkesi, aşağıdaki görünümleri arzeder:

1) Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü
2) Akdin karşı tarafını seçme özgürlüğü
3) Şekil özgürlüğü
4) Akdi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü
5) Akdin tipini (muhtevasını) belirleme özgürlüğü

Akdin muhtevasını belirleme veya tip özgürlüğü ilkesi, tarafların kanunda düzenlenen sözleşmeleri veya bunlara ait unsurları biraraya getirmek veyahut tamamen yeni sözleşme türleri kurmak suretiyle kanunî tiplerden ayrılabilme imkânını ifade eder[7]. Kısaca, kanunî modellere bağlı kalmadan sözleşme kurma yetkisidir[8]. İşte isimsiz veya atipik sözleşmeler, bu ilkenin ürünüdür.

Roma Hukukunda actiolar sisteminin varlığı nedeniyle atipik sözleşmeler bulunmamaktaydı. Sözleşme özgürlüğü ilkesi ile atipik sözleşmeler daha çok yapılmaya başlanmıştır.

---

5 Bazı yazarlar, tip mecburiyeti ile numerus clausus terimlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini; numerus clausus olmadan tip mecburiyeti veya tip mecburiyeti olmadan numerus clausus'un mevcut olabileceklerini; numerus clausus'un kanunda düzenlenen tiplerin sayı itibariyle sınırlandırılması, buna karşılık tip mecburiyetinin kanunda düzenlenen sözleşme tiplerinin kurulmasında öngörülen yapıya uyma zorunluluğu anlamına geldiğini ifade etmektedirler (**Schluep**, SPR, sh. 779, dn. 45; **Westermann**, Vertragsfreiheit und Typengesetzlickeit im Recht der Personen Geselschaften, Berlin 1970, sh. 115 vd; **Kramer**, Art. N. 53). Bununla beraber, her iki deyimin aynı anlama geldiğini savunanlar da bulunmaktadır (**Hofstetter**, SPR VII/2, sh. 24, dn. 42; **Larenz**, Schuldrecht, Bd. I, § 4 II a).

6 **Merz,** Vertrag, sh. 47; **Bucher,** AT, sh. 89 vd.; **Keller/Schöbi,** I, sh. 92; **Gauch/Schluep**, N. 484 vd.

7 **Honsell**, sh. 13; OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N. 2; **Bucher**, BT, sh. 15.

8 **Kramer**, Art. 19-20, N. 21 ve 49.

Bir sözleşmenin kanunda düzenlenmemiş olması uygulamada az tercih edildiği anlamına gelmemektedir. Bazı isimsiz sözleşmeler tipik sözleşmelerden daha fazla kurulmaktadır. Kanun koyucunun uygulamada az kullanılsa dahi bazı sözleşmeleri düzenlemesinin sebebi tarihsel olma yanında, belirgin karakterli edimleri içermeleridir. Ayrıca, bazı isimsiz sözleşmeler uygulamada çok tercih edildiğinden içerdiği hükümler bakımından standartlaşmaya başlamaktadır.

İşgörme sözleşmelerinde, yakın zamana kadar, numerus clausus ilkesinin mevcut olduğu ve bu alanda isimsiz sözleşme kurmanın mümkün olmadığı fikri savunulmakta idi[9]. BK m. 386/II'de yer alan, "Diğer sözleşmeler hakkındaki kanunî hükümlere tâbi olmayan işlerde dahi, vekâlet hükümleri carî olur" hükmüne dayanan bu düşünce, günümüzdeki hâkim görüş tarafından reddedilmektedir[10]. 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'nda, TBK m. 502/II'ye tekabül eden bir hüküm yoktu. İsviçre Borçlar Kanunu'nun hazırlık çalışmalarından ve Federal Mecliste'ki müzakerelerinden de anlaşıldığı gibi, BK m. 386/II'nin (OR Art. 394/II) konulmasındaki amaç, vekâlet sözleşmesinin sadece hukukî fiilleri değil, diğer işgörme sözleşmelerinin konusuna girmeyen fiilî hizmet edimlerini de kapsayabileceğini vurgulamaktır. Bu fıkrayla, işgörme sözleşmelerine numerus clausus ilkesinin getirilmesi söz konusu değildir[11]. Keza, İsviçre Federal Mahkemesi de, (tam) mimarlık sözleşmesini (Gesamtarchitektenvertrag) karma sözleşme olarak nitelendirmek suretiyle, eski içtihadını değiştirmiştir[12]. Buna karşılık, *Gauch*[13] ve *Merz*[14], mimarlık sözleşmesine vekâlet hükümlerinin uygulanacağını ifade etmektedirler. Nihayet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 502/II. maddesi vekâlete ilişkin hükümlerin niteliklerine uygun düştüğü ölçüde Borçlar Kanununda düzenlenmemiş işgörme söz-

---

9 **Gautschi**, Art. 394, N. 56; aynı yazar, FG für Oftinger, sh. 44; **Peyer**, sh. 168; BGE 104 II 15.

10 **Pedrazzini**, sh. 12, dn. 28; **Hoffstetter**, sh. 25, 26; **Bucher**, ZSR 102 II, sh. 324; **Leuenberger**, sh. 46 vd.; **Kramer**, Art. 19-20, N. 55; **Gauch/Schluep**, N. 627; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 17.

11 **Kramer**, Art. 19-20, N. 55; **Leuenberger**, sh. 47 vd.

12 BGE 100 II 466; 110 II 380; 111 II II 72; 114 II II 56; 127 III 545. Bu kararlarda sona erme bakımından tüm sözleşmenin vekâlet hükümlerine tabi olacağı ifade edilmiştir.

13 Das Architektenrecht, 1986, sh. 36 vd.

14 FS Schluep, sh. 255.

leşmelerine uygunacağını düzenlemiştir. Buna göre, Türk Borçlar Kanununda düzenlenmeyen işgörme sözleşmelerinin taraflarca kurulabileceği kabul edilmelidir. Bunun dışında söz konusu düzenleme vekâlete ilişkin düzenlemelerin kıyasen bu tür sözleşmelere uygunabileceğini düzenlenmekle yukarıda belirtilen tartışmayı sonlandırmış durumdadır.

III. Çeşitleri

Kanunda düzenlenmemiş veya isimsiz sözleşmeler geleneksel bir şekilde, kendisine özgü sözleşmeler karma sözleşmeler ve bileşik sözleşmeler olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır[15]. İsimsiz sözleşmelerde özel bir yer işgal eden, uygulanacak hukuk problemi, bileşik sözleşmelerde bulunmamaktadır. Bu itibarla, bileşik sözleşmelerin isimsiz sözleşmeler arasına dahil edilip edilmeyeceği, tereddüdü mucip olmaktadır[16]. Bununla beraber, bileşik sözleşmeler isimsiz sözleşmeler başlığı altında incelenmektedir. Esasen söz konusu üç ayrı türe ilişkin ayırımlar kapsam ve nitelik itibariyle farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Örneğin, kapıcılık sözleşmesi İsviçre Hukukunda kendine özgü sözleşme olarak nitelendirilmekte iken Türk Hukukunda karma sözleşme olarak kabul edilebilmektedir.

Buna göre, isimsiz sözleşmeleri üç grupta incelemek uygun olur: 1) Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler, 2) Karma sözleşmeler ve 3) Bileşik sözleşmeler.

1. Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler:

Bu tür sözleşmeler, kısmen veya tamamen, kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerinde bulunmayan unsurlardan meydana gelir. Bunların ihtiva ettiği unsurlar, kısmen veya tamamen kanunda düzenlenmiş sözleşmelerde mevcut değildir[17].

Sui generis sözleşmeler "gerçek anlamda yeni oluşumlar gösteren" sözleşmelerdir.

---

[15] **Schluep**, SPR, sh. 771; **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1134, sh. 1; **Kramer**, Art. 19-20, N. 56; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 32.

[16] **Schluep**, SPR, sh. 776; aynı yazar, OR Einl, vor Art. 184 ff, N. 6.

[17] **Meier-Hayoz**, FJS, N. 1134, sh. 1; **Schluep**, SPR, sh. 776; aynı yazar, Einl. vor Art. 183 ff, N.9; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 34; **Engel**, sh. 682; **Keller/Schöbi I**, sh. 97.

Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeleri sınırlayıcı şekilde sayma imkânı bulunmamaktadır. Zira çok sayıda olmaları yanında sözleşme özgürlüğü çerçevesinde yenileri meydana getirilebilmektedir. Bu türe başlıca misâl olarak sulh[18], satış için bırakma, kredi açma sözleşmesi, inançlı işlemler[19], repo işlemleri, franschise, lisans, know how, yönetim sözleşmeleri, tek satıcılık (bayilik), tahkim, mevduat ve sporcu transfer sözleşmeleri gösterilmektedir[20].

2. Karma sözleşmeler

a) Tanımı

Karma sözleşmeler, kanunun düzenlediği çeşitli sözleşme tiplerine ait unsurların, kanunun öngörmediği tarzda biraraya gelmesiyle kurulan sözleşmelerdir[21]. Bazı yazarlar[22], dar anlamda ve geniş anlamda karma sözleşme ayırımı yapmakta, az önce yapılan tanımı dar anlamda karma sözleşmelere hasretmektedirler. Geniş anlamda karma sözleşmeleri, kanunda düzenlenmiş veya düzenlenmemiş sözleşmelere ait unsurların karışımı olarak tanımlamaktadırlar. Bu takdirde, karma sözleşmeler ile kendisine özgü (sui generis) sözleşmeler arasındaki fark, bazı hallerde tamamen kaybolmaktadır. Nitekim, bu husus, anılan ayırımı yapan yazarlarca da kabul edilmektedir[23]. Bu nedenle biz geniş

---

18 Hukuk Muhakemeleri Kanunun 313, 314 ve 315. maddelerinde sulh sözleşmesi düzenlenmiştir. Buna göre, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda sulh yapılabilir. Taraflar görülmekte olan davada mahkeme huzurunda uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek için sulh sözleşmesi kurabilir. Ancak, sulh sözleşmesinin bu haliyle Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olması sulhü isimli bir sözleşme haline getirmemektedir. Zira yapılan düzenlemeyle sadece mahkeme içi sulh hükme bağlanmıştır. Mahkeme dışı sulh kapsam dışında bırakılmıştır. Diğer yandan, sulh sözleşmesine uygulanacak hükümler düzenleme konusu yapılmamıştır.

19 Bkz. İBK 5.2.1947 tarih ve 20/6 sayı; HGK 2012/1-330 E. 2012/558 K. – Kazancı-.

20 **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1134, sh. 10 vd.; **Schönle,** Vorbem zu Art. 184-551, N. 35; **Kramer**, Art. 19-20, N. 66; Enerji sözleşmelerinin sui generis karakteri için bkz. Ayrancı (Enerji Sözleşmeleri), sh. 150 vd.;

21 **Kramer**, Art. 19-20, N. 50; **Engel**, sh. 682; **Keller/Schöbi** I, sh. 96; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 35; **Tandoğan** I/1, sh. 14 vd.

22 **Schluep**, SPR, sh. 772 vd.; **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1134, sh. 1, Nr. 1135, sh.1.

23 **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1134, sh. 2; Nr. 1135, sh. 1; **Schluep**, SPR, sh. 771 vd. Ayrıca bk. **Kramer**, Art. 19-20, N. 58; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 32.

anlamda karma sözleşmeleri kendine özgü sözleşmeler olarak kabul etmekteyiz.

Karma sözleşmelerde farklı sözleşmelerin edimleri ilgili oldukları sözleşmeden koparak başka bir sözleşmenin edimleri ile birlikte yer alırlar.

b) Çeşitleri

Karma sözleşmeler başlıca dört kısma ayrılmaktadır[24]:

aa) Kombine sözleşmeler

Bu tür sözleşmelerde taraflardan biri, kanunî sözleşme tiplerine ait birden çok aslî edimde bulunmayı, diğeri de genellikle bir miktar para ödeme şeklinde tek bir edimde bulunmayı taahhüt eder[25].

Aşağıdaki sözleşmeler kombine sözleşmelere örnek teşkil eder:

– Pansiyon sözleşmesi: Mobilyalı bir odadan istifade (kira) + yemek veya kahvaltı (satış) + odanın temizlenmesi (hizmet) = Para

– Hastaneye kabul sözleşmesi: Bakım (hizmet) + tedavi (vekâlet) + oda tahsisi (kira) + yemek veya ilâç (satış) = Para

– Seyahat düzenleme (global seyahat) sözleşmesi: Taşıma (vekâlet veya eser) + otel temini (kira) + yemek (satış) = Para[26].

– Portföy yönetim sözleşmesi: Vekâlet + komisyon + vedia = Para

– Yatılı okul sözleşmesi: Kira + satış + vekâlet + hizmet = Para

bb) Çifte tipli sözleşmeler

Bu sözleşmelerde, taraflar farklı sözleşme tiplerine ait aslî edimleri karşılıklı olarak mübadele etmeyi taahhüt ederler. Başka bir ifadeyle, borçlanılan edim ve karşı edim değişik sözleşme tiplerine aittir[27].

Bu tür sözleşmelere şu örnekler gösterilebilir: Kapıcılık sözleşmesi (hizmet+kira); arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi (satış veya

---

[24] **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1135, sh. 3; **Honsell**, sh. 14 vd.; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 36 vd.

[25] **Meier-Hayoz**, FJS Nr. 1135, sh. 3; **Schluep**, SPR, sh. 772; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 8; **Honsell**, sh. 14; **Kramer**, Art. 19-20, N. 60; **Schönle**, Vorbem vor Art. 184 ff, N. 47; **Tandoğan** I/1, sh. 71.

[26] BGE 111 II 273.

[27] **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1135, sh. 3; **Schluep**, SPR, sh. 775; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 8, **Bucher**, BT, sh. 22 vd.; **Kramer**, Art. 19-20, N. 62; **Honsell**, sh. 15; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184, N. 42.

trampa + eser)[28]; yeni araba satışında satış bedelinin bir kısmı yerine kullanılmış arabanın mülkiyetinin devri (satış+trampa); kira karşılığı ders verme (kira+vekâlet); tamirat karşılığı bir dairede para ödemeden oturma (istisna+kira).

cc) Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler

Bu sözleşmelerde taraflardan biri veya her ikisi fonksiyon (değer) itibariyle değişik sözleşme tiplerine ait aslî edimleri ayrılmaz bir bütün halinde homojen bir yapı içinde taahhüt etmektedir[29]. Bunların klasik örneğini, karma bağışlama teşkil eder[30]. Ancak, karma bağışlamada, ivazlı ve ivazsız sözleşmelere ait bütün şartların gerçekleşmesi gerekir[31].

dd) Kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler

Bu sözleşmelerde aslî edimler kanunda düzenlenmiş bir sözleşme tipine ait olmakla beraber, başka bir kanunî sözleşme tipine ait edim yan yüküm olarak üstlenilmektedir[32].

Bu tür sözleşmelere örnek olarak montaj kaydıyla satış (satıcının müteahhit gibi montajı üstlenmesi); bakım kaydıyla kira (kiralayanın kiralananın temizlenmesi yükümünü üstlenmesi); TBK m. 208/III ve 211 anlamında mesafe satışı (Versendungskauf) (satıcı, vekil gibi gönderme yan yükümünü üstlenmektedir)[33].

Kiraya verenin kira konusu yerin ısınmasını temin etmesi, trampada taraflardan birinin denkliği sağlamak için bir miktar para vermesi gibi.

---

28 Eser sözleşmesinin kendine özgü türü şeklinde belirleme için bkz. 23. HD 2013/981 E. 2013/2985 K.ve Aynı Dairenin 2012/2054 E. 2012/4569 K. –Kazancı-; dava konusu sözleşmenin kendine özgü ve karma kuralları içeren bir bir sözleşme olduğuna ilişkin eklektik karar için bkz. 15. HD 2011/3349 E. 2012/5149 K. –Kazancı-; Bu sözleşmeler niteliği itibariyle güven esasına dayanır. Karşılıklı güven duygusu ve iyiniyet yanında tarafların dürüstlük kuralına uygun davranma yükümlülüğüne riayet etmeleri değerlendirilmelidir (23. HD. 28.1.2014 tarih E. 2013/5764 K. 2014/503- Kazancı-).

29 **Schluep**, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 8; aynı yazar, SPR, sh. 773 vd.; **Kramer**, Art. 19-20, N. 63; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 43.

30 BGE 98 II 358; 108 II 452.

31 **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 43; BGE 117 II 385.

32 **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 37. Ayrıca bk. **Honsell**, sh. 14-15.

33 **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 38.

Burada esas olan yabancı yan edimin sinallagma ilişkisi içinde yer alan asli edim haline gelmemesidir. Örneğin çamaşır makinesi satışına ilişkin sözleşmede makinanın montajına ve kullanımına ilişkin bilgi verme yükümlülüğü söz konusu sözleşme için asli edim niteliği taşımamaktadır. Yan edim taraflarca sübjektif bakımından esaslı nokta haline getirilmediği sürece sözleşmenin türünü belirlemekte etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle bu tür bir karma sözleşmenin bulunmadığı kabul edilmektedir.

3. Bileşik sözleşmeler

Bileşik sözleşmeler, birbirinden hukuken bağımsız ve farklı iki (veya daha çok) sözleşmenin, mahiyetlerine halel gelmeksizin, (iktisadî) fonksiyon itibariyle birbirine bağlanmasıdır. Öyle ki, edim-karşı edim ilişkisi içinde bulunan bu sözleşmelerden, birinin geçerliliği veya yerine getirilmesi diğerininkine bağlı, yani onun için işlem temeli sayılır[34].

Bileşik sözleşmeler sorumsuzluk anlaşması, cezai şart konulmasına ilişkin anlaşma, yazılı tahliye taahhüdü gibi bir yan anlaşma içermemektedir. Bileşik sözleşmelerde her bir sözleşme sinallagma ilişkisi içinde bulunmaktadır.

Bileşik sözleşmelerde sözleşme ile bağlı olma, diğer sözleşmenin geçerli hüküm ve sonuç doğurmasına bağlıdır. Aksi halde bir sözleşmenin geçersiz olması diğer sözleşmenin kendiliğinden geçersiz olması sonucunu doğurur[35].

Bileşik sözleşmelerde tarafların aynı olması her zaman söz konusu değildir. Bağlı kredi verilerek bileşik sözleşme kurulmasında, krediyi veren üçüncü bir kişi bileşik sözleşmenin tarafı olabilmektedir. Burada kredi veren ile satıcı arasında bileşik sözleşme kurulmaktadır.

Bileşik sözleşmelerde sözleşmelerin geçerlilik şartları birbirinden farklı değerlendirilir.

---

[34] **Schluep**, SPR, sh. 776 vd.; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 10; **Meier-Hayoz**, FJS, Nr. 1135, sh. 2; **Kramer**, Art. 19-20, N. 64; **Bucher**, BT, sh. 23; **Engel**, sh. 683; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 44; **Tandoğan**, I/1, sh. 75/76.

[35] **Gümüş**, 10.

Birden çok sözleşmenin bileşik sözleşme karakterini taşıyıp taşımadığı, tarafların iradelerine ve iktisadî fonksiyonlarının bütünlüğüne göre belirlenir[36].

Örnekler: Bira (meşrubat) imal eden bir firmanın sadece kendisinden bira almayı taahhüt eden bir müşteriye ödünç para vermesi[37]. Taşınmaz satışı ve alıcının satıcıya elektrik enerjisi verme taahhüdü[38]. Bir kereste satıcısının inşaat kredisi vermesi ve alıcının inşaatta kullanılacak keresteleri satın alma taahhüdü[39]. Cep telefonu ile birlikte SIM kart verilmesinde telefon satışı ile telefon abonelik işlemi bileşik sözleşme oluşturmaktadır.

Sözleşme şebekesi niteliğinde kurulan sözleşmelerin de bileşik sözleşme niteliği ayrıca değerlendirilmelidir.

IV. Hukuk kurallarının uygulanması

1. Genel olarak

İsimsiz sözleşmelerle ilgili anlaşmazlıkların çözümü, bu sözleşmelerin yorumlanması ve tamamlanması suretiyle gerçekleşir.

İsimsiz sözleşmelerin yorumlanması, kanunda düzenlenen sözleşmelerin yorumundan farklı değildir. Buna göre, isimsiz sözleşmeyi kuran taraf iradeleri güven ilkesine göre yorumlanır. Böylece, tarafların irade beyanları, mevcut şartlar içinde makul ve dürüst bir muhatabın bu beyana vermesi gereken anlama uygun olarak yorumlanır[40].

Böyle bir yorumdan, sözleşme hükümlerinin anlaşmazlığa uygulanacak bir kural ihtiva etmediği sonucuna varılırsa, bu takdirde bir sözleşme boşluğu karşısında bulunulur. Bu boşluk, sözleşmenin tamamlanması suretiyle doldurulur.

---

36 **Engel**, sh. 683; BGE 107 II 147 yahut JdT 1981 I 372; 94 II 361 yahut JdT 1970 140.

37 BGE 38 II 551.

38 BGE 97 II 390 yahut JdT 1973 I 84-85; ayrıca bkz. Ayrancı (Enerji Sözleşmeleri), sh. 139 vd.

39 **Staudinger/Löwisch**, § 305, N. 32.

40 **Meier-Hayoz**, FJS, N. 1134, sh. 5; **Engel**, sh. 684; **Schönle**, Vorbem zu Art. 184-551, N. 51; **Schönenberger/Jaeggi**, Art. 1, N. 181 ve 195; OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N. 11.

2. İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması

İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması, yorumlarında olduğu gibi, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin tamamlanmasına ilişkin esaslara tâbidir. Burada da, Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerinin, örf ve âdet hukuku kurallarının, ticarî teamüllerin ve Türk Borçlar Kanununun özel hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususları araştırılır.

a) Karma sözleşmelerin tamamlanması

Karma sözleşmelerdeki uygulanacak hükümlere ilişkin sözleşme boşluğunun giderilmesi için doktrin ve uygulamada aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür[41]:

aa) Soğurma (imtisas) teorisi

Bu teoriye göre, karma sözleşmelerde, bu sözleşmelerde yer alan hâkim tipe (unsura) ait hükümler uygulanmalıdır; hâkim sözleşme tipi, diğer unsurlar için öngörülen hukukî sonuçları kendi bünyesinde eritir[42]. Bu görüş, kendisine yabancı yan edimler ihtiva eden sözleşmelerde rahatlıkla uygulama alanı bulur[43]. Bunun yanında, bu teori, açıklığı ve sadeliği sebebiyle yargı içtihatlarında da kabul görmüştür. İsviçre Federal Mahkemesi, hisse senetlerinin müştereken tevdiinde vedia unsuru yanında, bankanın hizmet edimlerinin ağırlıklı olduğu gerekçesiyle, vekâlet hükümlerini uygulamıştır[44]. Keza, diş tedavisi dolayısıyla muhtemel eserlerin imalini vekâlete dahil saymış[45], otomat işletme sözleşmesinde kira karakteri hâkim görülmüştür[46]. Yargıtay ise arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini eser sözleşmesinin kendine özgü bir türü olarak kabul etmektedir. Bu tespitten hareketle hakim tip olarak eser sözleşmesi görülmekte, hukuki ilişkiye eser sözleşmesi hükümlerini uygulamaktadır. Örneğin eser sözleşmelerinden kaynak-

---

41 **Schluep**, SPR, sh. 800; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 13 vd.; **Kramer**, Art. 19-20, N. 74 vd.; **Tandoğan** I/1, sh. 73 vd.

42 **Schluep**, SPR, sh. 801; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184 ff, N. 13; **Kramer**, Art. 19-20, N. 75.

43 **Schluep**, SPR, sh. 801; aynı yazar, OR, Einl. vor Art. 184, N. 13. **Schluep** (anılan yerler), bu durumda, bir karma sözleşme bulunmadığı görüşündedir.

44 BGE 94 II 167 yahut JdT 1969 I 549 vd.

45 BGE 110 II 378.

46 BGE 110 II 475.

lanan alacaklara TBK m. 147/6 (BK m. 126/4) gereğince muacceliyet tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşamı süresi işletmektedir[47].

bb) Kıyas yoluyla uygulama

Buna göre, kanunla düzenlenmiş sözleşmelere ait hükümler, doğrudan doğruya değil, kıyas yoluyla uygulanır[48]. Ancak kıyas yoluyla uygulama için gerekli olan, her iki olayın benzerliği şartının gerçekleşmesi gerekir.

cc) Terkip (kombinezon) teorisi

Karma sözleşmeyi kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerinde mevcut unsurların yeni bir sentezi olarak anlayan bu teoriye göre, karma sözleşmelerdeki her unsura, ait olduğu sözleşme tiplerine ait unsurlar uygulanmalıdır[49]. İsviçre Federal Mahkemesi, tam mimarlık sözleşmesinde, mimarın proje hatasından dolayı sorumluluğunun eser akdine; yapım kontrolündeki özen eksikliğinin, vekâlet akdine ait hükümlere göre çözümleneceğini kabul etmiştir[50]. Ancak, bu görüşün, karma sözleşmelerde, sözleşmeyle gerçekleşen yapısal birliği bozduğu ifade edilmektedir[51].

dd) Yaratma teorisi

Bu teoriye göre, örf ve âdet hukuku kuralının bulunmadığı hallerde, yargıç isimsiz sözleşmelere uygulanacak hükmü, MK m. 1/II uyarınca bizzat kendisi koymalıdır[52]. Burada hakimin elindeki tek araç kıyas değildir. Hakim gerektiğinde isimli sözleşmelerin dışına çıkarak bağımsız hukuk yaratabilir. Bununla beraber, bu şekilde konulan genel ve soyut kurallar henüz iş hayatında yoğunlaşmamış münferit isimsiz sözleşmelerin tamamlanmasında elverişli olmayabilir.

---

47 Bkz. 23. HD. 3.7.2012 tarih E. 2012/2054 K. 2012/4569; 15. HD. 27.1.2012 tarih E. 2010/7098 K. 2012/350 –Kazancı-

48 OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N. 6; **Kramer**, Art. 19-20, N. 78.

49 OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N. 14; aynı yazar, SPR, sh. 801 vd.; **Kramer**, Art. 19-20, N. 79; **Leuenberger**, ZSR 106 II, sh. 61.

50 BGE 109 II 466.

51 OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff. N. 14; aynı yazar, SPR, sh. 802; **Kramer**, Art. 19-20, N. 79.

52 **Meier-Hayoz,** FJS, Nr. 1135, sh. 5; OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 ff, N. 17.

b) Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmelerin tamamlanması

Bu sözleşmelerin belirli bir tiple ilişkisi olmadığı için, yedek hukuk kurallarının doğrudan doğruya uygulanması söz konusu değildir[53]. Bu durumda, yargıcın MK m. 1/II gereğince hukuk yaratmak suretiyle boşluk doldurması gerekir[54]. Ancak hukuk yaratma, sözleşme tipi oluşturacak kadar çok kullanılan standartlaşmış sözleşmelerin tamamlanmasında elverişli sonuçlar doğurur. Bu suretle gerçekleşen uygulamalar sonunda, yargıcın yarattığı sözleşme tipleri hukuku doğmuş olur[55]. Buna karşılık standartlaşmamış sözleşme türlerinde tarafların farazi iradelerine dayalı oluşturulan kurallarla boşluk doldurulur. Özellikle, somut sözleşme ilişkisi ve menfaatler dengesi yedek hukuk kuralındaki çözümün dayanağını oluşturan normal ve ortaklaşa durumdan ayrılıyor ise, tarafların farazi iradeleri açıkça farklı bir çözümü işaret ediyorsa farazi iradeye dayalı tamamlayıcı sözleşme yorumu yapılır.

c) Bileşik sözleşmelerin tamamlanması

Bunlarda her sözleşme tipine ait hükümler uygulanır. Bu takdirde yargıcın münferit sözleşme yapılarını nasıl bir sistem bütünlüğü içinde toplayabileceği sorusuyla karşılaşılacaktır[56].

---

53 Yedek hukuk kurallarının kıyasen uygulanması örneği için bkz. HGK 2012/11-550 E. 2012/820 K. –Kazancı-.

54 OR-**Schluep**, Ein. vor Art. 184 ff, N. 69; aynı yazar, SPR, sh. 798.

55 **Schluep**, SPR, sh. 800; **Kramer**, Art. 19-20, N. 80.

56 OR-**Schluep**, Einl. vor Art. 184 vd., N. 71.

BİRİNCİ KISIM
TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR SATIŞI

§ 3. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, KURULMASI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU

I. Tanımı

Satış sözleşmesi en temel sözleşme türü olarak kabul edilmektedir. Günlük hayatta en çok kullanılan sözleşme türüdür.

6098 sayılı (yeni) Borçlar Kanunu'nda satım sözleşmesi deyimi, satış sözleşmesi olarak değiştirilmiştir. Tasarının gerekçesinde, bu değişikliği, satış kelimesinin sözleşmenin sadece satıcı tarafını ifade ettiği, günlük dilde satım yerine satış sözcüğünün kullanıldığı, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun bazı hükümlerinde "alım-satım"dan söz edildiğinden bahisle bu değişikliğin yapıldığı ifade edilmiştir. Oysa sözlük anlamı itibariyle, her iki kelime arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Satışa ilişkin hükümler tüketici hukuku ve taksitle satış dışında büyük ölçüde yedek hukuk kurallarından oluşmaktadır.

Borçlar Kanununun genel hükümleri ve borçların özel hükümleri aksi kararlaştırılmadıkça eldeki olaya uygulanacaktır.

Yeni Borçlar Kanunu'nun 207. maddesinin kenar başlığı "tanımı ve hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. TBK m. 207/I'e göre, "satış sözleşmesi satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir". Bu fıkrada, satış sözleşmesi tarafların asli edim yükümlerinden hareketle tanımlanmak istenmiştir. Satılan mal yerine, sadece satılan kelimesinin kullanılması yerinde bir değişiklik olmuştur. Düzenleme ile satış konusunun maddeselliğine daha az vurgu yapılmıştır. Böylece gayri maddi mallar ile eşya ötesi değerlerin satışı tanımlama kapsamına alınmıştır. Bu nedenle, mal niteliği taşıyıp taşımadığı tar-

tışma konusu olan elektrik enerjisi gibi tabii kuvvetlerin satış sözleşmesine konu edilmesi kavramsal olarak kolaylaştırılmıştır. Aynı husus alacaklar, patent, mirasçılık durumu, model, logo, müşteri çevresi, bilgi gibi maddi olmayan şeylerin satış konusu olması ihtimali içinde söylenebilir[1].

II. Türleri

Türk Borçlar Kanununun 207 vd. maddelerinde düzenlenen satış yanında, tüketici satışları, ticari satışlar ve milletlerarası mal satışına ilişkin farklı hükümleri içeren satış türleri bulunmaktadır.

Tüketici satışı, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişinin (tüketicinin) ticari veya mesleki amaçla hareket eden kişi ile kurduğu satış sözleşmeleridir[2]. TKHK da tüketici satışlarına ilişkin özel hükümler bulunmaktadır.

Ticari satış, satılanı tekrar satma ve kâr etmeyi meslek edinen kişiyle (alıcıyla) yapılan satışdır[3]. Bu tür satışlarda zilyetliğin devri için belirli bir sürenin konulması halinde, satıcının temerrüdünün sonuçlarını düzenleyen hükümler (TBK m. 212/II, III) yanında, diğer ticari satışlar bakımından da edimlerin kısım kısım yerine getirilmesi, alıcının temerrüdü halinde satıcının hakimden malın satışına izin verilmesini talep etme, ayıptan sorumluluk halinde muayene ve ihbar külfetleri (TTK m. 23/1-3) gibi hususlar hükme bağlanmıştır. Ticari işletmeler arasında yapılan satışlarda para borçlusunun temürrüdüne ilişkin özel hükümler öngörülmüştür (TTK m. 1530/2-8)[4].

---

1 **Serozan** 87.

2 Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi olarak tanımlanmaktadır (TKHK m. 3/k). Kanuna göre, alışverişe konu edilen taşınır eşya ile konut olarak veya tatil amaçlı taşınmazlar yanında elektronik ortamda kullanılmak için hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve diğer benzeri gayri maddi mallar bu kapsamda mal olarak kabul edilmektedir. Satıcı ise ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan veya bu kişiler adına ya da hesabına hareket eden kişileri ifade etmektedir (m.3/h, j). Tüketici işlemi ise mal ve hizmet piyasalarında ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeleri de kapsayan her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır (m. 3/ l). Bu tür işlemleri yapan kişinin kamu tüzel kişisi olması, gerçek veya tüzel kişi olması tüketici işlemi niteliğini değiştirmemektedir.

3 Bkz. aşağıda § 7/II/1.

4 Bkz. § 10/I/6/b/cc.

Milletlerarası mal satışı ise şartlarının bulunması halinde Milletlerarası Mal Satışına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerinin uygulandığı satış türüdür[5].

III. Kurulması

Bütün sözleşmelerde olduğu gibi, satış sözleşmesinin kurulması için, tarafların objektif ve sübjektif bakımdan esaslı noktalar üzerinde anlaşmaları gerekir (TBK m. 1, 2/II). Objektif esaslı noktalar malvarlığı değeri ile paranın mübadelesi üzerine tarafların anlaşmasıdır. Bu husus dışındaki noktalar kanun tarafından belirlenmiş durumdadır. Satış sözleşmesinin objektif bakımdan esaslı noktaları, satılan (satış konusu), bedel ödeme (semen) ve bunların birbirleriyle değiştirilmesi taahhüdüdür[6].

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 20 vd. maddelerinde genel işlem koşulları düzenlenmiştir. Bir sözleşme yapılırken düzenleyenin gelecekte çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak için önceden kendi başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu hükümler genel işlem koşulu olarak tanımlanmaktadır. Genel işlem koşullarının sözleşmenin diğer tarafının menfaatine aykırı olması halinde bağlayıcılığı, karşı tarafa açıkça bilgi verilmesi, içeriğini öğrenme imkânı sağlanması ve kabul edilmesine bağlı tutulmuştur. Aksi takdirde bu koşullar yazılmamış sayılmaktadır (m. 21). Genel işlem koşullarının yazılmamış sayılması, yorumlanması, değiştirme yasağı ve içerik denetimi kanunda düzenlenmiştir (m. 22-25).

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. maddesinde tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hükme bağlanmıştır. Tüketiciyle kurulan sözleşmelerde bulunan haksız şartlar kesin hükümsüzlük müeyyidesine tabi tutulmuştur (m. 5/2). Aynı Kanunun 9/2. Maddesi delale-

---

5 Milletlerarası Mal Satışına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods–CISG) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2.4.2009 tarih ve 5870 sayılı Kanunla onaylanmış, Bakanlar Kurulunca 11.3.2010 tarih 2010/247 sayılı katılma kararı verilmiştir. Antlaşma 1.8.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşma Viyana'da imzalandığı için Viyana Satış Anlaşması da denmektedir. Bkz. aşağıda § 4/I.

6 **Giger**, Art. 184, N. 8; **Cavin**, sh. 10 vd.; **Oser/Schönenberger**, Art. 184, N.2 ve 12; **Schönle**, Art. 184, N. 13 ve 20; **Honsell**, sh. 25; **Keller/Siehr**, sh. 8; **Tercier**, N. 123.

tiyle haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır (RG 17.6.2014, s. 29033). Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin uygun olmayan ölçüde yüksek tazminat ödemesi gibi haksız sözleşme şartları örnekleri sınırlayıcı olmamak üzere sayılmıştır.

Satış sözleşmesinin objektif esaslı noktaları satış konusunun ve bedelin belirlenmesi hususu, satış sözleşmesinin kurulabilmesi bakımından önem taşımaktadır. TBK m. 207/III, satış sözleşmesinin kurulabilmesi için bedelin belirlenebilir olmasını yeterli görmektedir. Bir edimin belirlenebilir olması (Bestimmbarkeit), edimin sözleşmenin kurulmasından sonra, yeni bir anlaşmaya gerek olmadan somut bir muhteva kazanma imkânını ifade eder[7]. Böylece, taraflar, sözleşmenin kurulması esnasında, edimin sonradan (ifa anında) belirlenmesini sağlayan kriterleri tayin edebilirler. Bu kriterler, genellikle borsa kurları veya carî fiyatlara yollamada bulunmak suretiyle "objektif" bir nitelikte olabileceği gibi, taraflardan birinin irade beyanı şeklinde (sübjektif belirlenebilirlik) (BGB §315) de olabilir. Aynı şekilde, edimin belirlenmesinin bu konuda yetkili bir üçüncü şahsa bırakılması (objektifleştirilmiş belirlenebilirlik) da mümkündür[8].

1. Bedelin -semenin belirlenebilir olması

TBK m. 207/III gereğince, mevcut durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, belirlenmiş sayılır[9]. Bu fıkrada kendisine yollama yapılan durum ve koşullar deyimiyle, kanun koyucunun objektif kriterleri ifade ettiğini, bedelin taraflardan birinin veya üçüncü şahsın keyfi takdirine bırakılması halinde, sözleşmenin kurulmamış

---

7 **Giger**, Art. 184, N. 223.

8 **Giger**, Art. 184, N. 223; OR-**Koller**, Art. 184, N. 47; **Tercier**, N.492-493; **Huguenin**, N.77; CISG m. 55'e göre, semen (bedel) açık veya örtülü olarak belirlenmemiş ya da belirlemeyi sağlayacak unsurlar kararlaştırılmamışsa tarafların sözleşmenin kurulduğu anda ilgili ticari alanda benzer koşullarda satılan aynı tür mal için uygulanan cari fiyatı örtülü olarak kabul edildiği varsayılır.

9 Satılıp teslim edilen dağ sahlebinin bedelinin yazılı delille ispatlanamamış olması veya bedelin belirlenmemiş olması halinde satış sözleşmesinin siparişin yapıldığı gün ve yerdeki cari fiyat üzerinden yapıldığının kabulü gerekir. Bu durumda satış bedelinin gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenmesi mümkündür (19. HD. 2013/181 E. 2013/4931 K. –Kazancı-).

olduğunu kabul etmek gerekir[10]. Zira burada ahlaka aykırılık nedeniyle geçersizlik söz konusudur. İsviçre Federal Mahkemesi, ön ödemeli satışlarda, "objektif olarak belirlenen fiyat" deyimini geniş yorumlayarak, satış konusunun seçildiği anda, teşhir salonunda veya prospektüste yazılı satıcının belirlediği fiyatlara yapılan yollamayı, serbest rekabet mekanizmasının keyfiliği önleyeceği düşüncesiyle, yeterli bulmuştur[11]. Bu içtihatlardaki anlayış, İsviçre Borçlar Kanunu'nda 1963 yılında yapılan ön ödemeli satışlara ilişkin değişikliklerde (OR Art. 227 e/II) de benimsenmiştir.

2. Satılanın belirlenebilir olması

Bedelin belirlenebilirliğinde olduğu gibi, satış konusunun belirlenebilirliğinde de objektif olarak belirlenebilirlik şartının aranması gerekir[12]. İsviçre Federal Mahkemesi, ön ödemeli satışlara ilişkin kararlarında, satıcının imal ettiği mallardan alıcıya seçim hakkı veren sözleşmelerde, satılanın belirlenebilir olduğu görüşündedir[13]. Federal Mahkeme, alıcıya tanınan bu seçim hakkında, TBK m. 86 anlamında seçimlik borç niteliği görmektedir[14].

IV. Hukukî niteliği

1. Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir

Satış sözleşmesinin kurulmasıyla, satıcı için, satılanı alıcıya teslim ve bunun üzerindeki hakkı ona geçirme; alıcı için de bir miktar para ödeme borcu doğar (TBK m. 207/I). Satış konusu üzerindeki hak sahipliğinde değişme menkullerde teslim (MK m. 763/I), gayrimenkullerde tescil (MK m. 705) ve alacaklarda temlik (TBK m. 183) şeklindeki tasarruf işlemleriyle gerçekleşir. Elden satış ile otomatla satışta, borcun doğumu ile ifasının zaman açısından birlikte vuku bulması,

---

[10] **Cavin**, sh. 19 vd.; **Giger**, Art. 184, N. 234 vd.; **Keller/Siehr**, sh. 10; bazı farklılıklarla: **Schönle**, Art. 184, N. 86 vd. Semeni belirleme yetkisinin sözleşmeyle taraflardan birine bırakılması ihtimalinde, şüphe halinde, bu belirlemenin hakkaniyete göre yapılacağı görüşünde: OR-**Koller**, Art. 184, N. 47; **Schönle**, Art. 184, N. 90, 91 ve 92.

[11] BGE 85 II 408; 84 II 13 vd.; 84 II 266 vd.; 84 II 628 vd.

[12] **Cavin**, sh. 20-21; **Giger**, Art. 184, N. 224 vd. Aksi fikirde: OR-**Koller**, Art. 184, N. 50.

[13] BGE 84 II 13 yahut JdT 1958 I, 263; 84 II 266 yahut JdT 1959 I 42; 85 II 402 yahut JdT 1960 I 260.

[14] Aynı görüşte: Zürich Obergericht, SJZ 58/1962, Nr. 37, sh. 41 vd.

bunların borç doğuran işlem niteliğini bertaraf etmez. Bu tür satışlarda taahhüt ve tasarruf işlemlerinin ayrı olması, alıcının kalp (geçersiz) para ödemesi (ifa etmeme) veya satılanın ayıplı olması (kötü ifa) hallerinde, tarafların taahhüt işleminden doğan ifa etmeme veya ayıba karşı tekeffüle ilişkin talepleri kullanabilmeleri açısından önem arzeder[15].

2. Satış sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir

Satış sözleşmesinin kurulabilmesi için iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir; bunun için, satış konusunun teslimine ihtiyaç yoktur.

3. Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir

Satış sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, tarafların borçlanmış oldukları edim ve karşı-edim, karşılıklı değişim ilişkisi içinde bulunmaktadır. Edimlerin bu değişim ilişkisine sinallagma adı da verilmektedir[16]. Böylece satılan ile satış bedeli (semen) birbirleriyle değiştirilmektedir.

Satış sözleşmesinde tarafların edimleri arasındaki karşılıklılık ve bağımlılık, hem genetik (doğuş yönünden), hem fonksiyoneldir. Genetik (doğuş yönünden) karşılıklılık veya bağımlılıkta, taraflardan birinin ediminin doğumu, diğerinin ediminin geçerli olarak doğumuna bağlıdır. Meselâ, satıcının satılanı teslim ve mülkiyeti geçirme borcu geçersiz ise, alıcının bedeli geçirme borcu da geçersiz olur. Bu husus, TBK m. 27/I ve m. 170/I'den dolaylı olarak çıkartılmaktadır[17]; tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflar zımnen veya açık olarak diğerinin borçlanma beyanını geçerliliği talikî şartına bağlı olarak borç altına girerler.

Fonksiyonel sinallagma veya karşılıklılıkta ise, ifa ve devam yönünden edimler birbirine bağlıdır. İfa yönünden bağımlılık TBK m. 97 ve m. 207/II'de ifade edilmiş olup, taraflardan her biri ödemezlik def'ine sahiptir. Aksine bir sözleşme olmadıkça, satılanın alıcıya teslimiy-

---

[15] **Oser/Schönenberger**, Art. 184, N. 12; **Becker**, Vorbem zu Art. 184-186, N. 2; **Keller/Siehr**, sh. 4; **Giger**, Art. 184, N. 8; **Schönle**, Art. 184, N. 24; OR-**Koller**, Art. 184, N. 5; **Bucher**, BT, sh.54; **Huguenin**, N.6.

[16] **von Tuhr/Peter**, sh. 149; **Schönenberger/Jaggi**, Art. 1, N. 118; **Eren**, C.I, sh. 274.

[17] **Schönle**, Art. 184, N. 37.

le satıcının satış bedeline hak kazanacağını öngören TBK m. 234/I hükmü, lafzına rağmen satıcıya önceden ifa yükümü koymamaktadır[18]. Edimlerin devam yönünden birbirine bağlılığı ise, edimlerden birinin ortadan kalkması halinde diğerinin de sona ereceği anlamına gelmektedir.

4. Satış sözleşmesi ani edimleri ihtiva eden bir sözleşmedir

Satış sözleşmesiyle kurulan borç ilişkisi, esas itibariyle, devamlı (sürekli) bir borç ilişkisi değildir; satış sözleşmesinin içerdiği aslî edimler sürekli değil, kararlaştırılan zamanda bir defada yerine getirilen bir anî edimdir. Bununla beraber, ard arda teslimli satış sözleşmesinde olduğu gibi, satış sözleşmesi, istisnaî olarak, devamlı borç ilişkisine (periyodik -devrevi borç ilişkisine) vücut verebilir[19]. Esasen ard arda teslimli satış sürekli borç ilişkisine yol açmaz. Bu ara bir ifa durumudur.

Ani edimli sözleşmeler, dönemli-devri sözleşmeler; ard arda edimli sözleşmeler, sürekli sözleşmeler yanında uzun süreli sözleşmeler – long term, langfristiger Vertrag- de bulunmaktadır.

Sürekli borç ilişkilerinde edimler bölümlere ayrılmamıştır. Oysa ard arda teslimli sözleşmelerde bölümlere ayrılma söz konusudur. Buna karşılık sürekli borç ilişkilerinde edimler süreklilik arz etmektedir.

Bu nedenle uzun süreli sözleşme ilişkileri (ani edimli ile sürekli borç ilişkisi arasında) ani edim karakteri ağır basanlar, sürekli edim karakteri ağır basanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu belirlemeye göre hukuk kuralları uygulanabilmektedir. Bazı doğal gaz sağlama sözleşmelerinde sürekli edim karakteri ağır bastığından sürekli borç ilişkisinde bulunan özellikler bulunabilmektedir.

Uzun süreli sözleşmelerde teslim konusu malların tamamı bütün olarak kabul edilir. Ancak bu tür sözleşmelerde edimlerin zamana yayılması sürekli borç ilişkilerinden farklı olarak belirleyici unsur değildir. Uzun solukluluk niceliğe ilişkin bir unsur değildir. Muaccel edimlere göre zaman içinde değişebilir. İnşaat yapım sözleşmeleri, kompleks teknik fabrikaların yapılması, hammaddelerin, enerjinin ve büyük mal teslimleri uzun süreli sözleşmelerden sayılabilir. Edimler bu tür

---

[18] **Oser/Schönenberger**, Art. 213, N. 1; **Becker**, Art. 213, N. 1; **von Tuhr/Escher**, sh. 49/50, dn. 47; **Schönle**, Art. 184, N. 8 ve 38; **Cavin**, sh. 22.

[19] **Keller/Siehr**, sh. 5.

durumlarda anlık yerine getirilir. Ancak belirli zaman dilimlerine bölünmüştür. Bunların bir kısmında planlama, üretim ve teslimde taraflar arasında işbirliği gerekir.

Uluslararası piyasada uzun süreli doğal gaz satış sözleşmeleri tercih edilmektedir[20]. Uzun süreli gaz sağlama sözleşmeleri, sözleşme konusu gaz miktarının uzun süreli elde edilebilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan, fiyat bakımından da olumlu etkileri bulunmaktadır. Fiyatların her türlü etkiye açık olması böylece engellenmekte "koruyucu bir kalkan" görevi yapmaktadır.

5. Satış sözleşmesi illî (sebebe bağlı) bir sözleşmedir

Taşınmaz satışının sebebe bağlı olduğu hususu, kanunda açıkça öngörülmüş bulunmaktadır (MK m. 705/I, 716 ve 1024-1025). Aynı sonucun taşınır satışında da geçerli olduğu doktrin ve uygulamadaki hâkim görüş tarafından kabul edilmektedir[21].

İsviçre Federal Mahkemesi, alacağın temlikinin sebebe bağlı (illî) olup olmadığı hususunu çözümsüz bırakmıştır[22]. Bazı yazarlar, Alman hukukunda olduğu gibi, alacağın temlikinin soyut (mücerret) olduğu görüşündedirler[23]. Ancak son zamanlarda İsviçre-Türk hukukunda hâkim görüş[24], haklı olarak, alacağın temlikinin sebebe bağlı (illî) bir işlem olduğunu kabul etmektedir.

V. Konusu

TBK md. 207/I'de satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme borcundan söz edilmektedir. Bu ifadeden, satış sözleşmesinin konusunun sadece maddî bir varlığı bulunan taşınır ve taşınmazlarla sınırlı olduğu sonucuna varılabilir. Bununla beraber, doktrin ve

---

20 Bkz. **Baur**, Langfristige Gaslieferungsvertraege, FS für Otto Sandrock zum 70. Geburtstag.

21 **Oftinger**, Von der Eigentumsübertragungs an Fahrnis, Bern, 1933, sh. 128 vd.; **Haab/Simonius**, Art. 714, N. 33; **Cavin**, sh. 28; **Merz,** Vertrag, sh. 44; **Schönle**, Art. 184, N. 28; **Gürsoy/Eren/Cansel**, sh. 676; BGE 55 II 306 vd.; 93 II 375. Aksi fikirde: **Oğuzman/Seliçi**, sh. 605; **Arslanlı**, sh. 629.

22 BGE 95 II 112; 84 II 363 vd.

23 **von Tuhr/Escher**, sh. 333; **Bucher**, AT, sh. 554 vd.; **Schmid,** SJZ 1970, sh. 299 vd.

24 **Dutoit**, Hundert Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, sh. 453 vd.; **Merz,** Vetrag, sh. 44 vd.; **Gauch/Schluep**, N. 3631 vd.; **Jaggi**, SJZ 1967, sh. 6 vd.; **Eren**, C. III, sh. 423.

uygulamada, bu fıkra hükmünün lafız itibariyle dar olmasına rağmen, satıcının malvarlığının aktifinde yer alan ve başkasına para karşılığında devredilebilen her türlü eşyanın, hakların, tabiî kuvvetlerin veya diğer hukukî varlıkların satış sözleşmesine konu olabileceği kabul edilmektedir; meğer ki, bunlar başka sözleşme tiplerine dahil edilmelerini zorunlu kılan özellikler taşısın (meselâ, hizmet edimi veya işgörme sonucu gibi)[25]. Buna göre, aşağıdaki hususlar satış akdine konu olabilirler:

1. Eşya

Maddî bir varlığı olan veya olmayan (MK m. 762 anlamında taşınır mülkiyetine konu olabilen elektrik gibi tabiî kuvvetler) taşınır veya taşınmaz eşya satış sözleşmesine konu olabilir.

Bir ücret karşılığı belirli bir miktar elektrik temini, doğalgaz sağlanması satış; bir yerin aydınlatılması, bir fırının belirli bir ısıda tutulması gibi sonuç taahhütleri, eser sözleşmesi sayılır[26].

Satış sözleşmesinin konusu eşya, çeşidiyle veya ferdî özellikleriyle belirlenebilir. Birinci halde, çeşit satışı, ikinci halde parça satışı söz konusu olur. Taraflar, çeşit satışının konusunu eşyanın ait olduğu cinsin genel özelliklerine göre; parça satışında ise, eşyanın ferdî (bireysel) nitelik ve özelliklerini göstererek belirlerler[27].

Parça eşya ve çeşit eşya kavramlarını, mislî eşya ve mislî olmayan eşya kavramlarından ayırmak gerekir. Mislî şeyler, iş hayatındaki objektif telakkilere göre, sayı, miktar ve ağırlık itibariyle belirlenir (beş ton zeytinyağı, on ton buğday gibi); mislî olmayan şeyler ise, iş çevresindeki genel anlayışa göre ferdî özellikleriyle belirlenip, biri diğerinin yerine geçmez (meselâ, taşınmazlar, tablolar). Görülüyor ki, parça-çeşit ayırımı tarafların iradelerinden kaynaklanan sübjektif kriterlere; mislî eşya-mislî olmayan eşya ayırımı, iş hayatındaki objektif ölçülere dayanmaktadır[28].

---

[25] **Giger**, Art. 184, N. 10 ve 18; **Keller/Siehr**, sh. 8/9; **Schönle**, Art. 184, N. 42; **Engel**, sh. 11; **Tercier**, N. 444-445.

[26] BGE 76 II 103 yahut JdT 1950 I 258; **Cavin**, sh. 14; OR-**Koller**, Art. 184, N. 10; **Schönle**, Art. 184, N. 55; **Engel**, sh. 121 vd, özellikle sh. 124.

[27] **Keller/Siehr**, sh. 9; **Schönle**, Art. 184, N. 44; **Honsell**, sh. 30; **Cavin**, sh. 12.

[28] **von Tuhr/Peter**, sh. 53-54; **Merz**, OR, sh. 141 vd.; **Keller/Siehr**, sh. 9; **Honsell**, sh. 30; **Eren**, C. I, sh. 133-134; **Kocayusufpaşaoğlu**, sh. 67.

Genel olarak, mislî şeyler çeşit satışının, mislî olmayan şeyler parça satışının konusunu teşkil eder. Bununla beraber, bazı hallerde, taraf iradeleri ile iş çevrelerindeki anlayış birbirinden farklı olabilirler. Böylece mislî şeyler parça satışına (meselâ, satıcının deposunun belirli bölümündeki otun satışı[29], markası, modeli ve serisi belirli yeni bir arabanın satışı)[30]; mislî olmayan şeyler de çeşit satışına konu olabilirler (meselâ, bir ressama ait üç tablonun satışı)[31].

Parça satışı-çeşit satışı kavramlarının açıkça belirlenmesi ve bu iki kavramın mislî eşya deyimlerinden ayırdedilmesi, sadece teorik bir değer taşımayıp pratik açıdan da önem arzetmektedir. Zira kanun, bazı hallerde satış sözleşmesinin konusunun parça veya çeşit borcu olmasına farklı hukukî sonuçlar bağlamıştır. Buna örnek olarak, ayıba karşı tekeffülde ayıplı eşyanın değiştirilmesini talep hakkını düzenleyen TBK m. 227/I, b.4 hükmü zikredilebilir. Aynı şekilde, kararlaştırılan şeyden başka bir şey teslimi (aliud) ve ayıplı bir mal teslimi (peius) hallerinin birbirinden ayırdedilmesinde parça satışı- çeşit satışı ayırımının önemli bir yeri vardır[32].

Eşya birlikleri (Sachgesamtheiten, meselâ bir sürü, bir kütüphane, bir kolleksiyon) de satış sözleşmesine konu teşkil edebilir. Ancak, eşya hukukuna ait belirlilik ilkesi gereğince, eşya birliğine dahil her eşya üzerindeki tasarruf işleminin, kendisi için öngörülen esaslar dahilinde, ayrı ayrı gerçekleşmesi gerekir[33].

2. Hak ve alacaklar

Maddî olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar (patent veya telif hakkı) ve nisbî haklar (alacaklar) da satış sözleşmesinin konusu olabilirler. Başkalarına bağımsız olarak devredilebilen sınırlı aynî haklar, meselâ irtifak hakları da satılabilir[34].

---

29 BGE 41 II 436.

30 BGE 84 II 158 yahut JdT 1959 I 40; 90 II 26 yahut JdT 1969 I 322.

31 **von Tuhr/Peter**, sh. 54; **Keller/Siehr**, sh. 10; **Honsell**, sh. 28; **Schönle** Art. 184, N. 44.

32 **Keller/Siehr**, sh. 10; **Honsell**, sh. 30; **Lanz**, recht 1996, sh. 250, IV, 1.

33 **Meier-Hayoz,** Syst. Teil, N. 76 vd.

34 **Engel**, sh. 13; OR-**Koller**, Art. 184, N. 11; **Huguenin,** N. 82-83; **Liver** (Einl. N. 134 ve Art. 732, N. 54) irtifakların devrini sui generis bir sözleşme olarak nitelendirmektedir.

Alacak satışında, devri taahhüt edilen alacak hakkında TBK m. 183/I anlamında temlik yasağının bulunması, sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Temlikin gerçekleşmemesi, alacağın devralana geçmemesi taahhüt işleminin geçerliliğini etkilemez. Zira TBK m. 191-193 hükümleri, TBK m. 27/I'den ayrılan özel hüküm niteliğindedir[35]. *Schönle*'ye göre[36], böyle bir durumda, satışın geçerliliği, temlik engelinin kalkmasının zaman açısından öngörülebilir, yani yakın bir gelecekte kalkabilir olması şartına bağlıdır.

Alacak satışında tekeffül bakımından, özel bir hüküm olan TBK m. 191 uygulanır[37].

Hukukî birlikler (tümlükler; Rechtsgesamtheiten) de satış sözleşmesine konu teşkil edebilir. Bu cümleden olarak, bir şahsa ait malvarlığının tamamı veya açılmış bir miras payı satılabilir; henüz açılmamış bir miras payı, ancak miras bırakanın rızasıyla devredilebilir (MK m. 678).

3. Ekonomik bir fayda

Hak şeklinde olmayan ekonomik veya fiilî bir fayda, meselâ henüz patenti alınmamış bir buluş, imalât sırrı, know-how (teknik bilgi, beceri) ve müşteriler satış sözleşmesine konu olabilir[38]. Aksi fikirde olan *Cavin*'e göre[39], ekonomik fayda, özellikle müşterilerin devri halinde, devredenin borcunun konusu bir hakkın devri olmayıp, belirli bir alanda faaliyette bulunmamak, bir rekabet yasağıdır. Satıcının aslî borcu teslim veya vermedir; müşteri devreden ise, yapmama veya bazen yapma borcu üstlenmektedir.

Müşterilerin satışı halinde, satıcı borcunu ifa etmez ise, alıcı TBK m. 112 gereğince tazminat talep edebileceği gibi, sözleşmeden de dönebilir (TBK m. 125/II)[40].

---

35 **Becker**, Art. 20, N. 18; OR-**Koller**, Art. 184, N. 39; **von Tuhr/Escher**, sh. 28; **von Tuhr/Peter**, sh. 264.

36 **Schönle**, Art. 184, N.166.

37 **Cavin**, sh. 14-15; **Engel**, sh. 13; **Schönle**, Art. 184, N. 60-61. Karş. **Giger**, Art. 187, N. 31.

38 **Keller/Siehr**, sh. 9; OR-**Koller**, Art. 184, N.12; **Engel**, sh. 14; **Schönle**, Art. 184, N. 63 vd.; **Giger**, Art. 184, N. 23; **Huguenin**, N.85.

39 **Cavin**, sh. 15. Ayrıca bk. **Karayalçın**, Ticarî İşletme, sh. 175.

40 **Schönle**, Art. 184, N. 67; SJZ 69, sh. 226, Nr. 97.

4. Gelecekteki eşya ve haklar

Satış sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut olmayıp ileride gerçekleşecek bir şey veya hak, satış sözleşmesine konu teşkil edebilir. Meselâ, ileride elde edilecek ürün, bir fabrikada ileride seri halinde imal edilecek eşyanın satışı, inşa edilmemiş bir binada kat mülkiyeti satışı veya müstakbel alacağın devri.

Gelecekteki bir şeyin satışında, ümit edilen bir şeyin satışı (meselâ, doğması beklenen yavrunun satışı) ile bizzat ümidin kendisinin satışını (bir piyango biletinin satışı, avlanacak balığın satışı) birbirinden ayırmak gerekir. Birinci halde, alıcı, şeyin miktar ve niteliğine ilişkin rizikoyu; ikinci halde ise hiç gerçekleşmemesinin riskini üzerine almaktadır[41].

Taraflar, mevcut olmayan bir şeyin satışını, gerçekleşme talikî şartına bağlı olarak yapabilirler. Bu yola başvurmadıkları takdirde, ümit edilen şeyin satışında satış konusunun ilerde gerçekleşmemesi halinde, sonraki imkânsızlık söz konusu olur (TBK m. 112 ve 136); ümit satışında ise, ümidin gerçekleşmemesi imkânsızlık olarak kabul edilemez.[42]

5. Üçüncü şahıslara ait şeyler ve haklar

Satış sözleşmesinin kurulduğu anda satıcıya ait olmayan şeyler ve haklar da satılabilir. Bu takdirde, satıcı borcunu ifa etmezse, TBK m. 27 anlamında imkânsızlık değil, geçerli bir sözleşmeden doğan borcun ifa edilmemesi söz konusu olur[43].

---

41 **Giger**, Art. 184, N. 27; **Bucher**, BT, sh. 63.

42 OR-**Koller**, Art. 184, N. 14; **Larenz**, Bd. II, sh. 8-9.

43 **Keller/Siehr**, sh. 9; **Giger**, Art. 184, N. 28; OR-**Koller**, Art. 184, N. 40; **Schönle**, Art. 184, N. 59.

§ 4. TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ

I. Konusu

Borçlar Kanunu'nun satışa ilişkin hükümleri, sözleşmenin konusuna göre, satış sözleşmesini taşınır satışı ve taşınmaz satışı olarak ikiye ayırmaktadır. Kanunun sistematiği itibariyle, her satış bu iki kategoriden birine girer ve özel bir düzenleme olmadıkça (alacak satışında tekeffülle ilgili TBK m. 193 vd. gibi), bunlara ait hükümlere tâbi olur[1]. Borçlar Kanununun ikinci kısmının 207. maddeyle başlayan 2. ayrımdaki hükümler, taşınır satışında doğrudan doğruya uygulama alanı bulurken, taşınmaz satışlarında da kıyas yoluyla uygulanır (TBK m. 246). Bu itibarla taşınır satışının konusunun tesbiti önem taşımaktadır.

Taşınır mal satışlarına ilişkin olarak kendi uygulama alanı olan Milletlerarası Mal Satışına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri söz konusu olmaktadır. Buna göre işyerleri farklı âkit devletlerde olan taraflar arasında kurulan mal satış sözleşmelerine milletlerarası özel hukuk kurallarının bu ülkelerden birinin hukukuna atıf yapması halinde CISG hükümleri uygulanır (m.1)[2].

CISG hükümleri, kişisel veya ailevi ihtiyaçlar için yapılan satışlara, açık artırma ile yapılan satışlara, cebri icra veya diğer bir kanun hükmü gereği yapılan satışlara, menkul kıymet, kambiyo senedi ve paraya ilişkin satışlara, deniz ve hava taşıtlarına ve elektrik satışına uygulanmaz (m. 2). Buna karşılık imal edilecek veya üretilecek malların sağlanmasına ilişkin sözleşmeler satış sözleşmesi olarak kabul edilmektedir (m. 3/1).

TBK m. 207'de zikredilen taşınır satışı ile MK m. 762'de sözü geçen taşınır eşya deyimleri örtüşmemektedir. Zira, taşınmaz dışında kalan diğer tüm satış konusu şeyler borçlar hukuku bakımından taşınır satışı sayılmaktadır.

TBK m. 209/I'e göre, "Taşınır satışı, Türk Medeni Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır."

---

1 OR-**Koller**, Art. 187, N. 1. Karş. **Schönle**, Art. 187, N.2.

2 CISG hükümlerinin uygulanmasında tarafların ilgili ülke vatandaşı olması, tacir olması ya da adi veya ticari iş kapsamında olması önem taşımamaktadır (m. 1/3)

Kanun koyucu, bu fıkra hükmüyle taşınır satışının konusunu olumsuz biçimde tanımlamakta ve taşınmaz satışının veya mülkiyetinin kapsamına girmeyen hususların, taşınır satışının konusunu teşkil edeceğini ifade etmektedir. Ancak, bu fıkrada nelerin taşınmaz satışının konusuna gireceği tam olarak belirtilmemiş bulunmaktadır. Aynı şekilde taşınmaz satışına ilişkin TBK m. 243 vd. da, taşınmaz satışının konusu hakkında hiçbir açıklamada bulunmamaktadır. Bu nedenle, taşınır satışının konusunu belirleyebilmek için, TBK m. 209'un eşya hukukuna ait hükümlerle (MK m. 684, 685, 704, 762 ve 998; KMK m. 13) tamamlanması gerekir[3]. Bu durumda konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için, önce taşınmaz satışının konusunu, sonra da taşınır satışının konusunu belirlemek uygun olur.

1. Taşınmaz satışının konusu

a) Arazi (MK m. 704/b. 1 ve 998/I, b. 1). Arazi, imar parseli şeklinde arsa olabileceği gibi, kadastral parsel ya da ham toprak (tarıma elverişli olmayan arazi) olarak da satışa konu edilebilmektedir.

b) Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen üst hakkı gibi bağımsız ve sürekli haklar (MK. m. 704/b.2 ve 998 b.2).

c) Kat mülkiyetinde bağımsız bölümler (KMK m. 13; MK m.704/b.3 ve 998/b.3)

3213 sayılı Maden Kanunu'nun 4. maddesine göre, "Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tâbi değildir". Aynı kanunun 1. maddesi gereğince madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması, Maden Kanunu hükümlerine tâbi tutulmuştur[4].

2. TBK m. 209 anlamında taşınır satışının konusu

Taşınır satışının konusunu:

a) Bir yerden diğer yere taşınabilen maddî (cismanî) şeyler ve taşınmaz mülkiyetine girmeyen ve mülk edinmeye elverişli doğal güçler (hava gazı, elektrik cereyanı) oluşturur (MK m. 762).

---

[3] **Giger**, Art. 187, N. 7. Ayrıca bk. **Schönle**, Art. 187, N.4 ve 7 vd.

[4] Madenler için ruhsat usulü benimsenmiştir. Arama ruhsatı ve işletme ruhsatları verilmektedir. Aynı alanda birden fazla ruhsat verilebilmektedir. Madenler I. Grup ile IV. Grup arasında çeşitli kategorilerde sınıflandırılmaktadır.

b) Temelli kalmak amacı olmaksızın başkasının arsası üzerine yapılan gazete büfeleri gibi kulübe ve baraka gibi hafif yapılar bu kapsamda sayılmaktadır (MK m. 728).

Yargıtay, hazineye ait arazi üzerinde yapılan gecekonduların satışını da bir kararında[5] taşınır satışı olarak değerlendirmiştir.

Kulübe, baraka, şantiye binası, akaryakıt pompası menkul inşaat niteliği taşıdığından taşınır eşya satışına konu olur. Banka veya döviz büfesinden döviz almak, trampa değil satış sözleşmesidir. Zira, karşı edim para olarak belirlenmiştir. Nitekim bunlar taşınır eşya sayılır[6].

Üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan tapusuz taşınmazın zilyetliğinin devrine ilişkin sözleşmeler, bir şekle bağlı olmaksızın yapılabilir; bunun için zilyetliğin devredilmiş olması da şart değildir[7]. Bu tür sözleşmeleri taşınır satışı olarak kabul etmek gerekir[8].

c) Ürünler, bir yapının yıkıntıları ve taş ocağından çıkarılacak olan taşlar gibi, taşınmazdan ayrıldıktan sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır (TBK m. 209/II).

Mütemmim cüzler (bütünleyici parça) asıl şeyin mukadderatını paylaşırlar. (MK m. 684/I); tabiî semereler de ayrılıncaya kadar asıl şeyin mütemmim cüzleridir (MK m. 685/III).

TBK m. 209/II hükmüyle hukukî anlamda taşınabilirlik ile maddî anlamda taşınabilirliğin ayrılmasının pratik yararı, tapu siciliyle ilgili formalitelere başvurmaksızın bütünleyici parçalarda yer alan değerleri kullandırmaktır. Asıl satılınca bütünleyici parça bu kapsamda satılmış olur. Başka bir ifadeyle, asıl şeyden ayrılmamış bütünleyici parçaların satışı gelecekteki taşınır eşya satışı olarak değerlendirilmektedir[9].

---

5 3. HD, 22.5.1953, E. 5171/K. 3550 (**Tandoğan** I/1, sh. 100, dn. 3). Yargıtay başka bir kararında (HGK, 11.12.1968, E. 968/ K. 827, ABD 1959, sh. 122), aksi sabit olmadıkça gecekondu satışlarında arazi üzerindeki zilyetlik hakkının da alıcıya devredilmiş olduğu kabul edilmelidir sonucuna varmıştır; Enerji satışı için ayrıntılı bilgi için bkz. **Ayrancı** (Enerji Sözleşmeleri), sh. 147 vd.

6 Serozan, 97.

7 **Oğuzman/Seliçi,** Eşya Hukuku, İstanbul 1997, sh. 303; **Sirmen**, Eşya Hukuku Dersleri, sh. 307; Yarg. HGK, 22.12.1982, E. 13-1905/K. 966 (YKD 1983, sh. 498 vd.).

8 Yarg. HGK, 11.3.1964 gün ve E. 5-3/K. 184, (**Olgaç**, Türk Borçlar Hukuku, C. II, İstanbul 1966, sh. 220, N. 147).

9 **Giger**, Art. 187, N. 19; OR-**Koller**, Art. 187, N. 4; ZBJV 102/1966, sh. 107; kesilecek ağaçlar: BGE 36 II 198.

d) Teferruat (Eklenti)

Aksi kararlaştırılmadıkça teferruat, bütünleyici parça gibi, satış açısından asıl şeyin akıbetini paylaşır (MK m. 686/I). Teferruatın tek başına satışı, niteliği icabı her zaman taşınır satışı şeklinde olur; asıl şey bundan etkilenmez. Teferruatın satışı, onun asıl şeyden kesin olarak ayrılmasını gerektirdiği takdirde, teferruat vasfı ortadan kalkar; bu sonuç MK 686/III'ten zıt kavram yoluyla çıkmaktadır[10].

e) Haklar

TBK m. 209/I anlamında taşınır kavramından alacak hakları ve mamelekî mahiyette imalât sırları, müşteri çevresi, know-how ve diğer maddî olmayan mallar üzerindeki hakların taşınır satışı sayılacağı sonucuna varılabilir. Alacak satışında ayıptan ve zapttan sorumluluk bakımından TBK m. 191/I ve II ve 193 hükümleri uygulanır. Diğer maddî olmayan mallar üzerindeki hakların satışında TBK m. 209-236 daki hükümler maddî malları şart kılmadığı ölçüde uygulanır. *Schönle*'ye göre[11], taşınır ve taşınmaz satışına girmeyen bu tür satışlara taşınır satışına ilişkin hükümlerin uygulanması MK m. 1/I, c. 2 çerçevesinde gerçekleşir.

f) Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında taşınır satışına ilişkin hükümler uygulanır

TTK m. 996'ya göre Kanunun mülkiyet ve diğer ayni haklara uygulanacak hükümler aksi düzenlenmedikçe sadece Türk Gemi Siciline kayıtlı gemiler bakımından caridir.

Bu sicile kayıtlı olmayan Türk gemilerine ilişkin mülkiyet ve sınırlı ayni haklara Türk Medeni Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanmaktadır (TTK m. 997)

g) Taşınırların taşınmazlarla birlikte satılması

Bir taşınmazın taşınırlarla birlikte satılması (meselâ, bir ticarethanenin, fabrikanın, eşyalarıyla birlikte ve üzerinde bulunduğu taşınmaz ile bir otelin satılması) halinde, taşınırlar taşınmazların teferruatı niteliğinde ise, satış sözleşmesinin TBK m. 237 gereğince resmî şekilde yapılması gerekir[12]. Taşınırların teferruat niteliği taşımamasına rağ-

---

[10] **Giger**, Art. 187, N. 22.

[11] Art. 187, N.9 vd.

[12] **Schönle**, Art. 184, N. 53.

men, taşınmazla birlikte aynı sözleşme çerçevesinde satılmaları halinde de, sözleşmenin resmî şekilde yapılması icap eder[13]. Akdin ifası açısından birinci ihtimalde, asıl şeyin mülkiyeti tescille alıcıya geçince, teferruat üzerindeki mülkiyet hakkı da teslime gerek olmadan alıcıya geçer (MK m. 686/I); ikinci ihtimalde, taşınmazlarda tescil, taşınırlarda teslim şarttır. Her iki ihtimalde de, zapta ve ayıba karşı tekeffül ile hasarın geçişi bakımından taşınır ve taşınmazlara, ait oldukları satış türüne ilişkin hükümler ayrı ayrı uygulanır[14]. Örneğin taşınırın ayıplı olması halinde taşınır satışına ilişkin ayıptan doğan sorumluluk hükümleri uygulanır.

II. Şekli

Taşınır satış sözleşmesinin geçerliliği, kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlı değildir (TBK m. 11). Bununla beraber, taraflar bu sözleşmenin belirli bir şekilde yapılmasını kararlaştırdıkları takdirde, kararlaştırılan şekle uyulmadan yapılan sözleşme geçersiz olur (TBK m. 16/I).

Bununla birlikte, bazı özel kanun hükümleriyle, bir kısım taşınır satış sözleşmelerinin, geçerlilik açısından şekil şartına bağlandığı görülmektedir. Bu hükümler şunlardır:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 52 gereğince, eser üzerindeki "malî haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır"; Markaların Korunması Hakkında KHK m. 15 ve 16/III uyarınca, markaların devri yazılı şekilde yapılmak zorundadır; Endüstriyel tasarımlar ve patentler için aynı kural geçerlidir; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m. 57'ye göre, alıcı "noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermekle yükümlüdür". Aynı şekilde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 46/I'e göre bu kanun hükümlerine tabi olanlarda, "yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

---

[13] **Oser/Schönenberger** Art. 187, N. 11; **Giger**, Art. 187, N. 37; OR-**Koller**, Art. 187, N.9; **Tandoğan** I/1, sh. 102-103.

[14] **Oser/Schönenberger**, Art. 187, N. 11; **Giger**, Art. 187, N. 35; **Schönle**, Art. 184, N. 53 ve Art. 187, N. 7.

Şirket ortaklık payının devri noterde yapılır. Ortaklık payı kıymetli evraka bağlanmışsa, hamiline senet teslimle, nama yazılı senet temlik ile, emre yazılı senet ciro ve teslim ile devredilir.

Karayolları Trafik Kanunu m. 20/d'ye göre trafik siciline kayıtlı her türlü motorlu taşıt araçlarının satış ve devirleri noterlikçe düzenlenen sözleşmeyle yapılır[15]. Trafik siciline yapılan tescil bildirici mahiyet taşımaktadır.

Buna karşılık, Ticari bir işletmenin satışında şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak, ticari işletmeyi oluşturan çeşitli satılanların tabi olduğu şekil kuralının uygulanması gerekir. Örneğin ticari işletme bir taşınmazı da içeriyorsa ticari işletme tapuda resmi şekilde satışa konu edilebilir. Ticari işletme motorlu araç içeriyorsa, satış buna ilişkin şekle tabi olmalıdır[16].

Taşınır satışında şekilsizliğin sakıncalarını önlemek amacıyla, TTK m. 21/III'te tacirler bakımından şu hüküm öngörülmüştür: "Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır". Böylece teyit mektuplarının yazılı olması şartı getirilmiştir.

---

15 Trafik siciline kayıtlı olmayan araçlarda âdi yazılı belgeyle satışın yeterli olduğu hakkında bk. 13. HD, 25.5.1992, E. 3983/K. 4898: "Davacı ile davalı Arslan arasında 8.9.1988 tarihli düzenlenmiş protokole göre dava konusu trafikte kayıtlı olmayan traktörün adı geçen davalı tarafından davacıya devir ve teslim edildiği ve davacının zilyetliğine geçtiği anlaşıldığı gibi esasen davalı Aslan da bu yönü kabul etmektedir. Traktörün trafik kaydı ve plakası bulunmadığından menkul bir mal gibi satışı ve zilyetliğin devriyle mülkiyeti davacıya geçer. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın 20/d maddesi gereğince ancak trafikte kayıtlı araçların noterde satışı gerekli olup, henüz kayıt ve tescil araçların adi bir belgeyle satışı ve mülkiyetin nakli mümkündür" (YKD 1992, sh. 1232-1233); HGK, 21.6.1995, E. 15-411/ K. 644 (YKD 1995, sh. 5 vd.).

16 **Gümüş**, 58.

§ 5. TAŞINIR SATIŞINDA YARAR VE HASARIN GEÇMESİ

I. Hasarın geçmesi

1. Hasar ve hasarın geçmesi kavramları

a) Hasar kavramı

Hasar (Gefahr, risque, periculum), satılanın, taraflardan herhangi birinin sorumlu olmadığı sebeplerden dolayı telef olması veya değerinin azalmasıdır[1]. Tarafların sorumlu olmadığı sebepler mücbir sebep ve umulmayan hal şeklinde olabilir. Meselâ, genel grev sebebiyle taşınamayan şeyin kısmen veya tamamen bozulması; İsviçre'nin Basel şehrindeki bir kolleksiyoncunun Yakohama'daki birinden satın aldığı Japon el basmalarının, alıcının kabul mektubunun satıcıya ulaşmasından birkaç saat sonra zelzele sonucu tahrip olması[2]. Aynı şekilde, üçüncü bir şahsın davranışı yüzünden satılanın tahrip olması (malın bulunduğu yerin kundaklanması) veya çalınması ve çalınan şeyin ve hırsızın bulunamaması halinde, TBK m. 208 anlamında hasar söz konusu olur[3]. Ancak bu halde satılanın hasara uğraması, satıcının özen eksikliğinden kaynaklanmamalıdır.

Hasar, satılan şeyin ifasını tamamen veya kısmen imkânsız kılabilir (TBK m. 136). Satılanın tamamen ortadan kalkması veya istimlâk yahut müsadere edilmesi halinde tam imkânsızlık söz konusu olur[4]. Satılanın bir kısmının telef olması (meselâ, on kitaptan üçünün yanması) durumunda kısmî imkânsızlık olgusu gerçekleşmiş olur.

Mücbir sebep (genel grev vb.) sonucu taşımanın gecikmesi sebebiyle saklananın bozulması da TBK m. 208 anlamında hasar sayılır.

---

1 **Keller/Siehr**, sh. 23 vd.; **Giger**, Art. 185, N. 7. Ayrıca bk. **Cavin**, sh. 34.

2 Sem Jud. 1926, sh. 433.

3 **Schönle**, Art. 185, N. 19; **Weber**, Art. 71, N. 57; **Bucher**, AT, sh. 248; **Engel**, Traité, sh. 477. Aksi fikirde olan **Giger**'e göre (Art. 185, N. 7) beşerî davranışlar ve üçüncü kişilerin müdahalesi kaza (Zufall), dolayısıyla hasar sayılmaz.

4 OR-**Koller**, Art. 185, N.4. Ayrıca bk. **Cavin**, sh. 34.

Bu durumda, değer azalması (kötüleşme) şeklinde bir hasar söz konusu olur[5].

b) Hasarın geçmesi kavramı

Hasarın geçmesi, sözleşmenin kurulması ile ifa edilmesi (teslim) anları arasında satılanın hasara uğramasından dolayı sorumlu olmayı ifade eder. Başka bir ifadeyle, hasarın geçmesi, sözleşmenin kurulması ile ifa edilmesi süresi içinde, satılanın taraflara yüklenemeyen, onların sorumlu olmadığı bir sebeple satılanın yok olması veya kötüleşmesinin sonuçlarından sorumlu olmaktır[6]. Buna göre, hasarın geçmesi, satılanın hasara uğraması dolayısıyla ortaya çıkan mamelekî azalmaya, yani zarara hangi tarafın katlanacağının veya hasarın hangi tarafın malvarlığını azaltacağının belirlenmesidir[7].

Konunun tam olarak anlaşılabilmesi için, maddî edim hasarı (Sachleistungsgefahr) ile bedel (semen) hasarı (Kaufpreisgefahr, Preisgefahr) kavramlarının açıklanması gerekir[8].

Maddî edim hasarı, alıcının, ayıpsız bir satış konusu şeyin mülkiyetinin ve zilyetliğinin geçirilmesine ilişkin talep hakkını, ikinci derecede (tali) edim yükümü şeklinde bir tazminat hakkına sahip olmaksızın kaybedip etmeyeceği sorusuna cevap vermektedir[9]. Başka bir ifadeyle, maddî edim hasarı, edim konusunun yok olmasına veya kötüleşmesine rağmen, satıcının gereği gibi ifa ile yükümlü olup olmayacağı sorusuna ilişkindir[10]. Bu durumda satıcının gereği gibi ifa yükümü (ister aslî edim yükümü, ister onun yerine geçen tazminat yükümü şeklinde olsun) devam ediyorsa, maddî edim hasarı satıcıdadır; aksi halde alıcıdadır[11].

Maddî edim hasarı, hem tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, hem iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ortaya çıkabilir[12].

---

5 **Cavin**, sh. 34; OR-**Koller**, Art. 185, N.7.

6 **Keller/Siehr**, sh. 24; **Giger**, Art. 185, N. 8 ve 9.

7 **Giger**, Art. 185, N. 9; **Tandoğan** I/1, sh. 106. Ayrıca bk. **Schönle**, Art. 185, N. 14.

8 **Schönle** (Art. 185, N. 15 vd.), şeye ilişkin hasar, maddî edim hasarı ve bedel hasarı şeklinde üçlü bir ayırım yapmaktadır.

9 **Schönle**, Art. 185, N. 18.

10 OR-**Koller**, Art. 185, N. 11; **Giger**, Art 185, N.11; **Tandoğan** I/1, sh. 106-107.

11 **Schönle**, Art. 185, N. 18 ve 19; **Kocayusufpaşaoğlu**, sh. 57.

12 **Tandoğan** I/1, sh. 107.

Bedel hasarı ise, satış sözleşmesi gibi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ortaya çıkar. Bunun için maddî edim hasarının alacaklıya (alıcıya) geçmesi gerekir. Buna göre satış sözleşmesinde bedel (semen) hasarı, satılanın hasara uğraması sebebiyle satıcının gereği gibi ifa yükümünden kurtulmasına rağmen, alıcının satış bedelini tamamen ödemek zorunda olmasıdır[13].

TBK m. 208/I'de geçen "satılanın.... hasarı" deyiminden sadece bedel (semen) hasarı anlaşılır[14]. Bu itibarla, aşağıdaki açıklamalarımızda, başka türlü ifade edilmediği takdirde, hasar kelimesi, bedel (semen) hasarı anlamında kullanılmaktadır.

2. Hasarın geçtiği an

a) Kural

Yeni Borçlar Kanunu'nun 208. maddesinde, hasarın geçiş anı konusunda, eski BK m. 183'de öngörülen, sözleşmenin kurulmasıyla hasarın alıcıya geçeceği ilkesinden farklı bir düzenleme getirilmiştir. Gerçekten TBK m. 208/I'e göre, "kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir". Böylece satılanın mülkiyetinin zilyetliğin geçirilmesi veya tescil ile alıcıya geçmesi anına kadar hasarın, kural olarak satıcıya ait olacağı ilkesi benimsenmiştir. Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği gibi, alıcıyı henüz maliki ve zilyedi olmadığı satılanın hasarından sorumlu tutan eski düzenlemenin yarattığı hakkaniyete aykırı durumun terk edilmesi isabetli olmuştur. Sonuç olarak, esas itibariyle hasara ilişkin bu tür bir rizikoyu mülkiyet sahibi taşımaktadır (casum sentit dominus). Satılanın teslimden sonra yok olması veya değerinin azalması halinde alıcı bu riski üstlenir. Bu durumda satış bedelini ödemekle yükümlüdür. Yeni düzenleme ile satış konusunun parça borcu veya cins borcu olmasına bakılmaksızın hasarın geçiş anı belirlenmektedir.

TBK m. 208'e göre, maddi edim hasarı (ifa yükümü asli edim veya yerine geçen tazminat şeklinde) zilyetliğin devrine kadar satıcıda, devirden sonra alıcıdadır; bedel hasarı (satıcının ifa yükümünden kur-

---

[13] **Schönle**, Art. 185, N. 31; **Giger**, Art. 185, N. 12 ve 13; **Tandoğan,** I/1, sh. 107; **Kocayusufpaşaoğlu**, sh. 58-59.

[14] **Schönle**, Art. 185, N. 15; OR-**Koller**, Art. 185, N. 1 ve 11.

tulmuş olmasına rağmen alıcının bedeli ödeme yükümlülüğü) zilyetliğin devrinden itibaren alıcıda, bu ana kadar satıcıdadır.

Buna göre, parça satışlarında kural aynen uygulanır. Satılanın taraflara atfı kabil olmayan sebeplerle yok olması ya da kötüleşmesi halinde zilyetliğin devrinden önce maddi edim hasarı satıcıdadır. Zira, o ifayı yerine getirmek zorunda değildir. İfa yerine bir tali edim (tazminat) yerine getirme borcu da bulunmamaktadır. Bedel hasarı da satıcıdadır. Çünkü alıcı bedel ödeme yükümlülüğü altında değildir.

Cins satışlarında cins yok olmayacağından zilyetliğin devrinden önce maddi edim hasarı satıcıdadır. Alıcı asli edimi ya da yerine geçecek tali edimi talep edebilmektedir. Satıcının ifa yükümlülüğünden kurtulması mümkün olmadığından cins satışlarında bedel hasarının değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

b) İstisnalar

Yeni TBK m. 208/I'de, yukarıda açıklanan kuralın, kanundan, durumun gereğinden veya sözleşme ile aksinin kararlaştırılmasından doğan istisnai hallerde, uygulanmayacağı öngörülmüştür.

aa) Kanundan doğan istisnalar

Yeni TBK m. 208/II'de, taşınır satışlarında, alıcının, satılanın zilyetliğini devralmakta temerrüde düşmesi halinde, zilyetliğin devri gerçekleşmiş gibi hasarın alıcıya geçeceği esası kabul edilmiştir.

Borçlar Kanunu dışında başkaca kanunlarda satış sözleşmesinde hasarın sözleşmenin kurulması ile alıcıya geçeceğini öngören özel bir hükmün bulunması halinde bu hüküm uygulanır. TBK m. 245 taşınmaz satışında yarar ve hasarı düzenlemektedir. Hükme göre satılanın tescilinden sonraki bir zamanda teslimin gerçekleşeceği kararlaştırılmışsa yarar ve hasar teslimle geçmektedir.

bb) Durumun gereğinden doğan istisnalar

Durumun gereği, sözleşmede hüküm bulunmamasına rağmen, hasara satıcının katlanmasını haklı gösteren özel durumları ifade eder; burada sözleşmenin hakkaniyet düşüncesiyle tamamlanması söz konusudur[15]. Bu hükmün dar yorumlanması gerekir.

---

[15] **Tercier**, N. 489; **Engel**, sh. 54-55; **Schönle**, Art. 185, N. 64.

cc) Sözleşmeden doğan istisnalar

TBK m. 208 hükmü bir yedek hukuk kuralıdır. Bu itibarla taraflar, bu maddede öngörülen hasarın geçmesine ilişkin esasları sözleşmeyle değiştirebilirler[16].

Uluslararası satışlarda, özellikle deniz aşırı satışlarda, hasarın geçişine ilişkin esaslar sözleşmeyle düzenlenir. Genellikle taraflar, bu tür satışlarda zilyetliğin geçirilmesi, satış bedelinin ödenmesi ve hasarın geçişi hususlarında uluslararası ticarette kullanılan ticarî kayıtlara yer verirler. Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), uluslararası sözleşmelerde kullanılan başlıca ticarî kayıtların yorumuna ilişkin kurallar koymuştur. En son 2007 yılında revize edilen bu kurallar, ICC'nin 600 numaralı Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama yayınında yer almaktadır. (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision, "International Commercial Terms", "International Rules for the Intepretation of Trade Terms")[17]. Bu kurallar, taşıma masrafları ve sigorta yükümlerinden başka, taşıma esnasındaki hasarın geçişine ilişkin esasları da düzenlemektedir. Buna göre, SİF ve FOB satışlarda hasar, satılan malın yükleme limanında geminin küpeştesine geçtiği anda alıcıya geçer[18].

Franko (masrafsız) teslim kaydı, tek başına hasarın geçişine ilişkin anlaşma sayılmaz ve hasarın teslime kadar satıcıda olduğu anlamına gelmez. Bu kayıt sadece taşıma masraflarına ilişkindir[19].

c) Mesafe satışlarında

Mesafe satışı (Distanzkauf), tarafların, satılanın kanunî ifa mahallinden başka bir yere gönderilmesini kararlaştırdıkları bir satışdır[20].

---

16 **Schönle**, Art. 185, N. 69; OR-**Koller**, Art. 185, N. 41; **Bucher**, sh. 80; **Giger**, Art. 185, N. 81.

17 Bu konuda bk. **Eisenmann/Derains**, la pratique des Incoterms, Usages de la vente internationale Toulouse 1988; Hasarın intikali CISG m. 66-70 arasında düzenlenmektedir.

18 **Schönle**, Art. 185, N. 76 ve 77; **Keller/Siehr**, sh. 26.

19 **Schönle**, Art. 185, N. 118; OR-**Koller**, Art. 185, N. 43; **Keller/Siehr**, sh. 26; **Honsell**, sh. 44.

20 Bkz. **Giger**, Art. 185, N. 38; **Keller/Siehr**, sh. 18; **Cavin**, sh. 39; TKHK m. 48'de mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin aynı zamanda birarada bulunmadan mal veya hizmete ilişkin anlaşmanın yapıldığı işlemler olarak kabul edilmektedir. Bu tür sözleşmeler için bkz. § 13, V.

TBK m. 208/III'e göre "satıcı alıcının isteği üzerine satılanın ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer". Böylece, mesafe satışında gönderilecek borçlarda hasarın geçişi satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçeceği kuralı kabul edilmiştir.

II. Yararın geçmesi

Yarar (Nutzen; profits), kendiliğinden veya her malikin normal olarak yapacağı faaliyetler sonucu satılanda meydana gelen her türlü fazlalıklar veya fazla değerdir[21]. TBK m. 208 anlamında yarar kavramına tabiî ve medenî semereler ile bir şeyin normal kullanılması sonucu elde edilebilen diğer istifadeler girer[22]. Meselâ, satılan hayvanın yünü, sütü, yumurtası, doğan yavrusu, kira gelirleri, tahvillerin faizi veya hisse senetlerinin temettü gelirleri. Adi kira veya hasılat kirasının, yararın geçtiği an itibariyle bölünmesi gerekir (pro rata temporis) (MK m. 805)[23].

Satılanın hasara uğraması sebebiyle sigortacıya veya üçüncü şahıslara (meselâ taşıyıcıya) karşı ileri sürebileceği talepleri (stellvertretendes commodum) de yarar olarak kabul etmek gerekir[24]; alıcı, bunların kendisine devrini talep edebilir.

Kanun koyucu, hakkaniyet düşüncesiyle hasar ve yararın geçmesi olguları arasında bir paralellik kurmuştur (TBK m. 208 ve 245). Yarar da hasarın geçtiği andan itibaren alıcıya aittir. Bunun tek istisnası, talikî şarta bağlı satışlarda satılanın şartın gerçekleşmesinden önce alıcıya teslim edilmiş olması halidir (TBK m. 172/I)[25]. Ancak, bu istisna, şartın gerçekleşmesi ihtimalinde bir değer taşır (TBK 172/II).

---

21 **Giger**, Art. 185, N. 68; **Cavin**, sh. 31; **Oser/Schönenberger**, Art. 185, N. 1.

22 **Schönle**, Art. 185, N. 6; **Giger**, Art. 185, N. 68; **Tandoğan** I/1, sh. 105.

23 **Giger**, Art. 185, N. 68; **Tercier**, N. 479.

24 **Giger**, Art. 185, N. 70-71; **Honsell**, sh. 43; **Bucher**, BT, sh. 81. Aksi fikirde: **Schönle**, Art. 185, N. 7.

25 **Giger**, Art. 185, N. 72; **Keller/Siehr**, sh. 27-28.

§ 6. SATICININ BORÇLARI

I. Satıcının aslî borçları

TBK m. 207/I'e göre, satıcının iki aslî borcu vardır. Bunlardan biri satılanın zilyetliğini devir, diğeri mülkiyeti geçirme borcudur.

1. Satılanın zilyetliğini geçirme borcu

a) Zilyetliğin geçirilmesi kavramı

Satıcının satılanın zilyetliğini geçirme borcu TBK m. 207/I'den başka, TBK 210. maddede de ayrıca düzenlenmiştir. TBK m. 210'a göre, "satıcı satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla, zilyetliğini alıcıya devretmekle yükümlüdür"[1]. Bu sonuncu madde hükmünün TBK m. 207/I karşısında yeni ve farklı bir şey getirdiğini söylemek mümkün değildir; sadece bir tekrardan ibarettir. Kanun koyucunun TBK m. 207/I ve 210 hükümlerinde, teslim yerine, zilyetliğin devri deyimini kullanması, gerekçede de ifade edildiği gibi, teslim dışında kalan diğer zilyetliğin devri hallerinin de yeterli olabileceği anlamına gelmektedir. Ancak zilyetliğin devrinin teslim dışındaki yollarla yani teslimsiz devrinin (kısa elden teslim ve hükmen teslim gibi) gerçekleşebilmesi için bazı özel şartların bulunması ve tarafların da bu konuda anlaşmış olmaları gerekir (BGB § 929).

Alacak ve hak satışında, yukarıda anlatılan anlamda zilyetliğin devri söz konusu olmaz. Bir maddî şeyin zilyetliğinin devrine ilişkin alacak satışında, satıcının borcu, şeyin zilyetliğinin devri değil, hakkı sağlamaktır; alıcı hakkı elde edemezse, satıcı hale göre, alacağın devrinde garanti yükümlülüğünü ve bundan sorumluluğu düzenleyen TBK m. 191–193 gereğince sorumlu olur[2]. Satılan hak bir kıymetli evrakta tecessüm etmişse, hakkın devri kıymetli evrakın teslimini şart kılacağı için, teslim borcu, hakkı geçirme borcuyla kaynaşmış olur[3].

---

1 Satış konusu malın malın teslim edildiğine ilişkin ispat yükü satıcının üzerindedir (Y. 19. HD. 2014/14716 E. 2015/553 K. –Kazancı-)

2 OR-**Koller**, Art. 184, N. 59.

3 OR-**Koller**, Art. 184, N. 59.

CISG m. 30'a göre, satıcı malları teslim etmek, bunlara ilişkin belgeleri vermek ve malların mülkiyetini geçirmekle yükümlüdür.

b) İfa yeri

Satılanın zilyetliğini geçirme borcunun ifa yeri, taraflar aksini kararlaştırmadıkları takdirde, TBK m. 89'da öngörülen yedek hukuk kurallarına göre belirlenir. Buna göre, ifa yeri, parça satışında, akdin kurulduğu anda satılan şeyin bulunduğu yer (TBK m. 89/b. 2); çeşit satışında ise, akdin kurulduğu andaki satıcının ikametgâhıdır (TBK m. 89/b. 3). Böylece, aksine bir anlaşma bulunmadığı sürece, satılanı teslim borcunun ifa yeri, hiçbir zaman alıcının ikametgâhı olmayıp, bu borç daima aranılacak bir borçtur[4]. Bununla beraber, taraflar satıcının zilyetliğini geçirme borcunu, götürülecek bir borç olarak kararlaştırabilirler. Mesafe satışlarının söz konusu olduğu böyle bir durumda, satıcı zilyetliği geçirme borcunu alıcının ikametgâhında veya kararlaştırılan başka bir yerde ifa etmek zorundadır. Satıcının zilyetliğini geçirme borcunun bir gönderme borcu (Schickschulden) olarak kararlaştırılması halinde ise, ifa yeri gönderme yeri, yani satılanın tarafsız taşıyıcıya teslim edildiği yerdir.

Para borçlarında alacaklını ödeme zamanındeki yerleşim yeri ifa yeri olarak belirlenmiştir (TBK m. 89/I/1)[5].

c) Devir masrafları

TBK m. 211'e göre, aksine âdet veya sözleşme mevcut değilse, ölçmek ve tartmak gibi teslim masrafları satıcıya aittir. Madde metninde yer alan "gibi" edatından da anlaşılacağı üzere, satıcının katlanacağı teslim masrafları ölçme ve tartma masraflarıyla sınırlı değildir. Bu cümleden olarak, aranacak borçlarda, satılan malın korunması için gerekli paketleme masrafları satıcıya aittir.[6] Aynı şekilde, gönderilecek ve götürülecek borçlarda, taşımaya elverişli paketlemenin masraf-

---

4 **Keller/Siehr,** sh. 18; **Bucher**, BT, sh. 70; **Engel**, sh. 19. CISG m. 31 ifa yerini kendi uygulama alanı bakımından düzenlemiştir.

5 Örneğin taşıma ücreti, para borcu olduğundan götürülecek borçtur. Bu borçlarda yetkili icra dairesi dahi ifa yerine göre belirlenmektedir (Yargıtay 11. HD'nin 29.9.2003 tarih ve E. 2003/2453 K. 2003/8521; 13. HD'nin 22.10.1982 tarih ve E. 1982/5443 K. 1982/6196 T. 22.10.1982) sayılı kararları.

6 Bkz. **Schönle**, Art. 188, N. 10; **Giger**, Art. 188, N. 13; OR-**Koller**, Art. 188-189, N. 9; BGE 96 II 118.

larına satıcı katlanacaktır[7]. Buna karşılık, satılanı devir almak üzere yapılan giderler alıcıya aittir (TBK m. 211/I).

d) Taşıma masrafları

TBK m. 211/I'e göre, "Aksine sözleşme ve adet yoksa, ölçme ve tartma gibi devir giderleri satıcıya, satılanı devralmak üzere yapılan giderler ve satılanın ifa yerinden başka yere taşınması gerektiğinde, taşıma giderleri alıcıya aittir". Satılanın zilyetliğinin ifa yerinden başka yerde devrinin kararlaştırıldığı satışlarda, satıcının zilyetliği devir borcu, gönderme borcu (Schickschulden) veya götürme borcu (Bringschuld) şeklinde olabilir. Bu iki tür borcu ihtiva eden satışları nitelendirme konusunda terim birliği bulunmamaktadır. Gönderme borcunu ihtiva eden satış akdine basit mesafe satışı, götürme borcunu ihtiva edene de mevsuf mesafe satışı adı verilmesi önerilmektedir[8].

Satıcının taşıyıcıyla sözleşme yaparak satılanın ifa yerinden başka yere gönderilmesini taahhüt etmesi, satış sözleşmesine ait bir yan yüküm ve gönderilecek borç teşkil eder; bu borca vekâlet sözleşmesine ilişkin TBK m. 502 vd. ndaki hükümler uygulanır[9]. Bu takdirde, taşıyıcıya teslime kadar yapılacak masraflar satıcı tarafından karşılanır; bizzat taşıma masrafları ise, aksine âdet veya sözleşme olmadıkça, alıcıya aittir[10].

Buna karşılık, satıcının satılanı ifa mahallinden başka bir yerde teslimi götürülecek borç olarak üstlenmesi halinde, taşıma masrafları satıcıya aittir[11].

Masrafsız (franko) teslim şart edilmişse, satıcı taşıma masraflarını üzerine almış sayılır (TBK m. 211/II). Franko deyimi, masraftan muafiyeti ifade etmekle beraber, anlamı eklenen kelimeye göre değişir. Meselâ, franko vagon kaydı, satıcının vagona kadar taşıma ve vagona yükleme masraflarını üzerine aldığını gösterir[12].

---

7 **Schönle,** Art. 188, N. 11. Aksi fikirde: **Cavin**, sh. 42. **Koller**'e göre (Art. 188-199, N. 9), ifa yerine gönderilmek üzere paketleme masrafları satıcıya, taşıma için gerekli ambalaj masrafları alıcıya aittir.

8 **Tercier,** N. 183; **Schönle,** Art. 189, N. 14; **Enneccerus/Lehmann**, sh. 417.

9 **Schönle**, Art. 189, N. 15.

10 **Schönle**, Art. 189, N. 16; OR-**Koller**, Art. 188-189, N. 11; **Bucher**, BT, sh. 70; **Weber**, Art. 74, N. 45.

11 **Keller/Siehr,** sh. 18, 19-20; **Weber**, Art. 74, N. 39.

12 **Tandoğan,** I/1, sh. 125.

TBK m. 211/III'te yer alan yedek hukuk kuralına göre, liman ve gümrük gideri olmadan devrin öngörüldüğü hallerde satıcı, dış satış, transit ve dış alım vergilerini üzerine almış sayılır. Fakat bununla malın teslim alındığı zaman ödenmiş olan tüketim vergisi üstlenilmiş sayılmaz. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre (m. 8-9), katma değer vergisinin mükellefi satıcı olup, alıcı ayrıca satış sırasında ve paranın ödenmesinden önce kabul etmiş olmadıkça ona rücu edilemez ve ondan tahsil edilemez; alıcı bunu kabul etmezse, satıcı malı satmayabilir[13].

TBK m. 211/II ve III'de düzenlenen bu kayıtların yanında, özellikle uluslararası veya deniz aşırı satışlarda, bu konuda başka kayıtlar da bulunmaktadır. Milletlerarası Ticarî Terimlerde (Incoterms 1990) uluslararası ticarette kullanılan başlıca kayıtlar tanımlanmış bulunmaktadır. Tip veya standart sözleşmelerde bunlara yollama yapılmaktadır. Bu hususta en çok kullanılan kayıtlar şunlardır:

CIF (SİF) = Cost (malın değeri) + Insurance (sigorta primi) + Freight (navlun): satıcı, yükleme, teslim yerine kadar taşıma ve sigorta primlerini ödemeyi üstlenir.

FOB = (Free on Bord): Satıcı yükleme dahil, mal geminin küpeştesine geçinceye kadarki taşıma yani gönderme masraflarına katlanır.

FOR/FOT = (Free on Rail, Free on Truck): Satıcı satılanın taşıyıcıya teslimine kadar yapılacak masrafları üstlenir.

2. Satılanın mülkiyetini geçirme borcu

TBK m. 207/I gereğince, satıcı, satılanın mülkiyetini alıcıya geçirmekle yükümlüdür. Daha önce de belirtildiği gibi, kanunun bu ifade şekli dar olup, mülkiyet hakkına konu teşkil etmeyen alacak ve hakların satışını kapsamamaktadır. Bu itibarla, satılan hakkı geçirme yükümünden bahsetmek daha isabetlidir[14].

Taşınır mülkiyetinin alıcıya geçebilmesi için, satılanın zilyetliğinin bu amaçla alıcıya geçirildiği konusunda tarafların anlaşmaları, yani bir aynî akit (dingliche Vertrag) gerekir[15] (TBK m. 210).

---

[13] Yarg. 13. HD, 11.4.1989, E. 533/K. 2502 (**Uygur,** C. 3, sh. 240-241).

[14] OR-**Koller,** Art. 184, N. 60; **Keller/Siehr,** sh. 15; **Honsell,** sh. 34.

[15] **Liver,** SPR, sh. 318, dn. 3; **Schönle,** Art. 184, N. 70; OR-**Koller,** Art. 184, N. 63 ve 65; **Bucher,** BT, sh. 73. Aksi fikirde: **Giger,** Art. 184, N. 12. Müteredit: **Honsell,** sh. 36.

Alacak satışında hakkın geçirilmesi temlikle (TBK m. 183 vd.) gerçekleşir. Hak mertebesine ulaşmamış fiilî faydaların (faktische Vorteil) satışında ise devir (ifa) işlemi, bunların alıcının tasarrufuna arzedilmesi veya alıcıya ait olmaları için gerekenlerin yapılmasıyla gerçekleşir[16].

II. Diğer borçlar

1. Yan yükümler

Yan yükümler, satıcıya, teslim ve mülkiyeti geçirme borcunu tam olarak ifa edebilmesi ve alıcının edimden yararlanabilmesi için gerekli her şeyi yapma borcu yükler[17]. Bu yükümler, sözleşmeden, kanundan (TBK m. 189/II, 211ve 226/III) veya dürüstlük kuralından (MK m. 2) doğarlar. Bu cümleden olarak, satıcı, satılanı teslime hazır hale getirme (ayırma, ambalajlama), teslime kadar muhafaza, gönderme, bilgi verme, işbirliği yapma, açıklama yapma ve sağlama yan yükümlerini yerine getirmek zorundadır[18]. Satıcının teslim ve taşıma masraflarına ilişkin borçları, pedagojik mülahazalarla, teslim borcu ile ilgili kısımda açıklanmıştır.

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)[19], bu kanunun uygulanma alanına giren olaylar açısından bazı yan yükümler öngörmektedir. Gerçekten bu kanunun 55. maddesine göre, tüketiciye sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımlarını ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunludur. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanmasına ilişkin sorumluluk üretici ve ithalatçıda iken, bunların tüketiciye verilmesi ve verildiğinin ispat sorumluluğu satıcıya yüklenmiştir. Malın güvenli kullanımına ilişkin yazılar ile kişi sağlığı, çevreye zararlı veya tehlike riski bulunması halinde yazı ve uyarıların usul ve esasları da belirlenmiştir. Hangi tür malların tanıtma ve kullanım kılavuzu ile etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunların asgari içeriği Yönetmelik-

---

16 **Schönle,** Art. 184, N. 72-74; OR-**Koller**, Art 184, N. 60 ve 66.

17 OR-**Koller**, Art. 184, N. 70; **Giger**, Art. 184, N. 49; **Tercier**, N. 189; BGE 43 II 665 vd.

18 Geniş bilgi için bkz. **Giger,** Art. 184, N. 48 vd., 112 vd.; **Schönle,** Art. 184, N. 76 vd. 79; **Keller/Siehr,** sh. 18 vd.

19 TKHK m. 87'ye göre Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Kanun Resmi Gazete 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı nüshada yayınlanmıştır.

le belirlenecektir. Bu konuda Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Yayımlanmıştır (RG. 13.6.2014, s. 29029).

Aynı şekilde TKHK m. 58 ile imalatçı ve ithalatçılara, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için, o malın Bakanlıkça tesbit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunma zorunluluğu getirilmiştir[20].

2. Koruma yükümleri

Bu yükümler gereğince, satıcı, alıcının edim menfaati dışında kalan depolama ve korumaya ilişkin diğer masrafları karşılama gibi her türlü şahıs ve malvarlıklarını zarardan uzak tutmak zorundadır. Koruma yükümleri esas itibariyle dürüstlük kuralından kaynaklanmaktır.

TKHK m. 55'te bu tür bir yükümle ilgili hüküm yer almaktadır: "Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. (f.3). Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir "(f.5).

III. Satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesi

1. Genel Hükümler

Satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesi halinde, alıcı, özel hükümlerin münhasır uygulanması söz konusu olmadıkça,

---

[20] Tüketici ihtilafları, ihtilaf konusunun değerinin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2.200 Türk Lirasının altında bulunması halinde ilçe tüketici hakem heyeti, 3.300 Türk Lirasının altında bulunması halinde il tüketici hakem heyeti; 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırları olduğu düzenlendiğinden büyükşehir statüsü olan illerde 2.200 ile 3.300 Türk Lirası arasında olması halinde il tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekmektedir. Başvurular tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yer hakem heyetine yapılır. Bu miktarların üzerindeki ihtilaflarda mahkemeler yetkilidir (TKHK m. 68/1, 3). Tüketici hakem heyeti kararlarının tebliğinden itibaren on beş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz da bulunulabilir. Tüketici mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karar kesindir (m. 70/3, 5). Ayrıca bkz. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği RG 27.11.2014 tarih ve 29188 sayı m. 6, 28).

Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine dayanarak aynen ifa ve tazminat davası açabilir (TBK m. 112 vd.)[21].

2. Özel hükümler

Satış akdinde satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesinin sonuçları, Borçlar Kanunu'nun özel hükümlerinde bazı hususlarda ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlar satıcının temerrüdü (TBK m. 212-213); zapta karşı tekeffül (TBK m. 214 vd.) ve ayıba karşı tekeffül (TBK m. 219 vd.) konusundaki hükümlerdir. Bu özel düzenlemeler aşağıda ayrı birer paragraf içinde incelenmiştir.

---

[21] CISG m. 25 sözleşme ihlali deyimini kullanmaktadır. Buna göre, bir taraf sözleşme uyarınca diğer tarafın beklemekte haklı olduğu menfaatten önemli ölçüde yoksun kalmasına sebep olmuşsa esaslı ihlalden söz edilir. Düzenlemeye göre sözleşmeyi ihlal eden taraf ihlalin öngörülebilir sonuçlarından sorumludur. Sözleşme ihlali, temerrüt ve ayıplı teslim gibi unsurları içinde barındırmaktadır. Buna karşılık, sorumluluk için sebep olmak yeterli olup, ayrıcı kusurlu olma şartı gerekmemektedir. Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde alıcı satıcıdan aynen ifa, ikame mal teslimi, onarım, bedelin indirilmesi ve alıcının uğradığı bütün zararların tazminini talep edebilir (m. 45, 74-77). Alıcı makul bir süre verdikten sonra şartları varsa sözleşmeden dönebilir.

§ 7. SATICININ TEMERRÜDÜ

Satış sözleşmesinde, satıcının temerrüdü TBK m. 212 ve 213'te düzenlenmiştir. TBK m. 212'de satıcının temerrüdünün sonuçlarına ilişkin kural ve bunun istisnası; TBK m. 213'te de temerrüdden doğan zararın hesaplanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

I. Satıcının temerrüdünün sonuçları

1. Kural

TBK m. 212/I'e göre, "satıcının temerrüdü halinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler uygulanır". Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerinde yer alan 117 vd. maddelerinde temerrüdün şartları ile temerrüdün hüküm ve sonuçları düzenlenmiştir. Satıcının temerrüdünün sonuçları bakımından, satış sözleşmesi, karşılıklı borç doğuran bir sözleşme olduğu için, TBK m. 123-125 hükümleri uygulama alanı bulur. Buna göre, satıcının temerrüdü halinde, alıcı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, borcun aynen ifasında vazgeçtiğini hemen bildirerek, olumlu zararının tazminini isteyebileceği gibi, sözleşmeden de dönebilir (TBK m. 125). TBK m. 124'deki hallerin bulunması halinde, süre verilmesine gerek yoktur.

Ticari satışta sözleşmenin diğer tarafını temerrüde düşürmek ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin şartlar için borçlar hukukun genel hükümlerinden farklı bir usül öngörülmüştür. Buna göre, diğer tarafı temerrüde düşürmek, sözleşmeyi fesih etmek ve sözleşmeden dönmek için gerekli ihbar ve ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılmak zorundadır (TTK m. 18/3).

2. İstisna: Zilyetliğin devri için belirli süre öngörülen ticari satışlar

TBK m. 212/ II ve III zilyetliğin devri için belirli bir sürenin konulduğu ticari satışlarda, satıcının temerrüdünün sonuçları bakımından bir istisna getirmiş bulunmaktadır. Buna göre, bu tür satışlarda satıcı temerrüde düşerse, alıcının, aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararın giderilmesini talep ettiği kabul edilmektedir (TBK m. 212/ II). Buna

karşılık alıcı, aynen ifa isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya hemen bildirmek zorundadır (TBK m. 212/III).

II. Ticarî satışlarda

1. Ticarî satış kavramı

Ticarî satış ne Borçlar Kanunu'nda ne de Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. 13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 23. maddesi ticari satış ve mal değişimini hükme bağlamıştır. Söz konusu düzenlemeye göre 23. maddede düzenlenen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tacirler arasında meydana gelen satış ve mal değişimlerine de Türk Borçlar Kanunun veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun satış sözleşmesine ve mal değişimine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu düzenleme de ticari satışın içeriğini belirleyememiştir. Bu düzenleme tek kriter olarak tacirler arası satışı öngörmüştür. Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde düzenlenen ticari iş tanımı ve 19. maddede düzenlenen ticari iş karinesine ilişkin hükümler de konuya açıklık kazandırmaktan uzak bulunmaktadır. Zira bu hükümler malın tekrar satmak için satın alındığı temel düşüncesine dayanmaktadır. Bu bakımdan ticari satış deyiminin belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.

Ticarî satış kavramını belirlemek üzere başvurulacak kriter konusunda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bir fikre göre[1], ticarî satış, tekrar satmak ve kâr elde etmek amacıyla yapılan bir satışdır. Ancak, bunun için satıcının, alıcının satılanı tekrar satmak amacıyla satın aldığını bilmesi gerekir; alıcının tacir sıfatını taşıması, ticarî satış konusunda bir karine teşkil eder. Buna karşılık, üstün tutulması gereken diğer bir fikre göre[2], ticarî satış, satış konusunu tekrar satma ve kâr etmeyi meslek edinen kişiyle (alıcıyla) yapılan satışdır[3]. Bu iki görüş arasındaki fark, birinci görüşün herhangi bir kişinin tekrar satmak amacıyla bir mal satın almasını ticarî satış olarak kabul etmesidir. Bu görüş kabul edilecek olursa örneğin TTK m. 15'te tanımlanan esnafın

---

1 **Cavin,** sh. 9; **Giger**, Art. 190, N. 15-16; OR-**Koller**, Art. 190, N. 7 ve 9; **Tercier**, N. 142; **von Tuhr/Peter**, sh. 5, dn. 6.

2 **Keller/Siehr**, sh. 32-33; **Oser/Schönenberger**, Art. 190, N. 7; **Becker,** Art. 190, N. 3; **Honsell**, sh. 47; BGE 65 II 173. Ayrıca bkz. **Schönle,** Art. 190, N. 19; TBK m. 225/II'de "satıcılığı meslek edinmiş kişiler" ibaresi tercih edilmiştir.

3 TKHK m. 3, satıcıyı, ticari veya mesleki amaçla tüketiciye mal sunan kişi olarak tanımlamaktadır.

satmak için aldığı mal bakımından ticari satış sözleşmesi yaptığı kabul edilecektir. Her iki görüşte ortak olan nokta, bir işletmenin techizi veya alıcının şahsî ihtiyacı için yapılan alımların, ticarî satış sayılmamasıdır[4]. Aynı şekilde, alıcının tacir sıfatını taşıması ve ticarî işletmesinin ticaret siciline kayıtlı bulunması şart değildir; bu husus, yapılan satışın ticarî sayılmasına sadece karine teşkil eder[5].

2. TBK m. 212/II'de öngörülen karineler

a) Kesin vadeli sözleşme karinesi

Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerindeki düzenlemeye göre (m. 123) borçlunun temerrüdü halinde, alıcının aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının tazminini isteme ve sözleşmeden dönme imkânlarından birini kullanabilmesi için, uygun bir süre vermesi gerekir; TBK m. 124'de öngörülen durumlarda, özellikle 3. bentte söz konusu olan kesin vadeli sözleşmelerde ise, süre verilmesine gerek yoktur. TBK m. 124/b. 3'te zikredilen kesin vadeli işlemlerde, kararlaştırılan vade, taraf iradelerine göre, borçlunun borcunu ifa edebileceği yegâne zaman dilimidir. Başka bir deyişle, kararlaştırılan vadenin geçmesinden sonra, borçlunun, alacaklının iradesine rağmen ifada bulunamayacağı hususunda tarafların anlaşmaları mevcuttur[6]. Bu tür işlemlerde, tarafların iradelerinden, alacaklının kararlaştırılan vadeden sonraki ifayı başlangıçtan itibaren istemediği sonucu çıkmaktadır[7].

TBK m. 212, teslim için belirli vade öngörülen ticarî satışlarda, TBK m. 124/b.3'teki düzenlemeden ayrılarak, kararlaştırılan vadenin satış sözleşmesine nisbî bir kesin vadeli işlem niteliği verdiğini karine olarak kabul etmiştir[8]. Bu sonucun doğması için, satış sözleşmesinin ticarî bir satış olduğunun ve teslimi için belirli bir vade kararlaştırıldığının kanıtlanması yeterlidir. Satıcının, bu nisbî kesin vadeli işlem karinesini çürütebilmesi için, kararlaştırılan vadenin, sonraki ifanın bertaraf edildiği anlamına gelmediğini ispat etmesi gerekir[9]. Buna karşı-

---

4 Bkz. **Honsell,** sh. 47.

5 **Schönle,** Art. 190, N. 20-21.

6 OR-**Koller**, Art. 190, N. 2; **Schönle**, Art. 190, N. 31 ve 32.

7 **Schenker,** N. 519; **von Tuhr/Escher,** sh. 151; **Eren**, C. III, sh. 290.

8 OR-**Koller**, Art. 190, N. 4; **Schönle**, Art. 190, N. 26 ve 30 vd. Ayrıca bkz. **Tercier**, N. 215; **Becker,** Art. 190, N. 6; **Tandoğan** I/1, sh. 133.

9 OR-**Koller,** Art. 190, N. 4; **Schönle,** Art. 190, N. 33; **Cavin,** sh. 46-47.

lık *Giger*[10] ve ona katılan *Keller/Siehr*[11] burada kanuni bir varsayımın (fiktion) bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın TBK m. 212'nin yedek hukuk kuralı olma niteliği ile bağdaştırılması mümkün değildir. Nitekim *Giger*[12], her iki görüşün sonuçlarının aynı olduğunu kabul etmektedir.

b) Alıcının olumlu zararının tazminini talep ettiği karinesi

Teslim için belirli vadeli ticarî satışlarda, satıcı kararlaştırılan vadede teslim borcunu yerine getirmezse, alıcının aynen ifadan vazgeçip, olumlu zararının tazminini istediği kabul olunur (TBK m. 212/II). Böylece, TBK m. 125/II'deki düzenlemeden farklı olarak, TBK m. 212/II, alıcının susması olgusuna, onun teslimden vazgeçip olumlu zararın tazminini istediği karinesini bağlamıştır. Alıcı, vadenin geçmesine rağmen, borcun aynen ifasını istiyorsa, bunu hemen satıcıya bildirmek zorundadır (TBK m. 212/III). Buna göre alıcı, vadenin sona erdiği veya onu takip eden günde bu bildirimi yapmalıdır; borsa işlemlerinde olduğu gibi, zamanın çok önemli olduğu işlerde teleks, telefaks veya telgrafla aynı günde bildirimin yapılması gerektiği ifade olunmaktadır[13]. İstisnaî veya özel durumların gecikmeyi haklı kıldığı hallerde, daha sonra normal haberleşme araçlarıyla bildirimde bulunulabilir[14].

TBK m. 212/III anlamında bildirme, açık veya örtülü, varması gereken bir irade beyanıyla kullanılan bir yenilik doğuran hak niteliğini taşır[15]. Bildirimin yapılmaması sonucu ortadan kalkan alıcının teslim veya aynen ifa talebi, tarafların anlaşmaları halinde yeniden tesis edilebilir[16].

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun m. 187'de, satıcının temerrüdü üzerine alıcının sözleşmeden dönme hakkı açıkça zikredilmemişti. Bazı yazarlar[17], bu maddede öngörülen satışlarda alıcının sözleşmeden

---

10 Art. 190, N. 4, 10 ve 13.

11 Sh. 34.

12 Art. 190, N. 28.

13 **Giger,** Art. 190, N. 39; OR-**Koller**, Art. 190, N. 15; **Schönle**, Art. 190, N. 48; **Becker**, Art. 190, N. 8.

14 Dn. 12'de zikredilen yazarlar.

15 **Schönle**, Art. 190, N. 47; **Giger,** Art. 190, N. 40; OR-**Koller**, Art. 190, N.15.

16 **Giger**, Art. 190, N. 40; OR-**Koller**, Art. 190, N. 20.

17 **Becker**, Art. 190, N. 10; **Cavin**, sh. 47-48; **Oser/Schönenberger**, Art. 190, N. 14.

dönemeyeceğini iddia etmekteydi. Buna karşılık, üstün tutulması gereken diğer bir fikre göre[18], BK m. 187'nin anlam ve amacı, alıcıya uygun bir mehil vermeden BK m. 106/II gereğince sözleşmeden dönme hakkının tanınmasını gerektirmediği, BK m.187'nin amacının genel hükümlere nazaran daha iyi bir durum sağlamak olduğu, oysa dönme hakkından yoksun bir alıcının BK m. 106 vd. ndan daha kötü şartlara itilmiş olduğu, diğer taraftan, olumsuz zararın olumlu zarardan daha fazla olduğu hallerde, alıcının, dönme sayesinde menfaatlerini diğer iki imkândan daha iyi bir şekilde koruyabileceği[19], özellikle satılanın fiyatının düşmesi ve alıcının ifa etmemeden doğan bir zararının bulunmaması ihtimalinde, alıcıyı dönme hakkından yoksun bırakmak için haklı bir sebep bulunmadığı[20] görüşleri ileri sürülmekte idi.

6095 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 212/I, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak satıcının temerrüdüne borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümlerin uygulanacağını açıkça hükme bağlamıştır. Kanun koyucu bu düzenlemeyi içeren birinci fıkradan sonra belirli süreli ticari satışlarda satıcı temerrüdü halinde aynen ifaden vazgeçilerek bundan doğan zararın giderilmesinin istendiğini kabul etmiştir. Bu düzenleme nedeniyle yukarıda zikredilen tartışma önemini kaybetmiştir. Zira, kanun, seçimlik hak olarak dönme hakkının da ifade edildiği borçlu temerrüdüne ilişkin genel hükümlerin (TBK m. 117-126) satıcı temerrüdünde uygulanacağını düzenlemektedir.

Alıcı, dönme hakkını kullandığını kararlaştırılan vadenin bitiminde satıcıya hemen bildirmek zorunda değildir. Zira bu durumda, spekülasyon tehlikesi bulunmadığı için, alıcının hemen karar vermesi istenemez[21]. Bu itibarla, alıcı uygun bir düşünme süresi içinde dönme hakkını kullanabilir[22].

---

18 **Giger**, Art. 190, N. 33 vd; **Keller/Siehr**, sh. 35; OR-**Koller**, Art. 190, N. 17; **Lemp**, sh. 74 vd; **Stanislas**, sh. 86; **Schönle**, Art. 190, N. 14; **Tandoğan** I/1, sh. 135.

19 **Keller/Siehr**, sh. 35; OR-**Koller**, Art. 190, N. 17; **Giger**, Art. 190, N. 35 ve 43.

20 OR-**Koller**, Art. 190, N. 17.

21 **Giger**, Art. 190, N. 43; OR-**Koller**, Art. 190, N. 19; **Stanislas**, sh. 86; **Schönle**, Art. 190, N. 15. Aksi fikirde: **Keller/Siehr**, sh. 35-36; **Schenker**, N. 535 ve 576.

22 **Giger**, Art. 190, N. 43, **Stanislas** (sh. 79) ve **Schönle** (Art. 190, N. 16), dönme hakkının, MK m. 1/II uyarınca borcun ifa edilmemesi sebebiyle istenecek tazminat alacağının zamanaşımı süresi içinde kullanılabileceği fikrindedirler.

c) Zilyetliğin devri için belirli vade öngörülen ticarî satışlarda farklı düzenlemenin gerekçesi

TBK m. 212'de yer alan teslim için belirli vadeli ticarî satışlara ilişkin farklı düzenleme, aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır[23]:

Ticarî satışlarda sözleşmenin amacı, tekrar satmak ve kâr elde etmektir. Bu itibarla, satıcının temerrüdünden doğan belirsizlik durumunun, ticarî işletmelerde aranan çabukluk ve güvenlik esasına uygun olarak giderilmesi gerekir. Bundan başka, belirsizliğin devamı, bir tarafın diğeri aleyhine spekülasyonda bulunmasına ve fiyat dalgalanmalarından yararlanmasına sebep olur. Nihayet, ticarî satışların konusu genellikle çeşidiyle belirli şeylerdir. Bu tür satışlarda, alıcı için satılanı teslim almaktan çok satıp kâr elde etmek önemlidir. Bu sebeple, tazminat talep etmek, alıcı için, satılanı teslim almaktan daha yararlı ve kolay olur.

III. Satıcının temerrüdünde Zararın hesabı

a) Genel olarak

TBK m. 213/I'e göre, "Borcunu ifa etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür". Bu fıkra hükmü yeni bir sorumluluk getirmemekte, TBK m. 212/I ile borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümlerin uygulanacağını öngören hükmün içeriğini tekrarlamaktadır. Bu durumda, zararı isbat alıcıya ait olup (TBK m. 50/I), daha kötü şartlarla sözleşme kurduğunu, tekrar satıştan elde edeceği kârdan yoksun kaldığını veya kendi alıcısına tazminat ödemek zorunda kaldığını isbat edecektir.

TBK m. 213/II ve III'te satış sözleşmesinde satıcının temerrüdü üzerine olumlu zararın fark nazariyesine göre[24] iki türlü hesaplanma şekli düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, somut yönteme, diğeri soyut yönteme göre zararın hesaplanma şeklidir. Böylece alıcı, satıcının ifa

---

[23] **Oser/Schönenberger**, Art. 190, N. 5; **Becker**, Art. 190, N. 3; **Giger**, Art. 190, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 33; **Tandoğan**, I/1, sh. 135/136.

[24] Borçlunun temerrüdü halinde iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde gecikmiş ifa (aynen ifa) talep edilebilmektedir. Ancak, alacaklının gecikmiş ifadan vazgeçmesi halinde müsbet zarar talep etmesi de mümkündür. Müsbet zarar fark veya mübadele teorisine göre hesaplanabilmektedir. Fark teorisinde, alacaklı kendi edimini yerine getirmeden ediminin değeri ile müsbet zarar arasındaki farkı tazminata esas zarar olarak talep edebilmektedir. Mübadele teorisinde ise alacaklı kendi asli edim yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Alacaklı bu takdirde müsbet zararını talep edebilmektedir.

etmediği edimin değeri, yani ifa etmemeden doğan zararı ile satış bedeli arasındaki farkı tazminat olarak talep etmek imkânına sahip olmaktadır[25]. Bu iki metod, özellikle soyut metod, alıcıya olumlu zararını isbat bakımından, genel hükümlere oranla (TBK m. 114/II delâletiyle m. 50/I) kolaylık sağlamaktadır[26]. Bununla beraber, TBK m.213/II ve III'ün şartlarının gerçekleşmesi halinde dahi, alıcı bu metodlara başvurmak, zorunda değildir; o, her zaman genel hükümler çerçevesinde zararını isbat ve talep edebilir[27].

TBK m. 213/II ve III hükümleri, kıyas yoluyla satıcının ediminin imkânsızlaşması ve TBK m. 218/I anlamında kısmî zabt hallerinde de uygulanır[28]. Bundan başka, TBK m. 213/II ve III hükümlerinin uygulanması, zilyetliğin devri için belirli vade öngörülen ticarî satışlarla (TBK m. 212/I) sınırlı değildir[29]. Nitekim söz konusu hükümler "Satıcının Temerrüdü" başlığı altında düzenlenmiş ve zilyetliğin devri için belirli süre öngörülmüş ticari satışlara inhisar ettirilmemiştir.

b) İkame alım halinde zararın somut hesaplanması (TBK m.213/II)

TBK m. 213/II, alıcıya, temerrüde düşen satıcının teslim etmediği satılanı başka yerden ikame alım suretiyle temin etmek ve ikame alım için dürüstlük kuralına göre ödediği bedel ile ifa edilmeyen satış konusu için kararlaştırılan bedel arasındaki farkı zarar olarak talep etmek yetkisi vermektedir[30]. Bu fıkra hükmüne göre, ikame alımın dürüstlük kuralına (MK m. 2) uygun olarak yapılması gerekir. Bu itibarla, alıcının, zararı azaltacak şekilde elverişli şartlarla alım yapması icap eder. Bunun için, ifanın imkânsızlaşması, belirlenen vadenin dolması (TBK m. 212) veya TBK m. 125/II anlamında aynen ifadan vazgeçmesi üzerine, gecikmeden yeterli süre içinde ikame alımını yapmak zorunda-

---

25 **Schönle**, Art. 191, N. 6; **Giger**, Art. 191, N. 23-24.

26 **Tercier**, N. 220; **Cavin**, sh. 49.

27 **Schönle**, Art. 191, N. 6 ve 7; **Cavin**, sh. 50; BGE 43 II 214 yahut JdT 1917 I 592; BGE 105 II 87 yahut JdT 1980 I 17.

28 **Schönle**, Art. 191, N. 9; OR-**Koller**, Art. 191, N. 4; BGE 104 II 198.

29 **Schönle**, Art. 191, N. 9; **Giger**, Art. 191, N. 6.

30 CISG m. 75'e göre, sözleşmenin ortadan kaldırılması halinde makul bir süre içinde alıcının ikame mal satın alması ve alıcının temerrüdünde satıcının malları yeniden satması durumunda sözleşmede kararlaştırılan bedel ile ikame işlem arasındaki farkı tazminat olarak talep edebilir. Taraflar bunun yerine m. 74'te düzenlenen tam tazminatı da talep edebilirler.

dır[31]. Satılanın değeri, bu alım için yapılan harcamalara göre belirlenir[32]. Aynı şekilde, dürüstlük kuralı, ikame malın, satıcının teslim etmesi gereken yerden ve bu mümkün değilse, mümkün olduğu kadar elverişli şartlarla alınabilen başka bir yerden temin edilmesini gerektirir[33]. Bu konuda, alıcıdan, uzun süre araştırma yapması beklenemez; onun iş tecrübesine göre hareket etmesi yeterlidir[34]. Keza, ikame malın, kural olarak borcunu ifa etmeyen satıcının edimiyle aynı cins ve kalitede olması gerekir; alıcının daha iyi kalitede ikame mal alması halinde, bunun fiyatından bir indirim yapılmalıdır[35].

Alıcının ikame alımında dürüstlük kuralına uygun hareket etmemesi halinde, hâkim, dürüstlük kuralına uygun alımlarda ödenmesi gereken bedele göre tazminata hükmeder[36].

TBK m. 213/II'de, İsviçre TBK m. 191/II'nin Fransızca metninde olduğu gibi, ikame alımı için verilen (ödenen) bedel deyimi kullanılmaktadır; Almanca ve İtalyanca metinlerde ise, "teslim edilmeyen şey için iyiniyetle yapılan ikame alımdaki bedel" ifadesi yer almaktadır. Bu durum, henüz ifa edilmemiş ikame alımındaki fiyatın zararın hesabında nazara alınmasına engel olmaz; bu sözleşmenin kurulduğunu isbat alıcıya, muvazaalı olduğunu isbat satıcıya aittir[37].

c) Zararın soyut olarak hesaplanması

TBK m. 213/III'e göre, "Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun yerine bir başkasını satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir"[38]. Bu fıkrada öngörülen zararın hesaplanma tarzına "soyut metod"

---

31 OR-**Koller**, Art. 191, N. 10; **Schönle**, Art. 191, N. 19; **Giger**, Art. 191, N. 36.

32 **Schenker**, N. 655, sh. 240; BGE 120 II 300.

33 **Giger**, Art. 191, N. 35: OR-**Koller**, 191, N. 12.

34 **Giger**, Art. 191, N. 35; **Keller/Siehr**, sh. 38; **Schönle**, Art. 191, N. 20.

35 **Giger**, Art. 191, N. 37; OR-**Koller**, Art. 191, N. 13; **Schönle**, Art. 191, N. 21.

36 **Giger**, Art. 191, N. 34; OR-**Koller**, Art. 191, N. 7; **Keller/Siehr**, sh. 38; **Schönle**, Art. 191, N. 18.

37 **Schönle**, Art. 191, N. 17; BGE 81 II 53 vd yahut JdT 1956 I 540.

38 CISG m. 76'ya göre, sözleşmenin ortadan kalktığı ve satış konusu mallar için cari fiyatın var olduğu hallerde ikame alış veya satış yapılmadan sözleşmede kararlaştırılan bedel ile sözleşmenin sona erdirildiği tarihteki cari fiyat arasındaki farkı tazminat olarak talep edebilir.

denilmesinin sebebi, alıcının fiilen (somut) bir ikame alımı yapmak zorunda olmamasıdır. *Schönle*'ye göre[39], TBK m. 213/III hükmünün amacı, kararlaştırılan fiyat ile satılanın carî veya borsadaki fiyatı arasındaki farkın zarar olarak kabul edilmesinden çok, yoksun kalınan kârın soyut olarak hesaplanmasıdır.

Satıcı, alıcının ikame alım yoluyla satılanı daha ucuza alabileceğini ileri sürerek, zararın soyut hesabına karşı çıkamaz[40].

Piyasa fiyatı (carî fiyat), belirli cins malın belirli bir ticarî çevrede muntazam yapılan alışverişlerinde, belirli zamanda ulaştığı belirli bir fiyattır[41]. Buna karşılık, alıcının veya satıcının şahsî durumlarına ve kişiliğine bağlı fiyatlar, piyasa fiyatı sayılmaz[42].

Zararın hesabında ifa günündeki fiyat esas alınır (TBK m. 213/III)[43].

IV. Satıcının teslim borcunu ifada kısmî temerrüdü

1. Bir defada ifa edilmesi gereken teslim borcunun kısmen yerine getirilmiş olması

Satış sözleşmesine konu olan borç tamamen belirli ve muaccel ise bu borcun tamamen ifa edilmesi gerekir. Aksi takdirde alıcı, TBK m. 84 uyarınca kısmî ifayı reddedebilir ve satıcıyı borcun tamamı için temerrüde düşürebilir. Buna karşılık, alıcı kısmî teslimi bir çekince ileri sürmeksizin kabul ederse, TBK m. 125 ve 212'deki hakları ancak ifa edilmeyen kısım için kullanabilir. TTK m. 23/ 1/a ticari satışlarda satış sözleşmesinin kısım kısım ifasının sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre mümkün olduğu durumlar ile bu şartların söz konusu olmadığı hallerde alıcının ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kısmi teslimi kabul etmesi halini düzenlemektedir. Buna göre, alıcı sadece teslim edilmemiş olan kısım için temerrüde ilişkin haklarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte kısmen teslim nedeniyle

---

39 Art. 191, N. 23.

40 **Tercier**, N. 225; **Schönle**, Art. 191, N. 26; **Keller/Siehr**, sh. 38-39; **Cavin**, sh. 51. Aksi fikirde: **Giger**, Art. 191, N. 51; OR-**Koller**, Art. 191, N. 24; BGE 43 II 221.

41 OR-**Koller**, Art. 191, N. 19; **Keller/Siehr**, sh. 39; BGE 49 II 84; CISG m. 76/2 cari fiyat malları teslim edilmesi gereken yerde geçerli olan fiyat olarak tanımlamaktadır.

42 BGE 78 II 435.

43 BGE 120 II 300, Cons 3 b.

sözleşmeden taraflarca beklenen yarar elde edilemiyorsa veya sözleşme ile ulaşılmak istenen amaca ulaşma imkânı kalmıyor veya zayıflıyor ya da durumdan ifa edilmeyen kısmın yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi "feshedebilmektedir". Tacirler arasındaki ticarî satışlar için öngörülen bu esas, kıyasen âdi satışlarda da uygulanır[44]. Ancak bu esasın uygulanabilmesi için, satılan şeyin bölünebilir olması ve teslim edilmeyen kısmın bedelin hangi miktarını karşıladığının tesbit edilebilmesi gerekir.

2. Ard arda teslimli satışda satıcının temerrüdü

Ard arda teslimli satışlarda, satış konusu malın zaman içinde birbirini takip eden kısımlar halinde teslim edilmesi kararlaştırılmaktadır[45].

Ard arda teslimli satışlarda satıcı, bir veya birkaç kısmın teslimine gecikirse, kural olarak sadece vadesinde teslim edilmeyen kısımlar için temerrüde düşer; alıcı, TBK m. 125 ve 212'deki seçimlik hakları ancak teslim edilmeyen kısımlar için kullanabilir. Bununla beraber, bir veya bir kaç teslimde temerrüt ilerdeki teslimleri tehlikeye düşürüyor veya faydasız kılıyorsa, ilerde yapılacak teslimleri de kapsayacak şekilde, sözleşmenin tamamı feshedilebilir[46]. Ancak bunun için, satıcıya uygun mehil tayin edilirken, bu mehil içinde teslim yapılmazsa sözleşmenin tamamının feshedileceği ona bildirilmelidir[47]. Ard arda teslimli satışların periyodik (devrevi) borç ilişkisi niteliği sebebiyle, kural olarak, dönme değil, fesih söz konusu olur[48]; meğer ki, alıcı sonraki teslimler olmazsa, önceki teslimleri kabul etmeyecek olsun (meselâ, bir kitabın çeşitli ciltlerinin teslimi)[49].

TKHK m. 52 alıcının tüketici sıfatı taşıdığı hallerde, ard arda teslimli satışların bir çeşidi olan abonelik sözleşmesine ve sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin özel hükümler getirmiştir. Buna göre, tüketici belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun belirlenmiş abonelik sözleşmesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile iradesini satıcı veya sağlayıcıya yöneltmek suretiyle gerekçe göstermeksizin

---

44 **Tandoğan,** I/I, sh. 136.

45 **Keller/Siehr,** sh. 147; **Kuntalp**, sh. 77-78.

46 **Keller/Siehr,** sh. 148.

47 **Tandoğan** I/1, sh. 138; **Keller/Siehr**, sh. 148; **Yavuz**, sh. 74; BGE 110 II 148 vd.; 116 II 440, Cons. 2b.

48 **Cavin**, sh. 167; **Tandoğan,** I/1, sh. 138.

49 **Tandoğan,** I/1, sh. 138; **Yavuz**, sh. 74.

feshedebilir. Bu takdirde kararlaştırılmış olsa dahi cezai şart ödemez. Buna karşılık süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde tüketici sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir (f. 4). Satıcı ve sağlayıcısının abonelik sözleşmesine son verme isteği çıkarılacak Yönetmelikte belirlenen süreler içinde kullanılabilir. Abonelik sözleşmelerinin bu süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda sürenin bitmesinden itibaren tüketici mal veya hizmetten yararlanmış olsa bile herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır (f. 5). Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketicinin, satıcının ve sağlayacının hak ve yükümlülükleri ve diğer uygulama esasları çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecektir (f. 7).

§ 8. SATICININ SATILANIN ZAPTINDAN SORUMLULUĞU

I. Kavram

Satıcının satılanın zaptından doğan sorumluluğu (Zapta karşı tekeffül borcu), üçüncü bir kişinin, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada mevcut bir üstün hak sebebiyle satılanı alıcının elinden almasından veya onu mülkiyet hakkından doğan bazı yetkileri kullanmaktan yoksun bırakmasından satıcının sorumlu olmasıdır[1].

Üçüncü kişiye satılanı zapt imkânı veren üstün hak, mülkiyet, sınırlı aynî hak, tapu siciline şerh edilen kişisel hak (MK m. 1009) veya gayri maddî mallar üzerindeki hak şeklinde olabilir[2].

Zapttan doğan sorumluk, satıcının satılan üzerindeki mülkiyet hakkını geçirme veya satılan hakkı devir borcunun bir sonucudur. Bu itibarla, kanunî bir borç olup, satıcının bu hususta ayrıca bir taahhütte bulunmasına gerek yoktur[3]. Zapttan doğan sorumluluğa ilişkin hükümler emredici nitelikte olmadığından aksinin taraflarca kararlaştırılması mümkündür. Bu nedenle taraflar sorumluluğun kapsamının daraltılmasını, genişletilmesini veya başka bir hükme bağlanmasını kararlaştırabilirler. Ancak, satıcının üçüncü kişinin üstün hakkını gizlemesi halinde sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan anlaşmalar kesin hükümsüzlük müeyyidesine tabi tutulmuştur (TBK m. 214/III). Diğer yandan, alıcının zapttan sorumluluğu düzenleyen hükümler dışında borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin hükümlere başvurması mümkündür. Zira, özel hüküm burada genel hükümle birlikte uygulanabilmektedir. Kanun, sadece alıcının sözleşmenin kurulduğu anda elinden alınma tehlikesini bildiği haklar bakımından, satıcının zapttan sorumlu olacağını ayrıca üstlenmesi şartını aramaktadır (TBK m. 214/II).

Satılanın zaptı, tam veya kısmî zapt şeklinde olabilir. Üçüncü şahsın, satılan üzerinde mülkiyet hakkı iddia etmesi halinde tam zapt; sa-

---

1 **Koller/Siehr**, sh. 48; **Giger**, Art. 192, N. 5; **Tercier**, N. 227; **Furrer**, sh. 19/20; **Tandoğan** I/1, sh. 148. CISG m. 41'e göre, satıcı satış konusu mal üzerinde üçüncü kişilerin her türlü hak ve talebinden ari mal teslim etmek zorundadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakkında 42. madde uygulanmaktadır.

2 **Giger**, Art. 192, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 48; **Tandoğan** I/1, sh. 152.

3 Bkz. **Giger**, Art. 192, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 48; **Cavin**, sh. 62; **Engel**, sh. 25; **Tandoğan** I/1, sh. 148-149.

tılanın bir kısmı üzerinde her türlü yetkileriyle mülkiyet hakkını veya satılanın tamamı üzerinde mülkiyet hakkından doğan yetkileri sınırlayan bir hakkı (meselâ, rehin hakkını) ileri sürmesi halinde kısmî zapt söz konusu olur[4].

Zapttan doğan sorumlulukla satılanın ayıplı olmasından sorumluluğu birbirinden ayırmak gerekir. Ayıptan doğan sorumluluğu düzenleyen TBK m. 219'da hukukî ayıp deyiminin yer alması sebebiyle bu ayırım önem taşımaktadır. Üçüncü şahsın, sözleşmenin kurulduğu anda satılan üzerinde alıcının hakkına nazaran üstün bir hakka sahip olması halinde, zapttan sorumluluk söz konusu olur. Buna karşılık, genel ve soyut bir hukuk normuna dayanan, yani kamu hukukuna ait sınırlamalar sebebiyle alıcının satılandan yararlanamaması (meselâ, satılan arsa üzerinde inşaat yasağının bulunması) hukukî ayıp sayılır ve TBK m. 219 vd. ndaki hükümler uygulanır[5]. Hukuki ayıba, tarım arazisinin bina yapmak için satılması, altında nekropol olan birinci derece arkeolojik sit alanı, enerji nakil hakkı güzergahı, uçuş maniasının bulunması gibi örnekler verilebilir.

II. Zapttan sorumluluk hükümlerinin uygulama alanı

1. Alıcının eşya hukukuna ait korumadan yararlanamaması

a) Alıcının iyiniyetli olması

Eşya hukukunun hak sahibi olmayan kişiden iyiniyetle bir aynî hak iktisap eden alıcıyı koruyan hükümleri (MK m. 763/III, 988 vd. ve 1025/II) zapta karşı tekeffül hükümlerinin uygulama alanını önemli ölçüde daraltmaktadır. Alıcının bu korumadan yararlanması halinde, onun iktisabı geçerli olup, üçüncü kişinin üstün hak iddiasında bulunması mümkün olmayacaktır. Buna karşılık, eşya hukuku kurallarının alıcının iyiniyetli iktisabını korumadığı durumlarda, üstün hak sahibi üçüncü kişi, alıcıdan satılanın iadesini talep edebilir[6]. Sahibinin elinden rızası olmadan çıkan menkul malların satışında, böyle bir durum söz konusu olur; hak sahibi üçüncü kişi beş yıl içinde alıcıdan iade talebinde bulunabilir (MK m. 989). Böylece zapttan sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulur.

---

4 **Keller/Siehr,** sh. 49; **Cavin,** sh. 62; **Engel,** sh. 25.

5 **Giger,** Art. 192, N.20; **Keller/Siehr,** sh. 49; OR-**Koller,** Vorbem zu Art. 192-210, N. 5; Art. 192, N. 2.

6 **Keller/Siehr,** sh. 50; **Giger,** Art. 192, N. 32.

b) Alıcının kötü niyetli olması

Kötü niyetli alıcı, üçüncü kişilerin üstün haklarına karşı eşya hukuku bakımından korunmamıştır (MK m. 991 ve 1023). Bu itibarla, üstün hak sahibi üçüncü kişi, kötü niyetli alıcıdan zapttan sorumluluk hükümlerine göre iade talebinde bulunabilir.

2. Eşya hukuku dışında uygulama alanı

Satış sözleşmesine ilişkin zapttan sorumluluk hükümleri (TBK m. 214 vd.), âdi şirkette aynî sermaye konulması halinde (TBK m. 621/III), eser sözleşmesinde (TBK m. 472/I), yayın sözleşmesinde (TBK m. 489/II), bağışlama sözleşmesinde (bağışlayanın ayrıca taahhütte bulunması halinde, TBK m. 294) ve mirasın taksiminde (MK m. 679/I) uygulanabilir.

III. Zapttan doğan sorumluluğun şartları

Satıcının zapttan dolayı sorumlu olabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir.

1. Satılanın alıcıya teslimi

Satıcının zapttan dolayı sorumlu olması için, satılanın alıcıya geçerli bir satış sözleşmesine istinaden teslim edilmiş olması gerekir. Üçüncü kişi, satılanı teslimden önce üstün hak sebebiyle zapt ettiği takdirde, satıcı, TBK m. 112 vd. gereğince borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumlu olur[7].

Satış sözleşmesinin bâtıl veya geçmişe etkili olarak geçersiz olması halinde alıcı lehine zapttan sorumluluk doğmaz; bu takdirde ödenen satış bedelinin iadesi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edilebilir[8].

2. Satış sözleşmesinin kurulduğu anda zaptı sağlayan bir hakkın bulunması

Üçüncü şahsın zaptı sağlayacak üstün hakkının satış sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut olması gerekir. Satıcının satış sözleşmesinin kurulmasından sonra ve teslimden (mülkiyetin geçmesinden) önce sa-

---

7 **Bucher**, BT, sh. 89; **Giger**, Art. 192, N. 38; **Keller/Siehr**, sh. 52; **Tercier**, N. 233; **Cavin,** sh. 65; **Tandoğan** I/1, sh. 151; **Yavuz**, sh. 83.

8 **Giger,** Art. 192, N. 39; 13. HD., 6.3.1986, E. 785/K. 1333 (**Uygur**, C. 3, sh. 327-328; **Yavuz,** sh. 82, dn. 7).

tılan üzerinde üçüncü kişi lehine bir üstün hak (meselâ rehin hakkı) kurması halinde, TBK m. 112 vd. na göre sorumlu olur[9].

3. Alıcının zapt tehlikesini satış sözleşmesinin kurulduğu anda bilmemesi

Alıcının zapt tehlikesini satış sözleşmesinin kurulduğu anda bilmemesi gerekir; biliyorsa, satıcının ayrıca (tahsisen) tekeffül taahhüdünde bulunması gerekir (TBK m. 214/II). Bu hususta, bilme yükümlülüğü veya ihmal sonucu bilmeme yeterli olmayıp, alıcının fiilen bilmesi şarttır. Bununla beraber, alıcının ağır kusurundan kaynaklanan bilgisizliğini (meselâ, satıcının verdiği belgeleri okumaktan dürüstlük kuralına aykırı olarak kaçınma), fiilen bilme olarak değerlendirmek gerekir[10].

4. Satılanın zaptı

Satıcının zapttan sorumluluğunun doğumu için, üçüncü kişinin üstün hakkının mevcut olması yeterli değildir; bundan başka, üçüncü kişinin üstün hakkını ileri sürerek satılanı zaptetmiş olması gerekir. Bunun için iradenin (açık, zımnî veya delâlet edici bir fiille) açıklanmış olması yeterlidir. Üçüncü kişinin bu hakkını dava veya mahkemede def'i yoluyla ileri sürmesi gerekli değildir[11].

Üçüncü kişi üstün hakkını ileri sürmediği sürece, alıcı, TBKm. 112 vd. ve m. 210'a (satıcının mülkiyeti geçirme borcuna) dayanarak, satıcıdan gereği gibi ifa ve üçüncü şahsın hakkını bertaraf etmesini talep edebilir[12].

TBK m. 216/II'ye göre, alıcının, dava açılmadan satılanın üçüncü kişiye vermekle yükümlü olduğunu isbat etmesi halinde de satıcı zapttan dolayı sorumlu olur. Bu fıkra hükmünün getirdiği çözüm gereksiz anlaşmazlıklar ile mahkeme külfet ve masraflarını önler[13]. Bu sonucun elde edilmesi için, üçüncü kişinin, satılan üzerindeki hakkını kullan-

---

9 **Giger,** Art. 192, N. 43; **Keller/Siehr,** sh. 52; **Becker,** Art. 192, N. 11; OR-**Honsell,** Art. 192, N.4.

10 **Cavin,** sh. 66-67; **Engel,** sh. 27; **Keller/Siehr,** sh. 53; **Oser/Schönenberger,** Art. 192, N. 15; **Giger,** Art. 192, N. 54.

11 **Giger,** Art. 192, N. 60 ve 62; **Keller/Siehr,** sh. 53; **Cavin,** sh. 65. **Yavuz,** sh. 83-84; BGE 109 II 319 vd. yahut JdT 1984 I sh. 141 vd.

12 **Giger,** Art. 192, N. 60; **Keller/Siehr,** sh. 53.

13 **Tandoğan** I/1, sh. 154; **Tunçomağ,** sh. 212-213; **Yavuz,** sh. 83-84.

mak istediğini gösteren iradesinin açıkça veya zımnen beyan edilmiş olması gerekir[14].

5. Zaptın isbat edilmesi

Alıcının zapttan doğan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmesi için, satıcıya zaptın varlığını kabul ettirmesi gerekir. Diğer bir deyişle alıcı zaptı isbat etmelidir. Burada iki hali ayrı ayrı incelemek gerekir:

a) Zaptın bir mahkeme hükmüyle gerçekleşmesi

Üçüncü kişi üstün hakkını alıcıya karşı açtığı bir davada ileri sürdüğü takdirde, bu dava sonunda verilen ilâmın satıcıya karşı hüküm ifade edebilmesi için, alıcının ona davaya katılma, müdahale ve savunmaya imkân verecek şekilde, davayı bildirmesi (ihbar etmesi) gerekir (TBK m. 215/I; CISG m. 43). Satıcının bildirim görevi külfet niteliğindedir. Zira, yerine getirilmemesi halinde hakkın kaybına veya daralmasına yol açmaktadır. Bildirim külfetinin yerine getirilmesi üzerine, satıcı, yargılama usulüne ilişkin kanun hükümlerine uygun olarak alıcının yanında davaya katılmak veya alıcı yerine geçerek üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve savunmak zorundadır (TBK m. 215/I; HMK m. 61-70)[15]. Bu takdirde verilen hüküm satıcıyı bağlar. Buna karşılık, satıcı, davaya katılmaya ve savunmaya elverişli bir zamanda yapılan bildirime rağmen davaya yardım etmediği takdirde, aleyhe çıkan hükmün alıcının ağır kusurunun eseri olduğunu isbat etmedikçe, verilen hükümle bağlı olur (TBK m. 215/II).

Alıcının davayı hiç veya vaktinde haber vermemesi ihtimalinde ise, satıcı, davanın zamanında bildirilmesiyle elde edeceğini isbat ettiği elverişli sonuç oranında sorumluluktan kurtulur (TBK m. 215/III). Bununla birlikte, alıcının davayı ihbar etmemesi halinde dahi satıcı davaya katılabilir (HMK m. 66). Kanun fer'i müdahale için ihbar ön şartı aramamaktadır.

---

[14] **Giger**, Art. 192, N. 62; Art. 194, N. 7; **Keller/Siehr**, sh. 53.

[15] **Tandoğan**, I/1, sh. 157; HMK m. 62'ye göre davanın ihbarı yazılı olarak yapılır. İhbar sebebi gerekçeleriyle açıklanır ve yargılamanın safhası belirtilir. HMK m. 67'de davaya fer'i müdahale düzenlenmiştir. Fer'i müdahil, yanında katıldığı dava tarafının yararına olacak iddia ve savunma vasıtalarını ileri sürebilir. Usul işlemlerini de yanında katıldığı tarafın işlemlerine aykırı olmamak kaydı ile yapabilir. Bu davada hüküm taraflar hakkında verilir (HMK m. 69/1).

b) Mahkeme kararı olmaksızın satılanın üçüncü kişiye verilmesi (TBK m. 216)

TBK m. 216, bir mahkeme kararı olmadan, alıcının satılanı üçüncü kişiye vermesi halinde, satıcının zapttan sorumluluğunun devam edeceği halleri düzenlemektedir:

aa) TBK m. 216/I'e göre, alıcı, bir mahkeme kararı beklemeden üçüncü kişinin hakkını dürüstlük kuralına uygun olarak tanıyıp, satılanı ona vermişse (b.1); alıcı üçüncü kişinin kendisine karşı dava açmasını beklemeden, satıcıyı zapt iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümlemesi, aksi takdirde tahkime başvuracağı konusunda gecikmeden uyarmış ve bundan sonuç alamadığı için tahkim yoluna başvurmuşsa (b.2) satıcının zapttan doğan sorumluluğu devam eder. birinci halde alıcının dürüstlük kuralına uygun hareket etmediğini isbat satıcıya düşer.

bb) Aynı şekilde, alıcının satılanı üçüncü kişiye vermekle yükümlü olduğunu isbat etmesi durumunda satıcının zapttan doğan sorumluluğu devam eder (TBK m. 216/II)

IV. Zaptın hükümleri

1. Tam zapt halinde

a) Sözleşmenin kendiliğinden ortadan kalkması

Satılanın tamamen zaptedilmesi üzerine, satış sözleşmesi, geçmişe etkili olarak kendiliğinden ortadan kalkar (TBK m. 217/I): "satış kendiliğinden sona ermiş sayılır". Burada TBK m. 125 ve 227 vd. ndaki dönme hallerinden farklı olarak, yenilik doğuran bir irade beyanıyla bir seçim hakkının kullanılması söz konusu değildir[16]. Bu sonucun gerçekleşmesi için, alıcının, herhangi bir irade beyanına ihtiyaç olmadığından, onun sözleşmeyi sona erdirmeyip aynı cins malın teslimini veya olumlu zararın tazminini istemesi mümkün değildir[17].

b) Satış bedelinin iadesi

Satıcı, alıcının ödemiş olduğu satış bedelini faiziyle birlikte iade etmek zorundadır. Faiz TBK m. 88 ve 3095 sayılı kanun hükümlerine (m. 1/I ve m. 2/III) göre belirlenir. İade edilecek satış bedelinden, alı-

---

[16] **Giger**, Art. 195, N. 5; **Keller/Siehr**, sh. 59; OR-**Honsell**, Art. 195, N. 5; **Furrer**, sh. 25; 13. HD, 6.4.1995, E. 3569/K. 3453 (YKD 1996, sh. 1257-58)

[17] **Giger**, Art. 195, N. 5; OR-**Honsell**, Art. 195, N.2.

cının satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerin bedeli indirilir (TBK m. 217/I, b. 1).

Satıcının satış bedelini iade borcu, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre değil, sözleşmeden doğan borç ilişkisine dayanır ve TBK m. 146'te öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tâbidir[18].

c) Alıcının tazminat talepleri

aa) Kusursuz sorumluluk esasına göre

Satıcı, alıcının TBK m. 217/I, b. 2-4'teki zararlarından kusursuz sorumluluk (sebep sorumluluğu) esasına göre sorumludur:

aaa) Satılan üzerinde alıcının yaptığı masraflar

TBK m. 217/I, b. 2 gereğince, alıcı, satılan üzerinde yaptığı ve üçüncü kişiden alamadığı masrafların ödenmesini satıcıdan talep edebilir. Alıcı, iyiniyetli üçüncü kişiden zorunlu ve faydalı masraflarının ödenmesini isteyebilir (MK m. 994). Fakat bu masraflardan fiilen tahsil edilemeyenler ile zapt tehlikesini öğreninceye kadar yapılan lüks masraflardan satıcı sorumludur.

bbb) Mahkeme masrafları

Satıcı, davanın kendisine bildirilmesi ile kaçınılması mümkün olanlar müstesna olmak üzere, alıcının bütün mahkeme masrafları ile mahkeme dışı masraflarını ödemek zorundadır (TBK m. 217/I, b. 3). Burada üçüncü kişi ile alıcı arasındaki davadan doğan masraflar söz konusudur.

ccc) Alıcının doğrudan doğruya zararları

TBK m. 217/I, b. 4'e göre, alıcı, satılanın tamamen elinden alınması yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlarının tazminini talep edebilir. Satıcının kusurlu olması halinde alıcıya tazmin edeceği zararlar ise, TBK m. 217/II'de diğer zararlar (dolaylı zararlar) şeklinde ifade edilmiştir. Bu maddede geçen, doğrudan doğruya zarar ile dolaylı zarar kavramlarının kapsam ve sınırları, doktrin ve uygulamada son derecede tartışmalıdır.

---

[18] OR-**Honsell**, Art. 195, N. 3; **Giger**, Art. 195, N. 9 ve 14; **Serozan**, Sözleşmeden Dönme, sh. 300-301; **Tandoğan**, I/1, sh. 159, dn. 38a; 13. HD, 6.4.1995, E. 3569/K. 3453 (YKD 1996, sh. 1258).

Bir fikre göre[19], olumsuz zararlar doğrudan doğruya, olumlu zararlar ise dolaylı zararlara tekabül eder.

Bu konuda savunulan ikinci görüş ise, doğrudan doğruya zarar-dolaylı zarar ayırımını, uygun illiyet bağına dayanarak açıklamaktadır[20]. Buna göre, doğrudan doğruya zarar, sözleşmenin ihlâlinin ilk ve en yakın sonucu olarak doğan zarar; dolaylı zarar ise, sözleşmenin ihlâlinin (zaptın) uzak sonucu olarak doğan zararlardır.

Üçüncü görüş[21] ise, bu konuda fiilî zarar ve yoksun kalınan kâr ayrımını ölçü olarak almaktadır.

Türk Borçlar Kanununun 217. maddesinde dört bent halinde sayılan kalemler satış bedelinin faiziyle geri istenmesi yanında menfi zarar kalemleridir. Bu zararların tazmini için satıcının kusurlu olması şartı aranmamaktadır. Buna karşılık 217. maddenin ikinci fıkrası, satıcının kusurlu olmadığını ispat edememesi halinde bu nedenle uğradığı diğer zararları talep edilebileceğini düzenlemektedir.

bb) Kusur sorumluluğu

TBK m. 217/II'ye göre, satılanın zaptından doğan diğer (dolaylı) zararlar için, satıcı kusur sorumluluğu ilkesine göre sorumludur.

2. Kısmî zapt halinde

Kısmî zapt halinde alıcı, satış akdinin feshini talep edemez; sadece bu yüzden uğradığı zararların tazminini talep edebilir (TBK m. 218/I). Bu durumda ödenecek tazminat, TBK m. 217'deki esasların kıyasen uygulanması suretiyle hesaplanır.

Kısmî zapt yüzünden satılanın değerinde meydana gelen eksilme, TBK m. 227'deki esaslara göre belirlenir[22].

Alıcının üçüncü kişinin üstün hakkını bilseydi şeyi satın almayacağı halin icabından anlaşılıyorsa, o, sözleşmenin tamamen ortadan kalkmasını dava edebilir (TBK m. 218/II). Bu durumda sözleşme kendiliğinden sona ermemekte; alıcının hakimden sözleşmenin sona ermesini talep etmesi gerekmektedir. Alıcı satılanın elinde kalan kısımı

---

19 **Oser/Schönenberger,** Art. 195, N. 7 vd.; **Cavin,** sh. 68; **Yavuz,** sh. 88; 13. HD., 4.8.1983, E. 8041/K. 1510 (**Uygur,** C. III, sh. 325).

20 **von Tuhr/Peter,** sh. 88-89; **Guhl/Merz/Kummer,** sh. 64; **Schubiger,** sh. 77; **Furrer,** sh. 27; **Fischer,** sh. 286 vd.; **Keller/Siehr,** sh. 62 vd.

21 **Giger,** Art. 195, N. 34; BGE 79 II 379 vd.

22 **Keller/Siehr,** sh. 65; **Giger,** Art. 196, N. 9; OR-**Honsell,** Art. 196, N. 2.

bu zamana kadar elde ettiği yararlarla birlikte geri vermekle yükümlü tutulmuştur.

V. Sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması

Satıcının zapttan doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümler, emredici nitelikte değildir. Bu itibarla taraflar, bu sorumluluğun kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını kararlaştırabilirler. Ancak, satıcı, üçüncü şahsın üstün hakkını gizlemiş ise, onun sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan şartlar geçersiz olur (TBK m. 214/III).

§ 9. SATICININ SATILANIN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

I. Tanımı

Ayıptan sorumluluk, satıcının, satılanın, hasarın geçtiği anda alıcıya bildirdiği (vaad ettiği) nitelikleri veya dürüstlük kuralı gereğince ondan beklenen lüzumlu vasıfları taşımamasından dolayı sorumlu olmasıdır (TBK m. 219/I)[1].

II. Hukukî niteliği

Satılanın vasfının satıcının edim yükümünün kapsamına dahil olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Bu konunun, parça ve çeşit borçlarında ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

1. Çeşit satışında

Çeşit satışında satılanın vasıf ve niteliğinin, tarafların özel bir anlaşma yapmalarına gerek olmadan, satıcının edim yükümünün kapsamına dahil olduğu ve ayıptan doğan sorumluluğun (ayıplı ifanın) bir kötü ifa teşkil ettiği konusunda görüş birliği mevcuttur[2].

2. Parça satışında

Bazı yazarlar[3], parça satışında, satılanın vasfının sözleşmenin ve satıcının edim yükümünün kapsamına dahil olmadığını; ayıplı ifanın

---

1 **Keller/Siehr,** sh. 71; **Giger,** Vorbem zu Art. 197-210, N. 4; **Tercier,** N. 255. TKHK m. 8'e göre ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında kararlaştırılan örnek ya da modele uygun olmayan veya objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır (f.1). Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında veya reklam ve ilanlarında ifade edilen özelliklere sahip olmayan, satıcı tarafından beyan edilen veya teknik düzenlemesinde belirlenen niteliklere aykırı olan, muadil malların kullanım amacını karşılayamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydayı azaltan veye ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklik içeren mallar ayıplı kabul edilmektedir (f. 2). Sözleşme konusu malın kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya satıcının sorumluluğu kendisine ait montajı gereği gibi yerine getirmemesi sözleşmeye aykırı ifa sayılır (f. 3).

2 **Giger,** Vorbem zu Art. 197-210, N. 14 vd; **Becker**, Art. 197, N. 5; **Neuenschwander,** sh. 24; **Keller/Siehr**, sh. 71; **Fischer,** sh. 207; **Aral,** sh. 101.

3 **von Tuhr/Escher,** sh. 2; **Bucher,** BT, sh. 68 vd; **Honsell,** sh. 56; OR-**Honsell,** Vorbem zu Art. 192-210, N.2.

bir kötü ifa olmayıp, kanundan doğan bir sonuç sorumluluğu olduğunu iddia etmektedirler.

Buna karşılık, bizim de katıldığımız hâkim fikre göre[4], parça satışında da satılanın niteliği (vasfı) sözleşmenin ve satıcının edim yükümünün kapsamına dahildir; ayıplı ifa, bir kötü ifa sayılır.

III. Satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartları

1. Hasarın geçtiği anda satılan ayıplı olmalıdır

a) Ayıp kavramı

Ayıp (Der Sachmangel; défaut), satıcının, alıcıya herhangi bir şekilde bildirdiği (varlığını vaad ettiği) veya alıcının dürüstlük kuralına göre beklediği vasfın satılanda bulunmamasıdır[5]. Buna göre ayıp, satılanın mevcut vasıflarının, onun taşıması gereken vasıflardan farklı olmasını ifade eder[6].

TBK m. 219 anlamında vasıf (nitelik), iş hayatındaki telakkilere veya alıcının satıcı tarafından bilinen veya bilinebilen ferdî menfaatine göre satılanın değerini veya kullanılmaya elverişliliğini etkileyen her türlü özellikleridir[7]. Başka bir ifadeyle, bu özellikler satılanın değerini ve kullanılabilirliğini, kullanmaya elverişliliğini etkilemektedir.

Satılandan başka bir şeyin teslimi (aliud) halinde, çeşit borçlarında kararlaştırılan cinsin bütün özelliklerini taşımayan bir eşya teslim edildiği takdirde, ayıplı ifa değil, ifa etmeme söz konusu olur[8]. Meselâ, köpek balığı eti yerine balina eti; kaz yerine ördek teslimi. Parça

---

4 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 17 vd; **Keller/Siehr**, sh. 72; **Neuenschwander,** sh. 26; **Fischer,** sh. 213 vd; **Schubiger**, sh. 9; **Aral,** sh. 103; BGE 107 II 165/166; 107 II 421.

5 **Tercier,** N. 278, sh. 38; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 2; **Honsell**, sh. 64.

6 **Keller/Siehr,** sh. 76; **Honsell,** sh. 64; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 2; CISG m. 35'e göre, aynı türden malların mutat olarak tahsis edildiği kullanım amacına uygun olmaması, satıcıya bildirilen her türlü özel kullanım amacına uygun olmaması, satıcının örnek veya model olarak sunduğu malların kalitesine sahip olmaması, benzer mallar için mutat olan muhafaza ve korumaya uygun olarak paketlenmemiş olması hallerinde mallar sözleşmeye uygun ifa edilmemiş sayılır.

7 **Tercier**, N. 278; **Keller/Siehr**, sh. 73; **Giger**, Art. 197, N. 34.

8 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 44; **Honsell**, sh. 64 ve 99; **Keller/Siehr**, sh. 77; **Tercier**, N. 281. İsviçre Federal Mahkemesi konuyla ilgili son kararında (BGE 121 III 453) cins kavramını objektif ve soyut olarak, yani iş hayatındaki genel anlayışa göre değil, nisbî olarak, yani tarafların satış sözleşmesinde satılan için yaptıkları tanıma göre belirlenmesi gerektiği görüşüne üstünlük tanımıştır.

satışlarında, ferdî nitelikleriyle belirlenmiş bir şey yerine başka bir şey teslim edilmişse, aliud vardır: X gemisindeki 25 varil kemiksiz domuz eti yerine Y gemisinden bozulmuş kemiksiz domuz eti teslimi[9]. Buna karşılık sözleşmeyle kararlaştırılan şey teslim edilmiş ise, o şey kararlaştırılan temel nitelikleri taşımasa da, aliud'dan söz edilemez; bu ihtimalde teslim edilen şeyin değerini veya kullanılırlığını azaltan ayıp, iş çevrelerindeki anlayışa göre, onun başka cins ve çeşit mal sayılması sonucunu doğuracak ölçüde olsa dahi, alıcı borcun ifa edilmemesine değil, ayıba karşı tekeffüle dayanarak dava açabilir[10].

Miktar eksikliği, genel olarak ayıp sayılmaz; çeşit satışında miktar itibariyle eksik ifa, TBK m. 84 anlamında kısmî ifa sayılır. Alıcının kısmî ifayı kabul etmesi halinde, o, ifa edilmeyen kısmın ifasını talep edebilir; kısmî ifayı reddetmesi ihtimalinde (TBK m. 84) ise, borcun tamamı için temerrüt hükümlerine (TBK m. 112 vd. veya m. 212) başvurabilir. Buna karşılık, kararlaştırılan miktar ve sayı, satılanın niteliğini belirliyorsa ve alıcının kullanma amacı açısından önem taşıyorsa, miktar eksikliği vasıf eksikliği olarak kabul edilebilir[11]. Meselâ, bir dondurucunun hacmi; bir âletin çapı[12]; bir evin genişliği[13]; tekrar satılmak üzere alınan paketler halindeki malın ağırlığının az olması; miktar eksikliğinin, niceliğin niteliği etkilemesi halinde ayıp sayılacağı TBK m. 219/I'de düzenlenmiştir.

Ayıp, satılanın ayıptan etkilenen vasıflarına göre, başlıca üç kısma ayrılır:

aa) Maddî ayıp

Bu tür ayıplar, satılanın fizikî özelliklerini (şekil, renk, mukavemet gibi) etkiler; satılan şey dış görünüş itibariyle kararlaştırılana uygun olmakla beraber, nitelik eksikliği sebebiyle alıcının ondan beklediği

---

9 BGE 26 II 328.

10 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 46; **Honsell**, sh. 64; **Engel**, sh. 33; **Katz**, sh. 95; **Flume**, sh. 114 vd; **Stanislas**, sh. 169; BGE 82 II 416 yahut JdT 1957 I 182 (Olayda, bir şahsa ait resim galerisinde bulunan Van Gogh'un yaptığı kendi portresinin satılıp teslimi ve sonradan bu tablonun kopya olduğunun anlaşılması söz konusu idi); BGE 121 III 453 yahut JdT 1997 I 201-202.

11 **Cavin**, sh. 75; **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 52; **Honsell**, sh. 67; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 9.

12 BGE 57 II 290.

13 BGE 87 II 247 yahut JdT 1969 I 322.

değer ve yararlanma özelliğine sahip değildir: Yeni arabanın kullanılmış olması veya kullanılmış arabanın önemli bir kazaya uğramış olması; mücevherin çizik olması; bir tablonun sahte olması hallerinde maddî bir ayıp söz konusu olmaktadır[14].

bb) Ekonomik ayıp

Satılanın, alıcının ondan beklediği geliri getirmemesi veya verimi sağlamaması, ekonomik ayıp sayılır.

cc) Hukukî ayıp

Satılan üzerinde, alıcının ondan yararlanmasını veya onun üzerinde tasarruf etmesini engelleyen kamu hukukundan doğan sınırların bulunması hukukî ayıp sayılır: Arsa üzerinde inşaat müsaadesinin bulunmaması veya beklenenden sınırlı olması; yapılarda iskân (yapı kullanma) izninin bulunmaması. Buna karşılık, üçüncü kişilerin satılan üzerindeki üstün hak iddiaları, zapttan doğan sorumluluk (TBK m. 214) teşkil eder[15]. Bununla beraber, alıcının yeterince dikkati sarf etmesi halinde böyle bir ayıbı bilebileceği hallerde (TBK m. 222), satıcının ayıptan sorumluluğu ortadan kalkar; ancak dürüstlük kuralı gereğince alıcıdan söz konusu kuralları bilmesi beklenemiyorsa, satıcı sorumlu olur[16].

b) Bildirilen (vaad edilen) vasıfların bulunmaması

TBK m. 219 gereğince satıcı, satılanın alıcıya bildirdiği vasıflarından sorumludur. Vasıf bildirimi (vaadinin), satıcının, satılanın olumlu vasıflara sahip olduğunu ve olumsuz niteliklerinin bulunmadığını ileri sürmesidir[17].

Vasıf bildiriminin hukukî niteliği tartışmalıdır. Bir fikre göre[18], satıcının vasıf bildirimi, hukuken bağlayıcı bir irade beyanı olup, sözleşmenin muhtevasına dahildir; satıcının vasıf bildiriminden dolayı so-

---

[14] **Tercier**, N. 287; OR-**Honsell,** Art. 197, N. 3 vd; **Engel,** sh. 32.

[15] **Giger,** Art. 192, N. 21; Art. 197, N. 64, 65; **Keller/Siehr,** sh. 49, 78.

[16] **Giger**, Art. 197, N. 63, 66; **Keller/Siehr**, sh. 78.

[17] **Giger,** Art. 197, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 73-74.

[18] **Giger**, Art. 197, N. 6 vd; **Oser/Schönenberger**, Art. 197, N. 8; **Merz**, FS für Guhl, sh. 96, dn. 15; **Katz**, sh. 45 vd; **Schubiger,** sh. 6 vd; **Fischer**, sh. 208 vd; **Jaeger,** sh. 35; **Flume**, sh. 59 vd, 78 vd; **Magnin,** sh. 15 vd.

rumluluğu sözleşmesel bir sorumluluktur. Buna karşılık, hâkim fikir[19] ve Federal Mahkeme'ye göre[20], satıcının vasıf bildirimi, sadece bir tasavvur (veya bilgi) açıklaması olup sözleşmenin muhtevasına dahil olmayan, sonuçta dürüstlük kuralına irca edilebilen, kanunî bir sorumluluktur. Burada sözleşmesel değil, kanunî bir sorumluluk söz konusudur. Bununla beraber, bu tartışma daha çok akademik nitelik taşımaktadır[21]; zira hâkim görüş, satıcının açık bir borçlanma iradesini aramamakta, alıcının satın alma kararını açıkça etkileyen vasıflar hakkındaki zımnî (konkludente, iradeyi gösteren) açıklamayı yeterli saymaktadır[22]. Böyle bir durumun bulunup bulunmadığı dürüstlük kuralına göre belirlenir[23].

Vasıf bildirimini, reklam amacıyla söylenmiş genel sözlerden ayırt etmek gerekir; bu hususta yapılan beyanları güven teorisine göre yorumlamak ve değerlendirmek gerekir[24]. Meselâ, kullanılmış araba için satıcının "olağanüstü iyi durumda" beyanı vasıf bildirimidir[25].

TKHK m. 61 ticari reklamlar ve ilanların tabi olduğu hukuki rejimi düzenlemektedir. Buna göre ticari reklamların Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere, genel ahlak kamu düzeni, dürüstlük ve doğruluğa uygun olması gerekmektedir (f. 2). Reklam verenin ticari reklamlarında bulunan somut beyanlarını ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır (f. 6).

Vasıf bildirimini, bağımsız garanti taahhüdü ile karıştırmamak gerekir. Garanti sözleşmesiyle, garanti veren satış konusunun sözleşmeye uygun vasıflar taşımasından da ileri olan belirli bir sonuçtan (verim veya sürüm gibi) kusur veya imkânsızlığa bakılmaksızın sorumlu ol-

---

19 **von Tuhr/Peter**, sh. 176, dn. 18; **Stauffer**, ZBJV 1944, sh. 145 vd; **Jaeggi,** FS für Guhl, sh. 73, 74; **Furrer**, sh. 44 vd; **Cavin**, sh. 80 vd; **Keller/Siehr** sh. 74; **Tercier,** sh. 292, 295; **Engel**, sh. 30; **Honsell,** sh. 68.

20 BGE 71 II 239 yahut JdT 1946 I 85; BGE 73 II 218 yahut JdT 1948 I 362; BGE 88 II 416.

21 **Honsell,** sh. 68; OR-**Honsell,** Art. 197, N.14.

22 BGE 102 II 100; 87 II 245; 71 II 240; **Jaeggi**, FS für Guhl, sh. 67; **Stauffer**, sh. 145 vd; **Bucher**, BT, sh. 91.

23 **Keller/Siehr,** sh. 74; **Honsell**, sh. 68; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 14; BGE 116 II 431 yahut JdT 1991 I 45.

24 **Katz,** sh. 44; **Furrer,** sh. 47; **Magnin**, sh. 57; **Giger**, Art. 197, N. 16.

25 SJZ 1953, sh. 198.

mayı taahhüt eder (TBK m. 128)[26]. Garanti taahhüdü, muhteva itibariyle satış sözleşmesinden bağımsız olma açısından, TBK m. 219 anlamında vasıf bildiriminden ayrılır; bundan doğan hakların kullanılması, ayıp ihbarının yapılmasına (TBK m. 223) ve TBK m. 231 ve TTK m. 23/1/c'de öngörülen kısa zamanaşımı süresine bağlı değildir. Diğer taraftan, vasıf bildirimi satılanın sadece hasarın geçtiği anda mevcut vasıflarına ilişkindir[27]. Satıcının, satış konusunun mevcut vasıflarının, gelecekteki belirsiz olaylara bağlı olarak devamını (meselâ, belirli bir gelir garantisi) bildirmesi halinde, bir garanti sözleşmesinin varlığını kabul etmek gerekir[28]. Bu itibarla, gelecekteki gelir ve kazanç taahhüdünde, genellikle bir garanti niteliği görmek gerekir.

Garanti ibaresinin kullanılması (garanti süresi, garanti belgesi verilmesi), garanti sözleşmesinin varlığı için yeterli değildir.

Vasıf bildirimi, normal olarak akdin kurulmasından önce veya kurulurken yapılır; bununla beraber, güven teorisine göre kurulmuş bir satış akdinin tamamlanması olarak nitelendirilebildiği takdirde, sonradan da yapılabilir[29].

Satıcının bildirilen vasıflardan sorumlu olması için, vasıf eksikliği veya ayıbın satılanın değerini veya faydalanılabilirliğini gidermesi veya önemli ölçüde azaltılması şart değildir; satılanın vasıf bildiriminin kapsamına giren özelliklerden herhangi birinden yoksun olması, satıcının ayıptan sorumlu olması için yeterlidir. Meğer ki, bu eksikliğin ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması teşkil etsin[30].

Bildirilen vasıfların bulunmaması şeklindeki ayıp, TKHK m. 8/2'de ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen hususların eksikliği olarak ifade edilmiştir[31].

---

[26] **Gauch/Schluep**, N. 4066; **Giger**, Art. 197, N. 20; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 17.

[27] **Kleiner,** Bankgarantie, sh. 109 vd.; **Jaeggi**, FS für Guhl, sh. 73 vd.; **Giger**, Art. 197, N. 20; OR-**Koller**, Art. 197, N. 17; **Honsell**, sh. 68-69.

[28] **Kleiner**, sh. 110; **Giger**, Art. 197, N. 17; **Honsell**, sh. 69; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 17; **Cavin**, sh. 81-82.

[29] **Giger**, Art. 197, N. 28; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 18; SJ 1973, sh. 327.

[30] **Giger**, Art. 197, N. 12, 41; OR-**Honsell**, Art. 197, N. 18; **Keller/Siehr**, sh. 75; BGE 87 II 245.

[31] **Zevkliler**, Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun, İzmir 1996. sh. 37.

c) Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği bir vasfın bulunmaması

TBK m. 219, satıcının, az önce açıklanan bildirdiği vasıflardan başka, satılanın değerini veya varsayılan kullanma amacına elverişliliğini kaldıran veya önemli ölçüde azaltan ayıplardan da sorumlu olduğunu ifade etmektedir[32]. Kanunda yer alan ve eksikliği ayıp teşkil eden bu sonuncu vasıflar, beklenen veya varsayılan vasıfları bildirilen (vaad edilen) vasıflardan ayırmak amacıyla belirtilmiştir[33]. Kanun koyucunun bu şekilde nitelikli bir ayıp aramasının sebebi, alıcıya TBK m. 227 vd. nda sağlanan hukukî imkânlar ve satıcının doğrudan doğruya zararlardan kusursuz sorumlu olması (TBK m. 229/I, b.3) esası karşısında, vasıf bildiriminde bulunmayan satıcı lehine denge sağlamaktır[34]. Böylece, bildirilen vasıfların bulunmaması halinden farklı olarak, burada satıcının sadece önemli ayıplardan sorumlu olması esası kabul edilmiş bulunmaktadır[35].

Satış konusunun varsayılan kullanma amacı, tarafların birbirine uygun irade beyanlarına veya bu konuda bir anlaşma yoksa, alışveriş hayatındaki anlayışa göre belirlenir; sözleşmenin kurulması esnasında alıcının tek taraflı amaçladığı kullanma, bu hususta önemli değildir[36]. Tarafların varsayılan kullanma amacını sözleşmeyle belirleyip belirlemedikleri, onların açık veya örtülü irade beyanlarının dürüstlük kuralına göre yorumundan çıkartılır[37]. Böyle bir yorumda, söz konusu işin mahiyeti, satılanın iktisadî fonksiyonu ve sözleşme müzakereleri nazara alınır. Bu yorumdan belirli bir sonuç alınamazsa, mutad kullanma amacı esas alınır ve bu tür şeylerin yer itibariyle durumu göz önünde bulundurulur[38]. Satıcının sorumlu olması gereken elverişliliğin derecesi, şüphe halinde, iş çevrelerindeki anlayışa göre belirlenir[39].

---

32 TBK m. 219'da yer alan kullanım amacı bakımından değeri deyimini, İsviçre TBK m. 197'ye uygun olarak, varsayılan kullanma (amacına) elverişlilik şeklinde (Tauglichkeit zu den vorausgesetzen Gebrauch) anlamak gerekir.

33 **Katz,** sh. 37; **Schubiger,** sh. 3 vd; **Giger**, Art. 197, N. 61.

34 **Giger**, Art. 197, N. 61.

35 **Giger**, Art. 197, N. 68.

36 **Giger**, Art. 197, N. 70; **Cavin**, sh. 83; **Keller/Siehr**, sh. 76; SJZ 1965, sh. 327.

37 **Keller/Siehr**, sh. 76; **Giger,** Art. 197, N. 70.

38 **Keller/Siehr**, sh. 76; **Giger,** Art. 197, N. 71.

39 **Giger**, Art. 197, N. 71.

TBK m. 219 anlamında alıcının beklediği faydalar değiminden, objektif carî değer veya mübadele değeri anlaşılır; alıcının satılana verdiği özel değer önemli değildir[40].

Satılanın değerinin veya varsayılan kullanma amacına elverişliliğinin kaldırılması (izalesi), satılanın objektif piyasa değerinden yoksun veya tamamen kullanılmaz olmasını ifade eder. Bunların önemli ölçüde azalması ise, alıcının, aynı branşta geçerli anlayışa göre ayıbı bilmesi halinde hiç sözleşme yapmayacağı veya daha düşük fiyat ile satış akdi kuracağı hallerde söz konusu olur[41].

Dürüstlük kuralı gereğince beklenen vasıfların bulunmaması şeklindeki ayıp, TKHK m. 8/2'de, " teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler" olarak ifade edilmiştir[42].

d) Satılanın hasarın geçtiği anda ayıplı olması

Satıcının ayıptan dolayı sorumlu olabilmesi için, ayıbın, hasarın alıcıya geçtiği anda (TBK m. 208; CISG m. 36)) mevcut olması gerekir[43]. Hasarın geçtiği anda ayıp sebebinin bulunması, TBK m. 219 anlamında ayıbın varlığı için yeterlidir; ayrıca onun sebeplerinin haricen görülebilir olması gerekmez[44].

2. Alıcının ayıbı bilmemesi gerekir

TBK m. 222'e göre, satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir (f. I; TKHK m. 10/2; CISG m. 35/3); Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçir-

---

40 **Giger**, Art. 197, N. 77; **Keller/Siehr,** sh. 77.

41 **Giger**, Art. 197, N. 68; **Cavin**, sh. 84; **Keller/Siehr**, sh. 77; **Jager**, sh. 33; CCF Art. 1641.

42 **Zevkliler**, Tüketicinin Korunması, sh. 37-38.

43 **Oser/Schönenberger**, Art. 197, N. 17; **Giger,** Art. 197, N. 42 ve 78; **Keller/Siehr**, sh. 76, 78; **Engel**, sh. 33. TKHK m. 8/1 malın tüketiciye teslimi anını esas almaktadır. Kanunun 10/1. Maddesine göre teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıbın teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu karinenin aksini yani malın ayıplı olmadığını satıcı ispat eder. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıbın açık veya gizli ayıp olması önem arz etmemektedir.

44 **Engel**, sh. 33; **Keller/Siehr**, sh. 76, 78.

mekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur (f. II).

Buna göre satıcı, alıcının sözleşmenin kurulduğu anda bildiği ayıplardan sorumlu değildir (TBK m. 222). Buradaki ayıp kavramı hem bildirilen (vaad edilen), hem varsayılan vasıfların bulunmamasından doğan ayıpları kapsar[45]. TBK m. 222'de yer alan ayıbın bilinmesi deyimi, ayıbın kapsamı ve önemi hakkında tam bilgi sahibi olma anlamına gelir; sadece ayıbın varlığından haberdar olmak yeterli değildir[46].

Temsilci aracılığı ile kurulan satış sözleşmelerinde temsilcinin veya temsil olunan alıcının, yani bunlardan birinin ayıbı bilmesi, satıcının sorumluluğunu giderir[47]. Satılanda birden çok ayıbın bulunması halinde, sadece alıcının bildiği ayıplar için sorumluluk kalkar, diğerleri bundan etkilenmez[48].

Kanundaki bu düzenlemeye temel teşkil eden düşünce, ayıbı bilerek satış sözleşmesini kuran alıcının, satılanı zımnen kabul etmiş sayılmasıdır; önceden bilinen ayıplar için, sonradan ayıptan sorumluluk iddiasında bulunmak çelişkili bir davranış olur[49].

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/2 maddesi hükmüne göre, "Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.". Buna göre, tüketici, ayıplı olduğunu bilerek satın aldığı mallar bakımından satıcıya karşı ayıptan doğan sorumluluk davası açamayacaktır.

TBK m. 222'de düzenlenen ikinci hal, alıcının olağan dikkati sarfetmekle öğreneceği ayıplardır. Buna göre satıcı, alıcının satılanı yeterli derecede (mutad) dikkatle muayene etmekle fark edeceği ayıplardan, bunların bulunmadığını vaad (temin) etmedikçe sorumlu değildir. Bu çözüm tarzı, MK m. 3/II'deki iyiniyete ilişkin düzenlemeye uygundur. Burada alıcıdan sözleşmenin kurulması esnasında veya ku-

---

45 **Giger,** Art. 200, N. 7; **Keller/Siehr**, sh. 80; OR-**Honsell**, Art. 200, N. 2.

46 **Furrer**, sh. 39; **Katz**, sh. 59; **Giger**, Art. 200, N. 7; **Keller/Siehr**, sh. 80; OR-**Honsell**, Art. 200, N. 2; **Engel**, sh. 34; BGE 66 II 137 yahut JdT 1940 I 559.

47 **Giger,** Art. 200, N. 9; OR-**Honsell,** Art. 200, N. 2.

48 **Giger,** Art. 200, N. 8; OR-**Honsell,** Art. 200, N. 2.

49 **Keller/Siehr**, sh. 80; OR-**Honsell**, Art. 200, N. 1; **Giger**, Art. 200, N. 4.

rulmasından önce, TBK m. 223 anlamında esaslı bir gözden geçirme ve araştırma beklenmemekte; ondan sadece satış konusunun seçiminde ve gözden geçirilmesinde mutad özenin gösterilmesi istenmektedir[50]. Gösterilmesi gereken bu özenin belirlenmesinde, somut olayın özellikleri, alıcının şahsı ve bilgisi gözönünde tutulur; bu safhada uzman birine inceletme söz konusu değildir[51]. Doktrin ve uygulamadaki hâkim fikir, BGB § 460'a uygun olarak, ayıbı bilmemenin ihmal teşkil ettiği, yani bakıldığı takdirde kolaylıkla görülebilecek ayıplarda, alıcının ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinden yararlanamayacağını kabul etmektedir[52].

TBK m. 222, böyle bir durumda, yani alıcının gerekli özeni gösterseydi bilebileceği ayıplarda, bu tür ayıpların bulunmadığını bildiren satıcının ayıptan sorumlu olacağını hükme bağlamaktadır. Kanunda zikredilmemekle beraber, satıcının hile ile ayıbı gizlemesi halinde de aynı sonucun doğacağını kabul etmek gerekir[53].

Buna karşılık, satıcının ayıbın varlığını bilmemesi, onun ayıba karşı tekeffülden dolayı sorumlu olmasını engellemez (TBK m. 219/II). TKHK m. 9/2'ye göre, satıcı yapılan reklamın kendisinden kaynaklanmaması hallerinde yapılan açıklamadan haberdar olmadığını haberdar olması da gerekmediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğinden sorumlu olmaz. Aynı durum, reklam yoluyla yapılan açıklamanın satış sözleşmesinin kurulması anında düzeltilmiş olduğunun ispatı veya bu açıklama ile satış sözleşmesinin kurulması arasında illiyet bağı bulunmadığının ispatı halinde de söz konusudur.

3. Alıcı ayıbı kabul etmemiş olmalıdır

Kanunda açıkca düzenlenmemiş olmakla beraber (TBK m. 223/II), alıcı, satılanı ayıbı ile kabul ettiği takdirde, ayıba karşı tekeffülden doğan haklarını kaybeder. Kabul bir irade açıklaması olup, alıcı bununla

---

50 **Cavin,** sh. 84; **Giger,** Art. 200, N. 16; **Keller/Siehr**, sh. 81; OR-**Honsell**, Art. 200, N. 3; BGE 66 II 137.

51 **Cavin**, sh. 84; **Keller/Siehr**, sh. 80-81; OR-**Honsell,** Art. 200, N. 3; **Giger,** Art. 200, N. 16; BGE 95 II 125.

52 **Oser/Schönenberger**, Art. 200, N. 3; **Furrer,** sh. 40; **Katz**, sh. 59; **Giger,** Art. 200, N. 15, 18. Aksi fikirde: OR-**Honsell**, Art. 200, N. 3.

53 **Giger**, Art. 200, N. 36; **Keller/Siehr**, sh. 81; OR-**Honsell**, Art. 200, N. 4; **Cavin**, sh. 85; BGE 66 II 138 yahut JdT 1940 I 554.

ayıba karşı tekeffülden doğan haklarını kullanmaktan vazgeçtiğini satıcıya bildirir[54].

Kabul açık veya örtülü (zımnî) bir irade beyanı ile gerçekleşebilir. Gözden geçirme ve bildirme külfetlerinin yerine getirilmemesi (TBK m. 223/II) veya alıcının gözden geçirmeden satılanı üçüncü bir kişiye satması halinde, zımnî kabul beyanı gerçekleşmiş olur[55].

4. Ayıptan doğan sorumluluk sözleşmeyle kaldırılmamış olmalıdır

Ayıptan sorumluluğa ilişkin kanun hükümleri yedek (dispositif) hukuk kurallarıdır. Bu sebeple taraflar, satıcının ayıba karşı tekeffülden doğan sorumluluğunu sözleşmeyle kaldırabilir veya sınırlayabilirler (TBK m. 221). Bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında (XI) incelenecektir.

IV. Ayıba karşı sorumluluktan doğan taleplerin ileri sürülmesinin şartları (şeklî şartlar)

1. Genel olarak

TBK m. 223, alıcının ayıba karşı sorumluluktan doğan haklarını kullanabilmesini, satılanı gözden geçirme (muayene) ve tesbit ettiği ayıpları satıcıya bildirmesi şartına bağlamaktadır. Gözden geçirme vebildirme, hukukî niteliği itibariyle, alıcı için bir borç değil, külfettir (Obliegenheit; incombance). Bunların yerine getirilmemesi, herhangi bir tazmin borcunu doğurmayıp, sadece alıcıyı, ayıba karşı sorumluluktan kendi lehine doğan talepleri ileri sürme imkânından yoksun bırakır[56]. TBK m. 223/II, olağan bir gözden geçirme ile anlaşılabilecek ayıplarda, gözden geçirme ve bildirme külfetlerinin yerine getirilmemesi halinde, satılanın kabul edilmiş sayılacağına ilişkin kanunî bir varsayım ihtiva etmektedir.

Alıcıya bu külfetleri yükleyen TBK m. 223'deki hükmün amacı, taraflar arasındaki hukukî ve fiilî durumun mümkün olduğu kadar çabuk açıklığa kavuşturulmasının işlerde güvenlik açısından yararlı olmasıdır. Bu hüküm, satıcının ayıpla ilgili iddiaların esaslı olup olmadığı hakkında çabuk fikir sahibi olmasını ve kendisine satılanı temin eden kişiye karşı haklarını zamanında kullanmasını mümkün kılmak-

---

54 **Tercier**, N. 303.

55 **Tercier**, N. 304.

56 **Cavin**, sh. 91; **Giger**, Art. 201, N. 5; **Keller/Siehr**, sh. 82; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 2; **Tercier**, N. 306; **Engel**, sh. 34.

tadır. Aynı şekilde, bu düzenleme ile, alıcının satıcı aleyhine fiyat dalgalanmalarından haksız olarak yararlanması ve ayıbı bilmesine rağmen satılanı kullanmaya devam etmesi imkânları da önlenmiş olmaktadır[57]. Ancak, gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getiren alıcının, ayıba karşı sorumluluktan doğan haklarının seçimini zamanaşımı süresi içinde yapabilmesi, onun spekülasyon yapma veya satılanı kullanmaya devam etme ihtimalini tamamen bertaraf etmemektedir. Bu sebeple, satıcıya, alıcıya satılanı geri almayı teklif ederek, onun dönme hakkı için bir süre tayin etme yetkisi tanıyan eski BGB § 466'nın kıyasen uygulanmasını kabul etmek gerekir. MK m. 2 hükmü, böyle bir uygulamaya temel teşkil edebilir[58]. Buna karşılık, TBK m. 223 hükmünün satıcıya ayıp, zarar ve illiyet bağı konularında isbat kolaylığı sağladığı görüşünü[59] kabul etmek mümkün değildir. Zira zarar ve illiyet bağı konusunda isbat yükü alıcıdadır[60].

Bununla beraber, gözden geçirme ve bildirim külfetine ilişkin kanunî düzenlemeler, bildirim külfetini yerine getirmeyen veya yerine getirecek durumda bulunmayan, tacir olmayan alıcılar için ağır sonuçlar doğurabilecek, onları mağdur edebilecek niteliktedir[61]. Bu durumu gidermek için, gözden geçirme biçim ve ihbar süresi bakımından tacir olmayan alıcılar için daha müsamahalı (geniş) davranmak gerekir[62].

Gözden geçirme ve bildirim külfetlerine ilişkin TBK m. 223 hükmü, vaad edilen (bildirilen) vasıflar gibi, varsayılan vasıflardan sorumluluk için de geçerlidir. Aynı şekilde, ayıba karşı sorumluluktan doğan hakların her çeşidinin (dönme, bedelin indirilmesi ve mislî mal satışında değiştirme) ileri sürülebilmesinin şartıdır[63].

Mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, 4822 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önceki "ayıplı mal ve hizmetler" başlığını taşıyan 4. maddesinde muayene ve ihbar külfetlerinden hiç söz edil-

---

57 **Cavin**, sh. 88; **Keller/Siehr**, sh. 82; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 1; **Tercier**, N. 307; BGE 88 II 365 yahut JdT 1963 I 242.

58 **Giger**, Art. 201, N. 15; **Bucher**, SJZ 1971, sh. 4.

59 BGE 63 II 406.

60 **Giger**, Art. 201, N. 14; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 1.

61 **Bucher**, SJZ 1971, sh. 2; **Giger**, Art. 201, N. 6.

62 **Bucher**, SJZ 1971, sh. 21; **Giger**, Art. 201, N. 16; **Keller/Siehr**, sh. 82; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 1; **Tercier**, N. 308; **Cavin**, sh. 91-92.

63 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 2; **Giger**, Art. 201, N. 18; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 3; BGE 107 II 419; 81 II 57.

memişti. 4. maddenin II. fıkrasında, satın alınanın ayıplı olması halinde, alıcının teslim tarihinden itibaren 15 gün için malın değiştirilmesi, bedelin vadesi bedelden indirim yapılması veya ücretsiz tamir şıklarından birini tercih edebileceği ifa edilmişti. Bazı yazarlar[64] ve Yargıtay[65] onbeşgünlük bu süreyi kanunun açık hükmüne rağmen, ihbar süresi olarak değerlendirmekteydi.

Bu Kanunun 4822 sayılı kanunla değişik ve ayıplı mal başlığı alan 4. maddesinin II. fıkrasının 1. cümlesine göre, "Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür". Böylece değişiklikten sonra ihbar süresi açıkça düzenlenmiş; fakat gözden geçirme süresinden söz edilmemişti. 6602 sayılı TKHK tüketiciye muayene külfeti getirmemiştir.

2. Gözden geçirme (muayene) külfeti

TBK m. 223/I'e göre, "Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır".

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gözden geçirme ve ihbar süresine ilişkin özel bir hüküm getirmemektedir. Buna göre tüketicinin gözden geçirme (muayene) külfeti bulunmamaktadır. Kanunun 10. maddesi, malın teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan açık veya gizli ayıpların teslim tarihinde mevcut olduğunu kabul etmektedir. İspat yükünü ters çeviren bu düzenlemeye göre, malın tesliminden itibaren altı ay içinde malın ayıplı olmadığını satıcı ispatla yükümlüdür.

Buna karşılık, Türk Ticaret Kanununun 23/1/c maddesine göre, açık ayıplarda alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Alıcı gizli ayıplarda malın tesliminden itibaren sekiz gün içinde inceleme yapmak veya incelettirmek ve inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu anlaşılıyorsa yine bu süre içinde satıcıya ihbar etmekle görevlendirilmiştir. CISG m. 38'e göre alıcı sözleşme konusu malları koşulların izin verdiği ölçüde kısa bir süre içinde muayene etmek veya et-

---

64 **Zevkliler**, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İzmir 1996, sh. 50; aynı yazar, Özel Borç İlişkileri, sh. 94.

65 13. HD, 9.11.1998, E. 6654/K. 8835 (YKD 1999, s.1, sh. 54)

tirmek zorundadır. Taşımayı gerektiren hallerde muayene malların varma yerine ulaşmasından sonra yapılabilir.

a) Gözden geçirmenin tarzı ve kapsamı

Gözden geçirmenin tarzı ve kapsamı, satılanın niteliğine ve bu tür şeylerin alınıp satıldığı çevredeki olağan uygulamaya göre belirlenir; alıcının olağan gözden geçirme ile anlaşılamayan, gizli ayıpları araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır[66]. Meselâ, satın alınan bir evin çatısının muhtemel ayıplarını bulmak için, özel bir özenle incelenmesi gerekmez[67]. Alıcı, konunun uzmanı olmasa bile, şüpheyi gerektirecek özel bir durum bulunmadıkça, satılanı uzman bir kişiye inceletmek zorunda değildir[68]. Ticarî olmayan (âdi) satışlarda alıcının gözden geçirme yükümü, normal bir alıcının dikkatinden kaçmayacak ayıplarla sınırlıdır[69].

Alıcının, gözden geçirme amacının gerektirdiği ölçüde, satılanın bir kısmını kullanması (meselâ, makinalarda), tadına bakması (meselâ, şişe içindeki meşrubata), işlemesi (meselâ, kumaşlarda) veya paketini açması, ticarî branşlarda olağan gözden geçirmelerden sayılır ve bunlar satılanı kabul anlamına gelmez[70]. Çok sayıda orjinal paketler içinde satılan mallarda (meselâ, konservelerde), bir veya iki paketin açılması yeterlidir[71]. Çok büyük miktarda teslim edilen seri halinde imal edilmiş mallarda uygun sayıda rastgele bir numunenin muayene edil-

---

66 **Giger**, Art. 201, N. 45; **Keller/Siehr**, sh. 83; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 5; BGE 76 II 223 vd. yahut JdT 1951 I 398.

67 SJZ 1950, sh. 27. N. 8. Yarg. 13. HD, 29.1.1987, E.13/K. 437: "Somut olayda, satış konusu mal, bir deniz motorudur. Bu tür maldaki ayıp ancak derhal yapılacak bir muayene, yani çalıştırma sonucunda anlaşılabilir. Davacı alıcı bu motoru derhal çalıştırmak ve ayıplı olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Şayet teslim alındığı tarihte yapılan çalıştırma ile motordaki arıza anlaşılamıyor ve ancak uzun süreli bir çalıştırma sonucunda arıza meydana çıkabiliyorsa o takdirde bu ayıba gizli ayıp denilebilir. Bütün bu yönler teknik bir bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkabilecek fen ve ihtisasa ilişkin bir konudur" (YKD 1987, sh. 1795).

68 **Giger**, Art. 201, N. 47; **Keller/Siehr**, sh. 83; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 5; BGE 63 II 468 yahut JdT 1938 I 306, cons. 3c; Sem Jud 1956, sh. 272.

69 **Giger**, Art. 201, N. 48; **Furrer**, sh. 49 vd; **Bucher**, SJZ 1971, sh. 21; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 5; **Keller/Siehr**, sh. 83.

70 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 10; **Furrer**, sh. 51; **Giger**, Art. 201, N. 50; **Keller/Siehr**, sh. 83; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 6.

71 **Giger**, Art. 201, N. 51; **Keller/Siehr**, sh. 83.

mesi yeterlidir[72]. Bu şekilde seçilen numunelerin ayıpsız olmasına rağmen, incelenmeyen diğer malların ayıplı çıkması halinde, TBK m. 223/II, c. 2 anlamında gizli (olağan gözden geçirme ile anlaşılamayan) ayıp söz konusu olur[73].

b) Gözden geçirme yeri

Gözden geçirme, kural olarak, satılanın alıcıya teslim edildiği yerde yapılır; bu husus, TBK m. 223/I'de yer alan "alıcı devraldığı satılanın durumunu" ibaresinden açıkça anlaşılmaktadır. Devralınan yer, satılanın alıcının fiilî hakimiyetine geçtiği yerdir; zira alıcı, satılanın niteliklerini ancak burada bizzat veya üçüncü kişi marifetiyle muayene edebilir[74]. TBK m. 223/I hükmü yedek hukuk kuralı olduğu için, aksine bir anlaşma veya âdet olmadığı takdirde uygulanır[75].

c) Gözden geçirmenin yapılacağı zaman

TBK m. 223/I'e göre, alıcı, satılanın niteliklerini, "işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz" gözden geçirmek zorundadır. Borçlar Kanunu, satılanın gözden geçirilmesi için, hayvan satışı dışında (TBK m. 224), kesin bir süre öngörmemiştir. Buna karşılık, Ticaret Kanunu m. 21/b. 3'te tacirler arasındaki ticarî satışlarda, açık ayıplarda alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Emtianın ayıplı olduğunun teslim sırasında açıkça belli olmaması halinde, alıcının teslimden itibaren sekiz gün içinde şeyi muayene ettirmekle yükümlü olduğu ve yine bu süre içinde durumu satıcıya ihbar etmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu süre âdi muayene ile meydana çıkmayacak ayıplar için yeterli olmayabilir. Bu takdirde, TTK m. 23/1/c'nin son cümlesi TBK m. 223/II'yi saklı tuttuğu için, âdi satışlarda olduğu gibi süre uzatılabilir[76]. CISG m. 38'de koşulların izin verdiği ölçüde kısa bir süre içinde muayene etme veya ettirme zorunluluğu öngörülmüştür.

---

72 **Furrer**, sh. 50; **Giger**, Art. 201, N. 54; **Keller/Siehr**, sh. 83; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 5; BGE 52 II 367; 34 II 707.

73 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 15; **Furrer**, sh. 50; **Giger**, Art. 201, N. 54.

74 **Giger**, Art. 201, N. 23; OR-**Honsell**, Art. 201, N. 8; BGE 88 II 366 yahut JdT 1963 I 242.

75 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 21; **Furrer**, sh. 53; **Katz**, sh. 63; **Giger**, Art. 201, N. 27; BGE 88 II 368.

76 **Tandoğan** I/1, sh. 179.

Hayvan satışlarında devrin yapıldığı günden başlayarak dokuz gün içinde ayıbın bildirilmesi ve bilirkişi muayenenenin yetkili makamlardan istenmesi gerekmektedir. Hayvanın gebeliği halinde bu hüküm uygulanmaz. Diğer yandan satıcınının sorumluluk süresinin yazılı olarak belirtilmiş olması halinde bu süre uygulanır (TBK m. 224).

Gözden geçirme süresi, esas itibariyle, satılanın alıcıya, vekiline veya temsilcisine devredildiği andan itibaren başlar[77]. İşlerin olağan akışına göre gözden geçirme imkânının doğması yeterli olup, alıcının gözden geçirmeyi kusurlu olarak geciktirmemesi gerekir[78]. Aynı şekilde, gözden geçirmenin, gecikmeye meydan verilmeden işlerin olağan akışına uygun bir süre içinde yapılması gerekir[79]. Bununla beraber, gözden geçirme süresi, satılanın niteliğine, ilgili ticaret dalında mevcut uygulamaya ve ayıbın cinsine göre değişir[80]. Meselâ, çabuk bozulabilecek şeylerde (sebze ve meyvelerde) gözden geçirme süresi kısa olur; uygulamada; etlerde 8 gün[81], portakallarda 9 gün içinde gözden geçirmenin yapılması gerekli görülmektedir. Bazı malların (meselâ pamuk) gözden geçirilmesi için onların işlenmesi gerekir[82]. Bazı makine ve âletlerin gözden geçirilmesi için, tahsis amacına uygun kullanmanın gerçekleşmesi gerekir; meselâ, biçer-döverin denenmesi için yazın, kar temizleme makinesi için kışın gelmesini beklemek gerekir[83]. Bir binanın sıcaklığa karşı tecrit edilmesini kontrol edebilmek için dışarıdaki ısının belirli bir seviyeye gelmesine ihtiyaç vardır[84].

d) Gözden geçirme (muayene) masrafları

Gözden geçirme masrafları satılanın devralmasıyla ilgili olduğu için (TBK m. 211) alıcıya aittir; sözleşmeden dönme halinde, bunların TBK m. 229/II uyarınca satıcı tarafından alıcıya ödenmesi gerekir.

---

77 **Giger**, Art. 201, N. 33.

78 **Cavin**, sh. 89; **Giger**, Art. 201, N. 36.

79 **Furrer**, sh. 52; **Giger**, Art. 201, N. 37.

80 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 22 vd; **Becker**, Art. 201, N. 15-18; OR-**Honsell,** Art. 201, N. 9; **Giger**, Art. 201, N. 37 ve 39.

81 ZBJV 1947, sh. 127 vd.

82 BGE 56 II 38; SJZ 1965, sh. 327 vd.

83 BGE 72 II 417.

84 BGE 81 II 56 yahut JdT 1955 I 562.

3. Bildirme (ihbar) külfeti

TBK m. 223/I, alıcıya, satılanda gördüğü ayıbı satıcıya uygun bir süre içinde bildirme külfeti yüklemektedir. Alıcı, ayıp bildirimi ile satılanda satıcının bildirdiği (vaad ettiği) veya varsayılan niteliklerin bulunmadığını satıcıya bildirmektedir. Ayıp bildirimi, bir tasavvur (fikir) açıklamasıdır[85].

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun tüketici için bildirim yükümlülüğü öngörmemektedir (m. 10/1. Buna göre teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihnde var olduğuna ilişkin adi bir karine öngörülmüştür. İhtilaf halinde malın ayıplı olmadığını satıcı ispat etmelidir. Bu nedenle, tüketici doğrudan doğruya seçimlik haklarını kullanabilir.

Ayıp bildiriminde ayıbın çeşidi somut olarak belirtilmeli ve satılanın kabul edilmediği açıklanmalıdır. Açıkça bir sebep bildirmeden genel bir ayıp iddiasında bulunmak yeterli değildir[86].

Bildirimin geçerliliği herhangi bir şekil şartına bağlı değildir; isbat kolaylığı sağlanması bakımından yazılı şekilde yapılması faydalı olur[87]. Tacirler arasındaki satışlarda da aynı esas geçerli olup, sonradan ayıp sebebiyle sözleşmeden dönülse bile, ayıp bildiriminin TTK m. 18/b. 3'te belirtilen şekilde yapılması gerekmez[88].

Olağan bir gözden geçirme ile anlaşılabilen açık ayıplarda bildirimin uygun bir süre içerisinde yapılması gerekir (TBK m. 223/I). Tacirler arasındaki ticarî satışlarda, teslim sırasında açıkça belli olan ayıplarda teslimden itibaren iki gün içinde; açıkça belli olmayıp muayene sonunda ortaya çıkan ayıplarda ise, teslimden itibaren 8 gün içinde ayıp ihbarı yapılmalıdır (TTK m. 23/c); yani teslim sırasında açıkça belli olmayan ayıplarda muayene ve ihbar teslimden itibaren 8 gün içinde gerçekleşmelidir[89].

---

85 **Furrer,** sh. 54; **Katz,** sh. 67; **von Tuhr/Peter**, sh. 176; **Giger**, Art. 201, N. 61; **Tercier,** N. 332; BGE 107 II 437 yahut JdT 1982 I 282.

86 **Giger**, Art. 201, N. 63 vd; **Keller/Siehr**, sh. 84-85; **Tercier**, N. 322.

87 **Keller/Siehr**, sh. 85; **Giger,** Art. 201, N. 73; **Tercier,** N. 323.

88 **Tandoğan,** I/1, sh. 180; **Arkan**, sh. 144; 11. HD, 25.12.1975, E. 5446/K. 7422. (YKD 1976, sh. 1460).

89 **Tandoğan** I/1, sh. 181; CISG m. 39'a göre alıcının ayıp gibi bir sözleşmeye aykırılığı fark etmesi halinde makul süre içinde satıcıya bildirmelidir. Ancak sözleşmeye aykırılık satıcının bildiği ve alıcıya açıklamadığı olgulara dayanıyorsa Antlaşmanın 38 ve 39. madde hükümlerine dayanamaz (m. 40).

Buna karşılık, gizli yani olağan bir gözden geçirme ile anlaşılamayacak ayıplarda, ayıp ortaya çıktıktan sonra hemen bildirim yapılmalıdır (TBK m. 223/II); yeter ki, zamanaşımı süresi (TBK m. 231) dolmamış olsun[90]. Ticari satış ve mal değişimlerinde gizli ayıplarda da bu hüküm uygulanır (TTK mn. 23/c). Tüketici işlemlerinde gizli ayıbın bildirilmesine ilişkin bir süre kanunda bulunmamaktadır. Ancak TKHK m. 83/I'e göre, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır. Bu nedenle altı aydan sonra ortaya çıkan gizli ayıp TBK m. 223/II'ye uygun olarak hemen satıcıya bildirilmelidir.

Ayıbı bildirme süresi, hukukî niteliği itibariyle, bir hak düşürücü (Verwirkung) süredir[91]. Hâkim görüşe göre[92], hak düşürücü sürelerin, kendiliğinden sonuç doğuracağı ve teknik anlamda def'i olarak ileri sürülmesine ihtiyaç olmadığı için, hak düşürücü olgunun hâkim tarafından re'sen gözönünde tutulması gerekir. Buna karşılık, diğer bir fikre göre[93], hak düşürücü sürenin hâkim tarafından re'sen nazara alınması, dava malzemesinin taraflarca hazırlanması ilkesinin (Verhandlungsmaxime) egemen olduğu usul hukukunda isabetli olmadığı gibi, yanlış kararların verilmesine de sebep olur. Zira, satıcının sürenin geçirildiğini iddia etmemesi veya bunu ileri sürmek istememesi halinde, hâkimin ayıba karşı tekeffül davasını reddetmesinin sebebi açıklanamaz[94]. Keza, ayıp ihbarının süresi içinde yapılıp yapılmadığı, geniş ölçüde her olayın özelliklerine, ticarî teamüle ve bunlara benzer unsurlara bağlıdır[95].

4. Gözden geçirme (muayene) ve bildirimin (ihbarın) yapılmamasının sonuçları

Alıcı, gözden geçirme ve bildirme külfetlerini yerine getirmediği takdirde, satılanı kabul etmiş sayılır (TBK m. 223/II) ve ayıba karşı

---

90 **Keller/Siehr,** sh. 85; **Tercier**, N. 326; **Tandoğan**, I/1, sh. 181.

91 **von Tuhr/Escher,** sh. 162; **Spiro**, Bd. II, sh. 1134; **Witschi**, sh. 61; **Stanislas**, sh. 162; **Yavuz**, Satıcının Sorumluluğu, sh. 117. Ancak, Yavuz'un bu konuda yollamada bulunduğu (sh. 117, dn. 48a) Federal Mahkeme kararı (BGE 107 II 231) ayıba karşı tekeffülden doğan hakların zamanaşımı süresiyle (TBK m. 207/II) ilgili olup, orada ihbar süresinin niteliği ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

92 **von Tuhr/Escher**, sh. 162; **Nabholz,** sh. 153 vd.; **von Büren**, Bd. I, sh. 441; **Gauch**, N. 1566; **Kummer**, Art. 8, N. 11; **Tercier**, DC 1981, sh. 31.

93 **Bucher**, AT, sh. 451, dn. 31; **Spiro**, Bd. II, sh. 1142 vd.; BGE 107 II 54 yahut JdT 1981 I 274; 107 II 178 yahut JdT 1981 I 602.

94 **Spiro**, Bd. II, sh. 1142 vd.

95 BGE 107 II 54.

sorumluluktan doğan haklarını kaybeder. Kanundan doğan bu kabul varsayımı, gizli ayıplarda ayıbın ortaya çıkmasından sonra bildirimin hemen yapılmamasıyla gerçekleşir (TBK m. 223/II). Kabul varsayımına bağlı olarak, ayıp sebebiyle sorumluluktan doğan hakların kaybı, gözden geçirmenin ihmalinin değil, bildirimin zamanında yapılmamış olmasının sonucudur. Bu itibarla, bildirimin zamanında yapılması halinde, satıcının gözden geçirmenin yapılmadığı itirazı önemli değildir[96].

Satıcının ayıbı ağır kusuru ile gizlemesi halinde, o, ayıbın vaktinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz (TBK m. 225)[97]. Satış işlemleri yapmayı meslek haline getirmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir (TBK m. 225/II). Kanun koyucu burada satışı meslek haline getirenlerin bilmesi gereken ayıplar bakımından alıcının ayıbı süresi içinde bildirmemiş olduğunu ileri sürmesi ve sorumluluktan kurtulması imkânını ortadan kaldırmıştır.

5. Mesafe satışlarında alıcının yükümleri

TBK m. 226, mesafe satışlarında, teslim yerinde temsilcisi bulunmayan ve ayıplı olduğu iddia edilen mal ile bizzat ilgilenemeyen satıcıyı zarardan korumak amacıyla, alıcıya bazı ek yükümler getirmektedir. Bu yükümlerin ihlâli, alıcı için, zararı tazmin borcunu doğurur (TBK m. 226/III) veya iddia edilen ayıpla ilgili isbat kolaylığını kaybetmesi (TBK m. 226/II) sonucuna vücut verir[98].

a) Şartları

TBK m. 226'nın uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

aa) Bir mesafe satışı bulunmalıdır

TBK m. 226 hükmü, satılanın kanunî ifa mahallinden başka bir yerde teslim edilmesi kararlaştırılan mesafe satışlarında uygulanır. Buradaki mesafe satışı deyimi, geniş anlamda kullanılmaktadır. Buna göre, bu hüküm, tarafların satılan için sadece bir gönderme borcu öngörmeleri halinde değil, bir götürme borcu (Bringschuld) kararlaştır-

---

96 **Oser/Schönenberger**, Art. 201, N. 5; **Furrer,** sh. 48 vd; **Giger**, Art. 201, N. 21; **Keller/Siehr**, sh. 86.

97 BGE 107 II 419 yahut JdT 1982 I 380.

98 Bkz. ve karş. **Giger**, Art. 204, N.4.

maları (mevsuf mesafe satışı) halinde de uygulanır. Bu konuda, ifa yeri ile teslim yerinin aynı yer olup olmaması önemli değildir[99]. Teslim yerinde satıcının temsilcisinin bulunmaması veya ayıplı olduğu iddia edilen satılan ile bizzat ilgilenememesi halinde, TBK m. 226 anlamında "başka yer" söz konusu olur; belediye veya posta sınırlarının farklı olması bu hususta önemli değildir[100].

bb) Satıcının devir yerinde bir temsilcisi bulunmamalıdır

Satılanın devredileceği yerde satıcının bir şubesi veya temsilcisi bulunmamalıdır.

cc) Alıcı kendisine devredilen satış konusunu ifa olarak kabul etmemelidir

TBK m. 226/I'de yer alan, "satılanın ayıplı olduğunu ileri süren" deyimini, alıcının kendisine devredilen satılanı ifa olarak kabul etmemesi şeklinde anlamak gerekir[101]. Satılanı ifa olarak kabul etmeme, alıcının sözleşmeden dönme veya ayıpsız benzeri ile değiştirme niyetinde olduğunu, yani satılanı iade etmek istediğini ifade eder[102]. Alıcı, bedelin indirilmesini arzu ediyorsa, onun, sadece satılanın durumunu tesbit ettirmesi (TBK m. 226/II) yeterlidir; bunun dışında, satılanın üzerinde serbestçe tasarruf edebilir. TBK m. 226'nın uygulanabilmesi için, alıcının ayıp iddiasının haklı olması veya satıcının ayıbı kabul etmiş olması gerekli değildir[103].

b) Sonuçları

aa) Satılanı koruma (muhafaza) yükümü

Alıcı, satılanı satıcıya göndermeyip, satılanın geçici olarak korunması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu yola başvurmadığı takdirde, satıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle yükümlü olur. Zira satılanı koruma, bir külfet olmayıp, ihlâli tazmin borcu doğuran

---

99 **Cavin**, sh. 92, dn. 8; **Giger**, Art. 204, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 118; OR-**Honsell**, Art. 204, N.2.

100 **Giger**, Art. 204, N. 7; OR-**Honsell**, Art. 204, N. 2.

101 **Oser/Schönenberger**, Art. 204, N. 3; **Giger**, Art. 204, N. 10; **Keller/Siehr**, sh. 118; OR-**Honsell**, Art. 204, N. 4.

102 **Oser/Schönenberger**, Art. 204, N. 3; **Giger**, Art. 204, N. 10; **Tandoğan**, I/1, sh. 185.

103 **Giger**, Art. 204, N. 11; OR-**Honsell**, Art. 204, N. 4.

gerçek anlamda bir hukukî yüküm, yani borçtur[104]. Koruma masrafları satıcıya aittir.

bb) Satılanın durumunu tesbit ettirme

Alıcı, ayıbın varlığını isbat etmek için, satılanın durumunu vakit geçirmeksizin mahkeme yoluyla tesbit ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, satılanın kendisine devredildiği zaman ayıplı olduğunu isbat zorunda kalır; TBK m. 226/II'nin verdiği izlenimin aksine, burada isbat yükünün tersine çevrilmesi değil, alıcının isbat güçlüğüne düşmesi söz konusudur. Zira, MK m. 6 gereğince, ayıbı isbat alıcıya aittir[105].

Satılanın durumunu tesbit ettirme, alıcı için bir borç değil, külfettir; ihlâli tazmin borcu doğurmaz[106].

cc) Satma yetkisi ve yükümü

Satılanın kısa zamanda bozulma tehlikesi varsa, alıcı onu bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığıyla sattırma yetkisine sahiptir; satıcının menfaati satışı gerektiriyorsa, satış alıcı için bir mecburiyettir. Satılan malı sattırmak için kendisine başvurulacak olan mahkeme devir yerindeki görevli mahkemedir. Alıcı, mümkün olan en kısa zamanda, bu satışdan satıcıyı haberdar etmek zorundadır; aksi takdirde alıcı, satıcının zararını tazminle yükümlü tutulur.

V. Ayıba karşı sorumluluktan alıcı lehine doğan seçimlik haklar

1. Seçim hakkının kapsamı

Ayıptan doğan sorumluluğun esas ve şekle ilişkin şartları gerçekleşince (TBK m. 219-226), alıcı lehine bazı seçimlik haklar doğar (TBK m. 227-230). TBK m. 227'ye göre, satılanın ayıplı olması halinde, alıcı, sözleşmeden dönme veya bedelin indirilmesi imkânlarından (TBK m. 227/I, b. 1 ve b. 2) birini kullanabilir. Aynı şekilde, alıcıya, satılanın, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere onarılmasını (TBK m. 227/ I, b.3) veya çeşit satışında satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkı (TBK m. 227/I, b.4) verilmiştir. Tasarının gerekçesinde değiştirme hakkının çeşit borçları ile sınırlı olma-

---

[104] **Giger**, Art. 204, N. 13; **Keller/Siehr**, sh. 118-119; OR-**Honsell**, Art. 204, N. 5.

[105] OR-**Honsell**, Art. 204, N. 6. Karş. **Giger**, Art. 204, N. 21-22.

[106] **Giger**, Art. 204, N. 23; **Honsell**, Art. 204, N. 6; **Keller/Siehr**, sh. 119.

dığı ifade edilmektedir. Parça borçlarında değiştirme hakkı alıcının tek taraflı irade beyanı ile kullanılamaz. Ancak tarafların anlaşması ile parça satışının konusu değiştirilebilir.

TBK m. 227/ II'de, alıcıya, dönme dışında kalan diğer seçimlik haklarda genel hükümlere göre tazminat talep etme hakkı tanınmıştır, dönme halinde istenebilecek tazminat ise TBK m. 229'da özel olarak düzenlenmiştir.

TBK m. 227/III'e göre, satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

2. Seçim hakkının hukukî niteliği

Alıcının ayıba karşı sorumluluk halinde sahip olduğu seçimlik haklarının hukukî niteliği tartışmalıdır. Tartışmanın konusu, alıcının seçimlik haklarının, özellikle dönme hakkının bir yenilik doğuran hak mı, yoksa tarafların anlaşması veya inşaî hükümle gerçekleşen bir talep mi olduğudur[107].

Hâkim fikre göre[108], alıcının seçimlik hakları bir yenilik doğuran hak olup, satıcıya karşı yapılan tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılır. Şayet hukukî şartlar mevcut ise, beyanın satıcıya varmasıyla istenen sonuç, meselâ dönme gerçekleşir. Anlaşmazlık veya itiraz halinde, mahkemenin vereceği karar, bir tesbit hükmünden ibaret olur.

Buna karşılık, bizim de katıldığımız diğer bir fikre göre[109], alıcının seçimlik hakları yenilik doğuran bir hak olmayıp, tarafların bu hususta anlaşmaları veya mahkemenin vereceği yenilik doğuran (inşaî) bir kararla gerçekleşir. TBK m. 227'de yargıca dönme yerine onarılmasına veya bedelin indirilmesine (IV. fıkra), bedelin indirilmesi yerine dönmeye veya ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesine (V. fıkra) karar verme yetkisinin tanınması, ancak bu takdirde bir anlam kazanır. Bu fikre, değiştirilmiş akit teorisi (modifizierte Vertragstheorie) adı verilmektedir[110]. Ancak, 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 202'de "tekeffüle müstenit dava" başlığı altında seçimlik hakların dava yoluyla ileri sü-

---

[107] **Giger**, Art. 205, N. 7 vd.; OR-**Honsell**, Art. 205, N. 1.

[108] **Cavin**, sh. 96; **Furrer**, sh. 64; **Bucher**, BT, sh. 99; **Tercier**, N. 744; **Katz**, sh. 75; **Engel**, sh. 38, 39.

[109] **Giger**, Art. 205, N. 12; **Koller/Siehr**, sh. 88; **Guhl/Koller**, sh. 388; **Stanislas**, sh. 119.

[110] **Larenz**, Bd. II, sh. 48.

rülebileceği, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ise dava yolunu tercih etmemiş olması nedeniyle seçimlik hakların yenilik doğuran hak olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhtilaf halinde mahkemenin vereceği karar inşai nitelik taşımayacak tespit niteliği taşıyacaktır.

TKHK m. 11'e göre, ayıplı mal teslimi halinde, tüketici, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da aşırı masraf gerektirmeyen hallerde ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle TKHK hükümlerinin uygulandığı satışlarda, alıcının (tüketicinin) seçimlik haklarını kullanmak için dava açması zorunlu değildir.

TKHK m. 15/III'e göre, tüketicinin sözleşmeden dönmesi veya ayıp oranında bedelden indirim talep etmesi hallerinde ödenen bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan miktar tüketiciye derhal iade edilir.

Tüketicinin ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesine ilişkin hakları üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanılabilmektedir. Bu bakımdan satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur (m.11/2). Bu hakların satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren en fazla otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Konut ve tatil amaçlı taşınmazlar bakımından süre altmış iş günü olarak düzenlenmiştir (m. 11/4). Söz konusu hakların kullanılması satıcı için orantısız güçlük doğuruyorsa tüketici dönme veya ayıp oranında bedel indirimi haklarından birini kullanabilir (m. 11/3). Kanunun 58. maddesinde ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde[111] satış sonrası hizmetler düzenlenmiştir. Buna göre üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için ilgili Bakanlıkça belirlenen kullanım süresi boyunca satış sonrası bakım ve onarım hizmeti sağlamak zorundadır. Bu tür bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi çıkarılacak yönetmelik-

[111] RG 13.06.2014 tarih ve 29029 sayı. Yönetmeliğin 1. maddesine göre bu düzenleme ekli listede yer alan malların kullanım ömürlerini, azami tamir sürelerini ve satış sonrası montaj, bakım, onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğin 4/ğ maddesine göre mal, ekli listede yer alan taşınır eşyayı ifade etmektedir.

te belirlenen azami süreyi geçmeyecektir (m. 58/3; Yönetmelik m.10/4)[112].

3. Seçim hakkının kullanılması ve tükenmesi

Seçim hakkını alıcının tek taraflı varması gereken irade beyanıyla kullanılabilen bir yenilik doğuran hak olarak nitelendiren hâkim görüş, bu hakkın bir defa kullanılmakla sona ereceğini ve artık bundan dönülemeyeceğini kabul etmektedir[113]. Buna karşılık, değiştirilmiş akit niteliğini savunan diğer görüş taraftarlarına göre[114], alıcının seçimlik haklardan birini kullandığını satıcıya bildirmesi, sorunun dava dışı yolla çözümlenmesi için yapılmış bir icaptır; satıcının bunu kabul etmesiyle veya dava açılması halinde, mahkemenin yenilik doğuran kararıyla seçim hakkı sona erer. Bu cümleden olarak, bedelin indirilmesi davası açan alıcı, dönme hakkından vazgeçmiş sayılır (değiştirme veya onarma isteme davasında da aynı sonuç söz konusudur)[115]. Bununla beraber, seçim hakkını önce onarma veya değiştirme yönünde kullanmaya karar veren alıcı, sözleşmeden dönmek istiyorsa, önce satıcıya TBK m. 123 uyarınca süre vermek zorundadır[116].

Alıcı, dönme davası açtıktan sonra, bedelin indirilmesini veya satılanın değiştirilmesini, davanın ıslahı prosedürü çerçevesinde isteyebilir[117]. Buna karşılık, seçim hakkının dava dışında bir irade beyanıyla kullanılacağını savunanlar, seçim hakkının bir defa kullanılmakla sona ereceği gerekçesiyle, alıcıya bu imkânı tanımamaktadırlar[118].

TKHK m. 56/3'e göre, garanti belgesi verme zorunluluğu bulunan mallarda, tercih hakkını onarım yönünde kullanan tüketiciye, "garanti

---

[112] Azami süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna ya da satıcıyı bildirimi tarihinde başlar. Garanti süresinin geçmesi halinde malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini ispat yükümlülüğü kendisine ait olmak, üzere telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir (Yönetmelik m. 10/4).

[113] **Schubiger**, sh. 59, dn. 2; **Furrer**, sh. 64.

[114] **Giger**, Art. 205, N. 65,66 vd.; **Comment**, FJS 222, sh. 2; **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 7.

[115] **Giger**, Art. 205, N. 67; **Comment**, FJS Nr. 222, sh. 2.

[116] **Giger**, Art. 205. N. 68; B1 ZR 1958, N. 46, sh. 113.

[117] **Giger**, Art. 205, N. 69; **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 7; OR-**Honsell**, Art. 205, N. 3; **Honsell**, sh. 77; **Guldener**, sh. 248; **Stanislas**, sh. 120; BGE 96 II 181 vd.

[118] **Furrer**, sh. 69; **Schubiger**, sh. 59, dn. 2.

süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde 11'inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur." (ayrıca bkz. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, RG. 14.6.2003, S. 25138, m.14).

4. Seçim hakkının sınırlanması

a) Konu yönünden

TBK m. 227 ve devamındaki hükümler yedek (dispositif) hukuk kuralları niteliğinde oldukları için, taraflar sözleşmeyle seçim hakkına veya onun kullanılmasına ilişkin sınırlamalar getirebilirler[119]. Ayıba karşı sorumluluktan doğan taleplerin, sadece dava yoluyla satıcıya karşı ileri sürülebileceği kararlaştırılabilir. Bundan bedelin indirilmesini satış bedelini devralana karşı def'i yoluyla ileri sürülebilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varma zorunluluğu çıkmaz. Taraflar sözleşme ile satış bedelinin karşılığı olan ayıba karşı sorumluluktan doğan hakların üçüncü kişiye geçeceğini de kararlaştırabilirler[120].

Tarafların anlaşması dışında, kanun, alıcının seçimlik hakkına bazı sınırlamalar getirmiştir:

aa) Dönme hakkının sınırlanması

TBK m. 227/IV'e göre, alıcının dönmeye ilişkin beyanda bulunduktan sonra dava açılması halinde, hâkim, mevcut şartlar dönmeyi haklı göstermediği takdirde, satılanın onarılmasına veya bedelin indirilmesine hükmedebilir[121]. Hâkim, şartların dönmeyi haklı gösterip göstermediğini hakkaniyete (MK m. 4) göre değerlendirir. TBK m. 227/IV, satıcıyı koruyan bir hakkaniyet normu olup, hâkime tarafların menfaatini tartmak suretiyle dönme hakkının kötüye kullanılmasını

---

[119] **Furrer**, sh. 65; **Giger**, Art. 205, N. 63.

[120] **Giger**, Art. 205, N. 64.

[121] Bilirkişi raporuna göre ticari aracın ön camından su girişinin önlenmesi için camın sökülmesi, takılması ve izolasyonunun yapılarak ayıbın bu şekilde giderilmesi mümkün olduğundan, ilk derece mahkemesinin satış bedelinin iadesine karar vermesi kabul edilmemiştir (19. HD. 2013/17668 E. 2014/14351 K. – Kazancı-).

önlemek imkânı vermektedir[122]. Ayıp sebebiyle satılandaki değer eksikliğinin küçük olduğu ve alıcının malı başka amaçla kullanabildiği hallerde, dönme yerine bedelin indirilmesine karar vermek gerekir[123]. Meselâ, fırıncının, sipariş edilen unu sözleşmede öngörülenden başka bir ürün imalinde kullanabilme imkânına sahip olması[124]; alıcının, kalitesi düşük bir tahılı da işleyebilmesi[125]. Aynı şekilde dönmenin alıcıya sağladığı fayda ile satıcıya vereceği zarar arasında açık bir oransızlık bulunup bulunmadığına bakmak gerekir[126]. Keza, satılanın geri gönderilmesinin çok fazla masraflı olması halinde, bedelin indirilmesine hükmedilmelidir[127]. Buna karşılık, ayıbın, alıcının bunu bilmesi halinde mevcut şartlara göre sözleşme yapmayacağı derecede önemli olması[128]; satılanın alıcı için kullanılamaz veya esaslı vasıflardan yoksun olması veyahut satıcının ağır kusurlu veya hileli davranışta bulunması hallerinde, hâkim, dönme yerine bedelin tenziline karar veremez[129].

BK m. 228/II'ye göre, satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep nedeniyle yok olmuşsa veya alıcı onu başkasına devretmişse yahut şeklini değiştirmişse, sadece değer eksikliği kadar bedelin indirilmesi talep edilebilir.

818 sayılı Borçlar Kanununun m. 204/II'de geçen kusur (taksir) kavramı, teknik anlamda bir kusur olarak kabul edilmemekteydi. Zira teslimle satılan üzerindeki mülkiyet hakkı alıcıya geçtiği için, onun yok edilmesi hukuka aykırı sayılmaz. Ayrıca aynı maddede satılanın başkasına devri ve şeklinin değiştirilmesi, kusurlu yok etmeyle eşdeğerde tutulmuştur. Bu nedenle sözkonusu hüküm TBK m. 228/II'de satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple yok olması şeklinde düzenlenmiştir. Bu itibarla, bu hükme temel teşkil eden düşünce, alıcının kendi davranışıyla ayıplı satılanda meydana getirdiği hukukî ve fiilî değişikliklerden sorumlu olmasıdır. Böylece alıcı, kendi davranışıyla

---

122 **Giger**, Art. 205, N. 50; **Keller/Siehr**, sh. 87; **Furrer**, sh. 66.

123 **Giger**, Art. 205, N. 50; **Engel**, sh. 41.

124 **Cavin**, sh. 97.

125 **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N.9; **Tandoğan**, I/1, sh. 189.

126 **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 11; **Giger**, Art. 205, N. 50; **Keller/Siehr**, sh. 87.

127 **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 11; **Giger**, Art. 205, N. 50, 55; **Engel**, sh. 41.

128 **Lautner**, sh. 64 vd.

129 **Giger**, Art. 205, N. 52; **Keller/Siehr**, sh. 87/88; BGE 94 II 55.

satılanı yok ettiği takdirde, sözleşmeden dönme hakkını kaybeder[130]. Alıcının satılanın ayıplı olduğunu bilip bilmemesi bu hususta önemli değildir[131]. Motorlu taşıt aracı işletilmesinden doğan tehlikelerde, mücbir sebep veya üçüncü şahsın davranışı kazaya sebebiyet vermedikçe, alıcı, aracın yok olması halinde akitten dönemez[132].

TBK m. 228/II'de satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple esaslı bir şekilde kötüleşmesi veya değer kaybetmesi halinin dönmeye etkisi düzenlenmemiştir. Burada kanun koyucunun mevsuf bir susması söz konusu olmadığı için, aynı esası bu durumda da uygulamak ve alıcının sözleşmeden dönemeyeceğini kabul etmek gerekir[133]. Buna karşılık esaslı olmayan kötüleşme ve değer kaybı hali, dönmeye engel teşkil etmez[134]; alıcı, şayet mevcut ise, satılanı iade zorundadır; bu takdirde, alıcının tazminat ödeme borcu söz konusu olabilir[135].

Satılanın şeklini değiştirme (tağyir), işleme, birleştirme veya karıştırma suretiyle (MK m. 699-700), onun başka bir şey haline getirilmesidir[136]. Alıcının satılanı gözden geçirme amacıyla kullanma veya tüketme zorunda kalması, TBK m. 228/II anlamında dönmeyi engelleyen değişiklik sayılmaz[137].

TBK m. 228/II'de kullanılan "başkasına devretmişse" ifadesini, sadece mülkiyetin geçirilmesi şeklinde anlamamak gerekir; satılan üzerinde rehin, sınırlı bir aynî hak veya eşyaya bağlı bir borç tesisi halleri de dönmeyi engeller[138].

Alıcının ayıbı bilmesine rağmen satılanı kullanmaya devam etmesinin, satılanın sözleşmeye uygunluğunu kabul veya dönmeden vazgeçme anlamına gelip gelmeyeceği, somut olayın özelliklerine göre yorumlanmalıdır[139]. İsviçre Federal Mahkemesi[140], alıcının ayıbı öğrenmesine rağmen geçerli bir sebep olmaksızın (meselâ, şeyin bozul-

---

130 **Giger**, Art. 207, N. 18; OR-**Honsell**, Art. 207, N. 2; **Tandoğan** I/1, sh. 189.

131 **Giger**, Art. 207, N. 18; OR-**Honsell**, Art. 207, N. 2.

132 **Giger**, Art. 207, N. 18.

133 OR-**Honsell**, Art. 207, N. 3; **Giger**, Art. 207, N. 24.

134 **Giger**, Art. 207, N. 26; OR-**Honsell**, Art. 207, N. 3.

135 **Giger**, Art. 207, N. 26 ve Art. 208, N. 14 vd.

136 **Oser/Schönenberger**, Art. 207, N. 9; **Giger**, Art. 207, N. 28.

137 **Giger**, Art. 207, N. 30.

138 **Giger**, Art. 207, N. 33; **Tandoğan** I/1, sh. 189.

139 **Giger**, Art. 207, N. 40 ve 41.

140 BGE 105 II 91 yahut JdT 1979 I 288; JdT 1980 I 137.

masını önlemek) satılanı kullanmakta ısrar etmesini, delâlet edici bir fiil ile dönmeden vazgeçme olarak nitelemiş ve TBK m. 228/II'deki temlik ve tağyire kıyasen alıcının sadece satış bedelinin indirilmesini talep edebileceğine hükmetmiştir.

bb) Bedelin indirilmesi hakkının sınırlandırılması

TBK m. 227/V'e göre, ayıp sebebiyle satılanın değerindeki eksiklik bedele çok yakın ise, alıcı, ancak sözleşmeden dönmeyi veya satılanın benzeri ile değiştirilmesi hakkını talep edebilir.

b) Zaman yönünden

Borçlar Kanunu, alıcının ayıba karşı sorumluluktan doğan seçimlik haklarını kullanmasını, zamanaşımı süresi (TBK m. 231/I; TTK m. 23/c; TKHK m. 12/1) dışında, herhangi bir süreyle sınırlamamaktadır[141]. Satıcının bu şekilde, zamanaşımı süresi sonuna kadar alıcının seçim hakkını kullanmasını beklemek zorunda olması, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir; alıcının satıcı aleyhine konjonktürel dalgalanmalardan yararlanmasına yol açabilir. Bu durumda, gerçek olmayan bir kanun boşluğu bulunduğunu kabul etmek ve bu boşluğu, satıcıya, dönmeyi teklif ederek, dönme beyanını kullanması için alıcıya uygun bir süre verme hakkı (eski BGB § 466) tanımak suretiyle doldurmak gerekir[142].

VI. Dönme (Wandelung)

1. Kavram

Alıcının talebinin satıcı tarafından kabul edilmesi veya hâkimin vereceği dönme kararı ile satış sözleşmesi geçmişe ekili olarak (ex tunc) ortadan kalkar[143]. Dönmeyi alıcının tek taraflı varması gereken irade beyanıyla kullanılan yenilik doğuran bir hak olarak kabul eden görüş taraftarları da, dönme beyanına aynı sonucu tanımaktadırlar[144].

---

[141] **Katz,** sh. 73; **Bucher,** SJZ 1971, sh. 4; **Giger,** Art. 205, N. 70; OR-**Honsell,** Art. 205, N. 2; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 349. Aksi fikirde: **Furrer**, sh. 64, dn. 189'a ait metin; **Gautchi**, Art. 368, N. 4a.

[142] **Giger,** Art. 205, N. 70; OR-**Honsell,** Art. 205, N. 2; **Bucher**, SJZ 1971, sh. 4 vd.

[143] **Giger,** Art. 205, N. 15 **Keller/Siehr**, sh. 88; **Guhl/Koller,** sh. 388, N. 39.

[144] **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 5; **Schubiger**, sh. 63 vd; **Furrer**, sh. 67; **Katz**, sh. 75; **Engel**, sh. 38-39; **Cavin**, sh. 96; **Tercier**, N. 345.

2. Hukukî sonuçları

a) Genel olarak

Dönme üzerine sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan kalkmasının sonucu olarak, yerine getirilmiş edimlerin iadesi gerekir (TBK m. 229/I). Tarafların iade yükümlerinin karşılıklı olarak aynı anda (Zug um Zug) gerçekleşmesi gerekir; TBK m. 97 hükmü burada da uygulanır[145]. Dönmenin amacı, sözleşmenin kurulmasından önceki durumun ihyası (restitutio in integrum) olduğu için, elde edilen semerelerin ve ödenen bedelin faizinin iadesi öngörülmüştür (TBK m. 229/I); aynı şekilde, satıcı alıcının zararını tazminle yükümlüdür (TBK m. 229/I b. 3 ve II)[146].

b) Alıcının borçları

aa) Satılanın iadesi borcu

TBK m. 229/I gereğince, dönme halinde, "alıcı, satılanı,... geri vermekle yükümlüdür". Bu hükümle satıcıya tanınan iade talebinin hukukî niteliği tartışmalıdır. Bir fikre göre[147], mülkiyetin geçişi sebebe bağlı (illî) olduğu için, dönme üzerine satış akdi geçmişe etkili olarak (ex tunc) ortadan kalkınca, tasarruf işlemi (teslim, tescil) de aynı şekilde varlığını kaybeder; satılanın mülkiyeti satıcıda kalır. Bu itibarla, satıcının iade talebi aynî hakka dayanır. Buna karşılık, bizim de katıldığımız fikre göre[148], dönme ile satış sözleşmesi ortadan kalkmayıp, bir tasfiye ilişkisine dönüşür. Bu sebeple, satıcının satılanı iade talebi sözleşmeye dayanır.

TBK m. 228/I'e göre, "Alıcıya ayıplı olarak teslim edilmiş olan satılanı, ayıptan, beklenmedik halden veya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması alıcının sözleşmeden dönme hakkını engellemez. Bu durumda alıcı satılandan elinde ne kalmışsa onu geri vermekle yükümlüdür".

---

145 **von Tuhr/Escher**, sh. 58, dn. 8; **Giger**, Art. 208, N. 11; **Keller/Siehr**, sh. 88; OR-**Honsell**, Art. 208, N. 1; BGE 109 II 29.

146 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 1.

147 **Giger**, Art. 208, N. 9; **Keller/Siehr**, sh. 88; **Cavin**, sh. 96; **Engel**, sh. 42; BGE 109 II 30.

148 **von Büren**, BT, sh. 39, dn. 163; **Bucher**, BT, sh. 98; OR-**Honsell**, Art. 208, N. 3; **Tercier**, N. 756; **Piotet**, DC 1984, sh. 10 vd.; **Huguenin**, N.331; **Yavuz**, sh. 142; BGE 114 II 152 vd.

bb) Semerelerin iadesi borcu

Alıcı, satılandan elde ettiği yararları geri vermek zorundadır (TBK m. 229/I). TBK m. 217/I, b. 1'in aksine, TBK m. 229/I, alıcının elde etmeyi ihmal ettiği istifadelerin değil, sadece fiilen elde ettiği istifadelerin iadesini öngörmektedir. Bu fark, ayıbı daha fazla artırmamak ve satılanın çevresinin olumsuz şekilde etkilenmesini (meselâ hayvan satışında hastalığın bulaşması, ayıplı makineyi kullanan personelin tehlikeye uğraması) önlemek endişesiyle, alıcının satılanı kullanmaktan haklı olarak kaçınabileceği gerekçesiyle açıklanmaktadır[149]. Buna karşılık, *Honsell*'e göre[150], alıcı, TBK m. 217'ye kıyasen, elde etmeyi ihmal ettiği istifadeleri de iade etmekle yükümlüdür. Zira her iki halde de menfaatler durumu ve normun amacı aynı olup, bu konudaki kanun boşluğunun, TBK m. 217 hükmüyle doldurulması gerekir.

Aynı şekilde, alıcı semere getirmeyen bir şeyi kullanmak suretiyle bir menfaat elde etmişse (meselâ, özel bir otomobilin kullanılması), satıcı, bu kullanma karşılığı uygun bir tazminat talep edebilir[151]. Bu tazminatın belirlenmesinde, ayıplı malın kullanılmasından doğan değer kaybı nazara alınmaz; sadece, alıcının elde ettiği iktisadî menfaate bakılır[152].

c) Satıcının borçları

aa) Bedeli iade ve masrafları ödeme borcu

Satıcı almış olduğu bedeli faiziyle beraber alıcıya iade etmek, tam zapt halinde olduğu gibi mahkeme masraflarını ve alıcının satılana yaptığı masrafları ödemekle yükümlüdür (TBK m. 229/I, b. 1 ve 2).

TBK m. 229/I, b. 1 gereğince satıcı satış bedelinden faiz elde etmemiş ve alıcı bedel ödemesi nedeniyle faiz kaybına uğramamış olsa dahi satış bedelini faiziyle birlikte geri vermek zorundadır. Satış bedelinin faiziyle birlikte geri verilmesi kanunla açıkça düzenlenmiştir.

Satıcının ödemek zorunda olduğu mahkeme masrafları, dönme davasından doğan masraflar olmayıp, alıcı ile satılanı ondan devralan üçüncü şahıslar arasındaki davanın masraflarıdır. Bu husus, TBK

---

149 **Giger**, Art. 208, N. 20; **Becker,** Art. 208, N. 2.

150 OR-**Honsell,** Art. 208, N. 4.

151 **Giger**, Art. 208, N. 22; **Keller/Siehr**, sh. 89; OR-**Honsell,** Art. 208, N. 4; BGE 106 II 221 vd.; 13. HD, 7.5.1981, E. 1942/K. 3498 (YKD 1982, sh. 532).

152 **Giger,** Art. 208, N. 23; Sem Jud 1955, sh. 106.

m. 229/I, b. 2'de "satılanın tamamen zaptında olduğu gibi", (TBK m. 217/I, b. 3) ibaresinden anlaşılmaktadır; dönme davasının masrafları, usul hukuku kurallarına göre hükme bağlanır[153]. Satıcının ödemesi gereken, "satılan için yapmış olduğu giderler" (TBK m. 229/I, b. 2), zorunlu ve faydalı masraflardır (yem veya tamir masrafları gibi)[154].

bb) Tazminat ödeme borcu

aaa) Genel olarak

Sözleşmeden dönen alıcının tazminini isteyebileceği zararlar, TBK m. 229/I, b. 3 ve fıkra II'de belirtilmiştir. TBK m. 229/I, b. 3'e göre, alıcı, dönme üzerine, ayıplı maldan doğan doğrudan doğruya zararın tazmin edilmesini isteyebilir. Burada, kusura dayanmayan bir sebep sorumluluğu söz konusudur. Buna karşılık, TBK m. 229/II'de "alıcının diğer zararlarını gidermekle yükümlüdür" ibaresiyle ifade edilen zararlar için, kusura dayanan bir sorumluluk öngörülmüştür. II. fıkradaki zararlara dolaylı zararlar denilmektedir.

TKHK m. 11/6'ya göre, tüketici seçimlik hakkı kullanması nedeniyle ortaya çıkan masrafları bu hakkı yerine getirin taraftan talep edebilir. Tüketici bu masraflar dışında kullandığı seçimlik hakla birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümlerinece tazminat isteme hakkına sahiptir. Buna göre, sözleşmeden dönen tüketici, bu hakkı kullanmasından doğan masraf dışında uğradığı zararı karşı taraftan talep edebilmektedir.

bbb) TBK m. 229/I, b. 3 ve II'nin sınırları

Bu fıkrada yer alan zarar türlerinin kapsamı ve sınırları konusunda doktrin ve yargı kararlarında önemli görüş ayrılıkları mevcuttur[155]. Bu hususta çeşitli kıstaslara başvurulmaktadır:

Bazı yazarlar[156] ve Federal Mahkeme[157] 1953 tarihli bir kararında, müsbet zarar-menfî zarar ayırımını kullanmaktadır. Buna göre, doğrudan doğruya zarar, menfî zararın sadece fiilî zarar kısmını; dolaylı zarar da her türlü müsbet zararı (fiilî zarar ve yoksun kalınan kârı) kapsar.

---

153 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 2; **Cavin**, sh. 90; BGE 79 II 381 vd, Erw. 5.

154 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 2.

155 **Aral**, Kötü İfa, sh. 172 vd.

156 **Giger**, Art. 208, N. 38; **Guhl/Koller**, sh. 388, N. 40; **Cavin**, sh. 100; **Engel**, sh. 43; **Oser/Schönenberger**, Art. 208, N. 5; **Baldi**, sh. 53.

157 BGE 79 II 380 yahut JdT 1957 I 105.

Buna karşılık, üstün tutulması gereken diğer bir fikre göre[158], her iki zarar kategorisi arasındaki sınırı illiyet bağının yoğunluk derecesine göre tesbit etmek gerekir. Böylece, ayıbın ve satılanın normal tahsis amacına uygun olarak kullanılmasının sebep olduğu ilk zararlar, doğrudan doğruya zarardır; satılanın ayıplı olması olgusuna başka olayların katılması sonucu doğan zararlar, dolaylı zarardır. Federal Mahkeme 28.11.2006 tarihli kararında eski içtihadını değiştirip bu görüşe katılmıştır[159].

Bu iki kriteri de yetersiz bulan *Giger*[160], fiilî zarar-yoksun kalınan kâr ayırımını esas almaktadır. Ona göre, menfî zararın fiilî zarar kısmı doğrudan doğruya zararı kapsar; "diğer zarar" deyiminden ise, müsbet zararı anlamak gerekir.

Nihayet *Schönle*'ye göre[161], her iki fıkrada sözü edilen zararlar, dönmenin sonucu olmaları sebebiyle, menfî zarardır. Bu itibarla, sorunu doğrudan doğruya menfî zarar olarak ele almak gerekir. Menfî zararın bu iki türünü illiyet bağına göre belirlemek uygun olur.

ccc) TBK m. 229/I b. 3 gereğince tazmin edilecek doğrudan doğruya zarar

TBK m. 229/I, b. 3'de öngörülen doğrudan doğruya zarar kavramına, ayıplı mal tesliminin ilk ve en yakın sonucu olan fiilî zararlar girer; ayıplı ifa olayına eklenen başka olayların sonucu olarak doğan fiilî zararlar, TBK m. 229/II anlamında, "diğer" veya "dolaylı" zarar sayılır[162].

Buna göre, ayıp sebebiyle doğrudan doğruya bizzat satılanda meydana gelen zarar (Mangelschaden) TBK m. 229/I, b. 3 anlamında zarar sayılır. Meselâ, hatalı fren sebebiyle otomobilin zarar görmesi, termostatın işlememesi sebebiyle bir makinenin zarar görmesi[163].

---

158 **Schönle/Higi**, ZK Art. 195, N. 67 vd ve N. 78; **Venturi,** Commentaire romand, Art. 208, N. 11; **Bucher,** sh. 104 vd; **Guhl/Merz/Kummer,** 7. Aufl, sh. 61; **Fischer,** sh. 286 vd; **Stanislas,** sh. 139; **Furrer,** sh. 68; **Neuenschwander,** sh. 79 vd; **Schubiger,** sh. 79 vd. Ayrıca TBKz ve karş. **Honsel,** BT, sh. 106 vd.

159 BGE 133 III 257 vd.

160 **Giger**, Art. 195, N. 34; Art. 208, N. 34-35.

161 **Schönle**, Sem Jud 1977, sh. 483 vd.

162 **von Tuhr/Peter,** sh. 88-89; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 61; **Schubiger**, sh. 77; **Neuenschwander,** sh. 80; **Furrer,** sh. 27; **Fischer**, sh. 286 vd; **Keller/Siehr**, sh. 62 vd, 91; **Stanislas,** sh. 142; **Lüthi**, sh. 80; **Venturı,** Art. 208, N. 11; **Schönle/Higi,** Art. 195, N. 78; BGE 133 III 257 vd.

163 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 6.

Ayıba karşı tekeffülden doğan sorumlulukta, ayıbı takip eden zararlar (Mangelfolgeschaden) önemli bir yer tutar. Bu tür zararlar, alıcının edim konusu dışında kalan diğer hukukî varlıklarda meydana gelen bir eksilmedir. Meselâ, hasta bir hayvanın tesliminden dolayı alıcının diğer hayvanlarına hastalığın geçmesi, zehirli hayvan yeminin atın ölümüne sebep olması, limonata şişesindeki amonyağın alıcının yemek borusunu tahrip etmesi[164].

Ayıbı takip eden zararda (Mangelfolgeschaden) araya başka bir sebep girmeden, ayıplı ifanın doğrudan sonucu olan bu tür zarardan, satıcı TBK m. 229/I, b. 3'ye göre sorumludur[165]. Meselâ, ayıplı bulaşık makinesinden akan suyun mobilya ve parkeleri bozması. İsviçre Federal Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği bir karara[166] konu teşkil eden olayda, bir satış sözleşmesiyle altı adet papağan satın alan alıcının, bu papağanlardaki virüsün diğer kuşlara bulaşması sonucu altı papağan ile beraber diğer kuşları da ölmüştü. Federal Mahkeme, bu olayda, satıcının, TBK m. 229/I, b. 3 anlamında doğrudan zarar çerçevesinde, alıcının virüs bulaşması sonucu ölen diğer kuşlarının değerini tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul etmiştir. Böylece ayıplı mal tesliminin ilk sonucu olarak doğan ayıbı takip eden zarar TBK m. 229/I, b. 3 anlamında doğrudan zarar kapsamına dahil edilmiştir. Buna karşılık, araya giren başka sebeplerle meydana gelen dolaylı zararlar TBK m. 229/II'nin kapsamına girer. Meselâ, ayıplı bulaşık makinesinden akan suyun elektrik kablosuna girmesi ve buna bağlı kısa devre sonucu yangın çıkması sebebiyle büyük zararların doğması[167].

ddd) TBK m. 229/II gereğince tazmin edilecek dolaylı (diğer) zararlar

Bu fıkra gereğince satıcı, kendisine hiçbir kusurun isnad edilemeyeceğini isbat etmedikçe, akdin ayıplı ifasına uygun illiyet bağıyla bağlı olan her türlü dolaylı (diğer) zararı tazminle yükümlüdür. Kusurun isbatı açısından, TBK m. 112'de öngörülen esaslar burada da geçerlidir[168]. Satıcı, TBK m. 229/II uyarınca alıcının her türlü müsbet

---

164 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 9; **Giger**, Art. 208, sh. 36.

165 **Keller/Siehr**, sh. 90; **Fischer**, sh. 290; Ayrıca bk. ve karş. **Giger**, Art. 208, N. 38; **Doering**, sh. 92 vd. Aksi fikirde: **Honsell**, sh. 86 vd.; OR-**Honsell**, Art. 208, N.9.

166 BGE 133 III 257 vd, özellikle sh. 271, 272, Erw. 3.

167 **Keller/Siehr**, sh. 91.

168 **Giger**, Art. 208, N. 44.

zararını tazminle yükümlüdür[169]. Yoksun kalınan kâr ile sorumluluk menfaatinin (Haftungsinteresse) ihlâli, TBK m. 229/II'nin kapsamına girer. Alıcının satılanı tekrar sattığı üçüncü kişilere ödediği tazminat sorumluluk menfaatinin ihlâlidir[170].

VII. Bedelin indirilmesi davası

TBK m. 227/I, b. 2, alıcıya, satılanı alıkoyup, değer eksikliği karşılığı bedelin indirilmesini dava etme hakkı vermektedir. Bu dava ile ayıplı ifa sebebiyle karşılıklı edimler arasında bozulan dengenin giderilmesi imkânı sağlanmaktadır[171]. Bu takdirde satış sözleşmesi, bedele ilişkin şartlar dışında, varlığını sürdürmekte ve karşılıklı alacaklara ait fer'i haklar devam etmektedir[172].

Dönmede olduğu gibi, burada da alıcının arzu ettiği sonuç (indirim), onun tek taraflı ve varması gereken irade beyanıyla değil, satıcının bedelin indirilmesini kabulü veya mahkeme kararıyla gerçekleşmektedir[173].

Kanun, bedelden indirilecek miktarın nasıl hesaplanacağını düzenlememiş bulunmaktadır. Doktrinde hâkim fikir[174] ve yargı kararları[175], bu konuda nisbî metodun uygulanmasını kabul etmektedirler. Buna göre, kararlaştırılan bedel, satılanın ayıpsız objektif değeri ile ayıplı objektif değeri arasındaki oran dahilinde indirilir.

$$\frac{\text{Ayıpsız objektif değer}}{\text{Ayıplı objektif değer}} = \frac{\text{Kararlaştırılan bedel}}{\text{X (ödenecek bedel)}}$$

$$X = \frac{\text{Kararlaştırılan bedel x Ayıplı objektif değer}}{\text{Ayıpsız objektif değer}}$$

İndirilecek miktar = Kararlaştırılan bedel - Ödenecek bedel.

---

169 **Aral**, sh. 178, dn. 78.

170 OR-**Honsell**, Art. 208, N. 10.

171 **Giger**, Art. 205, N. 16; **Keller/Siehr**, sh. 92; **Cavin**, sh. 102; **Engel**, sh. 42; BGE 85 II 193 yahut JdT 1959 I 605.

172 **Giger**, Art. 205, N. 16.

173 **Giger**, Art. 205, N. 12; **Keller/Siehr**, sh. 92.

174 **Oser/Schönenberger**, Art. 205, N. 18; **Becker**, Art. 205, N. 17; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 350; **Cavin**, sh. 102; **Keller/Siehr**, sh. 92; **Tandoğan**, I/1, sh. 197. Aksi fikirde: OR-**Honsell**, Art. 205, N. 7 ve 8; **Honsell**, sh. 82.

175 BGE 81 II 210; 88 II 413; 89 II 253, 111 II 162.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 10.11.1980, E. 5071 ve K. 5769 sayılı kararında nisbî metodun bu şekilde hesaplandığı görülmektedir:

"....yasada satış parasının indirilmesine uygulanacak bir ölçüye yer verilmiş değildir. Öyleyse, değer eksikliği hesaplanması için bir yöntem bulmak gerekir. Öğretide baskın görüş.... değer eksikliğinin orantılı bir hesap tarzına göre belirleneceğine ilişkindir ki bu yöntem, "nisbî metod" olarak adlandırılmaktadır...

Öyleyse, bu yöntem uyarınca, satış sözleşmesinin kurulması anında nesnenin (şeyin) ayıpsız olarak ya da vaad edilen niteliklerle birlikte taşıyacağı değer ile gerçekte bulunduğu (bozuk) durumda taşıdığı değer arasındaki orana göre, satış parasının indirilmesi gerekir. Satış parasının indirilmesi hesabı şu formülle anlatılabilir:

ad = Satılanın ayıpsız objektif değeri.

gd = Satılanın ayıplı objektif değeri.

sp = Satış parası.

X = İndirim sonunda satış parasının ineceği miktar

i = indirim tutarı

$$\frac{ad}{gd} = \frac{sp}{X} \quad X = \frac{gd.sp}{ad} \quad i = sp - X\dot{I} = sp - \frac{gd.sp}{ad}$$

Örneğin, satılanın ayıpsız objektif değeri 2400, ayıplı objektif değeri 1600 ve satış parası da 1200 olsa; ödenecek miktar

$$\frac{2400}{1600} = \frac{1200}{X} \quad \frac{1200x1600}{2400} = 800\,TL\,.dir.$$

İşte alıcının satıcıya ödeyeceği miktar, 800 liradır. Satış parasından indirilecek tutarı bulmak için de satış parasından (1200'den) bunun (800'ün) çıkarılması gerekir ki, sonuç 400 lira olur. Formüle başvurursak:

$(i = 1200 - \frac{1600x1200}{2400})$ ki indirilecek tutar olarak 400 lira bulunur.

Yargıtay'ın kökleşmiş inançları ile de yukarıda anılan (nisbî metod) benimsenmiş bulunmaktadır (Örneğin, 3. HD. 29.11.1966 Ta. 7843 E. 7506 K; 9.10.1962 Ta. 7285 E., 7573 K; 9.2.1961 Ta. 131 E. 1926 K.).

Bu duruma göre, yukarıda verilen bilgilerin ışığı altında somut (dava konusu) olayda «nisbi metod» uyarınca, satış parasından indirilmesi gereken tutarı belirlemek üzere uzman bilirkişi ya da bilirkişi kuruluna başvurulmalı ve gerekçeli rapor alınmalı ve böylece saptanacak bu tutar, istemle bağlı kalınarak davacı yararına ödetilmelidir". (YKD 1981, sh. 332-333).

Objektif değerin belirlenmesinde hasarın geçiş anı esas alınır[176]. Aynı şekilde, indirimin hesabında değer tayininde ifa yerindeki şartlar nazara alınır[177].

Bedelin indirilmesi bir tazminat niteliği taşımadığı için, indirilecek miktardan TBK m. 51-52'ye göre indirim yapılamaz[178].

Bedelin indirilmesi, alıcının ayıplı ifa dolayısıyla uğradığı zararları karşılamayabilir. TBK m. 227/I, 229. maddenin aksine, alıcının doğrudan doğruya ve dolaylı zararının tazminine ilişkin bir hüküm öngörmemektedir. İsviçre Federal Mahkemesi[179], bu durumda alıcının sadece TBK m. 112'ye dayanabileceğini, TBK m. 229/I, b.3'de öngörülen kusursuz sorumluluğun sadece dönmede uygulanabileceği görüşündedir[180]. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira zarara sebebiyet veren olaylar bakımından dönme ile bedelin tenzili arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde, satılandaki küçük bir ayıp, önemli bir zarara sebep olabilir. Bu tür bir zararını tazmin ettirmek için, alıcının, dönme yolunu seçebileceğini söylemek yeterli bir çözüm değildir; hâkimin dönme davası üzerine, TBK m. 227/I, b. 2 gereğince bedelin indirilmesine karar vermesi halinde, bu ihtimal gerçekleşmez. Bu itibarla, bedelin indirilmesi halinde de TBK m. 229/I, b. 3 ve II hükmünün kıyas yoluyla uygulanabileceğini kabul etmek gerekir[181].

---

176 **Cavin**, sh. 102; **Giger**, Art. 205, N. 27; **Engel**, sh. 43; **Keller/Siehr**, sh. 93; BGE 45 II 660; 81 II 207 yahut JdT 1956 I 104.

177 **Giger**, Art. 205, N. 27.

178 **Cavin**, sh. 102; **Giger**, Art. 205, N. 29; **Engel**, sh. 42; **Tandoğan**, I/1, sh. 197.

179 BGE 107 II 165; 82 II 139; 63 II 405; 4C. 300/2006, 10.02.2007 tarihli karar.

180 **Honsell** (OR-**Honsell**, Art. 205, N.7), doğrudan doğruya zararlar bakımından Federal Mahkemenin görüşüne katılmakla beraber, diğer zararlar için sadece TBK m. 205/III'ün uygulabileceği kanaatindedir.

181 **Cavin**, sh. 103; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 350; **Giger**, Art. 208, N. 56; **von Büren**, BT, sh. 41; **Schubiger**, sh. 90 vd.; **Keller/Siehr**, sh. 94; **Katz**, sh. 78; **Neuenschwander**, sh. 80 vd.; **Venturi**, Art. 208, N. 13; **Schubiger**, sh. 94; **Petitpierre**, Melanges Deschenaux, sh. 329 vd, 332 vd.

VIII. Ayıplı eşyanın değiştirilmesini talep hakkı

1. Alıcının hakkı

TBK m. 227/I, b. 4'e göre, alıcı, imkân varsa satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini de talep edebilir. Alıcıya tanınmış olan değiştirme hakkı yukarıda da ifade edildiği gibi ancak çeşit borçlarında söz konusu olabilir. Zira parça borçlarında, değiştirme hakkı ancak tarafların anlaşmasıyla mümkün olabilir[182].

Satıcının sözleşmeyle kararlaştırılan cinse ait özelliklerin tamamını taşımayan bir şey teslim etmesi (aliud) halinde, bizim de katıldığımız hâkim fikre göre[183], TBK m. 227/I, b. 4 hükmü uygulanmaz. Zira aliud (başka şeyin) tesliminde, alıcı ayıba karşı tekeffül hükümlerine (TBK m. 219 vd.) değil, ancak temerrüde ilişkin genel hükümlere (TBK m. 117 vd., m. 212-213) dayanabilir. Bu takdirde, alıcının gözden geçirme ve bildirme külfetini yerine getirmesi ve TBK m. 231/I' de öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açması zorunluluğu bulunmamaktadır; zamanaşımı açısından TBK m. 146 hükmü uygulanır.

İsviçre Federal Mahkemesi 1968 tarihli bir kararında[184], çeşit satışında kendisine başka bir şey (aliud) teslim edilen alıcının temerrüde ilişkin genel hükümlerin yanında, geniş anlamda ayıp kavramından hareket eden TBK m. 227/I, b. 4 gereğince de sözleşmeden dönebileceğini kabul etmişti. Bazı yazarlar, bu kararı hukuk dogmatiği açısından doğru bulmamakla beraber, başka şey (aliud) teslimiyle ayıplı teslim (peius) arasındaki ayırımın güçlük arzettiği ve keyfî sonuçlar doğurduğu durumlarda, alıcı yararına olarak TBK m. 112 vd. ile m. 219 vd.nın alternatif olarak uygulanabileceğini kabul etmektedirler[185]. Bu-

---

[182] **Giger**, Art. 206, N. 4 ve 5; **Keller/Siehr**, sh. 94; **Tercier,** N. 374. **Lanz,** recht 1996, sh. 254, dn. 53; BGE 94 II 26 yahut JdT 1969 I 330, cons. 4a.

[183] **Schönle**, Art. 185, N. 82; OR-**Honsell**, Art. 206, N. 3; **Honsell**, sh. 100 vd; **Bucher**, BT, sh. 118 vd.; **Keller/Siehr**, sh. 94-95; **Gauch/Schluep**, N. 3178; **Gauch,** Der Werkvertrag, sh. 401 vd, N. 1444 vd.; **Lanz**, recht 1996, sh. 254 vd; **Stanislas**, sh. 177; BGE 121 III 453 vd yahut JdT 1997 I, sh. 204-205. Kural olarak aynı görüşte: **Giger,** Art. 206, N. 9; Vorbem zu Art. 197-210, N. 42; **Weber**, Art. 71, N. 85; **Schraner**, Art. 71, N. 61.

[184] BGE 94 II 34 vd., Erw. 4 yahut JdT 1969 I 322. Federal Mahkeme son zamanlarda verdiği bir kararda (BGE 121 III, sh. 453 vd.) bu görüşü terketmiş bulunmaktadır.

[185] **Giger,** Vorbem zu Art. 197-210, N. 49; **Weber,** Art. 71, N. 93; **Schraner**, Art. 71, N. 62.

na karşılık, azınlıkta kalan bazı yazarlar, çeşit satışında aliud teslime sadece ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinin uygulanacağını ve böylece ayırım güçlüğü ile kısa sürelerden kaçınma imkânının gideri-leceğini iddia etmektedirler[186].

TBK m. 228'de öngörülen sınırlamalar, alıcının satılanın değiştirilmesini talep etmesi (TBK m. 227/I, b. 4) halinde de geçerlidir. Zira dönmede olduğu gibi, burada da, teslim edilen malın iadesi söz konusudur[187]. Böylece, satılanın alıcının kusuruyla ortadan kalkması, onun tarafından başkasına satılması veya şeklinin değiştirilmesi hallerinde, alıcı, ancak bedelin indirilmesini isteyebilir. Buna karşılık, menfaatler durumunun farklı olması ve istisnaî bir düzenleme niteliği taşıması sebebiyle, TBK m. 227/IV'de dönme hakkına getirilen sınırlamalar, alıcının değiştirme talebinde bulunması halinde kıyasen uygulanamaz. Çünkü dönme, satıcıya satılanın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesinden daha ağır sonuçlar yüklemektedir[188].

TBK m. 227/I, b. 4'de öngörülen değiştirme hakkı, muhtevası itibariyle, TBK 125'de yer alan aynen ifa talebine tekabül etmektedir. Çeşit satışında, alıcı TBK m. 125 vd. nda öngörülen imkânlardan yararlanma seçeneğine de sahiptir. Ancak, alıcı TBK m. 227/I, b. 4 uyarınca değiştirme talep ettiği takdirde, TBK m. 229/I, b. 3'ün kıyasen uygulanması sonucu, doğrudan doğruya zararları için kusura dayanmayan sorumluluk esasına göre tazminat talep edebilme avantajına sahip olur[189].

Alıcı, satılanı değiştirme talebini zamanaşımı süresi içinde (TBK m. 231) ileri sürebilir. Dönme halinde olduğu gibi, alıcının spekülasyonda bulunmasını önlemek amacıyla, satıcıya, değiştirme teklifiyle beraber, bu konudaki kararını bildirmesi için alıcıya uygun bir süre verme yetkisi tanınmalıdır[190].

2. Satıcının değiştirme hakkı

TBK m. 227/III, yerinde satışlarda (Platzkauf), satıcıya, derhal satılanın ayıpsız bir benzerini teslim etmek ve alıcının uğradığı zararı tamamen tazmin etmek suretiyle alıcının açacağı davadan kurtulmak yetkisi vermektedir. Mesafe satışlarında satıcıya bu hak verilmemiştir.

---

186 **Schubiger**, sh. 122 vd; **Katz**, sh. 91; **Neuenschwander**, sh. 24.

187 **Giger**, Art. 206, N. 11; **Oser/Schönenberger**, Art. 206, N. 4.

188 **Giger**, Art. 206, N. 11; **Oser/Schönenberger**, Art. 206, N. 5.

189 **Giger**, Art. 206, N. 13; **Tandoğan** I/1, sh. 199.

190 **Giger**, Art. 206, N. 16; **Tandoğan** I/1, sh. 199.

Kanun koyucu, bu düzenleme ile, satılanın ikinci defa gönderilmesinin masraflarını ve hasarını alıcıya yüklemek istememiştir[191].

Kanun koyucunun yerinde satış ile mesafe satışı arasında ayırım yapması çeşit satışının mahiyetiyle ilgili olmayıp, tamamen teknik düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde çabuk ve güvenli taşıma araçlarının bulunması göz önünde bulundurularak, değiştirmenin önemli külfet getirmediği ve sürenin fazla aşılmasına yol açmayacağı hallerde, mesafe satışlarında da satıcıya değiştirme hakkı tanımak gerekir[192].

IX. Zamanaşımı

Satış akdinde ayıba karşı tekeffülden doğan her türlü dava, satılanın alıcıya tesliminden itibaren iki sene geçince zamanaşımına uğrar (TBK m. 231/I). Alıcının satılanın devrinden sonra iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def'i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz (TBK m. 231/I, c. 2). Zamanaşımının kesilmesine ve durmasına ilişkin genel hükümler (TBK m. 153-158) burada da uygulanır. Ayıba karşı tekeffülden doğan haklardan herhangi birine ilişkin kesilme sebebi (TBK m. 154), ileri sürülen ayıpla sınırlı olmak üzere, diğeri hakkında da zamanaşımının kesilmesi sonucunu doğurur. Böylece, dönme davasının açılmasıyla, ileri sürülen ayıp bakımından, bedelin tenzili, tazminat ve değiştirme taleplerine ilişkin zamanaşımları da kesilmiş olur[193]. *Cavin*'e göre[194], ayıba karşı tekeffülden doğan davalardan biri için zamanaşımını kesen fiilin diğer davalar için de geçerli olduğunu kabul etmek, aynı hukukî sebebe dayanmakla beraber farklı davalar söz konusu olduğundan, çok ileri gitme sayılır. Ona göre, "Semenin iadesi talebini ihtiva eden bir dönme davası veya semenin tamamının iadesi amacıyla yapılan icra takibi, semenin indirilmesi veya tazminat davasının zamanaşımını kesebilir. Buna karşılık, semenin bir kısmı veya zararın tazmini için yapılan bir icra takibi, alıcının dönme iradesini göstermediğinden, dönme davasının zamanaşımını kesmez"[195].

Ticaret Kanunu m. 23/1 uyarınca, tacirler arasındaki ticarî satışlarda zamanaşımı süresine Türk Borçlar Kanununun satış sözleşmesine ilişkin hükümleri (m. 231) uygulanacaktır. TKHK m. 12'ye göre,

---

191 **Oser/Schönenberger**, Art. 206, N. 8.

192 **Giger**, Art. 206, N. 21; **Schubiger,** sh. 52.

193 **Oser/Schönenberger**, Art. 210, N. 7; **Giger**, Art. 210, N. 15; **Keller/Siehr**, 101; **Tercier**, N. 338; OR-**Honsell,** Art. 210, N. 4; **Tandoğan** I/1, sh. 201; BGE 96 II 185.

194 Sh. 104.

195 **Cavin,** sh. 104, dn. 28'e ait metin.

"Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır (f. 1). Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz (f. 2). Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz (f. 3)"[196].

Ayıptan doğan sorumlulukla ilgili zamanaşımı süreleri satılanın alıcıya devrinden itibaren işlemeye başlar; aynı esas, zamanaşımı süresi dolduktan sonra ortaya çıkan gizli ayıplar için de geçerlidir[197]. Ard arda devirli (teslim) satışlarda, zamanaşımı süresi, her münferit devir (teslim) tarihinden itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar[198].

Taraflar kanunla öngörülen zamanaşımı sürelerini sözleşmeyle uzatabilirler veya kısaltabilirler. TBK m. 148'de öngörülen yasak, Kanunun 3. babında yer almayan zamanaşımı sürelerine uygulanmaz. Uzatılan sürenin genel zamanaşımı süresi olan on yılı (TBK m. 146) geçmemesi gerekir[199]. TBK m. 231/I'de sadece uzatmadan bahsedilmesi kısaltmaya engel değildir; TBK m. 221'in taraflara tanıdığı ayıba karşı tekeffülden doğan sorumluluğu sınırlama imkânı, bu maddede öngörülen şartlar dahilinde, zaman unsuru yönünden kısıtlamayı da kapsar[200].

Tarafların sözleşmeyle tesbit ettikleri garanti sürelerinin anlamı şüpheli olabilir; böyle bir garantinin anlamını somut olayın özelliklerine göre yorumlamak gerekir. Tarafların kanunî zamanaşımı sürelerinden kısa bir garanti süresi öngörmeleri, şüphe halinde zamanaşımı süresinin kısaltılması değil, ayıba karşı tekeffülden doğan sorumlulu-

---

196 Tüketici işlemi, ticari veya mesleki amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicilerle kurulan eser, taşıma, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeleri de kapsayan her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak tanımlandığından (m. 3/l) zamanaşımı süreleri söz konusu ilişkiler bakımından da göz önünde tutulmalıdır.

197 **Giger**, Art. 210, N. 36; **Keller/Siehr,** sh. 101; OR-**Honsell**, Art. 210, N. 4; BGE 89 II 409; 107 II 231.

198 **Giger**, Art. 210, N. 39; OR-**Honsell**, Art. 210, N.4.

199 **von Tuhr/Escher**, sh. 217; **Oser/Schönenberger**, Art. 210, N. 6; **Giger**, Art. 210, N. 43; OR-**Honsell,** Art. 210, N. 5; **Furrer**, sh. 87; **Tandoğan** I/1, sh. 201; BGE 99 II 189.

200 **Giger**, Art. 210, N. 44; **Keller/Siehr**, sh. 101 ve 102.

ğun garanti süresinde ortaya çıkan ve derhal ihbar edilen ayıplarla sınırlandırılması anlamına gelir[201]. Buna karşılık, kanunî zamanaşımı süresinden uzun bir garanti süresi öngörülmesi, zamanaşımı süresinin, ihbar süresinin bitiminde[202] veya alıcının garanti süresi içinde tesbit edip hemen ihbar etmesi kaydıyla, ayıbın öğrenildiği tarihte işlemeye başlayacağı şeklinde[203] değerlendirilmektedir. Bu düşüncede olanlar, garanti süresinin bitiminden sonra ortaya çıkan ayıpların ancak def'i yoluyla ileri sürülebileceği; garanti süresinin son gününde öğrenilen ayıplara ilişkin taleplerin de, bu tarihte işlemeye başlayacak kanunî zamanaşımı süresi içinde dava edilebileceği sonucuna varmaktadırlar[204]. Bu görüşün ayıba karşı tekeffülle ilgili anlaşmazlıkların kısa sürede giderilmesini amaçlayan kanunî düzenlemelerle ve basit bir ödeme emriyle zamanaşımının kesileceğini kabul eden Borçlar Kanunu'nun (m. 154/b. 2) sistemiyle bağdaştırılması mümkün değildir. Bu itibarla, kanunî zamanaşımı süresinden uzun garanti sürelerini, şüphe halinde, teslimle başlayan bir zamanaşımı süresi olarak kabul etmek gerekir[205]. TKHK 57. madde ihtiyari garantiyi düzenlenmiştir. Buna göre, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydı ile satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından ilave taahhüt verilebilir. Kanunî zamanaşımı sürelerine eşit garanti süresi kararlaştırılması, bu süre içinde satılanın ayıpsız olduğunu garanti anlamına gelir. Böyle bir düzenleme, sadece ayıbın bulunduğu zamana ilişkin isbat yükünün yer değiştirilmesi sonucunu doğurur; alıcı sadece ayıbın mevcudiyetini isbatla yükümlü olup, ayrıca hasarın geçişi anında satılanın ayıplı olduğunu kanıtlamak zorunda değildir[206].

Ayıba karşı tekeffülden alıcı lehine doğan haklar, zamanaşımı süresinin dolmasıyla eksik borç haline gelirler ve satıcının zamanaşımı def'inde bulunması halinde, dava yoluyla elde edilemezler[207]. Bu du-

---

201 **Furrer**, sh. 92; **Giger**, Art. 210, N. 56; OR-**Honsell**, Art. 210, N.5; SJZ 1959, sh. 90.

202 Bl ZR 1944, sh. 275.

203 **Furrer**, sh. 91; OR-**Honsell**, Art. 210, N. 5.

204 **Furrer**, sh. 91, 92.

205 **Giger**, Art. 210, N. 57-58; **Witschi**, sh. 63.

206 **Giger**, Art. 210, N. 55; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 351; **von Büren**, BT, sh. 50.

207 **Giger**, Art. 210, N. 64; OR-**Honsell**, Art. 210, N. 6. Aksi fikirde olan **Keller/Siehr** (sh. 102) ve Federal Mahkeme'ye (BGE 104 II 357) göre, TBK m. 207/II'de öngörülen süre hak düşürücü bir süredir.

rumda, TBK m. 231/I, c. 2, alıcıya, satılanın devrinden itibaren iki yıl geçmeden ihbar ettiği ayıplardan doğan haklarını def'i yoluyla ileri sürme imkânı tanımaktadır. Bunun için, bu fıkrada öngörülen ayıp bildiriminin, TBK m. 223'de belirtilen şekillerde ayıbın öğrenilmesinden sonra yapılması şarttır[208]. Zamanaşımı süresinin dolmasından sonra ortaya çıkan ayıplar bakımından böyle bir def'i hakkı bulunmamaktadır.

TBK m. 231/I, c. 2'de söz konusu olan def'i hakkı, dar ve teknik anlamda def'i olmadığı için, alıcı, bildirim yükümüne ilişkin kayıtlar çerçevesinde, satıcıya karşı takas beyanında bulunabilir. Bu sonucun elde edilmesi için satıcının alacağının aynı hukukî işlemden doğması şart değildir; satıcının alıcıdan olan alacağının ayıba karşı sorumluluktan doğan alacağın tâbi olduğu zamanaşımı süresi içinde mevcut ve muaccel olması, yani takas şartlarının bulunması yeterlidir[209].

Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz (TBK m. 231/II); bu halde, TBK m. 146'da öngörülen on yıllık genel zamanaşımı süresi uygulanır. Zira ayıba karşı sorumluluktan doğan alacaklar sözleşmesel niteliktedir; TBK m. 231/I, TBK m. 146'da yer alan genel kuralın istisnası olup, TBK m. 231/II'nin amacı ağır kusur halinde genel kuralın uygulanmasıdır[210]. Böyle bir durumda bazı yazarların iddia ettiği gibi[211], ağır kusurun haksız fiil teşkil ettiği fikrinden hareket edilerek TBK m.72 hükmünün uygulanacağı sonucuna varılamaz. Ağır kusur ile ayıbın gizlendiğinin devirden kısa bir süre sonra öğrenilmesi halinde iki yıllık kısa zamanaşımı süresi uygulanacağından, kanun koyucunun ağır kusurla ayıbın gizlenmesi ve farklı bir zamanaşımı uygulanması yönündeki iradesinin bir anlamı kalmayacaktır. TKHK m. 12/3'te "Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Buradan yararlanılamayacağı ifade edi-

---

208 **Giger**, Art. 210, N. 65-66; **Keller/Siehr**, sh. 102; BGE 107 II 54; 104 II 358.

209 **Aral**, Takas, sh. 57; **Giger**, Art. 210, N. 68; OR-**Honsell**, Art. 210, N. 7; **Tandoğan** I/1, sh. 202; BGE 91 II 216 vd yahut JdT 1966 I 177 vd.

210 **Oser/Schönenberger**, Art. 210, N. 9; **Giger**, Art. 210, N. 73; **Keller/Siehr**, sh. 103; BGE 107 II 231 vd. yahut JdT 1982 I 72; 81 II 138; 116 II 431 cons. 3b. **Cavin**, sh. 106; CR CO I-**Venturi**, Art. 210, N. 1 ve 14. **Tandoğan** I/1, sh. 203; **Yavuz**, Satıcının Sorumluluğu, sh. 164. Aksi fikirde, yani haksız fiile ilişkin TBK m. 60 hükmünün uygulanması yönünde: **Becker**, Art. 210, N. 4; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 345; **Spiro**, Bd. I, sh. 85, 700 ve 711.

211 dn. 216'da belirtilen yazarlar.

len zamanaşımı süresini, TKHK m. 12/1 ve 2'de öngörülen süreler olarak anlamak gerekir. Bu durumda yukarıda da belirtildiği gibi TBK m.146 hükmünün uygulanacağını kabul etmek gerekir.

X. Ücretsiz onarım isteme hakkı

TBK m. 227/I, b. 3'e göre, alıcı, "aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme" hakkına sahiptir. Bu hükümden anlaşıldığı gibi, onarım isteme hakkının kullanılabilmesi için, onarımın, aşırı bir masrafı gerektirmemesi lazımdır. Aynı durum TKHK m. 11//I/c'de de düzenlenmiştir.

TKHK m. 11/2'ye göre ücretsiz onarım hakkı satıcı dışında üretici veya ithalatçıya karşı da ileri sürülebilir. Bu bakımdan satıcı, üretici ve ithalatçının müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak, üretici veya ithalatçı satıcıdan farklı olarak ayıbın malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra meydana geldiğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.

Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi halinde buna ilişkin irade beyanının muhatabına yöneltilmesinden itibaren otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Konut ve tatil amaçlı taşınmazlar için bu süre altmış iş günü olarak düzenlenmiştir (m. 11/4).

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin Eki Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu olan Ürünler Listesinde gösterilen mallar bakımından tüketicinin ücretsiz onarım hakkı bu yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir[212]. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanabilir (m.11/4).

Tüketici işlemlerinde garanti süresi geçtikten sonra servis istasyonu tarafından malın montajı, bakımı ve onarımının yapılması ve aynı arızanın bir yıl içinde tekrar meydana gelmesi halinde tüketiciden ücret talep edilemez. Ancak malın kullanım kılavuzuna aykırı kullanım

---

[212] Yönetmelik Eki Listede örneğin sağlık sektöründe kişisel kullanım cihazlarından tansiyon aletleri ve kan değeri ölçen cihazların kullanım ömrü beş yıl, azami tamir süresi 20 iş günü; bedensel engellilere ait cihazlardan tekerlekli sandalyeler 10 yıl ve 20 iş günü; güneş gözlükleri ve gözlük çerçeveleri beş yıl ve 20 iş günü; elektrikli oda ısıtıcıları ve şofbenler 10 yıl ve 20 iş günü; çep telefonları beş yıl ve 20 iş günü; araç lastikleri üç yıl ve 20 iş günü; buzdolapları 10 yıl ve 20 iş günü olarak öngörülmüştür.

nedeniyle meydana gelen arızalar bu hükmün kapsamı dışındadır (Yönetmelik m. 10/6)[213].

XI. Ayıptan doğan sorumluluğun sözleşmeyle sınırlandırılması veya kaldırılması

1. Genel olarak

Borçlar Kanunu'nun ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümleri yedek hukuk kuralı niteliğindedir. Bu itibarla, satış sözleşmesinin tarafları, sözleşme serbestisi ilkesine uygun olarak, kanunun çizdiği sınırlar dahilinde (TBK m. 221 ve 115-116) ayıptan doğan sorumluluğu sözleşmeyle sınırlayabilirler veya kaldırabilirler. Uygulamada çok rastlanmamakla beraber, bu sorumluluğun ağırlaştırılması da mümkündür[214].

Sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin şartlar, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla bağlayıcılık kazanır; tek taraflı irade beyanı yeterli değildir[215]. Bu konudaki irade beyanı açık veya zımnî olabilir; eski bir arabanın düşük fiyatla satılması veya satıldığı yer standartlarına uymayan ve yabancı bir ülkede imal edilmiş bir makinenin satışı halinde zımnî irade beyanlarına dayanan böyle bir anlaşma mevcuttur[216]. Buna karşılık, taşınmaz satışlarında sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan kayıtların resmî senette yer alması gerekir[217].

2. Yorumlanması

Sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan kayıtların kapsam ve muhtevası, tarafların iradelerinin, güven ilkesine ve somut şartlara göre yorumlanması suretiyle belirlenir[218]. Açık olmayan sorumsuzluk kayıtlarını dar ve alıcı lehine yorumlamak gerekir[219]. Bu cümleden olarak, bir binanın ayıbından dolayı sorumluluğun kaldırılması, inşaat alanına

---

213 Tüketici işlemlerinde arızanın giderilmesi için malın garanti süresi içinde yetkili servis veya satıcıya tesliminden itibaren on iş günü içinde onarımın sağlanamaması halinde tamir tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip bir başka balın tüketiciye tahsis edilmesi gerekir (Yönetmelik m. 14/4).

214 **Keller/Siehr**, sh. 112; **Giger**, Art. 199, N. 4; OR-**Koller**, Art. 199, N. 1; **Engel**, sh. 46.

215 **Keller/Siehr**, sh. 109.

216 **Giger**, Art. 199, N. 17; OR-**Honsell**, Art. 199, N. 1; BGE 95 II 124.

217 **Koller/Schumacher**, Der Grundstückkauf, N. 806; **Giger**, Art. 199, N. 19; OR-**Honsell**, Art. 199, N. 1.

218 **Keller/Siehr**, sh. 110; **Giger**, Art. 199, N. 10; BGE 109 II 25. 126 III 67.

219 **Cavin**, sh. 86; **Giger**, Art. 199, N. 10; OR-**Honsell**, Art. 199, N. 3; BGE 91 II 349; 109 II 25; 126 III 67, Erw. sa.

ilişkin ayıptan sorumluluğu kapsamaz[220]; satıcının hiç bir ayıptan sorumlu olmayacağı kaydı, satılan taşınmazın maddî ayıplarına ilişkin olup, onun üzerine inşaat yapılabilirliği kapsamaz[221]; sözleşmeye konan genel sorumsuzluk kayıtları, alıcının dürüstlük kuralına göre tahmin edemeyeceği ayıpları kapsamaz[222].

Satıcının nitelik vaadinde bulunduğu satış sözleşmelerinde, onun sorumluluğunu kaldıran kayıtların bulunması bir çelişki teşkil eder; borçlunun sözleşmeye sadakati ve sözleşmenin hukuken bağlayıcılığı ile bağdaşmaz. Böyle bir durumda, sorumsuzluk kaydının yanlış anlamaya sebep olmayacak şekilde ifa edilmesi şartıyla, söz konusu kaydın bildirilen vasıfların dışında kalan ayıplara ait olduğunu kabul etmek gerekir[223].

3. Kanunî sınırları

TBK m. 221'e göre, satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Bu hükmün amacı, satıcının, sadakat yükümüne aykırı olarak alıcı nezdinde satılanın vasıfları hakkında yanlış bir görünüm yaratmasını ve alıcının yanlış tasavvurundan yararlanarak sorumsuzluk kaydına onu razı etmesini önlemektir[224]. TBK m. 221'e göre, ayıptan doğan sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması, sadece susma yoluyla kasden aldatma değil, mevcut olmayan vasıfların ağır kusurla mevcut gösterilmesi ihtimalinde de geçersiz olur[225]. Ayıbın ağır kusurla gizlenmesi halinde sorumsuzluk şartı geçersiz olur; satış sözleşmesinin diğer kısımları bu butlandan etkilenmez; buradaki kısmî butlan hali, TBK m. 27/II'nin uygulanmasına ihtiyaç olmadan, yani ondan bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Aksi takdirde, TBK m. 221'in amacı gerçekleşmemiş olur. Zira, alıcı sözleşmenin tamamının geçersiz olacağı düşüncesiyle, sorumsuzluk şartının geçersizliği ileri sürmekten vazgeçebilir[226].

TBK m. 115 ve 116/III'de öngörülen sorumsuzluk şartlarıyla ilgili sınırlamalar, ayıptan doğan sorumluluk halinde de TBK m. 221 ile bir-

---

220 BGE 42 II 499 vd.

221 BGE 95 II 275 vd.

222 **Giger**, Art. 199, N. 10.

223 OR-**Honsell**, Art. 199, N. 3. Ayrıca bk. **Keller/Siehr**, sh. 110; BGE 109 II 25; 73 II 224 vd.

224 **Keller/Siehr**, sh. 112-113; **Giger**, Art. 199, N. 26.

225 **Keller/Siehr**, sh. 113.

226 **Keller/Siehr**, sh. 113; **Giger**, Art. 199, N. 51; **von Tuhr/Peter**, sh. 227, dn. 31.

likte uygulanır. Zira TBK m. 221, ayıptan doğan sorumluluğun kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın sınırlarını sadece ayıbın ağır kusur ile gizlenmesi açısından düzenlemektedir. Bunun dışında kalan hallerde TBK m. 115/II ve m. 116/III hükümleri, şartları gerçekleştiği takdirde uygulanabilir. Bu sonuncu hükümlerde kanun koyucu, kusur ilkesinin zayıflatılmasını önlemek istemiştir. Diğer taraftan TBK m. 115 ve 116'da yer alan sorumluluk kavramına sözleşmeden doğan yükümlerin ihlâlinden doğan sorumluluk da girer. Ayıptan doğan sorumluluk ise, özel olarak düzenlenmiş bir gereği gibi ifa etmeme halinden doğan bir borçtur[227].

XII. Ayıptan doğan sorumluluk ile Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerindeki diğer hukukî imkânlar arasındaki ilişki

1. Genel olarak

Ayıptan doğan sorumluluk (TBK m. 219 vd.), TBK m. 112'de düzenlenen kötü ifanın (nitelik yönünden gereği gibi ifa etmemenin) satış sözleşmesinde özel olarak düzenlenmiş bir şeklidir. Bazı hallerde ayıptan doğan sorumluluğun maddî şartları ile Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerinde düzenlenen diğer hukukî imkânlardan hata, hile ve haksız fiilin şartlarının (Tatbestandvoraussetzungen) aynı zamanda gerçekleşmesi de mümkündür[228]. Bu itibarla, ayıptan sorumluluk ile Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerinde düzenlenmiş bulunan diğer hukukî imkânlar arasındaki ilişkinin tesbit edilmesi gerekir.

2. Ayıptan doğan sorumluluk ile hata sebebiyle iptal arasındaki ilişki

Satış sözleşmesinin kurulması esnasında satılanda bildirilen ve gerekli vasıfların bulunmasının, alıcı için sözleşmenin temeli sayılmasına dürüstlük kuralının imkân verdiği hallerde, parça satışında bu niteliklerin bulunmaması, ayıptan doğan sorumluluğun yanında, temel hatasının (TBK m. 32) şartları da gerçekleşmiş olur. Çeşit satışında edim konusu, sözleşmenin kurulduğu anda henüz somut olarak belirlenmediği için, bu durum söz konusu olmaz. Parça satışında, böyle bir durumda, alıcının, ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hakların yanında temel hatasına da seçimlik olarak dayanıp dayanamayacağı hususu tartışmalıdır.

---

[227] **Keller/Siehr**, sh. 113-114; **Giger**, Art. 199, N. 6; **Furrer**, sh. 85; **Gautschi**, Art. 367, N. 34; **Lörtscher**, sh. 114 vd. Aksi fikirde: **Becker**, Art. 100, N. 6; **von Tuhr/Escher**, sh. 119, dn. 34.

[228] **Keller/Siehr**, sh. 103; **Tandoğan** I/1, sh. 203.

İsviçre hukukunda hayli taraftarı olan bir fikre göre[229], bir genel hüküm (lex generalis) olan TBK m. 32 hükmü karşısında, ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümler (TBK m. 219 vd.) bir özel hüküm (lex specialis) niteliğindedir. Bu itibarla, böyle bir durumda, hata hükümlerine başvurmak imkânı bulunmayıp, sadece ayıp hükümleri uygulanır. Aksi takdirde, kanun koyucunun ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümlerin ileri sürülebilmesi için koyduğu kısıtlayıcı şartlar ve bunların konulmasıyla güdülen amaç boşa çıkarılmış olur. Federal Mahkeme bu görüşü sadece hayvan satışı bakımından kabul etmiştir[230].

Alman hukukunda hâkim görüş de, hata hükümlerinin ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümleri yanında seçimlik olarak uygulanmasını reddetmekte, ayıp hükümlerinin münhasıran uygulanmasını kabul etmektedir[231].

Buna karşılık, İsviçre Federal Mahkemesi'nin yerleşmiş içtihatlarında savunulan[232] ve doktrinde bazı yazarlar tarafından[233], haklı olarak, benimsenen diğer bir fikre göre, hata hükümleri ile ayıptan doğan sorumluluk hükümleri arasında genel hüküm-özel hüküm ilişkisi bulunmamaktadır; bunlar farklı olguları düzenlemektedirler. Alıcı, ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinin yanında, seçimlik olarak, hata hükümlerine de dayanabilir; bunun için, gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin zamanında yerine getirilmemesi veya iki yıllık zamanaşımı süresinin geçirilmiş olması bir engel teşkil etmez.

---

229 **Becker**, Art. 24, N. 22; **Merz**, FS Guhl, sh. 85 vd; aynı yazar, ZBJV 1974, sh. 47; **Cavin**, sh. 114 vd; **Magnin**, sh. 106; **Wiegand**, recht 1989, sh. 101 vd; **Honsell**, sh. 111 vd; OR-**Honsell**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 9; **Guhl/Koller** sh. 393, N.63.

230 BGE 110 II 70.

231 **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 236 vd.

232 BGE 58 II 207; 82 II 139; 82 II 411 yahut JdT 1957 I 184; BGE 88 II 412 yahut JdT 1963 I 471; BGE 102 II 103; 106 II 34; 114 II 131 vd yahut JdT 1988 I 588 vd.

233 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 59 vd; **Bühler**, SJZ 1978, sh. 1 vd; **Oser/Schönenberger**, Art. 197, N. 5; **Katz**, sh. 118; **Bucher**, sh. 109 vd; **Keller/Siehr**, sh. 108 vd; **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 229 vd; **Schwenzer**, N. 39, 42; **Fastrich**, (zur Frage der Kankurreinz von Kaufrechtlicher sachmangelhaftung und Schadenersatz aus Delikt), **AjP 1995/9** sh. 115 vd. **Eren**, C. I, sh. 437; **Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop**, sh. 440 vd; **Kocayusufpaşaoğlu**, Borçlar Hukuku, sh. 335 vd; **Oğuzman/Öz**, sh. 84, dn. 178. Yargıtay'ın 4.6.1958 tarih ve E. 15/K.6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde (Yarg. İçt. Bir. Kar., C.5, sh. 101) ve 4. HD nin 12.10.1977 tarih ve E.12191/K. 9487 sayılı kararında (**Karahasan** I, sh. 282) bu görüş kabul edilmiştir.

Kocayusufpaşaoğlu'nun isabetle belirttiği gibi[234], "Ayıp hükümlerine münhasır uygulama alanı tanıyan birinci görüş çok serttir ve bazı hallerde alıcıyı, adalet duygusunu zedeleyecek biçimde mağdur etmeye elverişlidir. Kanun koyucu da bu düşüncelerden hareketle TBK m. 231'de öngörülen zamanaşımı süresini iki yıl olarak belirlemiştir. Mülga Ticaret Kanunu m.25/b. 4'te düzenlenmiş bulunan altı aylık süreyi ise kaldırmış TTK m. 23'e zamanaşımı süresini ticari satışlar bakımından azaltan hükmü kaleme almamıştır. Böylece ticari satışlarda da zamanaşımı süresi iki yıl olarak uygulanmaktadır (bkz. TTK m. 23 Gerekçesi).

3. Ayıptan doğan sorumluluk ile hile arasındaki ilişki

Satıcının satılandaki ayıbı ağır kusur ile gizlemesi veya onda bulunmayan vasıfları mevcut göstermesi halinde, ayıptan doğan sorumluluk ile hilenin şartları aynı anda gerçekleşmiş olur. Şüphesiz, ayıbın ağır kusurla gizlenmesi için, satıcının açıklama yükümünü ihlâl etmiş olması gerekir[235].

Hata halinde olduğu gibi, burada da alıcının ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinin yanında seçimlik olarak, hile hükümlerine de başvurabileceğini kabul etmek gerekir[236].

Hile halinde, alıcı TBK m. 223 ve m. 231/II uyarınca bildirim külfetinden (TBK m. 223) ve iki yıllık kısa zamanaşımı (TBK m. 231/I) gibi ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin katı sınırlamalardan kurtulur. Bununla beraber, ayıptan doğan elverişli imkânlar mevcut iken, hile hükümlerine dayanmak alıcıya herhangi bir yarar sağlamaz[237]. Hile hükümlerine göre sözleşmenin iptali, alıcının gözden geçirme ve bildirim külfetini yerine getirmemesi veya ayıptan doğan haklara ilişkin zamanaşımı süresinin (TBK m.231) dolması halinde önem taşır[238].

---

234 **Kocayusufpaşaoğlu**, Borçlar Hukuku, sh. 335.

235 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 68; **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 239.

236 **Giger**, Vorbem zu Art. 194-210, N. 69; **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 239; **Becker**, Art. 28, N. 16; **Oser/Schönenberger**, Art. 197, N. 5; OR-**Honsell**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 12; **Keller/Siehr**, sh. 107 vd; BGE 81 II 217.

237 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N: 70. **Katz**, sh. 131; **Baudenbacher/ Spiegel**, sh. 239. **Gulh/Merz/Koller**, buradaki yarışmanın pratik bir yararının olmadığını ifade etmektedir (sh. 394, N.65).

238 OR-**Honsell**, vorbem, zu Art. 197-210, N.12; **Hurlıman-Kaup**, ZBJV 138, N.137-151.

İsviçre Federal Mahkemesi 14.12.2000 tarihli kararında[239] hile sebebiyle iptal ile ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümlerine seçimlik olarak başvurulacağına ilişkin görüşünü tekrarlamış; ancak böyle bir seçimlik imkân mevcut iken, önce ayıptan sorumluluk hükümlerine göre dava açan alıcının, bununla hile ile sakat sözleşmeye TBK m.39 gereğince icazet vermiş olacağı sonucuna varmıştır.

Federal Mahkemenin bu kararı *Gauch* tarafından[240] çeşitli açıdan ve esaslı bir biçimde eleştirilmiştir. *Kramer*[241] de söz konusu karara gerekçe yönünden katılmadığını ifade etmiştir. Başlangıçta yarışmayı kabul eden bu karar, sonuçta hile ile ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümlerinin yarışmasını anlamsız hale getirmiştir.

4. Ayıptan doğan sorumluluk ile haksız fiil arasındaki ilişki

Ayıplı bir mal teslimi, aynı zamanda, bir haksız fiil (TBK m. 49 vd.) teşkil edebilir. Bizim de katıldığımız hâkim fikre göre[242], bu durumda, ayıptan doğan talepler ile haksız fiilden doğan talepler seçimlik olarak uygulanabilir.

İsviçre Federal Mahkemesi eski bir kararında[243], haksız fiil hükümlerinin uygulanmasını gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin yerine getirilmesi şartına bağlamıştır. Ancak, Federal Mahkeme daha sonraki kararlarında[244], konuyu çözümsüz bırakmıştır. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira ayıptan doğan sorumluluk davasının açılmasına ilişkin özel kurallar (TBK m. 226 vd.) konuluş amaçları itibariyle haksız fiilden doğan sorumlulukta uygulanmaz[245].

---

239 BGE 127 III 85 Erw. 1b

240 **Gauch**, Sachgewährleistung und Willensmängel beim Kauf einer mangelhaften sache, Recht 2001, sh. 184 vd.

241 **Kramer**, AJP 2001/12, sh. 1456.

242 **Cavin**, sh. 110 vd; **Neuenschwander**, sh. 49; **Schubiger**, sh. 139; **Katz**, sh. 152 vd; **Guhl/Koller**, sh. 393, N.64; **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 55-56; **Keller/Siehr**, sh. 107; OR-**Honsell**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 7; OR-Wiegand Art 97, N.58; BGE 90 II 86; 67 II 132;107 II 168, Erw. 8a.

243 BGE 67 II 132, Erw. 2. Aynı yönde: **Schubiger**, sh. 139.

244 BGE 90 II 86 yahut JdT 1964 I 560; BGE 114 II 132 yahut JdT 1988 I 512-513.

245 **Cavin**, sh. 111; **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 57; **Keller/Siehr**, sh. 107; **Bucher**, BT, sh.107; **Guhl/Koller**, sh. 393; OR-**Honsell**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 7; **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 251; **Katz**, sh. 152 vd.; **Neuenschwander**, sh. 92 vd.

5. Ayıptan doğan sorumluluğun gereği gibi ifa etmeme (kötü ifa) ile ilişkisi

Kötü ifa TBK m. 112'de düzenlenen gereği gibi ifa etmeme kategorisi içinde yer alır. Aynı şekilde, satış sözleşmesinde ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümler kötü ifanın şartlarını ve sonuçlarını özel olarak düzenlemektedir. Bu itibarla, ayıplı ifa halinde, alıcının, ayıptan sorumluluk hükümleri yanında seçimlik olarak, genel hükümlerde yer alan kötü ifadan sorumluluğa (TBK m. 112 vd.) dayanıp dayanamayacağı hususu önem taşımaktadır.

Hâkim fikre göre[246] alıcı, seçimlik olarak her iki hükme (TBK m. 112 vd. ve m. 228 vd.) dayanabilir. Ancak böyle bir yarışma için alıcının gözden geçirme bildirim külfetlerini (TBK m. 223) yerine getirmesi ve TBK m. 231'de öngörülen zamanaşımı süresi içinde dava açması gerekir.

Buna karşılık, üstün tutulması gereken diğer bir fikre göre[247] alıcı, ayıplı ifa halinde, ayıp bildiriminde bulunmadan (TBK m. 223) ve

---

246 **Becker**, Art. 207, N.27; Art. 210, N.6; **Katz**, sh. 149; **Furrer**, sh. 35; **Schubiger**, sh. 108 vd.; **Neuenschwander**, sh. 40, 86; **Jaeger**, sh. 74, 130 vd.; **von Tuhr/ Escher**, sh. 97 vd.; **Bucher**, BT, sh. 107; K. **Bähler**, sh. 157 vd; **Ginter**, sh. 95 vd. BGE 108 II 104; 107 II 161; 107 II 408; 96 II 117; 70 II 88; 67 II 135; 63 II 406; 58 II 211. Tamamen yarışmanın aleyhinde: **Cavin**, Sem Jud 1969, sh. 337; **Guhl/Koller**, sh. 392 vd; **Tercier**, N. 620 vd.; **Hansell**, BT, sh. 110.

247 **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 20 vd. ve özellikle, N. 26; **Keller/Siehr**, sh. 106 ve 107; **Widmer**, ZBJV 118/1982, sh. 160; **Baudenbacher/Spiegel**, sh. 242 vd., sh. 259 vd.; **Oser/Schönenberger**, Art. 197, N. 6; Thomas **Schluep**, sh. 78; **Simmen**, sh. 86 vd; 13. HD, 16.3.1984, E.8918/K.2052: "Dava, satın alınan otomobilin ayıplı olması nedeniyle uğranılan zararın tazmini isteğine ilişkindir. Mahkemece dava aynen kabul edilmiş, davalının temyizi üzerine karar Dairemizce satışı yapılan otomobilin ayıplı olması nedeniyle BK.nun 202. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacak inceleme ile satış bedelinden indirim yapmak veya aktin feshine karar verilmek gerektiği nedeniyle bozulmuştur.

Satış bedelinin indirilmesi davacının satılan şeyin ayıplı olmasından ileri gelen zararı karşılamamaktadır. Bu nedenle davacı, BK m. 202'de düzenlenen tekeffül hükümlerine dayanan bir bedel indirilmesi davası açabileceği gibi, şartları varsa eksik ifa nedeniyle BK.nun 96 maddesi uyarınca uğradığı zararın tazminine ilişkin bir dava da açabilir. BK m. 96 gereğince, alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde, borçlu kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini isbat etmedikçe bundan ileri gelen zararı tazmine mecburdur. İnceleme konusu olayda davalı kusurludur. Bu yön ceza mahkemesinin mahkumiyet kararıyla sabittir. Dava konusu edilen zarar kalemlerinin otomobilin şasi ve motor kabininin yabancı kaynaklı olmasından ve böylece ayıp durumundan kaynaklandığında tereddüt yoktur.

Şu halde davacı söz konusu zararlarının tazminini BK nun 96 maddesine dayanarak istemeye yetkilidir. Bu nedenle karar düzeltme isteği kabul edilmiştir". (YKD 1984, sh. 1046-1407).

TBK m. 231'de öngörülen kısa zamanaşımı süresi geçtikten sonra dahi TBK m. 112 hükmüne (kötü ifaya) dayanarak dava açabilir. Zira ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinde yer alan sıkı şeklî şartlar (TBK m. 223 ve m. 231), bu hükümlerde alıcı lehine tanınan maddeten çok elverişli özel düzenlemelerin karşılığında öngörülmüştür. Meselâ, doğrudan doğruya zararlardan satıcının kusursuz sorumlu olması, dönme, onarım veya bedelin indirilmesini isteyebilme imkânları. Oysa TBK m. 112 vd. nda öngörülen hükümlere dayanan alıcı için, bu tür avantajlar söz konusu değildir.

§ 10. ALICININ BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ

I. Bedeli ödeme borcu

1. Genel olarak

Satış akdinde bedeli ödeme borcu (TBK m. 207/I ve m. 232/I), alıcının aslî edim yükümünü teşkil eder. Bu yüküm, satışı trampa ve bağışlamadan ayırt eder.

Taraflar bedeli Türk parası veya yabancı para üzerinden kararlaştırabilirler; ülkemizde halen yürürlükte olan döviz mevzuatı karşısında bedelin dövizle aynen ödenmesini (TBK m. 99/II) kararlaştırmak mümkündür[1]. Buna göre satış bedelinin ödenmesi:

-Ülke parasıyla nakit olarak ödenebilir. Kağıt veya madeni paraların zilyetliği ile birlikte mülkiyeti diğer tarafa devredilir. Bu tür bir ifa için karşı tarafın ödeme şekline ilişkin bir kabul beyanı gerekmez.

Buna karşılık bedel ödenecek tarafın kabülünü gerektiren ödeme türleri bulunmaktadır.

-Çekle, kredi kartı ile, senetle ödeme ifa uğruna edim sayılır. İfa uğruna edime kaza isabet ederse risk bu tür ifayı yerine getiren taraftadır.

-Yabancı para, altın veya bir başka malla ödeme ifa yerine edim sayılır. Kaza halinde risk edimi alandadır.

-Kaydi para ile ödeme, havale veya virman talimatı ile veya alacaklının hesabına para yatırmak suretiyle yapılmaktadır. Niteliği tartışmalı olmakla birlikte akit ödeme olarak kabul edilebilir. Ancak, takas beyanı veya elkoyma hakkı riski nedeniyle ifa yerine edim veya ifa uğruna edim sayılabilir. Kanaatimizce kaydi para ile ödeme ifa yerine edim sayılmalıdır.

-Borçlunun kendi bankasına alacaklının isteği halinde istediği kadar miktarın ödenmesine ilişkin bir talimat vermesi, tahsil yetkisi vermesidir. Burada ödemelerin fatura miktarına itiraz bozucu şartı ile ya-

---

[1] **Eren,** C. I, sh. 156; **Tandoğan** I/1, sh. 85; **Yavuz**, sh. 45.

pıldığı kabul edilir. Otomatik ödeme talimatında bu tür bir ödeme olduğu kabul edilmektedir[2].

2. Bedelin miktarı

Taraflar, satış bedelini, gabin hakkındaki hükümler (TBK m. 28) çerçevesinde ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak şartıyla, serbestçe tayin edebilirler[3].

Daha önce de ifade edildiği gibi[4], satış sözleşmesinde bedelin belirli bir rakamla tesbiti şart olmayıp, onun belirlenebilir olması yeterlidir. TBK m. 233 bu hususta iki yorum kuralı ihtiva etmektedir.

a) Bedelin tayin edilmemiş olması

TBK m. 233/I'e göre, "Alıcı, satış bedelini belirtmeksizin, malı alacağını kesin olarak bildirmişse satış, ifa yeri ve zamanındaki ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılır".

TBK m. 233/I'deki kural, ancak ortalama fiyatı bulunan malların satışında uygulanır[5]; tarafların bedel üzerindeki anlaşmayı saklı tutmaları veya bedeli belirlemede anlaşamamaları halinde, sözleşme geçerli olarak kurulmamış olacağından, bu fıkra hükmü uygulanmaz[6].

b) Satılanın ağırlığına göre bedelin hesabı

TBK m. 233/II gereğince, satış bedeli, satılanın ağırlığına göre hesap ediliyorsa, darası (ambalajın ağırlığı) indirilir; ağırlıktan düşülür. Bununla beraber, bedelin safi olmayan ağırlıktan yahut bu ağırlıktan belirli bir miktar veya yüzde indirilmek suretiyle hesaplanacağına ilişkin ticarî teamüller saklıdır (TBK m. 233/III).

3. İfa yeri

Aksine bir anlaşma yoksa bedelin ifa yeri, ifa anındaki satıcının yerleşim yeridir (TBK m. 89/b. 1).

4. İfa zamanı

TBK m. 234/I'e göre, "Aksine sözleşme yoksa, satılan alıcının zilyetliğine girince satış bedeli muaccel olur". Bu hüküm satıcıyı önce-

---

2 Serozan, 102.

3 **Tercier**, N. 416; **Keller/Siehr**, sh. 10; **Tandoğan**, I/1, sh. 86 vd.

4 Bk. yukarda, sh. 60.

5 **Giger**, Art. 212, N. 5 vd; **Tandoğan** I/1, sh. 91.

6 OR-**Koller**, Art. 212, N.2.

den ifa ile yükümlü kılmamaktadır; bedelin muaccel olması için, satıcının ifayı teklif etmesi yeterlidir[7]. İyi olmayan ifade şekline rağmen, TBK m. 234/I, TBK m. 97 ve m. 207/II'deki aynı anda (Zug um Zug) ifa kuralını esas almış bulunmaktadır[8].

5. Bedele faiz ödenmesi

Para borçlarında borçlunun faiz ödeme yükümü, normal olarak, temerrüt anından itibaren doğar (TBK m. 120). TBK m. 234/II iki halde, satılanın teslim edilmesiyle ihtara gerek olmadan bedele faiz ödeneceğini öngörmek suretiyle bu kuraldan ayrılmıştır. Bu hallerden birincisi, faiz ödenmesi konusunda bir teamülün bulunması; diğeri ise, alıcının satılandan semere veya başka ürün elde etme imkânına sahip bulunmasıdır. Buna göre, faiz alıcının fiilen semere ve hasılat elde ettiği andan değil, elde etme imkânının doğduğu andan itibaren işlemeye başlar. Ayrıca, belirli bir günün geçmesiyle temerrüdün gerçekleştiği hallerde ayrıca ihtara gerek kalmaksızın satış bedeline faiz istenebilmektedir (TBK m. 234/II).

6. Alıcının bedeli ödemede temerrüdü

a) Genel olarak

Satış sözleşmesinde alıcının bedeli ödeme borcunda temerrüdünün şartları özel olarak düzenlenmiş olmayıp, bu konuda genel hükümler (TBK m. 117) uygulanır.

Buna karşılık, temerrüdün sonuçlarından olan seçim hakkının şartları ve muhtevası (TBK m. 235) ile satıcının zararının hesaplanması (TBK m. 236) bakımlarından özel hükümler sevk edilmiş bulunmaktadır.

b) Temerrüdün sonuçları

TBK m. 235, alıcının temerrüdünün sonuçlarını peşin ve ön ödemeli satışlar ile veresiye satışlarda farklı şekilde düzenlemiştir[9].

---

[7] **von Tuhr/Escher**, sh. 49, dn. 47; **Giger**, Art. 213, N.4; OR-**Koller**, Art. 213, N. 1.

[8] **Tercier**, N. 424; **Keller/Siehr**, sh. 21; OR-**Koller**, Art. 213, N. 1.

[9] CISG m. 61 alıcının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda satıcının sahip olduğu hukuki imkânları düzenlemektedir. Buna göre, alıcı bedeli ödeme borcunu yerine getirmez, malları teslim almaz veya verilen süre için bunları yapmayacağını

aa) Peşin ve ön ödemeli satışlarda

TBK m. 235/I-II hükümleri tarafların edimlerini aynı anda ifa etmekle yükümlü oldukları peşin satışlar ile ön ödemeli satışlarda uygulanır. Bundan başka, TBK m. 212/II-III'den farklı olarak, TBK m. 235/I ve II'nin uygulanması açısından, âdi satış-ticarî satış ve teslim için belirli vadeli olan veya olmayan satış ayrımı yapılmamış bulunmaktadır.

TBK m. 235'in kenar başlığında ve I. fıkrasında sadece dönmeden (fesihten) bahsedilmesi, bu tür satışlarda satıcının, TBK m. 125/II'de öngörülen diğer hukukî imkânlardan, sözleşmeyi ayakta tutarak aynen ifa yerine olumlu zararının tazminini isteme yetkisinden yoksun olduğu anlamına gelmez. TBK m. 235/I'in amacı satıcıyı TBK m. 125'e oranla daha iyi duruma getirmek olup, onun seçim hakkının kapsamını daraltmak değildir[10].

TBK m. 235/I, alıcının temerrüdü halinde, satıcının seçimlik imkânlardan sözleşmeden dönme hakkını, "herhangi bir işlem gerekmeksizin" kullanabileceğini öngörmektedir. Bunun anlamı, satıcının, sözleşmeden dönebilmek için alıcıya süre vermek zorunda olmamasıdır. Bu bakımdan TBK m. 235/I, TBK m. 123'deki düzenlemeden ayrılmıştır. Bu haliyle, kanun koyucu peşin satışlarda sözleşmeden dönmeyi kolaylaştırmıştır.

TBK m. 235/I anlamında dönme hakkını kullanmak isteyen satıcı, bunu derhal alıcıya bildirmek zorundadır (TBK m. 235/II, TBK m. 125/II). Bununla beraber, dönme beyanını TBK m. 235/II'de öngörülen şekilde derhal yerine getirmeyen satıcı, sadece mehil vermeden dönme hakkını (TBK m. 235/I) kaybeder; bu hakkını kaybeden satıcı, TBK m. 123'e dayanarak, alıcıya uygun bir mehil verdikten sonra, TBK m. 125/II'deki imkânların tamamını kullanabilir[11].

bb) Veresiye satışlarda

TBK m. 235/III, satılanın bedelinin ödenmesinden önce alıcıya teslim edildiği veresiye (kredili) satışlarda, satıcının, ancak açıkça saklı tutulan hallerde sözleşmeden dönebileceğini öngörmektedir. Satıcıya

---

beyan ederse makul bir süre verildikten sonra yoksun kalınan karı kapsayan tam tazminat talep edilebilir.

[10] **Giger**, Art. 214, N. 42; **Cavin**, sh. 55-56; **Keller/Siehr**, sh. 41; OR-**Koller**, Art. 214, N. 2.

[11] **Becker**, Art. 214, N. 5; **Cavin**, sh. 55-56; **Keller/Siehr**, sh. 42; **Giger**, Art. 214, N. 42 ve 58; OR-**Koller**, Art. 214, N. 12; **Bucher**, BT, sh. 65.

sözleşmeden dönme hakkı verilmesi, sözleşmeye konulan açık bir kayıtla gerçekleşir. Bununla beraber, sözleşmede mülkiyeti saklı tutma kaydının yer alması, sicile kaydedilmemiş olsa bile, satıcının dönme hakkının TBK m. 235/III anlamında saklı tutulduğunu gösterir[12].

TBK m. 235/III, saklı tutulan dönme hakkının kullanılma şartlarını açıklayan bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu konuda TBK m. 125/II uygulanır; satıcı, dönme hakkını kullanmak isteyen alıcıya uygun bir süre vermek ve bu süre sonunda alıcı ödemede bulunmamışsa derhal dönme beyanında bulunmak zorundadır[13].

Satıcı, alıcının iflâsı halinde, saklı tuttuğu sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz (İİK m. 199). Bunun için satılanın iflasın açılmasından önce teslim edilmiş olması gerekir. Satıcının böyle bir sonuca karşı korunması, ancak mülkiyeti saklı tutma kaydının kararlaştırılması ve sicile kaydı ile mümkün olur[14].

Sözleşmeden dönme hakkının açıkça saklı tutulmadığı hallerde, satıcı dönme hakkına sahip değildir; o, sadece TBK m. 125/II'de öngörülen diğer hukukî imkânlardan ifa ile birlikte gecikme tazminatı isteme veya aynen ifadan vazgeçip olumlu zararın tazminini talep haklarını kullanabilir. Böyle bir durumda satıcı, TBK m. 125/II vd.na dayanarak sözleşmeden dönme imkânına sahip değildir[15].

Tarafların peşin veya ön ödemeli satışı kararlaştırmaları halinde satıcı bedelin ödenmesinden önce satılanı devir etmişse, TBK m. 235/I'in mi, yoksa TBK m. 235/III hükmünün mü uygulanacağı tartışmalıdır. TBK m. 235/III'ün lafzından hareket eden hâkim fikre göre[16], bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi için satılanın bedel öden-

---

12 **Tercier**, N. 455; **Engel**, sh. 52; OR-**Koller**, Art. 214, N. 22; **Keller/Siehr**, sh. 44; **Honsell**, sh. 52; **Bucher**, BT, sh. 66; **Cavin**, sh. 57; BGE 90 II 285 yahut JdT 1965 I 130. Karş. **Giger**, Art. 214, N. 45 vd.

13 **Giger**, Art. 214, N. 40; **Cavin**, sh. 57; **Keller/Siehr**, sh. 43 ve 44; OR-**Koller**, Art. 241, N. 4; **Tandoğan** I/1, sh. 216-217; BGE 90 II 293.

14 **Giger**, Art. 214, N. 47; **Keller/Siehr**, sh. 44; **Cavin**, sh. 55-56 **Tandoğan**, I/1, sh. 216.

15 **Keller/Siehr**, sh. 43; **Giger**, Art. 214, N. 15 ve 49; **Honsell**, sh. 52; **Tandoğan** I/1, 215. Yarg. 13. HD 12.4.1990, E. 2604/K. 2898 (**Karahasan**, C. 5, sh. 252); Yarg. 1. HD 30.6.1986, E. 5656/K. 7761 (YKD 1982, sh. 192); 13. HD, 25.4.1985, E. 2265/K. 2791 (Yasa 1985, S. 10, sh. 1431 vd).

16 **Cavin**, sh. 56; **Giger**, Art. 214, N. 21; **Becker**, Art. 214, N. 7; **Lemp**, sh. 75-76; **Bucher**, sh. 66; BGE 110 II 45.

meden alıcıya teslim edilmiş olması yeterlidir; üçüncü fıkra, sözleşmeyle bedeli ödeme borcunun önce yerine getirilmesinin kararlaştırılmış olup olmadığına bakmaksızın, sadece devrin önceden yapılması olayını (fiilî veresiye satışı) esas almaktadır. Zira bu durumda satıcı, satılanı alıcıya devir etmekle dönme hakkından feragat etmiş olur ve TBK m. 235/III'e tâbi olur. Buna karşılık bizim de katıldığımız diğer fikre göre[17], TBK m. 235/III'ün uygulanabilmesi için alıcının bedeli malın devrinden sonra ödeme hakkına sahip olması gerekir. Aksi takdirde, alıcı, üçüncü fıkranın kendisine sağlayacağı elverişli hukukî durumu elde edebilmek için sözleşmeye aykırı olarak bedeli teslimden sonra ödemek isteyecek ve böylece sözleşmenin ihlâli ödüllendirilmiş olacaktır. Aynı şekilde, mecbur olmadığı halde bedel ödenmeden satılanı teslim eden satıcı cezalandırılmış olacak ve TBK m. 235/I ve m. 124 gereğince sahip olduğu dönme hakkından yoksun bırakılacaktır. Şüphesiz tarafların sonradan anlaşarak satış sözleşmesini veresiye satışa dönüştürmeleri halinde TBK m. 235/III uygulanır. Buna göre, TBK m. 235/III'ün sadece veresiye satışlarda uygulanacağını kabul etmek gerekir.

cc) Ticari İşletmeler arasında mal ve hizmet sağlaması amacıyla yapılan sözleşmelerde temerrüt ve sonuçları (TTK m. 1530)

aaa) Temerrüt anı

TTK m. 1530/2'ye göre ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmelerde diğer şartlar varsa bu düzenleme uygulanacaktır. Mal ve hizmet sağlanması deyimi ile taraflar arasında kurulan satış, eser ve hizmet gibi sözleşmeler kastedilmektedir. Mal ve hizmet yükümlüsünün edimini yerine getirmesine rağmen para borçlusunun bu işlemden doğan borcunu yerine getirmemesi söz konusu hükmün uygulanmasına yol açmaktadır. Para borçlusunun gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hallerde ihtara gerek kalmaksızın temerrüt söz konusu olmayacaktır.

Bu kapsamda kalan sözleşmelerde para borcunun ifası için bir tarih öngörülmüşse veya ödeme süresi belirlenmişse edimini yerine getirmeyen borçlu ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer (f. 2). Bu durumda temerrüt tarihinden itibaren kanun hükmü icabı temerrüt faizi

---

[17] **Oser/Schönenberger,** Art. 214, N. 12; **Keller/Siehr**, sh. 42-43; **Honsell**, sh. 53; OR-**Koller**, Art. 214, N. 6.

işlemeye başlar (f. 3). Şu kadar ki, belirli bir vade öngörülmüşse vade tarihinden; süre belirlenmişse, sürenin sonunu takip eden günden itibaren faiz işlemeye başlar. Kanun koyucu 1530/2. madde ile bu şartları taşıyan borç ilişkilerinde yeni bir muayyen vade türü oluşturmuştur. Zira Borçlar Kanunun genel hükümlerine göre para borçlusunun borcunu belirlenen ödeme günü veya sürede yerine getirmemiş olması halinde yapılacak ihtar ile temerrüt söz konusu olur (TBK m. 117/I, II).

Sözleşme ile ödeme günü veya süresi belirlenmemişse ve borçlu genel hükümlere göre ihtar çekilmek suretiyle temerrüde düşürülmemişse borçlu, Kanunda düzenlenen şu halleri takip eden otuz günlük sürenin sonunda ihtara hacet olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır (f. 4):

- Faturanın (veya buna eş değer ödeme belgesinin) borçlu tarafından alındığı gün;
- Faturanın borçlu tarafından alındığı tarih belirli değil ise mal veya hizmetin teslim alındığı gün;
- Borçlunun faturayı mal veya hizmetin tesliminden önce alması halinde mal veya hizmetin teslim edildiği gün belirleyici olmaktadır.
- Kanunda veya sözleşmede mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hallerde borçlu faturayı bu işlemlerin yapılması esnasında veya önceden almışsa kabul veya gözden geçirme günü esas alınır. Belirlenen bu günü takip eden otuz günlük sürenin sonunda borçlu mütemerrit olur ve faiz kendiliğinden işlemeye başlar.

Sözleşme ile öngörülen kabul ve gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü geçiyorsa ve bu durum alacaklının aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa mal ve hizmetin kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz gün olarak kabul edilir.

Sözleşme ile bir ödeme süresi öngörülmüşse, bu süre faturanın veya mal ve hizmetin alındığı tarihten itibaren en fazla almış gün olabilir. Ödeme süresinin sözleşme ile belirlendiği hallerde mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul usulünün tamamlandığı tarihten itibaren de aynı süre uygulanır. Ancak taraflar bunun aksini belirli şartlarla kararlaştırabilirler (TK m. 1530/5). Bunun için alacaklı aleyhine ağır bir haksız durumun yaratılmaması ve ödeme süresinin altmış günden fazla olduğunun açıkça kabul edilmesi zorunludur. Bununla birlikte alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme olması veya tarımsal ya

da hayvansal üretici olması hallerinde süre altmış günü aşamaz. Borçlunun büyük ölçekli işletme olması halinde de ödeme süresi kanunla belirtilmiş bulunan bu azami süreyi aşan temerrüt şartı kararlaştırılamaz.

bbb) Temerrüt faizi

Ticari işlerde özel bir temerrüt faizi oranının belirlenmesi, Avrupa Birliği Hukukunda Ticari İşlemlerde Geç Ödemelerle Mücadeleye ilişkin 29 Haziran 2000 Tarih ve 2000/35/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi[18]nce öngörülmüştür[19]. Bu Direktif, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 95. maddesine dayanarak çıkartılmıştır.

2003 yılında kabul edilen revize edilmiş Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda bu konu yer almıştır[20]. Programın "IV. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği" başlığı altında "I- Öncelikler Listesi"nde, "Öncelik 1-8" başlığı altında "Ticari işlemlerde geç ödemelerle mücadeleye ilişkin 29 Haziran 2000 tarih ve 2000/35/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu bakımından Adalet Bakanlığı ile ilişkili olarak 2004 yılı II. Çeyrek ve 2004 yılı IV. Çeyrek'te Türk Hukukuna aktarılması öngörülmüştür. Nihayet TTK m. 1530 ile bu kurallar ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmeler bakımından hukukumuzda kabul edilmiştir.

Söz konusu işlemlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı Direktifin 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ödeme temerrüdü halinde faiz başlığını taşımaktadır. Aynı maddenin d) fıkrasına göre borçlunun ödemekle yükümlü olduğu temerrüt faizinin oranı (kanuni faiz oranı), sözleşme ile başka türlü kararlaştırılmamışsa, Avrupa Merkez Banka-

---

[18] Die Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr-Directive 2000/35: EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions (OJ L 200 08.08.2000 P. 0035 – 0038).

[19] Ayrıntılı bilgi için bkz. **Ayrancı**, Hasan, Temerrüt faizi oranının belirlenmesi bakımından Avrupa Birliği hukuku, Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ile Türk hukukunun incelenmesi, Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan, Ankara 2008, sh. 201-221; **Ayrancı**, Hasan, Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK m. 105), sh. 76-80.

[20] RG.24.07.25178 (Mükerrer). Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı 2003/5930.

sının her yarı yılın ilk takvim gününden önce en yeni asıl kredi operasyonlarına uyguladığı faiz oranı temel faiz oranı olarak kabul edilmiş, bu orana, en azından %7 ek yapılması ile ortaya çıkan miktar temerrüt faizi oranı olarak belirlenmiştir. Üye devletler için uygulanan faiz oranı kendi merkez bankalarının faiz oranı esas alınarak bulunmaktadır. Bu faiz oranı her yarıyılda takip eden altı ay için belirlenmektedir.

3095 sayılı kanunun 2/1. maddesine göre, aksi kararlaştırılmamışsa, temerrüt faizi oranı yalın işlerde yıllık yüzde dokuzdur. Bakanlar Kurulu bu oranı aylık olarak belirlemeye ya da yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır (m. 2/II). Temerrüt esnasında yürürlükte olan düzenlemelere ve faiz oranlarına göre temerrüt faizi istenebilmektedir.

Taraflar yıllık yüzde dokuz olarak belirlenen oranının üstünde bir temerrüt faizi kararlaştırabilirler. Sözleşme ile faiz oranı kararlaştırılmışsa temerrüt faizi sözleşmede kararlaştırılan faizden az olamaz (m.2/III; TBK m. 120/III). TBK m. 120/II'ye göre sözleşme ile kararlaştırılan yıllık temerrüt fazi oranı faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine (3095 sayılı Kanun) göre belirlenen faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.

Taraflar temerrüt faizini kendi aralarında serbestçe kararlaştırabilirler. Böyle bir anlaşma yoksa temerrüt faizi, ticari işlerde de ilke olarak yüzde dokuzdur (BK m.103, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun m.2/II ve m.5/II). 3095 sayılı Kanunun 1/II. maddesine göre Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yüzde dokuz olarak gösterilen oranı aylık olarak belirlemeye veya yüzde onuna kadar indirmeye ve bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Ancak, Kanunun 2/II. maddesine göre, sözleşmeden doğmamış olsa bile ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, Kanunun 1. maddesine göre belirlenen orandan fazla ise temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Kısa vadeli avanslara uygulanan faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran temerrüt faizi oranı olarak uygulanır.

Böylece, Merkez bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı temerrüt faizi olarak kabul edilmiştir. Bu tür bir düzenleme-

nin yapılmış olması kredi alınması halinde ödenecek faizin bu faiz oranına yakın olması nedeniyle isabetli görünmektedir.

Kısa vadeli avanslara endeksli bu oran AB direktifinin temel faiz oranı deyimini karşılamaktadır. Belirli ticari işlemler için temel faiz oranına belirli bir oranın ilavesiyle temerrüt faiz oranı belirlenmektedir.

Bu faiz oranının esas alınması için alacaklının bu yönde bir talebi bulunmalıdır. Zira, söz konusu düzenleme kısa vadeli avans için uygulanacak faiz oranının esas alınması için talep koşulunu koymuştur. Uygulamada talebin açık bir biçimde belirtilmesi zorunlu görülmekte ticari temerrüt faizi gibi genel ifadelerin kullanılması halinde 3095/2/II. maddesinde sözü geçen faiz oranından yararlanılamayacağı hükme bağlanmaktadır.

3095 sayılı Kanunun 2/II. maddesinin uygulanması bakımından ticari işin sözleşmeden kaynaklanması yanında haksız fiil nedeniyle ödenecek temerrüt faizine, haksız fiilin ticari iş niteliğinde olması halinde kısa vadeli avans kredisine uygulanan faiz uygulanacaktır. Buna karşılık taraflardan biri tacir değilse bu faiz oranının uygulanması mümkün olmayacaktır. Zira, bu tür durumlarda tacirlerin kredi kullanma zorunluluğuna bağlı olarak yüksek kredi faizi ödeme durumu söz konusu olmamaktadır. Bu tür durumlarda tacir olmayan haksız fiil mağduru munzam zarar yoluyla zararını tazmin ettirme imkânına sahiptir[21].

Türk Ticaret Kanunu ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmelerde gecikme faizinin ödenmemesi veya haksız sayılacak ölçüde az faiz oranı belirlenmesinin geçersiz olduğunu hükme bağlamaktadır. Aynı şekilde geç ödeme nedeniyle kanunen ödenmesi gerekli gecikme tazminatından sorumlu olunmayacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz sayılmıştır. Bu tür durumlarda faiz miktarı ve alacağı tahsil masraflarından oluşan asgari tazminat miktarı T.C. Merkez Bankası tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilecektir (TTK m.1530/6. 7).

TTK m. 1530/7 ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin işlemlerde para borcuna uygulanacak temerrüt faizi oranını özel olarak belirlenmiştir. Kanununa göre bu işlemler bakımından faiz oranı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna gö-

---

[21] **Arkan** (2001), sh. 73-74.

re ticari işlere uygulanan gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmaktadır[22].

Bu durumda, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlere uygulanacak gecikme faizi belirlenecek, bu orana yüzde sekiz oranı ilave edilmek suretiyle temerrüt faizi ortaya çıkarılacaktır. Ticari işlerde gecikme faizi, yukarıda açıklandığı üzere, taraflarca kararlaştırılmamışsa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısa vadeli avaslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden belirlenmektedir.

Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet bedelinin taksitle ödemeli işlemlere konu edilmesi halinde ödeme sürelerine ilişkin düzenlemeler sadece birinci taksit bakımından uygulama alanı bulur. Buna karşılık her taksit bakımından ticari temerrüt faizi uygulanır. Nihayet alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme ya da tarımsal yahut hayvansal üretici olması ve borçlunun büyük ölçekli işletme olması halinde taksitle ödemeye ilişkin sözleşmeler hükümsüz sayılmıştır (TTK m. 1530/8).

dd) Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasında (CISG= Viyana Satış Sözleşmesi) temerrüt

Birleşmiş Milletler Satım Sözleşmelerine ilişkin Antlaşmanın 78. maddesi temerrüt halinde faiz ödeme yükümlülüğünü sadece sebebine göre düzenlemektedir[23]. Zira konvansiyonun tarafları temerrüt faizi oranı üzerinde anlaşamamışlardır[24]. Söz konusu düzenlemeye göre 78.

---

22 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını yıllık %12,75 olarak; alacak tahsil masrafı için oluşan asgari tazminat miktarını 123,00 TL olarak belirlemiş durumdadır (RG 25.1.2014 tarih s. 28893). Kısa vadeli avans faiz oranının %11,75 olduğu dikkate alındığında en az %8 fazla faiz oranı kuralının temel faiz oranı üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır Oysa, ticari işlerde geç ödemeye ilişkin Avrupa Birliği Direktifinin ve TTK m. 1530'un amacı temel faiz oranına (kısa vadeli avans oranına) %8 oranının doğrudan doğruya ilave edilmesi şeklindedir.

23 Bkz. **Ayrancı**, Hasan, Temerrüt faizi oranının belirlenmesi bakımından Avrupa Birliği hukuku, Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ile Türk hukukunun incelenmesi, Prof. Dr. Bilge Öztan'a Armağan, Ankara 2008, sh. 201-221.

24 Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2a, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 241-432, 4.Auflage, München 2003, **Ernst**, § 288, Rn.9; **Faust**, Florian, Zinsen bei Zahlungsverzug, RabelsZ, Bd.68 (2004), sh. 518 vd.

maddenin uygulama alanında faiz oranı her bir ulusal devletin hukukuna göre belirlenecektir. Bu nedenle sözleşmeye uygulanacak hukuka göre faiz belirlenebilecektir.

CISG Art.78 faiz ödeme yükümlülüğünü sınırlayıcı şekilde düzenlememiştir. Aksine, alıcı veya satıcı, geç ifa nedeniyle ödenen kredi faizleri veya kaçırılan yatırım faizlerini tazminat talebi olarak ileri sürebilirler (CISG Art.45/I/b ve Art.61/I/b)[25].

Bu düzenlemeye göre ihtara veya kusura ihtiyaç göstermeksizin tazminat talep edilebilir. Ödemenin belirli bir zamanda yapılacak olması yeterlidir. Satım sözleşmesinde satım bedelinin ne zaman ödeneceği belirtilmemişse Art.58'e göre satım konusunun veya bunu temsil eden evrakın karşı tarafa verilmesi ile satım bedeli muaccel olur. Bu durumda borçlu derhal satım bedelini ödemelidir. Aksi takdirde tazminat borçlusu olur[26].

CISG Art.74 borçluyu, sözleşme ihlalinin öngörülebilir sonuçlarından sorumlu tutmaktadır. Temerrüt faizinin öngörülebilir bir sonuç olduğu açıktır. Zira, satıcının banka kredisi ile çalıştığı ve piyasada mutad olan faizle kredi temin ettiği ya da parayı zamanında elde etmiş olsaydı mutad bir faiz oranı üzerinden yatırıma dönüştüreceğini öngörmesi gerekmektedir. Bu konuda tek zorluk, satıcının (para alacaklısı) ülkesinde sözleşmenin kurulması ile ödeme zamanı arasında faiz oranlarının değişmesidir. Bu tür bir değişikliğin önceden tahmin edilmesi mümkün olmamaktadır.

CISG Art.78, borçlunun satım bedeli ile diğer ödemeleri zamanında yapmaması halinde Art.74'te düzenlenen tazminat hakkı saklı kalmak üzere alacaklıya faiz talep etme hakkı tanımaktadır. Böylece alacaklının zararı olup olmadığına bakılmaksızın ve bu tür bir zararın tahmin edilebilir olup olmadığına bakılmaksızın faiz talep etme hakkı mümkün hale gelmiştir.

Alacak miktarının belirli olmaması ve bu miktarı alacaklının belirtmek zorunda olduğu hallerde borcun örtülü şekilde ertelendiği kabul edilmektedir. Alacaklı alacağından fazla bir miktarı belirleyerek talep etmişse yüksek olan kısım için faiz uygulanmaz. Çünkü, ihtar temerrüdün bir koşulu değildir.

---

[25] **Faust**, sh. 511, 512-527.

[26] Ayrıntılı bilgi için bkz **Faust**, sh. 512-513.

Borçlunun ödemezlik def'i (TBK m. 97) ileri sürme veya ifadan kaçınma hakkı (TBK m. 98 gibi) varsa bu durumda faiz işlemez.

c) Satıcının zararının hesabı

aa) Genel olarak

TBK m. 236, ticarî satışlarda alıcının bedeli ödeme borcunda temerrüdü üzerine, aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının tazminini isteyen satıcının bu zararının, fark teorisi çerçevesinde soyut ve somut metodlara göre hesaplanmasını öngörmektedir. Satıcının sözleşmeden dönmesi halinde bu hüküm uygulanmaz. Sözleşmeden dönme halinde sadece TBK m. 125/III gereğince olumsuz zararın tazmini istenebilir[27]. Satıcının aynen ifadan (bedelin ödenmesinden) vazgeçmesinin TBK m. 125'e veya TBK m. 236'a dayanması bu hususta önemli değildir; satıcının TBK m. 235'e başvurmadan TBK m. 125/II'e göre hareket etmesi halinde de TBK m. 236 uygulanır[28].

bb) Zararın somut olarak hesabı

Satıcı, bedeli ödemede temerrüde düşen alıcıdan, kararlaştırılan bedel ile satılanı iyiniyetle başkasına sattığı bedel arasındaki farkın kendisine ödenmesini isteyebilir (TBK m. 236/II). Buna göre, somut metoda göre zararın hesaplanmasında hareket noktası, satılanın tekrar satışı, yani ikame satışdır.

İkame satışda satıcının iyiniyetle hareket etmesi, hale göre kendisinden beklenen özenle hareket etmesi ve satış konusu malı mümkün olduğu kadar iyi bir fiyatla satmaya çalışması gerekir.

Satıcı, elverişli fiyatla malı satmak için uzun süre devam eden bir araştırma yapmak zorunda değildir; o, sadece kendisinden beklenen iş tecrübesine uygun hareket etmek zorundadır. Satıcı, en iyi satış imkânını bilmiyorsa, ikame satışı malın bulunduğu yerde, kendi ikametgâhında veya iş merkezinde yahut bunlara en yakın satış yerinde yapabilir[29].

Satıcı ikame satış için hâkimden izin almak zorunda değildir[30].

---

27 **Keller/Siehr**, sh. 44; OR-**Koller**, Art. 215, N. 1.

28 **Giger**, Art. 215, N. 6; OR-**Koller**, Art. 215, N. 1.

29 **Giger**, Art. 215, N. 46; OR-**Koller**, Art. 215, N. 10.

30 **Giger**, Art. 215, N. 45; **Tandoğan** I/1, sh. 218.

cc) Zararın soyut olarak hesabı

Zararın soyut metoda göre hesabı için, satılanın borsaya kayıtlı olması veya piyasa fiyatının bulunması gerekir. Bu takdirde zarar, satılanın vade günündeki fiyatı ile satılanın bedeli arasındaki farktır (TBK m. 236/III). İkame satışı daha iyi şartlarla yapmak mümkün olsa bile, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı olan mallar için soyut metoda başvurulabilir[31]. Satıcı, satılanın başkasına satabildiği kısmı için somut, satamadığı kısmı için soyut yönteme gidebilir[32].

II. Satılanı devralma borcu

1. Kavram ve hukukî niteliği

TBK m. 232/I'e göre, alıcı, kendisine kararlaştırılan şartlar dahilinde arzedilen satılanı devralmakla yükümlüdür; aksine âdet ve sözleşme mevcut değil ise, devralmanın derhal gerçekleşmesi gerekir (TBK m. 232/II).

TBK m. 232'de zikredilen devralmanın hukukî niteliği tartışmalıdır. Bir fikre göre[33], burada bir külfet söz konusu olup, bunun yerine getirilmemesi alıcının temerrüdü (TBK m. 106/I) sonucunu doğurur. Bununla beraber, taraflar satılanın kabzını aslî veya yan yüküm olarak kararlaştırabilirler. Aynı şekilde, bazı özel durumlardan devralmanın alıcı için bir borç teşkil ettiği sonucu çıkartılabilir; satıcının devralmada görülebilir bağımsız menfaatinin bulunması halinde böyle bir durum söz konusu olur[34]. *Cavin* de esas itibariyle, teslimde alıcının yararının bulunduğunu ve alıcının satılanın devralınmasını haksız olarak reddetmesinin daha çok alıcının temerrüdü (TBK m. 106 vd.) sayılacağını kabul etmektedir[35]. Ancak bu yazara göre, satılanın devir alınmamasının bedeli ödememe sonucunu doğurduğu veya ard arda teslimli satışlarda alıcının sipariş vermeyi reddettiği hallerde, satıcı borçlunun temerrüdüne ilişkin TBK m. 118-125) hükümlerine başvurabilir; satılanın devrinde yararı olan veya satılanı tevdi edecek durumda olmayan satıcının (meselâ, yıkılacak binanın enkazının satışı, tarladaki

---

31 **Giger**, Art. 215, N. 54; **Lemp**, sh. 194; **Tandoğan** I/1, sh. 218/219.

32 11. HD, 17.2.1984, E. 65/K. 827 (YKD 1984, sh. 759 vd.).

33 **Giger**, Art. 184, N. 200; Art. 211, N. 21; **Heinz/Bommer**, sh. 91-92; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 334; **Tercier**, N. 438; **Honsell**, sh. 39.

34 **Giger**, Art. 211, N. 25; **Honsell**, sh. 39-40.

35 **Cavin**, sh. 53.

ürünün satışı veya satılanın kaldırılması ve taşınmasının aşırı masraflı olması) TBK m. 113/I'deki imkânları kullanabilir ve TBK m. 125/II uyarınca sözleşmeden dönebilir[36]. Buna karşılık bizim de katıldığımız başka bir fikre göre[37], satılanın devri alıcı için gerçek bir hukukî yükümdür; bu yükümün yerine getirilmemesi halinde, satıcı, alıcının temerrüdüne ilişkin hükümlere (TBK m. 125 vd.) dayanabileceği gibi, borçlunun temerrüdüne ait TBK m. 112 ve m. 125 vd.na göre de hareket edebilir. TBK m. 232/I, satıcıya alacaklının temerrüdünü düzenleyen TBK m. 106 vd. ndakinden daha geniş kapsamlı koruma sağlamak için konulmuş bir hükümdür. TBK m. 113 ve 117 vd. daki kurallar, alıcının temerrüdündeki imkânlara oranla daha basit ve etkili olduğu gibi, ticaret hayatının gereklerine daha uygundur. Özellikle yıkılacak binanın malzemelerinin satışında, ürün satışında veya TBK m. 107 gereğince tevdii önemli ölçüde yükleme ve taşıma masraflarını gerektiren malların satışında satılanın alıcı tarafından devralınmasında satıcının menfaati vardır[38]; bu durum, satıcının borçlunun temerrüdüne ilişkin TBK m. 113 ve m. 125/II vd.ndaki hükümlere dayanmasını haklı kılar.

Kısmî teslimlerin alıcının talebi üzerine gerçekleşmesi öngörülen ard arda teslimli satışlarda, alıcının teslim talebinde bulunmaması, satılanın teslim alınmaması ve bedelin ödenmemesi sonucunu doğurur. İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararına konu olan[39] bir olayda, taraflar, 25.3.1968 tarihinde 28.000 kg Motorex yağı satışına ilişkin bir sözleşme yapmışlar ve bu sözleşmeyle alıcı 31.12.1975 tarihine kadar, kendisinin seçeceği çeşitli miktar ve fiyattaki yıllık 3000-4000 kg.lık yağı sipariş vermeyi taahhüt etmiştir. Alıcı, sözleşme süresi içinde sadece 5367 kg yağ satın almış ve satıcının geriye kalan 22.000 kg.lık yağ siparişi yapılması talebini yerine getirmemiştir. Satıcının sipariş edilmeyen yağların bedelinin ödenmesine ilişkin olarak açtığı davada, Federal Mahkeme aşağıdaki görüşlere yer vermiştir:

---

36 **Cavin**, sh 54. Ayrıca bk. OR-**Koller**, Art. 211, N. 5 vd.; **Honsell**, sh. 39-40.

37 **von Tuhr/Peter**, sh. 81; **Keller/Siehr**, sh. 22; **Schönle**, Art. 184, N. 94; **Becker**, Art. 211, N. 5; **Weber**, Art. 72, N. 52. **Tandoğan** I/1, sh. 208; BGE 110 II 151; 111 II 159.

38 **Keller/Siehr**, sh. 22; **Cavin**, sh. 54.

39 BGE 110 II 148 vd.

"(daha önceki) içtihatlara ve Cavin'in görüşüne uygun olarak, olayda olduğu gibi, teslim edilecek şeyin belirlenmesinin teşkil ettiği hazırlık fiilinin yerine getirilmemesi, bedelin ödenmemesi sonucunu doğuruyor ise, borçlunun temerrüdüne ilişkin kuralların uygulanması gerektiğini kabul zarureti vardır. Esasen, alacaklının temerrüdü hakkındaki kurallar, satıcıya tazminat bahşetmek veya ona alıcıdan bedelin ödenmesini elde etmek imkânı vermek için elverişli değildir. Bu kurallar, bir edim borçlusu satıcıya, sadece borçlarından kurtulma veya borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlerde zaten mevcut olan sözleşmeden dönme (TBK m. 110) yetkisi vermektedir.

Böylece, somut olaydaki gibi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme söz konusu olduğu zaman TBK m. 123-125'deki kurallar uygulanır. Bu kurallarda sözleşmenin ifasını veya sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçlarının giderilmesini isteyen tarafın mütemerrit tarafa ifa için uygun bir süre tayin etmesi veya tayin ettirmesini gerekli kılan ilke hâkim bulunmaktadır. Belirleme kaydıyla satışta, yani seçimlik bir borcun karşı ediminin istenmesi halinde, bedelin borçlusu kendisine düşen hazırlık fiilini (seçimi) yerine getirmediği takdirde, satıcıya, sadece alıcıdan (uygulama açısından kötü ve faydası az olan) seçim hakkını kullanmasını isteme hakkını değil, ayrıca, yukarda zikredilen içtihadın (BGE 42 II 225) kabul ettiği Alman hukukundaki çözüme uygun olarak, alıcının yerine seçim yapma hakkı da tanımak gerekir.

Bununla beraber, seçim ve belirleme hakkının bu şekilde (satıcıya) geçebilmesi için, satıcının mütemerrit alıcıya TBK m. 125/I gereğince ifa için uygun bir süre belirlemesi ve yerine getirmediği takdirde satıcının seçim yapacağının bildirilmesi gerekir. Bu son süre, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde temerrüde ilişkin kuralların esaslı bir unsurunu teşkil eder ve bundan vazgeçmek söz konusu olamaz"[40].

2. Şartları

Alıcının satılanı kabzetmekle yükümlü olması için şu üç şartın gerçekleşmesi gerekir[41].

a) Sözleşmeyle öngörülen şey devredilmeli ve aksi kararlaştırılmadıkça satılan tamamen ifa olarak arz edilmelidir.

b) Teslime arz, vaktinde yapılmalıdır.

---

[40] BGE 110 II 148 vd., Cous. 1.b.

[41] **Tercier**, N. 439; **Tandoğan** I/1, sh. 208-209.

c) Satılan ayıpsız olarak alıcıya arz edilmelidir.

3. Devralma borcunun yerine getirilmemesi

Alıcının satılanı devralma borcunu yerine getirmemesi halinde, satıcı, alacaklı temerrüdüne ilişkin hükümlere (TBK m. 107-109) başvurabilir; masrafı alıcıya ait olmak üzere satılan şeyi kaldırtabilir (TBK m. 113/I) veya borçlunun temerrüdüne ait hükümlere (TBK m. 123-125) başvurabilir.

TTK m. 23/b'de ticari satışlar bakımından özel hüküm getirilmiştir. Buna göre, alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteyebilmektedir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasını sağladıktan sonra satış giderleri satış bedelinden çıkarılır. Satıcı, artan parayı alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere tevdi ederek durumu hemen alıcıya ihbar eder. Satıcının takas hakkı ise saklı tutulmaktadır. Bu madde BK m.108'in (alacaklının temerrüdünde borçlunun satma hakkı) özel bir halini ifade etmektedir. Böylece satıcının satma hakkını kullanması kolaylaştırmaktadır.

III. Alıcının diğer yükümleri

Alıcının diğer yükümleri başlığı altında madde madde şu haller sıralanabilir:

1. Aksine âdet veya sözleşme yoksa, senet yapmak ve satılanı devralmak için yapılan masrafları ödeme yükümü (TBK m. 211/I).

2. İfaya hazırlık hareketlerine katılma yükümü.

3. Mesafe satışlarında satılanı muhafaza ve bozulacak şeylerin satışı (TBK m. 226) yükümü.

İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ SATIŞI, SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR VE SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

§ 11. TAŞINMAZ SATIŞI

I. Tanımı ve konusu

Türk Borçlar Kanunu'nun taşınmaz (gayrimenkul) satışına ilişkin hükümlerinde (TBK m. 237-246) taşınmaz satışının tanımı ve konusu düzenlenmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla, taşınmaz satışının tanımı ve konusunu, taşınmaz mülkiyetinin konusunu düzenleyen MK m. 704 ve nelerin tapu siciline taşınmaz olarak kaydedileceğine ilişkin MK m. 998 hükümlerinden çıkartmak mümkündür. Bunlara 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 13. maddesi hükmünü de eklemek gerekir[1].

Bu hükümlere göre, arazi, tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz sayılır. 3213 sayılı Maden Kanunun 4. maddesine göre, "madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tâbi değildir". Maden Kanunu m. 38'e göre maden haklarının (m. 3: madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinlerin ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânların) devri özel olarak tutulan maden siciline tescil edilmedikçe hüküm ifade etmez. Bu kanun hükümleri karşısında, maden denilince, özellikle madenler üzerindeki işletme imtiyazı; maden satışı deyiminden de işletme ruhsatının (işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için verilen yetki belgesinin) devri anlaşılır[2]. 4721 sayılı yeni Medeni Kanun'un 704. ve 998. maddelerinde tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilmesi gereken mal ve haklar arasında madenlere yer verilmemiştir.

Buna göre, taşınmaz satış sözleşmesi, arazi veya taşınmaz olarak tapu siciline kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine

---

1 **Tandoğan,** I/1, sh. 223; **Yavuz,** sh. 171; OR-**Hess,** Art. 226, N. 2.

2 **Zevkliler,** sh. 48.

konu olan bağımsız bölümlerin ücret karşılığında devri taahhüdü olarak tanımlanabilir.

II. Şekli

TBK m. 237/I'e göre, taşınmaz satışının geçerli olması için resmî şekilde yapılması şarttır[3]. Aynı kural, MK m. 706/II'de de ifade edilmiştir. Bu hükümlere göre, taşınmaz satışlarında, resmî şekil sözleşmenin geçerlilik şartını teşkil eder. Taşınmazlara ilişkin satış sözleşmelerinde geçerlilik şartı olarak öngörülen resmî senetler, Tapu Kanunu m. 26 gereğince tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından düzenlenir (TST. m. 17). Ancak 3045 sayılı kanunun[4] geçici 5. maddesinin (c) fıkrasında, tapu sicil muhafızları ve tapu memurlarına verilen her türlü sözleşme düzenleme ile tescil görev ve yetkilerinin, bu kanunla kabul edilen tapu sicil müdürleri tarafından yürütüleceği öngörülmüştür. Buna göre, taşınmaz satışına ilişkin resmî senetler tapu sicil müdürleri tarafından düzenlenir.

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre[5], arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmeleri, tapu sicil müdürlüklerince yapılabileceği gibi, noterler tarafından düzenleme biçiminde de yapılabilir.

TBK m. 237/II'de taşınmaza ilişkin satış vaadi ile geri alım ve alım sözleşmelerinin geçerliliği resmî şekil şartına bağlanmıştır. Bunlardan sözleşme yapma vaadleri, asıl satış akdini düzenlemeye yetkili tapu sicil müdürlükleri ve Noterlik K. m. 60/b. 3 gereği noterler tarafından düzenleme şeklinde tanzim edilebilir. İştira ve vefa sözleşmeleri ise, Tapu K. m. 26 gereğince tapu sicil müdürlüklerince düzenlenir.

---

3 Tapuda kayıtlı taşınmazların haricen satışı geçersizdir (8. HD. 2014/990 E. 2014/20930 K. –Kazancı-. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın haricen satışı satın alan bakımından kişisel bir hak sağlar (Y 10.7.1944 tarih İBK 2/77 sayı), İBK 22.11.1944 tarih 1944/27 e. 1944/32 K.; Tapusuz taşınmazların haricen satışı gelecekte mülkiyet hakkı kazanalımasına yol açan zilyetliğin devrine ilişkin olduğundan resmi şekle tabi değildir (Y İBK 9.10.1946 tarih 1946/6 E. 1946/12 K.

4 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (RG 9.10.1984 tarih Sayı: 18540).

5 15. HD, 4.12.1980, E. 1990/K. 2594 (YKD 1982, sh. 90); 15. HD, 2.2.1995, E. 2658/K. 480 (YKD 1995, sh. 1088); HGK, 29.1.1986, E. 14-849/K. 57 (ABD 1986, sh. 570); **Yavuz,** sh. 518, dn. 12'de zikredilen diğer kararlar.

Bununla beraber, Yargıtay, iştira ve vefa sözleşmelerini noterlerin de düzenleyebileceklerini kabul etmektedir[6].

TBK m. 237/III gereğince sözleşmeden doğan önalım hakkı için yazılı şekil yeterlidir.

1. Şeklin kapsamı

Taşınmaz satış sözleşmelerinde, objektif esaslı noktalar ile bu sözleşmeyle doğrudan doğruya ilişkisi bulunan sübjektif bakımdan esaslı noktaların resmî şekilde düzenlenmesi, yani resmî senette yer alması gerekir[7].

a) Objektif esaslı noktalar

Taşınmaz satış sözleşmesinde objektif bakımdan esaslı nokta olarak tarafların adları, satış konusu taşınmaz, semen ve hukukî sebebin resmî şekilde düzenlenecek senette yer alması gerekir[8].

Sözleşmenin vekil veya temsilci aracılığı ile kurulması halinde, vekilin kimliğinin ve temsil ilişkisinin resmî senette gösterilmesi gerekir; aksi takdirde temsil olunan, satış sözleşmesine dayanarak kendi lehine bir hak iddia edemez. Bu hususta, karşı tarafın temsil ilişkisini bilmesi veya bilebilecek durumda olması önemli olmadığı gibi, TBK m. 40/II'ye dayanarak temsilciyle veya temsil olunanla sözleşme yapılmasının farksız olduğu da iddia edilemez[9]. Buna karşılık hâkim fikir ve içtihatlar, taşınmaz alımına ilişkin temsil yetkisi ve vekâletin herhangi bir şekle bağlı olmadığı görüşünü savunmaktadır[10]. Bu görüşün, TBK m. 237/I ve MK m. 706/I'de öngörülen şekil mecburiyetinin amacıyla bağdaştığı söylenemez. Bu itibarla, kıyas yoluyla, burada da şekil mecburiyetini kabul etmek gerekir[11]. TST m. 13/IV'e göre de, "İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden Noterlik Kanununa göre düzen-

---

6 **Oğuzman/Seliçi**, Eşya Hukuku, sh. 481, dn. 727'deki kararlar.

7 **Giger**, Art. 216, N. 233; **Tercier**, N. 518; **Tandoğan**, I/1, sh. 228; **Zevkliler**, sh. 49; BGE 113 II 402 vd.

8 **Leuenberger**, in: Koller, Grundstückkauf, N. 112 vd.; **Giger**, Art. 216, N. 234 vd.

9 **Leuenberger**, N. 113; BGE 45 II 565 vd.

10 **Meier-Hayoz**, Art. 657, N. 52; **Becker**, Art. 216, N. 11; **Yavuz**, sh. 178; BGE 112 II 332, Erw. 1 a; 99 II 162; 81 II 231.

11 **Leuenberger**, N. 116; **Giger**, Art. 216, N. 239; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 138 ve 460 vd; **Hoffstetter**, sh. 41 vd; **Keller/Schöbi**, Bd. I, sh. 81; **Oğuzman/Seliçi**, sh. 290.

lenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir".

Tarafların daha az tapu harcı ödemek üzere satış bedelini gerçek miktarın altında göstermeleri halinde, taraflar muvazaa sebebiyle sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmedikleri sürece, satış sözleşmesi geçersiz olmaz[12]. Sözleşmenin ifasından sonra tarafların muvazaa iddiaları, hakkın kötüye kullanılması yasağı ile karşılaşır.

b) Sübjektif esaslı noktalar

Sübjektif esaslı noktalar, tarafların sözleşmenin esaslı noktaları haline getirdikleri objektif yan noktalardır. Sübjektif esaslı noktalar ya tarafların anlaşmaları (kararlaştırmaları), ya da taraflardan birinin diğer tarafa anlatması veya hissettirmesi suretiyle esaslı nokta, yani sözleşme iradesinin zorunlu şartı (condictio sine qua non) haline getirilebilir[13].

Şekil zorunluluğunun sübjektif esaslı noktaların tamamını kapsayıp kapsamadığı hususu tartışmalıdır. Sübjektif esaslı noktaların tamamının kanunî şeklin kapsamına dahil olduğunu iddia eden sübjektif teori, doktrindeki yeni görüşler tarafından eleştirilerek, yumuşatılmış ve sınırlandırılmıştır[14]. Buna göre, sadece satış sözleşmesinin objektif noktaları (tipik edimleri) ile sıkı bir ilişki içinde olan, edim ve karşı edimleri açıklayan ve güçlendiren sübjektif yan noktalar şekil zorunluluğunun kapsamına girer. İsviçre Federal Mahkemesi'nin yerleşmiş iç-

---

[12] Muris muvazaasında muris, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmaza ilişkin tapuda yapılan resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu durumda görünürdeki satış işlemi tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi ise kanunla öngörülen şekil şartını taşımadığından, miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar tarafından tapu kaydının iptali istenebilmektedir (İBK 1.4.1974 tarih ve 1/2 sayı, Y 1. HD. 2014/4241 E. 2015/3267 K. –Kazancı-.

[13] **Keller/Schöbi,** I, sh. 54-55; **Eren,** C. I, sh. 294; **Gauch,** von den Wesentlichen Vertrag, recht 1991, sh. 50; **Tercier,** N. 672; **Altaş,** Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998, sh. 53-54.

[14] **Gauch,** vom Formzwang des Grundstückkauf und seinem Umfang, BR 1986, sh. 82; **Bruckner,** Umfang des Formzwangs beim Grundstückkauf, ZBNR 1983, sh. 65 vd; **Leuenberger,** N. 109; **Cavin,** sh. 127 ve 128; **Tercier,** N. 666 vd; **Altaş,** sh. 56-57.

tihatları da bu yöndedir[15]. Yüksek Mahkeme bir ödüncü teminat altına almak için verilen iştira hakkında, âdi senetle düzenlenen ödünç sözleşmesinin kanunî şeklin (TBK m. 237) kapsamına girmediğine karar verirken, aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: "Objektif yan anlaşmalar ancak mahiyetleri itibariyle bir satış sözleşmesinin çerçevesine girdikleri takdirde, sübjektif esaslı nokta olarak şekil mecburiyetine tâbi olurlar. Bunun için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. Bir taraftan, üstlenilen borcun hukukî sebebinin satışın tabiî muhtevasının dışında kalmayan bir alacak içinde bulunması; taahhüt edilen hususun satış bedeli veya mülkiyet geçirilmesi için bir karşı edim teşkil etmesi gerekir. Diğer taraftan, borcun konusu bir satışın çerçevesinde yer almak, satılanın hukukî durumunu etkilemek ve doğrudan doğruya sözleşmenin muhtevasına ilişkin olmak zorundadır (BGE 90 II 37 vd). Bu itibarla, ancak satış sözleşmesinde edim ve karşı edim ilişkisini etkileyen anlaşmalar kanunî şekle tâbidir. Bir borcun diğerine sadece vesile olması, meselâ, sebebi yönünden karşılıklı bağımlılık içinde bulunan iki sözleşme yeterli değildir (Schmidlin, Art. 11, N. 102)"[16]

Bu itibarla, tarafların edim yükümlerini kuvvetlendirmeye yönelik cezai şart kaydı[17] ve pişmanlık akçesi resmî şekilde yapılmalıdır[18].

2. Şekle uymamanın sonuçları

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre, taşınmaz satış sözleşmesinde resmî şekil şartına uymamanın sonucu butlandır (kesin hükümsüzlük)[19]. Ancak şekil noksanını ileri sürmenin hakkının kötüye kullanılması sayıldığı durumlarda (meselâ, tarafların edimlerini bilerek ve isteyerek ifa etmiş olmaları), şekle aykırılık iddiası kabul edilemez[20].

---

15 BGE 90 II 37 yahut JdT 1964 I 360 vd; BGE 113 II 402; 117 II 259; 119 II 135 yahut JdT 1994 I 99.

16 BGE 113 II 402 yahut JdT 1988 I, sh. 69.

17 15. HD, 2.2.1995, E. 2658/K. 2658: "Yasada asıl sözleşme içerisinde kararlaştırılan ve sözleşmenin bir parçası olan cezaî şart için de (akdî kayıt) asıl borcun tâbi olduğu biçim koşulunun geçerli olacağı yolunda bir hüküm bulunmamaktadır. Taşınmaz satışını güçlendiren cezaî şart da, satış sözleşmesinin tâbi olduğu şekilde yapılmalıdır. Aksi halde cezaî şartın geçerliliğinden söz edilemez" (YKD 1995, sh. 1088).

18 **Meier-Hayoz,** Art. 657, N. 85; **Tandoğan** I/1, sh. 231-232; **Oğuzman/Seliçi,** sh. 282; **Altaş,** sh. 58.

19 Yarg. İTBK, 30.9.1988, E. 2/K. 2 (YKD 1989, sh. 153).

20 Yarg. İTBK, 30.9.1988, E. 2/K. 2 (YKD 1989, sh. 157 vd.); HGK, 9.6.1982, E. 15-1613/K. 565 (YKD 1982, sh. 1386).

Yargıtay'a göre, bir sözleşme henüz ifa edilmemiş olsa dahi, aşağıdaki şartların bulunması halinde, şekil noksanı sebebiyle butlan iddiası, hakkın kötüye kullanılması sayılabilir:

"Bir kimsenin a) şeklin gerçekleşmesine kendi yararı için veya yanıltıcı hareketlerle engel olduğu,

b) Sözleşmenin sonradan kendi yararına olmadığını görünce ondan kurtulmak istemesi ahlaki duyguları rencide ediyorsa veya şeklin koruyucu etkisinden yoksun kaldığı için değil, aksine, kendi borçlarını yerine getirmekten kaçınmak amacıyla şekilsizliği bir sebep olarak kullandığı anlaşılıyorsa,

c) Yine taahhütlerini mutlak ifa edeceğini, sözleşmenin yapılmasından sonra teyit etmiş ve diğer tarafın sözleşmeye karşı beslediği güveni sebepsiz ve haksız olarak kuvvetlendirmişse, artık sözleşmenin şekil yönünden geçersizliğini ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılması anlamını taşır ve bu savunma yasal korumadan yoksun kalır"[21].

III. Ayıptan ve zapttan doğan sorumluluk

1. Ayıptan doğan sorumluluk

Taşınır (menkul) satışında ayıptan sorumluluğu düzenleyen hükümler (TBK m. 219 vd.) kıyas yoluyla taşınmaz satışlarında da uygulanır (TBK m. 246)[22].

TBK m. 244 taşınmaz satışında ayıptan doğan sorumluluk ile ilgili olarak iki özel kural ihtiva etmektedir. Bunlardan birincisi taşınmazın yüz ölçümündeki noksanlara, diğeri zamanaşımı süresine ilişkin bulunmaktadır.

a) Taşınmazın yüz ölçümü eksiklerine karşı tekeffül borcu

TBK m. 244/I-II, taşınır satışındaki esastan ayrılarak, taşınmaz satışında yüz ölçümü eksikliklerini ayıp sayarak, satıcının bu eksiklikten ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine göre sorumlu olacağını öngörmektedir. Kanun koyucunun taşınmazlardaki miktar eksikliğini ayıp

---

[21] 13. HD, 2.12.1991, E. 7217/K. 10901 (YKD 1992, sh. 239).

[22] Taşınmazın satışından sonra deprem nedeniyle meydana gelen müteahhidin işin yapılmasında mevcut kusuruna dayanan zararlardan, ayıptan sorumluluk kurallarına göre sorumluluk yüklenmektedir. Taşınmaz, zararın doğmasından önce üçüncü bir kişiye satılmış olsa bile BK m. 297 delaletiyle m.194'e göre (TBK m. 249 delaletiyle m. 219 yeni malike karşı müteahhidin sorumluluğu devam etmektedir (13. HD. 2010 E. 2011/6465 K. –Kazancı-)

olarak nitelemesinin sebebi, taşınmaz satışının konusunu sözleşmede bildirilen yüz ölçümünün değil, ferden belirlenmiş bir parselin teşkil etmesidir. Burada alıcı, kural olarak, eksik olan miktar için, çeşit satışındaki gibi aynen ifa talebinde bulunamaz[23].

TBK m. 244/I ve II, satıcının yüzölçümü eksikliğinden dolayı sorumluluğunu satılan taşınmazın ölçüsünün resmî bir ölçmeye dayanıp dayanmamasına göre farklı şekilde düzenlemiştir. Buna göre, satış senedinde yazılı miktar resmî bir ölçmeye dayanmıyorsa, aksi sözleşmeyle kararlaştırılmadıkça, satıcı senette yazılı ölçüden eksik kalan kısmı tazmin etmekle yükümlüdür (TBK m. 244/I).

Buna karşılık, satılan taşınmazın ölçümü resmî bir ölçmeye dayanıyorsa, taşınmazın gerçek yüz ölçümü tapu siciline kaydolunan miktardan az olduğu takdirde, satıcı tahsisen taahhüt etmiş olmadıkça, noksanı tazminle mükellef değildir (TBK m. 244/II). Arazinin kadastrosunun yapılmış bulunması veya imarca parsellenmiş olması sicildeki kaydın resmî ölçmeye dayandığını gösterir[24].

b) Zamanaşımı süresi

TBK m. 244/III'e göre, bir binanın ayıplı olmasından dolayı ayıptan doğan sorumluluğa dayanan davalar, mülkiyetin devrinden itibaren beş yılın ve satıcının ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrarlar.

Yargıtay, bu hükmün lafzına bağlı kalarak sadece binalara ilişkin ayıplardan doğan tekeffül borcunun beş yıllık zamanaşımı süresine tâbi olduğunu; diğer hallerde bir yıllık zamanaşımının söz konusu olacağını kabul etmektedir[25]. Buna karşılık Federal Mahkeme, TBK m. 244/III hükmünün, üzerinde yapı bulunmayan taşınmazlardaki ayıba da uygulanacağı görüşündedir[26].

TKHK m. 12/1'de konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda zamanaşımı süresi teslim tarihinden itibaren beş yıl olarak öngörülmüştür. Buna karşılık ikinci el satışlarında konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda zamanaşımı süresi üç yıldan az olamaz (f. 2).

---

23 **Keller/Siehr**, sh. 122; OR-**Honsell,** Art. 219, N. 1; BGE 106 II 148; 62 II 161 vd.

24 **Tandoğan** I/1, sh. 271; **Yavuz**, sh. 186.

25 13. HD, 1.3.1984, E. 795/K. 1581 (YKD 1984, sh. 1404); HGK, 13.11.1957, E. 4-80/K.7 (**Tandoğan** I/1, sh. 269, dn. 124).

26 BGE 104 II 265 yahut JdT 1979 I, 95/96.

2. Zapttan doğan sorumluluk

Taşınmaz satışında zapttan doğan sorumluluk bakımından menkul satışına ilişkin kurallar (TBK m. 214 vd.) kıyas yoluyla uygulanır (TBK m. 246). Bununla beraber, tapu siciline güven ilkesi dolayısıyla bu hükümlerin uygulama alanı çok sınırlıdır.

IV. Yarar ve hasarın geçişi

Taşınmaz satışında yarar ve hasar kural olarak akdin kurulmasıyla alıcıya geçer; ancak, satılanın teslimi için sözleşmeyle bir süre tayin edilmişse, yarar ve hasar bu süre dolmadan önce alıcıya geçmez (TBK m. 245). TBK m. 245 hükmü, teslimin tescilden sonra yapılmasının kararlaştırılması halinde de uygulanmalıdır[27]. Türk Hukukunda taşınmaz satışlarında taahhüt aşaması ve tasarruf aşaması bir anda gerçekleşmektedir. Bu nedenle, teslimin tescilden sonra yapılması, sözleşmeye ilişkin tasarruf işlemi olarak değerlendirilemez. Bu durum taraflar arasında satış işlemi ile alıcıya geçen taşınmazın özel bir anlaşma ile satıcının elinde bir süre daha kalmasını kararlaştırmaları halidir.

---

[27] **Tandoğan** I/1, sh. 268; **Tunçomağ**, sh. 146; **Serozan (Hatemi/Arpacı)**, sh. 123; **Keller/Siehr,** sh. 137.

§ 12. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR

I. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi, taşınmaz satış sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmediği haller ile taşınmaz satışlarına ilişkin taahhüt işleminin tapuda tasarruf işlemi ile birlikte yapılma zorunluluğu nedeniyle bunun sözleşme esnasında taraflarca herhangi bir sebepten istenmemesi hallerinde yapılmaktadır. Tapuda şarta bağlı satış yapılamaması da taşınmaz satış vaadinin taraflarca tercih edilmesine yol açmaktadır. Bunun dışında işlemlerde çabukluk ve güven unsurlarını sağlaması bakımından uygulamada sıkça karşılaşılan hukuki kurumlardan biri haline gelmiştir.

1. Tanımı ve hukuki niteliği

Satış vaadi sözleşmesi, bir tarafa veya her iki tarafa belirli bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını talep hakkı sağlayan bir ön sözleşmedir[1].

Doktrinde hakim görüş taşınmaz satış vaadinin hukuki niteliğinin ön sözleşme olduğunu kabul etmektedir[2]. Önsözleşme, tarafların gelecekte borçlandırıcı bir sözleşme kurma konusunda yaptıkları anlaşmadır[3]. Önsözleşme yerine "akit yapma vaadi" veya "akit yapma taahhüdü" şeklinde deyimler de kullanılmaktadır. Ön sözleşme esas itibariyle bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Bu sebeple sözleşmelerin kurucu unsuru olan tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının ön sözleşme kurulurken de olması şarttır.

TBK m. 29 önsözleşmeyi düzenlemiş, "bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir" hükmü ile bu hukuki müessesenin geçerliliğine ilişkin tartışmayı sona erdirmiştir. TBK m. 29/II'de kanuni istisnalar dışında önsözleşmenin geçerliliğinin ileride kurulacak sözleşmenin şekline tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

---

1 Bkz. **Ayrancı**, Ön Sözleşme, 55 vd.; **Kocayusufpaşaoğlu**, Gayrimenkul Satış Vaadi, 48; **Dalamanlı**, 1986; **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 311.

2 **Ayrancı**, Ön Sözleşme, 53; **Esener/Güven,** 193; **Kocayusufpaşaoğlu**, 71; **Dalamanlı**, 3; **Çenberci**, 6.

3 **Ayrancı**, Ön Sözleşme, 40.

Türk Borçlar Kanununun 29. maddesinde ön sözleşmeye ilişkin şekil hükmü düzenlenmişken, Kanunun 237. maddesinde taşınmazlar bakımından neden tekrara düşüldüğü anlaşılamamaktadır[4]. Zira TBK 237. madde düzenlemesi olmasa da 29. madde nedeniyle taşınmazlara ilişkin satış işlemlerinin asıl sözleşmenin tabi olduğu şekilde yani resmi şekilde yapılması gerektiği açıkça ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirgindir[5]. Kanunun 237'nci maddesinde düzenlemeler birleştirilirken, muhtemelen aynı konunun TBK m.29/II'de (OR Art.22/II) düzenlendiği unutulmuştur. OR'nin 1919 revizyonunda ise bu tekrarın giderilmesi düşünülmemiştir. Aynı durum 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda da muhafaza edilmiştir.

Taşınmazlar bakımından özel bir düzenleme niteliğinde bulunan 237. maddenin amacı da tarafları acele karar vermekten korumaktır.

Türk Borçlar Kanununun 237. maddesinde taşınmaz satışı ve taşınmaz satış vaadi ayrı ayrı belirtilmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesi taşınmaz satış sözleşmesini düzenleyecek makamın tapu sicil müdürlükleri olduğunu, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 60/3 maddesi ise taşınmaz satış vaadi sözleşmesini yapmaya yetkili makamın noterler olduğunu düzenlemiştir.

Ön sözleşmede taraflardan biri asıl sözleşmeyi kurma borcu altına giriyorsa tek taraflı ön sözleşmeden, iki tarafta bu borç altına giriyorsa iki taraflı ön sözleşmeden söz edilir. Taşınmaz satış vaadini hukuki niteliği itibariyle bir ön sözleşme olarak kabul ettiğimizde taşınmaz satış vaadinin tek taraflı yapılabilmesi gerekir. Ancak Yargıtay taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iki taraflı olması ve bu durumunda hakim tarafından re'sen göz önüne alınması gerektiğini kabul etmektedir[6].

---

4 bkz. **Ayrancı**, Ön Sözleşme 54 vd.; **Oser/Schönenberger**, Art.216, N.16; **Çenberci** (12) taşınmaz satımının özel bir önemi olması nedeniyle böyle bir tekrarın yapıldığı görüşündedir.

5 OR görüşmeleri tekrarlanırken redaksiyon değişiklikleri yapılmış ve OR 216'da düzenleme yapılmıştı. Muhtemelen OR 22/II düzenlemesi nedeniyle şekle ilişkin başka bir düzenlemeye gerek olmadığı unutulmuştur (bkz. Ayrancı, Ön Sözleşme, 59 vd.).

6 "Tek taraflı olarak düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi geçersizdir." (HGK 30.11.1968, 811/787, **Çenberci**, 70) HGK 25.09.1995 tarih 1984/13 E.1985/729 K. Taşınmaz satış vaadinin bütün ön akitler gibi tek taraflı veya iki taraflı olarak yapılabileceğine ilişkin bkz. **Kocayusufpaşaoğlu**, 86.

Taşınmaz satış sözleşmesinin esaslı unsurları bedel ve satışa konu olan taşınmazdır. Ancak bu unsurların belirli veya belirlenebilir olmaları yeterlidir[7]. Sadece tapuya kayıtlı olan taşınmazlar taşınmaz satış vaadi sözleşmesine konu olabilir. Tapusuz taşınmazların satışının menkul malların satışına ilişkin hükümlere tabi olması bu hususu doğrulamaktadır.

Paylı mülkiyette paydaş payını satış vaadine konu edebilir. Aynı durum iştirak halinde mülkiyette de geçerlidir. Ancak iştirak halinde mülkiyette pay belli olmadığından sözleşmenin yerine getirilmesi iştirak halinin sona ermesinden sonra mümkündür[8].

Taşınmaz satış vaadine ilişkin sözleşmesinin geçerli olabilmesi için satış vaad edenin tasarruf ehliyetine sahip olması şart değildir. Çünkü taşınmaz satış vaadi tasarruf işlemi değil borçlandırıcı bir işlemdir. Borçlandırıcı işlemin yapılabilmesi için borç altına giren kişinin tasarruf ehliyetine sahip olması gerekmez. Satıcının tasarruf ehliyetine taşınmazın satışı anında sahip olması yeterlidir.

2. Şekli

Kanunda öngörülen şekle uygun olarak yapılmayan taşınmaz satışı ve taşınmaz satış vaadine ilişkin sözleşmeler geçerli değildir (TBK m. 12/II). Kanun koyucu sözleşmeleri şekle tabi tutmak suretiyle tarafları acele karar vermelerini önleyerek, kişileri daha dikkatli davranmaya yönlendirmektedir. Bunların dışında taraf iradelerine açıklık sağlama ve ispat kolaylığı sağlama sözleşmelerin şekle tabi olmasında öngörülen sebeplerdir. Bu bağlamda, genel olarak şeklin amacının bazen tarafları bazen de üçüncü kişilerin veyahut kamunun yararını korumak, hukuki güvenliği sağlamak olduğu görülmektedir[9].

TMK m. 706 *"taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır"* hükmünü amirdir. TBK m. 237 ise taşınmaz satışı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin geçerli olması için resmi senet şeklinde yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Tapu Kanununun 26. maddesi taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeleri yapmaya yetkili ma-

---

7 **Kocayusufpaşaoğlu**, 113; **Çenberci**, 85.

8 **Ertaş**, 315.

9 **Ayrancı**, Ön Sözleşme, 145; **Kocayusufpaşaoğlu**, 115; **Kılıç**, Halil, Son Değişikliklerle Gayrimenkul Davaları, Cilt 1, Ankara 2006, 1048; bkz. İBK 26.11.1980 gün ve 5/3 sayı.

kamın tapu sicil memur ve muhafızları olduğunu belirtmiş, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 60/3 maddesi de taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin düzenleme şeklindeki noter senediyle yapılacağını hükme bağlamıştır.

Noterler yanında tapu sicil memurlarının da taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapıp yapamayacağı doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bir görüşe göre[10] Noterlik Kanunu'na göre bu yetki açıkça noterlere verilmiştir. Dolayısıyla taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmaya da noterler yetkilidir. Hakim görüşe göre[11] ise satım sözleşmesini düzenleme yetkisine sahip olan makamın satış vaadi sözleşmesini düzenleme yetkisine evleviyetle sahiptir. Bu nedenle, noterler yanında tapu sicil memurlarının da taşınmaz satış vaadi sözleşmesini yapmaya yetkili olduğu kabul edilmektedir. Noterler tarafından yapılan taşınmaz satışına ilişkin sözleşme her ne kadar geçersiz olsa da bu satış taraf iradelerinin yorumu ve tahvil yolu ile satış vaadi olarak geçerli sayılabilir. Yargıtayın da bu yönde kararları bulunmaktadır[12].

Satış vaadi sözleşmesinin noterler tarafından re'sen düzenlenmesi gerekir. Onaylama biçimindeki noter senedi ile yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri geçerli değildir. Ancak resmi şekilde yapılmayan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi geçersiz olsa da ifa edilmiş bir satış vaadinin geçersizliğinin ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması sayılabilir.

3. Hüküm ve sonuçları

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde asıl sözleşmenin yapılmasını istemeye hakkı olan taraf bu isteğini karşı tarafa bildirdiğinde karşı taraf için satış sözleşmesini yapma borcu doğar. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hak, kişisel hak olduğu için sözleşmenin tarafları bu sözleşmeden doğan haklarını yalnız birbirlerine veya haleflerine karşı ileri sürebilirler[13].

Vaad alacaklısının talebine rağmen vaad borçlusu satım sözleşmesini yapmazsa vaad alacaklısı ifa davası açarak mahkemeden malikin irade beyanının yerine geçmek üzere karar verilmesini isteyebileceği

---

[10] **Çenberci**, 160–161.

[11] **Ertaş**, 314; **Kılıç**, 1050.

[12] HGK 10.2.1960 4-6E./188K.; HGK 26.6.1957 1-70E./64K. (**Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 361, 312).

[13] **Kocayusufpaşaoğlu**, 144.

ileri sürülmektedir. Ancak uygulamada ve doktrinde çoğunluk görüşüne göre[14] satış vaadi alacaklısı açtığı ifa davası ile taşınmazın mülkiyetini tapu kütüğü dışında tescil yapılmaksızın kazanmaktadır. Alıcıdan ayrıca tescile zorlama davasını açmasını beklemek aynı konuda iki dava açılmasına yol açar. Bu durum TMK. m. 2 ve usul ekonomisine aykırıdır. Yargıtay'ın da bu konudaki görüşü iki ayrı dava açmaya gerek olmadığı, açılacak ifa davası niteliğindeki tescile zorlama davasında (TMK m. 716/I) verilecek kararın kesinleşmesi üzerine tapu müdürlüğünde tescilin yapılabileceği yönündedir.

Uygulamada taşınmaz satış vaadinin taraflarca borçlanılan bir paranın teminatını teşkil etmek üzere yapıldığı görülmektedir. Borç alınan paranın satış bedeli teşkil ettiği ve satıcının bu parayı verdiği takdirde satış vaadinin sona ereceği kabul edilmektedir. Yargıtay bu sözleşmeleri muvazaa olarak görüp geçersiz saysa da burada sözleşme tarafların gerçek arzularını yansıttığı için muvazaadan değil "Lex Commissoria" yasağına aykırılıktan söz edilebilir (TMK m. 873/II).

4. Tapu kütüğüne şerhi ve sona ermesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan haklar kişisel hak niteliğinde olduğu için kural olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak, hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesi ile üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Tapu Kanununun 26. maddesi ile Türk Medeni Kanununun 1009. maddesi taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkı şerh edilebilecek kişisel haklar arasında saymıştır. Söz konusu haklar tapu kütüğünde şerh edilmesi halinde taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan kişilere karşı ileri sürülebilmektedir (TBK m. 1009/II).

Kural olarak bir kişisel hakkın tapu siciline şerh verilebilmesi tarafların şerh konusunda yapacakları bir anlaşmanın varlığına bağlıdır. Ancak Tapu Kanunu mad. 26/VI'ya göre "Noterlik Kanununun 44. maddesinin B bendi mucibince (yapılan değişiklikle1512 sayılı Noterlik Kanunu m. 60) noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vâdi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir" hükmünü içermektedir. Görüldüğü üzere Tapu Kanunu genel kuraldan ayrılarak taşınmaz satış vaadinden doğan hakkın şerhi için tarafların anlaşmasını aramamış, taraflardan birinin şerh isteminde bulunmasını yeterli görmüştür.

---

[14] **Esener/Güven**, 195; **Kocayusufpaşaoğlu**, 170–171; **Dalamanlı**, 4.

TMK m. 1009'un şerhi genel olarak düzenlemesi ve madde gerekçesindeki saymanın örnek niteliğinde olduğu yönündeki açıklamalar TMK m. 1009'un Tapu Kanunu mad.26/VI'yı ilga etme amacını gütmediğini göstermektedir. Kanun kişisel hakların şerhini genel bir çerçeve hüküm olarak düzenleme amacı takip etmektedir. Bu nedenle maddenin özel kanun hükümlerini saklı tutmuş sayılması gerektiği (Tapu Kanunu m. 26/VI) sonucuna varılmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Tapu Kanununun açık ifadesi karşısında taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin şerhi için şerh anlaşmasının yapılması zorunlu değildir.

Doktrinde hakim görüş taşınmaz satış vaadinin tapuya şerhinin etkisini eşyaya bağlı borç etkisi ve munzam etki[15] veya sadece munzam etki[16] ile açıklamaktadır.

Kişisel hakkın tapuya şerhi onu ayni hak haline getirmez. Şerh ile şahsi hakkın hükümleri kuvvetlendirilmiş, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir hale gelmiş olur. Özü itibariyle hak şahsi hak olma niteliğini muhafaza eder. Şerhle birlikte vaad alacaklısı bu hakkını hem taşınmazın sonraki maliklerine karşı ileri sürebilecek (eşyaya bağlı borç) hem de bu hakkını kullanmasına engel olabilecek üçüncü kişilere karşı (munzam etki) ileri sürebilecektir. Munzam etki konusunda görüş birliği olsa da taşınmaz satış vaadinin şerhinin eşyaya bağlı borç etkisi yaratıp yaratmadığı tartışmalıdır.

Tapu Kanunu m. 26'ya göre satış vaadi sözleşmesinin şerhinden itibaren beş yıl içinde asıl satış sözleşmesi yapılmazsa bu şerh tapu sicil memuru tarafından re'sen terkin olunur. Kanun şerhin etkisini beş yıllık süre ile sınırlamıştır. Burada getirilen beş yıllık süre sözleşmenin tapu kütüğüne şerhi için talepte bulunma süresi değildir. Tarafların sözleşmeyi kurduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde tapu kütüğüne şerh verdirmek zorunluluğu bulunmamaktadır[17]. Sözleşme kurulduktan sonra şerh, geçerlilik süresi olan beş yıl boyunca tapu kütüğüne tescilinden itibaren etkisini devam ettirecektir Satış vaadi yapıldıktan sonra 10 yıl içinde tapuya şerhin yapılmaması halinde, kanun şerhin verilmesi için herhangi bir süre öngörmediğinden, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl sonra da tapuya şerh verilebilir. Ancak sözleşmeden doğan borç yerine getirilmezse bu takdirde açılan ifa davasın-

---

15 **Oğuzman/Seliçi,** 314; **Esener/Güven,** 196.

16 **Çenberci,** 49.

17 1. HD 8.6.1971,4059/4105 (**Çenberci,** 56).

da, karşı taraf sözleşmenin zamanaşımına uğradığını, şerhin üçüncü kişilere karşı etkisini kaybettiğini ileri sürebilir. Dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak şekilde zamanaşımını ileri süren tarafın hakkı korunmaz.

Yargıtay, malik birden fazla kişi ile ayrı ayrı satış vaadi sözleşmesi yapmışsa hangi sözleşme önce yapılmışsa ona diğerlerine göre öncelik tanımaktadır[18]. Ancak öncelik ilkesi taahhüt değil, tasarruf işlemlerinde geçerlidir. Borçlandırıcı işlemler arasında tarih önceliği yaratmak diğer vaad alacaklılarına ifa için talep hakkı vermemek sonucu doğurur. Bu ise borçlandırıcı işlemlerin hepsinin ayrı ayrı geçerli olması ile bağdaşmaz[19]. Çünkü borçlandırıcı işlemlerden her biri o işlem ile ilgili geçerlilik koşullarını taşıdığı müddetçe hüküm ifade eder. Sonraki tarihli satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilmişse TMK m. 1009/II gereğince sonraki tarihli sözleşmeye öncelik verilir. Ancak sonraki tarihli sözleşme önceki sözleşmedeki alacaklıyı zarara uğratmak maksadıyla yapılmış ve tapuya şerh verilmişse sonraki sözleşmedeki vaad alacaklısının kötüniyeti korunmamalıdır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için kanunda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden zamanaşımına ilişkin TBK m. 146'da düzenlenen genel zamanaşımı kuralı uygulama alanı bulur. Buna göre satış vaadinden doğan davalar 10 yıllık zamanaşımına tabidir.[20]

II. Sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım sözleşmeleri

1. Genel olarak opsiyon hakkı

Bir kişinin henüz sözleşme kurmaya karar vermediği, uzun bir düşünme süresine ihtiyacı olduğu, sözleşmeyi kurma imkânını açık tutmak ve aynı zamanda düşünme zamanı içinde başka birinin aynı konu üzerinde sözleşme kurma ihtimalini bertaraf etmek istediği hallerde opsiyon sözleşmeleri yapılmaktadır[21].

Taraflar sözleşme ile daha önce şartlarını belirledikleri bir borç ilişkisini tek taraflı irade beyanı ile kurma, değiştirme veya süresini uzatma

---

18 14. HD. E. 1987/4244,K.1988/6494 (**Özmen/Yüce** Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, Cilt 2, İstanbul 2001, 984-985).

19 **Özmen/Yüce**, 956.

20 **Kocayusufpaşaoğlu**, 209; Ertaş, 317.

21 **MUNSCHENER KOMMENTAR/Kramer**, vor § 145, Rdnr.51; **Schmittat**, Einführung in die Vertragsgestaltung, München 2000, N.148.

hakkı tanımışlarsa, opsiyon hakkından bahsedilir"[22]. Bu nedenle opsiyon yenilik doğuran hak olarak nitelendirilebilir[23]. Herhangi bir hukuki ilişkide opsiyon hakkı tanınabilir. Örneğin kira ilişkisi veya satış sözleşmesi opsiyona konu olabilir. Satış sözleşmesine ilişkin opsiyonda alım hakkı kurulmuş demektir (TMK m. 736, 1009, TBK. m. 237/II)[24].

Opsiyon hakkını doğuran bazı hukuki yollar bulunmaktadır[25]. İlk olarak opsiyon tek tarafı bağlayan icap yardımıyla gerçekleşir[26]. Hak sahibinin uzun süreli bağlayıcı bir icapta bulunması halinde opsiyon hakkından söz edilebilir. Diğer taraf bu icabı kabul edip etmemek konusunda tam bir serbestiye sahiptir.

Opsiyon, ikinci olarak, asıl sözleşmenin kurulması ancak bir tarafın iradesiyle gerçekleşen erteleyici şarta bağlanmak suretiyle kurulur. Bu şarta iradi şart adı verilmektedir[27]. Bu ihtimalde karşı taraf sözleşmeyle bağlıdır. Hak sahibi ise dilediği gibi hareket eder[28].

---

22 **Kocayusufpaşaoğlu** (Borçlar), 104; **Larenz/Wolf** (2004), § 23 VI 1 N.103, 426; **Erman/Hefermehl**, vor § 145, Rdnr.43; **MUNSCHENER KOMMENTAR/Kramer**, vor § 145, Rdnr.50; **Soergel/Wolf,** vor § 145, Rdnr.69; **Palandt/Heinrichs**, Einf. vor § 145, Rdnr.23; **Larenz/Wolf** (1997), 464; BGE 113 II 31, 34-35 E.2a; BGE 122 III 10, 15 E.4b.

23 **Kocayusufpaşaoğlu** (Borçlar), 104; **MUNSCHENER KOMMENTAR/ Kramer,** vor § 145, Rdnr.50; **Gauch/Schluep/Schmid/Rey,** Nr.1097; **Palandt/ Heinrichs,** Einf. vor § 145, Rdnr.23.

24 **Kocayusufpaşaoğlu**, 101 dn.42; bkz. **von Tuhr/Peter,** 277; **Kocayusufpaşaoğlu** (Borçlar), 104; **MUNSCHENER KOMMENTAR/ Kramer,** vor § 145, Rdnr.50.

25 **MUNSCHENER KOMMENTAR/Kramer,** vor § 145, Rdnr.53 ve 54'e göre tek tarafı bağlayıcı icap dışında, opsiyon sözleşmesi olarak da isimlendirilen icap sözleşmesi (Angebotsvertrag) ile asıl sözleşmenin opsiyon kaydı ile kurulması yoluyla kurulabilir.

26 **Larenz/Wolf** (2004), § 23 VI 1 N.105, 426; **MUNSCHENER KOMMENTAR/Kramer,** vor § 145, Rdnr.52; **Palandt/Heinrichs,** Einf. vor § 145, Rdnr.23

27 **Soergel/Wolf,** vor § 145, Rdnr.70; **MUNSCHENER KOMMENTAR/ Kramer,** vor § 145, Rdnr.45; **Hase**, 35; **Palandt/Heinrichs,** Einf. vor § 145, Rdnr.23; Alman hukukunda düzenlenme konusu yapılmamış olan alım hakkı için uzun süreli icap görüşü hakim kanaattır. Ancak, kendisine opsiyon hakkı tanınmış bulunan kişi bir karşı edim borçlanmışsa opsiyon sözleşmesi kurulabilir (**Kocayusufpaşaoğlu**, 101 dn.42).

28 **Soergel/Wolf,** vor § 145, Rdnr.70, § 158, Rdnr.29; **Larenz/Wolf** (2004), § 23 VI 1 N.106, 426; **Schmittat**, 149.

Ön sözleşme ilk bakışta opsiyon hakkı veren bir sözleşme gibi görünse de bu görünüş yanıltıcıdır. Zira, opsiyon hakkından farklı olarak ön sözleşmeden dolayı asıl sözleşmeyi kurma konusunda alacaklı olan tarafın bu isteğini ileri sürmesi yenilik doğuran hak niteliği taşıyan bir beyan değildir. Aksine, sözleşmenin kurulmasına yönelmiş bir icap niteliğindedir. Ön sözleşme opsiyon hakkının verdiği sonuçlara benzer sonuçlar doğurur. Ancak, kendisinden doğan hakkın niteliği, kullanılma şekli ve hükümleri opsiyon hakkından tamamıyla farklıdır. Nitekim, asıl sözleşmenin kurulmasına ilişkin icaba uygun karşılık (kabul beyanı) verilmediği takdirde, alacaklı asıl sözleşmenin kurulmasını dava konusu yapacaktır.

Opsiyon hakkının muhatabı olan taraf satış sözleşmesinde satıcı veya alıcı olabilir. Muhatap satıcı taraf ise bir alım hakkı söz konusu olur. Bu borsa terminolojisinde Call-Option olarak da isimlendirilmektedir. Bekleyen alıcı tarafta ise kişi herhangi bir yükümlülük yüklenmeden sözleşme konusunu devretme imkânına sahip iken alıcı kazanma yükümlülüğü altındadır. Bu tür de Put-Option olarak isimlendirilir[29].

Opsiyonun üç önemli türü alım hakkı, geri alım hakkı ve saf opsiyondur[30]. Buna karşılık önalım hakları ile rüçhan hakları imtiyaz haklarından sayılmaktadır[31].

Opsiyon hakkının ne ölçüde üçüncü kişiye devredilebildiği sorunu tartışmalıdır. Opsiyon hakkı çoğunlukla şahsa sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçekten de TBK m. 239/I'de sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım hakkının aksi kararlaştırılmadıkça devredilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Opsiyon yükümlüsü, kendisine karşı opsiyon hakkının verildiği tamamıyla belirlenmiş bir kişiye karşı bu durumda bulunmaktadır. Bu kişi somut olaylar veya şartlar nedeniyle bu işlem için uygun göründüğü için kendisine karşı böyle bir yükümlülük altına girilmiştir. Bu nedenle kural olarak devredilemez olduğu söylenebilir[32].

---

[29] **Soergel/Wolf**, vor § 145, Rdnr.70; **MUNSCHENER KOMMENTAR/ Kramer,** vor § 145, Rdnr.50; bkz. **Larenz/Wolf** (2004), § 23 VI 1 N.103, 426.

[30] **Fikentscher**, 94; bkz. **von/Tuhr/Peter,** 277; **Stüber**, 30 dn.14; **Soergel/Wolf,** vor § 145, Rdnr.70.

[31] **Heinrich** (63) önalım hakkını opsiyon haklarından saymaktadır.

[32] **Hase**, 36.

2. Alım (iştira) sözleşmesi

Alım sözleşmesi hak sahibine tek taraflı irade beyanıyla satış sözleşmesi kurma hakkı veren bir sözleşmedir[33]. Alım sözleşmesi opsiyon sözleşmesinin satım sözleşmesine dönük yüzünü oluşturmaktadır. Alım hakkı belirli bir zaman içinde bir şeyi önceden belirlenen şartlarla satın alarak mülkiyetini kazanma yetkisi vermektedir[34]. Alım hakkının vasiyet işlemi ile verilmesi de mümkündür.

Alım hakkı, en çok on yıl için kararlaştırılabilmektedir. Ayrıca TBK m. 238/I göndermesi suretiyle kanunda belirtilen süre olan on yıl için tapuya şerh edilebilmektedir.

Alım hakkı, bu hakkı kuran anlaşmada belirtilen süre içinde kullanılabilir. Alım sözleşmesinde süre ile sınırlama çok az görülen bir durumdur. Ancak, TMK m. 736 alım ve geri alım haklarını şerhte belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabileceğini, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona ereceğini düzenlemektedir. Alım hakkını kuran anlaşmada bir sınırlama yoksa alım hakkı kişilik hakkının ihlali sınırına kadar kullanılabilir. Alım hakkı yükümlüsünün satım sözleşmesini üçüncü kişi ile kurma yükümlülüğü bulunmamaktadır[35].

Alım hakkı kurucu yenilik doğuran hak olarak kabul edilmekte, bir tarafın kendi iradesi ile hukuki bir ilişki kurması veya bir hakkı kazanması yetkisi olarak tanımlanmaktadır[36].

Alım hakkı, satım sözleşmesine ilişkin ön sözleşmeden, hak sahibinin tek taraflı şekle tabi olmayan beyanının satım sözleşmesinin kurulması sonucunu doğurmak için yeterli olması nedeniyle ayrılır[37]. Alım sözleşmesi ön sözleşmeden farklı olarak ikinci bir sözleşmenin kurulması yükümlülüğü değil doğrudan doğruya şeyin devri yükümlülüğü doğurur. Amaçları bakımından yapılan değerlendirmede, alım hakkı kuran sözleşme ile satıma ilişkin ön sözleşme arasında benzerlikler bulunmaktadır. Her iki hukuki kurum da satım konusunun mül-

---

33 **Henrich**, 229; **Stüber**, 30; **Honsell**, 159; **Giger** (Grundstückkauf), Art.216, N.84; **Herzog**, 96; **Oğuzman/Seliçi**, 395; **Yavuz**, 189; **Ertaş**, N.1752, 351.

34 **Stüber**, 30-31.

35 **Larenz/Wolf** (1997), 465.

36 **von Tuhr/Peter**, 277; **Stüber**, 30 dn.19; **Serozan** (Özel), 163; **Ertaş**, N.1752, 351.

37 **Oser/Schönenberger**, Art.216 N.17; **Çenberci**, 21; **Oğuzman/Seliçi**, 294; **Öztürk** (I), 523; **Dalamanlı**, 3; **Eren**, 290; **Yavuz**, 188.

kiyetinin kazanılması şeklinde yansıyan gelecekte meydana gelen bir vakıa olarak teminat fonksiyonuna sahiptir. Bunların dışında alım sözleşmesi ön sözleşmeden farklı olarak asıl sözleşmedir[38]. Buna karşılık, noter tarafından düzenlenen alım sözleşmesi tahvil yoluyla ön sözleşme olarak kabul edilebilir[39].

Alım sözleşmesi resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz (TBK m. 237/II). Kanun şekli geçerlilik şekli olarak düzenlemektedir.

Geri alım hakkı doğuran sözleşme belirli bir şeyin satıcısına bunu istediği zaman alıcıdan geri satın alma yetkisi veren bir alım sözleşmesidir. Geri alım sözleşmesinin tarafları satım sözleşmesinin taraflarıdır. Bu iki sözleşmenin konusu aynıdır[41].

3. Sözleşmeden doğan önalım hakkı

a) Genel olarak

Türk Medeni Kanununun 732 ve 735 vd. maddelerinde taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları arasında kanundan doğan ve sözleşmeden doğan önalım hakları düzenlenmiştir. Bu hak mülkiyet hakkının kısıtlamalarından birini oluşturmaktadır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı Türk Medeni Kanunda tek bir maddede düzenlenmesine karşın, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yasal önalım hakkının kullanılmasına ve feragate ilişkin hükümlerin sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir (TMK m. 735/III).

Sözleşmeden doğan önalım hakkı TBK m. 237 vd. da ayrıca düzenlenmiştir. Böylece aynı konuyu düzenleyen iki ayrı hüküm mevzuatımızda yer almıştır. Esasen mehaz İsviçre Kanunlarında olduğu gibi kanundan doğan önalım hakkının Medeni Kanunda sözleşmeden doğan önalım hakkının ise Türk Borçlar Kanununda düzenlenmesi isabetli olurdu.

b. Kanundan doğan önalım hakkı

Kanuni önalım hakkı paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın paydaşlarından birinin payını üçüncü bir kişiye satması halinde aynı şartlarla

---

38 **Eren**, 290; bkz. **Stüber**, 35.

39 **Kocayusufpaşaoğlu**, 124; **Oğuzman/Seliçi**, 396; **Gürsoy/Eren/Cansel**, 521.

41 **Stüber**, 31.

bu payın alıcısı olabilme yetkisi veren yenilik doğuran bir haktır[42]. Payın tamamının satılması halinde yasal önalım hakkı kullanılabileceği gibi, payın kısmen satımı halinde de bu hak kullanılabilmektedir.

Taşınmaz mülkiyetinin konusu arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşmaktadır (TMK m. 704). Paylı mülkiyet ilişkisinin söz konusu olduğu arsa üzerindeki kat mülkiyetine tabi paya bağlı olan bir bağımsız bölümün üçüncü kişiye satımı, diğer kat maliklerine TMK m. 732'ye dayanarak yasal önalım hakkını kullanma imkânı vermez (KMK m. 8). Buna rağmen, kat mülkiyetine tâbi bağımsız bölümler sözleşmeden doğan önalım hakkının konusunu oluşturabilir.

Kanundan doğan önalım hakkı, kanundan kaynaklanan bir hak olduğu için tapuya şerh edilmesine gerek yoktur. Sözleşmeden doğan önalım hakkında tapuya şerh ile kazanılan eşyaya bağlı borç niteliği, kanuni önalım hakkında şerh edilmeksizin kanun gereği bulunmaktadır. Böylece taşınmaza kim malikse, hak ona karşı kullanılabilecektir[43].

Önalım hakkı birden fazla paydaş tarafından kullanılırsa, önalım hakkı, satış konusu pay üzerinde eşit oranlarda paydaşlara ait olur. Bu halin dışında önalım hakkı bölünemez[44].

Kanundan doğan önalım hakkının kullanılması için payın üçüncü kişiye satılması, hakkın süresinde kullanılması, hakkın dava yolu ile kullanılması ve haktan feragat edilmemiş olması gerekmektedir.

Kanundan doğan önalım hakkı ile sözleşmeden doğan önalım hakkı birlikte bulunduğunda kanuni önalım hakkına öncelik verilmektedir.

c. Sözleşmeden doğan önalım hakkının tanımı ve konusu

Önalım hakkı, taşınmaz malikinin taşınmazını üçüncü bir kişiye satması ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer bir işlem yapmış olması halinde önalım hakkı sahibine tek taraflı beyan ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisi veren yenilik doğuran bir haktır[45].

---

42 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 428-429.

43 **Yücel**, 24.

44 **Esener/Güven,** 245.

45 **Oğuzman/Seliçi/Oktay,** 416.

Taşınmaz mülkiyeti hem kanuni hem de sözleşmeden doğan önalım hakkının konusu olabilmektedir[46]. Taşınır mallarda kanuni önalım hakkının kullanılamayacağı kabul edilmiştir[47]. Ancak, uygulamada pek görülmemekle beraber taşınırların sözleşmeden doğan önalım hakkının konusu olabileceği doktrin tarafından kabul edilmektedir.

Önalım hakkına ilişkin sözleşme uygulamada, mal sahibinin malını o anda satmak istememesi, fakat ileride satmasının muhtemel olması halinde veya o şeyin istenmeyen bir kimsenin eline geçmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır[48]. Kanuni önalım hakkı ise birbirini tanıyan paydaşlar arasına yabancı bir kimsenin girmesini önlemek, müşterek mülkiyete konu olan taşınmazın daha küçük parçalara ayrılmasını engellemek[49], taşınmazın tamamına sahip olmayı isteyen bir paydaşa bu imkânı tanımak amacını taşımaktadır.

Doktrinde hâkim olan[50] yenilik doğuran hak teorisine göre, önalım, sahibine tek taraflı irade beyanıyla kendisi ile muhatap arasında bir satış sözleşmesi kurma yetkisi veren bir yenilik doğuran haktır. Bu görüş, hak sahibinin hakkını kullanması ile satış sözleşmesinin kurulduğunu kabul etmektedir. Gerek sözleşmeden doğan önalım hakkı gerekse kanundan doğan önalım hakkı, yenilik doğuran hak niteliğindedir. Bu hakkı kurucu yenilik doğuran hak olarak niteleyenler[51], hak sahibinin hakkını kullanmak suretiyle muhatap ile aralarında yeni bir hukuki ilişki doğmasına imkân verdiğini ileri sürmektedir.

Sözleşmeden doğan önalım hakkı, kişinin mülkiyet hakkına kendi iradesi ile getirdiği bir sınırlamadır. Sözleşmeden doğması nedeniyle niteliği itibariyle bir alacak hakkıdır[52]. Alacak hakkı, nispi hak olduğu için sadece sözleşmenin tarafları arasında hüküm ifade etmekte, üçüncü kişilere karşı ileri sürülememektedir. Bazı alacak haklarının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi şerh ile mümkün olmaktadır. Sözleşmeden doğan önalım hakkının da tapu kütüğüne şerhi mümkündür

---

46 **Tunaboylu**, 20; **Yıldız**, Ekrem, Önalım Davaları, İstanbul 2008, 19.

47 6. HD 21.04.1975 T. E. 1814 K. 2916. (**Tunaboylu**, 20).

48 **Esener/Güven**, 246.

49 İBK, 27.03.1957 T. 12/2.

50 Bkz. **Ertaş**, 378; **Esener/Güven**, 246; **Kılıçoğlu**, Mustafa, Akdi ve Kanuni Şuf'a Davaları, Ankara 2000, 18; **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 416.

51 **Oğuzman/Barlas**, Medeni Hukuk, İstanbul 2003, 108; **Feyzioğlu**, Şuf'a, 17; **Sebük**, 44.

52 **Oğuzman/Barlas**, 105.

(TMK. m. 1009; TBK m. 238/I). Şerhle birlikte bu hak o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hak sahiplerine karşı ileri sürülebilir hale gelir (TMK. m. 1009/2, TBK m. 242). Aksi takdirde sadece satıcıya karşı ileri sürülebilir (TBK m. 242).

Sözleşmeden doğan önalım hakkı yasal önalım hakkı gibi yenilik doğuran bir haktır[53]. Ancak bu hakkın kullanılması taşınmazın üçüncü kişiye satılması ya da satışa eşdeğer bir işlem yapılmış olması şartına bağlıdır. Taşınmazın üçüncü kişiye satılmasından sonra hak sahibi hakkını malike karşı ancak dava açarak kullanabilmektedir[54].

Yargıtay bir kararında taşınır mallarda önalım hakkının kullanılamayacağını açıklamıştır. Ancak karar incelendiğinde kastedilenin yasal önalım hakkı olduğu, sözleşmeden doğan önalım hakkına ilişkin olarak kararda bir açıklık olmadığı görülmektedir[55]. Doktrinde, uygulamada sık rastlanmasa da taşınırlar üzerinde sözleşmeden doğan önalım hakkının kurulabileceği kabul edilmektedir[56].

Önalım sözleşmesinin hak sahibine satış sözleşmesinin şartlarını belirlemesine göre basit önalım ve nitelikli önalım sözleşmeleri ayırımı yapılmaktadır. Buna göre, önalım sözleşmesinin satış sözleşmesine ilişkin özel hüküm öngörmemesi durumunda, hak sahibinin hakkını dava yolu ile kullanmasından sonra meydana gelen satış ilişkisi, önalım borçlusunun üçüncü kişi ile yaptığı satış sözleşmesinin aynısıdır. Bu şekilde meydana gelen önalım hakkı basit önalım hakkı olarak ifade edilmektedir. Önalım hakkı veren sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça hak sahibi taşınmazı satıcının üçüncü kişi ile kurduğu satış sözleşmesi koşulları ile kazanır (TBK m. 241/III).

Önalım anlaşması ile taraflarca özel kayıtlar kararlaştırılmışsa, örnek olarak bedel tayin edilmişse, önalım hakkı kullanılınca, muhatap ile önalım hakkı sahibi arasında bu kayıtlara uygun bir satış ilişkisi kurulur. Bu tarzdaki önalım hakkına nitelikli önalım hakkı denmekte-

---

53 **Ertaş**, 378.

54 **Oğuzman/Seliçi/Oktay,** 416.

55 **6. HD. 21.04.1975 T.1814/ 2916 (Tunaboylu, 20)** "Şuf'a hakkı, müşterek taşınmaz malda bir paydaşın, diğer paydaş tarafından üçüncü kişilere satılan payın, bedeli mukabilinde adına tescilinin istenebilmesidir, diğer bir deyimle şuf'a hakkı ancak taşınmaz mallardaki hisselerin satışında kullanılabilir. Taşınır mallarda şuf'a hakkının kullanılması düşünülemez".

56 **Sebük**, 44; **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 419; **Yücel**, 36, dn. 168'de adı geçen yazarlar.

dir. Nitelikli önalım hakkında hak sahibi, üçüncü kişi ile yapılan sözleşmede kararlaştırılan bedelin miktarına bakılmaksızın, önalım sözleşmesinde kararlaştırılan bedeli ödeme borcu altındadır.

Önalım hakkı taraflarca en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilmektedir (TBK m. 238/I).

d) Şekli

Türk Borçlar Kanununda sözleşmeden doğan önalım hakkı yazılı şekle tabidir (TBK. m. 237/III). Bu düzenlemenin sebebi önalım anlaşmasının çoğunlukla kira sözleşmelerine konulan bir kayıt şeklinde görülmesidir. Kanun taraflara bu hususta kolaylık sağlamak istemiştir[57]. Yazılı şekil şartı geçerlilik şartıdır. Önalım sözleşmesinin tapuya şerh edilebilmesi için yazılı şekilde yapılmış olması yeterlidir, ayrıca resmi şekil şartı aranmaz.

e. Hakkın şerhi

Sözleşmeden doğan önalım hakkı nispi haklardandır. Önalım hakkı sahibi bu hakkını sadece sözleşme yaptığı karşı tarafa karşı ileri sürebilmektedir. Önalım konusu üzerindeki mülkiyet hakkının üçüncü kişiye devredilmesi durumunda hak sahibi hakkını ona karşı ileri sürememektedir. Hak sahibi sadece önalım yükümlüsünden sözleşmeye aykırılıktan dolayı meydana gelen zararların tazminini talep edebilmektedir. Kanun hak sahibinin hakkını taşınmazın sonraki maliklerine ve o taşınmazda şerhten sonra hak kazanan kişilere karşı ileri sürebilmesi amacıyla bazı nispi hakların tapuya şerhini öngörmektedir. Sözleşmeden doğan önalım hakkı da kanun tarafından şerhi öngörülen haklardandır (TMK. m. 735, 1009, TBK m. 242).

Doktrinde şerh edilebilir kişisel hakların etkisine ilişkin iki görüş mevcuttur. İlk görüş[58] şerhin iki etkisinin olduğunu kabul etmektedir. Kişisel hakkın kullanılmasıyla bir borç ilişkisi doğacaksa şerh, kişisel hakla ilgili borç ilişkisini eşyaya bağlı borç haline getirmektedir. Eşyaya bağlı borç ilişkisinde kişisel haktan doğan yükümlülük taşınmazın mülkiyetine bağlanmaktadır. Böylece, taşınmazın her maliki şerhten sonra, kendi mülkiyeti esnasında kendisine karşı kullanılacak hakkın içerdiği borçla yükümlü olacaktır. Şerhten sonra taşınmaz üzerinde üçüncü kişiler tarafından kazanılan hakların, şerh edilmiş hakkın

---

[57] **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 416–417.

[58] **Oğuzman/Seliçi/ Oktay**, 203–204; **Yücel**, 42, dn. 198'de adı geçen yazarlar.

kullanılmasını zorlaştırması durumunda, şerhin munzam etkisi sonucu bu hakların kullanılamamasını sağlanmaktadır. Her iki etki bakımından şerh kurucu nitelik taşır[59].

Sözleşmeden doğan önalım hakkı tapu siciline şerh verilmemişse, hak, yalnız önalım sözleşmesinin tarafı olan malike ve onun külli haleflerine karşı kullanılabilmektedir. Ancak hakkın şerh edilmesiyle, davanın hakkın kullanılacağı esnada taşınmaza malik olan kişiye karşı açılması imkânı doğmaktadır. Böylelikle hakkın kullanılıp satış ilişkisinin doğmasından sonra taşınmazın malikinin değişmesi durumunda, önalım hakkı sahibi şerhin etkisi ile taşınmazın mülkiyetini yeni malikten devralma imkânına sahip olmaktadır.

Kişisel hakların şerhinin etkisi üzerine ileri sürülen ikinci görüş[60], şerh edilen haktan doğan talebin ayni etki kazanacağı yönündedir. Buna göre, taraflar arasında doğan borç ilişkisi yine taraflar arasında kalmakta, ancak borç ilişkisinden doğan talep şerhin etkisiyle ayni nitelik kazanmaktadır. Borç ilişkisine ilişkin taleplerin ayni nitelik kazanması sonucunda, bu talepler hem borçluya hem de taşınmazı sonradan kazanan malike karşı ileri sürülebilmektedir.

Şerhin etkisi, verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle düşer (TMK m. 735/2, TBK m. 238). Başka bir deyişle, sözleşmeden doğan önalım hakkı şerhin verildiği tarihten itibaren azami on yıl için üçüncü kişilere karşı etkilidir. Bu sürenin dolmasından sonra şerh kendiliğinden düşeceğinden sonraki maliklere karşı ileri sürülemeyecektir.

Önalım hakkının kullanılması için satışın bildirilmesinden itibaren iki yıl içinde kullanılmasına ilişkin süre şerh süresince yapılacak diğer satışlar için yeniden başlatılır.

Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhedilmiş olması halinde, satış hak sahibine bildirilmeden taşınmazın satın alan tarafından diğer bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde, önalım hakkı bu kişiye karşı da ileri sürülebilir. Bu kişinin taşınmazı satış dışında örneğin bağışlama sebebiyle kazanması önem taşımaz. Zira TMK m. 1009/II kazanma sebebine önem vermeksizin sonradan hak kazanan kişilere şerhin etkisinin cari olacağını kabul etmektedir. Buna karşılık, kanuni önalım hakkının kullanılmasında tapu kütüğünde şerh bulunmayacağından,

---

[59] **Oğuzman/Seliçi/ Oktay**, 203–204.

[60] **Esener/Güven**, 98; **Gümüş**, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara 2003, 110 vd.

önalım hakkının dava yoluyla kullanılması halinde mahkemeden tedbir kararı talep etmek gerekir. Bu tür durumlarda tedbir kararı alınmaz ve tapu kütüğüne işletilmezse, bu zaman diliminde taşınmazı satın alanın diğer üçüncü kişilerle yaptığı satış ve bağışlama sözleşmeleri sonucu mülkiyet iktisabına karşı önalım hakkı ileri sürülemez.

f) Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılmasının koşulları

aa) Satış sözleşmesinin ya da satışa eşdeğer bir işlemin yapılmış olması

Önalım hakkının kullanılabilmesi için üzerinde hak kurulan taşınmaz sahibi ile bir üçüncü kişi arasında satış sözleşmesinin kurulması ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer bir işlemin yapılması gereklidir (TBK m. 240/I, 242). Bağışlama, trampa veya bir şirkete sermaye olarak koyulan taşınmazın devri halinde önalım hakkı kullanılamaz[61]. Taşınmaza ilişkin gayrimenkul yatırım ortaklığına ait tüm hisselerin devri halinde ise önalım hakkı kullanılabilir. Taşınmaz üzerinde üst hakkı kurulması da ekonomik bakımdan satışa benzer işlemlerden sayılabilir. Önalım hakkının kullanılmasını önlemek için tarafların satışı tapuya bağış olarak tescil ettirmeleri halinde muvazaa iddiası ileri sürülebilir. İcra ve İflas Kanununa göre yapılan cebri icralarda da önalım hakkı kullanılamaz[62]. Buna karşılık ihtiyari açık artırmalarda önalım hakkı kullanılabilir[63]. Yargıtay, satış vaadi yapılmasının, kesin satışı meydana getirmeyeceği gerekçesiyle önalım hakkının kullanılabilmesi için yeterli sayılmayacağını kabul etmiştir[64].

Taşınmazın miras paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmiş olması, cebri artırma yoluyla satış veya kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ya da bunlara benzer amaçlarla edinilmesi halinde önalım hakkı kullanılamaz (TBK m. 240/II).

bb) Satış işleminin ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemin gerçekleştiğinin önalım hakkı sahibine bildirilmesi

Önalım hakkının kullanılabilmesi için satış sözleşmesinin gerçekleştiğinin alıcı veya satıcı tarafından önalım hakkı sahibine noter ara-

---

61 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 417; İntifa ve sükna hakları mülkiyetin nakline yol açmadığından önalım hakkının kullanılmasına imkân vermezler (**Erkan**, 274 ve dn. 8 deki yazarlar).

62 İBK, 04.05.1940 T. 57/17.

63 **Esener/Güven**, 247; **Ertaş**, 378.

64 1. HD. 5.5.1951. E. 7860, K. 2429 (**Esener/Güven** dn. 249).

cılığıyla bildirilmesi gerekmektedir (TMK. m. 733/III, TBK m. 241/I). Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin yapılması halinde de işlemin yapıldığının ve içeriğinin önalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirilmesi zorunludur. Bu husus TBK m. 242 hükmünden anlaşılmaktadır.

Bildirmenin bizzat satıcı veya alıcı tarafından noter aracılığıyla yapılması gerekir (TBK m. 241/I). Aksi halde bildirim geçersiz olacaktır. Önalım hakkını kullanıp kullanmamaya karar verme yetkisi önalım hakkı sahibine ait olduğuna göre satımın önalım hakkı sahibine bildirilmesi gerekir. Bu bildirimle satış konusu, satış bedeli, satış tarihi, ödeme koşulları, alıcı gibi esaslı unsurlarının önalım hakkı sahibi tarafından öğrenilmesi sağlanmalıdır.

Satıcının ve alıcının satımın yapıldığını önalım hakkı sahibine bildirmesi, satışın hak sahibince öğrenilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte hakkın kullanılması için gereken üç aylık hak düşürücü süre bildirim tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Önalım hakkı sahibinin satışı başka yollardan öğrenmiş olması bu sürenin işlemesine neden olmaz[65].

Önalım hakkı sahibi satış işleminden uzun süre sonra haberdar olmuş ve bu hakkını kullanmış ise davalı alıcı, taşınmazın dava tarihindeki gerçek değeri üzerinden ödeme yapılmasını talep edebilir.

Taşınmazın ilk maliki önalım hakkının kullanılması üzerine kendisi ile üçüncü kişi arasındaki satış sözleşmesinde bedelde muvazaa yapıldığını ileri süremez. Zira, taraflar arasında yapılan muvazaa bu taraflarca ileri sürülemez. Buna karşılık, önalım hakkı sahibi, taraflar arasında bedelde muvazaa yapılarak tapuda satış bedelinin gerçek değerin üzerinde gösterildiğini iddia ve ispat edebilir. Bu takdirde gerçek değer üzerinden önalım hakkı kullanılmış olur.

cc) Önalım hakkının süresinde kullanılmış olması

Önalım hakkının kanunda öngörülen sonuçları sağlayabilmesi için zamanında kullanılmış olması gerekir. Önalım hakkı, bu hakkı doğuran sözleşmede kararlaştırılan süre kadar varlığını devam ettirir. Eğer bu süre içerisinde önalım hakkına konu olan taşınmaz satılıp hakkın kullanılması imkânı doğmazsa, önalım hakkı düşer[66].

---

[65] **Oğuzman/Seliçi/Oktay,** 422.

[66] **Oğuzman/Seliçi/Oktay,** 421–422.

Önalım hakkının kullanılması iki farklı süreye tâbidir (TMK. m. 733/IV, TBK m. 242). Bu sürelerden ilki hakkın kullanılması gereken asgari süre, diğeri ise azami süredir. Asgari süre, satışın yada ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemin hak sahibine bildirilmesinden itibaren üç aydır. Noter aracılığıyla yapılacak bildirimin önalım hakkı sahibine tebliğini izleyen günden itibaren bu süre işlemeye başlamaktadır. Azami süre ise satışın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır (TBK m. 242). Kanunun yasal önalım hakkı için öngördüğü süreler TBK m. 242'de aynı şekilde yeniden düzenlenmiştir. Şerh edilmiş önalım sözleşmesinde hak, şerhte belirtilen süre içinde her malike karşı en çok on yıllık süre için kullanılmaktadır (TMK. m. 735/I, TBK m. 238). Önalım hakkının kullanılması için öngörülen bu süreler hak düşürücü niteliktedir[67]. Önalım hakkı sahibinin hakkının sadece o satış için mi düşeceği veya hakkın tamamen mi ortadan kalkacağı da tartışılmaktadır. Bir görüş[68] önalım sözleşmesinin yorumu yoluyla değerlendirme yapılması gerektiğini ve esas olarak hakkın sadece ilk satışta kullanılabileceğini kabul etmektedir. Diğer görüş[69] ise önalım hakkının sonraki satışlarda da kullanılabileceğini savunmaktadır.

dd) Önalım hakkından feragat edilmemiş olması

Önalım hakkının kullanılabilmesi için gereken şartlardan biri de hak sahibinin önalım hakkından veya hakkın kullanılmasından vazgeçme yönünde iradesinin bulunmamasıdır. Türk Medenin Kanununda kanuni önalım hakkı için düzenlenen feragat (TMK. m 733/II), kanundaki atıf nedeniyle sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanmaktadır (TMK. m. 735/III). Feragat kök hakkı etkileyip etkilememesi yönünden mutlak ve nispi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mutlak feragat önalım hakkının kendisinden vazgeçme halinde bulunmaktadır. Hak sahibi mutlak feragatte sadece bir satışa veya kişiye karşı değil, herkese karşı ve sürekli olarak hakkından vazgeçmektedir[70]. Mutlak feragat, henüz doğmamış bütün önalım olaylarına ilişkin

---

67 **Ertaş**, 380; **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 422; Zira, yenilik doğuran haklar zamanaşımı süresine değil hak düşürücü süreye tabidir (Erkan, 278 ve dn. 20'deki yazarlar).

68 **Ertaş**, 381; **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 422.

69 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 422, dn. 1016'da adı geçen yazarlar.

70 **Yücel**, 81.

olmakta ve feragat edenin bütün külli ve cüz'i haleflerini de bağlamaktadır[71].

Sözleşmeden doğan önalım hakkında, kanuni önalım hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler uygulanır (TMK. m. 735/III). Kanuni önalım hakkından feragat mülkiyetin kanuni takyitleri kapsamına girer, bunun için resmi şekil ve tapu kütüğüne şerh aranır (TMK. m. 733/II). Resmi şekli kural olarak noter yerine getirir.

Kanuni önalım hakkından feragate yönelik sözleşmeler şerh edilmekle, sadece taşınmaza malik olan kişiye değil, sonraki maliklere ve sınırlı ayni hak sahiplerine karsı ileri sürülebilmektedir (TMK m. 1009/II).

Nispi feragat, hak sahibinin önalım hakkını kullanmaktan belli bir satış veya kişiye bağlı olmak üzere vazgeçmesidir[72]. Bununla önalım hakkı sahibi daha sonra yapılacak olan satışlar için hakkını sona erdirmeyip, hakkını kullanmayı saklı tutmaktadır[73]. Önalım hakkının kullanılmasından feragat satıştan önce veya sonra yapılabilmektedir (TMK. m. 733/II). Nispi feragatin adi yazılı şekilde gerçekleştirilmesi yeterlidir. Kanuni önalım hakkının kullanılmasından feragate ilişkin düzenlemeler kanundaki atıf nedeniyle sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır (TMK. m. 735/III).

ee) Önalım hakkının dava yolu ile kullanılması

Sözleşmeden doğan önalım hakkı malike karşı dava açarak kullanabilir (TMK. m. 734/II, TBK m. 242). 743 sayılı mülga Medeni Kanunda yer almayan bu hükmün getirilmesinin gerekçesi uygulamada önalım hakkının kullanılmasının sürekli olarak bir davaya dönüşüyor olmasıdır. Kanun koyucu önalım hakkına ilişkin beyanla istenilen sonucun ancak dava yolu ile elde edilebileceğini göz önünde tutmak suretiyle böyle bir düzenleme yapma yoluna gitmiştir[74].

Önalım davası, Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu tarafından öngörülen yenilik doğuran bir davadır (TMK m. 734/I, TBK m. 242). Önalım hakkı sahibi davacı ile alıcı veya taşınmaz maliki davalı arasında satış ilişkisinin kurulmasını sağlamaktadır. Satış ilişkisi,

---

[71] **Ertaş**, 388.

[72] Y.6.HD 24.10.1983 T. ve E. 9973 / K. 10158 (YKD, Cilt: 10, Sayı: 4, 1984).

[73] **Yücel**, 86.

[74] **Ertaş**, 381–382.

önalım hakkının kullanılması beyanını içeren dava dilekçesinin davalıya ulaştığı anda kurulmaktadır[75].

Sözleşmeden doğan önalım hakkında ise davada taraf sıfatının belirlenebilmesi için hakkın tapuya şerh edilmiş ve sonra mülkiyetin alıcı adına tescil edilmiş olup olmamasına göre ayırım yapılmaktadır. Önalım hakkı tapuya şerh edilmiş ve alıcı adına tescil yapılmışsa, davalı sıfatı alıcıda olmalıdır (TBK m. 242). Aksi takdirde davanın tapu sicilinde malik görünen kimseye, yani satıcıya karşı genel hükümlere göre tazminat davası açılması gerekmektedir (TBK m. 242).

g) Önalım hakkının satış sözleşmesinin sona ermesi halinde ileri sürülememesi, devri, mirasla intikali ve sona ermesi

Önalım hakkı kullanıldıktan sonra, satış sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bu durum önalım hakkını sahibine karşı ileri sürülemez (TBK m. 241/II). Söz konusu sözleşmenin ikale anlaşması ile veya sözleşmeden dönme gibi bir sebeple ortadan kalkması bu kapsamda değerlendirilir. Buna karşılık, satış baştan itibaren geçersiz ise önalım hakkı kullanılamaz. Benzer şekilde, yapılan satış sözleşmesi alıcının şahsından kaynaklanan sebeplerle onaylanmaz ise bu durum yine önalım hakkı sahibine karşı ileri sürülememektedir (TBK m. 241/II). Bu madde hükmü ile sınırlı ehliyetsiz küçük ve kısıtlıların yaptıkları satış işlemlerine kanuni temsilcilerinin rıza vermemeleri hali düzenlenmiştir.

Önalım hakkı aksi kararlaştırılmadıkça başka bir kişiye devredilemez (TBK m. 239). Bu husus, söz konusu hakkın kural olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı olması ile ilgilidir. Önalım hakkının verildiği sözleşmede, hak sahibi olacak kişinin kimliği önem arzetmektedir. Alım ve geri alım hakları da kural olarak başka bir kişiye devredilemez. Ancak, sözleşme ile aksi kararlaştırılabilir.

Önalım, alım ve geri alım hakkının üçüncü kişiye devrinin sözleşmeyle kararlaştırılması mümkündür. Bu takdirde devre ilişkin sözleşmenin asıl sözleşme konusunun tabi olduğu şekilde yapılması geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür (TBK m. 238/II). O halde, bir taşınmaz üzerinde sözleşmesel önalım hakkı verilecek ve bu hak başka kişiye devredilebilecekse devre izin veren sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekecektir.

---

[75] **Yücel**, 96.

Mahkemenin önalım davasının kabulüne ilişkin verdiği karar yenilik doğuran bir karardır. Bu kararla yenilik doğuran bir etki yaratılmış olur. Yenilik doğuran etki mahkeme kararının uygulanmasına gerek olmaksızın, kendiliğinden doğmaktadır[76].

Önalım davasının sonunda alınan karar taşınmazın mülkiyetinin hak sahibi adına tescilinin yapılmasına yöneliktir. Kararın kesinleşmesi ile taşınmazın mülkiyeti önalım hakkı sahibine geçmektedir[77]. Hak sahibi bu karara dayanarak taşınmazın mülkiyetinin tescilinin adına yapılmasını talep edebilir. Yapılacak tescil açıklayıcı niteliktedir[78].

Önalım davasında istenilen sonucun yaratılması, davacı hak sahibinin önalım bedelini ve karşı tarafın giderlerini karşılamasına bağlanmaktadır. Önalım hakkı sahibi hâkimin belirleyeceği süre içinde mahkeme veznesine, satım bedelini ve alıcıya düşen tapu giderlerini nakden yatırmak zorundadır (TMK. m. 734/2). Buna uygulamada depo kararı denmektedir. Depo kararının yerine getirilmesinde, nakit dışında teminat mektubu gibi bir güvencenin verilmesi yeterli değildir[79].

Önalım hakkı, sahibinin veya muhatabının ölümü ile, hak sahibi ile muhatap sıfatının birleşmesi ile, haktan feragat edilmesi ile ve hakkın kullanılma sürelerinin geçirilmesi ile sona erer. Hakkın konusunun yok olması ile de önalım hakkı kullanılamaz.

4. Geri alım (vefa) sözleşmesi

a) Tanım ve konusu

Geri alım hakkı, daha önceden satılmış olan hak konusunun tek taraflı irade beyanıyla geri alınabilmesini sağlayan yenilik doğuran bir haktır[80]. Geri alım anlaşması ile taşınmazını elden çıkarmak zorunda kalan kimseye daha sonra malını geri alma imkânı sağlanır.

Geri alım anlaşmasının zaman zaman borç verilen paraya teminat teşkil etmek amacıyla da kurulduğu görülmektedir[81]. Bu durumda taşınmaz üzerinde alacaklı lehine ipotek tesis etmek yerine aynı kişi ile satış ve geri alım anlaşması yapılmaktadır. Borcun ödenmesi halinde

---

76 **Kuru/Arslan/Yılmaz,** Medeni Usul Hukuku, Ankara 2005, 327.

77 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 418.

78 **Yücel**,

79 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 418.

80 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 414.

81 **Oğuzman/Seliçi/Oktay**, 415.

taşınmaz geri alım anlaşması ile malikin mülkiyetine dönmektedir. Ancak borcun ödenmemesi halinde taşınmaz mülkiyeti alacaklıda kalmaktadır. Bu durum TBK m. 873/II ile düzenlenmiş bulunan lex commissaria yasağının dolanılması anlamına gelmektedir. Söz konusu hükme göre borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçmesine ilişkin olarak yapılan sözleşme geçersizdir. Rehin karşılığı ödünç verme işi ile uğraşanların geri alma hakkı kurarak taşınmaz satın almaları halinde, taşınır rehni karşılığında ödünç verenlere ilişkin hükümler uygulanır (TMK m. 969). TMK m. 965'e yapılan bu atıf nedeniyle borcun vadesinde ödenmemesi halinde ödünç verenin borçluya önceden noter aracılığı ile borcun ödenmesini ihtar etmesi gerekmektedir. İhtarın semeresiz kalması halinde satışa ve geri almaya konu edilen taşınmaz icra yoluyla satılarak paraya çevrilmelidir. Satış bedelinin alacak miktarından fazla olması halinde artık miktar hak sahibine ödenmelidir (TBK m. 966/I).

Taşınmaz üzerinde kurulan geri alım sözleşmesinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Taşınmaz satış vaadinin şekline ilişkin kurallar geri alım hakkında da uygulanmaktadır. Kanun, önalım hakkının kullanılması için aradığı üç aylık ve iki yıllık hak düşürücü süreleri geri alım hakkı için aramamıştır.

Geri alım hakkında bedelin sözleşme ile belirlenmesi, zorunlu unsur değildir. Bedelin belirlenmemesi durumunda ilk satımdaki fiyat geri alım bedeli olarak esas alınmaktadır[82]. Tapu siciline şerh verilen geri alım hakkı önalım hakkıyla aynı hükümlere tâbi tutulmaktadır. Medeni Kanun'da her iki hak için şerhin etkisi on yıl olarak düzenlenmiştir (TMK. m. 735, 736, TBK m. 238/I). Bununla birlikte, önalım hakkının kullanılabilmesi için aranan hak sahibinin alıcıya karşı dava açma şartı geri alım hakkı için söz konusu değildir.

TBK 237/II. maddesine göre geri alım sözleşmesinin resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Şekil eksikliği sözleşmeyi geçersiz kılar.

Hukukumuzda resmi senet düzenleme yetkisi kural olarak noterlere tanınmıştır (Noterlik Kanunun m. 60). Bunun yanında ayni haklarla ilgili resmi senetleri düzenleme yetkisi münhasıran tapu müdürlükleri tarafından da yapılmaktadır. Taşınmaz mülkiyetini nakletme borcu doğuran sözleşmeleri düzenleme yetkisine sahip olan tapu müdürlük-

---

[82] **Sebük**, 27; **Feyzioğlu**, Feyzi N., Şuf'a Hakkı, İstanbul 1959, 24.

leri geri alım sözleşmesini düzenlemeye evleviyetle yetkilidir[83]. Şu halde hukukumuzda gayrimenkullere ilişkin resmi senetleri düzenleme yetkileri noter ve tapu sicili müdürlüklerine aittir.

b) Şerhi

Bir hakkın tapuya şerh verilebilmesi için bu hakkın kanunda açıkça belirtilmiş olması gerekir. Medeni Kanunun 1009. maddesi tapu kütüğüne şerh verilecek şahsi haklar arasında geri alım (geri alım) hakkını da saymaktadır. Önalım ve alım sözleşmelerinde şerhe ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar geri alım hakkı için de geçerlidir:

Geri alım hakkı kullanılmakla geri alım borçlusunun taşınmazın mülkiyetini geri alım alacaklısına devir borcunu içermektedir. Dava dışı kullanma iradesi borçlunun edimini yerine getirme olanağı sağlamazsa cebri tescil davasının açılması ve tapu kaydının düzeltilmesi davacı tarafından istenebilecektir[84].

Dava açılması halinde davacı sözleşmede alacaklı durumunda olan gerçek veya tüzel kişi olurken husumet sözleşmede borçlu olan ve adına tapu kaydı bulunan kişi olacaktır. Tapu kaydına şerh verilmesi halinde sözleşmenin borçlusu olmayan ve fakat geri alım hakkı konusu taşınmazı adına tapuda kayıtlı bulunduran kişiye karşı da dava açılabilecektir. Bu dava tapu kaydının iptali ve davacı adına tescili istemini kapsayacaktır. Ancak davanın açılabilmesi için verilecek uygun süre zarfında belirlenen yere bedelin depo edilmesi gerekir. Bedelin depo edilmemesi halinde ise davanın reddi gerekmektedir[85].

Geri alım hakkının kullanılmasıyla birlikte sadece geri alım hakkını kullanan kişinin değil muhatabın da hukuki durumunda değişiklik meydana gelmektedir. Geri alım hakkının kullanılmasıyla birlikte muhatap geri alım konusu malın satıcısı olmakta, böylece haklar ve borçlar edinmektedir. Geri alım hakkının kullanılmasından sonra bundan geri dönülmesi, muhatabın söz konusu hukuki durumunu da etkileyecektir. Bu sebeple, geri alım hakkı sahibi, bu hakkını kullandıktan sonra tek taraflı olarak bundan geri dönemez. Ancak bunun yerine, taraflar yapacakları bir ikale anlaşması ile geri alım hakkının kullanılmasından doğan satıy ilişkisini sona erdirebilirler.

---

[83] **Karahasan** Mustafa Reşit, **Özmen** İhsan, Türk Medeni Kanunu, Eşya Hukuku, 2. Cilt, Ankara 1988, 1769, 6. HD. 29.11.1952, 985/3045.

[84] **Turanboylu**, sh 694.

[85] **Turanboylu**, 695.

c. Geri alım hakkının kullanılmasının sonuçları

Geri alım hakkının kullanılmasıyla birlikte geri alım hakkını kullanan kimse ile muhatap arasında satış ilişkisi doğar. Bu ilişkide geri alım hakkını kullanan kimse alıcı, muhatap ise satıcı tarafı teşkil eder.

Geri alım hakkının kullanılmasından doğan satış ilişkisine Borçlar Kanununun satıma ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Geri alım hakkının devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi TBK m. 239'da düzenlenmiştir. Önalım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesine ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar geri alım hakkı için de geçerlidir.

§ 13. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

I. Örnek üzerine satış

Bu sözleşme tarafların, teslim edilecek malın alıcıya veya üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe yahut tesbit ettikleri bir mala uygun olması üzerinde anlaştıkları bir satışdır.

Örnek üzerine satış şarta bağlı bir satış değildir; sadece, satıcı, satılanın örneğin vasıflarına uygun olduğunu vaad ve tekeffül etmektedir.

TBK m. 248 örneğin gerçek olup olmadığı ve yapılan devrin örneğe uygunluğu bakımlarından isbat yükünün kime düşeceğini düzenlemektedir.

Karşılaştırmanın yapılacağı örneğin kararlaştırılan (gerçek) örnek olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık çıkarsa, örneğin bırakıldığı şahsın sözüne itibar edilir; aksini iddia eden, iddiasını isbatla yükümlüdür. Örnek onu saklayanın elinde, normal bir muayenenin sonucu olarak değişmiş olsa bile aynı sonuç geçerlidir; saklayanın sözü karine olarak doğru sayılır (TBK m. 248/I).

Teslim edilen malın örneğe uygunluğunu satıcı isbat etmek zorundadır. Buna karşılık örnek, alıcının elinde, kusuru olsun veya olmasın bozulmuş veya yok olmuşsa, malın örneğe uygun olmadığını alıcı isbatla yükümlüdür (TBK m. 248/II). Şayet örnek normal bir muayenenin sonucu olarak alıcının elinde bozulmuş ise, satılan şeyin örneğe uygunluğunu isbat satıcıya düşer.

II. Beğenme koşuluyla satış

1. Tanımı

Beğenme koşuluyla satış, alıcının satılanı deneyerek veya gözden geçirerek beğenmesi koşuluyla yapılan satıştır (TBK m. 249). Alıcının satılanı beğenmesi (tasvibi) iradî geciktirici şarttır[1].

2. Hükümleri

Beğenme koşulu ile satışta alıcı, satılanı kabul etmekte veya hiçbir sebep göstermemeksizin geri vermekte serbesttir (TBK m. 250/I). Satılan, alıcının zilyetliğine geçmiş olsa bile, satılanın mülkiyeti, beğenme koşulunun gerçekleştiği ana kadar satıcıda kalır (TBK m. 250/II).

---

[1] **Honsell**, sh. 161; **Keller/Siehr**, sh. 140; **Cavin**, sh. 155; **Tercier**, N. 848; **Tandoğan** I/1, sh. 296.

3. Deneme veya gözden geçirme

Alıcının satılanı beğenip beğenmeme konusunda uzun süre karar vermeksizin tereddüt içinde kalması doğru olmayacaktır. Kanun koyucu bu belirsizliği gidermek amacıyla, beğenme şartının gerçekleşmiş sayılıp sayılmayacağı konusunda kurallar (TBK m. 251-252) koymuştur. Bu hükümler iki hali birbirinden ayırmaktadır:

a. Deneme ve gözden geçirmenin satıcı yanında yapılması

Alıcı sözleşme veya adete göre belirlenen süre içinde satılanı beğendiğini bildirmezse, satıcı serbest olur (TBK m. 251/I). Böyle bir süre bulunmadığı takdirde, satıcı uygun bir süre geçtikten sonra kabul veya red beyanında bulunmasını alıcıya ihbar edebilir; alıcı derhal beyanda bulunmazsa, satıcı yine serbest kalır (TBK m. 251/II).

b. Deneme ve gözden geçirmenin alıcı yanında yapılması

Satılan, denenmeksizin veya gözden geçirilmeksizin alıcıya verilmişse, sözleşme veya adete göre gereken süre içerisinde veya böyle bir süre yoksa, satıcının ihtarı üzerine alıcı, satılanı beğenmediğini hemen bildirmez veya onu geri vermezse, beğenme koşulu gerçekleşmiş olur (TBK m. 252/I).

Alıcının, herhangi bir çekişme belirtmeksizin satış bedelinin tamamını veya bir kısmını ödemesi ile ya da satılanı deneme veya gözden geçirme amacını aşacak biçimde kullanmasıyla da beğenme koşulu gerçekleşmiş olur (TBK m. 252/II).

III. Kısmi Ödemeli satışlar

1. Taksitle Satışlar

a. Tanımı

Taksitle satışlar, TBK m. 253/I'de tanımlanmıştır. Taksitle satış veresiye satışın (kısmi ödemeli satışın) bir çeşididir. Buna göre, taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır. Taksitle satışta genellikle ekonomik sebeplerle peşin para ile işlem yapmak yerine taksitli işlem tercih edildiğinden özel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. TKHK m. 17'e göre, taksitle satış sözleşmesi tüketicinin satış bedelini kısım kısım ödediği sözleşmedir. Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının ise bedel tamamen ödendikten sonra satılanı tüketiciye

teslim etmeyi üstlendiği ödeme süresi bir yıldan uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanmaktadır (TKHK m. 21/1). Söz konusu şartları taşımayan ve bir tüketici ile yapılan taksitle satış sözleşmesi ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulama kapsamında kalmaktadır.

Taksitle satış sözleşmelerin zorunlu içeriği, tüketicinin, satıcının ve sağlayacağının hak ve yükümlülükleri ile cayma hakkı, erken ödeme ve diğer hususlar Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir[2].

b. Taksitle satış sözleşmesinin kurulması (şekli ve içeriği)

TBK m. 253/II'ye göre, "taksitle satış sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz". Aynı hüküm TKHK m. 17/3'te düzenleme konusu yapılmıştır. Ancak geçerli sözleşme yapmayan satıcı veya sağlayıcı daha sonra sözleşmenin geçersiz olduğunu tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Taksitle satılan malın, satıcının ticari faaliyeti kapsamında satılması halinde, sözleşmede yer alması gereken hususlar, TBK m. 253/III'de on bir bend halinde belirtilmiştir:

- Tarafların adı ve yerleşim yeri;
- Satışın konusu;
- Satılanın peşin satış bedeli;
- Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilave bedel;
- Toplam satış bedeli;
- Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler;
- Peşinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere taksit sayısı;
- Alıcının yedi gün içerisinde sözleşme yapma konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı;
- Öngörülmüşse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satış bedeli alacağın devrine ilişkin anlaşma kayıtları;
- Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının %30 fazlasını geçmemek üzere ödenecek faiz;
- Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.

Bu hususlar da ayrıca yazılı şeklin kapsamına girer.

---

[2] RG 14.01.2015 tarih ve 29236 sayı. Kredi kartı ile yapılan satışlara bu yönetmelik uygulanmamaktadır (m. 2/4).

Ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı tarafından yapılmış olan taksitle satış sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlıdır. Bu durumda rızanın, en geç sözleşmenin kurulduğu anda verilmiş olması gerekir (TBK m. 254).

c. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması (TBK m. 255)

Taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alıcı, bu süre içerisinde irade açıklamasını geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterlidir (TBK m. 255/I). TKHK m. 18'e göre de tüketici yedi gün içinde gerekçe göstermeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Satıcı geri alma süresi içerisinde malı alıcıya devretmişse alıcı, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde sözleşme hüküm ve sonuçlarını doğurmuş olur (TBK m. 255/II; TKHK m. 18/3).

Alıcının geri alma hakkını kullanması halinde, kendisinden cayma parası istenemez (TBK m. 255/III). Tüketicinin cayma hakkını kullandığı hallerde cezai şart kararlaştırılmış olsa bile ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır (m. 18/3).

Geri alma beyanı yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır. Bu hak, satıcının etkileyici davranışına karşı alıcıyı korumak için getirilmiştir[3].

d. Tarafların hak ve borçları

aa. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi

Alıcı, peşin satış bedelinin en az onda birini en geç teslim anında peşin olarak, satış bedelinin geri kalan kısmını da sözleşmenin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle yükümlüdür (TBK m. 256/I).

Bakanlar Kurulu, satılanın türüne göre peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini yarıya kadar indirebileceği gibi, iki katına kadar çıkartabilir (TBK m. 256/II).

---

[3] **Engel**, s. 74

Kanunda belirlenen asgari peşinatı tamamen almaksızın, satılanı alıcıya devreden satıcı, peşinatın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder (TBK m. 256/III).

Peşinattan vazgeçilmesi karşılığında, satış bedelinde yapılacak artırma hükümsüzdür (TBK m. 256/IV).

bb. Alıcının def'ileri

Alıcı, satıcının taksitle satıştan doğan alacağı ile kendisinin satıcıdan olan alacağını takas etme hakkından önceden feragat edemez (TBK m. 257/I).

Alacağın devredilmesi durumunda alıcının, satış bedeli alacağına ilişkin def'ileri sınırlanamaz ve ortadan kaldırılamaz (TBK m. 257/II).

cc. Satış bedelinin tamamen ödenmesi

TBK m. 258'e göre, Taksit borcu kambiyo senedine bağlanmış olmadıkça, alıcı satış bedelinin kalan kısmını her zaman bir defada ödeyerek borcundan kurtulabilir. Bu durumda, peşin satış bedeline ilave edilen bedelin ödenmemiş taksitlere isabet eden kısmı, yarısından az olmamak üzere ödeme süresinin kısaltılmasına uygun olarak indirilir.

e. Alıcının temerrüdü

aa. Satıcının seçimlik hakkı

Alıcı peşinatı ödemede temerrüde düşerse satıcı, sadece peşinatı isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir (TBK m. 259/I).

Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Satıcının geri kalan satış bedelinin tamamını isteyebilmesi veya sözleşmeden dönebilmesi, ancak bu hakkı açık biçimde saklı tutmuş olmasına ve alıcının kararlaştırılan satış bedelinin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ya da en son taksidi ödemede temerrüde düşmüş olmasına bağlıdır. Ancak, satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği miktar, ödenmiş olan taksitler tutarına eşit veya daha fazla ise satıcı sözleşmeden dönemez (TBK m. 259/II).

Tüketicinin taksitleri ödeme temerrüde düşmesi ve satıcı veya sağlayıcının kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutması halinde bu hakkın kullanılması belirli şartlara bağlıdır. Buna gö-

re, borcun tamamının ifasının talep edilmesi, satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olmasına, ödenmemiş meblağın kalan borcun en az onda birini oluşturmasına, ödememenin birbirini izleyen en az iki taksit şeklinde olmasına veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksitin ödenmemiş olmasına bağlıdır (TKHK m. 19).

Satıcı, satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeş günlük bir süre tanımak zorundadır (TBK m. 259/III). Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanması için tüketiciye en az otuz gün süre vermek suretiyle muacceliyet uyarısında bulunması gerekmektedir (TKHK m. 19). Buna karşılık, tüketici borç konusu miktarın tamamını önceden ödeyebilir; vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksiti ödeyebilir. Bu durumlarda satıcı ve sağlayıcı faiz ve komisyon alınan hallerde ödenen miktara göre faiz ve komisyon miktarını indirmekle yükümlüdür (m. 20).

bb. Sözleşmeden dönme

Satıcı, alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle satılanın alıcıya devrinden sonra sözleşmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Satıcı, ayrıca hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ve satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak satıcı, sözleşme zamanında ifa edilmiş olsaydı elde edecek olduğundan fazlasını isteyemez (TBK m. 260/I).

Satıcı, alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi yüzünden satılanın devrinden önce sözleşmeden dönerse, alıcıdan sadece ödenmeyen peşinat üzerinden, sözleşmeden döndüğü tarihe kadar işleyecek yasal faiz ile sözleşmenin kurulmasından sonra, satılanın uğramış olduğu değer kaybı sebebiyle tazminat isteyebilir. Ceza koşulu kararlaştırılmışsa, peşin satış bedelinin yüzde onunu aşamaz (TBK m. 260/II).

cc. Hakimin müdahalesi

TBK m. 261'e göre, hâkim, temerrüde düşen alıcının borçlarını ödeyeceği konusunda güvence vermesi ve satıcının da bu yeni düzenleme dolayısıyla herhangi bir zararının söz konusu olmaması koşuluyla, alıcıya ödeme kolaylıkları sağlayabilir ve satıcının satılanı geri almasını yasaklayabilir

f. Yetkili mahkeme ve tahkim

TBK m. 262'ye göre, yerleşim yeri Türkiye'de olan alıcı, tarafı olduğu taksitle satış sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar konusunda, yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisinden önceden feragat edemeyeceği gibi, tahkim sözleşmesi de yapamaz.

g. Taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulama alanı

Taksitle satışa ilişkin hükümler aynı ekonomik amacı taşıyan işlemelere de uygulanır (TBK m. 263/I). Kanunda bu uygulama alanına ilişkin olarak sık görülen bazı durumlar için kıyasen uygulama, bazı ödünç sözleşmelerinde taksitle satışa ilişkin zorunlu unsurların yer alması, taksitle satış hükümlerinin bazı peşin satışa bağlantılı taksitle ödünç sözleşmeleri için uygulanmaması, alıcının tacir olması veya bir malın ticari işletmenin ya da mesleki amaçlarla satışa konu edilmesi halinde Türk Borçlar Kanunun bazı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hükümler öngörülmüştür (TBK m. 263/II-IV).

2. Ön ödemeli taksitle satışlar

a) Tanımı, şekli ve içeriği

Ön ödemeli taksitle satış[4], alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendiği satış sözleşmesidir (TBK m. 264/ I; TKHK m. 21/1)[5].

---

4 Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tam olarak ödenmesinden sonra satılanın tüketiciye teslim etmeyi üstlendiği, ödeme süresi bir yıldan daha uzun ya da belirsiz olan sözleşmeler hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli satışa ilişkin hükümleri uygulanır (TKHK m. 21). Ön ödemeli konut satışları TKHK m. 40 ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. (Bkz. s. 125, dn. 10)

5 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 40. maddesi ön ödemeli konut satış sözleşmesini düzenlemektedir (Ayrıca bkz. Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik RG 27.11.2014 tarih ve 29188 sayı). Buna göre, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının ise bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme ön ödemeli konut satış sözleşmesidir. Kanun ile tüketiciler için ön bilgilendirme formu verilmesi (m. 40/2), satış için yapı ruhsatının alınması (m. 40/3), bina tamamlama sigortasının ve belirlenecek diğer teminatların verilmesi (m.42) zorunluluğu, tüketicinin ön dört gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı (m. 43), konutun

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz; sözleşmenin geçerli olarak kurulabilmesi için aşağıda belirtilen hususların da yazılı sözleşmenin içinde yer alması gerekir (TBK m. 264/II)[6]:

- Tarafların adı ve yerleşim yeri.
- Satışın konusu.
- Toplam satış bedeli.
- Taksitlerin sayısı, tutarı, vadesi ve sözleşmenin süresi.
- Taksitleri kabule yetkili banka.
- Alıcıya karşı üstlenilen faiz miktarı.
- Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı.
- Alıcının sözleşmeden cayma hakkı ve bu sebeple ödeyeceği cayma parası.
- Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.

TBK m. 272'ye göre, alıcının tacir sıfatı ile hareket etmesi veya malın bir ticari işletmenin ihtiyacı için ya da mesleki amaçla satın alınması halinde TBK m. 264 ilâ 271. maddeler uygulanmaz.

TBK m. 273'e göre, taksitle satışa ilişkin hükümlerden yasal temsilcinin rızasına, sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasına ve geri alma açıklamasına, alıcının def'ilerine, satıcının alacağının devrine, hâkim tarafından sağlanan ödeme kolaylıklarına ve yetkili mahkeme ile tahkime ilişkin olanlar, ön ödemeli taksitle satışa da uygulanır(f.I).

Satılanı devir süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan taksitle satışta alıcı, satılanın devrinden önce ödemeleri yapmakla yükümlü ise, ön ödemeli taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır(f.II).

b) Tarafların hak ve borçları

aa) Ön ödemelerin süresi

TBK m. 270/I ön ödemeleri ifa borcunun, beş yılın geçmesiyle sona ereceğini ifade etmektedir.

---

sözleşmeden itibaren en geç otuz altı ay içinde devir veya teslimi (m.44), konutun devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı gibi hususlar düzenlenmektedir.

6 **Engel**, s. 83; **Tercier**, N. 1432.

bb) Ön ödemelerin teminatı

TBK m. 265'e göre, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açılacak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım hesabına yatırmakla yükümlüdür (f.I).

Banka, her iki tarafın çıkarlarını gözetmek zorundadır. Açılan hesaptan her iki tarafın rızasıyla ödeme yapılabilir. Bu rıza önceden verilemez (f.II).

Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, satılanın devrine kadar 269. madde uyarınca sözleşmeden cayarsa satıcı, bu hesap üzerindeki bütün haklarını kaybeder (f.III).

Bu hükmün amacı, satıcının iflası halinde alıcıyı korumaktır[7].

cc) Alıcının malın devrini isteme hakkı

TBK m. 266'ya göre, alıcı satış bedelinin tamamını ödedikten sonra, her zaman malın kendisine devredilmesini isteyebilir. Ancak, satıcı malı başkasından sağlayarak devredecek ise alıcı, bunun için kendisine uygun bir süre tanımak zorundadır (f.I).

Satıcının malı alıcıya devredebilmesi için, taksitle satışa ilişkin koşullara uyulması gerekir (f.II).

Alıcı birden çok şey satın almış veya seçim hakkını saklı tutmuş ise, satılanın kısım kısım devredilmesini, ancak 256. maddede öngörülen asgari peşinatı ödedikten sonra isteyebilir. Satılanın eşya topluluğu oluşturduğu hâllerde bu istemde bulunulamaz. Satış bedelinin tamamen ödenmemesi hâlinde, satıcıdan satılanı kısmen devretmesi, ancak geri kalan kısmın yüzde onunun kendisine güvence olarak bırakılması koşuluyla istenebilir (f.III).

dd) Satış bedelinin ödenmesi

TBK m. 267'ye göre, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde satış bedelinin, satılanın devri anında tamamen ödenmiş olması gerekir. Satılanın devredilmesini isteyen alıcı, hesabındaki bakiyeden, satış bedelinin en çok üçte birlik kısmını satıcı lehine serbest bırakabilir. Ancak, sözleşmenin kuruluşu sırasında buna ilişkin taahhütte bulunulamaz.

---

[7] Tercier, N. 1435.

ee) Satış bedelinin belirlenmesi

TBK m. 268'e göre, satıcının sözleşmenin kurulduğu sırada belirlenen toplam satış bedeline ek bir bedel isteme hakkını saklı tutan bütün kayıtlar geçersizdir (f.I).

Ödenecek toplam satış bedeli sözleşmede belirlenmiş olmakla birlikte, devredilecek eşya önceden belirlenmemiş ve satıcı tarafından bu eşyayı seçme hakkı alıcıya tanınmış ise satıcı, peşin satıştaki olağan bedelleri göz önünde tutmak suretiyle alıcının yapacağı seçime tam olarak uymakla yükümlüdür (f.II).

Buna aykırı anlaşmalar, ancak alıcının yararına olduğu ölçüde geçerlidir (f.III).

c) Sözleşmenin sona ermesi

aa) Cayma hakkı

TBK m. 269'a göre, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, malın devrine kadar her zaman sözleşmeden cayabilir (f.I).

Sözleşmeden cayma hâlinde alıcı tarafından ödenmesi öngörülen cayma parası, durumun özelliğine ve sözleşmenin kurulması ile cayma arasında geçen süreye bakılarak belirlenir. Ancak, bu miktar satıcının toplam alacağının yüzde ikisinden az ve yüzde beşinden fazla olamaz. Alıcı, yapmış olduğu ödemelerin cayma parasını aşan kısmının, getirileri ile birlikte kendisine geri verilmesini isteyebilir (f.II).

Alıcının ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden cayılmış olursa, cayma parası istenemez (f.III).

bb) Sözleşme süresinin dolması

TBK m. 270/II'ye göre, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, sekiz yıl geçtiği hâlde satılanın devri isteminde bulunmazsa, satıcı kendisini uyararak üç aylık süre tanır. Alıcı bu süre içinde kayıtsız kalırsa satıcı, alıcıya sözleşmeden cayma hâlinde tanınan haklara sahip olur.

cc) Alıcının temerrüdü halinde satıcının sözleşmeden dönmesi

TBK m. 271'e göre, alıcı bir veya daha çok ön ödemede temerrüde düşerse satıcı, ancak vadesi gelmiş olan ödemeleri isteyebilir. Bununla birlikte, toplam alacağın en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen iki ön ödemenin veya toplam alacağın en az dörtte birini oluşturan bir tek ön ödemenin ya da sonuncu ön ödemenin vadesi gelmişse satıcı, ayrıca alıcıya tanıyacağı bir aylık ödeme süresinin geçmesinden sonra sözleşmeden dönme hakkına sahip olur (f.I).

Satıcı, ödeme süresi bir yıl veya daha az olan sözleşmeden dönerse, 260. maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. Süresi bir yılı aşan sözleşmelerde satıcı, ancak 269. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen cayma parasını ve alıcıya ödenmesi gereken ortalama banka mevduat faizini aşan zararlarının giderilmesini isteyebilir (f.II).

Bir yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde temerrüde düşmüş olan alıcının malın devrini istemesi hâlinde satıcı, yasal anapara faizi ile birlikte, devir isteminden sonra malın değerinde oluşacak eksilmelerin giderilmesini isteyebilir. Ceza koşulu öngörülmüşse miktarı, satış bedelinin yüzde onunu geçemez (f.III).

Satılanın devredilmiş olduğu hâllerde, dönme konusunda 260. maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır (f.IV).

IV. Açık arttırma yoluyla Satış

1. Tanımı ve çeşitleri

a) Tanım

TBK m. 274'e göre, açık artırma yoluyla satış, yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır.

b) Çeşitleri

aa) Cebrî artırma

Malikin rızasına bakılmadan resmî makamlar tarafından yapılan artırmadır. İcra takibine konu olan veya müflise ait malların İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılan satışları buraya girer.

bb) İsteğe bağlı artırmalar

Bu tür artırmalar mal sahibinin rızasıyla yapılırlar.

aaa) İsteğe bağlı özel artırma

Bu tür artırmalarda, önceden ilân yapılmaz ve artırmaya belirli kişiler katılır; hâkimin, MK m. 591 uyarınca terekeye dahil malların mirasçılar arasında artırma ile satışına veya MK m. 628 gereğince müşterek mülkiyet halinde sahip olunan malların paydaşlar arasında artırmayla satışına karar vermesi hallerinde böyle bir satış söz konusu olur. İsteğe bağlı özel arttırma, TBK m. 279/IV'de mülkiyetin geçmesine ilişkin olarak zikredilmiştir.

bbb) İsteğe bağlı açık artırma

Bu tür artırmalar önceden herkese ilân yoluyla duyurulur ve artırma şartnamesinde belirtilen nitelikleri taşıyan herkes artırmaya katılabilir.

2. Sözleşmenin kurulması

Herkesin katılabildiği isteğe bağlı açık arttırmalarda satış sözleşmesi, satıcı arttırma koşullarında aksine bir beyanda bulunmadıkça, arttırmayı yönetenin en yüksek bedeli öneren kişiye ihale etmesiyle kurulmuş olur (TBK m. 275/I).

Cebri arttırma yoluyla satış, arttırmayı yöneten memurun en yüksek bedeli öneren kişiye ihale etmesiyle kurulmuş olur (TBK m. 275/II). Cebrî artırmalarda ihale beyanı özel hukuka ilişkin sonuçlar doğuran idarî bir işlemdir[8].

3. Hükümleri

a) Arttırmaya katılanın bağlandığı an

aa) Genel olarak

TBK m. 276'ya göre, artırmaya katılan kişi, satış için konulmuş olan koşullar çerçevesinde önerisiyle bağlıdır (f.I).

Aksine bir koşul yoksa öneride bulunanın bağlılığı, kendisinden daha yüksek bir öneri yapılmasıyla sona erer veya daha yüksek öneri olup olmadığının sorulması üzerine böyle bir önerinin olmadığının anlaşılması hâlinde, önerisinin hemen kabul edilmemesiyle ortadan kalkar (f. II).

---

[8] **Tercier**, N. 809; **Becker**, Art. 229, N. 4; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 331; **Tandoğan** I/1, sh. 317.

bb) Taşınmazların açık arttırma yoluyla satışında

TBK m. 277'e göre, Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, ihalenin veya reddinin artırmadan hemen sonra yapılması gerekir (f. I).

Öneride bulunanın bağlılığının artırmadan sonra da devam edeceğini öngören koşul geçersizdir. Ancak, bu kural cebrî artırmalarda ve ihalenin bir kamu görevlisince onaylanması gerektiği durumlarda uygulanmaz (f. II).

b) İhale bedelinin ödenmesi

TBK m. 278'e göre, Artırma koşullarında aksi kararlaştırılmamışsa, ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekir (f. I).

İhale bedeli peşin olarak veya artırma koşulları uyarınca ödenmezse satıcı, satıştan hemen dönebilir (f. II).

c) Mülkiyetin geçişi

İsteğe bağlı açık arttırmayla satışta, taşınır mal alan kişi mülkiyeti zilyetliğin geçirilmesine gerek olmadan ihale anında kazanır. Arttırmadan alınan taşınmazın mülkiyeti ise, tapu siciline tescil ile alıcıya geçer (TBK m. 279/I); arttırma görevlisi satış tutanağında gösterilen taşınmazın alıcı adına tescil edilmesini hemen tapu idaresine bildirir (TBK m. 279/II).

Cebrî artırmada, gerek taşınırlarda, gerek taşınmazlarda mülkiyet ihale ile geçer[9]; taşınmazlarda tapuya tescil kurucu değil, bildirici niteliktedir (MK m. 705/II). Ayrıca bkz TBK m. 279/III.

İsteğe bağlı özel artırmalarda, mülkiyet, taşınırlarda teslimle; taşınmazlarda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenen resmî senede dayanarak yapılan tescille geçer (bkz. TBK m. 279/IV).

d) Zapttan ve ayıptan sorumluluk

TBK m. 280/I'e göre, cebri arttırmalarda, zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanmaz. Artırmadan mal alan kişi, o mala, tapu siciline veya satış koşullarına ya da kanuna göre belirli olan durumu, hakları ve yükleri ile birlikte malik olur (f. II). Bu nedenle

---

[9] İhalenin feshi davası açılması halinde, satılan taşınmaz dava sonuçlanıp ihale kesinleşinceye kadar icra idaresi tarafından muhafaza ve idare edilir (Y. 3. HD 2012/22983 E. 2013/17 K. –Kazancı-)

şartnamede gösterilmeyen mükellefiyetler iyiniyetli alıcıya karşı ileri sürülemez.

İsteğe bağlı açık arttırmalarda satıcı, satılanın zaptından ve ayıplarından sorumludur. Ancak, aldatma durumu dışında, arttırma koşullarında açıkça belirtilip duyurmak suretiyle bu sorumluluktan kurtulabilir (TBK m. 280/III).

e) İhalenin iptali

TBK m. 281 gereğince, hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi sağlanmışsa her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini izleyen bir yıl içinde ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir (f. I).

Cebrî artırmalar hakkında özel hükümler saklıdır (f. II). İcra ve İflas Kanununun 134. Maddesine göre ihaleye fesadın öğrenilmesinde itibaren yedi günlük şikayet süresi içinde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Bu süre ihlal tarihinden itibaren bir seneyi geçemez[10].

V. İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri ile mesafeli sözleşmeler[11]

1. İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında işyeri dışında tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan sözleşmelerdir[12]. Bu sözleşmeler tüketiciyle işyeri dışında yapılan görüşmeden hemen sonra satıcı ya da sağlayıcının işyerinde veyahut da internet imkânları kullanılarak yapılan sözleşmeler gibi uzaktan iletişim aracıyla da kurulabilir. Sözleş-

---

10 İİK m. 134/2'ye göre ihalenin feshini satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilinde görülen ilgililer ile pey sürmek suretiyle ihaleye katılanlar isteyebilir.

11 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda taksitle satış sözleşmeleri (m. 17 vd.), tüketici kredisi sözleşmeleri (m. 22 vd.), konut finansmanı sözleşmeleri (m. 32 vd.), ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (m. 40 vd.), diğer tüketici sözleşmeleri başlığı altında mesafeli sözleşmeler (m. 48-49), devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (m. 50), paket tur sözleşmeleri (m. 51), abonelik sözleşmeleri (m. 52) ve süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları (m. 53) düzenlenmiştir.

12 4077 sayılı mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda "Kapıdan Satışlar" başlığıyla düzenlenen hüküm, başlığıyla birlikte "İşyeri dışında yapılan sözleşmeler" olarak değiştirilmiş ve 25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesine uyumlu hale getirilmiştir.

meye konu mal veya hizmetin tüketiciye tanıtılması ya da satış amacıyla düzenlenen bir gezi esnasında kurulması halinde de işyeri dışında kurulan tüketici sözleşmelerinden söz edilir (TKHK m. 47/1/a-c) [13].

İşyeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Yönetmelikte düzenlenen hükümler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanır. Buna karşılık, finansal hizmetlere, taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların doğumu, devri ya da kazanılmasına, konut kiralanmasına, paket turlara, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmetlerine, fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlara, günlük tüketim maddelerinin düzenli teslimatına ilişkin sözleşmelere, mal veya hizmet bedeli 30 TL'yi aşmayan satışlara, montaj, bakım ve onarıma, bazı elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektrik, şu ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin aboneliklere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz (m. 2).

İşyeri dışında kurulan sözleşmelerde ön bilgilendirme yapılması zorunludur (Yön. m. 5). Söz konusu sözleşmeler tüketici ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı arasında kurulabilmektedir (m. 47/2, Yön. m. 6).

İşyeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı şekil şartına tabidir. Ancak, satıcının veya sağlayıcının kurduğu sözleşme geçerli değilse bu durum tüketici aleyhine ileri sürülemez. Bu sözleşmelerde sözleşme tarihi tüketicinin el yazısı ile yazılmalı, imzalanmalı ve bir nüshası tüketiciye verilmelidir (TKHK m. 4).

İşyeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici ön dört gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının bu süre içinde satıcıya veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcının TKHK m. 47'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gereği gibi bilgilendirmemesi durumunda cayma hakkı cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ermektedir (TKHK m. 47/6).

---

[13] Tüketicinin işyeri dışında kurduğu sözleşmeler ile bu sözleşmeye ilişkin kendisine yöneltilen icaba ilişkin bulunması gerekli unsurlar çıkarılan Yönetmelikle belirlenmiştir (İşyeri Dışında Yapılan Satışlar Yönetmeliği RG 14.1.2015 tarih 29236 sayı). Buna göre, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tarafların hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, bu tür sözleşmelerle satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim edilmesi kararlaştırılmışsa tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraf talep edilemez. Satıcı, malın tüketiciye ya da onun belirlediği taşıyıcı dışında üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasardan sorumludur (Yön. m. 15/2, 3).

2. Mesafeli sözleşmeler

Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcı ile eşzamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan pazarlama araçlarının kullanılması ile icra edilen bir organizasyon faaliyeti sonucu kurulan sözleşmelerdir (TKHK m. 48/I, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 4/1/e[14]). Bu sözleşme türünde taraflar karşı karşıya gelmemektedir. Yazılı veya görsel medya üzerinden ya da cep telefonlarına gelen mesajlar ile gönderilen e postalar üzerinden yapılan sözleşmeler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Mesafeli sözleşmelere ilişkin hükümler, Yönetmeliğin 2. maddesinde sayılan ve işyeri dışında yapılan sözleşmeleri ilişkin olarak sayılan finansal hizmet, taşınmaz mal, konut kiralama, paket tur, devre mülk, devre tatil, günlük tüketim maddeleri, montaj-bakım–onarıma ilişkin sözleşmeler dışında otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlara, halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı, bahis, çekiliş piyango gibi şans oyunlarına ilişkin hizmetlere, bazı yolcu taşıma hizmetlerine, bakımevi hizmetleri ile çocuk ya da yaşlı, hasta bakımına ilişkin sosyal hizmetlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz (Yön. m. 2)[15].

Mesafeli sözleşmelerde Yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan konularda ön bilgilendirme yapılması zorunludur. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyat, cayma hakkının kullanılma şartları gibi hususlar bilgilendirme kapsamında yer almaktadır.

Ön bilgilendirmenin en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir açıklık, sadelik ve üslupta, okunabilir şekilde olması zorunludur (Yön. m. 6).

---

[14] Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

[15] Kapsam dışında bırakılan sözleşme ilişkileri TKHK tarafından ayrıca düzenlenmiş, bu nedenle söz konusu hükümlerin uygulama alanı içine alınmamıştır.

Mesafeli sözleşmelerde mal satışı söz konusu ise ve daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa ifa süresi otuz günü geçemez. Bu süre içinde ifanın gerçekleşmemesi halinde tüketici sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu takdirde tahsil edilen tüm ödemeler, sona erdirmeye ilişkin irade beyanının muhataba varmasından itibaren on dört gün içinde teslimat masrafı ile birlikte faiziyle geri ödenmek zorundadır (Yön. m. 16).

Tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı caymanın kendisine ulaşmasından itibaren on dört gün için tahsil edilen ödemeleri ve teslim masraflarını iade etmekle yükümlüdür (Yön. m. 12).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

§ 14. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ, UNSURLARI VE ŞEKLİ

I. Tanımı ve niteliği

Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, mal varlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırmada bulunmayı üstlendiği bir sözleşmedir (TBK m. 285/I)[1].

Bağışlama temlik borcu doğuran ve ivazsız, yani tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir[2]. Bağışlamanın tek tarafa (bağışlayana) borç yükleyen bir sözleşme niteliğine uygun olarak, kanun, bağışlayanı ve onun malvarlığını korumaya yönelik özel hükümler öngörmüş bulunmaktadır[3]: Henüz kabul edilmemiş bağışlama icabının geri alınması imkânı (TBK m. 293); bağışlama taahhüdü için şekil mecburiyeti (TBK m. 288); fiil ehliyetine ilişkin özel şartlar (TBK m. 286-287; MK m. 429/I, b. 7 ve 449); gecikme faizinin başlangıç anı (TBK m. 121); bağışlayanın ayıptan doğan sorumluluğun yumuşatılması (TBK m. 294, 191/III ve 114/1); intifa hakkını saklı tutarak çıplak mülkiyeti bağışlayan kimsenin teminat gösterme yükümünün bulunmaması (MK m. 809); mahfuz hissesi ihlâl edilen mirasçıların tenkis talebi (MK m. 565, b. 3 ve 4) ve alacaklıların iptal davası açma imkânı (İİK m. 278 ve 280); bağışlayanın bazı hallerde bağışlamayı geri alabilmesi (TBK m. 295-296, MK m. 122).

II. Unsurları

Yukarıda yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere, bağışlamanın başlıca üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar, bağışlamanın bir sözleşme

---

1 **Cavin**, sh. 175; OR-**Vogt**, Art. 239, N. 1; **Tercier**, N. 861.

2 **Honsell**, sh. 137; **Tercier**, N. 867; OR-**Vogt**, Art. 239, N. 2; **Tandoğan** I/1, sh. 342.

3 **Oser/Schönenberger**, Art. 239, N. 3 vd; OR-**Vogt**, Art. 239, N. 2; **Tandoğan** I/1, sh. 342.

olması, bir kazandırmayı konu edinmesi ve ivazsızlık (bir karşı edimin bulunmaması).

1. Bağışlama sözleşmesi

a) Kurulması

Bağışlama sözleşmesi, borç doğuran bir sözleşme olup, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulur (TBK m. 1 vd.). Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine göre, icab sahibi kabul için bir süre tayin etmişse, bu sürenin sonuna kadar (TBK m. 3); böyle bir süre tayin edilmeyen hallerde, hazırlar arasında derhal kabul edilinceye kadar (TBK m. 4/I), gaipler arasında ise, zamanında ve muntazam bir şekilde gönderilen kabul beyanının varması anına kadar (TBK m. 5) icabıyla bağlıdır. İcap ve kabule ilişkin bu esaslar, bağışlamada TBK m. 293 hükmüyle değiştirilmiştir. Buna göre, bağışlayan, gaipler arasında yapılmış bir icabını, bağışlananın kabul beyanı kendisine ulaşıncaya kadar geri alabilir; hazırlar arasındaki icapta ise, icabın geri alınması kabule kadar mümkündür[4].

Bağışlama sözleşmesinde kabul, zımnî (örtülü) irade beyanıyla da gerçekleşebilir; bunun için, bağışlananın, bağışlama kurmaya yönelik icabı öğrenmiş olması gerekir, icabın ona varmış olması yeterli değildir[5]. Bağışlananın haberi olmadan onun lehine bir bankaya para yatırılması, yani bağışlayanın bağışlanan lehine üçüncü şahıs yararına sözleşme yapması halinde durum böyledir[6]. Şarta bağlı veya mükellefiyetli bağışlamalarda bağışlananın açık bir kabulü gerekir[7].

b) Tarafların ehliyeti

aa) Bağışlayanın fiil ehliyeti

Eşler arasındaki mal rejiminden ve mirasçılık hakkından doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlayan kimsenin fiil ehliyetine sahip olması gerekir (TBK m. 286/I). MK. m. 193'e göre, "Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle

---

4 **Becker,** Art. 244, N. 1; **Cavin,** sh. 175; OR-**Vogt**, Art. 244, N.1. Aksi fikirde: **Oser/Schönenberger,** Art. 244, N. 2.

5 **Cavin,** sh. 176; **Engel**, sh. 105-106; OR-**Vogt**, Art. 239, N. 3; **Honsell**, sh. 176; BGE 69 II 309 yahut JdT 1944 II 309 yahut JdT 1944 I 178; BGE 110 II 161 yahut JdT 1985 I 153.

6 **Cavin**, sh. 176; BGE 69 II 309 yahut JdT 1944 I 178 vd.

7 OR-**Vogt,** Art. 239, N. 3; BGE 52 II 289.

her türlü hukukî işlemi yapabilir". Bu maddede öngörülen hukukî işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine getirilen kanunî istisnalar arasında MK m.199 ve 223/II hükümleri yer almaktadır. Yeni Medenî Kanunla yasal mal rejimi olarak kabul edilen, edinilmiş mallara katılma rejiminde, "aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz" (MK m.223/II). Mal ortaklığında, olağan yönetim dışında kalan konularda eşler, ancak birlikte veya diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta bulunabilir (MK m.263/I). Mirasçılıktan doğan sınırlamalardan amaç, tasarruf nisabını aşan bağışlamaların tenkise tâbi tutulmasıdır (MK m. 508 ve 565/b. 1-3).

Diğer taraftan İİK m. 278, iflâs eden veya borç ödemekten âciz olan kimsenin alacaklılarına, bağışlamanın iptali davası açma hakkı vermektedir.

MK m. 449'a göre, mümeyyiz küçük ve kısıtlılar kanunî temsilcilerinin rızasıyla ancak önemsiz bağışlamada bulunabilirler; bunlar kanunî temsilcilerinin rızasıyla dahi önemli bağışlama yapamazlar[8]. Aynı esaslar, MK m. 343/I uyarınca, velayet altındaki kişiler için de geçerlidir. Bağışlamanın önemli olup olmadığı, bağışlayanın malvarlığı ve gelirine göre belirlenir[9].

Bağışlamayı takip eden bir yıl içinde, bağışlayanın israftan dolayı kısıtlanmasına karar verilmesi halinde, onun yaptığı bağışlama sulh mahkemesince iptal olunur (TBK m. 286/II).

bb) Bağışlananın ehliyeti

Bağışlamayı kabul için, bağışlananın ayırt etme gücüne sahip olması yeterli olup, tam ehliyetli olması şart değildir (MK m. 16/II; TBK m. 287/I). Bu bakımdan TBK m. 287/I, MK m. 16/II'nin gereksiz bir tekrarından ibarettir. Mükellefiyetli bağışlamalarda, bağışlanan borç altına gireceğinden, kanunî temsilcinin muvafakati gerekir[10]. Buna karşılık, bağışlama konusunun bakım masraflarını gerektirmesi ba-

---

8 **Egger,** Art. 408, N. 2; **Cavin,** sh. 176; **Tandoğan** I/1, sh. 353; BGE 69 II 65 yahut JdT 1943 I 418.

9 OR-**Vogt**, Art. 240, N. 4.

10 **Cavin,** sh. 177; **Bucher**, BT, sh. 150-151; **Tercier**, N. 896; OR-**Vogt**, Art. 242, N. 1; **Oser/Schönenberger**, Art. 241, N. 1; **Becker**, Art. 241, N. 2; **Tandoğan** I/1, sh. 355.

ğışlamanın ivazsızlığını bertaraf etmez; kanunî temsilcinin rızasına gerek yoktur[11].

TBK m. 287/c.2'ye göre, kanunî temsilci, sınırlı ehliyetsizi bağışlamayı kabulden men ve bağışlanılan şeyin iadesini emredebilir. Bu takdirde, bağışlama sözleşmesi geçmişe etkili olarak ortadan kalkar; iptal edilmiş olur[12]. Bağışlamanın konusu veya bağışlayan kişi yönünden bağışlananı küçültücü veyahut onu manevi borç altına sokan bağışlamalarda böyle bir durum (red) söz konusu olabilir[13]. Kanunî temsilci red için gerekçe göstermek zorunda değildir; bununla beraber, mümeyyiz mahcur, vasinin yasaklama kararına karşı MK m. 461 gereğince vesayet makamına şikâyette bulunabilir[14]. Velâyet altındaki küçüğün böyle bir hakkı yoktur.

Ayırt etme gücünden yoksun kişiler, bağışlama sözleşmesi kuramazlar (MK m.15/I). Bununla beraber, hukukî bir işlem söz konusu olmaksızın, bağış konusunun bağışlananın malvarlığına geçmesi (meselâ, bağışlanan bir miktar paranın karışma yoluyla iktisabı) halinde, iktisap geçerli olur; burada geçerli bir bağışlama taahhüdü bulunmamasına rağmen, sebepsiz zenginleşmeye dayanan (TBK m. 77 vd.) bir iade borcu bulunmamaktadır. Zira bağışlayan yönünden, kendisini borçlu zannederek ödeme, yani hata söz konusu değildir[15].

2. Sağlararası bir kazandırma

Bağışlamanın konusu bir kazandırma olup, bununla bağışlayanın malvarlığına dahil bir değer (menfaat) bağışlananın malvarlığına girer. Böylece bağışlayanın malvarlığı azalır, bağışlananınki artar[16]. Bağışlananın malvarlığının artması, aktifin artması veya pasifin azalması şeklinde olabilir.

---

[11] **Bucher**, BT, sh. 151; **Honsell**, sh. 177; OR-**Vogt**, Art. 241, N. 1.

[12] **Bucher**, BT, sh. 151; **Cavin**, sh. 177.

[13] **Cavin**, sh. 177; **Engel**, sh. 107.

[14] **Cavin**, sh. 177; **Engel**, sh. 107; **Tandoğan** I/1, sh. 355.

[15] **Bucher**, BT, sh. 151; OR-**Vogt**, Art. 241, N. 2.

[16] **Cavin**, sh. 177; **Engel**, sh. 107; **Tercier**, N. 869; BGE 102 II 313 yahut JdT 1977 I 130.

Başkasına devredilebilen her türlü mameleki değer bağışlamaya konu teşkil edebilir: Taşınır veya taşınmaz eşya; alacaklar, haklar (telif hakkı, patent) irtifak veya intifa hakkı tesisi[17].

Bağışlama sözleşmesiyle yapılan kazandırma doğrudan doğruya (meselâ, alacağın temliki) veya dolaylı (borç üstlenme, başkasının borcunu ödeme gibi) olarak yapılabilir[18].

Bağışlayanın malvarlığına dahil bir değerin bağışlananınkine geçişinin bulunmadığı hallerde bağışlama söz konusu olmaz. Meselâ, hatır için yapılan işler; henüz kazanılmamış bir haktan feragat (bir icabı kabul etmemek, önalım, gerialım veya alım hakkını kullanmamak (TBK m. 285/II).

Mirasın reddinin bağışlama sayılmayacağı TBK m. 285/II'de açıkça öngörülmüştür; red, diğer mirasçıların paylarını artırma kastıyla yapılsa dahi, sonuç değişmez. Zira mirası red beyanı tek taraflı bir hukukî işlemdir[19].

Ahlâkî borcun yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz (TBK m. 285/III); TBK m. 295 ve 296 burada uygulanmaz. Zaten, TBK m. 78/II ahlâkî görevin ifası amacıyla verilenlerin iadesinin istenemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Aynı şekilde, diğer eksik borçların ifası da bağışlama olarak kabul edilemez[20].

Kanunda özel olarak düzenlenmiş karşılıksız kazandırmalar, bağışlama sayılmaz; bunlar kendileriyle ilgili özel hükümlere tâbidir: Faizsiz ödünç; kullanım ödüncü ve ücretsiz vekâlet.

Bağışlama, tam üçüncü şahıs yararına sözleşme (TBK m. 126/II) veya havale (TBK m. 555) yoluyla gerçekleşebilir. Bu durumda bağışlanan, TBK m. 129/II, c.2 gereğince, üçüncü şahıs olarak, kendi lehine taahhüt edilen hakkı kullanmak istediğini beyan edince ve havale borçlusu havaleyi kayıtsız şartsız kabul ettiğini bildirince geri alınamaz bir hak kazanırlar[21].

---

17 Düğün esnasında kadına takılan ziynet eşyası bağışlama sayılır (6. HD. 2014/3491 E. 2014/6080 K); Para karşılığı bir taşınmazın alınarak eşe güven ve bağlılık sonucu 1/2 payını onun adın tescil ettirilmesi bağışlama olarak kabul edilmektedir (8. HD. 2012/2567 E. 2012/9347 K.

18 **Cavin**, sh. 177; **Engel**, sh. 107.

19 **Bucher**, BT, sh. 148.

20 OR-**Vogt**, Art. 239, N. 32; **Tandoğan** I/1, sh. 347.

21 **Honsell**, sh. 175; OR-**Vogt**, Art. 239, N. 12; **von Tuhr/Escher**, sh. 252.

3. İvazsızlık (karşı edimin bulunmaması)

Bağışlama karşılıksız bir kazandırmadır; bağışlama sözleşmesinin ve bununla yapılan kazandırmanın amacı sadece bağışlananı zenginleştirmektir. İvazlı akitlerin aksine, burada edim ve karşı edim değiş tokuşu söz konusu değildir.

Bununla beraber, bağışlananın bazı edim ve hizmetleri yerine getirmeyi taahhüt etmiş olması, karşılıklı edimlerin değişimi niyeti olmadıkça, kurulan sözleşmenin bağışlama niteliğini gidermez. Mükellefiyetli bağışlamada durum böyledir. Aynı şekilde, bağışlamanın ivazlı bir sözleşme içinde yapılması da mümkündür. Meselâ, bir şeyin normal fiyatının altında satılması. Bu takdirde karma bağışlama söz konusu olur. Karma bağışlamanın bulunabilmesi için, akdin kurulduğu anda edimler arasındaki değer farkını ve bu farkın bağışlama niyetinden kaynaklandığını tarafların bilmesi gerekir. Tarafların bildiği ve istediği farkın önemli olduğu hallerde bağışlama iradesi mevcut sayılır[22].

Buna karşılık, bağışlayanı karşılıksız kazandırma yapmaya sevkeden saikler (minnettar bırakma, reklâmını yapma, övünme vs.) önemli değildir[23].

III. Şekli

Bağışlamanın şeklini, kanundaki düzenlemeye uygun olarak bağışlama taahhüdü ve elden bağışlama ayırımına göre (TBK m. 288-289) incelemek gerekir.

1. Elden bağışlama

TBK m. 289'a göre, "Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurulmuş olur". Elden bağışlama borç doğuran bir sözleşme olup, bunun kurulmasıyla ifası aynı anda gerçekleşir; elden bağışlamada bağışlanan şeyin teslimi, tek başına bağışlamaya vücut veren soyut bir tasarruf işlemi değildir[24].

---

22 **Cavin**, sh. 178; **Engel**, sh. 117 vd.; BGE 116 II 234 yahut JdT 1991 I 226.

23 **Tercier**, N. 863; **Engel**, sh. 110.

24 **Cavin**, sh. 179; **Engel**, sh. 110; **Tercier**, N. 905; OR-**Vogt**, Art. 242, N. 1; BGE 105 II 107 yahut JdT 1985 I 492; 13.HD, 11.10.1994, E. 5745/K. 8501: "Bağışlama akdinin kurulması ile ifası aynı zamanda oluştuğu hallerde" elden bağışlama" akdinden söz edilir. Yararına bağış yapılan kimse bağışı kabul ettiğini her türlü delillerle kanıtlayabilir. Dava konusu iş makinası trafiğe kayıtlı olmadığı dönemde davalıya teslim edildiğine, davalının uzun süre makina üzerindeki

Elden bağışlama sadece menkullerin ve alacakların bağışlanmasında söz konusu olur. Menkullerde TBK m. 289 anlamında teslim, zilyetliğin her türlü naklini (MK m. 977 vd.) ifade eder: Eşyanın kendisinin veya onun üzerinde fiilî hâkimiyeti sağlayacak vasıtaların teslimi, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi ve kısa elden teslim[25]. Alacakların elden bağışlanmasında yazılı bir temlik sözleşmesine ihtiyaç vardır (TBK m. 184/I).

Buna karşılık, tapuya kayıtlı taşınmazlar ve bunlar üzerindeki aynî haklar elden bağışlamaya konu olamazlar. Zira bunların bağışlanması, ancak tapu siciline tescil ile tamam olur (MK m. 705/I)[26]; böyle bir tescil ise, ancak geçerli, yani resmî bir şekilde yapılmış bir bağışlama taahhüdüne dayanabilir (MK m. 1015/III).

2. Bağışlama taahhüdü

Elden bağışlamadan farklı olarak, bağışlama taahhüdünde sözleşmenin ifası, kurulması safhasından sonra gerçekleşmektedir; borç doğuran sözleşme ile tasarruf işlemi açık bir şekilde birbirinden ayrılmaktadır[27].

Kanun koyucu, bağışlayanın acele ve düşünmeden hareket etmesini önlemek amacıyla[28], bağışlama taahhüdünün geçerliliğini, kural olarak yazılı şekil şartına bağlamıştır (TBK m. 288/I)[29]. Taşınırlar ile alacaklara ilişkin bağışlama taahhütleri için âdi yazılı şekil yeterlidir; bağışlama amacıyla yapılan ibra vaadi veya mücerret borç ikrarı için de yazılı şekil gereklidir[30].

---

egemenliği eylemli biçimde devam ettiğine göre, tarafların "elden bağış" kasıt ve amacıyla anlaştıkları, davalının yıllardır bu ilişkiye güven duyarak elinde bulundurduğu kabul edilmelidir" (YKD 1995, sh. 600).

25 OR-**Vogt**, Art. 242, N. 2; **Engel**, sh. 111; **Tercier**, N. 906; **Honsell**, sh. 178; BGE 63 II 395 yahut JdT 1939 I 5. Federal Mahkeme eski bir kararında (BGE 47 II 120) bağışlamada hükmen teslimle mülkiyetin geçmesini kabul etmiyordu; BGE 105 II 404 yahut JdT 1979 I 492; 7. HD, 25.10.1976, E. 9792/K. 12151 (YKD 1978, sh. 208).

26 İmar planlamasındaa yola terk işlemi de bağış işlemi anlamına gelmektedir. Bu nedenle tapu siciline işlenmesi gerekmektedir (5. HD. 2012/12342 E. 2012/17633 K. –Kazancı-).

27 **Engel**, sh. 112; **Cavin**, sh. 180.

28 BGE 105 II 107 yahut JdT 1978 I 489.

29 **Tercier**, N. 908; OR-**Vogt**, Art. 243, N. 1; **Cavin**, sh. 180.

30 OR-**Vogt**, Art. 243, N. 3; **Oser/Schönenberger**, Art. 243, N. 6; Art. 239, N. 7-9; **Tandoğan** I/1, sh. 356; BGE 44 II 181.

Buna karşılık, taşınmazlara ve bunlar üzerindeki aynî haklara ilişkin bağışlama taahhüdünün geçerli olması için, resmî şekilde yapılmaları şarttır (TBK m. 288/II).

Öngörülen şekil tarafların adlarını, bağışlama konusunu ve bağışlayanın karşılıksız kazandırmada bulunma iradesini ihtiva etmelidir[31]. Bununla beraber, şekil şartı sadece borç altına giren bağışlayanın beyanı için aranır; bağışlananın kabul beyanının yazılı şekilde yapılması zorunlu değildir[32].

Öngörülen şekle uyulmamasının sonucu mutlak butlandır (kesin hükümsüzlük). Ancak, geçersiz olan bağışlama taahhüdü yerine getirilince elden bağışlama sayılır (TBK m. 288/III) ve geçerlilik kazanır. Bu durumda yapılan bir ifa veya elden bağışlama yeni bir bağışlama olarak kabul edilmektedir[33]. Tapuya kayıtlı taşınmazlarda elden bağışlama söz konusu olmaz. Zira taşınmazlarda tescil geçerli bir bağışlama taahhüdüne dayanılarak yapılır[34].

---

31 OR-**Vogt**, Art. 243, N. 4; **Tercier**, N. 913; **Engel**, sh. 112; BGE 117 II 385; 105 II 107.

32 **Tercier**, N. 911; **Honsell**, sh. 178; **Engel**, sh. 112; BGE 110 II 161 yahut JdT 1985 I 153.

33 **Tercier**, N. 915; OR-**Vogt**, Art. 243, N. 6.

34 **Engel**, sh. 113.

§ 15. BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ

I. Koşullu bağışlama

TBK m. 290/I'e göre, bağışlama koşula bağlı olarak yapılabilir. Bağışlamanın bağlandığı koşul, geciktirici (TBK m. 171/I) veya bozucu (TBK m. 173/I) koşul olarak kararlaştırılabilir. Geciktirici veya bozucu tın iradî koşul niteliği taşıması da mümkündür. Bu ihtimalde, koşulun gerçekleşip gerçekleşmemesi taraflardan birinin, özellikle bağışlayanın iradesine bırakılmış olur. Bu cümleden olarak, bağışlayan bağışlamayı istediği zaman geri alma hakkını mahfuz tutabilir[1].

Bağışlamada koşulun zımnen kararlaştırılabileceğini, bu konuda ihtiyatlı davranmak gerektiği ifa edilmekle beraber[2], kabul etmek gerekir[3].

II. Mükellefiyetli (Yüklemeli) bağışlama

Mükellefiyet ile, bağışlanan, belirli bir edimde bulunma yükümü altına girer. Bu edim, bir verme (bağışlama konusunu kısmen veya tamamen belirli bir amaçla kullanmak), bir yapma (bağışlayan veya üçüncü bir kişi lehine belirli bir hizmette bulunmak) veya bir yapmama (belirli bir davranıştan kaçınma) şeklinde olabilir[4]. Buna göre, mükellefiyet bağışlayan veya üçüncü bir kişi lehine olabileceği gibi, bağışlanan lehine de öngörülebilir[5]. İlk iki halde vasıflı, sonuncu ihtimalde ise basit mükellefiyet söz konusu olur[6]. Meselâ:

– Bir heykeltraş kendi yaptığı sporcu heykelini belediyeye bağışlıyor ve mükellefiyet olarak bunun spor salonunun girişine konulmasını istiyor[7].

---

1 **Bucher**, BT, sh. 157; OR-**Vogt**, Art. 245, N.1; **von Tuhr/Escher**, sh. 275 vd.; **Becker**, Art. 245, N. 1; Art. 247, N.1.

2 **Honsell**, sh. 180; OR-**Vogt**, Art. 245, N. 3; BGE 113 II 255.

3 **Tercier**, N. 953; **Bucher**, BT, sh. 157; **Engel**, sh. 112.

4 **Cavin**, sh. 181; **Engel**, sh. 118-119; OR-**Vogt**, Art. 246, N. 1; **Tercier**, N. 955.

5 **Honsell**, sh. 179.

6 **Tercier**, N. 957; **Honsell**, sh. 179.

7 BGE 80 II 263 yahut JdT 1955 I 162.

– Belirli bir amaçla kullanılacak bina yapılması için bir arsa bağışlanması[8].

– Bağışlanan menkul kıymetlerin idaresini bağışlayanın kendi elinde tutması[9] veya bağışlanan paranın faizlerinin yaşadığı sürece bağışlayana ödenmesi[10].

– Bağışlanan şeyin gelirinin mahallenin fakirlerinin ihtiyacına tahsisi veya bağışlanan paranın bağışlanan kişinin tedavi veya öğrenim masrafları için kullanılmasının öngörülmesi.

Mükellefiyet olarak öngörülen edim, bağışlayanın edimi ile değişim, yani karşılıklılık (sinallagma) ilişkisi içinde bulunmamaktadır. Aksi takdirde, bağışlamanın karşılıksız kazandırma niteliği ortadan kalkar[11]. Bu sebeple, mükellefiyetin bağışlanılan şeye oranla tâli bir nitelik taşıdığı ifade edilmektedir[12]. Bununla beraber, bazı hallerde mükellefiyet bağışlamanın aslî amacını teşkil edebileceği ve münhasıran üçüncü kişiler yararına konulan mükellefiyetlerde böyle bir durumun söz konusu olabileceği ifade edilmektedir[13].

Mükellefiyeti şarttan ayırmak gerekir. Şartlı bağışlamada, bağışlamanın hükümleri gelecekteki gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir olaya bağlanmıştır. Bağışlamanın hükümleri geciktirici şartın gerçekleşmesiyle doğar, bozucu şartın gerçekleşmesiyle ortadan kalkar. Şartlı bağışlamada bağışlananın bir borcu söz konusu olmadığı halde, mükellefiyetli bağışlamada bağışlanan için bir yüküm (borç) tesis edilmektedir[14]; mükellefiyetli bağışlamada sözleşmenin hükümlerini doğurması, mükellefiyetin ifasına bağlanmamıştır[15]. Bağışlananın önceden ifa zorunda olması halinde, şartın varlığı kabul edilir. Zira, mü-

---

8 BGE 96 II 611 yahut JdT 1960 I 510; 96 II 125.

9 BGE 57 II 513 yahut JdT 1932 I 489.

10 BGE 69 II 310.

11 **Bucher**, BT, sh. 154; **Tercier**, N. 956; **Engel**, sh. 119; OR-**Vogt**, Art. 246, N. 1; **Honsell**, sh. 179; BGE 80 II 260 yahut JdT 1955 I 162.

12 **Oser/Schönenberger**, Art. 245, N. 3; **Tercier**, N. 955; **Guhl/Merz/ Kummer**, sh. 358; **Tandoğan** I/1, sh. 363.

13 **Cavin**, sh. 182; **Engel**, sh. 119; BGE 80 II 260 yahut JdT 1955 I 162.

14 **Merz**, SPR VI/1, sh. 153; **Engel**, sh. 119.

15 OR-**Vogt**, Art. 246, N. 3.

kellefiyeti ifa yükümü, kural olarak, bağışlamanın ifasından sonra doğar[16].

Bağışlayan, mükellefiyetin ifa edilmesini, bağışlanana karşı açacağı bir dava ile talep edebilir (TBK m. 291/II); bağışlayanın ölümü halinde bu hak mirasçılara geçer[17]. Kusurlu imkânsızlık halinde, bağışlayan, mükellefiyetin ifa edilmemesi sebebiyle, şartları varsa, TBK m. 112'ye dayanarak tazminat talep edebilir[18]. Aynı şekilde, bağışlayan bağışlamayı geri alabilir ve bağış konusunun kendisine iadesini talep edebilir (TBK m. 295/b. 3). Kamu yararına öngörülen mükellefiyetlerde, bağışlayanın ölümü halinde yetkili merci mükellefiyetin ifasını dava edebilir (TBK m. 291/II).

TBK m. 291/III uyarınca, bağışlanan malın değeri mükellefiyetin masrafını korumaz ve masraf fazlası da kendisine ödenmezse, bağışlanan şahıs mükellefiyeti yerine getirmekten kaçınabilir.

III. Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamada, bir süreye (ecele) bağlı sözleşme söz konusudur; bu sözleşmenin ifası ancak bağışlayanın ölümünden sonra talep edilebilir[19]. Ölüm gerçekleşmesi şüpheli bir olay olmadığı için, bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama, şarta bağlı bir bağışlama olarak nitelendirilemez[20].

TBK m. 290/II'ye göre, "Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uygulanır". Burada geçen vasiyet kelimesini kaynak kanuna uygun olarak (OR Art. 245/II), "ölüme bağlı tasarruf" olarak anlamak gerekir. Bağışlama bir akit olduğu için, bu tür bağışlamaların miras sözleşmesi şeklinde yapılması gerekir. Bununla beraber, şekil yönünden geçersiz olan böyle bir bağışlamayı, tahvil yoluyla, vasiyet olarak kabul etmek imkânı

---

16 **Bucher**, BT, sh. 154; OR-**Vogt**, Art. 246, N. 3.

17 BGE 96 II 119 yahut JdT 1977 I 144.

18 **Cavin**, sh. 183; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 358; **Engel**, sh. 120; **Tercier**, N. 958; BGE 80 II 263 yahut JdT 1955 I 162. Aksi fikirde; **Bucher**, BT, sh. 155; **Honsell**, sh. 179; OR-**Vogt**, Art 246, N. 6.

19 **von Tuhr/Escher**, sh. 46; OR-**Vogt**, Art. 245, N. 6; **Engel**, sh. 120.

20 Karş. **Yavuz**, sh. 213.

vardır[21]. Ancak, burada şekil noksanlığının müeyyidesi butlan değil, iptaldir (MK m. 557)[22].

TBK m. 290/II ile ölüme bağlı tasarruf hükümlerine yapılan yollamanın kapsamı konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Azınlıkta kalan bir fikre göre[23], yapılan yollama sadece şekle ilişkin olup, bunun dışında bağımsız hukukî bir kurum söz konusudur ve bundan bağışlayanın sağlığında bağışlanan lehine bir hak doğar. Buna karşılık bizim de katıldığımız hâkim fikre göre[24], yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama gerek şekil, gerek esas yönünden tamamen ölüme bağlı tasarruf (miras sözleşmesi) hükümlerine (MK m. 514 vd.) tâbidir; ancak bağışlanan mirasçı olmayıp, kural olarak vasiyet alacaklısı durumundadır[25]. Bu iki görüş arasındaki pratik fark, bağışlananın vasiyet alacaklısı veya borçlar hukuku anlamında alacaklı sayılmasından ibarettir. Vasiyet alacaklısı sayılınca, bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde, onun mirasçıları hak sahibi olmazlar; buna karşılık, vadesi (eceli) borçlunun ölüm anı olan bir alacak olarak kabul edilince, alacaklının mirasçılarına geçer; bundan başka, bağışlanan vasiyet alacaklısı olarak kabul edilince, miras bırakanın alacakları ona tekaddüm etme hakkına (MK m. 603) sahip olur[26].

TBK m. 290/II anlamında bir bağışlama bulunup bulunmadığını tesbitte somut olayın özelliklerine ve tarafların iradesine, yani onların, bağışlayanın sağlığındaki mal varlığını mı, yoksa terekesini mi kayıtladıklarına bakmak gerekir[27]. Uygulamada, bağışlayanın, üçüncü kişideki alacağını ölümünde bağışlanana ödenmek üzere, faizlerini tahsil yetkisini kendisinde saklı tutmak suretiyle temlik etmesi[28] veya bir bankaya üçüncü kişi adına tevdi edilen menkul değerler üzerinde, tev-

---

21 **Tercier**, N. 929; OR-**Vogt**, Art. 245, N. 7; **Engel**, sh. 121; **Honsell**, sh. 184; **Tandoğan** I/1, sh. 368; BGE 76 II 278 yahut JdT 1972 I 172; BGE 75 II 184.

22 OR-**Vogt**, Art. 245, N. 7; **Honsell**, sh. 184; BGE 113 II 274.

23 **Oser/Schönenberger**, Art. 245, N. 19; **Tuor**, Vorbem. zum Erbvertrag, Art. 278, N. 20; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 359.

24 **Escher**, Einl. zum 14. Titel, N. 7, sh. 99-100, Zürich 1959; **Piotet**, Traité, sh. 179; **Cavin**, sh. 184; OR-**Vogt**, Art. 245, N. 6 ve 8; **Honsell**, sh. 184. Federal Mahkeme sorunu cevapsız bırakmıştır (BGE 89 II 92).

25 OR-**Vogt**, Art. 245, N. 6.

26 **Cavin**, sh. 184.

27 **Tercier**, N. 927; OR-**Vogt**, Art. 245, N. 9; BGE 113 II 272.

28 BGE 69 II 310 yahut JdT 1944 I 176.

di edenin, üçüncü kişiye, kendisinin vereceği izinle tasarruf imkânını öngörmesi[29] hallerinde sağlararası bir kazandırmanın bulunduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, bir büyük babanın torunu adına bir tasarruf hesabı açtırıp, bu hesap üzerinde ölünceye kadar yalnız kendisinin tasarrufta bulunma yetkisini saklı tutması halinde, hesap cüzdanı torunun elinde bulunsa dahi, ölüme bağlı tasarruf olarak değerlendirilmektedir[30].

IV. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama

TBK m. 292/I'e göre, bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi halinde bağışlanılan şeyin kendisine dönmesini şart edebilir. Bu anlamda bir şartın, bağışlamanın şarta bağlı olarak yapılabileceğini öngören TBK m. 291/I çerçevesinde bir bozucu şart olarak kararlaştırılması mümkündür; böylece taraflar bağışlama konusunun geriye dönmesini, önce ölmeden başka şartlara da bağlayabilirler. Kanunun bağışlanan kişinin bağışlayandan önce ölmesi halini bir geriye dönme şartı olarak bir hükümle düzenlemesi, bu şart için tapu siciline şerh imkânı tanımasıyla (TBK m. 292/II) açıklanmaktadır[31]. TBK m. 292'nin dışında kalan bozucu şartlarda, tapu siciline şerh imkânı bulunmamaktadır[32].

Bağışlayana dönme şartıyla yapılan bağışlamada, bağışlanan, şeyin mülkiyetini veya hakkı iktisap eder; bu iktisap olgusu menkullerde teslim, taşınmazlarda tapuya tescille gerçekleşir. Bu itibarla geriye dönme (rücu) şartı, unsurunu teşkil ettiği sözleşmenin şekline bağlıdır: Elden bağışlamada herhangi bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna karşılık, taşınmazlara veya bunlar üzerindeki sınırlı aynî haklara ilişkin olanlarda ise, resmî şekil gereklidir[33].

Bağışlananın önceden ölme şartı gerçekleşince, bağışlama sözleşmesi geçmişe etkili (ex tunc) olarak ortadan kalkar; bağışlayan, bağışlananın mirasçılarına karşı aynî istihkak veya sebepsiz zenginleşme davası açarak iade talebinde bulunabilir. Taşınmazlarda, tapuya şerh

---

29 BGE 96 II 151 yahut JdT 1971 572.

30 BGE 89 II 87 yahut JdT 1963 I 599-600.

31 **Cavin**, sh. 185; **Becker**, Art. 247, N. 1; Or-**Vogt**, Art. 247, N. 2; **Engel**, sh. 117.

32 **Cavin**, sh. 186; **Tercier**, N. 967; BGE 76 II 273.

33 **Cavin**, sh. 185; OR-**Vogt**, Art. 247, N. 2. Bk. ve karş. **Engel**, sh. 117.

verilmiş geriye dönme (rücu) şartı, bunları bağışlanandan devralanlara karşı da ileri sürülebilir.

Diğer taraftan, bağışlanan tarafından bağışlanılan şeyin üçüncü kişilere devredilmesi halinde, bağışlayan, TBK m. 171/III'ün kıyasen uygulanması suretiyle, kötü niyetli kişilere karşı geri dönme (rücu) şartıyla bağdaşmayan tasarrufların bâtıl olduğunu ileri sürerek, iade talebinde bulunabilir[34]; taşınmazlarda, şerhin bulunmadığı hallerde üçüncü kişilerin iyiniyeti ancak MK m. 1023 çerçevesinde korunur.

[34] **Cavin**, sh. 185; **von Tuhr/Escher**, sh. 268-269; **Tercier**, N. 965.

§ 16. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ

I. Bağışlayanın borçları

1. Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu

Bağışlama tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir; bundan sadece bağışlayan için borç doğar. Bağışlama sözleşmesinde, bağışlayan bağışlanılan şeyi teslim ve onun üzerindeki mülkiyet hakkını bağışlanana geçirme borcu altına girer.

Bağışlayanın bu borçları ifa etmemesi halinde, bağışlanan her zaman aynen ifayı talep ve dava edebilir. Bağışlama sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmadığı için, bağışlananın aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının tazminini isteme ve akitten dönme hakları (TBK m. 125 vd.) bulunmamaktadır. Bağışlayanın gecikme tazminatından ve sonraki imkânsızlıktan sorumluluğu, TBK m. 114/I, c. 2 gereğince daha az şiddetle takdir olunur. Bu gibi durumlarda TBK m. 294 kıyasen uygulanarak, bağışlayanın ancak kast veya ağır ihmalinden dolayı sorumlu olacağını kabul etmek gerekir[1]. TBK m. 121 gereğince bağışlayan, icraya veya mahkemeye müracaat tarihinden itibaren temerrüt faizi ödemek zorundadır.

TBK m. 298 bağışlayanın borçlarının kapsamına ilişkin olarak bir yorum kuralı ihtiva etmektedir. Buna göre, aksi kararlaştırılmadıkça belirli zamanlarda ifa edilecek (periyodik) edimleri ihtiva eden bağışlama, bağışlayanın ölümüyle sona erer.

2. Kötü ifa halinde sorumluluk

TBK m. 294/I'e göre, bağışlayan, bağışlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuru ile sebep olmadıkça sorumlu olmaz. Kanun koyucu, bu fıkra hükmüyle, bağışlama sözleşmesinin kötü ifa edilmesinden doğan dolaylı zararların tazminini amaçlamaktadır. Meselâ, bağışlanan hayvandaki hastalığın, bağışlananın sürüsündeki diğer hayvanlara geçmesi[2].

---

1 **Cavin**, sh. 186-187; OR-**Vogt**, Art. 248, N. 1; **Honsell**, sh. 182; **Tercier**, N. 936; **Tandoğan** I/1, sh. 374. **Bucher** (BT, sh. 156), burada zımnen kararlaştırılmış bir sorumsuzluk kaydı bulunduğu kanaatindedir.

2 **Engel**, sh. 113; **Cavin**, sh. 186; OR-**Vogt**, Art. 248, N. 4.

3. Zapttan ve ayıptan doğan sorumluluk

TBK m. 294/II'ye göre, bağışlayan, bağışlanan şey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermişse bununla sorumlu olur. Buradaki garanti sözü verme deyimin, hem zapta karşı, hem ayıba karşı sorumluluğu kapsamaktadır[3]. Bu fıkra hükmü gereğince, satışdan farklı olarak, bağışlayan ancak açıkça taahhüt ettiği takdirde, zapttan veya ayıptan sorumlu olur; alacakların bağışlanmasında TBK m. 191/II, temlik edenin alacağın varlığını tekeffül etmediğini açıkça ifade etmektedir; meğerki TBK m. 294 çerçevesinde garanti sözü vermiş olsun[4].

II. Bağışlamanın geri alınması

1. Genel olarak

Geri alma hakkı, tek taraflı varması gerekli irade beyanıyla kullanılır ve bununla sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Bu durumda, hukukî sebep ortadan kalktığı için, yerine getirilmiş bağışlama edimlerinin iadesini sağlamak üzere, iyi niyetli üçüncü kişilerin iktisapları saklı kalmak kaydıyla, bağışlayanın aynî istihkak davası açabilmesi gerekirdi. Kanun koyucu, metnin kaleme alındığı sırada egemen olan soyut aynî akit görüşünün etkisiyle, iade borcunu sebepsiz zenginleşme hükümlerine tâbi kılmıştır (TBK m. 295/I)[5]. Geri alma hakkının dava yoluyla kullanılması zorunlu değildir.

2. Yerine getirilmiş bağışlamanın geri alınması

TBK m. 295'e göre, bağışlayan, üç halde, elden bağışlama veya ifa edilmiş bağışlama taahhüdünde bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın elinde kalanın iadesini isteyebilir. Bu maddede öngörülen bağışlamayı geri alma sebeplerinden ilk ikisi, aynı zamanda mirasçılıktan çıkarma sebebidir (MK m. 510); diğeri ise bağışlamayı kayıtlayan mükellefiyetin haklı bir sebep olmadan yerine getirilmemesidir.

a) Bağışlananın, bağışlayana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olması (TBK m. 295/b. 1). Suçun bağışlamadan sonra işlenmesi icab eder; bağışlananın bu suçtan dolayı mahkûm olması şart değildir[6].

---

3 **Tercier**, N. 939; OR-**Vogt**, Art. 248, N. 3; **Tandoğan** I/1, sh. 375.

4 OR-**Vogt**, Art. 248, N. 3; **Tandoğan** I/1, sh. 375.

5 **Cavin**, sh. 187; **Engel**, sh. 114. Geri alma hakkının kullanılmasıyla bağışlama sözleşmesinin ileri etkili olarak ortadan kalkacağı fikrinde: **Bucher**, BT, sh. 159; OR-**Vogt**, Art. 249, N. 14.

6 **Tandoğan** I/1, sh. 378; **Zevkliler**, sh. 146.

b) Bağışlananın, bağışlayan veya ailesi için kanunen yükümlü olduğu görevlere önemli ölçüde aykırı davranmış olması (TBK m. 295/b. 2). Meselâ, kadının zina yapması; bağışlananın, bağışlayana veya ailesine ağır hakarette bulunması[7]; bağışlananın, kötü niyetle babasına ceza davası açması[8] veya bağışlayana karşı bilerek ve yersiz olarak hacir altına alınma talebinde bulunması[9].

c) Bağışlananın, haklı bir sebep olmadan, bağışlamayı kayıtlayan bir yüklemeyi yerine getirmemesi (TBK m. 295/b. 3).

3. Bağışlama taahhüdünün geri alınması ve ifadan kaçınma (TBK m. 296)

a) Yerine getirilmiş bir bağışlama için öngörülen (TBK m. 295) bir sebebin bulunması (b. 1).

b) Bağışlama taahhüdünden sonra bağışlayanın malî durumunun bozulması sebebiyle, bağışlamanın ifasının olağan üstü ağır olması (b. 2).

c) Bağışlama taahhüdünden sonra eskiden mevcut olmayan veya eskisine oranla daha külfetli aile ödevinin ortaya çıkması (b. 3).

4. Geri alma hakkının kullanılma süresi ve mirasçılara geçmesi

Bağışlayanın geri alma hakkı, geri alma sebeplerinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilir (TBK m. 297/I). Buna karşılık, geri alma hakkının kullanılması üzerine yerine getirilmiş bağışlama ediminin iadesi talebinin tâbi olduğu zamanaşımı süresi (TBK m. 82), geri alma beyanının bağışlanana vardığı andan itibaren işlemeye başlar[10].

Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan öldüğü takdirde, mirasçıları, bu sürenin sonuna kadar geri alma hakkını kullanabilirler (TBK m. 297/II). Bağışlayan sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları ölümden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alma hak-

---

7 **Tandoğan,** I/1, sh. 379 ve orada zikredilen Yargıtay kararları; **Zevkliler**, sh. 146; Düğün esnasında kadına takılan ziynet eşyası bağışlama sayıldığından bu tür bir bağışlamanın geri alınması için bağışlananın bağıylayana veya onun ailesinden bir kişiye karşı kanundan doğan yükümlülüklerini önemli surette ihlal etmiş olması şartı aranmaktadır (6. HD. 2014/3491 E. 2014/6080 K).

8 BGE 76 II 279.

9 OR-**Vogt**, Art. 249, N. 12; **Honsell**, sh. 181.

10 OR-**Vogt**, Art. 251, N. 3. Aksi fikirde: **Oser/Schönenberger**, Art. 251, N. 4; **Becker**, Art. 251, N. 2; **Spiro**, Bd. II, sh. 973, N. 4; **Engel**, sh. 116; **Stanislas**, SJZ 1978, sh. 74.

kını kullanabilirler (TBK m. 297/III). Bağışlanan, hukuka aykırı olarak veya kasden bağışlayanı öldürür veya geri alma hakkını kullanmasını engellerse, mirasçılar geri alma sebebini öğrendikten sonra bir yıl içinde bağışlamayı geri alabilirler (TBK m. 297/IV).

5. Bağışlama taahhüdünün kendiliğinden sona ermesi

TBK m. 296/II'ye göre, bağışlayanın borç ödemeden aciz duruma düşmesi veya iflâsına karar verilmesi halinde, ifa yükümü ortadan kalkar.

İKİNCİ KISIM
KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM
ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİ

§ 17. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SİSTEMİ

Türk Borçlar Kanunu'nun, özel borç ilişkilerinin düzenlendiği ikinci kısmın dördüncü bölümünün başlığı "Kira Sözleşmesi" adını taşımaktadır. Bu bölümde âdi kira sözleşmesi ile beraber ürün (hasılat) kirası da düzenlenmiş bulunmaktadır. Kira sözleşmesinin tanımının yapıldığı TBK m. 299'da ürün kirası ile âdi kira sözleşmesine ait asli edim yükümlerine birlikte yer verilmiştir. Bunun yanında, ürün kirasının düzenlendiği üçüncü ayırımda ürün kirası ayrıca tanımlanmıştır (TBK m. 357/I)[1]. Bu düzenleme tarzının yani ürün kirasının, kira sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilme tarzının yerinde olduğunu söylemek güçtür. Nitekim kira ile ilgili hükümler kaleme alınırken göz önünde tutulan İsviçre Borçlar Kanunu'nda ürün kirası ayrı bir ayrım altında düzenlenmiştir (OR Art. 275 vd.).

Kira sözleşmesinin düzenlendiği dördüncü bölümün birinci ayrımı "Genel Hükümler"; ikinci ayrımı "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları"; üçüncü ayrım ise "Ürün Kirası" başlıklarını taşımaktadır. Ayrıca konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıların korunmasında önemli işlevi bulunan Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un (GKK) hükümleri de Kanun metnine dahil edilmiştir[2].

6098 sayılı Borçlar Kanununun birinci ayırımında 300. maddede düzenlenen kira süresi, 311. maddede düzenlenen üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması, 320. maddede düzenlenen kiracının kirala-

---

1 Ürün kirası, kiraya verenin ürün veren bir şey veya hakkın kullanılmasını ve kullanmayla birlikte yararlanılmasını bedel karşılığında kiracıya bırakmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

2 6570 sayılı Kanun, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkında Kanun ile (m.10) yürürlükten kaldırılmıştır.

nanda değişiklik yapması, 322. maddede kiranın devri, 326. maddede düzenlenen takastan feragat yasağı ve 334. maddede düzenlenen kiralananın geri verilmesinde gözden geçirme ve bildirme yeni hüküm olarak düzenlenmiştir.

Birinci ayrımda düzenlenen ve TBK m. 299-308 arasındaki hükümlerden oluşan "Genel Hükümler", kural olarak taşınır veya taşınmaz her türlü kiralara uygulanır. Bununla beraber, genel hükümlerden bazıları ise sadece konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanır. Bu cümleden olarak, TBK m. 301, c.2, 315/II, 316/II-III, 322/II, 323/III hükümleri sırf konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanırken; TBK m. 312, 316, 336 sadece taşınmaz kiralarına, TBK m. 329 taşınmaz ve taşınır kiralarına ve TBK m. 330 hükmü de taşınır kiralarına ilişkin bulunmaktadır.

Dördüncü bölümün ikinci ayrımının başlığı "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" adını taşımaktadır. Nüfusun hızlı artması, köylerden şehre akın ve ailelerin bölünmesi, şehirlerde konut sıkıntısı yaratmıştır. Bu durumun ülkede sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaratacağı tespit edilmiştir. Bu düşünceyle 1955 yılında, kiraları 1953 rayiçleriyle donduran ve kiralayanın fesih hakkını sınırlayan 6570 sayılı "Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun" yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunda kiracıları koruma amacı ile Borçlar Kanununa hakim olan sözleşme özgürlüğü ilkesine önemli sınırlamalar getirilmiştir. TBK'nın Yürürlük ve Uygulama Kanunun 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan 6570 sayılı GKK hükümleri, bazı değişikliklerle, konut ve çatılı işyeri kirası başlığı altında, TBK'ya dahil edilmiştir (m.339-356). Ancak TBK m. 339-356 hükümlerinin uygulama alanı, 6570 sayılı GKK'dan farklı olarak, kiralananın bulunduğu yer açısından herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Böylece TBK'da "belediye teşkilatı olan yer, iskele, liman ve istasyondaki taşınmazlar" ibaresine (GKK m.1) yer verilmemiştir. Gerçekten konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerin uygulama alanını belirleyen TBK m. 339/I'e göre, "Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz". Böylece konut ve çatılı işyeri kiralarında, bunlarla beraber kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da ikinci ayrım (TBK m. 339-356) hükümleri uygulanacaktır.

Dördüncü bölümün üçüncü ayrımında ürün kirası düzenlenmiştir (TBK m. 357-378). Yukarıda da belirtildiği üzere, ürün kirasının âdi kira sözleşmesi ile birlikte tanımlanmasının (TBK m. 299) ve her ikisinin de dördüncü ayrımda düzenlenmesinin yararlı bir yönü bulunmamaktadır. Zira ürün kirasının tanımı üçüncü ayrımda yer alan TBK m.357'de ayrıca yapılmıştır. Keza TBK m. 358'e göre, "Bu ayırımda ürün kirasına ilişkin özel hüküm bulunmadıkça, kira sözleşmesine ilişkin genel hükümler uygulanır".

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6217 sayılı "Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" geçici ikinci maddesinin 6353 sayılı Kanunun 53. maddesi ile değişik geçici ikinci maddesine göre, kiracının tacir sayılan kişilerden olması ile özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olduğu işyeri kiralarında TBK m. 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. madde hükümleri 01.07.2012 tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile uygulanmaz[3]. Kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilen konularda sözleşme serbestisi gereğince kira sözleşmesi hükümleri uygulanır. Kira sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte bulunduğu zamanda uygulanan kurallar uygulanır.

[3] Bu düzenlemeler, ilk zikredildiğinde madde üzerine * konulmak suretiyle gösterilmiştir.

§ 18. ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE UNSURLARI

I. Tanımı

TBK m. 299'da yapılan tanıma göre, "kira sözleşmesi, bir şeyin kullanılmasını ve kullanılması ile birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir". Bu tanımda, âdi kira ile ürün kirası birlikte değerlendirilmiştir; hem kullanmanın hem de yararlanmanın devri tanıma dahil edilmiştir. Sistematik açısından, âdi kira ile ürün kirasının aynı bölümde düzenlenmesinin bir yararının bulunmadığına yukarıda değinilmiştir. Bundan başka, yapılan yasal tanımda "eşya" kelimesinden hareket edilmiştir. Oysa ürün kirası, eşyanın yanında ürün getiren hakları da konu edinebilir[1].

Âdi kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin belirli bir süre kullanılmasını bir bedel karşılığında kiracıya devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Satış ve bağışlama sözleşmelerinden farklı olarak, kira sözleşmesinde, bir şeyin mülkiyetinin kesin olarak devri taahhüdü söz konusu değildir. Aynı şekilde, hak sahibine, bir şeyi kullanma ve ondan yararlanma aynî hakkını veren intifa (MK m. 794) ve oturma hakkı (MK m. 823) gibi şahsî irtifaklardan farklı olarak, kira sözleşmelerinde kiracı, şahsî bir hak olan geçici kullanma hakkına sahip olur.

II. Hukukî niteliği

1. Kira sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir; sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterli olup, ayrıca kiralanan şeyin kiracıya teslimi şart değildir.

2. Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran ve ivazlı bir sözleşmedir; kiracı kullanma karşılığında bir bedel (kira parası) ödeme borcu altına girmektedir.

3. Kira sözleşmesi devamlı borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir; kiralayanın kiralanan şeyin kiracı tarafından kullanılmasına katlanma

---

[1] **Gümüş**, Kira Sözleşmesi, sh. 22.

borcu zamana yayılmış bulunmaktadır. Kira sözleşmesi belirli süreli veya süresiz olarak kurulabilir.

III. Unsurları

1. Tarafların anlaşması

Kira sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli ilk şart, tarafların kiralananın kullanılmasını bir ücret karşılığında devri konusunda anlaşmış olmalarıdır. Kira sözleşmesi rızaî bir sözleşme olduğundan, kiralananın kiracıya teslimi, sözleşmenin kurulması için gerekli değildir.

Kira sözleşmesinin geçerliliği, kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlı değildir; zımnî irade beyanıyla da kurulabilir.

2. Bir şeyin kullanılmasının devri

a) Kira konusu bir şey

Âdi kira sözleşmesinin konusunu cismanî bir varlığı olan menkul veya gayrimenkul bir şey teşkil eder[2]. Haklar veya iktisadî değerler hâsılat kirasına konu olabilir[3]; hasılat getiren bir şey, hasılat getirme özelliğinden bağımsız olarak kiralandığı zaman âdi kira söz konusu olur. Meselâ, bir çayırın spor alanı olarak kiralanması[4].

Kira sözleşmesinin kurulabilmesi için, kiralanan şeyin mutlaka kiralayana ait olması, yani kiralayanın malik olması şart değildir. Başkasının malını kiraya veren kişi, kiralananı kiracıya teslim edemezse veya teslim edip de malik tarafından geri alınırsa, kiracıya karşı, borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden sorumlu olur[5]. Böyle bir durumda, malik, kiralayanın haklarını kullanamaz, meselâ, ihtar çekerek onu mütemerrit duruma düşüremez[6].

Kat Mülkiyeti Kanunu m. 59/c. 2'ye göre, "sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanılmasını başkalarına bırakılabilir". Devre mülkten yararlanma hakkının bir ücret

---

2 Taşınmazın trafo yeri olarak kullanılmak amacıyla kiraya verilmesi halinde adi kiradan söz edilir (6. HD. 2014/7033 E. 2014/9469 K.).

3 **Honsell**, sh. 186; OR-**Weber/Zihlmann**, Art. 253, N. 2; **Reymond**, sh. 204; **Tandoğan,** I/2, sh. 3.

4 **Reymond**, sh. 204.

5 **Tandoğan,** I/2, sh. 11; **Zevkliler**, sh. 162; **Yavuz**, sh. 242.

6 **Zevkliler**, sh. 162; **Yavuz**, sh. 242; 6.HD, 5.5.1983, E. 4927/K. 4953 (YKD 1983, sh. 1755); 6.HD, 8.5.1981, E. 2249/K. 7882 (YKD 1982, sh. 798 vd.).

karşılığında, hak sahibine tahsis edilen dönem için başkasına devri halinde, kira sözleşmesi söz konusu olur[7].

b) Kiralananın kullanılmasının devri

Âdi kira sözleşmesiyle, kiralayan kira konusu şeyin kullanılmasını kiracıya devreder. Yukarıda da ifade edildiği gibi, devredilen kullanma hakkı şahsî nitelikte bir haktır; kiracı, satışda olduğu gibi kiralanan şeyin maliki olmaz. Kiracı, kiralananın kendisine teslimiyle fer'i zilyet (MK m. 974) olur[8] ve zilyetliğe bağlı savunma vasıtalarını (MK m. 981 vd) kullanabilir.

Kiracıya devredilen kullanma hakkı, kira süresiyle sınırlı olup, kiracı kira sözleşmesinin sona ermesiyle kiralananı kiralayana iade etmekle yükümlüdür (TBK m. 334/I).

Kiralayanın kullanmayı devir borcu, sadece kiralananın teslimiyle yerine getirilmiş olmaz; kiralayan, aynı zamanda, kira sözleşmesinin devamı esnasında kiralanan şeyi kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurmakla da yükümlüdür[9].

3. Kira parası

Kira sözleşmesi niteliği itibariyle ivazlı bir sözleşmedir; kiralananı kullanma karşılığında bir miktar para ödemek, kiracının aslî edim yükümlerindendir (TBK m. 299). Kira parası ödeme veya ivaz unsuru, kirayı kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmelerinden ayırır.

Kira parasının altın (aynen veya değer) olarak[10] veya yabancı para ile kararlaştırılması mümkündür: "Yabancı ülke paralarıyla ilgili yasa ve kararnamelerdeki sınırlayıcı hükümler, bugün için yürürlükte bulunmadığından; döviz ile kira parasının belirlenmesi serbest olup, kira parası ödeme borcunun dövizle ödenmesi hususundaki engeller ortadan kaldırılmıştır. Yabancı para üzerinden kira parası borcunun temerrüt faizine, Devlet bankalarının, o yabancı para ile açılmış bir yıllık vâdeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir. Kiralayan, yabancı para üzerinden kira parasının aynen ödenmesini istemekle; kiracı yabancı para üzerinden kira parasını ay-

---

7 **Yavuz**, sh. 241.

8 3.HD, 19.12.1983, E. 4525/K. 5037 (YKD 1984, sh. 369).

9 OR-**Weber/Zihlmann**, Art. 253, N. 3; **Tandoğan** I/2, sh. 12.

10 HGK, 17.6.1987, E. 13-734/K. 517 (**Yavuz**, sh. 243, dn. 6a).

nen veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ödemek suretiyle borcundan kurtulabilir"[11].

Kira bedeli, normal olarak, bir miktar para şeklinde kararlaştırılır. Ancak kira bedelinin paradan başka bir edim (meselâ, hizmet edimi veya kiralananın tamiri) şeklinde kararlaştırılması halinde, bir karma sözleşme karşısında bulunulur[12].

Taraflar, kira sözleşmesinde kullanmanın bir ücret karşılığında olduğu hususunda anlaşıp, kira parasının miktarını belirlememişlerse veya bu miktar objektif olarak belirlenebilir değilse, sorunun aşağıdaki şekilde çözümlenmesi gerekir: Taraflar sözleşme müzakereleri esnasında kira miktarı üzerinde anlaşamamışlarsa, TBK m.1 gereğince, kira sözleşmesinin kurulmamış olduğu sonucuna varmak gerekir[13]. Tarafların kira miktarını sükûtla geçmeleri veya bunu saklı tutup ileriye bırakmaları, kira miktarı ikinci derecede değil, esaslı bir nokta olduğu için, TBK m.2 hükmü uygulanmaz[14]. Kira miktarı tesbit edilmeden kiralananın kiracıya teslim edilmesi, kira sözleşmesini geçerli kılmaz; böyle bir durumda, sadece kullanılan döneme ilişkin kira bedelinin yargıç tarafından dürüstlük kuralına göre belirleneceğini kabul etmek gerekir[15]. Özellikle kiralananın kiracıya teslim edilmesi halinde, kiralayan kendisine ödenen kira bedelini itirazsız kabul etmediği takdirde, sadece kullanılan döneme ilişkin kira bedelinin dürüstlük kuralına göre yargıç tarafından belirlenebileceğini sonucuna varılmalıdır[16].

İsviçre Federal Mahkemesi, 24.9.1974 tarihli kararında, tarafların bir şeyin kullanılmasının ücret karşılığında devri konusunda, kira miktarını tesbit etmeksizin, anlaşmaları halinde, eksik bir sözleşmenin bulunduğu ve anlaşmazlık halinde hâkimin sözleşmeyi tamamlayacağı

---

11 3.HD, 11.3.1996, E. 716/K. 3055 (YKD 1996, sh. 536).

12 **Reymond**, sh. 205; **Tercier**, N. 1744. 6.HD, 23.5.1980, E. 683/K. 5353 (YKD 1981, sh. 40): "Kira karşılığı kural olarak paradır. Ancak, bu bedel, paradan başka bir şey, örneğin, bir mal, bir hizmet akdi, bir şey imal etmek (istisna akdi) gibi şeyler de olabilir".

13 **Honsell**, sh. 204; OR-**Weber/Zihlmann**, Art. 253, N. 6

14 **Merz**, ZBJV 112/1976, sh. 100-101; **Jeanprêtre**, JdT 1975 I, sh. 612 vd.; **Engel**, sh. 153 vd.

15 OR-**Weber/Zihlmann**, N.6; **Engel**, sh. 163; **Hansell**, sh. 204.

16 **Honsell**, sh. 187.

içtihadında bulunmuştur[17]; Federal Mahkeme, bu kararında, TBK m. 2 hükmünden söz etmeden, eser sözleşmesinde değere göre bedeli düzenleyen TBK m. 481 ve vekâlete ilişkin olan 502/II'de öngörülen genel hukuk kurallarının, kirada da uygulanabileceğini kabul etmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi, bu karara karşı doktrinde yapılan eleştirileri[18] haklı bulan 15.9.1993 tarihli kararında, tarafların kira miktarını tesbit etmedikleri hallerde, kira sözleşmesinin henüz kurulmadığını ve daha önce gerçekleşen kullanma süresi için ödenecek ücretin hâkim tarafından belirlenebileceğini kabul etmiştir[19].

Taraflar, kira sözleşmesinin kurulması esnasında kira parasını akit serbestisi ilkesi gereğince (TBK m.26) serbestçe kararlaştırabilirler. Bu serbesti, sadece gabine ilişkin genel kurallarla (TBK m. 28) sınırlandırılmıştır[20]. Bunun dışında, kiracı başlangıçta tesbit edilen kira parasına itirazda bulunamaz. Zira ülkemizde, kiracıyı başlangıçta tesbit edilen aşırı kira parasına karşı koruyan bir hüküm bulunmamaktadır ve kiracı sözleşmeyle öngörülen kira süresi içinde bununla bağlıdır. Meğer ki, işlem temelinin çökmesi (MK m. 2) söz konusu olsun.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında TBK m. 346* hükmüyle kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka ödeme yükümü getirilemeyeceği; özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde cezai şart ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmanın geçersiz olduğu ifade edilmiştir[21].

---

17 BGE 100 II 330 yahut JdT 1975 I 609 vd.

18 **Jeanprêtre**, JdT 1975 I 610 vd; **Merz**, ZBJV 112/1976, sh. 99 vd.

19 BGE 119 II 347 vd. Ayrıca bk. 108 II 112 vd, Erw. 4.

20 Yarg. İBK, 21.12.1966, E. 19/K. 10 (RG. 12490).

21 TBK m. 346 hükmü kiracının tacir olarak sayılan kişiler için 01.07.2012 tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle uygulanamayacağından taraflar arasında kurulan sözleşmede muacceliyet şartına yer verilmişse, sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri uygulanır (6. HD. 6.3.2013 tarih E. 2013/663 K. 2013/3867 –Kazancı-.

§ 19. KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE SÜRESİ

I. Kira sözleşmesinin tarafları

1. Kiralayan

Fiil ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi, kiralayan sıfatıyla kira sözleşmesini kurabilir. Mümeyyiz küçük veya kısıtlılar, kanunî temsilcilerinin rızasıyla kira sözleşmesi yapabilirler. Bu gibi kişilerin bir yıl veya daha uzun süreli ürün (hasılat) kirası ve üç yıl veya daha fazla süreli taşınmaz kira sözleşmesi kurmaları halinde, ayrıca vesayet makamının iznine ihtiyaç vardır (MK m. 462/b.6).

Kiralayanın kiralanan şeyin maliki olması gerekli değildir; onun kiralananın kullanılmasını başkasına devir yetkisini veren bir hakka sahip olması (alt kira kurmaya yetkili kiracı gibi) yeterlidir[1]. Böyle bir yetkiye sahip olmayan kiralayanın yaptığı kira sözleşmesi geçerli olmakla beraber, kiralananı teslim edemediği veya akit süresince kullanmaya hazır halde bulunduramadığı takdirde kiracının müsbet zararını tazminle yükümlü olur[2].

Paylı malikler, sahip oldukları şeyi birlikte kiraya verebilirler. Bu takdirde, bölünemeyen bir borç (TBK m. 85) söz konusu olduğundan, hepsi birlikte sorumlu olunur. Kiraya verme işi MK m. 691/I'de önemli idarî tasarruflardan sayılmış[3] ve kira sözleşmesinin yapılması veya bunun feshi için, pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekli görülmüştür. Gerekli çoğunluk kararı bulunmadan, bir veya birkaç paydaş, müşterek malı bütün paydaşlar adına kiraya vermişlerse, yetkisiz temsil hükümleri (TBK m. 46-48) uygulanır; sadece kendi adlarına kiraya vermişlerse, kira akdi geçerli olur, diğer paydaşların kiracının kullanmasına engel olması halinde, kiralayanlar borcun yerine getirilmemesinden sorumlu olurlar[4].

---

1 **Tercier**, N. 1033.

2 **Tandoğan** I/2, sh. 105; **Zevkliler**, sh. 151; 13.HD, 3.10.1977, E. 3688/K. 4249 (YKD 1978, sh. 243).

3 Yarg. İBK, 27.11.1946, E. 28/K. 15 (RG. 21.4.1947, S. 1588).

4 **Oğuzman/Seliçi**, Eşya Hukuku, 6. bası, sh. 302-303; **Tandoğan**, I/2, sh. 106-107; **Zevkliler**, sh. 152.

Elbirliği mülkiyetine konu olan şeyin kiralanmasında, elbirliğini doğuran sözleşme veya kanun hükümleri uygulanır (MK m. 702/I). Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, maliklerin hepsinin oybirliği ile kiraya verilebilir (MK m. 702/II). Buna göre, maliklerden biri veya bir kaçı yetkisiz olarak diğerleri adına da hareket etmişlerse, onlar icazet vermezlerse sözleşme geçersiz olur; sadece kendi adlarına kira sözleşmesi yapmışlarsa, diğerlerinin kiracının kullanmasına engel olmaları halinde, onlar kiracıya karşı sorumlu olurlar[5].

2. Kiracı

Fiil ehliyetine sahip her hukuk süjesi kiracı sıfatıyla kira akdi kurabilir; mümeyyiz küçük veya mahcurlar açısından, kiralayan hakkında yukarıda belirtilen sınırlamalar kiracılar için de geçerlidir.

Yeni Medenî Kanun eşlerin birlikte oturacakları konutu (aile konutunu) seçme hakkını eşlere tanımıştır. Gerçekten MK m. 186/I'e göre, "eşler oturacakları konutu birlikte seçerler", Aile konutu için ev kiralanması MK m. 188/II anlamında, "ailenin diğer ihtiyaçlarından" sayıldığı için[6], eşlerden birinin evlilik birliğini temsilen kira sözleşmesi kurabilmesi ancak aşağıdaki hallerde mümkün olur[7]: 1) Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından onun yetkili kılınması (MK. m.188/II, b.1), 2) Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunması ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızasının alınamaması (MK m.188/II, b.2). MK m.194/IV'e göre, "Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur". Bu takdirde, kiraya veren fesih bildirimi ile fesih ihtarı bağlı ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır (TBK m. 349/III). Aynı şekilde, eşlerden biri, diğer eşin rızası bulunmadan aile konutuna ilişkin kira sözleşmesini feshedemez (MK. m.194/I).

---

5 **Tandoğan** I/2, sh. 108; **Zevkliler**, sh. 153.

6 **Hasanböhler**, Zürcher Kommentar zum ZGB, Art. 166 N.40 ve orada zikredilenler; **Akıntürk** Aile Hukuku, İstanbul 2002, sh. 117.

7 bk. **Engel**, Contrats de droit suisse Bern 2000, sh. 141-142.

Birden çok kimsenin birlikte kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapmaları halinde, sözleşmede açık bir hüküm bulunmuyorsa, Yargıtay'a göre[8], her kiracı kendi payına düşen kira borcundan sorumludur. *Schmid*'e göre bu hususta kanunda bir boşluk bulunmaktadır ve bu boşluğun, TBK m. 382 ve 567'nin kıyasen uygulanarak doldurulması suretiyle, aksi açıkça öngörülmedikçe, kiracıların müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekir[9]. TBK m. 162 gereğince müteselsil borçluluk ancak kanun veya sözleşmeden doğabileceği için, bu görüşe katılmak mümkün değildir[10]. Bununla beraber, birden çok kişinin kiracı sıfatıyla müteselsil borç iradelerinin, sözleşmenin yorumundan, durumun özelliklerinden ve dolayısıyla onların örtülü irade beyanından anlaşılması da mümkündür. Örtülü de olsa müteselsil borç iradesinin hal ve şartlardan açık ve kesin olarak anlaşılması yeterlidir[11].

Kira sözleşmesinde kiracı sıfatını taşıyan birden çok kişinin bulunması halinde, kural olarak, ihtar zorunluluğu varsa; ihtarın tüm kiracılara gönderilmesi ve tahliye davasının, aralarında dava arkadaşlığı bulunduğu kabul edilen bütün kiracılara birden yöneltilmesi gerekmektedir[12]. Buna karşılık, kiracılar arasında teselsülün bulunduğu hallerde, kiracılardan birine gönderilecek ihtarın veya biri aleyhine açılacak tahliye davasının diğer kiracılar için de hüküm doğuracağı sonucuna varılmaktadır[13]. Ticarî bir kira söz konusu olduğu takdirde, TTK m. 7/I gereğince aksi kararlaştırılmadıkça, kiracılar müteselsilen sorumlu olurlar.

---

8 12.HD, 7.2.1981, E. 7888/K. 9307 (YKD 1982, sh. 370 vd.); 12.HD, 9.12.1982, E. 9039/K. 9255 (YKD 1983, sh. 1343-1344).

9 **Schmid**, Art. 253, N. 19. Ayrıca bk. **Tercier**, N. 1037.

10 **Zevkliler**, sh. 153.

11 **Eren**, C. III, sh. 390; **Gauch/Schluep**, II, N. 2397. Ayrıca bk. **Tandoğan,** I/2, sh. 109: "Çoğu zaman halin icaplarından (ortaklaşa kullanma, tek bir kira parası tesbiti ve diğer belirtilerden) kiracıların müteselsilen sorumlu olmak iradesi bulunduğu çıkarılabilir" Karş. **Zevkliler**, sh. 153.

12 **Tandoğan,** I/2, sh. 109; **Burcuoğlu**, sh. 78; Yarg. 12.HD, 9.12.1982, E.9039/K. 9255 (YKD 1983, sh. 1343-1344); 12.HD, 1.10.1985, E. 1788/K. 7616 (**Uyar**, Tahliye, sh. 82).

13 **Burcuoğlu**, sh. 79-80; Yarg. 6.HD, 31.5.1991, E. 7013/K. 7688 (YKD 1991, sh. 1328-1329). Farklı yönde: 6.HD, 17.10.1983, E. 9600/K. 9793 (**Burcuoğlu,** sh. 80-81).

II. Kira sözleşmesinin şekli

Kira sözleşmesinin kurulması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır; kural olarak, sözlü olarak veya delâlet edici bir irade beyanıyla (zımnen) kurulabilir[14]. Bununla beraber, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m. 57 gereğince, kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlara ilişkin kira sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenip noterce tasdik edilmesi gerekir. FSEK m. 50'ye göre lisans sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 86. maddesine göre ihtira beratına ilişkin hakkın kullanımının devri yazılı şekil şartı gerekmektedir. Yargıtay, bu hükümde öngörülen şekli geçerlilik şartı olarak değerlendirmektedir[15]. Aynı şekilde, 2290 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu m. 119'a göre, hava araçları kirası yazılı bir şekilde yapılmadıkça geçerli değildir.

III. Kira sözleşmesinin süresi

Kira sözleşmesinde kiralananın kullanılması belirli bir süre için kiracıya devredilir. Ancak, kira sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların kira süresini belirlemiş olmaları şart değildir; kira süresinin belirlenmesi sözleşmenin kurulması için zorunlu bir unsur olmayıp, kira sözleşmesinin sona ermesi açısından önem taşımakta ve bu nedenle kanunda bunun düzenlenme zorunluluğu doğmuştur.

1. Genel hükümlere tâbi kiralarda

TBK'nın kira süresi kenar başlığını taşıyan 300. maddesine göre, kira sözleşmesi, belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir (f.I). Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmadan sona erecek kira sözleşmeleri belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır (f.II).

a) Belirli süreli kira sözleşmesi

Bu tür kira sözleşmesi, fesih beyanına gerek olmadan, kararlaştırılan sürenin dolmasıyla sona erer. Kira sözleşmesinin süresini taraflar açık veya örtülü irade beyanlarıyla belirleyebilirler. Bu belirleme gün, ay veya sene olarak yahut belirli bir tarih şeklinde yapılabilir. Mesela,

---

[14] **Tercier**, N. 1045; **Engel**, sh. 131; **Tandoğan** I/2, sh. 92-93; **Zevkliler**, sh. 94; BGE 100 II 18; 12.HD, 5.11.1980, E. 6588/K. 7848 (YKD 1981, sh. 65-66).

[15] **Tandoğan,** I/2, sh. 93, dn. 207'deki Yargıtay kararları.

kira sözleşmesi on ay süre ile kurulmuştur; bir motorlu aracın 1 Ağustos- 20 Ağustos 2012 günleri için kiralanması[16]. Aynı şekilde, sözleşme süresi, kira sözleşmesinin amacına göre de belirlenebilir. Mesela, bir vincin inşaatın yapımı süresince kiraya verilmesi; nikâh töreninin görüntülenmesi için bir kameranın kiralanması. Buna karşılık, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kiraya verilecek taşınır veya taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz; turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür (m. 64/I).

Belirli süreli kira sözleşmesi ancak olağanüstü fesih yoluyla veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilebilir[17]. Belirli süreli kira sözleşmesi, tarafların süre sonunda kira sözleşmesine örtülü olarak devam etmeleri yani zımnen yenilemeleri halinde, belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüşmüş olur (TBK m. 327/II).

Hâkim fikre göre[18], TBK m. 327'ye göre gerçekleşen yenilemede, eski kira sözleşmesinin uzatılması değil, içeriğini eski sözleşmeden alan yeni bir sözleşmenin zımnen yapılması söz konusudur. Bu sebeple, yenileme zamanında tarafların ehil olmaları şarttır. Yenileme ile kiracının eski sözleşmeden doğan borçları için verilmiş olan teminat ortadan kalkar. Bu kural, özellikle kefalet ve üçüncü kişinin kiracı lehine verdiği rehin için uygulanır. Buna karşılık kiracının kendisinin verdiği rehinin devam etmesinin normal olarak tarafların iradesine uygun olacağı kabul edilmelidir; eğer rehin kurulmasının şeklî şartları mevcutsa, yani taşınır şeyin ve hâmiline yazılı senedin zilyetliği kiralayanda kalmakta devam etmişse, tarafların bu iradesi hüküm ifade eder; alacak rehninde ise yeni bir yazılı beyana ihtiyaç vardır. Aynı şekilde, yenileme halinde eski sözleşme ortadan kalkmış olduğundan, eski sözleşme zamanında doğmuş ve ödenmemiş kira bedellerinden dolayı yeni sözleşme feshedilemez[19].

---

16 **Müller-Chen/ Girsberger/ Furrer**, BT, sh. 130.

17 **OR- Weber,** Art. 255, N. 2; **Müller-Chen/ Girsberger/ Furrer**, BT, sh. 130; **Gümüş**, sh. 33.

18 **Oser/Schönenberger**, Art. 268, N. 3; **Becker**, Art. 268, N. 2; **Guhl/Merz/ Kummer**, sh. 351/2; **Tandoğan** I/2, sh. 101; **Zevkliler**, sh. 228-229.

19 **Tandoğan** I/2, sh. 102; **Zevkliler**, sh. 229.

Buna karşılık, *Schmid*[20] ve *Reymond*[21] hâkim fikre karşı çıkmakta ve yenileme halinde yeni bir sözleşme kurulmadığını, mevcut sözleşmenin devam ettiğini ileri sürmektedir.

b) Belirsiz süreli kira sözleşmesi

Belirli süreli kira sözleşmelerinin dışında kalan, yani belirli bir süre içermeyen diğer bütün kira sözleşmeleri belirsiz süreli sayılır (TBK 300/II). Buna göre, taraflar sözleşmede süre konusunda sessiz kalmışlarsa veya belirsiz süreli bir sözleşme kurduklarını açıkça ifade etmişlerse, ortada belirsiz süreli bir kira sözleşmesinin bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Belirsiz süreli kira sözleşmesi, hem fesih bildirimi (TBK m. 328) hem olağanüstü fesih yoluyla (TBK m. 330) veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilebilir[22].

2. Konut ve çatılı işyeri kiralarında

Konut ve çatılı işyerine ilişkin kira sözleşmesi de belirli veya belirsiz süreli olarak kurulabilir. TBK m. 347/I*'e göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin biriminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı şartlarla uzatılmış sayılır. Oysa kiraya veren için böyle bir hak tanınmamıştır. Ancak kiraya veren on yıllık uzama süresinin sonunda, bu süreyi takip eden her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak suretiyle, herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir[23].

Buna karşılık, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından evvel on yıl geçtikten

---

20 **Schmid**, Art. 268, N. 8 vd.

21 **Reymond**, sh. 231.

22 **Müller-Chen/ Girsberger/ Furrer**, BT, sh. 130 N. 11; **OR- Weber,** Art. 255, N. 2; **Gümüş**, sh. 34- 35.

23 4.2.2011 tarih ve 27836 sayılı R.G' de yayımlanan 12.1.2011 tarih ve 6101 sayılı Kanun'un Geçici 2. Maddesi hükmü gereğince "Bu Kanunun 1 inci maddesinin son cümlesi hükmü bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl; on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.".

sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir (TBK m. 347/ III).

Fesih hakkının genel hükümlere doğduğu hallerde bu hak kendisine terettüp eden taraf sözleşmeyi fesih edebilir (TBK m. 347/III).

IV. Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı ve kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler

1. Genel olarak

Türk Borçlar Kanunu'nun kiraya ilişkin hükümlerini içeren dördüncü bölümünün ikinci ayrımında konut ve çatılı işyerleri ile ilgili düzenlemeler (m. 339-356) yer almaktadır. Konut ve çatılı işyeri kirasına ait bu hükümlerden bazıları (m. 339, 340, 341 ve 342) İsviçre Borçlar Kanunundaki maddeler göz önünde tutularak kaleme alınmıştır. Bunların dışında kalan hükümler, esas itibariyle 6570 sayılı GKK'daki düzenlemelere dayanılarak yapılandırılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, genel hükümler içinde (m. 299 vd.) de konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ancak TBK'nın kiraya ilişkin hükümlerinde konut ve çatılı işyeri kavramları tanımlanmamış bulunmaktadır. Bunun yanında, işyeri kirası deyiminin önünde çatılı sıfatının kullanılması isabetli bir tercih değildir; çatılı kelimesi yerine üstü örtülü ifadesine yer vermek gerekir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin ikinci ayrım hükümlerinin uygulama alanı 339. maddesine göre, "konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz". Böylece, konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler, kiralananla birlikte kullanılması kiracıya bırakılan eşyalar hakkında da uygulanır. Burada kullanılan eşya kavramına, mobilya, fırın ve bulaşık makineleri, garaj, bahçe ve benzerleri girer. Kiralanan yer ile bu eşyalar arasında kullanım bakımından fonksiyonel (işlevsel) bir bağlantı veya iç ilişkinin bulunması gereklidir[24]. Buna karşılık, geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha az süreli kiralanması hali bu hükümlerin kapsamı dışında bırakılmıştır.

---

[24] **OR- Weber,** Art. 253a, N. 15; Bohnet/ Dietschi, art. 253a, n. 16 vd; **Gümüş,** sh. 20; BGE 125 III 231 yahut JdT 1999 I sh. 107.

2. Konut kavramı

Bir yerin, kira ile ilgili hükümler çerçevesinde konut olarak kabul edilebilmesi için, onun kişilerin sürekli oturması amacıyla kiralanması gerekir. Kiralanan konutun, MK m. 19 vd. anlamında yerleşim yeri (ikâmetgâh) niteliği taşıması gerekli değildir. Burada önemli olan, kiracının uyumak vb. ihtiyaçlarını karşılayan, günübirlik niteliği taşımayan ve onu dış etkenlerden koruyacak bir mekan niteliğinin bulunmasıdır. Bu bağlamda, kira konusu konutun dış yapısı değil, sözleşme ile öngörülen kullanım amacı ilk planda belirleyicidir[25]. Kiralanan konut möbleli veya möblesiz bir daire veya oda olabilir; kiralanan yerin mutfak ve tuvalet gibi her türlü günlük ihtiyaçları sağlayacak nitelikte olması gerekli görülmemektedir[26]. Bir çadırın, birden fazla kişinin kaldığı barakanın veya yurtta bir yatma yerinin kullanılmasının devri halinde konut kirası söz konusu olamaz[27].

3. Çatılı işyeri kavramı

İktisadi ve ticari nitelikte bir teşebbüsün işletilmesine veya bir mesleğin icrasına özgülenmiş yerlere ilişkin kira sözleşmesi işyeri kirası sayılır[28]. Aynı şekilde yapılacak bu faaliyetlerin gelir elde etme amacına yönelik olması gerekir[29]. Bu cümleden olarak büro, mağaza, muayenehane, atölye, depo ve ardiye kiraları işyeri kirası sayılır.

Kiralanan yerin sağlam bir şekilde toprağa bağlı, üstü örtülü ve etrafı dikey ve yatay olarak kapalı olması gerekir[30].

4. Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler

TBK'nın bağlantılı sözleşme başlıklı 340. maddesine göre, "konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi,

---

25 **OR-Weber,** Art. 253 a/ 253 b, N. 4; **Honsell,** s. 209; **CR, Lachat,** Art. 253 N. 1; **Bonnet/Dietschy,** Art. 253, N. 3; **Gümüş,** s. 15.

26 **OR- Weber,** Art. 253a/ 253b, N. 4; **Honsell,** s. 209; **Gümüş,** sh. 16.

27 **Gümüş,** sh. 15; **OR-Weber,** Art. 253 a, N. 4

28 **OR- Weber,** Art. 253 a/ 253 b, N. 4; **Bonnet/Dietschy,** Art. 253a, N. 10; **Tercier/ Favre,** N. 2006; **Gümüş,** s. 16- 17.

29 **Bonnet/Dietschy,** Art. 253a, N. 11; **Tercier/Favre,** N. 2006; **Higi,** Art. 253a/ 253b, N. 31.

30 **Bonnet/Dietschy,** art. 253a, N. 6 vd.; Bir arsanın restaurant olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi halinde üzerinde çatılı işyeri vasfını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi ve buna göre ilgili hükümlerin uygulanması gerekmektedir (6. HD. 2014/3948 E. 2014/5071 K. –Kazancı-).

kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir". Metinde de açıkça ifade edildiği gibi, bu hüküm, sadece konut veya çatılı işyeri kiralarında uygulanır. Bu hükmün amacı, kiraya verenin, kiracının kiralanan yere olan ihtiyacını fırsat bilerek ve böylece elde ettiği baskın durumu bir istismar aracı olarak kullanmak suretiyle, kirayla bağlantılı sözleşme yapılmasına neden olmasını yasaklamaktır.

TBK m. 340 uyarınca, kirayla bağlantılı sözleşmenin geçersiz sayılabilmesi ve bu madde hükmünün uygulanabilmesi için, aşağıdaki şartların birlikte bulunması gerekir:

a) Kira sözleşmesinin konut veya çatılı işyerlerine ilişkin olması gerekir. Başka bir ifade ile, bağlantılı sözleşmenin bu tür bir kira sözleşmesi bağlamında yapılmış olması gerekir. Bu cümleden olarak, taşınır kiraları, açık otopark kirası veya arazi kiraları, TBK m. 340 kapsamına girmez[31].

b) Kira sözleşmesinin kurulması ve devamının başka bir sözleşmenin kurulmasına bağlı tutulması gerekir. Öyle ki, bağlantılı sözleşmenin yapılması kira sözleşmesinin kurulması ve devamının "olmasa olmaz (condictio sine qua non)" şartı teşkil etmelidir. Bu anlamda bağlantılı sözleşmenin kiracıyla kiraya veren arasında veya kiracı ile üçüncü bir kişi arasında yapılmış olması önemli değildir. İsviçre Borçlar Kanunu m. 254'te açıkça belirtilen bu hususun, TBK m. 340'da ifade edilmemiş olması, varılan sonucu değiştirmez[32]. Nitekim TBK m. 340 gerekçesinde, bağlantılı sözleşmenin geçersizliği açısından bu borçlanmanın, kiraya veren veya üçüncü kişiye karşı olmasında fark yoktur denilmektedir.

c) Bağlantılı sözleşme ile kiracının kiralananın kullanılması ile doğrudan bir ilişkisi bulunmayan bir borç altına girmesi gerekir. Kiracının kiralananı satın alma, eski kiracıya ait mobilyaları satın alma veya bir sigorta sözleşmesi yapma borçları altına girme zorunluluğunda bırakıldığı hallerde, kiralananın kullanılmasıyla doğrudan ilişkinin bulunmadığı sonucuna varılmalıdır[33].

---

31 **OR-Weber,** Art. 254 N. 1; **Gümüş**, sh. 40.

32 Aynı görüşte: **Gümüş**, sh. 40; **Yavuz**, sh. 263.

33 **CR-OR, Lachat,** Art. 254 n. 5; **Yavuz**, s. 262; BGE 118 III 157 erw.3c.

d) Bağlantılı sözleşmenin yapılmasında kiracının bir yararı bulunmamalıdır. İsviçre BK m. 254'te bağlantılı sözleşmenin geçersizliği için kiracının yararının bulunmaması şartından söz edilmemektedir. Bu durumda, Türk Hukuku'nda kiralananın kullanılması ile doğrudan ilişkinin bulunmaması şartına, kiracının yararının olmaması şartı da eklenmiş bulunmaktadır[34].

Yukarıda açıklanan şartların bulunması halinde, bağlantılı sözleşmenin geçersizlik yaptırımına tabi olacağı TBK m. 340'da ifade edilmiş bulunmaktadır. Burada, bağlantılı sözleşme için butlan yaptırımı söz konusu olup, yargıç tarafından re'sen (kendiliğinden) nazara alınır; butlan sebebi ile bağlantılı sözleşmenin geçersizliği geçmişe etkili sonuçlar doğurur. Bu durumda, kısmi butlan bulunduğundan, kira sözleşmesi geçerliliğini korur[35]. Daha önce yerine getirilmiş edimlerin sözleşme hükümlerine göre gerçekleşmesi gerekir[36].

---

[34] **Yavuz**, sh. 263.

[35] **Tercier/Favre,** n. 1980; **Bohnet/Buverat,** Art. 254 n. 40.

[36] **OR- Weber,** Art. 254 N. 6; **Gümüş,** sh. 45.

§ 20. KİRAYA VERENİN BORÇLARI

I. Kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına elverişli şekilde teslim ve bu halde bulundurma borcu

TBK m. 301/c.1 gereğince, kiraya veren kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına elverişli şekilde teslim etmek ve kira süresince bu halde tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kiralananın teslim borcunu ve ayıptan sorumluluğu içinde barındırmaktadır.

1. Teslim borcu

Kiraya veren, kira konusu şeyi sözleşmeyle öngörülen kullanılmaya elverişli bir şekilde teslim etmek zorundadır. Kiralananın kiracının taşınmasına imkân verecek bir halde bulundurulduğu anda teslim borcu yerine getirilmiş olur[1]. Aynı şekilde, kiracıya ortak yerlerden ve araçlardan yararlanma imkânının sağlanması gerekir[2].

Teslim borcunun sözleşmede öngörülen tarihte gerçekleşmesi gerekir; kural olarak, aksi kararlaştırılmadıkça, kiraya veren teslim borcunu kiracıdan önce ifa eder[3]. Teslim zamanının sözleşmeyle belirlenmediği hallerde teslim borcu ile kira bedeli alacağına ilişkin borç aynı anda doğar. Bu nedenle teslim borcu yerine getirilmedikçe kiracı kira bedeline ilişkin olarak ödemezlik defi ileri sürebilir.

Teslim zilyetliğin devri ile gerçekleşir. Zilyetlik şeyin fiilen teslimi veya şey üzerinde hakimiyet sağlayan araçların teslimi ile mümkün

---

1 **Reymond**, sh. 210-211; **Becker**, Art. 254/255, N.2; **Tandoğan** I/2, sh. 110; Kiralananın sözleşmede amaçlanan kullanım amacına elverişli durumda teslim edilmiş olması ve kira sözleşmesi süresince bu durumda bulundurulması gerekmektedir. Kullanım amacını ortadan kaldıran veya derecesini azaltan ayıp veya kusurun varlığın ispat yükü kiracıdadır. Kiracının kira konusu yerin imar planı dışında olduğu bu nedenle çalışma izni alamadığı iddiasının değerlendirilmesi için bu durumun ticari faaliyete engel olduğunun ispatlanması gerekmektedir. O nedenle ilgilinin ruhsat başvurusu yapıp yapmadığının da araştırılması gerekmektedir (6. HD. 2014/798 E. 2014/11010 K. –Kazancı-).

2 **Schmid**, Art. 253, N. 34; **Oser/Schönenberger**, Art. 254, N.4; **Tandoğan** I/2, sh. 110.

3 **Tercier**, N. 1056; **Reymond**, sh. 224.

olabilir. Ayrıca zilyetliğin havalesi, hükmen teslim veya emtiayı temsil eden senedin teslimi ile de teslim gerçekleştirilebilir.

Kiraya verenin teslim borcunu yerine getirmede temerrüde düşmesi halinde, kiracı TBK m. 123-125'de öngörülen imkânlardan yararlanabilir. Teslim borcunun yerine getirilmemesi halinde temerrüdün sonuçlarından olan ve sözleşmeyi sona erdiren dönme söz konusu olabilir. Buna karşılık teslim borcu yerine getirildikten sonra kira konusu kullanıma elverişli tutulmamışsa bu nedenle sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshi ileriye etkili sonuç doğurur. Teslim borcunun yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde TBK m. 112 veya 136 hükümleri uygulanır[4]. Buna karşılık, kiralananın sözleşmeyle öngörülen kullanmaya elverişli bir şekilde teslim edilmemesi halinde ayıba karşı tekeffülden doğan sorumluluk (TBK m. 304) söz konusu olur[5].

2. Kiralananı sözleşme süresince öngörülen kullanma amacına uygun halde bulundurma borcu

Kiraya verenin bu borcu, kira sözleşmesinin devamlı bir borç ilişkisi doğurmasının tabiî bir sonucudur[6]. Bu cümleden olarak, kiraya veren, kira süresi içinde kiracının kiralananı kullanmasını engelleyen veya sınırlayan hususları gidermek zorundadır[7].

Kiraya verenin bu borcunu ihlal etmesi, ayıptan doğan sorumluluk hükümleri gereğince (TBK m. 304) sorumlu olması sonucunu doğurur[8].

II. Ayıptan doğan sorumluluk

Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu TBK m. 304, 305 ve 306'da düzenlenmiştir. Kiralananın sözleşmeyle öngörülen kullanma amacına uygun nitelik taşıması, yani onun vasıfları, kiraya verenin edim yükümünün kapsamına dahildir[9].

---

4 **Reymond**, sh, 211; **Tercier**, N. 1057-1058; **Tandoğan** I/2, sh. 110; **Yavuz**, sh. 263; BGE 97 II 58 vd; HGK, 7.4.1993, E. 13-45/K. 153 (YKD 1993, sh. 840 vd.).

5 **Tercier**, N. 1059-1060, **Yavuz**, sh. 263-264.

6 **Tercier**, N. 1061; OR-**Weber/Zihlmann**, Art. 256, N. 3; **Yavuz**, sh. 264; **Bucher**, BT, sh. 166, 177.

7 **Bucher**, BT, sh. 166.

8 **Tercier**, N. 1064; **Yavuz**, sh. 265.

9 Bk. **Tercier**, N. 1070; **Reymond**, sh. 212-213.

1. Esasa ilişkin şartlar

a) Kiralanan ayıplı olmalıdır

Kira sözleşmesinde ayıp, kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen amaca uygun olarak kullanmasını imkânsız kılan veya önemli ölçüde azaltan vasıf eksikliklerinin bulunmasıdır (TBK m. 301/ c. 1 ve m. 306/ II). Başka bir ifadeyle kiralananın, kira sözleşmesiyle öngörülen kullanma amacına uygun vasıflardan yoksun olmasıdır. Kiraya veren, sözleşmeye uygun kullanmayı veya belirttiği nitelikleri sağlamakla yükümlüdür. Buna göre kiralanan şeydeki ayıp, vaad edilen (meselâ, konut olarak kiralanan yerin manzarasının inşaatla kapatılamayacağı, işyerinin belirli bir sürüm sağlayacağı) veya sözleşmeyle kararlaştırılan kullanma amacına göre beklenen vasıflarının bulunmaması şeklinde olabilir[10]. Sözleşmeyle öngörülen kullanma amacına elverişlilik haline, arabanın çalışır vaziyette olması, depo olarak kiralanan yerin istif edilecek malları taşıyabilecek nitelikte olması, işyerinin müşterilerin girmesine elverişli olması, konutun ikamet etmeye elverişli olması halleri zikredilebilir[11].

Kira sözleşmesindeki ayıp maddî ayıp (rutubet, su sızıntısı veya ısıtma yetersizliği) veya hukukî ayıp (iskân veya işyeri izninin bulunmaması) ya da manevî ayıp (rahatsız edici durumlar) şeklinde ortaya çıkabilir[12]. Kiralananda gürültü yapma, duman, koku yayma, kiracıya devamlı hakaret ve onu tehdit, kiralanan vitrinli dükkânın vitrini önüne devamlı olarak otomobil koymak, azgın bir köpeği girişte ve merdivenlerde boş bırakmak gibi durumlar rahatsız edici nitelikte (manevî) ayıplardandır[13].

---

[10] **Tercier/Favre,** N. 2096; **Schmid**, Art. 254/5, N.2.

[11] **Schmid**, Art. 254/5, N. 3 vd; **Tercier**, N. 1083; **Engel**, sh. 140.

[12] **Tercier**, N. 1079; **Engel**, sh. 140; **Tandoğan** I/2, sh. 112; **Zevkliler**, sh. 191; **Yavuz**, sh. 266.

[13] **Tandoğan** I/2, sh. 112; **Zevkliler**, sh. 191; **Yavuz**, sh. 266. Yarg. 13.HD, 12.4.1996, E. 3139/K. 3683 (YKD 1996, sh. 971 vd): "...Kiralayan, yalnız diğer kiracıların değil, aynı zamanda başka üçüncü kişilerin, örneğin, komşuların da kira akdinden beklenen kullanmayı azaltacak şekilde kiracısını rahatsız etmelerini önlemekle görevlidir. Bu bağlamda hemen belirtelim ki, kiracının bu gibi hallerde üçüncü kişilere karşı kendisinin bazı hukukî yollara başvurabilecek durumda olması az yukarda açıklanan kiralayanın akdî borcunu ortadan kaldırmaz. Kiralayanın malik sıfatıyla komşuluk hükümlerine dayanarak üçüncü kişilerin mülkiyet haklarını aşmalarına karşı önlem alması gerekir. Kiralananın altındaki

Kiralanandaki ayıp başlangıçtaki ayıp (sözleşmenin kurulduğu sıradaki ayıp, TBK m. 304) veya sonraki ayıp (kira akdinin devamı sırasında ortaya çıkan ayıp, TBK m. 305) şeklinde de olabilir[14]. Kira akdinin devamı esnasında ortaya çıkan ayıpların kiracının kusurundan doğması veya kiracının kiralanana zarar vermesi halinde, kiraya veren sorumlu olmaz[15]. Buna karşılık kiraya verenin kusurundan, umulmayan halden veya diğer kiracıların davranışlarından doğan ayıplardan kiralayan sorumludur[16]. Meselâ, çevrede çıkan bir yangın, su basması veya deprem sebebiyle ortaya çıkan ayıplardan kiraya veren sorumludur ve kiralanandaki bu ayıpları gidermek (onarmak) zorundadır[17]. Ancak kiralananın kiraya verenin kusuru olmadan tamamen yanması veya depremde yıkılması halinde, kira sözleşmesi TBK m. 136 gereğince sona erer ve TBK m. 306 hükmü uygulanmaz[18].

b) Kiracı ayıbı bilmemelidir

Kiracı, sözleşmenin kurulduğu anda kiralananda mevcut olduğunu bildiği veya bilmesi gereken ayıplar için kiraya verene karşı ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine başvuramaz. Bu sonuç 818 sayılı BK m. 249/ III'ün zıt kavramından çıkarılıyordu; bu fıkra hükmüne göre kiralanandaki ayıp kiracının veya kendisiyle birlikte yaşayanların yahut işçilerin sağlığı için tehlike teşkil ediyorsa, kiracı bu tehlikeyi sözleşme kurulurken bilse veya fesih hakkından feragat etmiş olsa dahi kira sözleşmesini feshedebilir. TBK 249/III hükmü, TBK'ya alınma-

---

dairenin randevu evi olarak kullanılması nedeni ile yapılan bir ihbarı değerlendiren ahlak zabıtasının, evde fuhuş yapıldığını suçüstü yapmak suretiyle tesbit ettiği, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı'nın 19.1.1994 tarih ve 23 sayılı kararıyla da 25.1.1994 tarihinde kapısının mühürlendiğini, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yazısı ile belirlenmiştir. Bu olgu karşısında, davacı kiralayanın anlatılan BK.nun 249. maddesindeki akde uygun şekilde kiralananı teslim ve koruma borcunu ağır bir şekilde ihlâl ettiğinde kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır. Bu durumda, davalı kiracının öğrenci olarak okuyan iki genç kızlarının içtimai, sosyal ve ahlâkî durumlarının tehlikeye maruz kalmamasını temin amaç ve düşüncesiyle akdi fesihde haklı olduğunun kabulü zorunludur." (YKD 1996, sh. 972-973).

14 **Tercier**, N. 1079; **Engel**, sh. 140; OR-**Weber/Zihlmann**, Art. 258, N.4.

15 **Reymond**, sh. 214; **Tercier**, N. 1079, 1084; **Zevkliler**, sh. 192.

16 **Tercier**, N. 1084.

17 **Zevkliler**, sh. 192; HGK, 30.9.1981, E. 3-372/K. 657 (YKD 1981, sh. 1544).

18 **Tandoğan** I/2, sh. 120; **Zevkliler** sh. 192; 13.HD, 24.12.1979, E. 14866/ K. 14804 (YKD 1985, sh. 1015-1018).

mıştır. Buna rağmen, kiracının kira sözleşmesinin kurulduğu anda bildiği veya bilmesi gereken ayıplardan kiraya verenin sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda kiracının ayıptan doğan haklarından feragat ettiğini kabul etmek gerekir. Zira kiracının sözleşme kurulurken bildiği ayıpları sonradan ileri sürmesi çelişkili bir davranış sayılır ve TMK m. 2/ II anlamında hakkın kötüye kullanılması durumunu teşkil eder. Ayrıca böyle bir durumda sözleşmenin kurulduğu esnada bilinen ayıplardan sorumlu olunamayacağını düzenleyen TBK m. 222 hükmü kıyas yoluyla uygulanabilir[19]. Sağlık yönünden tehlike teşkil eden ayıplarda feragatin TMK m. 23'e aykırılık sebebiyle geçerli sayılamayacağı sonucuna varılmalıdır[20].

c) Kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan bir sözleşme kaydı bulunmamalıdır

TBK m. 301/ c. 2'de kira sözleşmesinin tarafları arasında, kiraya verenin kiralananın ayıplı olmasından doğan sorumluluğunun kaldırılması veya sınırlandırılmasına ilişkin yapacakları anlaşmalara iki önemli sınırlama getirilmiştir;

aa) Birinci sınırlama: TBK m. 301/ c. 1 hükmü, konut veya çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez. TBK m. 301/ c.2'deki sınırlama getiren hüküm emredici nitelikte olup, aksi kararlaştırılamaz.

bb) İkinci sınırlama: Konut veya çatılı işyeri kiraları dışında kalan diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşuları yoluyla TBK m. 301/ c. 1 hükmüne aykırı düzenleme yapılamaz. Buna karşılık, genel işlem koşulları yoluyla yapılmayan değişiklikler, sözleşme özgürlüğü (TBK m. 26) çerçevesinde, sorumsuzluk anlaşmasına düzenleyen TBK m. 115 ve yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluğu düzenleyen m.116'daki sınırlamalara aykırı olmamak şartıyla, gerçekleşebilir[21]. TBK m. 115'in gerekçesinde 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan hile ibaresinin ağır kusur kavramına dahil olduğu için metne alınmadığı ifade edilmiştir.

---

19 **Tercier/Favre,** N. 2105.

20 **Yavuz,** sh. 195 ve 196.

21 **Tercier/Favre,** N. 2050; **Yavuz,** sh. 197.

2. Kiracının ayıptan doğan hakları kullanmasına ilişkin (şekli) şartlar

Satış (TBK m. 223) ve eser (TBK m. 474) sözleşmelerinden farklı olarak, kira sözleşmesinde, kiracının ayıptan doğan haklarını kullanabilmesini, onun inceleme ve bildirme külfetini yerine getirmesi şartına bağlayan açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber, kiracının sözleşmenin kurulduğu veya kiralananı kullanmaya başladığı sırada bildiği ayıpları kiraya verene bildirmemesi, ayıptan doğan haklarından zımnen feragat ettiği anlamına gelir; bu tür ayıpların sonradan ileri sürülmesi dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırı olur[22]. Aynı şekilde, kiracı inceleme ve bildirme yükümünü yerine getirmediği takdirde, kiralananı iyi bir halde, yani sözleşmede öngörülen kullanma amacına uygun şekilde teslim almış sayılır[23]. Zira kiralanan ne durumda teslim alınmışsa o durumda geri verilmelidir (TBK m. 334).

Diğer yandan, TBK m. 318 düzenlemesinde inceleme ve bildirme külfetine ilişkin dolaylı bir hüküm bulunmaktadır. Kiracının kira sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkan ayıpları kiraya verene bildirmemesi halinde TBK m. 318'e göre "Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur".

3. Kiraya Verenin Ayıptan Doğan Sorumluğunun Hükümleri

TBK'nın, kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğunun hükümlerini düzenleyen TBK 304- 308 maddelerinde teslim anındaki ayıplar-sonradan ortaya çıkan ayıplar ayrımı yapılmıştır. Bu ayrımda önemli ayıp ile önemli olmayan ayıp kavramlarına da belirleyici bir işlev verilmiştir. TBK m. 304- 308 hükümleri, esas itibariyle, İsviçre Borçlar Kanunu'nun (OR) 258- 259. maddelerinden alınmıştır. Bu arada İsviçre Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerinin içeriği anlamsız bir şekilde metne dahil edilmemiştir.

---

[22] **Tercier/Favre,** N. 2109 ve 2110; **Corboz**, Sem. Jud. 1979, sh. 133; **Yavuz,** sh. 197; **Tandoğan** I/2, sh. 115-116; HGK, 30.3.1979, E. 77-13-169/K. 79-349 (YKD 1980, sh. 330-331): "Davacı kiralananı on yıldan fazla bir süreden beri tesisler kurmak suretiyle kullanmış ve taşınmazın eksik bir şekilde kendisine teslim edildiğini aynı süre içerisinde ileri sürmemiş, hatta kira parasının artırılması yolundaki ihtara cevapta kira parasının normal olduğunu bildirmiştir. Uzun süre devam eden bu fiilî durum karşısında davacının, BK.nun 249/II. maddesine dayanarak kiralanan yerin kendisine eksik teslim edildiği iddiasıyla, kira parasının indirilmesini istemesi objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz".

[23] **Reymond**, sh. 213; **Corboz**, sh. 133; **Becker**, Art. 254/5, N.9.

a) Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk

TBK m. 304'e göre "Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir (f.1)[24]. Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde ise kiracı, kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir (f. 2)". İsviçre Borçlar Kanunu'nun teslim esnasındaki ayıplardan sorumluluğu düzenleyen 258. maddesinin I. ve II. fıkralarında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

"Kiraya veren eşyayı kararlaştırılan zamanda teslim etmemişse veya onu öngörülen kullanıma elverişliliğini kaldıran veya önemli ölçüde eksilten bir ayıpla teslim etmişse, kiracı sözleşmelerin ifa edilmemesine ilişkin 107-109. madde hükümlerine başvurabilir (f.1). Kiracı bu tür ayıplara rağmen, eşyayı kabul eder ve sözleşmenin gereği gibi ifasını isterse bu takdirde ancak kiranın devamı esnasında ortaya çıkan ayıplarda sahip olduğu talepleri "OR Art. 259/b" sürebilir (f.2)".

Görüldüğü gibi, İsviçre Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeleri model olarak alan TBK m. 304/I'de, İsviçre BK m. 258/ I'de yer alan "kararlaştırılan zamanda teslim edilmemişse" ibaresine yer verilmemiş; yine İsviçre BK m. 258/ II hükmü de TBK m. 304/ II'ye değişik ve eksik bir biçimde yansıtılmıştır. TBK m. 304 hükmü değerlendirilirken bu hususun göz önünde tutulması gerekir. Zira İsviçre ve Türk Borçlar Kanunlarında (TBK m. 304; OR Art. 258) ifa etmemeyle ayıptan sorumluluk aynı şekilde ele alınmış; ifa etmeme, temerrüt ve ayıplı ifa, kanunda birlikte düzenlenmiş ve satış sözleşmesindeki gibi ifa etmeme ile ayıplı ifa arasındaki ayırım kira hukukunda kısmen terkedilmiştir[25]. Bu itibarla TBK m. 304/I hükmünün tam olarak anlaşılabilmesi için İsviçre BK m. 258/I ve II'nin göz önünde tutulması gerekir.

---

[24] Kararlaştırılandan daha az bir alana sahip kiralanan teslim edilmiş, kiracı TBK m. 304 hükmüne uygun olarak sözleşmenin feshi ya da TBK m. 305'e göre kira bedelinin indirilmesi talebinde bulunmamıştır. Kiracı eksik olan yerlerin belirli bir sürede teslim edilmesini talep etmiştir. Kiraya veren sözleşmede kararlaştırılan miktarı bedel indirimi yapılmadan talep edebilir (6. HD. 2013/8305 E. 2013/10601 K. –Kazancı-).

[25] **Honsell**, BT, sh. 215 ve 216; **Huguenin,** BT, N. 476, 477 vd.; **Perman,** in Handkomm, Art. 258, N. 1 ve 2; Ayrıca bk. **Aubert**, in: Droit du bail á loyer, art. 258, n. 1, 2- 4; **OR- Weber,** Art. 258, N. 2, sh. 1399 ve N. 6.

Kiraya veren kiralananı kararlaştırılan tarihte teslim etmemişse, yani teslim borcunu (TBK m. 301) ifada temerrüde düşerse, kiracı TBK m. 123-126'da öngörülen karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere başvurabilir. Bu sonuç, TBK m. 304/I'de İsviçre BK m. 258'deki gibi açıkça ifade edilmese de, genel hükümlerin özel hükümle birlikte uygulanabileceği kuralının bir örneğini oluşturur.

Buna karşılık, kiraya verenin, önemli ayıplar taşıyan kiralananı teslim etmeyi teklif etmesi, yani onu ifa olarak sunması halinde, kiracı kiralananı kabul etmeyip ifayı reddedebilir. Bu takdirde, kiracı, borçlunun temerrüdüne ilişkin TBK m. 123-126 hükümlerine başvurabilir; sözleşmeden dönme imkânını elde eder[26]. Bu sonucun doğması için aşağıdaki şartların birlikte bulunması yeterli olup, kiraya verenin kusurlu olması gerekli değildir[27].

- Kiralananın teslim anında önemli bir ayıp taşıması gerekir. TBK m. 304/ I'de İsviçre BK m. 258/I'den farklı olarak önemli ayıp kavramı tanımlanmamıştır. Bu durumda önemli ayıp kavramını İsviçre BK m. 258/ I ve TBK m. 306/II hükümlerini göz önünde tutarak tanımlamak zorundayız[28]. Buna göre, önemli ayıbı, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini kaldıran veya önemli ölçüde azaltan ayıp olarak tanımlamak gerekir. Kiralanan yerde yeterli ısıtmanın bulunmaması, sağlığa zararlı rutubet, pencerelerin işlevini sağlayacak şekilde sağlam olmaması; su, gaz ve elektrik tesisatının zarar verici olması önemli ayıp olarak nitelendirilebilir[29].
- Kiraya veren ifayı teklif etmiş olması gerekir.
- Kiracı ifayı kabul etmemiş olması gerekir.
- Kiracının ayıptan sorumlu olmaması gerekir.

Kendisine, önemli ayıplar taşıyan kira konusu bir eşya teslim edilmek olgusuyla karşılaşan kiracı, yukarıda belirtilen şekilde hareket etmeyip, ayıplı ifayı kabul edip, sözleşmenin gereği gibi ifasını isteyebilir. Bu takdirde, kiracı ancak kiranın devamı sırasında ortaya çıkan ayıplarda sahip olduğu talepleri (TBK m. 305- 308) ileri sürebilir.

---

[26] **Higi,** Art. 258, N. 53; **Huguenin,** BT, N. 478; **Aubert,** in: Droit du bail á loyer, art 258, n. 1 ve n. 44 vd.

[27] **Huguenin,** BT, N. 478; **Higi,** Art. 258, N. 53 ve 59.

[28] **Gümüş,** sh. 106 ve 107.

[29] **Higi,** Art. 258, N. 45; **Huguenin,** BT, N. 478.

Aynı şekilde, kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde de kiracı kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir (TBK m. 304/ II).

b) Kiralananın teslimden sonraki ayıplarından sorumluluk

Burada kiralananın tesliminden kira sözleşmesinin sona ermesine kadar geçen süre içinde ortaya çıkan ayıplardan sorumluluk söz konusu olmaktadır. TBK m. 305'e göre "Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez (f. I). Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır (f. II)". Eski BK m. 249- 250'yi kısmen karşılayan ve İsviçre BK m. 259/a göz önünde bulundurulmak suretiyle kaleme alınan bu hüküm, teslimden sonra ortaya çıkan ayıplarda, kiracının kullanabileceği hakları genelde ismen saymaktadır. Bu hakların kullanımına ilişkin hususlar ise TBK m. 306- 308'de düzenlenmiştir. Ancak, gerek eski BK m. 250/I'de, gerek İsviçre BK m. 259/a'da ifade edilen ayıpların ortaya çıkmasında "kiracıya yüklenebilecek bir sebebin bulunmaması" şartına TBK m. 305'te yer verilmemiştir. Madde gerekçesinde vurgulanan bu hususun, madde metninde yer verilmemesi bir eksikliktir.

Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesi halinde, kiracı aşağıdaki seçimlik haklarını (TBK m. 305- 308) kullanabilir:

aa) Ayıbın giderilmesini (tamirini) isteme hakkı (TBK m. 306)

TBK'nın "ayıbın giderilmesini isteme ve fesih" başlığını taşıyan 306. maddesine göre, "Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir (f. I). Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir (f. II). Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir (f. III). Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanma-

sını önleyebilir (f. IV)". Bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen sözleşmeyi fesih hakkı, aşağıda ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Tasarının, TBK m. 306'yı karşılayan 305. maddesine ait gerekçede, bu maddenin eski BK m. 250'yi kısmen karşıladığı; birinci ve ikinci fıkraların düzenlenmesinde İsviçre BK m. 259b ve 259c'nin göz önünde tutulduğu ifade edilmiştir. Ancak, gerek eski BK m. 250'de, gerek İsviçre Borçlar Kanunu'nun anılan maddelerindeki kriterlere yer verilmemesi, aşağıdaki açıklamalarda görülecek olan bazı önemli sorunların yorum yoluyla değerlendirilmesi sonucunu doğurur.

TBK m. 306/ I'de kiracının, ayıbın uygun bir sürede giderilmesini kiraya verenden isteyebileceği öngörülmektedir. Bunun için, kiralananın olağan kullanımı sonucu olan ve TBK m. 317 uyarınca kiracının gidermekle yükümlü olduğu bir ayıbın bulunmaması gerekir. Giderilecek ayıbın kiraya verenin kusuruna bağlı olması gerekmez[30]. Diğer taraftan, kiracının kiraya verenden kiralanandaki ayıbı "uygun bir sürede" giderilmesini yani tamirini talep etmesi gerekir. Eğer kiraya veren kiralanandaki ayıbı bilmiyorsa kiracı ayıbın neden olacağı zarar artışından sorumlu olmamak için bu talebini gecikmeksizin bildirmesi icap eder (TBK m. 318). Madde gerekçesinde de ifade edildiği gibi uygun süre kiracı tarafından belirlenip verilecektir. Uygun sürenin ne kadar olması gerektiği, somut olayın şartlarının tamamının birlikte değerlendirilmesine bağlıdır (tamirin aciliyeti, giderim çalışmalarının kapsamı, gerekli iznin alınması ve masraf dökümü[31]). Kiracının verdiği süreyi çok kısa bulan kiraya veren, hemen tamire başlayarak kiracıdan sürenin uzatılmasını istemek zorundadır; aksi halde verilen süreyi kabul etmiş sayılır[32].

Yeni Borçlar Kanunu, kiracının ayıbın giderilmesini (tamirini) isteyebilme açısından önemli ayıp- önemli olmayan ayıp ayırımı yapmamıştır (TBK m. 305/ I ve 306/ I). Sadece sözleşmenin feshedilebilmesi için ayıbın önemli olması şartı öngörülmüştür (TBK m. 305/ II ve 306/ II).

---

30 **Higi,** Art. 259b, N. 22; **Aubert,** in: Droit du bail á loyer, art 259b, n. 2 ve 3; **Gümüş,** sh. 116.

31 **CR- CO I, Lachat** art. 259b, n. 3; **Higi,** Art. 259b, N. 23; **Aubert,** in: Droit du bail á loyer, art 259b, n. 7 vd.

32 **CR- CO I, Lachat** art. 259b, n. 3; BGE 116 II 436, cons 2a.

Kiraya veren kendisine verilen uygun süre içinde ayıbı gidermezse, kiracı onun hesabına ayıbı gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir (TBK m. 306/ III).

Kiraya veren kendisine verilen uygun süre içinde kiralanandaki ayıbı gidermediği takdirde, kiracı, TBK m. 306/ I uyarınca şu iki imkândan birini kullanmak hakkına sahip olur: Bunlardan biri, kiraya veren hesabına ayıbın giderilmesini sağlamak ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilmek; diğeri ise, kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilmektir.

Buna karşılık, kanun koyucu, ayıbı gidermek yoluna gitmek istemeyen kiraya verene, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirmek (TBK m. 306/ III) veya kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vermek ve uğradığı zararın tamamını gidermek suretiyle, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilmek (TBK m. 306/ IV) haklarını tanımaktadır.

Bu durum karşısında, önce kiracının kiraya veren hesabına ayıbı giderme hakkına, bundan sonrada ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesine ilişkin sorunları incelemek uygun olur.

aaa) Kiracının kiraya veren hesabına ayıbı giderme (tamir) hakkı

TBK m. 306/ I'e göre, kiraya verenin uygun süre içerisinde ayıbı gidermemesi halinde, kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Türk kanun koyucu, gerek İsviçre BK m. 259b/ I.b, gerek eski BK m. 251/ II'den farklı olarak, kiracının giderebileceği ayıbın derecesi hakkında herhangi bir hüküm içermemektedir. İsviçre Borçlar Hukuku'nda (m. 259/ I.b) kiracının, kiralananın öngörülen kullanma amacına elverişliliğini önemli ölçüde engellemeyip, azaltan yani önemli olmayan ayıplarda ayıbı giderebileceğini açıkça belirtilmiştir. İsviçre Hukuku'nda önemli (ağır) ayıp- orta ayıp- hafif ayıp ayırımı yapılmaktadır. İsviçre BK m. 259b/ I.b'de tamir ettirilecek ayıp, orta ayıp olarak nitelendirilmektedir.

Kiracının önemli olmayan ayıbın giderilmesi için hakimden izin alması (TBK m. 113) gerekmediği gibi, kiraya verenin onayına ihtiyaç

yoktur[33]. Tamir masraflarının kira bedelinden indirilmesi deyimi takas anlamına gelir; kiracı tamirden doğan alacağını kira bedeli borcuyla takas etmiş olur (TBK m. 139)[34].

Buna karşılık önemli (ağır), yani kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldıran veya önemli ölçüde engelleyen ayıplarda, kiraya veren taraf hesabına ayıbı giderebilmek için, kiracının TBK m. 113 gereğince hakimden izin istemesi gerekir[35].

Kiracı bu şarta uymadan ayıbı giderme yoluna başvurursa yaptığı masrafları en fazla gerçek olmayan vekâletsiz işgörme sonucu sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edebilir. Çok acil veya kiraya verene ulaşmanın imkânsız olduğu hallerde, kiracı tamiratı yaptırarak gerçek vekâletsiz işgörmeye ilişkin kurallara göre masraflarını talep edebilir[36].

bbb) Kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi

TBK m. 306/ I'de kiraya verenin kendisine verilen uygun süre içinde ayıbı gidermemesi halinde, kiracının kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebileceği öngörülmüştür. Aynı maddenin III. fıkrasında kiraya verenin, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız bir benzeri ile değiştirilebileceği ifade edilmiştir. TBK m. 306/ IV'e göre, "Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir". İsviçre Borçlar Kanunu'nda sadece kiraya verene tanınan ayıpsız bir benzeri ile değiştirme hakkı (OR, Art. 259 c), TBK m. 306/ I'de kiracıya da tanınmış bulunmaktadır. TBK m. 306 çerçevesinde taraflara tanınan ayıpsız bir benzeri ile değiştirme talebinde en önemli husus, kiracının bu hakkı kullanabilmesi için, kiraya verene ayıbın giderilmesi için uygun bir süre vermesi ve bu süre içinde ayıbın giderilmemesi şartıdır. Kiraya veren için böyle bir şart öngörülmemiştir.

---

33 **CR- CO I, Lachat** art. 259b, n. 7; **Tercier/Favre**, N. 2127; **Yavuz,** sh. 203; **KUKO OR, Water** Art. 259b-c, N. 7; **OR- Weber,** Art. 259b. N. 10; **Guhl/ Koller,** sh. 412, N. 41.

34 **Tercier/ Favre,** n. 2127.

35 **CR- CO I, Lachat** art. 259b, n. 7; **Tercier/Favre**, N. 2129; **Higi,** Art. 259b, N.46; **Guhl/ Koller,** sh. 412, N. 41; **Yavuz,** sh. 202; **Gümüş,** sh. 120; BGE 61 II 37.

36 **Guhl/ Koller,** sh. 412, N. 41; **OR- Weber,** Art. 259b. N. 12; BGE 61 II 37.

TBK m. 306'ya ilişkin gerekçede kiracının değiştirme hakkını kullanabilmesi için "kiralananın misli eşya (mal) niteliği taşıması gerektiğinde duraksama yoktur" denilmektedir. İsviçre'de kiraya verenin değiştirme hakkını düzenleyen İsviçre BK 259 c maddesi hükmünün başlangıçta taşınır kiraları için düşünüldüğünü, meclis çalışmaları esnasında her türlü kiraların bu madde kapsamına katıldığı; buna rağmen bu normun uygulamadaki öneminin konut ve çatılı işyeri kiralarında çok sınırlı olduğu ve pek gerçekleşemeyeceği ifade edilmektedir[37]. Taşınmaz kiralarında kararlaştırılan kullanılma amacı ve sözleşme şartlarına uygun ayıpsız bir malın bulunması güçtür. Taşınmazın yeri, yüz ölçümü, yapının yapım yılı ve konforunun eş değerde olması çok zor olduğu için, maddede öngörülen değiştirmeye ilişkin hükmün uygulama açısından ölü bir hüküm olduğu söylenebilir. Ancak aynı taşınmazda veya sitede benzer nitelikleri taşıyan daireler bulunabilir[38].

bb) Fesih hakkı

Kiralananın kiracıya teslim edilip, kullanılmaya başlaması halinde ortaya çıkan ayıplarda, kiracının fesih Hakkı TBK m. 305/ II ve m. 306/ II'de düzenlenmiştir. TBK m. 305/ II'ye göre, "önemli ayıp durumunda kiracının fesih hakkı saklıdır". Bu ifade, sonraki ayıplarda kiracının sahip olduğu hakların kataloğu niteliğindeki TBK m. 305/ I'den sonraki ikinci fıkrada çok kısa olarak yer almaktadır. TBK m. 306/ II'ye göre "Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir". Bu fıkrada önemli ayıpların tanımı da yapılmış olmaktadır[39]. Buna göre, TBK m. 306'de önemli ayıp, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliği ortadan kaldıran veya önemli ölçüde engelleyen ayıp olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan aynı fıkrada, kiracının fesih hakkını kullanabilmesi, verilen sürede kiraya verenin ayıbı gidereMEMesi şartına bağlanmıştır. Böylece, fesih hakkı, ayıbın giderilmesi sürecinin başarısız olmasından sonra kullanılabilecektir. TBK m. 306/ II gereğince kiracının fesih hakkını kullanabilmesi için ayıbın önemli olması ve verilen

---

37 **Aubert,** in: Droit du bail á loyer, art 259c, n. 1 ve 7; **Tercier/ Favre,** n. 2125; Ayrıca bk. **CR- CO I, Lachat** art. 259c, n. 1; **OR- Weber,** Art. 259c. N. 1.

38 **Aubert,** in: Droit du bail á loyer, art 259c, n. 7.

39 Bk. **Gümüş,** sh. 117.

uygun süre içinde ayıbın giderilmemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Böyle bir durumda, kiracı yeni bir süre tayin etmeden[40] kira sözleşmesini, varması gereken, tek taraflı bir irade beyanıyla ileriye etkili olarak sona erdirebilir; fesih beyanı bozucu bir yenilik doğuran hakkın kullanılmasıdır.

Kiracının, fesih hakkını sürenin dolmasından sonra hemen kullanmak zorunda olup olmadığı hususunda iki görüş vardır. Hakim fikre göre, özellikle konut veya çatılı işyeri kiralarında feshin derhal yapılması zorunlu değildir.

cc) Kira bedelinin indirilmesi

TBK m. 307'ye göre, "Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir". Kiracının kira bedelinin indirilmesini isteyebilmesi için, öncelikle kiralananın kullanımını etkileyen bir ayıbın bulunması gerekir. Kullanımı etkileyen ayıp kavramı TBK m. 307'yi karşılayan İsv. BK m. 259 b'de, kiralananın öngörülen kullanımı engelleyen veya kısıtlayan ayıp şeklinde ifade edilmiştir. İsviçre Hukuku'nda m. 259 a/ TBK m. 305 uyarınca kiracının sorumlu olduğu ister önemli ister önemli olmayan nitelikte olsun her türlü ayıplarda kira indiriminin istenebileceği görüşü hakim bulunmaktadır[41]. Bu görüşün Türk Hukuku için de geçerli olduğunu kabul etmek gerekir[42].

TBK m. 307'de, kiracının, söz konusu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden, ayıpların giderilmesi anına kadar geçen süre için kira bedelinin indirimini isteyebileceği öngörülmüştür. Bu açıdan, kiracı için, mümkün olan süre içerisinde, ayıbı bilmeyen kiraya verene ayıp ihbarı yapmakta yarar bulunmaktadır.

İndirilecek kira miktarının tespiti nisbi metoda göre yapılacaktır. Ancak burada satış sözleşmesinde olduğu gibi satılanın objektif piyasa değerinden hareket edilmez; tarafların kararlaştırdıkları kullanım değerinden hareketle indirim yapılır. Kirayı, kiralananın kararlaştırılan

---

40 **Guhl/ Koller,** sh. 413.

41 **Higi**, Art. 259d, N. 8; **OR- Weber**, Art. 259d, N. 2. Ayrıca bk. **Honsell**, sh. 216.

42 **Gümüş**, sh. 123. Aynı bk. **Yavuz,** sh. 205.

kullanımı fiilen (efektif olarak) azalmasına eş değer bir yüzde olarak indirmek gerekir[43].

Kiracının indirim talebi, mahkeme yoluyla kullanılması gerekmeyen ve kiraya verene yöneltilen bir yenilik doğuran hakkın kullanılması niteliğini taşır[44].

dd) Tazminat talebi

TBK m. 305/ I'e göre kiracı seçimlik hak olarak zararın giderilmesini isteyebilir. Bu fıkranın son cümlesi gereğince zararın giderilmesini istemek kiracının diğer seçimlik haklarını kullanmasını önlemez; yani tazminat talebini diğer seçimlik haklarla birlikte de ileri sürebilir.

TBK m. 308 uyarınca, kiraya veren, ancak kusuru bulunmadığını isbat etmek suretiyle kiralananın ayıplı olmasından doğan zararı tazmin etmekten kurtulur. Görüldüğü gibi burada da TBK m. 122'de olduğu gibi, kiraya veren aleyhine bir kusur karinesi mevcuttur. Ayıptan doğan zararın tazmininde ayıbın derecesi, yani önemli veya önemsiz olması sonucu değiştirmez[45].

III. Kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumlu olması

Bu başlık altında incelenecek hususlar, zapttan sorumluluk (TBK m. 309), üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması (kiralananın el değiştirmesi/ temliki, TBK m. 310 ve üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması, TBK m. 311) ile tapu siciline şerh (TBK m. 312)'den oluşmaktadır.

1. Kiraya verenin zapttan sorumluluğu

TBK m. 309'a göre, "Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür".

Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için üçüncü kişinin sözleşmenin kurulması anında mevcut ve kiracının kiralananı kullanma hak-

---

[43] **CR- CO I, Lachat** art. 259d, N. 2; **Higi**, Art. 259d, N. 12; **Züst**, N. 325 vd.. Ayrıca bk. **Koller,** BT, sh. 209 N. 112.

[44] **Higi,** Art. 259d, N. 21 vd.; **Guhl/ Koller**, sh. 414; **Koller,** BT, sh. 209, N. 112; **Tercier/ Favre**, N. 2113. Değişik fikirde: **OR- Weber**, Art. 259d, N. 4.

[45] **Tercier/ Favre**, N. 2125.

kıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi gerekir. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü hak mülkiyet hakkı, irtifak hakkı veya komşuluk hukukundan doğan bir hak şeklinde olabilir. Buna karşılık çifte kirada olduğu gibi kişisel talepler, tapu siciline şerh edilmediği takdirde TBK m. 309 kapsamına girmez[46]. Bu madde anlamında zapttan doğan sorumluluğun doğması için kiralananın kiracıya teslimi gerekir; aksi halde, TBK m. 112 veya TBK m. 118 vd.'na göre kiraya veren sorumlu olur[47].

Şayet üçüncü kişi bu konuda kiracıya karşı dava açmış ise, kiraya veren kiracının bildirimi (ihbarı) üzerine davayı üstlenmek zorundadır. Yapılan bildirime rağmen kiraya veren, davayı üstlenmekten kaçınırsa kiracı yargılamadan çekilebilir[48].

Üçüncü şahsın üstün hak iddiasını mahkeme yoluyla ileri sürüp, kiracının elinden alması halinde, kiracı, kiraya verenden tazminat talep edebilir; bunun için kusur gereklidir. Burada tazmin edilecek zarar ifa menfaatinin kaybına dayanan müspet zarardır[49].

2. Kiralananın kira sözleşmesinin kurulmasından ve kiracıya tesliminden sonra temliki

a) Genel olarak

Türk Borçlar Kanunu'nun kiralananın el değiştirmesi başlığını taşıyan 310. maddesine göre, "sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur" (f. I); "kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır" (f.II).

TBK m. 310/I'de öngörülen kural gereğince, kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiraya veren/ malik kira konusu eşyanın mülkiyetini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devrederse, yeni malik, hak ve borçlarıyla bire bir kira sözleşmesinin tarafı olur. Burada kanun gereğince sözleşmenin devri söz konusu olur; üçüncü kişi başka bir işleme gerek olmadan kiraya verenin yerini alır ve ileriye dönük olarak bütün hak ve borçları üstlenmiş olur[50]. Bu sonucun gerçekleşmesi için, satış,

---

46 **OR- Weber,** Art. 259f, N. 2; **CR- CO I, Lachat,** Art. 259f, n. 2, bk. **Tercier/ Favre,** n. 2157.

47 **Tercier/ Favre**, n. 2157; **Koller,** BT, sh. 193- 194, N. 59 vd.; **Gümüş**, sh. 131.

48 **Higi**, Art. 259f, N. 22; **OR- Weber**, Art. 259f, N. 4; **Koller,** BT, sh. 195- 196, N. 85; **CR- CO I, Lachat**, Art. 259f, n. 4; **Gümüş,** sh. 133- 134.

49 **Gümüş,** sh. 131; **Schmid**, Art. 258, N. 9.

50 **Tercier/ Favre**, n. 2469; **Favre,** le transfer conventionnel de contrat, n. 78; **Honsell,** sh. 225; Ayrancı (Sözleşmelerin Devri), sh.119-120; BGE 127 II 273.

trampa, bağışlama veya diğer temlik sözleşmesinin yapılması yeterlidir; kira konusunun icra ve iflas yoluyla satılması halinde de aynı sonuç doğar. Kiralananın mülkiyetinin miras, yani külli halefiyet yoluyla geçmesi halinde bu hüküm uygulanmaz. Zira mirasçılar miras bırakanın borcundan miras hukuku kuralları gereğince sorumludurlar.

TBK m. 310/ I gereğince üçüncü kişinin/ yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olması için, kanunun lafzına rağmen, devir işleminin kira sözleşmesinin kurulmasından sonra yapılması yeterli değildir; ayrıca kiralananın kiracıya teslim edilmiş olması gerekir. Zira teslimden önce kiralananın temlik edilmesi halinde kiraya veren TBK m. 112 gereğince sorumlu olur[51].

TBK m. 310/ I ile getirilen kuralla eBK m. 254 gereğince kabul edilen "satış kirayı bozar" kuralı terk edilmiş ve tersine çevrilmiş bulunmaktadır[52]. Bu maddenin gerekçesinde bu değişikliğin sebebi şu şekilde açıklanmaktadır: "Kiracıya yeni malik karşısında koruma amacıyla, kiracılık hakkını yeni malike karşı da ileri sürülebileceği ve yeni malikin kiralananı edindiği anda, kanun gereği, kira sözleşmesinin tarafı olacağı kabul edilmiştir. Bununla beraber, bu fıkra ile İcra ve İflas Kanununun 135. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde, belirtilen maddenin uygulama olanağı ortadan kaldırılmamaktadır".

b) Kira sözleşmesinin devrinin sonuçları

aa) Kiracı ile üçüncü kişi/yeni malik arasındaki ilişki

Yukarıda da ifade edildiği gibi, kiralanan üzerindeki mülkiyet hakkının geçişiyle birlikte yeni malik kanun gereği kira sözleşmesinin tarafı olur (TBK m. 310/ I); mülkiyetin geçtiği andan itibaren kira sözleşmesinden doğan hakkın sahibi ve borcun yükümlüsü olur. Bu andan önceki mevcut hakları (ödenmemiş alacağı) ve borçları (kiracının ileri sürdüğü kira bedelinin indirimi talebi) kiraya veren eski malik ve kiracı arasında kalır; taraf değişikliği geriye olarak değil, ileriye dönük

---

[51] **Koller,** BT, sh. 22, N. 165; **Guhl/ Koller,** sh. 420, N. 73; **Higi,** Art. 261- 261a, N. 13; **Gümüş,** sh. 144.

[52] **Koller,** BT, sh. 232, N. 164; **Tercier/ Favre,** n. 2469; **Bail á Loyer, Marchand,** Art. 261, n. 2 vd. Bu sonucun tam anlamda gerçekleşmediği fikrinde: Honsell, sh. 225 vd.; ayrıntılı bilgi için bkz. Ayrancı (Sözleşmelerin Devri), sh. 73.

olarak sonuç doğurur. Başka bir ifadeyle daha önce kiraya veren taraflar ile kiracı arasında doğmuş olan haklar ve borçlar bundan etkilenmez[53].

Eski malik/ kiraya veren lehine verilmiş olan teminatlar, kira alacağının ferileri olarak yeni malike geçer (TBK m. 189)[54].

Kira sözleşmesinde taraf değişikliğine ilişkin kurala, (konut ve çatılı işyeri kiralarında) TBK'nın aşağıda ayrıntılarıyla anlatılacak olan 351. maddesiyle süre yönünden bir sınır getirilmiştir. Buna göre, kiralananı sonradan devralan yeni malik, ihtiyaç sebebiyle, belirli sürelere uygun olarak tahliye davası açabilir.

bb) Kiracı ile eski malik/kiraya veren arasındaki ilişki

Daha önce açıklandığı gibi kiralananın mülkiyetinin devri ile kiraya veren/ eski malik, kiraya veren durumundan çıkar ve kiralananın kullanımı hazır bulundurmak yükümünden kurtulur. Buna karşı daha önce muaccel olanlar hariç kira bedelinin kendisine ödenmesini isteyemez[55]. Bununla beraber yeni malikin belirli süreli kira sözleşmesini süresinden önce feshetmesi halinde (TBK m. 351), kiracı uğradığı zararın tazminini eski malik kiraya verenden talep edebilir[56]. Her ne kadar İsv. BK m. 261/III'de bu hususu açıkça öngören bir hüküm TBK'da bulunmasa da aynı sonucun Türk Hukuku'nda da geçerli olduğunu kabul etmek gerekir.

c) Kiralananın kamulaştırılması

TBK m. 310/ II'ye göre, "Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır". 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu m. 20/I'e göre, idare adına tescil yapıldıktan sonra, kiracı, kiralanandan çıkartılır. Bu durumda TBK m. 136 anlamında borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık söz konusu olduğu için kiracı kiraya verenden tazminat talep edemez; kira sözleşmesinin tapuya şerh verilmiş olması da bu

---

53 **Koller,** BT, sh. 223, N. 169; **Tercier/ Favre,** n. 2469 ve 2476.

54 **Tercier/ Favre,** n. 2476; **Bail á Loyer, Marchand,** art. 261, n. 22; **Higi,** Art. 261- 261a, N. 22; BGE 127 II 273 Erw. 3a; buna karşılık eski malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ereceği, satış tarihi itibariyle tasfiyesi gerektiği, bu çerçevede kiracıdan alınan güvence parasının yeni malike teslim edilmesi gerektiği yönünde bkz. 6. HD. 2014/2092 E. 2014/12561 K. –Kazancı-.

55 **Koller, BT,** sh. 226, N. 181; **Tercier/ Favre,** n. 2478.

56 **Tercier/ Favre,** n. 2478; **Koller, BT,** sh. 226, N. 181.

sonucu değiştirmez. Kiraya veren, kiralananın yakında kamulaştırılacağını bildiği halde, bunu gizlemişse, tazminat ödenmekle yükümlü olur[57].

3. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması

TBK m. 311'e göre, "Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır". Emredici nitelikte olan bu hüküm, sözleşme kurulup kira konusu eşya kiracıya teslim edildikten sonra, kiraya verenin kiralanan üzerinde üçüncü bir kişiye mülkiyetin devrine eş değer önemde bir sınırlı ayni hak tesis etmesi hallerini, TBK m. 310/ I anlamında kiralananın temlikine benzetmekte; bu hükmün bu gibi hallerde kıyas yoluyla uygulanacağını ifade etmektedir. Üst hakkı, intifa hakkı tesisi bu hükmün kapsamına girer; geçit hakkı ise girmez[58].

4. Tapu siciline şerh

TBK m. 312'ye göre, "Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir". Bu maddenin gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: "Tasarıda kiralananın el değiştirmesinden ya da sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü kişinin, kiralanan üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olmasından, kira sözleşmesinin etkilenmeyeceği ve varlığını sürdüreceği esasının benimsenmesine karşın, 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi, kiracılık hakkının tapu siciline şerhi olanağının korunmasında bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu şerhe dayanan kiracı, yeni malikin 315. madde uyarınca gereksinimi ileri sürerek kira sözleşmesini sona erdirilme hakkını kullanmasına engel olabilecektir".

Kiracının kira sözleşmesinden doğan kullanma hakkı, kiraya veren ile kiracı arasında yapılacak şerh anlaşmasına dayanarak tapu kütüğüne şerh verilebilir. Şerhin yapılabilmesi için Tapu Sicili Tüzüğü m. 55/ b.d uyarınca malikin yazılı şerh talebinde bulunması gerekir[59].

Kira sözleşmesinin şerhi yeni malikin TBK m. 351'e dayanarak tahliye davası açma ihtimalini ortadan kaldırır[60].

---

57 **Tandoğan I/ 2**, sh. 135; **Gümüş,** sh. 148.

58 **CR- CO I, Lachat**, art. 261a, sh. 1367; **Koller, BT**, sh. 222, N. 164.

59 **Gümüş**, sh. 149.

60 **Gümüş**, s. 150.

IV. Vergi ve yan giderlere katılma borcu

1. Vergileri ödeme borcu

TBK m. 302'ye göre, "Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır". Kiraya veren, malik sıfatıyla mükellef olduğu emlak vergisini, aksi kararlaştırılmadıkça ödemek zorundadır. Buna karşılık 3914 sayılı kanunla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen mükerrer 44. maddenin II. fıkrasına göre, kiracılar çevre temizlik vergisinin mükellefidirler. Gerçekten mükerrer 44. maddenin II. fıkrasına göre, "Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş binalarda bu verginin mükellefi, bunların maliki ve malik gibi tasarruf edenlerdir".

2. Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu

TBK m. 303'e göre, "Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür". Kira sözleşmesinin Genel Hükümler kısmında yer alan bu kuralın İsv. BK m. 257 a'dan alındığı madde gerekçesinde belirtilmiştir. İsv. BK m. 257 a'da yan giderlerin ancak özel olarak kararlaştırılması halinde kiracıya ait olacağı ifade edilmiştir. TBK'nın kullanım gideri başlığını taşıyan ve konut veya çatılı işyeri kiralarına ilişkin 341. maddesinde yan giderlerin kiracı tarafından karşılanacağı öngörülmüştür. TBK m. 341 hükmüne aşağıda kiracının borçları çerçevesinde değinceğiz. Bu durumda TBK m. 303'ün kapsamına, doğrudan doğruya kiralananın kullanılmasına bağlı olmayan (elektrik, su ve ısıtma gibi) ve genel giderlere dahil olmayan harcamaların, mesela çatı onarımı, dış sıva, bahçe düzenlenmesi ve park yerlerinin tanzimi gibi kalemlerin gireceğini kabul etmek gerekir.

§ 21. KİRACININ BORÇLARI

I. Kiralananın kullanılmasına ilişkin borçları

1. Kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu

TBK m. 316/I'e göre, "Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak(la)....yükümlüdür". Bu cümlede açıkça ifade edildiği gibi, kiracı kiralananı sözleşmeyle öngörülen tahsis amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

TBK m. 316/I anlamında kiralananı kullanırken özenle hareket yükümü, kiracının kiraya verenin rıza ve muvafakatı olmadan kiralananın özünü etkileyecek veya ona zarar verecek davranışta bulunmamasını ve onda kira sözleşmesinin bitiminden sonra da etkisi kalacak şekilde değişiklik yapmamasını gerektirir. Bu cümleden olarak, kiracının iki oda veya bitişikteki taşınmaz arasındaki duvarı yıkması[1], dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermesi[2], kiralananı özenle kullanma borcunun ihlâli sayılır. Aynı şekilde kiralananın iyi bir durumda muhafazası ve normal kullanmanın gerektirdiği basit tamiratların yapılması (TBK m. 317) da, kiracının özen borcunun gereğidir[3]; TBK m. 318'de öngörülen ihbar yükümünün özen borcunun bir sonucu olduğunu kabul etmek gerekir.

Yargıtay kararlarına göre, depo olarak kullanılan birinci kata fazla un çuvallarının yığılması sonucu beton döşemede eğilme ve çökme ih-

---

1 **Schmid**, Art. 261, N.3; **Oser/Schönenberger**, Art. 261, N.2; **Tercier**, N. 1150; **Tandoğan**, I/2, sh. 141 vd.; HGK, 17.12.1993, E. 6/K. 55 (**Tunaboylu**, N. 154, sh. 132). "Davalı, kiralananın bitişiğinde bulunan dava dışı bir şahsa ait taşınmazla arasındaki duvarı kaldırmış ve tedbir kararı üzerine komşu taşınmazı kullanan kişi ara duvarını yeniden örmüş ancak çekişmeli kiralanan yanındaki duvar sıvasız kalmış kiralanan eski hale getirilmemiştir. Bu eylemin kiralananın açıktan kullanılması olarak değerlenmenin yerinde olacağı açıktır". 6. HD, 27.9.1994, E. 8680/K. 9189 (**Tunaboylu**, N. 177, sh. 152): "Gerçekten duvar kaldırılması veya kapı açılması söz konusu ise akde aykırılık olacağı düşünülmelidir"; HGK, 22.4.1992, E. 158/K. 265 (**Tunaboylu**, N. 155, sh. 133-134).

2 6.HD, 19.3.1984, E. 3094/K. 3337 (YKD 1985, sh. 37-38).

3 **Schmid**, Art. 261, N. 14 ve 15; **Tercier**, N. 1151.

timalinin bulunması[4], kiracının kendisine verilen yeri taşması sonucu salonun daralıp yolcu trafiğini engellemesi[5], asma katın ikiye ayrılması ve merdiven ve ön cephe değişikliği yapılması[6], kiralanan yerin projesine aykırı olarak ana duvarların kaldırılması ve banyoda değişiklikler yapılması (yapılan değişiklikler yararlı olsa dahi)[7], kiralananın balkonunun kapatılması[8], sinema zeminine şap (çimento) dökülerek zemin seviyesinin yükseltilmesi[9] özenle kullanma yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden hallerdendir. Buna karşılık Yargıtay, çocukların düşmemesi için balkon demirlerinin yükseltilmesini sözleşmeye aykırı saymamıştır[10].

Kiracının, kiraya verenin rıza ve muvafakatı olmadan kiralananı sözleşmeyle öngörülen tahsis amacına aykırı olarak kullanmaması gerekir. Yargıtay, yazıhanenin depo olarak kullanılmasını[11], televizyon anteni, malzemesi ve parçaları yapılmak üzere kiralanan yerde yürüteç denilen çocuk arabası imalâtının yapılmasını[12], bakkal dükkânı olarak kullanılan yerin çay ocağı olarak kullanılmasını[13], konut olarak kiralanan yerin depoya dönüştürülmesini[14], halı teşhir ve satış mağazası olarak kiraya verilen yerin depo olarak kullanılmasını[15] sözleşmeye aykırı saymıştır. Kiralananın tahsis amacına aykırı kullanma kiracıyla devamlı olarak oturabilecek kişilerin dışında kalan kişilerin kiralananda sürekli olarak kalması şeklinde de ortaya çıkabilir[16]. Yargıtay'a göre, reşit baldızın eniştesiyle oturması[17], bilet satış gişesine kiraya verenin rızası olmadan tâli bir firmanın alınması[18] akde aykırılık teşkil eder.

---

4 6.HD, 23.3.1982, E. 3054/K.3146 (**Uygur**, C.4, sh. 551).
5 6.HD, 29.6.1987, E. 12318/K. 10065 (**Uygur**, C.4, sh. 554).
6 HGK, 22.4.1992, E. 158/K. 265 (**Tunaboylu**, N. 155, sh. 133-134).
7 6.HD, 13.6.1994, E. 5747/K. 6489 (**Tunaboylu**, N. 178, sh. 152-153).
8 6.HD, 17.2.1993, E. 1575/K. 1809 (**Tunaboylu**, N. 192, sh. 162).
9 6.HD, 22.2.1989, E. 435/K. 2971.
10 6.HD, 28.11.1983, E. 334/K. 259 (**Uygur**, C.4, sh. 561).
11 6.HD, 15.3.1982, E. 2718/K. 2805 (**Uygur**, C.4, sh. 440-550).
12 6.HD, 24.4.1980, E. 7/K. 4083 (**Uygur**, C. 4, sh. 551-552).
13 HGK, 2.11.1994, E. 6-694/K. 682 (**Tunaboylu**, N. 153, sh. 130-131).
14 6.HD, 24.5.1993, E. 5956/K. 6142 (**Tunaboylu**, N. 183, sh. 155-156).
15 6.HD, 15.3.1993, E. 3142/K. 3398 (**Tunaboylu**, N. 190, sh. 161).
16 **Tandoğan,** I/2, sh. 145 vd.
17 6.HD, 15.9.1980, E. 3410/K. 7752 (**Uygur**, C.4, sh. 553).
18 6.HD, 29.5.1980, E. 1407/K. 5577 (**Uygur**, C.4, sh. 552-553).

Buna karşılık, Yargıtay, bekâr kızın evlenerek eşiyle birlikte aynı kiralananda oturmasını[19] bir kimsenin yalnız olan kız kardeşini yanına almasını[20] akde aykırı saymamıştır.

Kiralanan yerin kötü ad almasına sebep olacak ahlâka aykırı hareketlerde bulunması, özenle ve tahsis amacına uygun olarak kullanma yükümünün ihlâli sayılır[21]. Yargıtay, kiralanan otelde fuhuş yaptırılması[22], kiralanan yerin randevu evi olarak kullanılması[23] hallerinde böyle bir nitelik görmüştür.

Kiracı kural olarak, kiralananı kullanıp kullanmamakta serbesttir. Sözleşmede kullanma borcunun öngörülmesi hallerinde veya işyeri kiralarında kiracının kullanmaması sebebiyle kiralananın değerinin azalacağı hallerde kullanma borcunun bulunduğunu kabul etmek gerekir[24]. Yargıtay'a göre, yazıhane olarak kiralanmış bir yerin hiç kullanılmaksızın kapalı tutulmasını kiralanma değerine etki yapan bir durum yaratacağından akde aykırılık olarak kabul etmek gerekir[25].

2. Komşulara saygı gösterme borcu

TBK m. 316/ I'e göre, "kiracı, ... kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür". Aynı şekilde, kiracı, MK m. 737'deki komşuluk ödevlerine ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesinde öngörülen yükümlere uymak zorundadır[26].

Yargıtay'a göre, kiracının karısının geçimsiz olması, komşulara bağırması ve hakarette bulunması[27] veya kiracının kiraya verenin eşini

---

19 6.HD, 28.1.1988, E. 13050/K. 1080 (**Uygur**, C.4, sh. 562).

20 6.HD, 21.3.1963, E. 435/K. 1375 (**Tunaboylu**, N. 272, sh. 217).

21 **Schmid**, Art. 261, N. 17; **Tandoğan** I/2, sh. 147.

22 6.HD, 3.4.1989, E. 2797/K. 5726 (**Tunaboylu**, N. 217, sh. 180-181).

23 6.HD, 11.4.1969, E. 954/K. 1568 (**Tunaboylu**, N. 262, sh. 212).

24 **Tercier**, N. 1154; **Reymond**, sh. 228; BGE 68 II 247; **Engel**, sh. 158.

25 6.HD, 1.5.1995, E. 4389/K. 4566 (**Tunaboylu**, N. 167, sh. 144).

26 **Tandoğan** I/2, sh. 147-148; **Schmid**, Art. 261, N. 19; **Engel**, sh. 158; **Yavuz**, sh. 278.

27 6.HD, 15.10.1984, E. 9113/K. 9562 (**Uygur**, C.4, sh. 547-548). Yargıtay'a göre, aynı binada oturmayan kiralayana hakaret BK m. 256/II anlamında açıktan açığa fena kullanma sayılır: 6. HD, 12.6.1995, E. 5799/K. 5991 (**Tunaboylu**, N. 163, sh. 142); 6.HD, 28.4.1987, E. 3708/K. 5313 (YKD 1987, sh. 1321); 6.HD, 13.9.1995, E. 7661/K. 7903 (YKD 1996, sh. 26).

darp etmesi[28], kiralananda kiracı tarafından beslenen köpeklerin bina dahilinde oturanların huzurunu bozması ve koku yayması[29], kiracının kiraya vereni dövmesi[30] kiralananda geç vakte kadar içki içip müzik çalma ve merdivenlerin koku yapar şekilde kirletilmesi[31], kiracının bina dahilinde oturanlara tecavüzkâr hareketlerde bulunması[32] halleri bina içinde oturanlara saygı yükümünün ihlalidir.

3. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

TBK m. 317'ye göre, "Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır". Burada kiracının kiralananın olağan temizlik, bakım ve tamir giderlerini ödeme yükümü söz konusudur. Başka bir ifadeyle olağan kullanım için gereken temizlik ve küçük tamirat masraflarını (mesela anahtar veya sigortanın değişimi) kiracı karşılamak durumundadır. Kanun bu konuda yerel adetlere de bakılacağını ifade etmektedir.

4. Kiracının ayıpları kiraya verene bildirme borcu

TBK m. 318'e göre, "Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur". Bu hükmün amacı, ayıp ağırlaşmadan önce kiracının kiraya verene haber vererek, kiralanan şeyi çabuk bir şekilde tamir ettirmesini sağlamak ve böylece onun malvarlığını korumaktır[33]. Kısaca zararın artmasını önlemektir.

5. Kiracının ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu

TBK m. 319'a göre, "Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yüküm-

---

28 6.HD, 28.3.1989, E. 4005/K. 5089 (**Tunaboylu**, N. 218, sh. 181).

29 6.HD, 22.9.1983, E. 8560/K. 8905 (**Tunaboylu**, N. 182, sh. 155).

30 6.HD, 14.4.1988, E. 4600/K. 6682 (**Tunaboylu**, N. 214, sh. 178).

31 6.HD, 18.11.1992, E. 12771/K. 13325 (**Tunaboylu**, N. 193, sh. 163).

32 6.HD, 4.11.1991, E. 12857/K. 13349 (**Tunaboylu**, N. 208, sh. 174); Kiracının gürültü yapması nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmemesine dayalı tahliye davasında Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu uyarıncı idari işlem yapıldığına dair bir bilgi bulunmadığından sadece davacının kızı ve dünürünün tanık beyanları ispata yetersiz bulunmuştur (6. HD. 26.9.2013 tarih E. 2013/11150 K. 2013/13173 –Kazancı).

33 **CR- CO I, Lachat**, art. 257g, n. 1.

lüdür". Tamiratın niteliği gerekli kıldığı takdirde, kiraya veren kiraya verilen yerin geçici olarak boşaltılmasını da isteyebilir[34]. Bu şekilde bir geçici tahliye halinde kira sözleşmesi devam ettiği için, kiraya veren zorunlu tamirat süresi sonunda kiralananı kiracıya teslim etmek zorundadır[35].

TBK m. 319/ II ve III'e göre, "Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür (f. I). Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır (f. II)". Görüldüğü gibi, II. fıkrada kiracının kiralananın gezilip görülmesine katlanma yükümü; III fıkrada da, kiraya verenin, kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirme ve gezilip görülmede kiracının yararlarını gözetme zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Kiracının kiralananın bakım, satış ve yeniden kiralanması amacıyla gezilip görülmesine katlanma yükümü, zorunlu olduğu ölçüde ve kiracının yararının hakkaniyete uygun olarak gözetilmesi suretiyle gerçekleşecektir.

6. Kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanım giderlerini ödeme borcu

TBK m. 341'e göre, "Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür (f. I). Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır (f. II)".

7. Kiracının yukarıda açıklanan borçlarını yerine getirmemesinin sonuçları

Kiracının yukarıda açıklanan yükümleri yerine getirmemesi halinde, kiraya veren aşağıdaki haklara sahip olur:

a) Kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşularına gerekli saygı gösterme yükümüne aykırı davranması halinde, kiraya veren, konut veya çatılı işyeri kirasında en az otuz gün süre vererek söz ko-

---

[34] **Tandoğan** I/2, sh. 151; 6.HD, 13.12.1982, E. 12066/K. 12061 (**Uygur**, C.4, sh. 506).

[35] 13.HD, 8.3.1982, E. 1108/K. 1541 (**Uygur**, C.4, sh. 504).

nusu aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı bir ihtarla kiracıya bildirir; diğer kiralarda ise, kiraya veren herhangi bir ihtarda bulunmadan yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m. 316/II)[36].

Konut veya çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya süre vermenin faydasız olacağının anlaşılması veya kiracının davranışının kiraya veren ile komşular bakımından çekilmez olması hallerinde, kiraya veren yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m. 316/ III)[37].

b) Kiracı kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin ihbar borcunu yerine getirmediği takdirde bundan doğan zararı tazmin etmek zorundadır (TBK m. 318).

c) Kiracının kiralanandaki ayıpların giderilmesine ve onun gösterilmesine katlanma borcunun ihlal edilmesi halinde, kiraya verenin bu yüzden uğradığı zararı tazmin etmesi gerekir.

II. Kira bedelini ödeme borcu

Kira bedelini ödeme borcu, kiraya verenin kiralananın kullanılmasını kiracıya devir borcunun karşılığı olup, kiracının aslî edim yükümlerindendir. TBK m. 313'te, "Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür" hükmü yer almaktadır.

Tartışmalı olmakla birlikte kira bedeli içine yan giderlerin girmediği kabul edilmektedir. Bu nedenle yan giderlerin kira bedeli içinde yer alması için ayrıca kararlaştırılması gerekir. Vergi borcunun kural olarak kira bedeli içinde bulunduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle aksi kararlaştırılmadıkça vergi borcunu kiraya veren öder. Ancak uygulamada açık veya zımni olarak vergi borcunun kiracı tarafından ve kira bedelinden ayrı olarak ödeneceği kararlaştırılmaktadır. Örneğin işyeri kiralarında her ay veya üç ayda bir stopaj ödenmesi zorunluluğu bu-

---

[36] Dava konusu olayda sözleşme ile dava konusu yeri genişletemeyeceği hükme bağlanmıştır. Kiracı Cafe kullanımındaki yapının metrekare kullanımına uymayarak ilaveler yapmıştır. TBK m. 316'ya aykırılık nedeniyle açılan davada tahliye kararı verilebilmesi çin sözleşmeye aykırı davranışın kiralananın kullanımına ilişkin olması gerekir. Kira konusunu verilen zararlar bu madde kapsamında sözleşmeye aykırılık olgusu olarak kabul edilemeyeceğinden tahliye kararı verilemez (6. HD. 3.3.2014 tarih E. 2014/1854 K. 2014/2405 –Kazancı-).

[37] 6. HD. 20.1.2014 tarih E. 2013/16586 K. 2014/570 -Kazancı-.

lunmaktadır. Uygulamada stopajın her zaman kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırılmaktadır.

Kira sözleşmesinde ivaz kural olarak paradır. Para dışında hizmet gibi diğer ivazların öngörüldüğü sözleşmelerde karma sözleşme söz konusu olur.

Kira bedeli kararlaştırılmış ancak miktarı belirlenmemişse somut ilişkiye ve dürüstlük kuralına göre belirlenmesi gerekmektedir. Yargıtay da bu görüşe uygun karar vermektedir.

Tarafların daha az vergi ve işyeri kiralarında daha az stopaj vermek için çifte kira sözleşmesi yapması halinde bedelde muvazaa söz konusudur. Bu durumda tarafların vergi miktarını azaltmak için yaptıkları ve gerçek iradelerini yansıtmayan sözleşme yerine gerçek iradelerini yansıtan asıl sözleşme esas alınır. Sözleşmeye göre kira bedeli bu sözleşme üzerinde belirlenir.

Son olarak, kira bedelinin aylık, üç aylık, haftalık gibi dönemsel ödeneceği kararlaştırılmışsa TBK m.147/I'e göre beş yıllık zamanaşımına tabidir. Buna karşılık bir defada ödenmesi kararlaştırılmaşsı TBK m.146'ya göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

1. İfa zamanı ve yeri

TBK m. 314'e göre, "Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür".

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre[38] kira sözleşmesinde kira bedelinin her ay işlemeden peşin olarak ödeneceğinin kararlaştırılması halinde, ödemenin her ayın üçüncü günü akşamına kadar yapılması gerekir.

Kira bedelini ödeme borcu götürülecek borçlardan olup, aksine bir anlaşma olmadıkça kiraya verenin yerleşim yerinde (TBK m. 89/ b.1) ödenir; kiracı, ödemeyi, kiraya verenin konutunda elden yapmak veya masrafı kendisine ait olmak üzere, konutta ödemeli olarak, postayla göndermek zorundadır[39]. Günümüzde sıklıkla yapılan anlaşmaya göre kira bedelinin kiraya verenin banka hesabına yatırılarak ödenmesi ka-

---

[38] 6.HD, 05.04.2007 tarih ve E. 1868/ K. 3965 sayılı karar (YKD 2007, s. 6, sh. 1083-1084).

[39] 6.HD, 7.10.1993, E. 9398/K. 9785 (YKD 1994, sh. 1759); 6.HD, 16.6.1994, E. 6446/K. 6724 (YKD 1995, sh. 563); 6. HD. 3.7.2014 tarih ve E. 2014/7392/ K. 2014/8930 –Kazancı).

rarlaştırılmaktadır. Bu ihtimalde kiraya verenin banka hesabını açık tutma külfeti bulunmaktadır. Aksi takdirde diğer şartları varsa alacaklı temerrüdü söz konusu olur. Taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılmadan banka havalesi çıkarma suretiyle kira bedelinin ödenmesi mümkün değildir. Bu yolun tercih edilmesi ve kiraya verenin bunu kabul etmemesi halinde borçlu temerrüdü söz konusu olur. Adi posta havalesi ile yapılan havale borcun ifası sonucunu doğurmaz. Zira kiraya veren para alacağını posta idaresine giderek almak zorunda değildir. Ancak evinde ödemeli havale yapılmışsa bu borcun ifası sayılır.

268 sayılı Gelir Vergisi Tebliğine göre 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir düzenleme çıkarılmıştır. Buna göre, konut kiralarından aylık 500 TL veya üzeri kira geliri elde edenler ile iş yerlerinde kira geliri miktarına bakılmaksızın gelir elde edenler kira ve ödemeleri banka veya PTT üzerinden tahsilat makbuzlarıyla belgelemek zorundadır.

2. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin tesbiti (TBK m. 344- 345)

TBK m. 343*'te konut veya çatılı işyeri kiralarında, kira bedelinin belirlenmesi dışında, kira sözleşmesinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı öngörülmüştür[40]. Bu çerçevede kira bedelinin tesbitinin esasları ve dava yoluyla ileri sürülmesi TBK m. 344 ve 345'de düzenlenmiştir.

a) Kira bedelinin tesbitinde izlenecek esaslar (TBK m. 344)*

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu döneminde konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin artırılmasına ilişkin olarak sözleşme özgürlüğü ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. Buna göre, kira sözleşmelerinde, tarafların yenilenen her kira döneminde ödenecek kira bedelinde yapılacak artışlara ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat oranının (ÜFE) aşmamak kaydıyla geçerlidir (TBK m. 344/ I)[41]. Bu

---

[40] 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun bu hükmünün uygulanmasına kadar Yargıtay içtihatları ile oluşturulan kira bedeline ilişkin artırım kuralları uygulanmaktadır. 18.11.1964 gün, 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3.maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra, yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedeli mahkemece belirlenmektedir.

[41] Üretici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın üçüncü günü ilan edilmektedir. Sözleşmede kira bedelinin sadece enflasyona göre zam ya-

kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerine de uygulanmaktadır. Buna karşılık, tarafların yenilenen dönemlerde artış oranı veya miktarı konusunda herhangi bir anlaşma yapmamaları halinde, kira bedeli bir önceki kira yılının üretici fiyat oranını geçmemek kaydıyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir (TBK m. 344/ II)[42]. Hakim hakkaniyet ölçütünü kullanırken kiralananın durumunu göz önünde tutacaktır[43].

TBK m. 344/ III'e göre, "Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir". Bu fıkrada yer alan "beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri" ibaresi, tarafların yenilenen dönemde kira bedelinin artış oranı ve miktarı hakkında anlaşmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşinci yılın sonuna kadar yenilenmiş bütün belirli süreli kira sözleşmelerini kapsar[44]. Bu fıkra uyarınca hakkaniyete göre kira tesbitinde, hakimin, üretici fiyat endeksindeki artış oranının, kiralananın durumunu ve emsal kira bedellerini nazara alacağı TBK m. 344/ III, c. 1'de ifade edilmiştir.

TBK m. 344/ IV'e göre, "Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik

---

pılacağı kararlaştırılmıştır. Bu artış şartının belirli ve muayyen olduğundan söz edilemez (6. HD. 20.11.2014 tarih E. 2014/10692 K. 2014/12773 –Kazancı-).

42 Kira bedelinin tespiti kamu düzenine ilişkindir. Buna ilişkin davanın amacı yeni dönemde belli olmayan ücret unsurunu belirli hale getirmektir. Kira tespitinde hukuki sonuç hakimin kararıyla doğmaktadır. Bu haliyle kira tespit davaları eda davası sonunda verilen kararlara değil inşai davalar sonunda verilen yakın nitelik taşımaktadır (HGK 26.2.2014 tarih E. 2013/3-633 K. 2014/154 –Kazancı-).

43 **Gümüş**, sh. 66.

44 **Gümüş**, sh. 64 vd.; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdikten sonra açılan davada, kira bedelinin hak ve nasafet kuralına göre belirlenmesi için 4 + 1 kuralının uygulanması gerekir. İlk yıl sözleşme hükmü, uzayan dört yıl ÜFE oranını geçmemek üzere endeks üzerinden bedel tespiti yapılmalı, beş yıldan sonra –altıncı yıl- için hak nasafet kuralı uygulanmalıdır (6. HD. 12.1.2015 tarih E. 2014/4518 K. 2015/27 –Kazancı-).

yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, "Aşırı ifa güçlüğü" başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır".

b) Tesbit davası açma süresi ve verilecek kararın etkisi

TBK m. 345/ I hükmü uyarınca kira bedelinin belirlenmesine (tesbitine) ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak verilecek kararın zaman açısından etkisi bakımından TBK m. 345/ II ve III. fıkrasında iki ihtimale göre düzenleme yapılmıştır:

- Taraflar, kira sözleşmesinde, yenilenen her kira döneminde kira bedelinin arttırılacağı ya da artış oranını veya miktarı konusunda bir hükme yer vermemişlerse, açılacak tespit davasının süresi ve verilecek tespit hükmünün etkisi TBK m. 345/ II'de düzenlenmiştir. Buna göre, kira sözleşmesinde yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm kararlaştırılmamışsa; kiraya veren, yeni kira döneminin başlangıcından en az otuz gün önce, kira tesbit davası açmışsa veya kira bedelinin arttırılması için kiracıya bu tarihten önce yazılı bir ihtarda bulunmuşsa, yeni dönem sonuna kadar tesbit davası açabilir; mahkemenin vereceği tesbit hükmü yeni dönemin başından itibaren geçerli olur (TBK m. 345/ II). bu fıkra metninde bir ifade zaafı bulunmaktadır. Eğer kira tesbit davası yeni dönem başlangıcından en az otuz gün önce açılmışsa, bu dönem içinde yeni bir dava açmaya gerek yoktur; bu süreden önce sadece kiracıya yazılı bir ihbar gönderilmişse, bu takdirde yeni dönem sonuna kadar dava açmak gerekir.

- Kira sözleşmesinde yeni kira döneminde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar dava açıldığı takdirde, mahkemece verilecek tesbit hükmü yeni dönemin başından itibaren geçerli olur (TBK m. 345/ III).

Kira bedelinin tespiti davası gerçek anlamda tespit davası niteliği taşımamaktadır. Zira aynı zamanda eda davası niteliği taşımaktadır. Bu nedenle kararın kesinleşmesi ile ilamlı icraya konulması mümkündür.

3. Kira sözleşmesinin uyarlanması

TBK'nın yürürlüğe girmesinden önce uyarlamaya ilişkin sorunlar aşağıdaki Yargıtay kararları çerçevesinde çözülmekteydi.

Kira sözleşmesinin tarafları, akit serbestisi kuralları çerçevesinde (TBK m. 26, 27), sözleşme süresince ödenecek kira bedelini serbestçe tayin edebilirler. Bu takdirde sözleşme süresi ne kadar uzun olursa olsun, kiraya veren, yukarıda anlatılan şekilde kira parasını tesbit davası açma hakkına sahip değildir[45]. Buna karşılık, Yargıtay, uzun süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin kurulduğu anda mevcut ekonomik ve sosyal şartların, ifa sürecinde, önceden tahmin edilmeyecek derecede olağanüstü ve objektif olarak değişmesi sebebiyle edimler arasındaki dengenin bozulması halinde, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması gerektiğini (MK m. 1, 2 ve 4) kabul etmektedir. Zira bu durumda işlem temelinin çökmesi söz konusudur. İşlem temelinin çöktüğünü tesbit eden yargıç, kira parasını dürüstlük (MK m. 2) ve hakkaniyet (MK m. 4) kuralları çerçevesinde uyarlar[46].

Uygulamada, taşınmaz kiralarında uyarlama önce kiraya veren lehine gündeme gelmiş, daha sonra, özellikle kira bedellerinin yaygın bir şekilde yabancı para birimiyle tesbit edilmesi üzerine kiracılar için de kabul edilmiştir[47].

Kira sözleşmesinde kiraya veren lehine uyarlama, ilk defa Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 12.02.1981 tarihli kararında kabul edilmiştir[48]. Bu karara konu olan olayda, on yıl süreli kira sözleşmesinde, kiraya veren üstlendiği yakıt parasının aşırı ölçüde yükselmesi sonucu, aylık 15.000.- TL olarak kararlaştırılan kira bedelinin yetersiz olduğu iddiasıyla uyarlama davası açılmıştı.

Yargıtay'ın kira sözleşmelerinde uyarlama davalarına ilişkin temyiz taleplerini karara bağlayan 13. Hukuk Dairesi, bu konuda yerleşmiş kararlarında her yıl için kira bedelinin belirlendiği uzun süreli kira ilişkilerinde de uyarlama kararı verilebileceği içtihadında bulunmuştur. 13.HD, 1.4.1985 başlangıç tarihli ve 8 yıl süreli bir kira sözleşmesinde, her yıl için kira bedelinin belirlenmiş olmasına rağmen,

---

45 13. HD. 21.11.1991, E. 8374/K. 10619 (YKD 1992, sh. 81). HGK, 12.12.1990, E. 3-527/K. 627 (YKD 1991, sh. 326) (obiter dictum).

46 13.HD, 19.11.1991, E. 7359/K. 10653 (**Uygur**, C.4, sh. 699-702); 13.HD, 3.7.1991, E. 5339/K. 7518 (**Uygur**, C.4, sh. 704-705).

47 **Burcuoğlu**, Uyarlama, sh. 29.

48 13.HD, 12.02.1981, E. 147/K. 932 (YKD 1982, sh.1561 vd.).

1.4.1989'dan itibaren talep olunan uyarlamanın yapılabileceğine, oldukça uzun gerekçelerle karar vermiştir[49].

Yargıtay 13.HD'nin uyarlama konusundaki yerleşmiş görüşlerini geniş bir şekilde açıklayan 13.3.1985 tarihli kararının[50] metnini, önemine binaen, aşağıda aynen veriyoruz:

"Davacı değişen ekonomik şartları, enflasyon, bölgedeki taşınmazların kira bedellerindeki artışlar karşısında kiralananın kira bedelinin çok düşük kaldığını, katlanılmaz duruma geldiklerini, kira bedelinin bugünkü rayiç kira bedeli 5.000.000 TL.sına artırılarak sözleşmenin uyarlanmasını istemiştir.

Davalı 5 yıllık kira sözleşmesinin tarafların hür ve serbest iradesiyle yapıldığını, uyarlamanın koşullarının oluşmadığını savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkeme uyarlama yoluyla aylık kira bedelinin 4.700.000 TL.si olarak tesbit etmiştir.

Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Sözleşme hukukuna egemen olan sözleşmeye bağlılık (ahde vefa - Pacta Sund Servanda) ilkesi hukukumuzda da kabul edilmiştir. Bu ilkeye göre; sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalıdır. Sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış; kararlaştırılan edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeniyle değişmiş olsa bile borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir.

Gerçekte de, sözleşmeye bağlılık ilkesi hukuki güvenlik, doğruluk, dürüstlük kuralının bir gereği olarak sözleşme hukukunun temel ilkesini oluşturmaktadır. Ancak bu ilke özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandırılmıştır.

Sözleşmenin yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ile sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çelişki hasıl olur ve artık bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet (MK. md. m. 2) kaidelerine aykırı bir durum yaratır hale gelir. Hukukta bu zıtlık (Clausula Rebüs Sic

---

[49] 13.HD, 21.11.1991, E. 8374/K. 10619 (YKD 1992, sh. 80 vd.). Bu yöndeki diğer kararlar için bk. **Burcuoğlu**, Uyarlama, sh. 32 vd.

[50] 13.HD, 13.3.1995, E. 2077/K. 2418 (İzmir Barosu Dergisi 1995, S.2, sh. 152-156).

Standibus = beklenmiyen hal şartı = sözleşmenin değişen şartlara uydurulması) ilkesi ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Tarafların iradelerini etkileyip sözleşmeyi yapmalarına neden olan şartlar daha sonra önemli surette değişmişse artık taraflar o akitle bağlı tutulmazlar: değişen koşullar karşısında Medeni Yasanın 2 nci maddesi uyarınca sözleşmenin yeniden düzenlenmesi imkânı hasıl olur. Sözleşmenin edimleri arasındaki dengeyi bozan olağanüstü hallere harp, ekonomik krizler, aşırı enflasyon örnek olarak gösterilebilir.

Enflasyon, paranın "İŞTİRA-SATIN ALMA" gücünü kaybetmesi nedeni ile fiyatlarda aşırı ve sürekli artış olayıdır.

Yurdumuzda ekonomik koşullar önemli derecede değişmiş, eşya fiyatları tahminlerin üstünde yükselmiş, enflasyonist bu durum artarak bireylerin hayat yükünü çekilmez düzeye çıkarmıştır. Paranın değer kaybı toplumda her zaman her yerde önemli huzursuzluk kaynağı olmaktadır. Son yıllarda da değer kaybı tahminlerin ötesinde artışını sürdürmektedir. Ayrıca yasalarla sağlanan düzenlemelerde de paranın değer kaybının dikkate alınmadığı izlenmektedir. Sözleşmedeki edim ve karşı edim arasındaki dengeyi esaslı surette sarsan olağanüstü olaylara beklenilmeyen olaylar denir.

Önceden görülmeyen değişikliklerin borcun ifasını güçleştirmesi halinde "İşlem Temelinin Çökmesi" gündeme gelir. İşlem temelinin çöktüğün kabul eden hakim; duruma göre, alacaklı lehine borçlunun edimini yükseltmeye, borçlu lehine onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına karar vermek suretiyle sözleşmeyi değişen şartlara uydurur. Başka bir deyimle sözleşmeye müdahale eder.

Sözleşmenin yeni durumlara uyarlanması yapılırken önce sözleşmede, daha sonra kanunda bu hususta intibak hükümlerinin bulunup bulunmadığına bakılır, sözleşmede ve kanunda hüküm bulunmadığı takdirde sözleşmenin değişen hal ve şartlara uydurulmasının gerekip gerekmeyeceği incelenir. Bazen de sözleşmede olumlu ve olumsuz intibak kaydı bulunmakla beraber, bu kayda dayanarak sözleşmenin kayıtla birlikte aynen uygulanmasını talep etmek MK. m. 2/2 hükmü anlamında hakkın kötüye kullanılması manasına gelebilir.

Böyle bir durumda sözleşmedeki intibak kaydına rağmen edimler arasında aşırı bir nisbetsizlik çıkmışsa uyarlama yine yapılmalıdır. İşlem temelinin çöktüğüne ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesinde kaynak olarak Medeni Yasanın 1, 2 ve 4 üncü maddelerinden yararlanıla-

caktır. İşlem temelinin çöktüğünün dikkate alınması dürüstlük kuralının gereğidir. Diğer bir anlatımla durumun değişmesi halinde sözleşmede ısrar etmek dürüstlük kuralına aykırı bir tutum olur. Değişen durumların sözleşmede kendiliğinden bulunan sözleşme adaletini bozması halinde, taraflar bu haller için bir tedbir almadıklarından sözleşmede bir boşluk vardır. Bu boşluk sözleşmenin anlamına ve taraf iradelerine önem verilerek yorum yolu ile ve dürüstlük kuralına uygu olarak doldurulur (MK. m. 1). Bu yönteme sözleşmenin yorum yoluyla düzeltilmesi veya değişen hal ve şartlara uyarlanması denilir. Uyarlama daha çok ve önemli ölçüde uzun süreli borç ilişkilerinde söz konusu olur.

Her talep vukuunda sözleşmeyi değişen hal ve şartlara uydurmak mümkün değildir. Aksi halde özel hukuk sistemimizde geçerli olan "İrade özgürlüğü", "Sözleşme serbestisi" ve "Sözleşmeye bağlılık" ilkelerinden sapma tehlikesi ortaya çıkar. Sözleşmeye müdahale müessesesi istisnai tali (ikinci derecede) yardımcı niteliktedir. Uyarlamanın anlatılan hukuki tanımından sonra şimdi, sözleşmeye müdahale için gerekli olan esaslara değinelim:

Sözleşme kurulduktan sonra onun ifası sırasında ortaya çıkan olaylar olağanüstü ve objektif nitelikte olmalıdır. Örneğin para değerinin aşırı derecede düşmesi (enflasyon gibi...).

Yine değişen hal ve şartlar nedeniyle tarafların yüklendikleri edimler arasındaki denge aşırı ölçüde ve açık biçimde bozulmuş olması şarttır. Ne var ki değişen hal ve şartlara rağmen aşağıdaki hallerden biri mevcutsa sözleşmenin değiştirilmemesi kaçınılmaz olacaktır.

Sözleşmede veya yasada değişen hal ve şartlara dair bir kayıt veya hüküm bulunmaması gerekir. Nitekim, sözleşmedeki bir kayıtla değişen hal ve şartların rizikosunu üstlenen kimse doğruluk ve dürüstlük kuralına dayanarak sonradan bu rizikodan kendisini kurtaramaz.

Uyarlama isteyen davacının değişen hal ve şartların ortaya çıkmasına kendi kusuru ile sebebiyet vermemelidir. Değişen hal ve şartlar taraflar bakımından önceden öngörülebilir (tahmin edilebilir) veya beklenebilir nitelikte olmamalıdır veya olaylar öngörülebilir nitelikte olmakla beraber bunların sözleşmeye olan etkilerinin kapsam ve biçim bakımından bu derecede tahmin edilmemelidir. İlaveten edimler henüz ifa edilmemiş olmalıdır. Davacı değişen hal ve şartlara rağmen edimini "ihtirazı kayıt" koymaksızın ifa etmişse uyarlama talep edemez

(Doç. Dr. İbrahim Kaplan, Hakimin sözleşmeye müdahalesi, Ankara-1987, sh. 152 vd.).

Bu davalarda hakimin gözönünde tutacağı temel esaslar da genel olarak şunlar olabilir: sözleşmeye bağlılık ve saygı esastır. Uyarlama daima yardımcı bir çözüm olarak düşünülmelidir. Karar verilirken sözleşmeye yönelik ve bağlantılı değerlendirme yapılmalı, özellikle tarafların farazi iradeleri yani taraflar sözleşmede açık kalmış hukuki meseleyi sözleşmenin in'ikadı sırasında düzenlemiş olsalardı doğru ve makûl düşünen taraflar olarak neyi kararlaştırmış olabileceklerinin tesbitine önem verilmelidir. Somut sözleşmenin özelliği koşulları süresi beklenilmeyen ekonomik değişiklikler (enflasyon) kiralananın nitelikleri, sözleşmenin anlamına aykırı olmayacak şekilde her iki tarafın menfaatleri gibi tüm objektif ve sübjektif hal ve şartlar tartışılıp kıymetlendirilmeli, sonuçta uyarlama yapılması kanaatına kavuşulursa hakim, sözleşmedeki intibak boşluğunu hak ve nasafet, doğruluk dürüstlük kuralları (MK. md. 4.2) ışığında kanun boşluğunda olduğu gibi M.K.nun 1. maddesindeki yetkiye dayanarak yine bizzat kendisinin yaratıp takdir ettiği bir kuralla doldurmaya çalışmalıdır. Sözleşmenin değişen hal ve şartlara intibakını öngören veya görmeyen her türlü karar, yukarıda açıklanan esasların, toplanan delillerin red ve kabul edilen yönlerinin dayanaklarını içerir şekilde gerekçeli ve Yargıtay denetimine uygun olmalıdır. Önemle vurgulayalım ki; belirtilen uyarlama davalarına özgü temel kurallar gözetilmeksizin salt kira parasının tesbitine ilişkin davalarda izlenen yöntemlerle örneğin sadece taşınmazın cinsi, yüzölçümü, bulunduğu mevkii, emsal taşınmazların kira bedelleri gibi donelerle intibak boşluğu, doldurulup sözleşme düzeltilemez. Değerlendirmede bunlar ancak yardımcı kaynak olarak gözetilebilir. Diğer bir anlatımla sözleşmede yüklenilen edimleri tamamen başka bir anlam verilecek hale getirmek suretiyle bir tarafa beklenmedik şekilde olağanüstü yararlar sağlanamaz. Sözleşme yeni bir hale dönüştürülemez. Yine sözleşmenin kurulması sırasında tarafların sözleşmeyi uzun süreli yapmalarına ilişkin birleşen amaç ve iradeleri hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gereken vazgeçilmez bir olgudur. Gerçekte de; uzun bir süreyle kira akdine bağlanmış kiracı ve kiraya verenin hak ve vecibelerini kısa süreli kira sözleşmesinin tarafları ile bir konumda görmenin sözleşme serbestisi ilkesine adalet ve mantık kurallarına aykırı olacağından duraksamaya yer olmamalıdır. Aksinin düşünülmesi halinde sözleşmenin fesih edildiği yeni bir sözleşmenin ortaya çıktığı

sonucuna kavuşmak gerekir ki hükümlerini sürdüren, bağlayıcı ve ayakta duran sözleşme karşısında bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu yüzden kiralananın sanki boş durumda yeni kiraya verilecekmiş gibi gözetilerek rapor düzenleyen bilirkişilerin görüşleri uyarlama ilkelerine ters düştüğü için aynen hükme esas alınıp sözleşme boşluğunun düzeltilmesi yoluna gidilemeyeceği çok açıktır. Yukarıda geniş şekilde açıklanan uyarlama kurallarının ışığı altında mahkemece yapılacak iş resmi kurumlardan enflasyon oran ve seyri araştırılmalı, bununla birlikte kiralananın kullanım sahası, nitelikleri bulunduğu mevkii, konumu, emsal kira paraları sözleşmenin kurulduğu davanın açıldığı tarih itibariyle vergi ve amortisman giderleri artış oranı ve diğer makul ve normal objektif etkenler yerinde uzman bilirkişiler aracılığı ile incelenmeli, böylece belirlenecek uygun durum baz kabul edilmeli, daha sonra az yukarıda anlatılan uyarlama ilke ve esaslarına sadakatla hal ve şartların değişmesi nedeniyle borçluya (kiracıya) ne miktarda mükellefiyet yüklenebileceği tartışılmalı kira parası tarafların amacına uygun objektif iyiniyet, hakkaniyet ve nasafet (MK. md. 4.2) kurallarının elverdiği ölçü ve düzeyde aşırı olmayan, tahammül edilebilir bir seviyeye getirilmeli sonuçta tüm dayanakları belirtmiş, gerekçeli karar verilerek sözleşmedeki intibak boşluğu doldurulmalıdır."

Yargıtay, sadece kiraya veren değil, özellikle yabancı para birimine endeksli veya onunla ifade edilen kira bedellerinde, kiracı lehine de uyarlama yapılabileceğini kabul etmektedir. Nitekim, 13.HD'nin 24.10.1994 tarihli kararında[51] bu husus aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

"Davacı, davalının maliki bulunduğu taşınmazı 5.1.1993 tarihinde aylık net 3000 Amerikan Doları'na kiraladığını, kira parasının sözleşmenin kurulduğu tarihte Türk Parası karşılığının 26.106.000 TL. iken, yaşanan ekonomik kriz ve alınan devalüasyon kararlarıyla Dolar'ın 40.000 TL.sına kadar yükseldiğini, o nedenle 120.000.000 TL. kira parası ödemek zorunda kaldığından, sözleşmenin ifasının çekilmez ve katlanılmaz hale geldiğini, işlem temelinin çöktüğünü öne sürerek, sözleşmenin yeni hal ve koşullara uyarlanmasını istemiştir.

Davalı, asıl olan sözleşmeye bağlılık ve sadakat olduğunu, serbest irade ile kira parasının Amerikan Doları üzerinden ödenmesinin taraflarca kararlaştırıldığını, Dolar'ın değerinde de bir değişiklik olmadığını savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

---

[51] 13.HD, 24.10.1994, E. 6791/K. 9014 (YKD 1994, S. 12, sh. 1939 vd.).

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa – Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalıdır. Eş söyleyişle, sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, sözleşme serbestliği ilkesi tarafların birbirleri karşısında eşit hak sahibi olarak bulunmalarını gerektirir.

Gerçekte de, sözleşmeye bağlılık ilkesi; hukuki güvenlik, doğruluk, dürüstlük kuralının bir gereği olarak sözleşme hukukunun temel ilkesini oluşturmaktadır. Ancak, bu ilke özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandırılmıştır.

Sözleşmenin yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ile sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çelişki hâsıl olur ve artık bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet, (MK. md. 4, 2) kaidelerine aykırı bir durum yaratır hale gelir. Hukukta bu zıtlık (Clausula Rebus Sic Stantibus – beklenmeyen hal şartı – sözleşmenin değişen şartlara uydurulması) ilkesi ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Tarafların iradelerini etkileyip sözleşme yapmalarına neden olan şartlar daha sonra önemli surette, çarpıcı, adaletsizliğe yol açan olayların gerçekleşmesi ile değişmişse taraflar artık o akitle bağlı tutulmazlar. Değişen bu koşullar karşısında Medeni Yasanın 2. maddesinden yararlanılarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesi imkânı hâsıl olur...

Tarafların dövize endeksli kira sözleşmesi yapmalarındaki gerçek ve ortak amaçlarının saptanması uyuşmazlığın çözümünde önem kazanmaktadır.

Yurdumuzda eşya fiyatlarının her geçen gün şaşırtıcı ve beklenilenin üstünde yükselmeler gösterdiği çok açıktır. Memleketin bu hususta yerleşmiş ekonomik durumu bireylerin yaşamını ağırlaştırarak huzursuzluk kaynağı olmaktadır. İşte bu açık olgu karşısında; kiralayan mal sahiplerinin enflasyonun rizikolarından korunmak amacıyla dövize endeksli kira sözleşmeleri düzenledikleri, kiracıların da bunu kabul

zorunda kaldıkları yaşanan bir gerçektir. Demek ki, dövize endeksli kira sözleşmelerinin kurulmasında tarafların gerçek ve ortak amaçları, sırf zaman zaman yükselen enflasyonun olumsuz etkilerinden kiralayanı korumak ve güvence altına almak iradesinden kaynaklandığının kabulü zorunludur (MK. m. 2/1; BK. m. 18). O nedenle; sözleşmenin in'ikadı anında ileride ekonominin aniden bozulacağını, Hükümetçe de bir dizi kararlar alınacağını tarafların tahmin edip, bunun olumsuz sonuçlarına yalnız kiracının peşinen katlanacağını kararlaştırdıkları şeklinde bir yoruma gidilmesi mümkün değildir. Kaldı ki; işlem temelini altüst edecek, çökertecek edimin ifası iktisadi bir yıkım olacak nitelikte fahiş bir durumun vücut bulması hallerinde de çıkar dengesi aleyhine bozulan borçlunun, MK. 2/1'deki kurallarından kaynaklanan "Clausula Rebus Sic Stantibus" (Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması) ilkesi uyarınca, hâkimden sözleşmenin edimler arasındaki bozulan dengesini dürüstlük ve hakkaniyete uygun bir duruma getirmesini isteme olanağına sahiptir. Gerçekte de sözleşme serbestliği ilkesi tarafların birbiri karşısında eşit hak sahibi olarak bulunmalarını ve sözleşmenin kuruluşu ve içeriği üzerinde serbestçe uyuşmalarını gerektirir. Hal böyle olunca da, ekonomideki ani bozulma (kriz) ve buna bağlı olarak hükümetçe alınan kararlar sonucu olarak döviz fiyatlarında meydana gelen şok patlamalar karşısında sözleşmedeki denge davacı kiracı aleyhine katlanılmayacak derecede bozulabilir ve kiracı beklemediği, hiç hesaba katmadığı böyle bir sonuçla borçlarını ödeyemeyecek duruma girebilir. O nedenle, uyuşmazlığın çözümünde sözleşmenin temel edimi olan ve taraflarca başlangıçta kabul edilen döviz fiyatlarındaki normal artışlar dışında, sözleşmenin in'ikadından sonra yaşanan ekonomik kriz ve Hükümetçe alınan kararlarla işlem temelinin çöküp çökmediğinin araştırılması ve aydınlığa kavuşturulması zorunlu olmaktadır. Hemen belirtelim ki, beklenilmeyen, olağandışı sonuçları önceden tahmin edilemeyen ekonomik kriz ve devalüasyondan dolayı kiralayanın bir gün içinde sözleşme dışı nedensiz zenginleşmesi ve yarar sağlaması MK. m. 2/1 hükmünce asla haklı görülemez ve tarafların sözleşmede eşit hak sahibi olmaları ilkesine de aykırı olur; dahası somut adalet duygularını da zedeler. Nitekim, Dairemizin sapma göstermeyen, oturmuş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca ve öğretide de tasvip gören kararlarıyla, enflasyon olgusuna dayanarak kiralayanların açtıkları kira bedelinin yeni şartlara uyarlanması davaları mesmu kabul edilmiştir (Bkz. Yargıtay 13. HD, 14.2.1990,

5697/8708 ve 21.11.1991, 8374/10619; HGK. 1992/13-360 E., 1992/425 K. 1.7.1992 T.). Öyleyse, uyarlama esas ve ilkeleri lehine oluşmuş ise kiracının da kira bedelinin uyarlanması için dava açabileceğinin "Evleviyetle" kabul edilmesi gerekir.

Uyarlama davalarında hâkimin gözden kaçırmaması gereken temel esaslar şöyle sıralanabilir:

Sözleşmeye bağlılık ve saygı esastır. Uyarlama daima yardımcı bir çözüm olarak düşünülmelidir. Sözleşmeye yazılan özel hükümler yorumlanıp tarafların sağladığı hak ve yararlar, değerlendirilmeli, ekonomik değişikliklerin (enflasyon, devalüasyon) etkileri, kiralananın nitelikleri gibi, somut olayın özelliği ile belirlenecek tüm objektif ve sübjektif hal ve koşullar kıymetlendirilmeli, uyarlama yapılması kanaatına kavuşulursa, sözleşmedeki intibak boşluğu hak ve nasafet, doğruluk, dürüstlük kuralları (MK. m. 4, 2/1) ışığında yasa boşluğunda olduğu gibi MK. m. 1'deki yetki kullanılarak doğrudan kendisinin yaratıp takdir ettiği bir kuralla hâkim tarafından doldurulmalıdır. Sonuçta verilecek her türlü karar, az yukarıda açıklanan esaslara aykırı olmamalı, özellikle toplanan delillerin red ve kabul edilen yönlerini, dayanaklarını içerir şekilde gerekçeli ve Yargıtay denetimine uygun olmalıdır. Yukarıda geniş şekilde açıklanan, uyarlama yöntem ve kurallarının ışığı altında mahkemece yapılacak iş; yerinde uygulama yapılıp uzman bilirkişiler düşüncesinden de yararlanmak suretiyle; sözleşmenin kurulduğu günden dava tarihine kadar geçen süre içinde Ülkemizin yerleşmiş ekonomik koşullarının etkisiyle sözleşmedeki yabancı paranın (dövizin) Türk Parası karşısında normal artışlarla ulaşması gereken değeri bulunmalı, bulunan bu değerin sözleşme gereği kiralayan yararına kabul edilmeli, daha sonra 1994 yılı başlarından itibaren umulanın üstünde hareket gösteren ve giderek aralıksız şiddetini artıran ekonomik krizin ve bu krize bağlantılı ve zorunluluk altında hükümetçe alınan bir dizi ekonomik karar ve tedbirlerin tabii sonucu ortaya çıkan, sözleşmedeki yabancı paranın Türk Parası karşısındaki dava tarihi itibariyle değer artışı tesbit edilmeli, böylece belirlenecek iki değer arasındaki farklılık miktarı, sözleşmedeki özel hükümler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgede kira parasında etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticari gelişmeler gibi değişiklikler, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar ile, somut olayda görülebilen objektif etkenlerle karşılaştırılıp, değerlendirilmeli, sonuçta işlem temelinin çöktüğü, sözleşmedeki çıkar dengesinin

katlanılamayacak derecede davacı aleyhine bozulduğunun benimsenmesi halinde, kiracının ne miktar kira parasından sorumlu olacağı belirlenmeli, böylece sözleşmedeki kira parasını tarafların amacına uygun objektif iyiniyet hak ve nasafet (MK. m. 4, 2/1) kurallarının elverdiği ölçü ve düzeyde yine yabancı para olarak uyarlanmalıdır."

Buna karşılık, GKK m. 11 gereğince birer yıl yenilenen kira sözleşmelerinde işlem temelinin çökmesi gerekçesiyle kira bedelinin uyarlama yoluyla tesbiti istenemez: "Kiranın yeni koşullara uyarlanması, ancak uzun süreli kira sözleşmelerinde geriye kalan sürenin çok uzun olması ve kira tesbit davası açılamaması durumunda talep edilebilir. Taraflar arasındaki kira bedeli sadece 1 yıl için bağlayıcı olup 1 yılın sonunda kira tesbit davası açılabileceğine göre kiralayan ayrıca kira bedelinin olağanüstü durumlar nedeniyle uyarlanmasını talep edemez"[52]. Aynı şekilde, uyarlama davalarında, kira tesbit davalarında uygulanan yöntem uyarınca kiranın belirlenmesi yoluna gidilemez[53]; uyarlama davasında tesbit edilecek kira, "hiçbir zaman taşınmazın dava konusu yapılan 1.6.1990 tarihinde boş olarak yeniden kiraya verilmesi durumunda getireceği kira bedeline ulaşamaz. Öte yandan, bu tür davalar kira tesbit davası gibi, sadece emsal rayiçler nazara alınarak saptanamaz. Taraflar arasındaki ilişkinin 1981 yılından beri devam ettiği ve davalının eski kiracı olduğu dikkate alınarak, taşınmazın boş olarak kiraya verilmesi halinde getireceği kira bedelinden daha az bir bedele hükmedilmesi gerekir[54]. Uyarlamada, "sözleşmede yüklenilen edimleri tamamen başka anlam verilecek hale getirmek suretiyle bir tarafa beklenmedik şekilde olağanüstü yararlar sağlanamaz. Sözleşme yeni hale dönüştürülemez... Aksinin düşünülmesi halinde sözleşmenin feshedildiği yeni bir sözleşmenin ortaya çıktığı sonucuna kavuşmak gerekir ki, hükümlerini sürdüren, bağlayıcı ve ayakta duran sözleşme karşısında bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu yüzden, kiralananın sanki boş bir durumda yeni kiraya verilecekmiş gibi gözetilerek rapor düzenleyen bilirkişilerin görüşleri uyarlama ilkesine ters düştüğü için aynen hükme esas alınıp sözleşme boşluğunun düzeltilmesi yoluna gidilemeyeceği çok açıktır"[55].

---

[52] 13.HD, 14.1.1991, E. 5858/K. 161 (**Uygur**, C.4, sh. 698); 13.HD, 18.6.1990, E. 475/K. 4327 (İBD 1990, S. 7-9, sh. 788-789).

[53] 13.HD, 27.5.1991, E. 3368/K. 6052 (**Uygur**, C.4, sh. 696-697).

[54] 13.HD, 3.12.1991, E. 7018/K. 11021 (**Uygur**, C.4, sh. 703).

[55] 13.HD, 13.3.1995, E. 2077/K. 2418 (İzmir Barosu Dergisi 1995, S. 2, sh. 155).

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, uyarlama işleminin, TBK m. 138 çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir. Buna göre TBK m. 138 uyarınca, "Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır (f. I). Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır (f. II)". 12.1.2011 tarih ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun[56] 7. maddesine göre aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138'inci madde görülmekte olan davalarda da uygulanacaktır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 4. maddesine göre kira ilişkisinden doğan tüm davalar sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Bu kuralın tek istisnası İcra İflas Kanununa göre kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesi yoludur.

Kira bedelinin uyarlanması davası kira dönemi içinde herhangi bir tarihte açılabilir. Ancak uyarlama davasından önceki tarih için uyarlama talep edilemez. Bununla birlikte uyarlama hakkı saklı tutulmuşsa saklı tutulma anına kadar geriye dönük uyarlama talebinde bulunulması da mümkündür. Uyarlama yapılırken, enflasyon verileri, kiralananın kullanım alanı, niteliği, mevkii, konumu, emsal kira bedeli, sözleşmenin yapıldğı ve uyarlama davasının açıldığı tarihe göre vergi ve amortisman giderleri artış aranları, diğer menkullerdeki değişiklikleri ve objektif etkenleri dikkate alınmalıdır. Sadece kira bedelinin artırılması için değil kiracı lehine indirim için de uyarlama davası açılabilmektedir[57].

---

[56] RG 4 Şubat 2011 sayı 27836.

[57] Kira bedelinin ÜFE artış oranınına göre hesaplanacak miktarın altında belirlenmesinin özel gelişmelerin, değişen şartların bu duruma neden olan olumsuzlukların bulunması halinde mümkün olabileceği yönünde bkz. HGK 26.2.2014 tarih E. 2013/3-633 K. 2014/154 (-Kazancı-).

4. Kiralananın kullanılmaması sebebiyle kira bedelinin ödenmesi

a) Kullanmanın mümkün olmaması halinde kira bedelinin ödenmesi (TBK m. 324)

TBK m. 324 hükmü gereğince, kiraya veren kiralananı kullanılmaya elverişli durumda bulundurmasına rağmen, kiracı, kendisinden kaynaklanan bir sebeple kiralananı kullanmaması veya sınırlı olarak kullanması halinde de, kira bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Böyle bir durumda kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir (TBK m. 324).

b) Kiralananın sözleşmenin sona ermesinden önce geri verilmesi (TBK m. 325)*

TBK m. 325'e göre, "Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer (f.I)[58]. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür (f.II)".

5. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kiracının güvence vermesi

Konut veya çatılı işyeri kiralarında, kiracı sözleşmeyle güvence verme borcu altına girmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz (TBK m. 342/ I*). Güvencenin depozito, teminat gibi genel olarak ifade edildiği hallerde, kiraya verenin kira sözleşmesinden doğan bütün alacaklarını (mesela kira bedeli alacağı veya yan gider alacağı, tazminat alacağı gibi) kapsadığını kabul etmek gerekir[59].

---

[58] Kiracının sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri vermesi halinde kiradan doğan borçlar devam edeceğinden, yerinde keşif yapılarak teslim tarihinden itibaren kiralanan taşınmazın aynı koşul ve şartlarda kiraya verilebileceği ve tadilatın tamamlanabileceği süre tespit edilmeli, buna göre kira bedeline hükmedilmelidir (6. HD. 31.3.2014 tarih E. 2013/9792 K. 2014/4045 – Kazancı-).

[59] **OR- Weber**, Art. 257e, N. 1; **Higi,** Art. 257e, N. 7; **Gümüş**, sh. 160.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa, kiracı, kiraya verenin onayı olmadan çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymeti evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya kesinleşmiş bir icra takibinin veya kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanarak geri verebilir (TBK m. 342/ II). Para veya kıymetli evraka tahakkuk ettirilecek faiz ve temettü (kar payının) da teminatın kapsamında yer alacağı kabul edilmelidir[60].

TBK m. 342/ III gereğince, "Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür".

6. Takas hakkından önceden feragat yasağı

Kiracı veya kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hakkından önceden feragat edemezler (TBK m. 326).

7. Kira parasının ödenmemesinin teminatı: kiraya verenin hapis hakkı

Kanun, taşınmaz kiralarında kira parasının ödenmesini teminat altına almak üzere, kiraya verene kiralananda bulunan taşınır eşyalar üzerinde hapis hakkı tanımıştır (TBK m. 336- 338).

a) Hapis hakkının konusu

TBK m. 336/ I uyarınca, bir taşınmazı kiraya veren, kiralananda bulunan ve onun döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Buna göre, kiraya verenin hapis hakkının konusunu, kiralanan yerde bulunan ve kiralanan şeyi döşemek, süslemek veya ondan yararlanmayı sağlamaya mahsus taşınır eşyalar teşkil eder. Meselâ, bir konuttaki mobilya, halı, radyo, televizyon; bir garajdaki araba; bir depodaki mallar. Ayrıca bu eşyaların İİK m. 82 anlamında haczi caiz olmayan ve mahiyeti itibariyle paraya çevrilemeyen (MK m. 951) eşyalardan olmaması gerekir (TBK m. 336/III).

Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği taşınmazları da kapsar (TBK m. 336/ II).

---

[60] **Higi,** Art. 257e, N. 34; **Gümüş,** sh. 162.

Kiralananda bulunan üçüncü kişilere ait eşyalar da bazı şartlar altında hapis hakkının kapsamına girerler (TBK m. 337). Bu konuda, kiraya verenin iyiniyetli olup olmamasına göre bir ayrım yapmak gerekir.

aa) Kiraya veren iyiniyetli ise, yani kiracının bu eşyaların maliki olmadığını bilmiyorsa ve bilmesi gerekmiyorsa, bunlar üzerinde hapis hakkına sahip olur. İyiniyetin belirlenmesinde bu menkul eşyanın kiralanana getirildiği an esas alınır. Bununla beraber, kiraya veren, kiracının getirdiği eşyanın ona ait olmadığını sözleşmenin devamı esnasında öğrenmişse, en yakın vakit için sözleşmenin feshini ihbar etmezse, bunlar üzerindeki hapis hakkını kaybeder (TBK m. 337/II). Buna karşılık, çalınmış, sahibinin elinden rızası hilafına çıkmış eşyalar üzerinde kiraya veren iyiniyetli olsa bile hapis hakkını kullanamaz (TBK m. 337/I).

bb) Kiraya verenin kötü niyetli olması halinde, üçüncü kişiye ait menkul eşyalar üzerinde, kural olarak hapis hakkı olmaz; alt kiracının getirdiği eşyalara ilişkin TBK m. 336/II hükmü bu kuralların istisnasıdır.

b) Hapis hakkının temin ettiği alacaklar

TBK m. 336/I'e göre, hapis hakkı geçmiş bir senelik ve işleyecek altı aylık kirayı temin eder. Geçmiş bir yılın sonu ile işleyecek altı ayın başlangıcı, takip talebinin yapıldığı veya iflâsın açıldığı tarihten önceki son kiranın muacceliyet tarihine göre hesaplanır[61].

c) Kullanılması

TBK m. 337/ I'e göre, "Üçüncü kişilerin, kiraya verenin kiracıya ait olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği eşya ile çalınmış, kaybolmuş veya başka bir biçimde malikinin elinden iradesi dışında çıkmış eşya üzerindeki hakları, kiraya verenin hapis hakkından önce gelir". Ancak İİK m. 270 hapis hakkının geçici olarak muhafazası için icra memurundan yardım istenebileceğini öngörmektedir. Diğer yandan, TBK m. 338/I'e göre kiracı taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka yere taşımak istediği takdirde kira alacağını güvence altına alacak miktardaki taşınır sulh hakiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkonabilmektedir. Keza, gizlice veya zorla götürülmüş eşya, götürüldükleri tarihten itibaren 10 gün içinde kollun gücünün yardımıyla kiralanana geri getirilir (TBK m. 338/II; İİK m. 271).

---

[61] **Tercier**, N. 1197; BGE 50 III 113; 72 II 364.

8. Kiralananı geri verme borcu

a) Genel Olarak

Kiracı, kiralananı ne durumda teslim almış ise, kiranın bitiminde, o durumda geri vermek (teslim etmek) zorundadır. Kiracı, sözleşmeye uygun kullanma sonucu kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir (TBK m. 334/ I).

Kiracı sözleşmeye aykırı kullanmaktan doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür[62]; kiracının bundan başka bir tazminat ödeneceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir (TBK m. 334/ II).

Kiraya verenen yazılı rızasıyla kiracı kiralananda yenilik ve değişiklik yapabilir. Kira konusunda yapılan yenilik ve değişikliklere kiraya veren rıza göstermişse kiralananın eski durumuyla iadesini talep edemez. Ancak, yazılı olarak kararlaştırılmışsa kiralanın eski haliyle iadesi talep edilebilir. Kiracının kiraya verenin rızasını alarak ancak yazılı bir anlaşma yapmadan yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığı istenemez. Taraflar arasında yazılı bir anlaşma varsa bu durumda değer artışı talep edilebilir (TBK m 321/I-III).

b) Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları kiracıya bildirme borcu

Kiraya veren, geri verme (iade) esnasında kiralananın durumunu incelemek ve varsa kiracının sorumlu olduğu ayıp ve eksiklikleri ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan bir incelemeyle anlaşılmayacak ayıp ve eksikliklerin bulunması halinde, kiracının sorumluluğu devam eder; kiraya veren bu tür ayıp ve eksiklikleri öğrenir öğrenmez kiracıya yazılı olarak bildirmek zorundadır (TBK m. 335).

---

[62] Kiralananın, kullanıldığı süre ve kullanma amacı gözetilerek olağan kullanımdan doğan yıpranma ve eksilmeler dışında kötü kullanılmasından doğan hasar bedeli tespit edilerek tazmin edilir (6. HD. 29.1.2015 E. 2014/6044 K. 2015/593 –Kazancı-; Kötü kullanımdan doğan hasar kiralananın tahliye edildiği tarih esas alınarak hesaplanmalıdır (6. HD. 29.1.2015 tarih E. 2014/6044 K. 2015/993 – Kazancı-).

III. Alt kira, kullanım hakkının devri ve kira ilişkisinin devri

1. Alt kira ve kullanım hakkının devri

TBK m. 322/ I gereğince, kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak şartıyla, kiralananı kısmen veya tamamen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanma hakkını da başkasına devredebilir. Kanun koyucu bu fıkrada iki hali düzenlemektedir. Bunlardan birincisi, kiracının kiralananı başkasına tekrar kiralaması, yani alt kira ilişkisinin kurulması; ikincisi ise, kira sözleşmesinden doğan kullanma hakkının kiracı tarafından bir üçüncü kişiye temlik edilmesidir. TBK m. 322/ II hükmüne göre, konut veya çatılı işyeri kiralarında, kiracının kiralananı başkasına kiralayabilmesi (alt kira) veya kullanma hakkının devredilebilmesi için kiraya verenin yazılı rızasının bulunması zorunludur.

Alt kira sözleşmesi ilk kiracının kiraya veren ve alt kiracının da kiracı sıfatıyla kurdukları bir kira sözleşmesi olup, bununla ilk kiracı kiralananın kullanılmasını kısmen veya tamamen alt kiracıya devretmeyi taahhüt eder[63]; alt kira sözleşmesinin kurulması kiracı ile kiraya veren arasındaki ilk kira ilişkisinden doğan hukuki statüde değişiklik yapmaz; her iki kira sözleşmesi de varlığını sürdürür.

Borçlar Kanunu; alt kira veya kullanma hakkının gerçekleşebilmesini, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğin meydana gelmemesi şartına bağlamaktadır (TBK m. 322/ I). Buna göre, kiracı, alt kiracı veya devralana kendisinin sahip olduğundan daha fazla veya daha uzun süre devam eden bir kullanma imkânı veremez[64].

TBK m. 322/ III'e göre, "Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir". Bu hüküm, kiraya verene, kiralananın esas kira sözleşmesinde öngörülen kullanma amacına uygun hareket etmeyen alt kiracı veya kullanımı devralana doğrudan yönelme hakkı vermektedir. O, ilk kiracı ve alt kiracı veya kullanımı devralandan uğradığı zararın tazminini isteyebilir[65].

---

[63] **Reymond,** sh. 229; **Tercier,** N. 1157; **Schmid,** Art. 264, N. 6

[64] **Becker**, Art. 264 N. 3; **Oser/ Schönenberger**, Art. 264, N. 6 vd.; **Schmid,** Art. 264, N. 8.

[65] **CR- CO I, Lachat**, art. 262, n. 1; **Higi,** Art. 262, N. 27; **Koller,** BT, sh. 233, N. 211.

2. Kira ilişkisinin devri

a) Genel olarak

Kira ilişkisinin devri TBK m. 323*'te düzenlenmiştir. Buna göre, kiracı, kiraya verenin rızasıyla, kira ilişkisini bir üçüncü kişiye devredebilir (TBK m. 323/I)[66]. Böylece, üçüncü kişi –alt kira ve kullanma hakkının devrinden farklı olarak- kiracının yerine geçer (taraf değişikliği), kiracı kiraya verene karşı borçlarından hemen kurtulur; işyeri kiralarının devrinde, devreden kiracının TBK m. 323/ III*'te öngörülen müteselsil sorumluluğu mevcut kalır.

TBK m. 323 gereğince yapılan devir TBK m. 205 anlamında sözleşmenin devri niteliği taşımaktadır. Kira sözleşmenin devri, sözleşmeyi devreden kiracı, sözleşmede kalan kiraya veren ile sözleşmeyi devir alan yeni kiracının rızasını gerektirir.

İşyeri kiralarında TBK m. 323/I/c.2 uyarınca gerçekleşecek sözleşmenin devrinde, devreden kiraya veren, haklı bir sebep olmadıkça taraf değişikliğine rıza vermekten kaçınamaz. Kiracıya kanuni şartların gerçekleşmesi halinde, kiraya vereni buna zorlama veya devredeceği kişiyi ona kabul ettirme imkânı verilmiştir (kanundan doğan sözleşmeyi kurma borcu)[67]. Burada taraflardan birinin sözleşmenin devrine rıza beyanı vermesi mecburiyeti öngörüldüğünden sözleşmenin kanuni devrinden söz edilir[68]. Sözleşmeyi devreden kiracı için bunun bedeli ise, TBK m. 323/ III gereğince müteselsil sorumluluktur[69].

b) Şartları

TBK m. 323/ I uyarınca, kira ilişkisinin devrinin gerçekleşmesi için, kiraya verenin rızası gereklidir. Bu rızayı talep etmek kiracıya aittir[70]. Rıza, kiraya verenin varması gerekli bir irade beyanıyla verilebilir; üçüncü kişinin kira ödemelerini kiraya verenin kabul etmesi örtülü rıza olarak yorumlanamaz. Zira kiraya veren, bunu kiracının verdiği yetkiye dayanarak yapılmış olarak değerlendirmesi mümkündür[71].

---

66 **Ayrıntılı** bilgi için bkz. Ayrancı, Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), 97 vd.

67 **Koller,** BT, sh. 229, N. 189 ve 190; **CR- CO I, Lachat**, art. 263, n. 1; **Tercier/ Favre,** n. 2498.

68 **Ayrancı,** Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), 71-75.

69 **CR- CO I, Lachat**, art. 263, n. 1.

70 **Tercier/ Favre,** n. 2501; **CR- CO I, Lachat**, art. 263, n. 3; **Koller,** BT, sh. 234-235, N. 216.

71 **Tercier/ Favre,** n. 2501; BGE 125 III 226.

Kiraya verenin rızası kiracı ile üçüncü kişi arasındaki devir sözleşmesinin kurulmasından önce veya sonra verilebilir; teknik anlamda bir onay (muvafakat) sayılır[72]. Sözleşmenin devrinin kendine özgü üç taraflı bir sözleşme ile de yapılması mümkündür[73]. Kiraya verenin rızasının yazılı bir şekilde yapılması gereklidir (TBK m. 223/ I); bu kuralın ispat kolaylığı sağlamak amacını taşıdığı, geçerlilik şartı olmadığı kabul edilmektedir[74].

TBK m. 323/ I, c.2'ye göre, "Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz". Haklı sebep teşkil eden durumlar, objektif, sübjektif veya hatta kirayla ilişkisi olmayan nitelik taşıyabilir. Başka bir ifadeyle, dürüstlük kuralı gereğince, devralanı yeni kiracı olarak kabul etmenin kiraya verenden beklenemeyeceği durumlar haklı sebep sayılır[75]. Üçüncü kişinin ödeme gücünün bulunmaması veya kötü bir şöhrete sahip olması, mesleği icra izninin bulunmaması haklı sebebe örnek olarak gösterilebilir[76].

c) Sonuçları

Kira ilişkisini devralan, bu ilişkiden doğan hakların sahibi ve borçların sorumlusu olur[77]; devreden kiracı, kural olarak borcundan kurtulur (TBK m. 323/ II). Devreden kiracının borcundan kurtulması kuralının istisnası, TBK m. 323/ III'te düzenlenmiştir. Buna göre işyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte sorumlu olur. Kiraya veren ve yeni kiracı devredilen kirayla bağlı olur. Devralan, kiracının daha önce mevcut kira ilişkisindeki hak ve borçlarına halef olur, yani onun yerini alır (TBK m. 323/ II).

---

72 **Tercier/ Favre,** n. 2503; **Koller,** BT, sh. 234, N. 215.

73 **Ayrancı,** Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), 97-105.

74 **CR- CO I, Lachat,** art. 263, n. 5; **Koller,** BT, sh. 235, N. 217.

75 **Koller,** BT, sh. 234-235, N. 216; **Tercier/ Favre,** n. 2503- 2504; **CR- CO I, Lachat,** art. 263, n. 6.

76 **Tercier/ Favre,** n. 2504; **Koller,** BT, sh. 235, N. 216; **CR- CO I, Lachat,** Art. 263, n. 6.

77 Burada borç ilişkisine cüzi halefiyet söz konusudur (**Ayrancı,** Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), 55-58; Kira sözleşmesinde bedel artırımına ilişkin hükmün halefiyet nedeniyle yeni maliki bağlayacak olması hakkında bkz. 6. HD. 10.2.2014 tarih E. 2013/15862 K. 2014/1341 –Kazancı-.

§ 22. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

I. Borçlar Kanunu'nun kiraya ilişkin genel hükümlerine (TBK m. 299- 338) göre sona erme sebepleri

1. Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması

Taraflar kira sözleşmesi için, açık veya örtülü bir irade beyanıyla bir süre belirlemişlerse, kira sözleşmeleri kararlaştırılan sürenin sonunda, herhangi bir bildirime gerek olmadan, kendiliğinden sona erer (TBK m. 327/ I ve 300/ II)[1].

TBK m. 327/ II'ye göre, "Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür". Bu fıkrada geçen "açık bir anlaşma olmaksızın" ibaresini İsv. BK. m. 266/ II'ye uygun olarak, "örtülü olarak" şeklinde anlamak gerekir[2]. Buna göre, tarafların, kira sözleşmesini bu şekilde örtülü olarak uzatmaları halinde kira sözleşmesi karine olarak belirsiz süreli bir sözleşme olarak varlığını ve geçerliliğini sürdürür. Bu hükmün anlam ve önemi tartışmalıdır. Üstün tutulması gereken bir fikre göre, örtülü olarak uzatma deyimi örtülü olarak bir devam sözleşmesini (uzatma sözleşmesini) ifade eder; TBK m. 327/ II anlamı sadece, kira sözleşmesinin bir uzatma sözleşmesinin varlığı halinde süresiz sözleşme olarak geçerli olmasıdır. Kiranın uzatıldığını iddia eden taraf böyle bir sözleşme iddiasını isbat zorundadır[3]. Bunun sonucu olarak,

---

1 Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunulmuşsa süre sonunda kira ilişkinisin son bulduğunun kabulü gerekir. Taraflar açık bir anlaşma yapmaksızın kira ilişkisini devam ettirirlerse kira sözleşmesi belirsiz süreli kira ilişkisine dönüşür (6. HD. 14.10.2014 tarih E. 2014/113 K. 2014/10964 –Kazancı-).

2 **Gümüş,** sh. 252; 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi mucibince 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 75. maddesi belediye taşınmazları için de uygulanacağından taraflar arasındaki sözleşme kira süsenin dolduğu tarihte sona erecek, sürenin dolması ile kira sözleşmesi süresiz hale gelmeyecektir. Bu durumda eski kiracı fuzuli şagil durumuna düşeceğinden tahliye talep edilebilecektir (HGK 22.12.2010 tarih E. 2010/13-671 K. 2010/696 -Kazancı-).

3 **Koller,** BT, sh. 182, N. 16; **Higi,** Art. 266, N. 37 ve 50 vd.; **Gümüş,** sh. 253; Aksi fikirde: **OR- Weber,** Art. 255, N. 5.

kiracı veya üçüncü kişilerin verdiği teminatlar ve sözleşmeye dayanan ön alım hakkı devam eder; meğer ki bu teminatların belirli süreli kira sözleşmesi için verildiği açıkça ifade edilmiş olsun[4].

2. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

a) Genel olarak

Tarafların açık veya örtülü bir irade beyanıyla kira sözleşmesinin süresini tayin etmemeleri veya TBK m. 327/ II uyarınca örtülü bir anlaşmayla belirli süreli kira sözleşmesini uzatmaları halinde, belirsiz süreli kira sözleşmesi söz konusu olur. Bu tür sözleşmelerde, TBK m. 328- 330 hükümleriyle taraflara, öngörülen fesih bildirim süresine ve fesih dönemine uygun bir fesih bildirimiyle kira sözleşmesini sona erdirme imkânı verilmiştir. Böyle bir durumda kira sözleşmesinin olağan yoldan veya olağan fesih yoluyla sona erdirilmesinden söz edilmektedir. Aksi takdirde, belirsiz süreli ve feshedilemeyen bir kira sözleşmesi TMK m. 23 / II hükmünün ihlali sebebiyle hukuka aykırı olur[5].

b) Fesih bildiriminin şartları

Fesih bildirimi (congé, denonciation; Kündigung) hukuki niteliği itibariyle varması gereken bir irade beyanıyla kullanılan bozucu yenilik doğuran haktır[6]. TBK m. 328 vd. anlamında fesih bildirimiyle kira sözleşmesinin olağan sona erebilmesi için, bildirim süresine uyulması ve fesih dönemi (vade) sonunun dolması gerekir[7].

aa) Maddi şartlar

Fesih bildirimi maddi şartlar yönünden herhangi özel durumun bulunmasına bağlı değildir; tarafların fesih bildirimi yoluyla süresiz sözleşmeyi sona erdirebilmesi için haklı bir sebebin bulunması ve bunun kanıtlanması gerekmez[8]. Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildirimi yoluyla sözleşmenin sona ermesi TBK m. 347 vd. da düzenlenmiştir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı konut ve çatılı işyeri

---

4 **Higi,** Art. 266, N. 51; **Bail á Loyer, Bohnet/ Dietschiy**, art. 266, n. 9.

5 **Tercier/ Favre**, n. 2344; BGE 103 II 176.

6 **Tercier/ Favre**, n. 2349; **CR- CO I, Lachat**, art. 266a, n. 1; **Higuenin,** BT, N. 513.

7 **Tercier/ Favre**, n. 2352; **CR- CO I, Lachat**, art. 266a, n. 9- 10.

8 **Tercier/ Favre**, n. 2350.

kiralarında TBK m. 347/II'ye göre her zaman bu hakkı kullanabilir. Buna karşılık kiraya verenin sözleşmeyi feshedebilmesi kira ilişkisinin başlamasından on yıl geçmesine bağlanmıştır[9].

bb) Fesih dönemlerine ve bildirim sürelerine uyulması

Karşı tarafa yapılan fesih bildiriminin geçerli olması için kanuni fesih dönemlerine ve sürelerine uyulması gerekir[10]. TBK m. 329 ve 330'da öngörülen süreler, uyulması gereken asgari zorunlu sürelerdir; taraflar bu sürelerin altında bir süre kararlaştıramazlar[11].

- Fesih süresi ve fesih vadesi (le terme; Termin)

Aksine bir anlaşma yoksa, taşınmaza veya taşınır yapılara (TMK m. 728) ilişkin kira sözleşmelerinde yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için; böyle bir adetin bulunmaması halinde altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyularak feshedilebilir (TBK m. 329). Fesih dönemlerinin (vadenin) hesabında kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır (TBK m. 328/ I, son cümle).

Buna karşılık, taşınırlara ilişkin kira sözleşmelerinde, taraflardan her biri üç gün önceden yapılacak fesih bildirimi ile her zaman feshedebilir (TBK m. 330/ I). Bununla beraber, TBK m. 330/ II'ye göre, "Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur".

- Fesih bildirim süresi (Fristen; delai)

Kira sözleşmesinin fesih bildirimi yoluyla sona erdirilebilmesi için, bu bildirimin, taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında, fesih vadesinin sona ermesinden üç ay önce yapılması gerekir (TBK m. 328). Taşınır kiralarında, bu süre kural olarak üç gün (TBK m. 330/ I), TBK m. 330/ II anlamında taşınır kiralarında üç aylık kira döneminin bitiminden bir ay önce yapılmalıdır.

---

9 Dava konusu olayda TBK m. 347/son cümlesinin henüz uygulanması mümkün olmadığından tahliye talebinin reddedilmesi gerekmektedir (6. HD. 17.9.2014 tarih E. 2014/7855 K. 2014/9878 –Kazancı-).

10 **Tercier/ Favre**, n. 2352.

11 **Higuenin,** BT, N. 513; **Higi;** Art. 266, N. 22; **Gümüş**, sh. 257.

c) Şekli

Fesih bildirimi, kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak isbat kolaylığı açısından yazılı şekilde yapılamasında fayda vardır. Konut veya çatılı işyeri kiralarında, fesih bildiriminin geçerliliği yazılı şekil şartına bağlanmıştır (TBK m. 348).

Konut veya çatılı işyeri kiralarında TBK m. 347/ II gereğince kiraya veren on yıl geçtikten sonra kirayı feshedebilir. Bununla beraber bu tür kira sözleşmelerinde, TBK m. 350 gereğince açılacak tahliye davalarında davanın açılacağı tarihin belirlenmesinde TBK m. 328- 330 hükmü uygulanır[12].

3. Kiraya verenin kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcunun ihlal etmesi sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi

Kiracının kiralananı özenle kullanma ve komşularına saygı gösterme borcuna aykırı davranması halinde, konut veya çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin kiracıya yazılı bir ihtar göndererek, otuz gün içinde bu aykırılığı gidermemesi halinde sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi gerekir; diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren önceden ihtarda bulunmadan, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m. 316/ II).

Buna karşılık, konut veya çatılı işyeri kiralarında, kiralanana kasten ağır bir zarar verilmesi, kiracıya süre vermenin faydasız olacağının anlaşılması, bu borcun ihlalinin kiraya veren veya aynı binada oturanlar ile komşular için çekilmez olması halinde kiraya veren yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir (TBK m. 316/ III).

4. Kiracının temerrüdü

TBK m. 315'e göre, "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir (f.I). Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar (f. II)".

---

[12] **Gümüş**, sh. 262.

a) Genel olarak

TBK m. 315 hükmü, kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödemede temerrüde düşmesi halinde, kiraya verene süresi dolmamış kira sözleşmesini önceden fesih yetkisi vermektedir. Bu maddede açıkça düzenlenmeyen hususlarda, TBK m. 117 vd.'da yer alan genel hükümler uygulanır[13].

b) Şartları

Bu madde uyarınca fesih hakkının kullanılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

- Kiralananın kiracıya teslim edilmesi gerekir. İsviçre Federal Mahkemesine göre, kiraya verenin kiralananı kiracının kullanmasına hazır bulundurması yeterli olup, kiracının zilyetliğine geçirmesi zorunlu değildir[14].
- Kiracının kira parasını, kanunda veya sözleşmede belirlenen vadede kısmen veya tamamen ödememiş olması gerekir; aynı sonuç yan giderlerin ödenmemesi halinde de geçerlidir. Zira TBK m. 315/ I'de muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme borcunu ifa edilmemesi ifadesi yer almaktadır. Bu durumda kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödemede temerrüdü gerçekleşmiş olur.
- Kiraya verenin kiracıya süre vererek, bu süre içinde temerrüde düşülen borcu ödememesi halinde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi gerekir[15]. Bu ihbarda sözleşmenin feshedileceği hususunun açıkça vurgulanması gerekir; TBK m. 315'e veya bir sözleşme şartına atıf yapılması yeterli görülmemektedir[16]. Kiracıya verilecek sürenin kirayla ilgili genel hükümlere

---

13 **Tercier/ Favre**, n. 2388; **Koller,** BT, sh. 196, N. 68

14 BGE 127 II 548.

15 İcra Dairesi marifetiyle gönderilen ödeme emri temerrüt ihtarı yerine geçmektedir (6. HD. 18.9.2014 tarih E. 2014/8135 k. 2014/10095 –Kazancı-). Kiraya veren birden fazla kişi ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve tahliye davasını birlikte açmaları gerekmektedir. Aksi halde tahliye davası reddedilir (6. HD. 19.2.2014 tarih E. 2014/85 K.2014/1742 –Kazancı-.

16 **Koller,** BT, sh. 218, N. 149- 150; BGE 136 II 196, Erw. 2.4); Uygulamada kira borcunu ödemede temerrüde düşülmesi halinde İcra ve İflas Kanunun 269 vd. maddelerine göre kira bedeline ilişkin ödeme emri gönderilmekte ve 30 gün

tabi kiralarda en az on gün, konut veya çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün olması zorunludur. Bu süre kiracıya yazılı ihbarın yapıldığı tarihi takip eden günden itibaren işlemeye başlar (TBK m. 315/ II)[17].

- Kiracının verilen sürenin bitiminde ödemeyi yapmaması gerekir.

c) Sonuçları

Sürenin bitiminde kiraya verenin sözleşmeyi feshettiğini kiracıya bildirmesi gerekir. Kiraya verenin sözleşmeyi fesih beyanının TBK m. 125/ II'de olduğu gibi hemen yapılması gerekir[18].

Sözleşmenin bu şekilde erken fesih halinde kiraya veren uğradığı zararların tazminini isteyebilir (TBK m. 125/ II). Kiracı söz konusu tazminat ödeme borcundan kusursuz olduğunu isbat suretiyle kurtulabilir.

5. Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshi

Türk Borçlar Kanunu, İsviçre BK'nun değiştirilen kiraya ilişkin hükümlerine paralel olarak, olağanüstü fesih üst başlığı altında, önemli sebeplerin bulunması (TBK m. 331*), kiracının iflası (TBK m. 332) ve kiracının ölümü hallerine de yer vermiştir. Borçlar kanunu, bunların dışında başka olağan sebeplere de değişik maddelerde yer vermiştir: kiracının temerrüdü (TBK m. 315); özen veya saygı borcunun ihlali (TBK m. 316/ II- III) buna örnek olarak gösterilebilir.

- TBK m. 331/ I, kira sözleşmesinin taraflardan her birine, kendisi için sözleşmeye devamı çekilmez kılan bir önemli sebebin bulunması halinde, sözleşmeyi yasal bildirim süresine uyarak her zaman fesih hakkı tanımaktadır. Bu hüküm emredici nitelikte olup her türlü taşınır

---

içinde borcun ödenmesi ihtar edilmektedir. Bu süre içinde borcun tam olarak ödenmemesi veya yedi günlük itiraz süresi içinde itirazda bulunulmaması üzerine icra mahkemesinde tahliye talepli dava açılmaktadır. Ürün kirasında kiracıyı en az altmış günlük önel verilmelidir (TBK m. 362/II).

17 Adi kira, ürün kirası ve taşınmaz kiralarında icra daireleri marifeti ile tahliye istekli ödeme emrinin gönderilmesi İİK m. 269 vd. hükmüne göre yapılabilmektedir. 13 nolu örnek ödeme emri ile kiracının yedi günlük itiraz süresi olduğu belirtilerek TBK m. 315. maddesi gereğince ödeme için 30 günlük süre verilmektedir. Bu sürenin dolması beklenmeden kira bedeli alacaklısı icra mahkemesinden tahliye talep edememektedir (6. HD 27.11.2014 E. 2014/11950 K. 2014/13161 –Kazancı-).

18 **Koller,** BT, sh. 220, N. 155.

ve taşınmaz kiralarına belirli veya belirsiz süreli olmalarına bakılmaksızın uygulanır[19].

TBK m. 331/ I anlamında önemli sebepler, sözleşme kurulurken öngörülemeyen ve diğer taraf için sözleşmenin ifasını ve sürdürülmesini çekilmez kılan ağır durumların ortaya çıkması halinde söz konusu olur[20]. Bu hüküm işlem temelinin çökmesi halinin uygulama hallerinden birini oluşturur; sözleşmeyi fesheden tarafın bu sebebin doğumunda kusurunun bulunmaması gerekir. Olayda sözleşmeye devamın çekilmez olup olmadığı hususu, mevcut şartlar hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilerek (TMK m. 4), özellikle kiraya veren veya kiracının menfaat durumları göz önünde tutularak tesbit edilir[21].

Haklı sebepler objektif veya sübjektif nitelikte olabilir. Objektif nitelikteki haklı sebepler, taraflardan birinin şahsından kaynaklanmayan sebeplerdir; harp hali veya ağır ekonomik kriz gibi öngörülemeyen dış olaylar buna örnek gösterilebilir. Sübjektif nitelikte haklı sebepler ise tarafların şahsına ilişkindir. Mesela kiracının mali durumunun önemli ölçüde ve sürekli olarak bozulması, ailenin büyümesi veya eşin ölümü[22].

- Önemli sebebe dayanarak sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf, TBK m. 329 ve 330'da öngörülen yasal sürelere uymak zorundadır; bu sürelere uymak kaydıyla fesih beyanı her zaman yapılabilir.

- TBK m. 331/ II'ye göre, "Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar". Fesih beyanına muhatap olan tarafın uğradığı ve tazmini gereken zarar müsbet (olumlu) zarardır.

---

19 **Müler,** n. 950; **Tercier/ Favre**, n. 2423; Yargıtay'a göre TBK m. 331 (BK m. 264) ancak belirli süreli kira sözleşmelerinde uygulanır. Süresiz kira sözleşmelerinde ve taşınır mal kirasında bu hüküm uygulamanamaz (6. HD. 4.6.2013 tarih E. 2013/6353 K. 2013/9857 –Kazancı-). Bu görüşe katılmamaktayız. Zira Kanun "yasal fesih bildirim süresi"ne uymak kaydıyla feshi mümkün kılmakla belirsiz süreli kira sözleşmeleri için ayrık bir hüküm getirmemiştir. Ne var ki belirsiz süreli sözleşmenin feshinde bildirim süresine uymak gerekeceğinden sonuç değişmemektedir.

20 **Tercier/ Favre**, n. 2425; **Müler,** n. 951; **Koller,** BT, sh. 249, N. 275; BGE 122 III 262.

21 **Tercier/ Favre**, n. 2426; **Koller,** BT, sh. 249, N. 275; **Müler**, n. 951.

22 **Müler,** n. 953- 954; **Tercier/ Favre**, n. 2427.

6. Kiracının iflası

TBK m. 332 gereğince kiralananın tesliminden sonra kiracının iflas etmesi yani iflasın açılması halinde kiraya veren işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir (f. I). Kiraya veren, kiracıya ve iflas masasına kendisine güvence verilmesi için yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde güvence verilmediği takdirde, kiraya veren herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir (f. II).

7. Kiracının ölümü

Kiracının ölmesi halinde, onun mirasçıları yasal fesih bildirim süresine (TBK m. 328- 330) uyarak en yakın fesih dönemi için sözleşmeyi feshedebilirler (TBK m. 333).

Buna göre, kiracının ölümü üzerine kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez; TBK m. 333'e göre kiracı veya kiracıların fesih bildirimi üzerine sözleşme bitim tarihinden önce feshedilir. Fesih beyanı, mirasçıların tamamı tarafından yapılabilir.

II. Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi

1. Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerine göre sona erme

Konut veya çatılı işyeri kira sözleşmesinin sona ermesi TBK m. 347- 348'de "bildirim yoluyla", m. 350- 356 arasında "dava yoluyla (tahliye davası açmak suretiyle)" sona erdirme şeklinde düzenlenmiştir. Bununla beraber, kira sözleşmesinin genel hükümlerinde düzenlenen ve sözleşmeden doğan borcun ihlali nedeniyle tarafların sözleşmeyi sona erdirme imkânları, aksine düzenleme olmadıkça konut veya çatılı işyeri kiralarında da uygulanır. Bu husus, TBK m. 347/ III hükmünde öngörülmüştür[23]. Bu çerçevede TBK m. 328'e göre olağan fesih imkânı, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracının her zaman, kiraya verenin ise kiranın başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirme imkânı veren TBK m. 347/II'deki istisna dışında uygulanabilir; Kiracının ölümü halinde mirasçılarının olağanüstü feshi düzenleyen TBK m. 333'ün de ölen kiracının ortaklarının veya bunların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçılarının ya da ölen kiracı ile birlikte aynı konutta

[23] **Yavuz,** sh. 288; **Gümüş,** sh. 313.

oturanların sözleşme ve kanun hükümlerine uydukları sürece taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebileceklerini düzenleyen TBK m. 356 hükmünün uygulama alanında uygulanabilmesi düşünülemez[24].

2. Kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona ermesi

a) Belirli süreli kira sözleşmelerinde

TBK m. 347/ I'e göre, "Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir".

Bu fıkra hükmünde ifade edildiği gibi, belirli süreli konut veya çatılı işyeri kiralarında onbeş gün önce bildirim yoluyla sözleşmenin yenilenmemesini sağlama hakkı sadece kiracıya verilmiştir; kiraya verene, on yıllık uzama sonunda uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak şartıyla, her hangi bir sebep göstermeden sözleşmeye son verebilir.

b) Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde

Bu tür sözleşmelerde kiracı her zaman; kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir (TBK m. 347/ II).

c) Şekli

Bildirimin geçerliliği konut veya çatılı işyeri kiralarında yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

d) Aile konutunda

TBK m. 349'a göre, "Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez (f. I). Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir (f. II). Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını

[24] **Gümüş,** sh. 313.

kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır (f. III)".

e) Kiracının ölümünde sözleşmenin devamı

TBK m. 356'ya göre, "Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler".

3. Tahliye davası açma yoluyla

a) Tahliye davası açma sebeplerinin sınırlılığı

TBK'nın dava sebeplerinin sınırlılığı kenar başlığını taşıyan 354*. maddesine göre, "Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez". Bu hükme göre, kiraya veren, ancak TBK m. 350, 351 ve 352'de öngörülen sebeplere dayanarak tahliye davası açabilir. Burada öngörülen sınırlı sayıda olma ilkesi, kiraya verenin genel hükümlere göre önemli sebeplerle dayanarak fesih hakkını (TBK m. 331) kullanmasını engellemez[25].

b) Tahliye davası süresinin uzaması

TBK m. 353'e göre, "Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır".

Bu hükümle, kiraya veren tarafa, dava açılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunması kaydıyla, bir kira yılı içinde bildirim konusu davanın açılması imkânı verilmiştir.

c) Yeniden kiralama yasağı

Kiraya veren, ihtiyaç (gereksinim) sebebiyle kiralananın boşaltılmasını sağladığı takdirde, haklı bir sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz (TBK m. 355/ II).

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski haliyle, haklı bir sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşası veya imarı gerçekleştirilen taşınmazları yeni durumu ve yeni kira bedeliyle kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın kiraya verenin yapacağı yazılı bildi-

[25] **Yavuz,** sh. 293- 294.

rimi takip eden bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz (TBK m. 355/ II)

Kiraya verenin yukarıda açıklanan TBK m. 355/ I ve II'de öngörülen hükümlere aykırı davranması haklinde, kiracıya bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek yükümlülüğü vardır (TBK m. 355/ II). Zararın dafa fazla olduğunu ileri süren kiracı ispat etmekle yükümlüdür.

4. Tahliye sebepleri

a) Kiraya verenin konut veya işyeri ihtiyacı (gereksinimi) sebebiyle tahliye davası açması

TBK m. 350/ b. 1'e göre, kiraya veren "kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa", kira sözleşmesini açacağı tahliye davasıyla sona erdirebilir. Bu bentte geçen, kiraya verenin "kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler" ise, TMK m. 364 hükümlerine göre belirlenir.

TBK m. 350/ b. 1'e göre tahliye davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

aa) Kiraya verenin kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kiralananı konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacının olması

Yargıtay, kararlarına göre kiraya verenin konut ihtiyacının kabul edildiği başlıca haller şunlardır:

- Kiraya verenin kirada veya bir yakını ile birlikte ona ait evde oturması

Yargıtay kiraya verenin kirada oturmasını ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmak için yeterli saymakta ve onun tahliye tehdidi altında bulunması şartını aramamaktadır[26]. Aynı şekilde, kiraya verenin kiracı olmadan bir yakını ile birlikte ve ona ait evde oturması halinde ihtiyaç şartının gerçekleştiği kabul edilmektedir[27].

---

[26] 6.HD, 7.3.1988, E. 15849/K. 3446 (YKD 1989, sh. 808-809); 6.HD. 4.6.1989, E. 7774/K. 7981 (YKD 1990, sh. 1465-1466); 6.HD, 8.2.1994, E.1169 /K. 1443 (**Tunaboylu**, N. 680, sh. 535)

[27] 6.HD, 3.5.1993, E. 4796/K. 5283 (**Tunaboylu**, N. 690, sh. 541-542); 6.HD, 5.4.1993, E. 3956/K. 4132 (**Tunaboylu**, N. 694, sh. 543-544); 6.HD, 22.11.1989, E. 16027/K. 17996 (Yasa 1990, sh. 637-638).

- ***Kendi konutunda oturmakta olan kiraya verenin haklı sebeplerle kiralananda oturmak istemesi***

Yargıtay, kiraya verenin kendi konutunda oturmakta iken, sağlık durumunun kiraladığı konuta taşınmasını gerektirmesini[28], kiraya verenin oturduğu yerin alan itibariyle konut ihtiyacını karşılamamasını[29], haklı tahliye sebepleri arasında saymaktadır.

- Kiralananın ekonomik açıdan daha elverişli olması

Kiralanan yerin, kiraya verenin halen oturduğu kendi evine nazaran, yakıt ve genel gider açısından daha az masraflı olması ihtiyacın gerçek olduğunu gösterir[30].

İşyeri kiralarında ise, yapılacağı öne sürülen işin belirli bir uzmanlığı gerektirdiği hallerde (meselâ, eczacılık veya avukatlık), uzman olmayan kişinin işyeri ihtiyacı için açtığı tahliye davasını reddetmek gerekir[31]. Buna karşılık yardımcılar vasıtasıyla yapılabilecek işlerde, ihtiyacı ileri sürülen kişinin, işin yapılmasına nezaret edecek durumda olması, tahliye için yeterli sayılmalıdır[32]. Konut ihtiyacı sebebiyle tahliyeden farklı olarak, işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliyede, ihtiyacı ileri sürülen kişinin kirada olması halinde, onun tahliye tehdidi altında bulunması veya ihtiyaç duyulan işyerinin, en az kiracı olarak kullanılan yer kadar elverişli olması şartları uygulamada aranmaktadır[33].

---

28 HGK, 9.5.1990, E. 6-188/K. 288 (**Tunaboylu**, N. 668, sh. 527-528); 6.HD, 9.2.1988, E. 13718/K. 1804 (Yasa 1988, sh. 1156-1157).

29 6.HD, 11.3.1992, E. 3266/K. 3619 (**Tunaboylu**, N. 750, sh. 579); 6.HD, 30.12.1982, E. 13059/K. 13079 (**Burcuoğlu**, sh. 369).

30 **Tandoğan** I/2, sh. 247; **Burcuoğlu**, sh. 370; 6.HD, 25.6.1987, E. 5435/K. 7567 (**Uygur**, C. 4, sh. 874).

31 **Tandoğan,** I/2, sh. 256; **Burcuoğlu**, sh. 410; 6.HD, 4.6.1984, E. 6531/K. 6757 (**Uygur**, C. 4, sh. 915): "Rüştünü ikmal etmeyen davacının oğlunun müstakilen iş yapması ve bunun için kiralananın boşaltılması mümkün değildir".

32 6.HD, 16.10.1987, E. 7487/K. 9942 (Yasa 1988, sh. 734); 6.HD, 11.11.1987, E. 8583/K. 11270 (Yasa 1988, sh. 471-472): HGK, 30.1.1963, E.6-30/K.6 (**Tandoğan** I/2, sh. 257, dn. 255); İstanbul'da oturan davacı, Çanakkale'deki bir hamamı arada sırada gidip gelerek yardımcıları vasıtasıyla işletebilir.

33 6.HD, 25.3.1987, E. 1595/K. 3583 (YKD 1988, sh. 40); 6.HD, 24.11.1989, E. 16195/K. 18242 (Yasa 1990, sh. 409); HGK, 28.12.1985, E. 6835/K. 1052 (**Uygur**, C. 4, sh. 913-914).

Yargıtay içtihatlarına göre, mevcut işyerinin yetersiz olması[34] veya kiraya verenin eczacı kızının resmî işten istifa edip boşta olması[35] hallerinde işyeri ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu kabul edilir. Buna karşılık tahliyesi istenen yerin icra edilecek iş için elverişli ve yeterli olmaması[36], yasal düzenlemelerle getirilen sınırlamalara uymaması[37] veya yapılacak iş için gerekli ruhsat ve iznin alınmamış olması[38] hallerinde tahliye talebi reddedilmektedir.

bb) Kiralananın konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacının gerçek olması

Kiraya verenin konut ihtiyacına dayanarak açtığı davanın samimi ve gerçek olması gerekir. Yargıtay'a göre, kiraya verenin dava devam ederken boşalan dairesini, bakmakla yükümlü olmadığı ve ihtiyacı olmayan yeğenine vermesi ihtiyacın samimi olmadığını gösterir[39]. Keza, kiraya verenin kendisine ait boş bir daireyi kızının ihtiyacına tahsis etmeyerek tahliye davasından kısa bir süre önce kiraya vermesi ihtiyaç iddiasının samimi olmadığını gösterir[40].

cc) Dava açma süresi

Kiraya veren, TBK m. 350/ III uyarınca, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya

---

34 6.HD, 26.10.1987, E. 8311/K. 10272 (Yasa 1988, sh. 599-600); 3.3.1988, E.15213 /K. 3230 (YKD 1989, sh. 34-35); 4.3.1988, E. 15310/K. 3276 (YKD 1989, sh. 37).

35 6.HD, 22.9.1992, E. 8056/K. 8136 (**Uygur**, C. 4, sh. 921-922).

36 6.HD, 2.5.1984, E. 2216/K. 250 (**Uygur**, C.4, sh. 922); 6.HD, 3.2.1993, E. 639/K. 1040 (**Tunaboylu**, N. 918, sh. 692-693).

37 6.HD, 25.12.1991, E. 16118/K. 16498 (**Uygur**, C.4, sh. 918); 6.HD, 26.3.1985, E. 2838/K. 3811 (**Uygur**, C.4, sh. 923).

38 6.HD, 31.3.1981, E. 13779/K. 5324 (**Uygur**, C. 4, sh. 924).

39 6.HD, 8.3.1988, E. 15558/K. 3491 (YKD 1988, sh. 957-958); Yazlık ev olarak kullanılan taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliyesi talebinde, kural olarak ihtiyacın devamlılığı esas iken, yazlık evin yaşam biçimi olarak sürekli konut ihtiyacının bir devamı olarak nitelendirilmesi halinde tahliye kararı verilebilmektedir (6. HD. 12.1.2015 tarih E. 2014/13336 K. 2015/39 –Kazancı-).

40 6.HD, 26.2.1994, E. 1777/K. 2030 (**Tunaboylu**, N. 679, sh. 534-535); HGK, 22.5.1991, E. 6-170/K. 277 (**Uygur**, C. 4, sh. 879-880); İhtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanması gerekir. Devamlı olmayan geçici ihtiyaç tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye kararına yol açmaz (6. HD. 25.9.2014 tarih E. 2014/8931 K. 2014/10381 –Kazancı-).

ilişkin genel hükümlere (TBK m. 328- 329) göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde dava edebilir[41].

dd) Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle dava açması

TBK m. 351'e göre, "Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir (f. I). Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir (f. II)".

b) Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi

TBK m. 350/ b. 2'ye göre, "kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise", kiraya veren kira sözleşmesini, bu maddenin son fıkrasında öngörülen sürelere uymak şartıyla sona erdirebilir.

Bu bent hükmüne göre tahliye davası açılabilmesinin şartları şunlardır:

aa) Kiralananın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya imar amacıyla esaslı surette onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi

Yeniden inşa sebebiyle açılacak tahliye davalarında imar kastı aranmaz; zira imar mevcut bina üzerinde söz konusu olabilir[42]. Buna

---

[41] Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olduğundan davalı taraf ileri sürmese dahi mahkemece kendiğinden göz önönde bulundurulması gerekir. Buna göre tahliye davasının belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılması gerekir (6.HD. 27.10.2014 tarih E. 2014/11209 K. 2014/11683 –Kazancı-).

[42] **Tandoğan** I/2, sh. 278; 6.HD, 26.12.1984, E. 13492/K. 3565 (**Uygur**, C.4, sh. 952); Kira konusu yerde kar karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat yapma yükümlülüğünün üstlenilmesi ve ilgili Belediyeden yıkım kararı alınması tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Yeniden inşaat nedeniyle tahliye kararı verilebilmesi dava konusu yere ilişkin onaylı projenin bulunmasına bağlıdır (6. HD. 2.3.2015 tarih E. 2015/824 K. 2015/2027 -Kazancı-).

karşılık onarım, genişletme ve değişikliğin imar, yani binanın daha iyi duruma sokulması amacıyla yapılması ve esaslı olması halinde tahliye davası açılabilir. Yapılacak değişiklikle binanın daha kullanışlı ve estetik yönden daha güzel hale getirilmesi[43], binanın üst katına çıkışta karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve sosyal bakımdan daha kullanışlı ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi[44], mevcut dairelerin geniş ve iki cepheli daireye çevrilmesi ve çatı katına yeni kat ilavesi ve binanın tamamına kalorifer tesisatı yapılması[45] hallerinde imar amacının varlığı kabul edilmektedir.

bb) Yapılacak onarım, genişletme veya değişiklik işleri esnasında binanın içinde oturmanın veya çalışmanın mümkün olmaması

cc) İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve imar mevzuatına göre mahalline uygulanmasının mümkün olması[46].

Projenin dava sırasında ibraz edilmesi mümkündür[47]; davadan önce inşaat ruhsatının alınması zorunlu olmayıp, tasdikli ön (avan) projeye dayanarak tahliye davası açılabilir[48].

dd) Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılması

TBK m. 350/ II uyarınca kiraya veren, kira sözleşmesini, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

c) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü

TBK m. 352/ I hükmüne göre, "kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltma-

---

43 6.HD, 4.3.1987, E. 1081/K. 2383 (**Uygur**, C.4, sh. 953) (kararda daire adedinin azaltılmasının imar amacına etkili olmadığı belirtilmiştir).

44 6.HD, 20.1.1981, E. 9482/K. 560 (**Uygur**, C.4, sh. 953).

45 6.HD, 30.3.1993, E. 3471/K. 3848 (**Tunaboylu**, N. 1078, sh. 807-808).

46 6.HD, 10.3.1993, E. 2800/K. 3126 (**Tunaboylu**, N. 1081, sh. 809-810); 6.HD, 12.1.1993, E. 1896/K. 1998 (**Tunaboylu**, N. 1083, sh. 810-811).

47 6.HD, 25.11.1968, E. 3776/K. 4864 (**Erdoğan**, sh. 815); 6.HD, 9.9.1968, E. 2506/K. 3642 (İBD 1968, sh. 567); 6.HD, 22.11.1983, E. 10848/K. 11655 (**Uygur**, C.4, sh. 956-957).

48 HGK, 28.12.1993, E.6-745/K. 1410 (YKD 1984, sh. 1471-1474).

yı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir".

Tahliye taahhüdünün geçerliliği ve buna dayanarak tahliye talebinde bulunulması aşağıdaki şartlara bağlıdır:

aa) Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve tahliyenin hangi tarihte yapılacağını göstermelidir

Tahliye taahhüdünün yazılı şekilde yapılmış olması bir geçerlilik şartıdır. Ancak tahliye taahhüdü noterce re'sen düzenlenmediği veya tarih ve imzası tasdik edilmediği takdirde, kiracının imzasını inkâr etmesi halinde, kiraya veren itirazın kaldırılmasını icra tetkik merciinden isteyemez (İİK m. 275/II); sadece mahkemede tahliye davası açabilir[49].

Tahliye taahhüdünde tahliyenin hangi tarihte yapılacağının belirtilmesi gerekir[50]; tahliye taahhüdünde sadece tahliyenin yapılacağı ayın belirtildiği hallerde, bunun ayın son günü olarak yorumlanabileceği kabul edilmektedir[51].

bb) Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesi kurulduktan sonra verilmelidir

Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için ilk kira sözleşmesinin yapılmasından sonra, onun devamı esnasında veya sonraki dönemlerde verilmesi gerekir[52]. İlk kira sözleşmesi kurulmadan veya kurulurken alınan tahliye taahhütleri, serbest iradeye dayanmadıkları için geçersizdir[53].

cc) Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından yapılmalıdır

Birden çok kiracı varsa, tahliye taahhüdünün bütün kiracılar tarafından verilmesi gerekir[54]. Bununla beraber, tahliye taahhüdünün vekil aracılığı ile verilebileceği; vekilin taahhüdünün geçerli olması için,

---

49 **Tandoğan** I/2, sh. 198.

50 6.HD, 20.5.1987, E. 4098/K. 6303 (**Uygur**, C. 4, sh. 824).

51 12.HD, 9.1.1981, E. 4122/K. 5669 (**Burcuoğlu**, sh. 303).

52 6.HD, 17.12.1987, E. 11004/K. 13386 (**Tunaboylu**, N. 641, sh. 504-505); 6.HD, 28.1.1988, E. 12631/K. 1067 (**Tunaboylu**, N. 639, sh. 503).

53 6.HD, 8.2.1991, E. 1187/K. 1624: "4.10.1944 tarih ve 20/28 sayılı içtihadı birleştirme kararına göre, ilk kira ilişkisi kurulmadan veya kurulurken alınan tahliye taahhütlerinin serbest iradeye dayanmaması nedeniyle geçersizliği kabul edilmiştir" (YKD 1991, sh. 698 vd).

54 6.HD, 19.10.1982, E. 9004/K. 9099 (**Tunaboylu**, N. 652, sh. 511).

yetkisinin vekâletnamenin muhtevasından anlaşılmasının yeterli olduğu, ayrıca özel bir yetkiye ihtiyaç olmadığı kabul edilmektedir[55].

dd) Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talep edilmelidir

TBK m. 352/ I uyarınca kiraya veren, kiracının tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten itibaren bir ay içinde icraya veya mahkemeye başvurarak tahliye istemek zorundadır.

d) İki haklı ihtar sebebiyle tahliye

TBK m. 352/ II'ye göre, "Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir".

Bu hükme dayanılarak tahliye davası açılabilmesinin şartları şunlardır:

aa) Kira bedelini ödememeden dolayı kiracıya haklı ihtar yapılmış olması

İhtarın haklı olması için, kira parasının ifa zamanında yerine getirilmemesi, yani muaccel olması üzerine gönderilmiş olması gerekir; muacceliyet tarihinden önce gönderilen ihtar haklı sayılmaz[56]. Aynı şekilde, ihtarın haklılığını tesbitte, ihtarın gönderildiği tarih değil kiracıya tebliğ edildiği tarih göz önünde tutulur[57]; tebliğ tarihinden sonra yapılan ödemeler ihtarın haklılığını gidermez[58].

Kira parasının ödenme zamanı sözleşmeyle kararlaştırılmış olsa bile, kiracının uzun süre ve muntazaman farklı zamanda yaptığı ödemelere kiraya verenin karşı çıkmaması üzerine taraflar arasında bir tea-

---

55 **Burcuoğlu**, sh. 298 ve orada zikredilen Yargıtay 12. HD'nin 12.2.1981, E. 8935/K. 1362 sayılı kararı.

56 6.HD, 9.12.1991, E. 15164/K. 15353 (**Uygur**, C. 4, sh. 995-996; 6.HD, 15.3.1993, E. 3199/K. 3375 (**Tunaboylu**, N. 1168, sh. 941-942).

57 6.HD, 15.4.1985, E. 3986/K. 4902 (**Uygur**, C.4, sh. 998); 6.HD, 20.2.1995, E. 1678/K. 1861 (**Tunaboylu**, N. 1238, sh. 922).

58 6.HD, 28.11.1994, E. 11804/K. 12064 (**Tunaboylu**, N. 1249, sh. 929-930).

mül oluşmuş ise, sözleşmedeki tarihe göre ödeme yapılmadığı için çekilen ihtar haklı sayılmamaktadır[59].

bb) İhtarın yazılı olması ve ödenmeyen kira miktarları ile bunların ait olduğu vadenin gösterilmesi

İhtarın yazılı şekilde gönderilmesi şartı TBK m. 352/ II'de açıkça ifade edilmiştir. İhtar noter aracılığı ile, mektupla, telgrafla veya icradan gönderilecek ödeme emriyle yapılabilir[60]. Ayrıca çekilen ihtarda ödenmeyen kira miktarları ile bunların ait olduğu vadelerin (ayların) gösterilmesi gerekir[61].

cc) Bir kira yılı içinde iki haklı ihtarın yapılmış olması

İhtarın bir kira yılı içinde ayrı ayrı aylara ait olması gerekir; aynı aya ait iki ihtar yeterli değildir[62].

Kira parasının yıllık peşin olarak ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde iki ihtar şartından söz edilemez[63]. Yargıtay, süresiz veya bir yıldan az süreli kira sözleşmelerinde iki haklı ihtar şartının oluşamayacağı fikrindedir[64]. Ancak, 6098 sayılı Kanunun 352/II. maddesine göre, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde kira bedelini ödemediği için iki haklı ihtar çeken kiraya veren kira süresi-

---

59 6.HD, 24.5.1995, E. 4893/K. 5063 (**Tunaboylu**, N. 1237, sh. 921-922); 6.HD, 16.1.1989, E. 15951/K. 63 (**Uygur**, C.4, sh. 994); 6.HD, 26.10.1987, E. 8333/ K. 10289 (Yasa 1988, sh. 161, N. 138); 6. HD, 23.2.1993, E. 2078/ K. 2285 (**Tunaboylu**, N. 1274, sh. 945-946).

60 6.HD, 3.2.1993, E. 462/K. 1000 (**Tunaboylu**, N. 12181, sh. 950); 6.HD, 11.11.1992, E. 12398/K. 12894 (**Tunaboylu**, N. 1286, sh. 953); İki haklı ihtarın muhatabına tebliğ edildiğine ilişkin tebliğ belgesinin aranması gerekir (6. HD. 16.4.2014 tarih E. 2014/4247 K. 2014/5072 –Kazancı-).

61 6.HD, 23.12.1983, E. 13345/K. 13357 (**Uygur**, C. 4, sh. 989-990); 6.HD, 26.1.1981, E. 13808/K. 1309 (**Uygur**, C. 4, sh. 990); 6. HD, 18.1.1995, E. 146/K. 232 (**Tunaboylu**, N. 1241, sh. 924-925).

62 **Tandoğan,** I/2, sh. 225; **Yavuz**, sh. 297; 6.HD, 30.10.1984, E. 10067/ K.10381 (YKD 1985, sh. 814); 6.HD, 3.2.1989, E. 591/K. 1605 (**Tunaboylu**, N. 1327, sh. 981); 6.HD, 21.12.1994, E. 12729/K. 12991 (**Tunaboylu**, N. 1245, sh. 927); 6.HD, 2.11.1992, E. 11720/K. 12354 (YKD 1993, sh. 1646).

63 6.HD, 17.11.1993, E. 11824/K. 12071 (YKD 1994, sh. 1255); 6.HD, 25.11.1986, E. 11663/K. 13371 (**Tunaboylu**, N. 1339, sh. 990). Her ay peşin ödeme kaydının anlamı için bkz. yukarda § 19, dn. 59 ve buna ait metin.

64 6.HD, 6.11.1986, E. 10559/K. 12458 (YKD 1987, sh. 700). Yargıtay'ın görüşünün tenkidi için bk. **Burcuoğlu**, sh. 263 vd.

nin bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilmektedir. Bu nedenle bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde söz konusu tartışmanın yapılmasına gerek kalmamıştır.

dd) Kira süresinin sona ermesini takip eden bir ay içinde tahliye davası açılması

TBK m. 352/ II uyarınca kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

e) Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması (TBK m. 352/ III)

TBK m. 352/ III'e göre, "Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir".

Bu fıkra hükmüne göre tahliye davası açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

aa) Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin maliki bulunduğu bir konutun bulunması

Kiracının veya eşinin sahip olduğu konutun tapulu veya tapusuz arsa üzerinde bulunması önemli değildir[65]; konutun kiracıya kooperatifçe oturulabilecek bir mesken olarak tahsis edilmesi de yeterli olup, ortak adına tapu kaydının bulunması gerekli değildir[66].

bb) Konutun aynı şehir veya belediye sınırları içinde olması

Büyükşehirler söz konusu olduğu takdirde, belediye kavramından "büyükşehir belediyesi"nin anlaşılması gerekir; mücavir alanda olduğu halde belediye hududundan farksız her türlü belediye hizmetlerinden yararlanan yerler de bu madde kapsamına girer[67].

---

[65] 6.HD, 11.10.1984, E. 8957/K. 9380 (**Tunaboylu**, N. 1384, sh. 1023); 6.HD, 9.5.1994, E. 5031/K. 5276 (YKD 1995, sh. 1770).

[66] Yarg. İBK, 21.2.1968, E. 21/K. 4 (RG. No. 12913).

[67] 6.HD, 31.10.1989, E. 14060/K. 16349 (**Kılıçoğlu**, sh 343-344); 6.HD, 22.4.1987, E. 5390/K. 5031 (**Tunaboylu**, N. 1379, sh. 1020). Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5. maddesini değiştiren 6360 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırı olarak belirlendiğinden, "amaca uygun yorum" yapılarak belediye sınırlarının merkeze bağlı ya-

cc) Konutun kiracının kullanmasına elverişli olması gerekir

Kiracının veya eşinin sahip olduğu konutun kullanılmaya elverişliliğini tesbitte, onun fizikî (fiilî) durumu, kiracının nüfus adedi ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur.

dd) Kiraya verenin kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli bir konutu bulunduğunu bilmemesi

TBK m. 352/ III uyarınca tahliyenin talep edilebilmesi için, kiraya veren tarafından, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunduğunu, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bilmemesi gerekmektedir.

ee) Kira süresinin sona ermesini takip eden bir ay içinde tahliye davası açılması

TBK m. 352/ III hükmü gereğince, kiraya veren, kira sözleşmesinin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

---

pı yoğunluğu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle büyükşehir sınırında kalmakla birlikte köy yerleşim alanında kalan konut ihtiyaç sebebiyle tahliyeye engel olmamalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
ÖDÜNÇ VERME SÖZLEŞMELERİ

§ 22. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ

I. Tanımı, hukukî niteliği ve unsurları

1. Tanımı

TBK m. 379'a göre, "Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir". Buna göre kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesi, bir şeyin kullanılmasının belirli bir süreyle başkasına karşılıksız olarak devri borcunu doğuran bir sözleşmedir[1]; devredilen kullanmanın belirli bir süreyle sınırlı olması sebebiyle, kullanım ödüncü alan aldığı şeyi iade ile yükümlüdür.

2. Hukukî niteliği

Kullanım ödüncü sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir; kurulabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterli olup, kullanım ödüncü verilen şeyin teslimi şart değildir; teslim sözleşmenin ifasıyla ilgilidir.

Kullanım ödüncü sözleşmesi karşılıksız ve eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir; karşılıklı edimlerin değişimi söz konusu değildir. Ödünç alanın ödünç konusu teslim aldıktan sonra geri verme borcu bulunmaktadır. Kullanım ödüncü alanın normal bakım masraflarına katlanmakla yükümlü olması (TBK m. 381/I), sözleşmenin bu niteliğini gidermez.

Diğer taraftan, kullanım ödüncü sözleşmesi devamlı borç ilişkisine vücut verir[2]; kullanım ödüncü verenin edimi belirli bir zamana yayılmıştır.

3. Unsurları

a) Bir şeyin (veya hakkın) kullanılmasının devri

Kullanım ödüncü sözleşmesi, kirada olduğu gibi, bir şeyin kullanılmasının devri borcunu doğuran bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin

---

1 **Tercier**, N. 2296; **Reymond**, sh. 264; **Honsell**, sh. 230.

2 OR-**Shaerer**, Art. 305, N. 2; **Tercier**, N. 2299.

konusunu, hasılat getirsin veya getirmesin, her türlü taşınır veya taşınmaz şeyler teşkil eder. Bu cümleden olarak, bir otomobilin, bir dairenin, bir arsanın kullanılmasının devrine ilişkin kullanım ödüncü sözleşmesi yapılabilir. Bir taşınmazın kullanım ödüncüne konu edilmesi halinde sözleşmenin resmi şekle uygun olması gerekmez. Zira, taşınmaz mülkiyeti diğer tarafa geçirilmemektedir. Kural olarak, mislî olmayan şeyler kullanım ödüncü sözleşmesine konu olurlar. Bununla beraber istisnaî olarak, mislî şeylerin de, aynen iade edilmek üzere, kullanım ödüncü olarak verilmesi mümkündür; meselâ, bir sergide gösterilmek üzere değerli pulların veya bir düğünde takılmak üzere bir altın liranın verilmesi[3].

Kullanım ödüncü sözleşmesini tanımlayan TBK m. 379'da sadece şey kavramına yer verilmekle beraber, haklar da kullanılabilir (faydalanılabilir) oldukları ölçüde (meselâ, patent hakkı veya avlanma hakkı) kullanım ödüncü olarak verilebilir[4]. Buna karşılık, alacaklar, kullanılmaları mümkün olmadığı için kullanım ödüncü olarak verilemezler[5].

Kullanım ödüncü verenin mutlaka kullanım ödüncü olarak verilen şeyin maliki olması gerekmez; intifa hakkı sahibi veya şeyi başkasına kullandırma yetkisi olan kiracı da kullanım ödüncü verebilir. Böyle bir durumda, kullanım ödüncü alan, sözleşme sona erince, kullanım ödüncü konusu şeyi malike değil, kullanım ödüncü verene iade etmek zorundadır[6].

b) Kullanmanın devrinin karşılıksız olması

Bu unsur kullanım ödüncü sözleşmesini kiradan ayırt eder. Kullanım ödüncü sözleşmesi, esas itibariyle, kullanım ödüncü alanın menfaatine kurulan bir sözleşmedir. Bununla beraber, bir şeyin kullanılmasının ücretsiz olarak devri, her zaman kullanım ödüncü olarak nitelendirilemez. Meselâ, bir otel idaresinin otelin kapısında görev yapan işçisine üniforma (özel bir elbise) vermesi hizmet sözleşmesine ilişkin bir edimdir[7].

---

3 **Tandoğan** I/2, sh. 288-289; **Engel**, sh. 241; **Yavuz**, sh. 359; **Zevkliler**, sh. 262.

4 **Reymond**, sh. 265; **Tercier**, N. 2303; OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 6; **Tandoğan** I/2, sh. 289; **Zevkliler**, sh. 262; **Yavuz**, sh. 359.

5 **Oser/Schönenberger**, Art. 305, N. 2; OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 6.

6 **Engel**, sh. 242-243; **Tercier**, N. 2312; **Tandoğan** I/2, sh. 289; **Yavuz**, sh. 359; **Zevkliler**, sh. 262; 13. HD, 6.5.1981, E. 3079/K. 5 118: "Âriyet verenin malik olması şart değildir; malik olmayan âriyet veren, âriyet alana karşı sözleşmenin tarafı olarak dava hakkını haizdir" (**Uygur**, C. 5, sh. 353).

7 **Engel**, sh. 242; **Becker**, Art. 305, N. 6.

Diğer taraftan, kullanım ödüncü sözleşmesinde kullanım ödüncü verenin de menfaatinin bulunması, bu sözleşmenin karşılıksız olma niteliğini kaldırmaz. Meselâ, bir spor malzemesinin onu yapan firmanın reklâmını yapan markayı taşıması. Ancak, sözleşme konusu şeyin geçici olarak başkasına bırakılması, münhasıran bunları verenin menfaatine gerçekleşmişse, burada hukuken kullanım ödüncü değil, başka bir sözleşme, bir vedia veya vekâlet söz konusu olur[8].

II. Tarafların borçları

1. Ödünç verenin borçları

a) Kullanım ödüncü konusu şeyi teslim borcu

Ödünç verenin en önemli borcu, kullanılmak üzere kullanım ödüncü konusu şeyi kullanım ödüncü alana teslimdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, kullanım ödüncü veren teslim (zilyetliği geçirme) borcunu hemen yerine getirmekle yükümlüdür (TBK m. 90).

Kullanım ödüncü veren, kullanım ödüncü olarak verilecek şeyi teslim borcunu kusurlu olarak yerine getirmediği veya şeydeki bozukluk yüzünden kullanım ödüncü alanın bir zarara uğramasına sebebiyet verdiği takdirde, TBK m. 112 vd. gereğince sorumlu olur. Kullanım ödüncü sözleşmesinin karşılıksız bir sözleşme olması sebebiyle, TBK m. 114 gereğince kullanım ödüncü verenin sorumluluğunu daha az şiddetle takdir etmek ve ayıptan doğan sorumluluk bakımından TBK m. 294'ü kıyasen uygulamak gerekir[9]. Buna göre, kullanım ödüncü veren kast ve ağır ihmalden dolayı sorumlu olur, vaad edilen nitelikler bakımından da TBK m. 112 vd. uygulanır[10].

b) Kullanım ödüncü alanın yaptığı olağanüstü masrafları ödeme borcu

Ödünç alan taraf ödünce konu şeyin olağan bakım ve koruma giderlerinden sorumludur (BK m. 381/I). Ödünce konu evin temizlik giderleri ile bir otomobilin yakıt, yağ, fren hidroliği gibi olağan giderler bu kapsamdadır.

---

8 **Becker**, Art. 305, N. 6; **Engel**, sh. 242; **Tandoğan** I/2, sh. 290; **Yavuz**, sh. 359.

9 **Becker**, Art. 305, N. 8; OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 12; **Tercier**, N. 2318; **Honsell**, sh. 232; **Engel**, sh. 243.

10 OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 12.

Kullanım ödüncü veren, kullanım ödüncü alanın sözleşme konusu şey için yaptığı olağanüstü masrafları ise ona tazmin etmekle yükümlüdür (TBK m. 381/II).

Olağanüstü masraflar, kullanım ödüncü verilen şeyin alelâde bakım ve muhafaza masraflarını (TBK m. 381/I) aşan, onun varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan masraflardır. Meselâ, kullanım ödüncü verilen otomobilin motorunun değiştirilmesi zorunluluğundan doğan masraflar[11].

Bu masrafların kullanım ödüncü verenin menfaatine olup olmadığını tesbitte vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler kıyasen uygulanmalıdır[12]. Kullanım ödüncü verenin menfaatine olmayan olağanüstü masraflar için, kullanım ödüncü alan sadece sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurabilir[13].

2. Kullanım ödüncü alanın borçları

a) Kullanım ödüncü verilen şeyi sözleşmeye uygun olarak kullanma borcu

TBK m. 380/I gereğince, kullanım ödüncü alan, kendisine kullanım ödüncü olarak verilen şeyi sözleşmeyle öngörülen şekilde; sözleşmede bu konuda bir hüküm yoksa şeyin niteliğine veya tahsis amacına uygun olarak kullanmak zorundadır. Keza kullanım ödüncü alan için kullanım ödüncü verilen şeyi özenle kullanma borcu mevcuttur.

Kullanım ödüncü alan, kullanım ödüncü olarak verilen şeyi başkasına kullandıramaz (TBK m. 380/II). Kullanım ödüncünde kural olarak karşı tarafın kişiliğinin önem taşıdığı kabul edildiğinden, ödünç konusu başka bir kişiye devredilemez. Ancak, ödünç verenin rızası ile devir mümkün olur. Sözleşmeye aykırı kullanma halinde, kullanım ödüncü alan, mütemerrit borçlu gibi, beklenmeyen hallerden dahi sorumlu olur; kullanım ödüncü alan, yükümlerine uygun hareket etseydi dahi, kazanın meydana geleceğini isbat ederek, bu sorumluluktan kurtulabilir (TBK m. 380/III).

b) Kullanım ödüncü verilen şeyin olağan masraflarına katlanma borcu

TBK m. 381/I'e göre, "Ödünç alan, ödünç konusunun olağan bakım ve koruma giderlerini karşılamakla yükümlüdür".

---

[11] OR-**Schaerer**, Art. 307, N. 6.

[12] **Oser/Schönenberger**, Art. 307, N.3; **Tandoğan** I/2, sh. 293.

[13] **Oser/Schönenberger**, Art. 307, N. 3; **Tandoğan** I/2, sh. 293.

Kullanım ödüncü verilen otomobilin yağlama, yıkatma ve benzin masrafları, evin temizlik masrafları bu fıkra anlamında alelâde masraflardan sayılır[14]. Alelâde küçük tamiratlar da bu anlamda masraflar arasında yer alır[15].

c) Geri verme borcu

Kullanım ödüncü sözleşmesi sona erince, kullanım ödüncü alan kullanmak üzere aldığı şeyi iadeyle yükümlüdür. Kullanım ödüncü alan aynen iadeyle yükümlü olup, onun iade borcu bir parça borcu teşkil eder[16]. Ödünç alan aldığı şeyi bu zamandaki haliyle iade eder. Olağan kullanım nedeniyle meydana gelen eskimeler iade kapsamını etkilemez. Kullanım ödüncü veren, kullanım ödüncü olarak verilen şey üzerinde mülkiyet, intifa veya sükna hakkı gibi bir aynî hakka sahipse eşya hukuku hükümlerine göre iade talebinde de bulunabilir. İade borcunun yerine getirilmemesi halinde, kullanım ödüncü alan TBK m. 112 vd. gereğince sorumlu, yani kullanım ödüncü verenin zararını tazminle yükümlü olur; kullanım ödüncü sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmadığı için BK m. 123- 125 uygulanmaz[17].

III. Sona ermesi

1. Sözleşmeyle öngörülen sürenin dolması

Kullanım ödüncü sözleşmesinde belirli bir kullanma süresi öngörülmüşse, bu sürenin dolmasıyla sözleşme sona erer. Bu süre belirli bir zaman dilimi (meselâ 2 ay) şeklinde veya belirli bir kullanma amacı tayin edilmek suretiyle (meselâ, belirli bir yolculuk için otomobilin veya bir elbisenin dikimi için dikiş makinasının kullanım ödüncü verilmesi) tesbit edilebilir[18]. Bu sonuncu halde, öngörülen kullanma için gerekli zaman, şey kullanılmadan geçse dahi sözleşme sona ermiş olur. Zira TBK m. 383/I'e göre, "Kullanma için belirli bir süre öngörülmemişse, ödünç alanın, ödünç konusunu sözleşme uyarınca kullanmış olmasıyla veya kullanabilecek kadar bir zaman geçmesiyle sözleşme sona erer".

---

14 **Tandoğan** I/2, sh. 295.

15 OR-**Schaerer**, Art. 307, N. 3; **Tandoğan** I/2, sh. 295.

16 OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 14.

17 **Honsell**, sh. 231; OR-**Schaerer**, Art. 305, N. 14.

18 OR-**Schaerer**, Art. 309, N. 2; **Tandoğan** I/2, sh. 296.

2. Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih beyanı

TBK m. 384'e göre, "Ödünç konusu, kullanım süresi ve hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeden verilmişse, ödünç veren onu dilediği zaman geri isteyebilir". Şüphesiz, bu hakkın dürüstlük kuralına (MK m. 2) uygun olarak kullanılması gerekir.

3. Kullanım ödüncü alanın sözleşmeyi ihlâl etmesi

Kullanım ödüncü alan, kullanım ödüncü verilen şeyi sözleşmeye aykırı olarak kullanırsa veya bozarsa veyahut kullanılmak üzere diğer bir şahsa verirse, kullanım ödüncü sözleşmesi için belirli bir süre öngörülmüş olsa dahi, kullanım ödüncü veren derhal iade talebinde bulunabilir (TBK m. 383/II). Bunun için mehil verilmesine ve ihtar çekilmesine gerek yoktur.

4. Kullanım ödüncü verenin âcil veya öngörülmeyen ihtiyacı

TBK m. 383/II'ye göre, "Ödünç alan, ödünç konusunu sözleşmeye aykırı olarak kullanır, onu bozar veya kullanmak için başka bir kimseye verirse ya da önceden bilinmeyen bir durum yüzünden ödünç verenin ivedi gereksinimi ortaya çıkarsa, ödünç veren o şeyi daha önce geri isteyebilir". Kullanım ödüncü verene bu şekilde vaktinden önce sona erdirme imkânı tanıyan bu hüküm, "clausula rebus sic stantibus" ilkesinin uygulanma hallerinden biri olup, kullanım ödüncü sözleşmesinin karşılıksız olması özelliği ile açıklanabilir[19].

5. Kullanım ödüncü alanın ölümü

TBK m. 385'e göre, "Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç alanın ölmesiyle kendiliğinden sona erer". Kanun koyucu bu hükümle, kullanım ödüncü sözleşmesinin kural olarak, kullanım ödüncü alanın şahsı gözönünde bulundurularak kurulduğu fikrinden hareket etmektedir[20]; kullanım ödüncü alanın mirasçıları sözleşmenin ifa edilmesini talep edemezler. Buna karşılık, kullanım ödüncü verenin ölümü halinde, sözleşme onun mirasçılarıyla devam eder[21].

---

[19] **Tercier**, N. 2335.

[20] OR-**Schaerer,** Art. 311, N. 1; **Tercier,** N. 2336.

[21] **Tercier**, N. 2336.

§ 24. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ

I. Tanımı ve hukuki niteliği

1. Tanımı

TBK m. 386'ya göre, "Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir". Kanun koyucu, burada da, tarafların aslî edim yükümlerine göre tüketim ödüncü sözleşmesini tanımlamış bulunmaktadır. Böylece tüketim ödüncü sözleşmesi çerçevesinde ödünç veren, bir miktar para veya un, tahıl, şeker, kumaş, kömür, benzin gibi mislî bir şeyin mülkiyetini belirli bir süre için ödünç alana geçirmeyi; ödünç alan da aynı miktar ve nitelikte şeyi iade etmeyi taahhüt etmektedirler. Bu nedenle parça borcu oluşturan şey tüketim ödüncüne konu olmamaktadır.

Ödünç alan, kendisine ödünç verilen şeyi tüketebilir veya yok edebilir. Aynı şekilde, ödünç verilen şeyin teslimi ile, bunun üzerindeki mülkiyet hakkı ödünç alana geçtiği için, ödünç veren sözleşmenin sona ermesi halinde sadece şahsî hakka dayanarak iade talebinde bulunabilir.

Tüketim ödüncü sözleşmesinde, ödünç verenin sözleşme konusu şeyin mülkiyetini devir borcunun, ödünç alanın da bunları tüketme yetkisinin bulunması sebebiyle, bir şeyin değerinin kullanılması (Wertgebrauch) söz konusudur[1].

2. Hukukî niteliği

– Tüketim ödüncü sözleşmesi borç doğuran ve rızaî bir sözleşmedir.

– Tüketim ödüncü sözleşmesi, faiz öngörülmediği takdirde, eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliği taşır; karşılıklı edimlerin değiştirilmesi söz konusu değildir; mülkiyetin devrinin amacı, iadeye ilişkin bir alacak elde etmek değildir. Zira ödünç verenin sözleşme süresince devredilen şeyin değerinden yoksun kalmasının karşılığı bulunmamaktadır. Ancak faiz kararlaştırılan veya faiz ödenmesi gereken

---

[1] **Tercier**, N. 2356; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 1 ve 7.

(TBK m. 387/II) hallerde tüketim ödüncü sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliği taşır[2].

– Tüketim ödüncü sözleşmesi devamlı bir borç ilişkisi doğurur. Zira ödünç verenin edimi bir zamana yayılmıştır; ödünç veren ancak sözleşmenin sonunda benzer bir şeyi talep edebilir[3].

II. Unsurları

1. Ödünç verilebilecek bir miktar para veya bir mislî şey

Tüketim ödüncü sözleşmesinin konusunu bir miktar para veya mislî şeyler teşkil eder; yabancı paralar da ödünç sözleşmesine konu olabilirler[4]. Mislî şeyler genellikle kullanılması tüketime tâbi şey niteliğini taşırlar. Bununla beraber, tüketim ödüncü sözleşmesinin konusunun mutlaka kullanılması tüketilme suretiyle olan şey niteliği taşıması zorunlu değildir[5].

2. Ödünç konusunun mülkiyetinin ödünç alana geçirilmesi taahhüdü

Kira ve âriyet sözleşmelerinden farklı olarak tüketim ödüncü sözleşmesinde, ödünç veren, sözleşme konusunun mülkiyetini ödünç alana geçirmeyi taahhüt eder. Tüketim ödüncünün amacı ödünç alana kullanabileceği bir sermaye sağlamak olup, bu amaç ancak mülkiyetin geçmesiyle gerçekleşir[6].

Bir şeyin ödünç verilmesi halinde, ödünç veren emin sıfatıyla zilyet ise, iyiniyetli ödünç alan onun üzerindeki mülkiyeti kazanır (MK m. 901); para veya hâmiline yazılı senetlerde, iyiniyetli ödünç alan, ödünç veren emin sıfatıyla zilyet olmasa dahi, MK m. 903 gereğince bunlar üzerindeki mülkiyet hakkına sahip olur[7].

3. Ödünç alanın aynı miktar ve nitelikte aynı cinsten şeyleri verme taahhüdü

Ödünç alan, sözleşmenin sonunda, aldığı şeyin aynı miktar ve vasıfta bir benzerini iade etmek zorundadır. Alınan ile verilen şeylerin

---

2 **Engel**, sh. 250; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 1; **Tercier**, N. 2357-58.
3 **Tercier**, N. 2357; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 3; BGE 100 II 345.
4 **Yavuz**, sh. 367, dn. 9 a.
5 **Oser/Schönenberger**, Art. 312, N. 10; **Tercier**, N. 2355; **Tandoğan** I/2, sh. 298; **Zevkliler**, sh. 271; **Yavuz**, sh. 368.
6 **Tandoğan** I/2, sh. 299.
7 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 8; **Tandoğan** I/2, sh. 299.

fiyat veya değerlerinin aynı olması gerekmez; ödünç alınan paranın değerindeki değişiklikler de iade borcunun kapsamını etkilemez[8].

4. Faiz ödeme borcu

a) Genel olarak

Bir miktar paranın ödünç verilmesini konu edinen tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alanın ayrıca faiz ödemek zorunda olup olmadığı hususu TBK m. 387'de düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşmede faiz kararlaştırılmamışsa, âdi işlerde faiz gerekmez (TBK m. 387/I). Buna karşılık, ticarî işlerde sözleşmeyle faiz ödenmesi kararlaştırılmamış olsa dahi, faiz vermek gerekir (TBK m. 387/II).

b) Faizin miktarı

aa) Âdi tüketim ödüncünde faiz oranı

Âdi tüketim ödüncü sözleşmesinde faiz ödeneceği kararlaştırılmış olmasına rağmen, faiz oranı sözleşmede belirlenmemişse, TBK m. 388/I'e göre, "Tüketim ödüncü sözleşmesinde faiz oranı belirlenmemişse, kural olarak ödünç alma zamanında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan faiz oranı uygulanır". Böyle bir durumda, Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 3095 sayılı Kanun'un 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı kanunla[9] değişik 1. maddesine göre, "Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde dokuz[10] oranı üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir". Âdi tüketim ödüncünde taraflar faiz oranını serbestçe tayin edebilirler.

TKHK m. 25/1'e göre, tüketicilere verilecek kredilerde faiz oranları sabit olarak belirlenir ve tüketici aleyhine değiştirilemez.

bb) Ticarî tüketim ödüncünde faiz oranı

Ticarî işlerde kanunî kapital (ana para) faiz oranı, TTK m. 8/I'e göre, serbestçe belirlenir. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt

---

8 **Oser/Schönenberger,** Art. 312, N. 12; **Tandoğan** I/2, sh. 299; **Zevkliler**, sh. 272; **Yavuz**, sh. 368.

9 RG 27 Nisan 2005, sayı: 25798.

10 Kanunun 1. maddesinde yer alan yıllık %12'lik kanuni faiz oranı 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı R.G.'de yayımlanan, 19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükmü gereğince yıllık % 9 olarak tespit edilmiştir.

Faizine İlişkin Kanun m. 5/II'ye göre, "Borçlar kanunu ve Ticaret Kanununda kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz". Diğer yandan TTK m. 9/1'e göre "Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır". Bu durumda, ticarî işlerde faiz oranı 3095 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecektir. Buna göre, taraflar uygulanacak faiz oranını sözleşmeyle serbestçe belirleyebilirler (3095 sayılı Kanun m. 1). Bu serbestinin sınırlarını MK m. 23/II ve gabine ilişkin TBK m. 28 hükümleri belirler. Ödünç alan tacir ise, tacirin ticarî işlerinde tecrübesizliği söz konusu olamıyacağından (TTK m. 20/II), onun sadece muzayaka halinin varlığını ileri sürerek sözleşmeyi iptal etmesi düşünülebilir[11].

Tarafların sözleşmeyle faiz oranını belirlememeleri halinde ticari tüketim ödüncünde de faiz oranı, 3095 sayılı Kanun m. 1 hükümlerine göre belirlenmektidir. Günümüzde yürürlükte bulunan faiz oranı yıllık yüzde dokuzdur. Bakanlar Kurulu bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir[12].

Tüketim ödüncü sözleşmelerinde faizin anaparaya eklenerek birlikte yeniden faiz yürütülmesi kararlaştırılamaz (TBK m. 388/III).

cc) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tâbi tüketim ödüncü sözleşmelerinde

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek ve değişiklikleri ile birlikte Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 52. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 13.12.2012 ve 28946 sayı). Diğer kanunlarda 90 sayılı Kanun Hükümdü Kararnameye yapılan atıflar Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ilgili maddelerine yapılmış sayılır (f. 2).

Kanunun 51/2. maddesine göre, "Bakanlar Kurulu, Türkiye'de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ve şubelerin ödünç para verme işlemlerinde uygulayacakları azami faiz oranlarını ve diğer menfaatlerinin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını

---

[11] **Arkan**, Ticari İşletme, sh. 69; **Tandoğan** I/2. sh. 305-306.

[12] Türk Borçlar Kanunun 88/II. maddesinde "Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz" hükmünün ticari işlerde uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır.

tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredebilir".

c) Faize faiz yürütülmesi (mürekkep faiz)

TBK m. 388/III'e göre, "Faizin anaparaya eklenerek birlikte yeniden faiz yürütülmesi kararlaştırılamaz". Aynı husus, 3095 sayılı Kanun m. 3/I'de" kanunî faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez" şeklinde ifade edilmiştir. Ancak 3095 sayılı kanun m. 3/II'de, "Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır" hükmü yer almaktadır. Bu durumda TTK m. 8/II hükmü varlığını korumaktadır[13]. Bu hükme göre, " Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz.". Kanun tüketicinin korunmasına ilişkin hükümleri saklı tutmuştur (f. 3). Bu düzenlemele aykırı olarak işletilen faiz yok hükmünde sayılmıştır (f.4).

III. Tüketim ödüncü sözleşmesinin benzeri işlemlerden ayırdedilmesi

1. Usulsüz tevdi ve tüketim ödüncü

Usulsüz tevdi, saklatanın (mudinin) bir miktar para, mislî eşya veya kıymetli evrakı saklayana (müstevdiye) teslim etmeyi ve saklayanın da bunları aynen değil, mislen iade etmeyi taahhüt ettikleri bir sözleşmedir (TBK m. 570)[14].

Usulsüz tevdide, tevdi edilen şeyin mülkiyeti saklayana geçer. Bu husus, "paranın yararı ve hasarı kendisine (saklayana) ait olur" (TBK m. 570/I) ifadesinden anlaşılmaktadır. Saklayan, saklatan tarafından kendisine açıkça yetki verilmedikçe, saklanan diğer misli eşya veya kıymetli evrak üzerinde tasarrufta bulunamaz (TBK m. 570/ III). Paranın mühürsüz ve açık olarak bırakılmış olması, örtülü anlaşma sayılır (TBK m. 570/ II).

---

13 **Arkan**, sh. 76 vd.

14 **Tercier**, N. 4894; **Engel**, sh. 566; **Honsell**, sh. 326; Alelade tevdide saklayan saklananı kullanamaz. Saklanan bütün çoğalmalarıyla birlikte geri verilir (TBK m. 563/I, 564).

Saklayanın sözleşme konusu şeyi aynen değil mislen iade etmekle yükümlü olması (TBK m. 570/I) ve saklatanın iade konusunda şahsî bir talep hakkına sahip olması sebebiyle, normal tevdiden farklı olarak, saklayanın kendisine tevdi edilen şeyi muhafaza yükümü (Obhutspflichten) ve özen borcu bulunmamaktadır[15]. Bu yükümlerin yerini mislen iade yükümü almıştır[16].

Sözleşme konusu şeyin mülkiyetinin saklayana geçmesi, mislen iade yükümünün bulunması ve saklayanın şeyi kullanma imkânının bulunması açılarından usulsüz tevdi ile tüketim ödüncü arasında benzerlik bulunmaktadır. Bununla beraber, tüketim ödüncü ile usulsüz tevdi arasındaki ayırım şu bakımlardan önem taşımaktadır:

Tüketim ödüncünde ödünç alanın ödünç verene karşı takas yetkisi bulunduğu halde, usulsüz tevdide saklayan, saklatanın rızası olmadıkça takas imkânına sahip değildir (TBK m. 144/b. 1)[17]. Keza, tüketim ödüncünde ödünç alanın iade borcu götürülecek borç (TBK m. 89/b. 1); usulsüz tevdide şeyin iadesi onun saklandığı yerde yapılacağı için (TBK m. 566), aranacak borç söz konusudur. Aynı şekilde, tüketim ödüncünün aksine, usulsüz tevdide paradan başka mislî eşya ve kıymeti evrakı saklayan, saklatanın izni olmadıkça, bunları kullanamaz (TBK m. 570/III)[18]. Ancak bu ayırıma ilişkin hükümler yedek hukuk kuralı niteliğinde oldukları için, ayırımın uygulamada fazla bir önemi bulunmamaktadır[19].

Her iki sözleşme türünün birbirinden ayırdedilmesinde, tarafların iradesini, onların menfaat durumlarını ve sözleşmenin iktisadî amacını (saklama veya kredi amacını) göz önünde tutmak gerekir[20].

2. Banka tasarruf hesabı ve tüketim ödüncü

Bankalar nezdinde açılan tasarruf hesabının veya tasarruf mevduatının hukukî niteliği, yani tüketim ödüncü mü yoksa usulsüz tevdi mi olduğu çok tartışmalıdır.

---

15 **Bucher**, BT, sh. 281; **Berlocher**, sh. 699; OR-**Koller**, Art. 481, N. 7; **Tercier**, N. 4908.

16 **Tercier**, N. 4908; OR-**Koller**, Art. 481, N. 7.

17 **Aral**, Takas, sh. 73 vd.

18 Geniş bilgi için bk. **Tandoğan** I/2, sh. 327 vd.

19 OR-**Koller**, Art. 481, N. 13 vd; **Tercier**, N. 4902.

20 **Tercier**, N. 4901; OR-**Koller**, Art. 481, N. 11; **Tandoğan** I/2, sh. 328 vd.

Bazı yazarlar[21], bankayla yapılan tasarruf mevduatlarına ilişkin sözleşmeyi tüketim ödüncü olarak nitelendirmektedirler. Bunlara göre tasarruf mevduatlarında temel amaç mevduat sahibinin faiz elde etmesi olup, saklama amacı ön planda yer almaz. Aynı şekilde vadeli mevduatta, mevduat sahibinin istediği zaman yatırılan parayı çekme hakkı (TBK m. 564) bulunmamaktadır.

Buna karşılık, hâkim fikre göre[22], tasarruf mevduatı sözleşmesi TBK m. 570 anlamında usulsüz tevdi sözleşmesi niteliği taşır. Zira mevduat sahibinin amacı kredi vermek olmayıp, cüz'i bir faiz karşılığında paranın muhafaza edilmesidir. Ülkemizdeki bankacılık uygulamasında genellikle vadeli mevduatın çekilmesine, kararlaştırılan faizin ödenmemesi veya vadesiz mevduat faizleri uygulanması suretiyle müsaade edilmektedir.

3. Kredi açma sözleşmesi ve tüketim ödüncü

Kredi açma sözleşmesi (Krediteröffnungsvertrag) ile kredi açan (genellikle bir banka), kredi alana belirli bir limite kadar devamlı olarak kredi vermeyi taahhüt eder ve karşılığında faiz ve komisyon alır[23]. Bu sözleşmeyle verilecek krediler, nakit para verilmesi, havale talimatının yerine getirilmesi, akreditif açılması, çeklerin ödenmesi, teminat mektubu verilmesi, poliçe ve bonoların iskonto edilmesi suretiyle kullanılabilir[24].

Bazı yazarlar[25] kredi açma sözleşmesini tüketim ödüncü olarak nitelendirmektedir. Kredi açma sözleşmesi çerçevesinde verilen iskonto kredisinde veya kefalet kredisinde tüketim ödüncü niteliği görmek güçtür[26]. Aynı şekilde, tüketim ödüncünden farklı olarak, alınan para-

---

21 **von Büren**, BT, sh. 183 vd; **Bucher**, BT, sh. 199; **Honsell,** sh. 235 ve 327; OR-**Koller**, Art. 481, N. 12; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 34.

22 **Gautschi**, Art. 481, N. 6a; **Oser/Schönenberger**, Art. 481, N. 22; **Berlocher,** sh. 700; **Guggenheim**, sh. 114; **Christ**, sh. 268 vd; BGE 100 II 155 yahut JdT 1975 I, sh. 177-179; **Aral,** Takas, sh. 76, dn. 73'de zikredilen diğer yazarlar; HGK, 2.11.1983, E. 11-2802/K. 1047: "davacı ile parayı yatırdığı banka arasındaki ilişki vedia aktine dayanmaktadır" (YKD 1983, sh. 350); Mevduat sözleşmesinin ödünç ve usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşme olduğuna dair bkz. HGK 2012/11-550 E. 2012/820 K. – Kazancı-.

23 OR-**Schaerer,** Art. 312, N. 28; **Bertheau**, sh. 47; **Tandoğan** I/2, sh. 331-332; **Engel,** sh. 262.

24 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 27 vd; **Guggenheim**, sh. 122 vd; **Tandoğan** I/2, sh. 332.

25 **Honsell,** sh. 236.

26 **Bertheau**, sh. 48; OR-**Schaerer**, Art. 312. N. 29.

nın geri verilmesiyle sözleşme sona ermemekte, kredi limiti içinde, alınan paralar bir çok defa çekilip yatırılmaktadır[27].

Buna karşılık, hakim fikre göre[28], kredi açma sözleşmesi kendine özgü (sui generis) bir çerçeve sözleşmesi olup, tüketim ödüncüne ilişkin hükümler ancak kıyas yoluyla uygulanabilir.

4. Kâra katılmalı ödünç ve tüketim ödüncü

Kâra katılmalı ödünç sözleşmesiyle, ödünç veren, bir miktar parayı belirli bir amaçla kullanılmak üzere ödünç vermeyi, ödünç alan da ödünç verene faiz yerine kârdan belirli bir pay vermeyi ve sözleşmenin sona ermesi üzerine aynı miktarda parayı iade etmeyi karşılıklı olarak taahhüt ederler[29].

Kâra katılmalı ödünç, karma bir sözleşme değil, ödünç sözleşmesinin bir türüdür[30]. Ancak bu sözleşmeyi diğer ödünç sözleşmesinden ayıran iki tipik unsur, ödünç alanın kendisine ödünç verilen parayı belirli bir amaçta, kâr getiren faaliyette, özellikle bir ticarî işletmede kullanmak zorunda olması ve alınan parayla girişeceği faaliyetten elde ettiği kârın belirli bir kısmını ödünç verene iadeyle yükümlü olmasıdır[31]. Kârdan ödünç verene ödenecek kısım, net veya brüt kârın veyahut satış tutarının belirli bir oranı veya maktu bir tutar olabilir[32].

IV. Tüketim ödüncü sözleşmesinde tarafların borçları

1. Ödünç verenin borçları

a) Ödünç konusunun mülkiyetini geçirme ve teslim borcu

Ödünç konusunun mülkiyetini geçirme ve bu amaçla teslim borcu, ödünç verenin aslî edim yükümlerindendir. Bu borcun ifası için, menkullerde mülkiyetin geçirilmesine ilişkin şart ve şekillere uymak (MK m. 763) gerekir.

Bir miktar paranın ödünç verilmesinde, ödünç verenin teslim borcu, nakden ödemenin yanında, ödünç alanın banka veya posta çeki he-

---

27 **Tandoğan** I/2, sh. 332.

28 **Guggenheim**, sh. 127 ve 128; **Maurenbrecher**, sh. 79 vd, 86; **Christ**, sh. 265, vd; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 27 ve 29; **Stauder**, sh. 74 vd; **Tandoğan** I/2, sh. 332-333; **Bertheau**, sh. 48-49.

29 **Engel**, sh. 260; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 37; **Kuntalp**, sh. 8; **Tandoğan** I/2, sh. 334.

30 **Kuntalp**, sh. 13-14; **Tandoğan** I/2, sh. 334-335.

31 **Kuntalp**, sh. 8 vd; **Tandoğan** I/2, sh. 334-335.

32 **Kuntalp**, sh. 9-11; **Tandoğan** I/2, sh. 335.

saplarına para yatırma şeklinde de yerine getirilebilir. Aynı şekilde, taraflar ödemenin dolaylı yoldan gerçekleşmesini de kararlaştırabilirler. Meselâ, ödünç verenin üçüncü bir kişiye (ödünç alanın alacaklısına) ödemede bulunması, ödünç verenin talimatıyla bir bankanın, parayı ödünç alana vermesi veya ödünç verenin hesabından ödünç alanın hesabına nakletmesi veya bir çek veya bononun teslimi yoluyla ödeme uğruna ifada bulunma[33].

Paraya ilişkin tüketim ödüncünde, TBK m. 89/b. 1 hükmüne rağmen, ödünç verenin ödeme yükümün, kural olarak özellikle bankaların verdiği ödünçte, bir aranılacak veya gönderilecek borç olduğu, yani tarafların iradelerinin bu yönde olduğu kabul edilebilir[34]. Meğer ki taraflar aksini kararlaştırmış olsun. Buna karşılık, para dışındaki mislî şeylere ilişkin tüketim ödüncünde ifa yeri hakkında TBK m. 89/b. 3 uygulanır.

Ödünç verenin teslim veya ödeme borcunu yerine getirmede temerrüde düşmesi halinde, borçlunun temerrüdünü düzenleyen TBK m. 117 vd.'ndaki hükümler; ödünç alanın faiz ödemesi kararlaştırıldığı takdirde, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüde düşmesi halinde seçimlik hakları belirleyen TBK m. 125 vd.'nda yer alan hükümler uygulanır[35].

Ödünç veren borçlandığı parayı ödemekte temerrüde düşerse, TBK m. 120 gereğince temerrüd faizi ödemek zorundadır; ödünç veren ödeyeceği temerrüt faizinden, ödünç alanın ödemesi kararlaştırılan kapital (ana para) faizini indiremez. Zira kapital faizi, ödünç verenin teslim borcunu yerine getirmesinden sonra işlemeye başlar[36].

Kanun koyucu, ödünç verenin teslim borcu konusunda genel hükümlerden ayrılan iki özel kural öngörmektedir[37]:

aa) Zamanaşımı Süresi

TBK m. 389 gereğince, ödünç veren ödünç konusunun tesliminde temerrüde düşerse, ödünç alanın teslimi talep hakkı temerrüt tarihin-

---

33 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 8; **Tandoğan** I/2, sh. 348-349.

34 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 7; Art. 313, N. 5; **Maurenbrecher**, sh. 137 vd; **Tandoğan** I/2, sh. 350.

35 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 10; **Honsell**, sh. 236-237; **Engel**, sh. 252.

36 OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 10. Ayrıca bk. **Tandoğan** I/2, sh. 350.

37 **Tercier**, N. 2371 vd.

den itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. Genel hükümlerden farklı olarak (TBK m. 146), burada zamanaşımı muacceliyet tarihinden değil, temerrüt tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

bb) Ödünç alanın borç ödemekten aczi halinde ödünç verenin korunması

Ödünç alan kimse tüketim ödüncü sözleşmesinin kurulmasından sonra borcunu edadan âciz duruma girerse, ödünç veren taahhüt ettiği şeyi teslimden kaçınabilir (TBK m. 390/I). Ödünç alan sözleşme kurulmadan önce borç ödemekten âciz halinde olup da, ödünç veren sözleşme kurulduktan sonra bundan haberdar olursa yine ödemeden kaçınabilir (TBK m. 390/II).

b) Ödünç verenin ayıba ve zapta karşı tekeffül borcu

Ödünç verenin zapta ve ayıba karşı tekeffül borcu, mislî şeylerin ve kıymetli evrakın ödünç verilmesi halinde söz konusu olur. Bu konuda satış sözleşmesinde satıcının zapta ve ayıba karşı tekeffülden sorumluluğuna ilişkin kuralların uygulanması gerektiği kabul edilmektedir[38]. Bununla beraber, faizsiz tüketim ödüncünde, âriyete ilişkin esasların kıyas yoluyla uygulanmasının ve TBK m. 114/I, c.2 uyarınca ödünç verenin sorumluluğunun daha az şiddetle takdir edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı savunulmaktadır[39].

c) TKHK m. 4/3'e göre Tüketici Kredileri

TKHK m. 4/3'e göre, "Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir".".

---

[38] **Oser/Schönenberger,** Art. 312, N. 11; **Becker**, Art. 312, N. 12; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 8; **Engel,** sh. 253.

[39] **Tandoğan** I/2, sh. 353; **Zevkliler,** sh. 282.

2. Ödünç alanın borçları

a) Ödünç konusu şeyi kabul borcu

Tüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç alanın ödünç konusu şeyi kabul borcu, dolaylı olarak, bu borcun zamanaşımını düzenleyen TBK m. 389'da zikredilmiştir. Bu maddeye göre, "Ödünç alanın, ödünç konusunun teslimine ve ödünç verenin de bu şeyin teslim alınmasına ilişkin istemleri, diğer tarafın bu konuda temerrüde düşmesinden başlayarak altı ayın geçmesiyle zamanaşımına uğrar".

Ödünç alanın bu borcu, ancak faizli tüketim ödüncünde söz konusu olur; zira faizsiz tüketim ödüncünde ödünç verenin ödünç alanı şeyi kabule zorlamakta hukukî bir yararı bulunmamaktadır[40].

Ödünç alanın şeyi kabul borcunda temerrüdü halinde, ödünç veren, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre (TBK m. 125) hareket edebilir[41].

b) Ödünç konusunu iade borcu

Tüketim ödüncü sözleşmesi sona erince, ödünç alan, miktar ve nitelik olarak aldığına eşit aynı türden şeyleri geri vermekle yükümlüdür (TBK m. 386). Buna karşılık, kumar ve bahis için bilerek verilen ödünç için, ödünç alanın iade yükümü bulunmamaktadır. Ödünç veren, ödünç verilen şeyin maliki olmadığı için, iade konusunda şahsî bir talep hakkına sahiptir.

TBK m. 381'e göre, "Ödünç alan, ödünç konusunun olağan bakım ve koruma giderlerini karşılamakla yükümlüdür (f. I). Ödünç alan, ödünç verenin yararına yapmak zorunda kaldığı olağanüstü giderlerin ödenmesini isteyebilir (f. II)". TBK m. 391 para yerine verilen şeyleri düzenlemektedir. Emredici nitelikte olan bu hüküm, tüketim ödüncü sözleşmesinde, ödünç konusunun para olarak kararlaştırıldığı halde, ödüncün para olarak değil, mal veya kıymetli evrak olarak teslim edilmesi halinde geri ödeme yükümünün sözleşmede öngörülen miktarla değil, mal veya kıymetli evrakın teslim zamanındaki gerçek de-

---

[40] **Oser/Schönenberger**, Art. 315, N. 2; **von Tuhr/Peter**, § 7, dn. 3, § 10, dn. 7; **Tandoğan** I/2, sh. 353; **Zevkliler**, sh. 282; **Honsell**, sh. 236.

[41] **Engel**, sh. 254; **Tandoğan** I/2, sh. 353. Bu durumda ödünç alanın alacaklının temerrüdüne düşeceği görüşünde: **Honsell**, sh. 236; OR-**Schaerer**, Art. 315, N. 3.

ğerine göre belirlenmesini öngörmektedir[42]. Gerçek değer teslim zamanı ve yerindeki borsa ya da piyasa değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Böylece, tarafların bunların değerindeki değişikliğe göre spekülasyona girmeleri ve kıymetli evrak veya emtianın gerçek değerinin üstünde yüksek takdir edilmesi suretiyle ödünç alanın sömürülmesi önlenmek istenmiştir[43].

Yabancı paranın ödünç olarak verilmesi halinde, ödünç alanın iade borcu konusunda TBK m. 99 hükmü uygulanır; aynen (efektif) ödeme veya buna benzer deyim şart edilmişse, ödünç alan yabancı parayla iade borcunu yerine getirmek zorundadır[44].

Ödünç konusunun para olması halinde, iade borcunu ifada temerrüde düşen ödünç alan, ayrıca temerrüt faizi ödemekle yükümlü olur (TBK m. 120/I ve 3095 sayılı Kanun, m. 2). Taraflar ödünç sözleşmesinde temerrüt faizini kararlaştırmamışlarsa, ödünç alan, kanunî temerrüt faiz oranının üstünde kararlaştırılan kapital faizi oranında temerrüt faizi ödemek zorundadır[45]. Ödünç veren, şartları varsa TBK m. 122'ye göre tazminat da talep edebilir.

c) Faiz ödeme borcu

Ödünç sözleşmesinde, faiz ödenmesi gereken hallerde ödünç alan faiz ödemekle yükümlüdür. Tüketim ödüncünde faiz unsuru yukarda incelenmiştir.

TBK m. 388/II'ye göre, "Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, belirlenen faiz, yıllık olarak ödenir". Tüketim ödüncü sözleşmesinin rızaî bir sözleşme niteliği gözönünde tutulmak suretiyle, bir yıllık sürenin başlangıcını paranın ödünç alana verildiği veya onun teslim almada temerrüde düştüğü tarih olarak kabul etmek gerekir; aksi kararlaştırılmadıkça faiz borcu bu tarihlerden itibaren bir yıl geçince muaccel olur[46].

Ödünç alanın faiz ödeme borcunun tabi olduğu zamanaşımı süresi, TBK m. 147/b. 1 gereğince beş yıldır. Bununla beraber, ödünç alanın ödünç konusu parayı teslim almakta temerrüde düşmesinden itibaren

---

[42] **Bucher,** BT, sh. 195.

[43] **Tercier**, N. 2378; **Tandoğan** I/2, sh. 354; **Engel,** sh. 254.

[44] Bk. OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 20.

[45] **Honsell,** sh. 239; OR-**Schaerer**, Art. 312, N. 14; **Eren**, C. III, sh. 277.

[46] **Oser/Schönenberger,** Art. 314, N. 6; **Tandoğan** I/2, sh. 360.

altı ay geçmişse, ödünç verenin paranın teslim alınmasına dair alacağı TBK 389 gereğince zamanaşımına uğrar ve onunla birlikte faiz alacağı da TBK m. 152 uyarınca zamanaşımına uğramış olur[47].

Şayet ödünç alan faiz ödeme borcunda temerrüde düşerse, ödünç veren TBK m. 125'e göre ona mehil vererek sözleşmeden dönebilir[48].

V. Tüketim ödüncü sözleşmesinin sona ermesi

Borçlar Kanunu tüketim ödüncü sözleşmesinin sona erme sebeplerini özel olarak düzenlememektedir. Kanun koyucu, TBK m. 392'de ödünç alanın iade borcunun zamanını düzenlemekle yetinmiştir. Sözleşme sona ermeden iade söz konusu olamayacağından, TBK m. 392 hükmünün, aynı zamanda tüketim ödüncü sözleşmesinin sona ermesine ilişkin bir hüküm olduğunu kabul etmek gerekir[49].

1. Sürenin sona ermesi

Taraflar, sözleşmeyle ödünç verilen şey veya paranın iade edileceği tarihi (vadeyi) belirlemişler ise, öngörülen vadenin gelmesiyle tüketim ödüncü sözleşmesi sona erer ve geri verme (iade) borcu muaccel olur.

2. Fesih bildirimi

Belirsiz süreli tüketim ödüncü sözleşmelerinde, taraflar ödünç verenin iade talebi üzerine derhal veya bir süre sonra sözleşmenin sona ereceğini kararlaştırabilirler. Bu ihtimalde iade talebi bir nevi fesih bildirimi niteliği taşır[50]. Tüketim ödüncü sözleşmesinde belirli bir sürenin veya fesih bildirimi üzerine derhal yahut bir müddet sonra iade borcunun muaccel olacağı kararlaştırılmamış ise, ödünç alan ödünç konusunu ilk talepten başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir (TBK m. 392)

Tüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç alana da fesih bildiriminde bulunma hakkı tanınabilir. Bu takdirde, sözleşmede aksine bir hüküm

---

47 **Tercier,** N. 2397; **Tandoğan** I/2, sh. 360 ve dn. 248.

48 **Tercier,** N. 2398; **Tandoğan** I/2, sh. 360; BGE 100 II 345 yahut JdT 1975 I 619, cons. 3.

49 **Tercier,** N. 2399. Ayrıca bk. OR-**Schaerer,** Art. 318, N. 1.

50 **Becker,** Art. 318, N. 8; **Tandoğan** I/2, sh. 362.

yoksa, her iki taraf için de fesih bildirimi sürelerinin aynı olduğunu kabul etmek gerekir[51].

TBK m. 392 hükmü, sadece belirsiz süreli tüketim ödüncünde tarafların sona erme tarzını kararlaştırmamaları halinde uygulanır. TBK m. 392'de açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, faizli tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alana da TBK m. 392'deki imkânı tanımak gerekir.

3. Ödünç alanın vadeden önce ödemede bulunması

Faizsiz tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alan, her durumda ödünç konusunu iadeyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Buna karşılık faizli tüketim ödüncü sözleşmelerinde, ödünç alan vade veya fesih bildirimi süresi dolmadan ödemede bulunamaz; meğer ki bu sürenin sonuna kadar işleyecek faizi kabul etsin veya ödünç veren faiz talebinden vazgeçsin. Bununla beraber, ödünç alan, ödünç veren iade talebinde bulununca, faizli tüketim ödüncünde dahi TBK m. 392'de öngörülen altı haftalık süre dolmadan borcunu ödeyebilir. Zira bu süre onun lehine konulmuştur[52].

Tüketici kredilerinde TKHK m. 27'ye göre, "Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür".

---

[51] **Christ,** SPR VII/2, sh. 252; OR-**Schaerer,** Art. 318, N. 5; **Tandoğan** I/2, sh. 363.

[52] **Oser/Schönenberger,** Art. 318, N. 5; **Tandoğan** I/2 sh. 363.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ

§ 25. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE UNSURLARI

I. Tanımı

TBK m. 470'e göre, "Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir". Burada geçen eser meydana getirme deyiminin kapsamına yeni bir eser meydana getirmenin yanında, mevcut bir eserin değiştirilmesi, onarılması, bakımı veya ortadan kaldırılması (yıkımı) da girer ve bunlar TBK m. 470 anlamında bir eser sözleşmesine konu olabilir[1].

II. Hukukî niteliği ve özellikleri

1. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir

Eser sözleşmesinin kurulmasıyla taraflardan yüklenici bir eser meydana getirme, işsahibi bedel ödeme edimlerini borçlanmış olurlar; bu sözleşmenin amacı, söz konusu aslî edimlerin değişimidir. Bu bakımdan, eser sözleşmesi, ivazlı sözleşmeler kategorisine girer. Eser meydana getirme borcunun ivazsız olarak veya bedel ödemeden başka bir edim karşılığında taahhüt edilmesi halinde, eser sözleşmesinden söz edilemez.

Yüklenicinin eser meydana getirme borcu, eserin tamamlanıp işsahibine teslim edilmesiyle sonuçlanmış olur[2]. Teslim borcu, TBK m. 470'te açıkça zikredilmemiş olmakla beraber, işin niteliği icabı

---

1 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 3; **Gauch**, N. 28; **Gautschi**, Art. 363, N. 1 b; **Bühler**, Art. 363, N. 33 vd; **Tercier/Favre**, N. 4225; BGE 130 III 458.

2 **Gauch**, N. 8; OR-**Zindel/Pulver**, Vorbem zu Art. 363-379, N. 12; Art. 363, N. 2; **Tercier/Favre**, N. 4214; **Eren**, İnşaat, sh. 51.

varsayılır ve eser sözleşmesine ilişkin diğer hükümlerde de varlığı teyid edilmiş (TBK m. 473/I, m. 478 ve m. 476) bulunmaktadır[3]. Eser meydana getirme ve teslim borçları birlikte yüklenicinin edim yükümünü teşkil ederler[4].

2. Eser sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir

Eser sözleşmesi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla kurulur; eserin teslimi ifa süreciyle ilgili bir husustur.

3. Eser sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi doğurmaz

Eser sözleşmesinde, yüklenicinin eser meydana getirme ve teslim borçlarının ifası zaman içinde temadi eden bir ifaya yönelik olmayıp, ifa ile sona erer. Yüklenicinin edim yükümü, hizmet sözleşmesinde işçinin edim yükümünden farklı olarak (TBK m. 393/I), belirli veya belirsiz zaman boyunca sürekli olarak ifa edilmesi gereken devamlı bir borç niteliği taşımaz. Bazı münferit hallerde, eser sözleşmesinin kurulmasıyla tam olarak ifa edilmesi arasında uzun bir sürenin bulunması mümkündür. Ancak, bu şekilde uzun süreli bir eser sözleşmesinin kurulmuş olması da bu sonucu değiştirmez. Zira kanun, eser sözleşmesinde, belirli zamanın geçmesini ve feshi ihbarı olağan sona erme sebebi olarak öngörmemiştir[5].

Eser sözleşmelerinden inşaat sözleşmesinde yüklenicinin meydana getirme borcu uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Edim yükümlülüğünün bu niteliği sürekli borç ilişkilerine ilişkin kuralların dikkate alınmasını gerektirmektedir[6].

---

3 **Gauch**, N. 8; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 2; **Gautschi**, Art. 363, N. 4; **Bühler**, Art. 363, N. 43; **Tercier/Favre**, N. 4214.

4 **Gauch**, N. 8; **Pedrazzini**, sh. 17.

5 **Gauch**, N. 9, 322 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Vorbem zu Art. 363-379, N. 14; BGE 98 II 302 vd. **Tercier/Favre**'a göre (N. 4208), yüklenicinin edimi sadece bir eserin tesliminden ibaret olmayıp, onun meydana getirilmesini de kapsadığı için, eser sözleşmesi devamlı borç ilişkisi doğuran sözleşmelere benzer sözleşmedir. Ayrıca bk. **Eren**, İnşaat, sh. 52. Bu bakımdan eserin teslimi borcu bakımından ani edimli, meydana getirme borcu bakımından sürekli borç ilişkisine ilişkin kurulların uygulanması gerekir.

6 İBK 25.1.1984 tarih E. 1983/3 K. 1984/1; bu konudaki tartışmalar için bkz. Zevkliler/Gökyayla (2013), 470-472 ve aynı yer dn. 76. Edimin zamanında ifa edilmemesi halinde sözleşmenin ileriye etkili veya geçmişe etkili sona erdirilmesi imkânları buradan doğmaktadır.

III. Unsurları

1. Bir eser meydana getirme

a) Eser kavramı

Eser sözleşmesinde yüklenicinin borçlandığı bir eser meydana getirme ediminin konusu, bir iş görme sonucudur (Arbeitserfolg). Hizmet sözleşmesinde işçinin ve vekâlet sözleşmesinde vekilin iş görme borcunun aksine, yüklenicinin eser meydana getirme borcu, bir edim fiili (Leistungshandlung) değil, edim sonucudur. Başka bir ifadeyle, yüklenicinin bu edim yükümü, bir sonuç borcudur (obligation de resultat)[7]. Borçlanılan bu işgörme sonucuna eser adı verilmektedir.

Eser sözleşmesinin konusunu teşkil eden TBK m. 470 anlamında eser, bir maddî veya maddî olmayan belirli bir iş görme sonucudur[8]. Şüphesiz eser sözleşmesinde maddî (cismanî) bir varlığı olan eserler ön planda yer alır ve bunlar taşınır veya taşınmaz şeyler şeklinde olabilir. Meselâ, bir bina yapımı, ölçü üzerine elbise dikimi, bir otomobil tamiri.

Bazı yazarlar[9] eser sözleşmesinde eser kavramını maddî varlığı olan eserlerle sınırlamakla beraber, günümüzde doktrinde hâkim olan görüş[10], haklı olarak, maddî (cismanî) bir varlığı olmayan hizmet edimleri sonucunu da TBK m. 470 anlamında eser kavramına dahil etmektedir. Meselâ, bir metnin tercümesinin yapılması, özel bir ihtiyaç için bilgisayar programı hazırlanması, fotoğraf veya film çekimi, inşaat projesinin çizilmesi, bir konser verilmesi, bir gazeteye ilân konması, ışıklı reklâm, bir reklâm programının hazırlanması, bir arazinin ölçümü[11]. Böylece, geniş anlamda eser kavramı anlayışını benimseyen hâkim fikir taraftarları arasında, TBK m. 470 anlamında

---

7 **Gauch**, N. 18; BGE 115 II 53 vd; 111 II 171.

8 **Gauch**, N. 24; OR-**Zindel/Pulver**, Vorbem zu Art. 363-379, N. 1; **Tercier/Favre**, N. 4223 vd.

9 **Gautschi**, Vorbem zu Art. 363 ff, N. 1, 4; Art. 394, N. 63.

10 **Engel**, sh. 402; **Corboz**, FJS, N. 458, sh. 10; **Gauch**, N. 33; **Tercier/Favre**, N. 4228 vd; **Jäggi**, SJZ, 1973, sh. 301 vd; **Becker**, Art. 363, N. 4; **Oser/Schönenberger**, Art. 363, N. 1 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Vorbem zu Art. 313-379, N. 1 vd; **Honsell**, sh. 242 vd; **Gulh/Merz/Kummer**, sh. 418 vd; **Pedrazzini**, sh. 7; **Leuenberger**, ZSR 1987/106 II, sh. 20; **Bühler**, Art. 363, N. 45; **Tandoğan** II, sh. 19 vd; **Zevkliler**, sh. 321; **Yavuz**, sh. 451.

11 Bu örnekler için bk. **Gauch**, N. 34; **Tercier/Favre**, N. 4230.

eser sayılabilecek maddî (cismanî) olmayan iş görme sonuçlarının kapsamı konusunda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bunlardan bazıları, belirli ölçüde maddî bir varlıkta kendini gösterme ve devamlılık unsurunu aramakta[12]; diğerleri[13] ise, maddî (cismanî) varlıkta kendini gösterme unsurunun eser sözleşmesinde tâli nitelikte olduğunu ve taraf iradelerine göre uygulanacak hukuk normlarının belirlenmesinde önemli olmadığını savunmaktadır. Bunun sonucu olarak, fikrî eser (geistige Werk) veya fikrî eser sözleşmesi (Geist-Werkvertrag) kavramları ortaya çıkmış bulunmaktadır[14]. Aynı şekilde, fikrî eser veya maddî olmayan işgörme sonuçlarının eser sayılması Alman Medeni Kanunu'nda benimsenen eser anlayışıyla da uygunluk arzetmektedir. Gerçekten BGB § 631/II'ye göre, eser sözleşmesinin konusunu, gerek bir şeyin imâli veya değiştirilmesi, gerek bir işgörme veya hizmet ediminden ortaya çıkan diğer bir sonuç teşkil edebilir.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin bu hususta görüşleri de hâkim fikirle uygunluk arzetmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi 1937 yılında verdiği bir kararında[15], bir yapı planının çizilmesini eser olarak nitelendirmiştir.

Federal Mahkeme daha sonra içtihat değiştirerek, *Gautschi* tarafından savunulan görüş doğrultusunda, eser sözleşmesinin konusunu sadece maddî varlığı olan çalışma sonuçlarının teşkil edebileceğini kabul etmiştir[16]. Bu kararda, eser sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümlerinin sadece maddî eserlerde uygulanabileceği gerekçesine dayanılmış; avukat veya jeologun mütalâa vermesi, mühendisin statik hesapları yapması, mimarın ön proje veya plân çizmesi hallerinde fikrî çalışma sonuçları bir kâğıtta tecessüm etse dahi, bunların vekâlet sözleşmesi hükümlerine tâbi olacağı kabul edilmiştir.

Bu karar özellikle *Jäggi* tarafından eleştirilmiştir[17]. Bunun üzerine yeniden görüş değiştiren Federal Mahkeme, maddî olmayan iş görme sonuçlarını da eser sayan eski içtihadına dönmüştür[18]. Bir arsanın öl-

---

12 Bk. aşağıda dn. 28 ve 29.

13 OR-**Zindel/Pulver**, Vorbem zu Art. 363-379, N. 2 ve 5; **Engel**, sh. 403; **Oser/Schönenberger**, Art. 363, N. 3; **Corboz**, FJS, N. 458, sh. 10 vd.

14 **Zimmermann,** Der Geist-Werkvertrag, Diss, Basel 1984.

15 BGE 64 II 12 yahut JdT 1938 I, sh. 280.

16 BGE 98 II 311 yahut JdT 1973 I 542.

17 **Jäggi,** SJZ 1973, sh. 310 vd.

18 BGE 109 II 34 yahut JdT 1983 I, sh. 266 vd.

çümlerinin bir plan üzerinde gösterilmesine ilişkin sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak nitelendiren bu kararda, şu tesbitlere yer verilmiştir: "İstisna sözleşmesinin sadece maddî bir şeye ilişkin çalışma sonuçlarını konu edinebileceği görüşü hatalı idi. TBK m. 470 (OR Art. 363) anlamında eser, bu görüşün aksine maddî olduğu kadar maddî olmayan bir şekilde de ortaya çıkabilir"[19]. Federal Mahkeme bu görüşünü daha sonraki kararlarında teyid etmiştir[20].

Yargıtay Başkanlar Kurulu bir kararında[21], belirli bir gündelik karşılığında bir gazinoda solist olarak şarkı söylemeyi taahhüt eden bir ses sanatçısı ile gazino sahibi arasındaki sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak nitelemiştir. Aynı şekilde, Yargıtay, mimari bir proje yapılmasına ilişkin sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak kabul etmiştir[22]. Başka bir Yargıtay kararında, yapının projesini çizen ve bunun uygulanmasını yapan mimarla yapılan sözleşmeyi eser ve hizmet sözleşmelerinden oluşan bileşik bir sözleşme olarak nitelemiştir[23]. Keza, fizibilite raporunun hazırlanması[24], nikâh törenini video kasetiyle görüntülemek[25], bir film artistinin, meydana getirdiği filmin o sahnesini kendi sanat gücü ve yeteneği oranında gerçekleştirmesi, bağımlı olmadan yaptığı işlerin bağımlı işlere nazaran üstün olduğu durumlarda[26] eser sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Bununla beraber, başta *Gauch*[27] olmak üzere bazı yazarlar[28] maddî olmayan işgörme sonuçlarının eser sözleşmesine konu olması görüşüne, haklı olarak, iki açıdan sınırlama getirmektedirler:

---

19 BGE 109 II 37.

20 BGE 109 II 465; 113 II 266; 114 II 56; 115 II 53 vd; 119 II 45 vd.

21 23.2.1968, E. 12/K. 76 (**Tandoğan** II, sh. 17/18; **Karahasan**, C. 4, sh. 879).

22 15. HD, 20.9.1976, E. 2108/K. 3038 (YKD 1978, sh. 423 vd); 15. HD, 11.2.1991, E. 2751/K. 526: "Taraflar arasındaki uyuşmazlık avan proje, etüd ve çizimi ile yetkili kuruldan onay almak koşuluna dayanan eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır" (**Uygur,** İnşaat Hukuku, C. 1, sh. 329).

23 10. HD, 22.1.1976, E. 4935/K. 1294 (YKD 1976, sh. 678 vd.).

24 15. HD, 20.6.1978, E. 644/K. 640 (**Karahasan,** C. 6, sh. 41).

25 15. HD, 20.6.1989, E. 1742/K. 2970 (**Uygur,** C. 5, sh. 104).

26 10. HD, 21.7.1974, E. 3612/K. 4738 (**Uygur**, İnşaat Hukuku, Ankara 1993 sh. 107).

27 **Gauch,** N. 42 vd.

28 **Tercier/Favre**, N. 4228, 4231; **Fellmann**, Art. 394, N. 327. **Tandoğan** II, sh. 21 vd.; **Yavuz,** sh. 451 vd.

aa) Önce, maddî olmayan bir sonuç, ancak niteliği icabı bir iş görme sonucu olarak taahhüt edilebildikleri ölçüde eser sözleşmesine konu olabilirler[29]. Bu anlamda olmak üzere, öğretim, dava ve tedavide belirli başarılı bir sonucun elde edilmesi taahhüt edilemez; bu durumlarda sonuç, esas itibarıyla, niteliği gereği taahhüt edenin gücü dışında kalan ve tartılamayan faktörlere bağlıdır.

Hasta ile doktor arasındaki tedavi ve genel cerrahî müdahalelere ilişkin sözleşmeleri vekâlet sözleşmesi olarak kabul etmek gerekir. Aynı sonuç estetik amaçla yapılan ameliyatlar (meselâ saç nakli) için de savunulmakta ve sınırda bir hal olmakla birlikte, bu tür ameliyatlarda, cerrahî müdahalenin çok kişisel karakter taşıması ve taraflar arasındaki belirgin güven ilişkisinin varlığı sebebiyle, vekâlet hükümlerinin uygulanması gerekir[30]. Bununla beraber Yargıtay'a göre, "Davada dayanılan maddi olgu, burnun estetik ameliyatı yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan şekle uygun güzel bir görünüm kazandırılmasıdır. Bu olgudan hareket edildiğinde, böyle bir sözleşmede sonucun ortaya çıkması yönünden teminat verilerek borç altına girildiği, diğer bir anlatımla belli bir sonucun elde edilmesinin kararlaştırıldığı kuşkusuz ve duraksamaya yer olmayacak şekilde açıktır. O halde bu sözleşmenin eser sözleşmesi olarak kabulü gerekir"[31]. Kanaatimizce hekimin estetik müdahalesinin vekâlet veya eser sözleşmesi olarak nitelendirilmesi için girişimin hangi amaçla yapıldığının tespiti gerekir. Hastanın sağlık ihtiyacı için yapılan girişimsel müdahaleye vekâlet hükümlerinin uygulanması, buna karşılık sadece dış görünümü isteğe uygun hale getirmek için yapılan müdahaleye eser sözleşmesi hükümlerinin uygulanması düşünülmelidir.

bb) İkinci olarak, eser sözleşmesine ait bazı kurallar (özellikle eserin teslim ve muayenesine ilişkin olanlar) maddî olmayan sonucun belirli ölçüde maddîlik kazanması, (yapı planında olduğu gibi) bir şeyde (meselâ bir yazılı metinde, bir modelde, bir ses bandında veya bir elektronik veri hafızasında) devamlılık taşıyan şekil alması ve böylece görülebilir tarzda tesbit edilmesi gerekir[32]. Bununla beraber, uygula-

---

29 **Gauch,** N. 43; **Corboz**, FJS, Nr. 458, sh. 11; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 478.

30 **Gauch**, N. 44; **Tandoğan** II, sh. 21; BGE 108 II 59 vd.

31 13. HD, 5.4.1993, E. 131/K. 2741 (YKD 1994, sh. 79).

32 **Gauch**, N. 45; **Leuenberger**, ZSR 106/1987 II, sh. 20; **Tercier/Favre**, N. 4228, 4234; **Fellmann**, Art. 397, N. 187; **Tandoğan** II, sh. 21-22; **Yavuz**, sh. 452; BGE 113 II 266. Aksi fikirde, yukarda dn. 14'te zikredilen yazarlar ve BGE 109 II 38.

mada sinema veya havaî fişek gösterilerini seyretme sözleşmesi[33], hizmet sözleşmesi şeklinde yapılmayan müzisyen, orkestra şefi veya ses sanatçılarıyla yapılan sözleşmeler[34] eser sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Bu kararlar, TBK m. 470 anlamında eser kavramını aşırı derecede genişlettiği için tenkit edilmektedir[35].

b) Meydana getirme kavramı

Eser sözleşmesinin tanımıyla ilgili yukarıdaki açıklamalarımızda, TBK m. 470'te yer alan meydana getirme kavramına değinilmişti.

Buna göre eserin meydana getirilmesi aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

aa) Yeni bir eser meydana getirme

Bir binanın inşaası[36], bir otoyolun yapımı[37], bir ısıtma tesisatının yapımı[38], bir makinenin yapımı[39], bir teleferik tesisatının kurulması hallerinde yeni bir eser meydana getirilmesi söz konusudur.

bb) Mevcut bir eser üzerinde gerçekleşen çalışma sonuçları

Bu anlamda eser meydana getirme deyimine ve kapsamına tamir, bakım, takviye, şekil değişikliği veya yenileme şeklindeki çalışma sonuçları girer[40]. Meselâ, bir çatının, otomobilin[41], ısıtma tesisatının[42], bir makinenin tâmiri; bir yapının dış cephesinin yenilenmesi veya temizlenmesi[43]; bir çatının izole edilmesi[44] veya tamiri; bir vinç tesisatının kurulması[45].

---

33 BGE 109 II 38; 80 II 34; 70 II 218.
34 BGE 112 II 41 vd.
35 **Gauch,** N. 45, **Leuenberger**, sh. 56; **Tercier/Favre**, N. 4221.
36 BGE 117 II 273; 107 II 438.
37 BGE 107 II 314.
38 BGE 94 II 158.
39 BGE 98 II 298.
40 **Gauch,** N. 28; **Tercier/Favre**, N. 4252 vd; OR-**Zindel/Pulver,** Art. 363, N. 8.
41 BGE 113 II 421; 59 II 63.
42 BGE 116 II 454.
43 BGE 120 II 215; 117 II 425 vd.
44 BGE 107 II 271 yahut JdT 1981 I 598.
45 BGE 111 II 170 vd.

Mevcut bir binanın yıkılması veya zehirleyici ürünlerin tahribi de TBK m. 470 anlamında çalışma sonucu ve eser sözleşmesinin konusu olarak kabul edilmektedir[46].

cc) İnsan vücudu üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçları

Belirli bir sonuç taahhüdü bulunduğu takdirde, insan vücudu üzerinde çalışma sonuçları da eser meydana getirme sayılır. Meselâ, saç boyama veya saç yapma, manikür veya pedikür yapımı[47].

2. Bedel ödeme borcu

Eser sözleşmesinde işsahibinin meydana getirilecek eser karşılığı olarak bir bedel ödemeyi taahhüt etmesi, bu sözleşmenin aslî yükümlerindendir[48]. Kanun koyucu ücret yerine bedel kavramını tercih etmek suretiyle eser sözleşmesini unsurları bakımından hizmet sözleşmelerinden (TBK m. 393 vd.) ayırmıştır. Sözleşmede bedel ödeme taahhüdünün bulunması yeterli olup, bunun miktarının önceden belirlenmiş olması şart değildir. Zira, eserin bedelinin önceden belirlenmemesi veya yaklaşık olarak belirlenmiş olması hallerinde bedel, eserin yapıldığı yer ve zamandaki değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenebilmektedir (TBK m. 481). Bir eser meydana getirmenin bedelsiz olarak taahhüt edilmesi halinde, eser sözleşmesi söz konusu olmaz. Bu takdirde vekâlet sözleşmesinin söz konusu olacağı ileri sürülmekte[49] ise de, burada eser sözleşmesi benzeri bir isimsiz (karma) sözleşme bulunduğunu kabul etmek gerekir[50].

3. Taraflar arasında anlaşma

a) Genel olarak

Yukarda da ifade edildiği gibi, eser sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir. Sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların, bir bedel karşılığında eser meydana getirilmesi konusunda anlaşmaları, yani onların karşılık-

---

[46] **Gauch**, N. 28; **Tercier/Favre**, N. 4210 vd; **Oser/Schönenberger**, Art. 363, N. 5.

[47] **Gauch**, N. 31; **Tercier/Favre**, N. 4225 ve 4226; **Gautschi**, Vorbem zu Art. 363-379, N.6.

[48] **Gauch**, N. 110; **Tercier/Favre**, N. 4210 ve 4649 vd.; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 4.

[49] **Oser/Schönenberger**, Art. 363, N. 7; **Pedrazzini**, sh. 38; **Bucher**, BT, sh. 211; BGE 64 II 10.

[50] **Gauch**, N. 111, 115; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 6; **Tandoğan** II, sh. 24.

lı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. Bu anlaşmanın tarafları ise, bir eser meydana getirme borcu altına giren "yüklenici" ile bedel ödemeyi borçlanan "işsahibi"dir. Satış sözleşmesinde bedel ifa yeri ve zamanındaki ortalama piyasa fiyatına göre belirlenirken (TBK m. 233/I), eser sözleşmesinde bedel eserin yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenebilmektedir.

b) Sözleşmenin şekli

Eser sözleşmesinin geçerliliği, kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlı değildir; zımnî irade beyanlarıyla da kurulabilir[51]. Buna karşılık, yüklenicinin bir taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesi borcunu ihtiva eden eser sözleşmelerinin (meselâ, yüklenicinin kendisine ait bir arsa üzerinde bir bina inşa edip işsahibine teslim etmeyi taahhüt etmesi) resmî şekilde yapılması gerekir[52]. Aynı şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bu kanun hükümlerine tâbi kurum ve kuruluşlara ait yapım işlerinin sözleşmeye bağlanmasını (m. 53/I) ve bu sözleşmenin noterlikçe tescilini (m. 57) öngörmektedir. Bir geçerlilik şartı olan tescile esas teşkil eden sözleşmenin imza tasdiki şeklinde yapılması yeterlidir[53].

---

51 **Gauch**, N. 406; **Tercier/Favre**, N. 4357; OR-**Zindel/Pulver,** Vorbem. Zu Art. 363-379, N. 16; **Tandoğan** II, sh. 28-29; **Yavuz**, sh. 454-455; 15. HD, 16.2.1984, E. 3983/K. 437 (YKD 1984, sh. 1555-1556); 15. HD, 31.10.1984, 1631/K. 3266 (YKD 1985, sh. 1218 vd).

52 **Tercier/Favre**, N. 4358; **Gauch**, N. 408; **Yavuz**, sh. 455; BGE 117 II 264.

53 **Tandoğan** II, sh. 33; **Yavuz**, sh. 455; HGK, 7.12.1983, E. 81-4-224/K. 83-1276 (YKD 1984, sh. 707 vd); 15. HD, 6.11.1995, E. 5314/K. 6113: "Yanlar arasındaki davanın konusu davalıya ait tapulu taşınmazlara yapılacak kat karşılığı inşaatlar oluşturmaktadır. Gerçekten tapuda pay devrini içeren bu akitlerin "bozma ilâmında da belirtildiği gibi" geçerli olabilmesi için resmî biçimde tapuda ya da düzenleme şeklinde noterlerde yapılması gerekmektedir. Ne var ki olayda davalı Belediye iki taşınmazına inşaat yapımı konusunda 2886 sayılı yasa uyarınca ihale açmış ve usûlüne uygun biçimde sonuçlanan ihale üzerine, noterde onaylanan sözleşmelerde iş bağıtlanmıştır. Yöntemine uygun ihale kararı, Belediye Encümeninin kabulü ve noterde onaylanan sözleşmeler karşısında artık, bu sözleşmelerin geçersizliğinden söz edilemez. Zira 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 53. maddesinde bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanacağı, 57. maddesinde geçici teminatın kesin teminata çevrilerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmenin idareye verileceği esası getirilmiş, tapulu, taşınmazlarla ilgili sözleşmelerin noterde düzenleme biçiminde yapılacağına dair bir hükme de yer verilmemiştir. O halde 57. maddede sözü edilen "tescil edilecek sözleşmeden" noterde onaylanacağı anlamının çıkartılması gerekir. Nitekim Yargıtay Hukuk Ge-

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun, bu kanun hükümlerine tabi kurum ve kuruluşlara ait yapım işlerinin sözleşmeye bağlanmasına ilişkin, 46. maddesine göre, "yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır". 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununun 7. maddesinde de, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu olan hususlara yer verilmiştir. Kamu ihale sözleşmelerine imzalanmasından itibaren özel hukuk hükümleri uygulanmaktadır. Zira, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 36. maddesinde bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yüklenici ile arsa sahibi arasında yapılan arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı sözleşmeleri, hukukî niteliği itibariyle bir karma sözleşmedir. Bu tür inşaat sözleşmeleri arsa payının yükleniciye devir borcunu (taşınmaz satış vaadini) içerdikleri için, resmi şekilde yapılmaları (TBK m. 237, MK m. 706, Tapu K. m. 26, Noterlik K. m. 60) zorunludur. Bu şekil geçerlilik şartı olup, hukukumuzda bu tür sözleşmelerin tapu sicil müdürlüklerince veya noterlerce re'sen düzenleme yoluyla yapılabileceği kabul edilmektedir[54].

---

nel Kuruluna intikal eden davalarda da tescil sözcüğünün noterde onay anlamı çıkartılmış ve sözleşmelerin noterde onaylanmasının akdin geçerliliği bakımından kafi olduğuna karar verilmiştir (HGK 21.4.1982, E. 15-550/K. 417; 7.12.1983, E. 4-224/K. 1276; 14.1.1981, E. 4-259/K.10). Kaldı ki ihalenin mahiyeti bakımından resmi şekle bağlanmasında güçlük bulunduğundan, taşınmazların ihtiyari açık artırma yoluyla satılmasında mülkiyeti devir borcu ihaleyle doğmakta, ayrıca resmi şekle ihtiyaç bulunmamaktadır (BK m. 225 ve 228) (**Uygur**, İnşaat Hukuku, C. 1, sh. 315).

[54] Yarg. İBK, 24.4.1978, E. 3/K 4 (RG, Nr. 16312); **Yavuz**, sh. 518 ve dn. 32'de zikredilen Yargıtay kararları.

§ 26. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI

Eser sözleşmesinde, yüklenicinin iki aslî yükümü bulunmaktadır. Bunlardan biri eser meydana getirme, diğeri eseri teslimdir. Bunların yanında yüklenicinin özen yükümü ve diğer yan yükümleri yer alır.

I. Eser meydana getirme borcu

1. Genel olarak

Yüklenicinin ilk aslî borcu "bir eser meydana getirme" borcudur; bu borç eser sözleşmesini tanımlayan TBK m. 470te yer alan, "yüklenici bir eser meydana getirmeyi üstlenir" ifadesinden çıkartılmaktadır. Aynı şekilde, eserin teslim edilebilmesi için tamamlanması gerekir.

Yüklenicinin bir eser meydana getirme borcu çerçevesinde, şahsen ifa veya kendi yönetimi altında yaptırma (TBK m. 471/III), araç gereç ve malzemeleri sağlama (TBK m. 471/IV ve m. 472) borçları bulunmaktadır.

2. Eseri şahsen meydana getirme veya kendi idaresi altında yaptırma borcu

a) Kural

TBK m. 471/III, c.1'e göre, "Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür". Kanun koyucu bu hükümle, yüklenicinin, eser meydana getirme borcunu, kural olarak, şahsen (bizzat) ifa etmekle veya yardımcılarının (işçilerinin) çalışmasını şahsen yönetmekle yükümlü olduğunu öngörmektedir. TBK m. 471/III, c.1'de yer alan bu kuralla, eser sözleşmesinde eser meydana getirme borcunun bizzat yüklenici tarafından ifa edilmesinde veya onun yönetiminde yapılmasında işsahibinin menfaati bulunduğu ve burada TBK m. 83'te öngörülen genel kuralın değil, onun istisnasının söz konusu olduğu ifade edilmektedir[1]. Bunun sebebi ise, eser sözleşmesinde maddî (aynî) edimlerin yanında yer alan hizmet edimleri dolayısıyla, yüklenicinin

[1] **Honsell**, sh. 246; **Gauch**, N. 617; **Bühler**, Art. 364, N. 47.

şahsının veya şahsî yeteneklerinin, sözleşmenin kurulmasında önem taşıdığı düşüncesidir[2].

TBK m. 83'e göre, kural olarak, borçlu şahsen ifada bulunmakla yükümlü olmadığı halde, TBK m. 471/III c. 1'de yüklenicinin eser meydana getirme borcunun kişisel niteliği karine olarak kabul edilmiştir; TBK m. 471/ III c. 2'ye göre ise, "Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir". Eserin yapılmasının kendisinin kişisel niteliklerine bağlı olmadığını iddia eden yüklenici, bu durumu isbatla yükümlüdür[3]. Buna karşılık, yüklenicinin eseri kendi yönetiminde yaptıramayacağını, onu şahsen ifa etmekle yükümlü olduğunu iddia eden işsahibi, bu iddiasını isbatla yükümlüdür[4].

Bununla beraber, söz konusu karinenin iş bölümüne dayanan modern ekonominin gereklerine uygun olmadığını kabul etmek gerekir[5].

Meydana getirilecek eserin seçilen yüklenicinin ferdî (fikrî ve bedenî) yeteneklerinin damgasını taşıyacak türden olduğu ve başkalarının aynı eseri onun idaresi altında dahi meydana getirmesinin mümkün olmadığı hallerde (meselâ bir sanat eseri) şahsen ifa yükümü söz konusu olur[6]. Bu ihtimal ise el işçiliğine dayanan işletmelerde gerçekleşir; büyük çaptaki inşaat ve makine tesislerinin yapımında şahsî yeteneklere dayanmayan çalışmalar hâkimdir[7]. Bunun dışında kalan ve çoğunluğu teşkil eden hallerde eser, yüklenicinin idaresi altında meydana getirilir; ticaret şirketlerinin üstlendiği işlerde veya meydana getirilecek eserin iş bölümünü gerektirdiği hallerde böyle bir durum karşısında bulunulur[8]. İşi kendi idaresi altında yaptıracak yüklenicinin, işi yapacak olanların seçiminde özenli davranmak, gerekli talimatları vermek ve işin icrasını denetlemek yükümü mevcuttur[9].

---

2 **Honsell**, sh. 246; **Tercier/Favre**, N. 4381.

3 **Pedrazzini**, sh. 37; **Gauch**, N. 617; **Bühler**, Art. 364, N. 79.

4 **Pedrazzini**, sh. 37; **Gauch**, N. 617; **Bühler**, Art. 364, N. 79.

5 **Gauch**, N. 617; **Bühler**, Art. 364, N. 79; **Tandoğan** II, sh. 72.

6 **Gauch**, N. 609; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 30; **Schraner**, Art. 68, N. 15; **Bühler**, Art. 364, N. 56.

7 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 30; **Gautschi**, Art. 364, N. 9 d, e, 17 a vd.

8 **Gauch**, N. 610; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 31.

9 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 34; **Gautschi**, Art. 364, N. 11 c.

b) Yüklenicinin eseri başkasına (alt yükleniciye) yaptırma yetkisi

aa) Yüklenicinin işi başkasına yaptırma yetkisi ve alt yüklenici kavramı

Yüklenicinin işi şahsen yapma veya kendi idaresi altında yaptırma yükümünün istisnasını düzenleyen TBK m. 471/III, c. 2'ye göre, "Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir". Bu hüküm, yüklenicinin işsahibine borçlandığı işi başkasına yaptırma veya devir yetkisini, işin niteliğine göre şahsi yeteneklerin önemli olmaması şartına bağlamaktadır. Burada yer alan "yüklenicinin kişisel özellikleri" deyimi, yüklenicinin edimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. Bu belirlemede, sözleşme konusuyla ilgili teamül ve uygulama önemli bir rol oynar; yüklenici ile işsahibi arasındaki şahsî ilişki (akrabalık veya dostluk) ve yüklenicinin ödeme gücü önemli değildir[10]. Tüzel kişilerde edim bakımından önem taşıyan şahsî nitelikler, özellikle tecrübe, know-how, özel metodlara hâkimiyet ve personelin seviyesi gibi, işletmenin edimle ilgili özelliklerini ifade eder[11].

Az önce de ifade edildiği gibi, yüklenicinin şahsî niteliklerinin esas alınması modern ekonomideki iş bölümü anlayışına uygun düşmediği için, günümüzdeki uygulamada, genel eser sözleşmelerinde işin başkasına devri bir istisna değil, kural haline gelmiştir[12].

Diğer taraftan, TBK m. 471/III, c. 1 hükmü emredici bir nitelik taşımadığı için, taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler; yüklenicinin işi başkasına devir yetkisini genişletebilirler veya daraltabilirler yahut tamamen işsahibinin muvafakatına bağlayabilirler[13].

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 15. maddesine göre, ihale konusu işin niteliği gereği ihtiyaç bulunması halinde isteklilerin ihale aşamasında alt yüklenicilere yaptırmayı tasarladıkları işleri beyan etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde belirtilen alt yüklenicilerin listesi idare tarafından kamu ihale sözleşmesi imzalanmadan önce onaylanmalıdır. İdare onayına rağmen alt yüklenicinin bu çerçevede yaptığı işlerden yüklenicinin sorumluluğu devam etmektedir. 4735 sayılı Kamu

---

10 **Gauch**, N. 612; **von Tuhr/Escher**, sh. 23, dn. 1.

11 **Gauch**, N. 614; OR-**Zindel-Pulver**, Art. 364, N. 38.

12 **Tercier/Favre**, N. 4382, sh. 423; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 36; **Bucher**, BT, sh. 205.

13 **Tercier/Favre**, N. 4387, **Gauch**, N. 618; **Tandoğan** II, sh. 73.

İhale Sözleşmeleri Kanununun 7/c maddesi alt yüklenicileri ilişkin bilgiler ve sorumluluklarının belirtilmesini sözleşmenin zorunlu unsurları arasında saymaktadır[14], Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin devrini düzenleyen 16. maddesine göre, "sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takiben üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden veya devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır".

Aynı hüküm, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin devri başlıklı 47. maddesinde de yer almaktadır.

Yüklenicinin, TBK m. 471/III, c.2 çerçevesinde, yüklendiği işin bir kısmını veya tamamını başkasına yaptırması halinde alt yüklenicilik ilişkisi söz konusu olur. Alt yüklenici (Subunternehmer), yüklenici ile yaptığı bir eser sözleşmesiyle, yüklenicinin (asıl) işsahibine karşı borçlandığı işin bir kısmının veya tamamının yerine getirilmesini taahhüt eden kişidir[15]. Asıl yüklenicinin alt yükleniciyle işin bir kısmının veya tamamının yapılması amacıyla kurdukları bu eser sözleşmesine "alt yüklenicilik sözleşmesi" (Subunternehmervertrag) adı verilmektedir. Yüklenici bu sözleşmeyi, işsahibi adına değil, kendi ad ve hesabına yapmaktadır[16]. Buna karşılık, asıl yüklenici ile onun işsahibi arasındaki eser sözleşmesine "asıl sözleşme" (Hauptvertrag) denilir[17]. Alt yüklenici, kural olarak, asıl yükleniciden bağımsız olarak ve onun

---

[14] Kamu İhalelesi ile verilen yapım işlerinde yükleniciler ve alt yükleniciler eserin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zarardan sorumludur. Söz konusu zarar yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Sorumluluk, işe başlama tarihi ile kesin kabul tarihi arasında bulunan zaman dilimi için vardır. Yüklenici ve alt yüklenici kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur (4735 sayılı Kanun m. 30).

[15] **Gauch**, N. 138 ve 620; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 37; **Tercier/Favre**, N. 4386; **Tandoğan**, II, sh. 77.

[16] **Gauch**, N. 138; **Bühler**, Art. 364, N. 50; **Eren**, İnşaat, sh. 65.

[17] **Gauch**, N. 137.

kişisel yönetim, denetim ve gözetimine bağlı olmadan çalışan bir ifa yardımcısıdır[18]. Bununla beraber, bazı yazarlar[19] genellikle alt yüklenicinin bağımsız ifa yardımcısı olduğunu kabul etmekle birlikte, alt yüklenicinin asıl yükleniciden bağımsız olarak hareket etmesinin zorunlu bir unsur olmadığını ve yüklenicinin kişisel yönetimi altında da çalışabileceğini iddia etmektedirler. Onlara göre, sözleşmede kararlaştırılan veya işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, alt yüklenici asıl yüklenicinin yönetim ve denetimi altında çalışabilir.

bb) Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki

Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasında, alt yüklenicilik sözleşmesi adı altında bir eser sözleşmesi kurulmaktadır. Bu sözleşmeyle alt yüklenici, asıl yükleniciye karşı, bedel karşılığında bir eser meydana getirmeyi ve ona teslim etmeyi taahhüt eder; aynı şekilde, alt yüklenici eserin ayıplarından dolayı asıl yükleniciye karşı sorumludur. Alt yüklenicinin malzemeyi sağlamayı taahhüt edip etmemesi önemli değildir[20]. Alt yüklenicilik sözleşmesi, kurulma ve muhteva açısından, işsahibi ile asıl yüklenici arasındaki eser sözleşmesinden (asıl sözleşmeden) bağımsızdır; bununla beraber, alt yüklenicilik sözleşmesinin şartlarının asıl sözleşmeyle bağlantılı olması da mümkündür[21].

cc) Asıl işsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki

Asıl (ilk) işsahibi ile alt yüklenici arasında herhangi bir eser sözleşmesi ilişkisi bulunmamaktadır. Bu itibarla asıl işsahibi, alt yükleniciden eser meydana getirilmesi ve onun kendisine teslimi konusunda bir talep hakkına sahip değildir. Alt yüklenici, eser meydana getirmeyi sadece asıl yükleniciye taahhüt etmiştir. Asıl işsahibi, alt yüklenicilik sözleşmesinin ihlâlinden asıl yüklenici lehine doğan hakları kendi adına ileri süremez; o, sadece, şartları varsa, haksız fiil hükümlerine dayanarak alt yükleniciye başvurabilir[22].

---

18 **Gautschi**, Art. 364, N. 11 a, 11 b, 15 a ve c; **Pedrazzini**, sh. 36, dn. 101; **Eren**, sh. 65; BGE 103 II 57.

19 **Becker**, Art. 364, N. 6; **Gauch**, N. 623-624; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 31; **Cerutti**, sh. 101 vd.

20 **Gauch**, N. 144; **Tandoğan** II, sh. 82.

21 **Gauch**, N. 146 vd; **Bühler**, Art. 364, N. 52; **Tandoğan** II, sh. 83 vd.

22 **Gauch**, N. 163; **Tandoğan** II, sh. 85.

Bununla beraber, iki halde asıl işsahibi, sözleşmeye dayanarak doğrudan doğruya alt yükleniciye başvurabilir[23]. Bu hallerden birincisi, alt yüklenicinin ilk yüklenicinin kendisine verdiği işleri tam olarak ve zamanında ifa edeceğini asıl işsahibine karşı sözleşmeyle taahhüt etmesidir; diğeri ise, alt yüklenicilik sözleşmesinin TBK m. 128/II anlamında asıl işsahibi lehine yapılmış bir tam (gerçek) üçüncü kişi yararına sözleşme niteliği taşımasıdır.

Asıl işsahibi ile alt yüklenici arasında eser sözleşmesi ilişkisi bulunmadığı için, onun alt yükleniciye karşı herhangi bir bedel ödeme borcu bulunmamaktadır[24]. Bununla beraber, asıl (ilk) işsahibi, alt yükleniciye karşı müteselsil borçlu sıfatıyla (TBK m. 162) veya kefil olarak bedel ödeme taahhüdünde bulunmuş veya ona garanti vermiş ise, alt yükleniciye karşı bedel ödeme borcu altına girmiş olur[25].

dd) İlk yüklenicinin, alt yüklenicinin davranışlarından dolayı, asıl işsahibine karşı sorumluluğu

İlk yüklenicinin işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye devir yetkisinin bulunması halinde, alt yüklenici onun ifa yardımcısıdır; ilk yüklenici, alt yüklenicinin asıl işsahibine verdiği zararlardan dolayı yardımcı kişilerin fiilinden sorumluluğu düzenleyen TBK m. 116 gereğince sorumlu olur[26]; ilk yüklenicinin işi alt yükleniciye devir yetkisinin bulunmadığı hallerde de aynı sonuç geçerli olur[27]. İlk yüklenicinin, alt yüklenicinin davranışından dolayı asıl işsahibine karşı TBK m. 116 gereğince ifa yardımcısı olarak sorumluluğu, alt yüklenicinin kendisine karşı sorumlu olmasına veya bu sorumluluğun kapsamına bağlı değildir[28].

İlk yüklenici, yetkisi olmadığı halde işi alt yükleniciye devretmiş ise, bu davranış sözleşmenin müsbet ihlâli sayılır ve alt yüklenicinin asıl işsahibine verdiği zararlardan dolayı ayrıca TBK m. 112 gereğince

---

23 **Gauch**, N. 164-165; **Tandoğan** II, sh. 85; **Eren**, İnşaat, sh. 66.

24 **Gauch**, N. 173; **Tandoğan** II, sh. 88.

25 **Gauch**, N. 174; **Tandoğan** II, sh. 88; **Eren**, İnşaat, sh. 66.

26 **Gauch**, N. 177; **Spiro**, Erfüllungsgehilfen, sh. 32, 188 ve 199; **Chaix**, sh. 117 vd.; **Bühler**, Art. 364, N. 67; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 31; BGE 116 II 308.

27 **Gauch**, N. 177; **Spiro**, sh. 159; **Koller**, Erfüllungsgehilfen, sh. 61 vd; özellikle, N. 226 vd.; **Eren**, İnşaat, sh. 68; **Tandoğan** II, sh. 92/93.

28 **Gauch**, N. 177; **Tandoğan** II, sh. 93 karş. **Spiro**, sh. 206.

de sorumlu olur[29]. Bu durumda sözleşmenin ihlâli, alt yüklenicilik sözleşmesinin kurulmasıyla değil, alt yüklenicinin fiilen çalıştırılmasıyla gerçekleşir[30]. İşin yetkisiz olarak alt yükleniciye devri halinde, asıl işsahibi, ilk yükleniciden alt yüklenicinin işten uzaklaştırılmasını isteyebilir. İsviçre Federal Mahkemesi'ne göre, bu durumda, asıl işsahibi, borçlunun temerrüdüne ilişkin TBK m. 123-125 hükümlerine göre sözleşmeyi feshedebilir[31]. Buna karşılık bazı yazarlar[32], asıl işsahibine, TBK m. 473 uyarınca işi başkasına yaptırma hakkı tanımanın doğru olacağı görüşündedirler.

Meydana getirilen eser alt yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı ayıplı olarak asıl işsahibine teslim edilmişse, ilk yüklenici, asıl işsahibinin sözleşmeden dönme, semenin tenzili veya onarım haklarını kullanması halinde, TBK m.116'dan bağımsız olarak, kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu olur. Buna karşılık, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin tazminini kusur şartına bağladığı ayıbı takip eden zararlar açısından, ilk yüklenicinin TBK m. 116 gereğince kusursuz sorumluluğunun uygulanması söz konusu olur[33].

2. Eserin meydana getirilmesi için gerekli araç ve gereçleri sağlama borcu

TBK m. 471/IV'e göre, "Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır". Bu hüküm uyarınca, aksine bir âdet veya sözleşme olmadıkça, işin görülmesi için gerekli olan araç ve gereçleri sağlamak ve bunların masraflarını karşılamak yükleniciye aittir. Araç ve gereç sağlama borcu kapsamına iş makineleri, şantiye binası, işte kullanılacak âletler, elektrik ve su tesisatı kurulması, mazot, petrol vs. sağlanması girer[34].

---

29 **Gauch**, N. 177 ve 640; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 51; **Koller**, N. 234; **Cerutti**, N. 458 vd; **Bühler**, Art. 364, N. 69. BK m. 96 ve 100'e ait sorumlulukların şartları ve kapsamları için bk. **Cerutti** ve **Bühler** (anılan yerler). Ayrıca bk. **Koller**, N. 224 vd ve dn. 194.

30 **Gauch**, N. 639; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364. N. 51; **Bühler**, Art. 364, N. 68.

31 BGE 103 II 55 yahut JdT 1977 I sh. 544, cons. 4.

32 **Gauch**, N. 640; **Cerutti**, N. 498 vd.; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 52.

33 **Gauch**, N. 178; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 31; **Gautschi**, Art. 364, N. 21 a; **Bühler**, Art. 364, N. 21 a; **Tandoğan** II, sh. 93; BGE 116 II 308.

34 **Gauch**, N. 69 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 43.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi[35] m. 20'ye göre;

"Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır."

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmış Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi[36] 18. maddeye göre:

"Sözleşmenin imzasından sonra müteahhit, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makina, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır."

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir.

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır.

Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları her zaman diğerlerine tercih edecektir.

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır".

---

35 "Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar" (m. 2).

36 "Bu Genel Şartname, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, Özel İdareler ve Belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taahhüde bağladıkları yapım ve hizmet işlerini kapsar."

Yüklenici uygun olmayan veya ayıplı araç ve gereç sağlarsa, işsahibi, TBK m. 473/II'ye göre hareket edebilir; araç ve gereçlerin işsahibi tarafından sağlanması halinde, yüklenici bunların özenle kullanılmasından sorumlu olur (TBK m. 472/II ve TBK m. 483/II hükümleri kıyasen uygulanabilir)[37].

3. Malzemelerin sağlanması borcu

a) Genel olarak

Malzeme, eserin imalinde kullanılan ve onun bünyesine dahil olan maddelerdir[38]. Meselâ taş, kum, tuğla, hazır beton, inşaat demirleri, kapı, pencere, lavabo, küvet, binaya monte edilecek tesisat, borular vs. malzeme, ham madde şeklinde (taş, kum gibi) olabileceği gibi, önceden imal edilmiş bir şey (prefabrik yapı elemanları) de olabilir. Bu malzemeler eserin meydana getirilmesinde kullanılmakla beraber, bizzat kendileri eser sözleşmesinden doğan eser meydana getirme yükümünün konusunu oluşturmaz. Yüklenici malzemeyi kullanmakla yükümlü olmakla beraber, onu imal etmekle yükümlü değildir[39]. Buna karşılık, inşaatın üzerinde yapılacağı arsa ve planlar bu anlamda malzeme sayılmazlar; bunlar hakkında TBK m. 472/II hükmü kıyas yoluyla uygulanabilir[40].

Borçlar Kanunu, eser sözleşmesinde malzemelerin kimin tarafından temin edileceği konusunu açıkça düzenlememiştir. TBK m. 472/I'de yer alan, "malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa" ibaresinden ve TBK m. 472/ III'ün zıt kavramından hareket ederek; aksine bir anlaşma yoksa, eserin meydana getirilmesinde kullanılacak malzemelerin, kural olarak işsahibi tarafından sağlanması gerektiği sonucuna varılabilir[41]. Şüphe halinde, yüklenicinin malzeme temin borcunun bulunmadığını kabul etmek gerekir[42].

---

37 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 44; **Eren**, İnşaat, sh. 68.

38 **Gauch**, N. 66; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 4; **Tandoğan** II, sh. 104.

39 **Gauch**, N. 66; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 4; **Tandoğan** II, sh. 104.

40 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 4; **Oser/Schönenberger**, Art. 364, N. 2, **Gauch**, N. 73; **Oser/Schönenberger**, Art. 365, N. 3. Aksi fikirde: **Tercier**, N. 3430.

41 **Gauch**, N. 74; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 2; **Oser/Schönenberger**, Art. 365, N. 11; **Eren**, İnşaat, sh. 69.

42 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 2.

Aksi fikirde olan *Tandoğan*'a göre[43], TBK m. 472/I'e karşılık gelen "BK m. 357/I'in "Mütaahhit, imal ettiği şeyde kullandığı malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı işsahibine karşı mesul ve bu hususta bayi gibi mütekeffildir" biçimindeki ifadesi bu malzemenin işsahibi tarafından verilmesine ilişkin ikinci fıkradan önce yer alması, kural olarak malzemeyi yüklenicinin getireceği yorumuna daha elverişlidir. Bayındırlık işlerinde de BİGŞ.nin malzeme ocaklarına ilişkin 6. ve 29. maddeleriyle "Müteahhide ait Giderler" kenar başlığını taşıyan 25. maddesinden malzemenin kural olarak yüklenici tarafından sağlanacağı, dolaylı olarak olsa da anlaşılmaktadır".

Bühler'e göre[44], malzemelerin işsahibi tarafından sağlanacağına ilişkin bir karine bulunmamaktadır[45].

TBK m. 472/I'in metni, İsviçre Borçlar Kanunu'nun Fransızca metnine (CO art. 365/I) uygun ise de, Almanca metindeki (OR Art. 365/I) ifade farklıdır: "Yüklenici malzemeyi sağlamayı üstlendiği takdirde onun iyi vasıfta olmasından dolayı işsahibine karşı sorumlu ve bir satıcı gibi mütekeffildir". İtalyanca metni de Almanca metin gibidir. Borçlar Kanunu'muzun Fransızca metinden tercüme edildiği düşünülünce, Türk Kanun Koyucunun TBK m. 472/I hükmüyle farklı bir sistem tercih ettiği söylenemez. Bununla beraber, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesinde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 18. maddesinde yüklenicinin işlerin yapılması için gerekli "her türlü malzemeyi" temin etmek zorunda olduğu ifade edilmiştir.

b) Malzemelerin yüklenici tarafından sağlanması

Yüklenicinin sözleşmeyle malzemeyi sağlama borcunu üstlenmesi halinde, eser teslim sözleşmesi (Werklieferungsvertrag) söz konusu olur. Böyle bir durumda, yüklenici iyi cinsten malzeme sağlama borcunu da üstlenmiş olur[46]. İyi cins veya ayıpsız malzeme, sözleşmede vaad ve zikredilen veya dürüstlük kuralına göre beklenen (lüzumlu) vasıfları taşıyan malzemelerdir; dürüstlük kuralı gereğince beklenen

---

[43] **Tandoğan** II, sh. 105.

[44] Art. 365, N.5. Ayrıca bk. **Gautschi,** Art. 365, N. 2a

[45] **Tercier**'ye göre (N. 3429), uygulamada aksi çözüm kabul edilmekteyse de sistemden kural olarak, malzemeyi işsahibinin temin edeceği sonucu çıkmaktadır. Şüphe halinde, konuyu sözleşmede tesbit etmek taraflara ait olacaktır.

[46] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 5.

vasıflara sahip malzeme deyiminden, eserin sözleşmeye uygun şekilde meydana getirilmesine elverişli malzemeler anlaşılır[47].

İyi cins malzeme, aksi sözleşmede öngörülmedikçe, en azından orta kalitede olmak zorundadır. Orta kalitede malzeme, eserin kararlaştırılan tarzda ve vasıfta meydana getirilmesine elverişli malzemedir[48].

TBK m. 472/I'e göre, "Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur". Bu fıkrada satış sözleşmesine yapılan yollama zapttan doğan yükümü bakımındandır; ayıptan doğan sorumluluk, yani iyi cins malzeme temininden veya kullanılan malzemenin gerekli niteliği taşımamasından dolayı yüklenicinin sorumluluğu eser sözleşmesindeki ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine göre belirlenir[49]. Bu konuda satış sözleşmesine ilişkin ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanacağını savunan aksi yöndeki fikre[50] katılmak mümkün değildir. Zira, bu takdirde, eser akdinde yüklenicinin sorumluluğunu ayıbın sebebine göre farklı hükümlere tâbi tutma sonucu doğar; bu sonuç teleolojik yoruma uygun değildir[51].

c) Malzemelerin işsahibi tarafından sağlanması

Malzemelerin işsahibi tarafından sağlanması, onun malzemeleri doğrudan yükleniciye teslimi, işsahibinin kendisinden malzemeleri satın aldığı üçüncü kişinin teslimi veya işsahibinin ad ve hesabına yüklenici tarafından başkalarından satın alınma şekillerinde gerçekleşebilir; bizzat işsahibinin teslimi dışında kalan hallerde, işsahibinin temsilcisi olarak hareket edilir[52]. Malzemenin işsahibi tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teslim edilmesi halinde, kanun yükleniciye aşağıdaki mükellefiyetleri yüklemektedir:

---

47 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 6; **Tercier**, N. 3432; **Gauch**, N. 83.

48 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 7; **Gauch**, N. 83.

49 **Gauch**, N. 85, 1477 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 27 vd; **Honsell**, sh. 247; **Tercier**, N. 3501; **Schlatter**, sh. 34; **Schönle**, Art. 184, N. 132; BGE 117 II 428 yahut JdT 1992 I 606.

50 **Gautschi**, Art. 365, N. 2 b ve 8 d; **Becker**, Art. 365, N. 2; **Oser/Schönenberger**, Art. 365, N. 2; **Giger**, Vorbem zu Art. 197-210, N. 8.

51 **Gauch**, N. 1477 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 27 vd.

52 **Gauch**, N. 77-80; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 11.

aa) Malzemeleri özenle kullanma, hesap verme ve artan kısımları iade borcu

Malzemeleri özenle kullanma yükümü, onların gerekli şekilde muhafaza edilmesini (uygun şekilde depo edilmesini) ve üçüncü kişilerin olumsuz etkilerinden (çalınma, tahrip edilme gibi) korunmasını gerektirir[53].

Aynı şekilde, yüklenici, işsahibine malzemeler hakkında hesap vermek ve bunların artanlarını iade etmekle yükümlüdür.

bb) İhbar yükümü (BK m. 472/III)

İşin devamı esnasında, işsahibinin verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın ayıplı olduğu anlaşılır yahut işin (imalâtın) gereği gibi veya zamanında ifa edilmesini tehlikeye sokacak durumlar ortaya çıkarsa, yüklenici işsahibine bunları bildirmek zorundadır; aksi takdirde, bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur (TBK m. 472/ III).

TBK m. 472/III'te özel olarak düzenlenen bu bildirim yükümü, yüklenicinin genel özen ve sadakat yükümünün bir uzantısıdır[54].

4. Yüklenicinin özen ve sadakat borcu

a) Genel olarak

Eser sözleşmesinde yüklenicinin genel özen borcunu düzenleyen TBK m. 471/I ve II'ye göre, "Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır (f. I). Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır (f. II)". Eski BK m. 356/ I hükmünde, yüklenici, genel olarak hizmet ilişkisinde işçinin göstereceği özenin aynısını göstermekten sorumludur ifadesi yer almaktaydı. Böylece hizmet sözleşmesinde işçinin özen yükümünü düzenleyen eBK m. 321'e yollama yapılmaktaydı. Bu tür bir düzenleme ve yollamanın yerinde olmadığı ifade edilmekte ve düzenleme eleştirilmekteydi:

Kanun koyucunun bu şekilde bir yollamada bulunmasının isabetli olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira gerek işsahibi ile ilişki, gerek taahhüt edilen edimler açısından bu iki sözleşme ilişkisi arasında

---

[53] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 13; BGE 113 II 422.

[54] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 365, N. 17.

önemli farklılıklar mevcuttur[55]. Yüklenici meslekî açıdan belirli bir uzmanlığa sahip olup, işçi gibi işsahibinin emir ve talimatıyla bağlı değildir. Bu itibarla, yükleniciden, işçiye oranla daha fazla bir özen beklemek gerekir[56].

TBK m. 471/ I ve II hükümlerinde yüklenicinin özen yükümünden borcun belirlenmesinde, yerinde olarak, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışın esas alınması kabul edilmiştir. Böylece yükleniciden beklenecek özenin belirlenmesinde objektif bir ölçünün esas alınması benimsenmiştir.

Yüklenici, benzer işi taahhüt eden bir yükleniciden işlerde geçerli anlayışa göre beklenen her türlü (tam) özeni göstermek zorundadır. Yüklenicinin göstermek zorunda olduğu bu özene "objektif özen" (objektif gebotene Sorgfalt) adı verilmektedir[57].

Yüklenici, yüklendiği eser meydana getirme borcunu yerine getirirken, işin görüldüğü zamanda bilinen teknik kurallara (meselâ, bir inşaat eserinin temelinin atılmasına, inşaatın yapılmasına, malzemenin kullanılmasına veya güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin kurallara) uymak zorundadır[58]. Bilinen teknik kurallar, bilimde teorik olarak doğruluğu kabul edilmiş olan ve ilgili uzmanların çoğunluğu tarafından pratikte uygulanabilir sayılan kurallardır; bu niteliği taşıyan teknik kurallar bilinmiş sayılır. Ancak bu kuralların mutlaka bilimsel olması gerekmez; bunlar pratik (özellikle el sanatlarıyla ilgili) tecrübelerden doğmuş ve ilgili uzman çevrelerinde doğruluğu kabul edilmiş ve başarıyla uygulanmış kurallar şeklinde de olabilir[59]. Bu kuralların hiç kimse tarafından çürütülmeyecek nitelikte veya yazılı olarak tesbit edilmiş olması gerekli değildir[60]. Buna karşılık, bilimin en son düzeyine uygun olmakla beraber, uygulamada başarıyla uygulanmamış kurallar bilinen teknik kural sayılmaz[61].

---

55 **Engel**, sh. 408.

56 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 4; **Pedrazzini**, sh. 19 vd.; **Gauch**, N. 840; **Engel**, sh. 408; **Bühler**, Art. 364, N. 37.

57 **Gauch**, N. 840-841; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 7; **Bühler**, Art. 364, N. 37.

58 **Gauch**, N. 842; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 7 ve 8; BGE 117 II 261.

59 **Gauch**, N. 846; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 8; **Tandoğan** II, sh. 56.

60 **Gauch**, N. 846; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 8; **Tandoğan** II, sh. 56.

61 **Gauch**, N. 848; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 8; **Tandoğan** II, sh. 56.

818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde yüklenicinin işsahibi yararına olan şeyleri yapma ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınma anlamına gelen sadakat borcu, MK m.2'de öngörülen dürüstlük kuralından çıkartılmaktaydı[62]. Hâkim fikre göre[63], özen borcu, yüklenicinin yazılı olmayan sadakat borcunun bir ifadesi olarak kabul edilmekteydi. Bu cümleden olarak, yüklenici, işsahibinin kendisine tevdi ettiği veya işin görülmesi esnasında öğrendiği imalât ve iş sırlarını başkalarına açıklamamak ve korumak zorundaydı[64]. Türk Borçlar Kanununda eser sözleşmesinde yüklenicinin sadakat ve özen borcu açıkça düzenlenmiştir (TBK m. 471). Bu nedenle yorum yoluyla çıkarılan sonuçlar yeni kanun döneminde geçerli olmalıdır.

b) Yüklenicinin göstermek zorunda olduğu başlıca özen yükümleri

Yüklenicinin göstermekle yükümlü olduğu genel özen görevleri TBK m. 472/II (işsahibi tarafından verilen malzemenin özenle kullanılması) ve TBK m. 472/III'te (eserin meydana getirilmesinin tehlikede olması halinde bildirim yükümü) somut olarak düzenlenmiştir. Bunların dışında, kanunla düzenlenmemiş olup, doktrin ve yargı kararlarıyla somutlaştırılmış özen yükümleri de mevcuttur; bazıları sadakat yükümünden çıkartılan bu yükümler şunlardır[65]:

– Kendi gücünü otokritik yoluyla değerlendirme yükümü. Yüklenici kendisinin veya yardımcılarının meslekî bilgisinin, yapımını üstlendiği iş için yeterli olup olmadığını objektif olarak değerlendirmek zorundadır[66].

---

62 **Gauch**, N. 820; **Merz**, SPR VI/1, sh. 63 vd.; BGE 93 II 279. **Gautschi** (Art. 364, N. 1a) ve **Tandoğan**'a göre (C. II, sh. 49), sadakat borcu eser sözleşmesinin bir iş görme akdi niteliği taşımasından çıkar. Ayrıca bk. **Bühler**, Art. 364, N. 29.

63 **Gauch**, N. 820; **Gautschi**, Art. 364, N. 1d; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 25; **Tercier**, N.3547; **Tandoğan** II, sh. 49, dn. 6'ya ait metin; BGE 96 II 61. Olaydan olaya değişen sınırlı bir sadakat yükümünün kabul edilmesi görüşünde: **Bucher**, BT, sh. 206.

64 **Gauch**, N. 820; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 25; **Tandoğan** II, sh. 50; BGE 93 II 272; 77 II 263.

65 **Gauch**, N. 834 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 11 vd; **Tercier**, N. 3458 vd; **Bühler**, Art. 364, N. 17 vd, N. 30 vd.

66 **Gauch**, N. 835; **Engel**, sh. 408; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 20; BGE 93 II 323 vd.

– Aydınlatma ve dikkatini çekme yükümü. Yüklenici, meydana getirilecek eserin tam ve zamanında yerine getirilmesini geciktirecek veya tehlikeye düşürecek, eserin maliyetini önemli ölçüde artıracak olağanüstü durumları derhal işsahibine bildirmekle yükümlüdür (TBK m. 482/I ve m. 480/II)[67]. Aynı şekilde, işsahibinin verdiği talimatlar ve eserin kullanılmasıyla ilgili hususlar hakkında aydınlatıcı bilgiler vermek zorundadır[68].

– İş sahibinin, eserin meydana getirilmesi dolayısıyla edim konusu dışında kalan şahıs ve malvarlığını korumak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak. Bu yüküm özellikle tehlike taşıyan işlerde veya iş vasıtalarında söz konusu olur[69].

c) Özen yükümünün ihlâlinin sonuçları

aa) Genel olarak

Özen yükümünü ihlal etmek suretiyle işsahibinin bir zarara uğramasına sebebiyet veren yüklenici TBK m. 112 vd. ve malzemenin ayıplı olması nedeniyle yüklenicinin işsahibine karşı satıcı gibi kabul edildiği TBK m. 472/I hükümlerine göre sorumlu olur[70]. Aynı şekilde, yüklenici, yardımcılarının veya işi devrettiği alt yüklenicinin zarar verici davranışlarından dolayı TBK m. 116 gereğince sorumlu olur[71].

Eser işsahibine teslim edildikten sonra yüklenici, eserde mevcut ayıplardan ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre (TBK m. 474- 477) sorumlu olur; bunun için, ayıbın özen yükümünün ihlâlinden doğup doğmaması önemli değildir. Bu anlamda olmak üzere, TBK m. 471/I-II'ye göre özen yükümünün ihlâlinden doğan sorumluluk, özel nitelikteki ayıba karşı tekeffül sorumluluğu bünyesine dahil olur, yani onun

---

67 **Gauch**, N. 836; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364. N. 12 ve 16.

68 **Tercier**, N. 3459; BGE 94 II 157.

69 **Gauch**, N. 838; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 18.

70 **Gauch**, N. 853; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 46; **Bühler**, Art. 364, N. 40; BGE 113 II 422, cons. 2b; 111 II 172; Eser sözleşmesinde tarafların karşılıklı güvenleri esastır. Yüklenicinin kendisi temin ettiği halde işsahibi adına satın alınmış gibi fatura düzenleyerek göndermesi gibi güven sarsıcı işlem ve davranışları karşısında sözleşmeyi "geriye etkili sonuç doğurur şekilde" fesih etmesi haklıdır (15. HD. 3.12.2012 tarih E. 2012/2356 K. 2012/7573 –Kazancı-).

71 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 46; **Gauch**, N. 853; **Bühler**, Art. 364, N. 40; BGE 95 II 50.

tarafından absorbe edilmiş (emilmiş) olur[72]. Bununla beraber, ayıbı takip eden zararlardan sorumluluk bakımından özen yükümü önem taşır; bu durumda yüklenicinin kusuru, onun özen yükümüne aykırı davranışından çıkartılır[73].

Buna karşılık, yüklenicinin işin devamı esnasında özen yükümünü ihlâl ederek, eseri ayıplı veya sözleşmeye aykırı şekilde yapacağı anlaşıldığı takdirde, TBK m. 473, işsahibine, eserin tesliminden önce bazı hukukî imkânlar tanımıştır. Bu özel düzenleme aşağıda ayrı bir başlık altında incelenecektir.

bb) TBK m. 473/II'de öngörülen hukukî imkânların kullanılması, özellikle işin başkasına yaptırılması

TBK m. 473/II'ye göre, "Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda bulunabilir".

aaa) Şartları

TBK m. 473/II'nin uygulanabilmesi için aşağıdaki üç şartın gerçekleşmesi gerekir:

a`) Eserin meydana getirilmesi sırasında işin ayıplı veya sözleşmeye aykırı biçimde yapılacağı açıkça anlaşılıyorsa.

Bu fıkrada geçen "eserin meydana getirilmesi sırasında" deyimi, yapımına başlanmış eserin, henüz tamamlanmamış olmasını gerektirmektedir. Bununla beraber, işin yapımına henüz başlanılmadan önce de yapılacak eserin ayıplı olacağı açıkça görülüyorsa, TBK m. 473/II hükmü, lafzına rağmen, uygulanabilir[74]. Meselâ, yapı için elverişli olmayan malzeme işyerinde depo edilmiş olabilir; böyle bir halde işsahibi bu malzemelerin oradan götürülmesini isteyebilir[75]. Yapı İşleri

---

[72] **Gautschi**, Art. 364, N. 5 e; **Gauch**, N. 853; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 47; **Bühler**, Art. 364, N. 40; BGE 111 II 172.

[73] **Gauch**, N. 853 ve 1887; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 364, N. 48; BGE 116 II 455.

[74] **Gauch**, N. 874; **Bühler**, Art. 366, N. 62; **Tandoğan** II sh. 63.

[75] **Tandoğan** II, sh. 63.

Genel Şartnamesi m.16/V bu hususu şu ifadelerle teyit etmektedir: "Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, yapı denetim görevlisinin bu hususta yazılı tebliğinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir".

İşin yapılması esnasında eserde belirli niteliklerin bulunmaması, eser tamamlanınca onun ayıplı olacağını açıkça gösteriyorsa, TBK m. 473/II'nin uygulama şartı gerçekleşmiş olur[76]; bu fıkradaki onarım deyimi bu tür (önceki) ayıplar gözönünde tutularak kullanılmıştır[77].

TBK m. 473/II'de ayıplı imal ve sözleşmeye aykırılık farklı haller olarak öngörülmüştür[78]. Bu fıkra anlamında "sözleşmeye aykırılık", caiz olmayan alt yükleniciye başvurma veya sözleşmeye aykırı imal yöntemleri uygulama şeklinde olabilir[79]. İfada gecikme TBK m. 473/I'de düzenlenmiş olup, TBK 473/II'nin kapsamına girmez.

b`) Ayıplı veya sözleşmeye aykırı imal yüklenicinin kusuruna dayanmalıdır.

TBK m. 473/II'de zikredilen "yüklenicinin kusuru" deyimini, işsahibinin ayıbın doğumunda kendi kusurunun bulunmaması gerektiği şeklinde yorumlamak gerekir. Zira teslim edilen eserin ayıplı olması halinde yüklenicinin sorumluluğu, ayıbı takip eden zarar hariç, kusura dayanmayan bir sorumluluktur ve bunun için işsahibinin kendi kusuruyla ayıba sebep olmaması gerekir (TBK m. 476). Eğer eserin başkasına onartılması için yüklenicinin kusuru aranırsa, işsahibi kendi kusurunun bulunmadığı hallerde, eserin bitirilip teslim edilmesini bek-

---

[76] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 32; **Gauch**, N. 875; **Tandoğan** II, sh. 64.

[77] **Gauch,** N. 875; **Tandoğan** II, sh. 64; İnşaat sözleşmesinde müteahhitin yapıyı sözleşme ve eki projesine aykırı şekilde imal ettiği, bu haliyle yapı kullanım izin belgesi verilemeyeceği, fazla imalatın kamu düzeninden sayılan imar planlarına aykırı olduğu, bu tür imalatın imar kirliliği suçu oluşturduğu, ilgili belediyesince yasal hale getirilemeyeceğine dair görüş verildiği düşünüldüğünde eksik ve kusurlu işler giderim bedeline hükmedilmemesi gerekir (bkz. 23 HD. 19.1.2015 tarih E. 2014/6892 K. 2015/275 –Kazancı-).

[78] **Gauch**, N. 877; **Bühler**, Art. 366, N. 64; **Tandoğan** II, sh. 64.

[79] **Gauch**, N. 877; **Bühler**, Art. 366, N. 64; **Tandoğan** II, sh. 64.

lemek zorunda kalır; bu sonuç TBK m. 473/II'nin amacına ters düşer[80].

c') İş sahibi, yükleniciye işi düzeltmesi için bir süre tayin etmeli veya ettirmeli ve bu süre içinde düzeltme yapılmazsa işin başkasına yaptırılacağı ihtarında bulunmalıdır. Ancak yüklenicinin ayıbı veya sözleşmeye aykırılığı gideremeyeceğinin ilk bakışta anlaşıldığı veya onun, açık veya iradeyi gösteren davranışla, mevcut durumda herhangi bir değişiklik yapmak istemediğini gösterdiği hallerde ihtar gerekli değildir[81].

bbb) Sonuçları

Yukardaki şartların gerçekleşmesi, yani yüklenicinin ayıpsız eser teslim edemiyeceğinin kesin olarak anlaşılması ve yükleniciye verilen sürenin sonuçsuz kalması halinde, işsahibi, hasar ve masrafı yükleniciye ait olmak üzere, onarımı veya işin devamını başkasına tevdi edebilir (TBK m. 473/II). Bunun için, TBK m. 113'den farklı olarak, işsahibinin hâkimden izin almasına gerek yoktur[82]. Bu husus, TBK m. 473/II'nin acele tedbir alınmasını sağlama amacından çıkartılmaktadır[83].

TBK m. 473/II, bu konuda herhangi bir hüküm ihtiva etmemektedir; TBK 113'ün kıyasen uygulanması suretiyle bu sonuca varılmaktadır[84]. Bunun için, işsahibinin onarım veya işe devam edebilecek yetenek ve imkânlara sahip olması gerekir[85].

TBK m. 473/II anlamında işin başkasına yaptırılması veya ayıbın başkası tarafından giderilmesi olgusu, işsahibinin varması gereken bir irade beyanıyla gerçekleşir. Bu beyan, söz konusu hükmün öngördüğü uygun sürenin belirlenmesi anında veya sürenin bitiminde yapılabilir. Böylece, yüklenicinin eser meydana getirme edimi, ikame ifanın masraflarını ve gerektiğinde tazminat ödeme borcuna dönüşür; işsahibinin

---

80 **Gauch**, N. 880; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 35; **Tandoğan** II, sh. 64. Farklı görüşte olan **Bühler**'e göre (Art. 366, N. 65) buradaki kusur ayıba değil, sözleşmeye aykırılık haline ilişkindir.

81 **CR-Chaix**, CO art 366, n. 34; **Tercier/Favre**, N. 4451; Federal Mahkeme 4C. 77/2005, 20.04.2005, cons. 4.

82 **Gauch**, N. 887; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 37; **Tandoğan** II, sh. 65.

83 **Gauch**, N. 887; **Tandoğan** II, sh. 65.

84 **Gauch**, N. 891; **Zindel/Pulver**, Art 366, N. 38; **CR-Chaix**, CO, art. 366, N. 36.

85 **Gauch**, N. 891.

eser sözleşmesinden bedel ödeme borcu varlığını korur. Taraflar, karşılıklı borçlarını şartları varsa takasla sona erdirilebilirler[86].

İş sahibinin işin yapımı sırasında gördüğü ayıpları yükleniciye tamir ettirebileceği veya gerektiğinde işi, üçüncü kişiye yaptırabileceği hususları, Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 16/VI, m. 26/I-IV ve m. 16/VI'deki hükümlerde ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. YİGŞ m. 16/VI'ya göre:

"Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir". Aynı şekilde, YİGŞ m. 26/I-IV'e göre; "Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksikliklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yaptırabilir. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.

İdare, yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemleri-

---

[86] Bk. **Gauch**, N. 868 vd; **Koller**, Berner K., Art. 366, N. 465-473, 547 vd ve 615; **Niklaus**, sh. 111 vd; BGE 126 III sh. 233, cons. 7a,aa.

ni uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.

Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkânı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunmaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz.

Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27'nci maddesi hükümleri uygulanır."

Keza YİGŞ m. 42/VI'da benzer bir hüküm yer almaktadır:

"Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksikleri giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması davam eder ve kabul tarihi ertelenir."

TBK m. 473/II'de öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde, işsahibinin yükleniciye karşı başka hukukî imkânlara, özellikle sözleşmeden dönme veya fesih hakkına sahip olmadığı konusunda bu fıkra metninde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus doktrinde tartışmalıdır.

Gauch'a göre[87], işsahibine, TBK m. 125'de öngörülen seçimlik hakları, tartışmasız bir şekilde bahşeden TBK m. 473/I ile m. 473/II farklı hususları düzenlemektedir. Bu itibarla, işsahibi, ikame ifa veya

[87] **Gauch**, N. 867, 869 ve 893. Ayrıca bk. **Engel**, PS, sh. 443 vd.

işin başkasına yaptırılması yoluna başvurabilecek durumda ise, sözleşmeden dönemez; buna karşılık, o yüklenicinin eser meydana getirme edimini şahsen ifa etmekle yükümlü bulunduğu ve bu nedenle onun yerine başkasının ikame edilemeyeceği veya somut olayın özellikleri sebebiyle yüklenicinin değiştirilmesinin beklenebileceği hallerde, işsahibi, TBK m. 473/I'in kıyasen uygulanması suretiyle, sözleşmeden dönebilir. *Zindel/Pulver*[88] de bu görüşe katılmaktadır.

Buna karşılık, doktrinde hâkim görüş[89], TBK m. 473/II'nin uygulanma şartlarının gerçekleşmesi halinde, işsahibinin TBK m. 125'de öngörülen seçim haklarına sahip olacağını kabul etmektedir. Bu görüş tarafları, aralarında bazı gerekçelendirme farkları bulunmakla beraber, esas itibariyle, işin görülmesi sırasında ortaya çıkan ayıpların (TBK m. 358/II), müdeahhidin ifada gecikmesinden daha ağır şartlara tâbi tutulması için haklı bir sebep bulunmadığını ifade etmektedirler. Türk hukukunda *Tandoğan* da, haklı olarak, bu görüşü şu ifadelerle savunmaktadır: "Borçlunun temerrüdünde feshe ilişkin BK m. 106-108 (TBK m. 123-125) kıyas yoluyla diğer sözleşmeye aykırılık hallerinde de uygulanabilmelidir; başka bir deyimle, yüklenici verilen mehil içinde gereken düzeltmeyi yapmaz veya imalatı sözleşmeye uygun biçimde yapmaya girişmezse, işsahibi işi başkasına yaptırmak yerine fesih yolunu tercih edebilmelidir"[90]. İsviçre Federal Mahkemesi[91] bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldığı 28 Mart 2000 tarihli kararında çoğunluk görüşüne uygun biçimde karar vermiştir.

Federal Mahkemenin de belirttiği gibi[92] gerek zamanında ifa, gerek ayıpsız veya sözleşmeye uygun ifa, eser meydana getirme borcunun içinde değerlendirilmelidir.

Diğer taraftan, işsahibi aynen ifadan vazgeçip müsbet zararın tazminini de talep edebilir[93]. İş sahibinin irade beyanı neyin seçildiği konusunda belirleyici olacaktır.

---

88 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 41.

89 **Koller**, Berner K, Art. 366, N. 477 vd; **Niklaus**, sh. 42, N. 1. 98; **Corboz**, FjS N. 460, sh. 11; Bucher, BT, sh. 214; **Gautschi**, Art. 366, N. 7d, **Honsell**, 7. Auf, sh. 277, **Pally**, Mangelfolgeschaden, sh. 24 vd.; **Weber**, Art. 98, N. 62; **Tercier/ Favre**, N. 4455.

90 **Tandoğan** II, sh. 63.

91 BGE 126 III 230, 234 vd.

92 BGE 126 III 234-235, cons. 7a,bb. Ayrıca bk. **Niklaus**, sh. 42, N. 1.98.

93 **Koller**, Art. 366, N. 603 vd; **Niklaus**, sh. 164 vd, N. 4, 24 vd, BGE 126 III, sh. 236.

Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında[94] da TBK m. 473/II çerçevesinde ayıbın giderilmesi veya işin tamamlanmasının üçüncü kişiye bırakılması dışında yükleniciye sözleşmeden dönme hakkı (TBK m. 125) tanınmaktadır.

5. İşe zamanında başlama ve devam borcu

TBK m. 473/I'e göre, "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir". Kanun koyucu bu hükümle, eser akdinde bir aynî (maddî) edim yükümü olan teslimle beraber, eser meydana getirme unsuruna ait işgörme ediminin mevcut olduğunu dolaylı olarak ifade etmiş; bunun sonucu olarak işsahibine teslimden önceki gecikme sebebiyle erken dönme hakkı tanımıştır[95]. Bu itibarla, TBK m. 473/I işin icrasında temerrüdü düzenlemektedir[96].

---

[94] Yarg. 15. HD. 11.4.1990 T. ve E. 3936/K. 1735 "Bu durumda işsahibinin BK m. 358'e dayanarak inşaatın sağlamlaştırılmasını istemeye hakkı vardır. Yapılan ayıp ihbarına ve verilen mehile rağmen, davalının takviye işlerini kesinlikle reddettiği görülmektedir. Bu durumda, davacının BK m. 358'deki koşulları yerine getirmiş ve ihtar semeresiz kalmış olmakla, akdi feshetmeye haklı olduğunun kabulü gerekir. Tarafların vecibelerini yerine getirirken kendilerinden beklenmesi gereken tüm dikkat ve özeni göstermeleri gerekir... İşin başında taşıyıcı sistemleri çürük imal eden, projeyi tasdik ettirmeyen, Proje dışı işler yapan (iskân izninin alınmasına engel olacak biçimde yüklenicile arsa sahibi arasında güven duygusunun yok olacağı açıktır. Hele ayıplı işleri tamamlamayı reddeden bir kişiyle sözleşmeyi devama davacıyı zorlamak, hakkaniyet kurallarına ve hayatın olağan akışına ters düşer. O halde akdin feshine karar vermek gerekir" (Uygur, C.7, sh. 7817-7818). 15. HD. 30.05.1996 T. ve E.1303/K. 3035: "O halde, davalının BK'nun sağladığı sonuçlardan yararlanmak üzere, aynı yasanın 358/II. maddesi uyarınca akdi feshedebileceğine ve oluşa göre de davacıya verilecek bir mehilden de sonuç alınamayacağının (BK. m. 107) anlaşılmış bulunmasına göre davalının fesihte haklı olduğunun kabulü gerekir" (Uygur, C.7, sh. 7819-7820). Aynı yönde: 15. HD. 1.2.2006 T. ve E.6210/K.397; 15. HD. 17.9.2007 T. ve E. 4320/K. 5351; 15. HD. 17.09.2007 T. ve E. 1704/K. 5393.

[95] **Gautschi**, Art. 366, N. 1 d; **Gauch**, N. 668; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 1; **Tandoğan** II, sh. 113.

[96] **Gauch**, N. 669; **Chavanne**, sh. 54 vd.; **Lemp**, sh. 88 vd.

a) Dönme hakkının şartları

İş sahibinin, TBK m. 473/I uyarınca sözleşmeden dönebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

aa) İşe zamanında başlamama

Yüklenicinin işin icrasına başlama zamanı sözleşmeyle tayin edilmiş olabilir. İşe başlama zamanının sözleşmeyle belirlenmediği veya işin niteliğinden anlaşılmadığı takdirde, yüklenici TBK m. 90 gereğince sözleşmenin kurulmasından sonra hemen işe başlamak zorundadır. Şüphesiz yükleniciye gerekli ve mutad bir hazırlık zamanı tanımak gerekir[97].

bb) İşin icrasının sözleşmeye aykırı olarak geciktirilmesi

Bu durum, yüklenicinin sözleşmeyle öngörülen iş programına uymaması, ara vadeleri geçirmesi veya yeterli iş gücü ile araç ve gereçleri sağlamaması halinde söz konusu olur[98].

cc) Gecikmenin eserin kararlaştırılan tarihte tamamlanmasına engel olacak derecede olması

Bu şartın gerçekleşmesi için, gecikmeden sonra kalan sürenin eserin vadesinde teslimi için yeterli olmaması, yani gecikmenin kaçınılmaz olması gerekir[99]. Bu şart yukarıda açıklanan her iki gecikme halleri için gereklidir.

dd) Yüklenicinin gecikmesini haklı kılan bir sebebin bulunmaması

İşin gecikmesini haklı gösteren bir sebebin bulunmaması veya gecikme sebebinin işsahibinin riziko alanına dahil olmaması şartı, TBK m. 473/I'in uygulanmasında önemli bir yer işgal eder.

---

97 **Gauch**, N. 674; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 3; **Weber**, Art. 75, N. 80, 93; **Pedrazzini**, sh. 18, dn. 1.

98 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 10; **Gauch**, N. 670.

99 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 11; **Gauch**, N. 674; Dava üç adet villanın eksik ve kusurlu iş bedeli yanında kiranın tazmini ile inşaatına başlanılmamış olan taşınmaz yönünden sözleşmenin feshine ilişkindir. Sözleşmede inşaat ruhsatı alınması ve işe başlanması için belirli bir vade kararlaştırılmamıştır. Yüklenicinin işe başlaması için bir bildirimde yapılmamıştır. Bu nedenle TBK m. 473 uyarınca işsahibinin erken fesih istemesi mümkün değildir (23. HD. 21.6.2013 tarih E. 2013/1452 K. 2013/4306 –Kazancı-).

İsviçre-Türk hukukunda temerrüt için kusur şart olmamakla beraber, ifa etmemenin borca aykırı bir davranış olması gerekir[100]. Yüklenicinin ediminin objektif olarak imkânsızlaşması veya onun TBK m. 97- 98'e dayanarak işi yerine getirmekten kaçınabildiği hallerde bu şart gerçekleşmemiş olur[101]. Aynı şekilde, işsahibinin alacaklı sıfatıyla gerekli hazırlık ve işbirliği fiillerini yerine getirmemesi (meselâ, inşaat alanını teslim etmemesi, gerekli talimatları vermemesi), haklı gecikme sebebi veya onun riziko alanına giren bir sebep olarak, temerrüdü önler[102].

Temerrüdün diğer şartları bakımından eksik olan TBK m. 473/I hükmünün, TBK m. 117- 125 hükümleriyle tamamlanması gerekir. Bu cümleden olarak, temerrüt için gerekli olan hallerde ihtar çekilmesi ve verilen uygun mehilden sonra dönme beyanının, bu mehilin bitiminde derhal yükleniciye bildirilmesi gerekir[103].

b) Dönmenin sonuçları

Yukarda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, işsahibi, teslim tarihini beklemeden sözleşmeden dönebilir. İş sahibinin sözleşmeden dönmesi, esas itibariyle TBK m. 125'de öngörülen genel hükümlere uygun sonuçlar doğurur. Dönme ile sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar; işsahibi bedel ödemeyi reddedebilir ve daha önce ödediği bedelin iadesini isteyebilir; eserin daha önce yerine getirilmiş kısmını iade eder[104].

Son zamanlarda savunulan ve doğru olan anlayışa göre, daha önce icrasına başlanan işlerde, işsahibi sözleşmeyi ileriye etkili olarak sona erdirme yolunu seçebilir. Bu takdirde, eserin daha önce meydana getirilmiş kısmını, bedelini ödemek suretiyle isteyebilir[105]. İş sahibi, yukarda açıklanan bütün şartların gerçekleşmesi halinde sözleşmenin

---

100 **Schenker**, N. 57 ve 67; **Gauch/Schluep/Jäggi**, N. 1475; **Eren**, C. III, sh. 273; **Gauch**, N. 676.

101 **Gauch**, N. 676-677; **Tandoğan** II, sh. 115; **Eren**, C. III, sh. 273.

102 **Gauch**, N. 678; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 12; **Becker**, Art. 366, N. 3; **Tandoğan** II, sh. 115-116.

103 **Gauch**, N. 675; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 13 ve 25; BGE 115 II 55, cons. 2 a; 98 II 115, Erw. 2. Ayrıca bk. **Uygur**, C. 5, sh. 853 vd.ndaki Yargıtay kararları.

104 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 20; **Gauch**, N. 683; BGE 115 II 55.

105 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 21; **Gauch**, N. 685 vd.; BGE 116 II 452 vd.

(geriye veya ileriye etkili olarak) sona erdirilmesinin yanında, TBK m. 125'de öngörülen diğer iki imkânı da kullanabilir[106].

Buna karşılık, işsahibinin TBK m. 473/I'e dayanarak sözleşmeden dönmesinin haksız olması halinde, işsahibi yükleniciye TBK m. 484'de öngörülen tam tazminatı ödemek, yani onun müsbet zararını tazmin etmek zorundadır[107].

II. Eseri teslim borcu

1. Genel olarak

Yüklenici eseri meydana getirmekle borcunu tam olarak ifa etmiş olmaz; bundan başka, eseri işsahibine teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin bu teslim borcu Borçlar Kanunu'nda açıkça düzenlenmemiş olmakla beraber, bazı maddelerde (TBK m. 473/I, 474/I, 475/I, 478/I ve 479/I) zikredilmiştir.

Teslim, tamamlanmış eserin işsahibine ifa olarak arzedilmesidir. Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmadıkça, işsahibi, eserin sadece bir kısmını kabul etmek zorunda değildir. Eserin tamamlanması, kararlaştırılan işlerin tamamen yapılmasıyla gerçekleşir[108]. İş sahibine ifa olarak arzedilen eserin ayıplı olması, bu anlamda teslime engel değildir; eserin ayıpsız olması, onun teslim edilmesinin ve teslim alınmasının şartını teşkil etmez[109]. Yüklenicinin teslim borcunun karşıtını, işsahibinin teslim alma borcu teşkil eder. İş sahibi, eseri teslim almaktan kaçınırsa, alacaklının temerrüdüne düşmüş olur. Buradaki teslim almayı, TBK m. 477'de öngörülen "kabul" den ayırmak gerekir; kabul, eserin ayıpsız ve sözleşmeye uygun olduğunu açıklayan işsahibinin irade beyanıdır[110].

Teslim borcu, taşınırlarda eserin ifa amacıyla işsahibinin fiilen hâkimiyet alanına madden geçirilmesini ve onun doğrudan doğruya zilyet kılınmasını ifade eder[111]. Eserin bu şekilde teslimi götürülecek,

---

[106] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 24; **Gauch**, N. 675; **Becker**, Art. 366, N. 4.

[107] **Merz**, ZBJV 1974, sh. 62; **Honsell**, sh. 248; **Mosimann**, sh. 136; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 2 ve 8; **Tercier**, N. 3778; **Corboz**, FJS,sh. 8; **Tandoğan** II, sh. 346; BGE 98 II 115.

[108] **Gauch**, N. 87 ve 101; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 3; **Tercier**, N. 3442; **Bühler**, Art. 367, N. 7; BGE 118 II 49; 115 II 458.

[109] **Gauch**, N. 106; **Tercier**, N. 3444.

[110] **Tercier**, N. 3441.

[111] **Gauch**, N. 88; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 4.

gönderilecek veya aranılacak bir borcun konusunu teşkil edebilir. Eseri teslim borcunun ifa edileceği yer, tarafların açık veya zımnî irade beyanıyla belirlenmemişse (TBK m. 89), aranılacak borç sayılır (TBK m. 89/b. 2 ve 3)[112]. İş sahibine ait arsa üzerinde gerçekleştirilen yapı işlerinde eserin madden teslimi, yüklenicinin eserin tamamlandığını işsahibine bildirmesiyle gerçekleşir; bu bildirme açık veya zımnî irade beyanıyla yapılabilir[113]. Maddî olmayan iş görme sonuçlarında, eserin üzerinde devamlı olarak biçimlendiği şeyin verilmesiyle teslim borcu gerçekleşmiş olur[114].

Eser sözleşmesinde eserin teslim anı aşağıdaki hususlarda pratik sonuçlar doğurur.

Bu andan itibaren;

– Yarar ve hasar işsahibine geçer (TBK m. 483),

– Ayıba karşı tekeffülde inceleme ve bildirim süreleri işlemeye başlar (TBK m. 474/I),

– Ayıba karşı tekeffülden doğan davaların tâbi olduğu zamanaşımı süreleri işlemeye başlar (TBK m. 478),

– Yüklenicinin ücret alacağı muaccel olur (TBK m. 479).

2. Teslim borcunun ifa zamanı

Genellikle taraflar teslim borcunun ifa zamanını sözleşmeyle belirlerler; taraflar bu tarihi, belirli bir takvim günü göstererek veya belirli bir süre tayin edip bu sürenin dolduğu tarihte eserin teslim edileceğini öngörerek (meselâ, sözleşmenin imzalandığı veya işin yapılacağı yerin teslim edildiği tarihten itibaren on ay içinde) tesbit edebilirler. Bu şekilde teslim tarihinin yanlış anlamaya meydan vermeyecek tarzda tesbit edilmesi halinde, TBK m. 117/II anlamında borcun ifa edileceği günün "birlikte belirlenmiş" olması söz konusu olur[115]. Teslim tarihi anlaşmayla belirlenmemiş ise, sözleşmedeki bu boşluğun işin niteliğine göre (TBK m. 90) ve tarafların varsayılan iradesine dayanarak doldurulması gerekir; bunu yaparken, deneyimli bir uzmanın zamanında

---

[112] **Gauch**, N. 89; **Tercier**, N. 3452.

[113] **Gauch**, N. 92; BGE 115 II 459; 113 II 267; Eser sözleşmesinde teslim maddi vakıa niteliğinde olduğundan tanıkla ispatı mümkündür (15. HD. 28.3.2014 tarih E. 2013/6053 K. 2014/2925 –Kazancı-.

[114] **Gauch**, N. 90; **Tandoğan** II, sh. 125.

[115] **Gauch**, N. 647; **Tandoğan** II, sh. 128.

başladığı işi mutad araç ve gereçleri ve iş gücünü kullanarak harcayacağı zaman göz önünde tutulur[116].

3. Mülkiyetin işsahibine geçirilmesi

Yüklenici, meydana getirdiği eserin mülkiyetini işsahibine geçirmek zorundadır. Eser sözleşmesi mülkiyetin geçirilmesinin hukukî sebebini teşkil eder; mülkiyetin geçirilmesi eşya hukukunda öngörülen kurallara uygun olarak gerçekleşir[117].

4. Teslim borcunu ifada temerrüt ve bunun sonuçları

Yüklenici borçlandığı eserin tesliminde temerrüde düştüğü takdirde, temerrüdün şartlarına ve sonuçlarına TBK m. 117-125 hükümleri uygulanır[118].

a) Teslim borcunu ifada temerrüdün şartları

Yüklenicinin eseri teslim borcunu ifada temerrüde düşmesi için, onun teslim tarihinin gelmesine rağmen, eseri yükümlülüğüne objektif olarak aykırı şekilde (objektiv Pflichtwidrig) henüz tamamlamamış veya tamamlanmış eseri henüz teslim etmemiş olması gerekir[119]. Temerrüdün gerçekleşmesi için yüklenicinin gecikmede kusurlu olması şart değildir; gecikmenin onun objektif olarak yükümlülüğüne aykırı olması gerekir. Yüklenicinin geciktirici def'ileri (TBK m. 97 ve 98) ileri sürmesi, işsahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi veya gecikmenin işsahibine yüklenebilen sebeplerden ileri gelmesi hallerinde yükümlülüğe aykırı bir gecikme söz konusu olmaz[120]. Böyle bir haklı gecikme halinde, eserin meydana getirilmesi henüz mümkünse, teslim süresi tarafların varsayılan iradesine dayanarak haklı gecikme süresi kadar uzatılmış olur; meğer ki sözleşmede aksine bir hüküm bulunsun[121].

Yüklenicinin temerrüde düşmesi için, işsahibinin ona teslim borcunu yerine getirmesi için ihtarda bulunması gerekir; teslim tarihi sözleşmede taraflarca "birlikte belirlenmiş" ise (TBK m. 117/II) veya ih-

---

116 **Gauch**, N. 649; **Tandoğan** II, sh. 129; BGE 113 II 517.

117 **Tercier**, N. 3456.

118 **Gauch**, N. 659; **Tercier**, N. 3467 vd; BGE 116 II 452.

119 **Gauch**, N. 659; **Tandoğan**, II, sh. 130.

120 **Gauch**, N. 676 vd; **Tandoğan** II, sh. 131.

121 **Gauch**, N. 682; **Gautschi**, Art. 366, N. 4 d; **Chavanne**, sh. 144; **Tandoğan** II, sh. 131.

tarın faydasız olacağı önceden anlaşılıyorsa (BK m. 124/b. 1'e kıyasen), yüklenici ihtara gerek olmadan temerrüde düşer[122].

b) Teslim borcunu ifada temerrüdün sonuçları

aa) Genel olarak

Temerrüde düşen yüklenici, TBK m. 119/I gereğince gecikmeden dolayı tazminat ödemek zorunda olduğu gibi, edimin umulmayan halden dolayı (kazara) imkânsız hale gelmesinden de sorumlu olur. Buradaki umulmayan halden sorumluluk esası, TBK 480/II anlamında olağanüstü durumların ortaya çıkması, teslimden önce eserin kaza sonucu telef olması veya ayıplı duruma girmesi hallerinde de uygulanır[123].

Gecikme tazminatının kapsamına fiilî zarar ve yoksun kalınan kâr kalemleri girer. Bu cümleden olarak, işsahibi, kredi faizlerinin artması, üretim veya kira kaybı sebebiyle yaptığı fazla masrafları veyahut üçüncü kişilere ödediği tazminat veya cezaî şartın tazminini isteyebilir[124].

bb) Aynen ifadan vazgeçip müsbet zararın tazmini

İş sahibi uygun bir mehil verip, bu mehlin sonunda teslim borcu yerine getirilmezse, aynen ifadan vazgeçip müsbet zararının tazminini talep edebilir.

Müsbet zararının tazminini isteyen işsahibi, TBK m. 486/son c. hükmünün kıyasen uygulanması sonucu, eserin kullanılması kabil kısmını kabul etmek ve bu kısmın bedelini ödemek zorundadır[125].

cc) Sözleşmeden dönme

Yüklenicinin teslim borcunu yerine getirmede temerrüde düşmesi halinde, işsahibi verilen sürenin sonunda derhal bildirmek suretiyle, sözleşmeden dönebilir ve menfî zararının tazminini isteyebilir (TBK m. 123-125).

Bu durumda, işsahibinin dönme beyanı üzerine sözleşme, kural olarak, geçmişe etkili olarak (ex tunc) sona erer[126]. Bununla beraber, bu kuralın bazı eser sözleşmelerinde sınırlandırılması gerekir. Bu

---

122 **Gauch**, N. 659; **Tandoğan** II, sh. 131-132.

123 **Gauch**, N. 661; **Tandoğan** II, sh. 132.

124 **Gauch**, N. 665; **Tandoğan** II, sh. 134.

125 **Gauch**, N. 662; **Tandoğan** II, sh. 140.

126 **Gauch**, N. 683; **Bühler**, Art. 366, N. 48; BGE 116 II 452.

cümleden olarak, dönme anında işin bir kısmı yapılmış bulunuyorsa işsahibi, işin yapılan kısmını alıkoymak ve bu kısmın bedelini ödemek suretiyle, sözleşmeyi ileriye etkili olarak (ex nunc) sona erdirebilir. Böylece yüklenici eserin yapılmayan kısmını tamamlamak, işsahibi de bu kısmın bedelini ödemek suretiyle yükümlerinden kurtulurlar[127]. Bu şekilde sözleşmenin ileriye etkili olarak sona erdirilmesi halinde, eserin yapılan kısmı işsahibi için kullanılabilir ise, işsahibi yüklenicinin eseri teslimde temerrüde düşmesinden zarar görmeyebilir. Aynı şekilde, eser işsahibinin arsası üzerinde veya onun malzemesiyle yapılmışsa veyahut eser önemli ölçüde tamamlanmışsa, sözleşmenin ileriye etkili sona erdirilmesi yüklenicinin de yararınadır[128]. Bu durumda dönmenin feshe dönüşmesi veya dönmenin fesih olarak değerlendirmesi söz konusudur[129].

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 25.1.1984 tarih ve E.3/K.1 sayılı kararında[130] şu sonuca varılmıştır:

"Şayet olayın niteliği (yüklenicinin yapının tamamladığı kısmının kapsamı ve özelliği) uyuşmazlığın yalnızca BK m. 106-108. maddeleri uyarınca çözümlenmesini gerektiriyorsa, sözleşmenin feshinin bu hükümlerde öngörülen hukukî sonuçları doğuracağı tabiidir. Artık bu durumda, inşaat sözleşmesinin yüklenicinin edim borcu yönünden özelliği de sonucu etkilemez.

Ancak olayın niteliği ve özelliğinin (uyuşmazlığa 106-108. maddeler hükümlerinin uygulanmasının doğuracağı adalete aykırı sonuçlarının) haklı gösterdiği durumlarda, Medeni Kanunun 2. maddesi hükmü gözetilerek, sözleşmenin feshinin (sürekli borç ilişkilerinde olduğu gibi) ileriye etkili sonuç doğuracağı kabul edilmelidir. Böyle bir çözümün sonucu olarak da, mütemerrit yüklenici, kısmî ifasının bedelini işsahibinden ve işsahibi de, yüklenicinin kusuruna bağlı tüm zararlarını yükleniciden talep edebilecekler ve bu suretle tarafların yararları arasında karşılıklı bir denge kurulmuş olacaktır.

---

127 **Gauch**, N. 685-686; **Bühler**, Art. 366, N. 48; BGE 116 II 452.

128 **Gauch**, N. 682; **Bühler**, Art. 366, N. 49; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 23; **Sungurbey**, Medeni Hukuk Sorunları, C. 4, sh. 466 vd.

129 **Gauch**, N. 686 ve 688; **Bühler**, Art. 366, N. 49; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 366, N. 22; **Chavanne**, sh. 84, dn. 208'e ait metin; **Sungurbey**, C.4, sh. 466 vd.

130 RG. 27.2.1984, Nr. 18325.

Sonuç: Eser sözleşmelerinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin kendi kusuruyla işi muayyen zamanda bitirmeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmenin işsahibi tarafından feshi halinde, uyuşmazlığın kural olarak Borçlar Kanununun 106-108. maddeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekeceğine, ancak olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda, Medeni Kanunun 2. maddesi hükmü gözetilerek, sözleşmenin feshinin ileriye etkili sonuç doğuracağına.... çoğunlukla karar verildi".

c) İfa zamanına uyulmaması halinde cezaî şart ödenmesinin kararlaştırılması

Eserin teslim tarihi işsahibi için büyük önem taşıyabileceğinden, genellikle ifa zamanına uyulmaması halinde ödenmek üzere bir cezaî şart kararlaştırılmaktadır (TBK m. 179/II). Bu şekilde cezaî şart anlaşmasında, yüklenici borçlandığı edimi öngörülen tarihte ifa etmediği takdirde, işsahibine belirli bir para ödemeyi veya başka bir edimde bulunmayı taahhüt etmektedir[131]. Erken teslim halinde, yükleniciye prim ödenmesi kararlaştırılmasa dahi, geçerli olarak cezaî şart taahhüdünde bulunmak mümkündür[132].

Yüklenicinin ödemeyi taahhüt ettiği cezaî şart, buna ilişkin anlaşmada belirli bir miktarda para veya gecikmenin devamına bağlı olarak (meselâ aylık, haftalık veya günlük belirli bir miktar şeklinde) tesbit edilebilir[133]. Gecikme süresine bağlı olarak tesbitte taraflar cezaî şartın azamî miktarını tesbit etmemeleri halinde, işsahibinin uzun süre seçimlik hakkını (TBK m. 123-125) kullanmaması sonucu cezaî şart tutarı çok yüksek miktarlara ulaşacaktır. Bu ihtimalde davalı yüklenici tacir olduğu için fahiş cezaî şartın indirilmesi de söz konusu olamamaktadır (TTK m. 22). Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 1991'den önceki kararlarında[134], seçimlik haklarını uzun süre kullanmayan işsahibinin cezaî şart talebinin TBK m. 52 ve MK m.2 uyarınca tamamen karşılanamayacağı, işin tamamlanması için gerekli olan süre kadar cezaî şart ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

---

131 **Gauch**, N. 692; **Bühler**, Vertragsrecht, sh. 149; **Tandoğan** II, sh. 135.

132 **Gauch**, N. 692; **Tandoğan** II, sh. 135.

133 **Gauch**, N. 693; **Tandoğan** II, sh. 135.

134 **Karahasan**, İnşaat, İmar ve İhale, C.1, sh. 588 vd.ndaki kararlar; **Uygur**, İnşaat, C.2, sh. 349'da zikredilen 15. HD'nin 29.6.1988 tarihli kararı.

Buna karşılık, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun içtihadı tamamen aksi yöndedir: "Davalı, işin süresinde teslim edilmemesi halinde davacıya verilecek her daire için aylık 300.000 lira ödeyeceğini kabul etmiştir. Bu, BK m. 158/II maddesinde belirtilen bir cezaî şart niteliğindedir. BK.nun m. 161/3. maddesi gereğince cezaî şartın, "fahiş olduğu gerekçesi ile tenkisi" gerekeceği düşünülebilir. Ancak davalılar tacir olduğundan böyle bir indirim söz konusu olamaz (TK m. 24). Özen borcuna aykırı davranarak kusurlu durumunda bulunan davalı yüklenici teslim gününden itibaren işleyecek cezaî şartı ödemek zorundadır (Tandoğan, Borçlar, sh. 133-135). Kaldı ki davacının geç teslim süresince en az kabul edilen cezaî şart kadar zarara uğradığı da bir olgudur. Bu nedenle de davacı hiçbir indirime tabi tutulmadan gerçek zararını isteyebilecek durumdadır (BK m. 159/II)"[135]. Bu kararın gerekçesinde TBK m. 52 ve MK m.2'nin olaya uygulanamıyacağı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde, 15. HD, bu tarihten sonra verdiği kararlarda[136] bu sonucu benimsemiş ve eski içtihadından dönmüştür.

Cezaî şartın işlemeye başlamasının yüklenicinin temerrüde düşmesine bağlı olup olmadığı cezaî şart anlaşmasının muhtevasına göre belirlenir; bu muhtevanın yorumundan kesin bir sonuç çıkartılamadığı takdirde, cezaî şartın temerrüde bağlı olduğu kabul edilmelidir[137].

Aksine anlaşma yoksa, yüklenici gecikmede kusurunun bulunmadığını isbat ederse, cezaî şart ödemekten kurtulur; TBK m. 182/II'nin kıyasen uygulanması suretiyle bu sonuca varılır[138].

TBK m. 179/II gereğince, işsahibi ifada geciken yükleniciden hem sözleşmenin ifasını, hem cezaî şartın ödenmesini talep edebilir; işsahibi cezaî şart isteme hakkını saklı tutmadan eseri teslim alırsa cezaî şartı talep hakkını kaybeder (TBK m. 179/II); saklı tutma beyanının en geç eserin teslimi anına kadar yapılması gerekir.

İş sahibi sözleşmeden döndüğü takdirde, cezaî şartın ödenmesini talep edemez[139]; buna karşılık fesih halinde, fesih anına kadar gerçekleşen cezaî şart talep edilebilir.

---

135 HGK, 9.10.1991, E. 15-340/K. 467 (**Uygur**, İnşaat, C.2, sh. 347-348).

136 15. HD, 13.3.1996, E. 665/K. 1346 (**Uygur**, İnşaat, C.2, sh. 390-391).

137 **Gauch**, N. 696; **Bucher**, AT, sh. 526.

138 **Gauch**, N. 697; **Bucher**, AT, sh. 526; **Tandoğan** II, sh. 135.

139 15. HD, 5.2.1992, E. 4877/K. 428 (**Uygur**, İnşaat, C.2, sh. 376-377); 15. HD, 14.2.1996, E. 463/K. 821 (**Uygur**, İnşaat, C. II, sh. 393)

Temerrüdün sonuçları bakımından TBK m. 118-125 uygulanır.

III. Yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu

Eser sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluk borcu TBK m. 474-478'de düzenlenmiş bulunmaktadır.

1. Ayıptan doğan sorumluluğun şartları

a) Ayıplı bir eser teslim edilmiş olmalıdır

Eser sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan dolayı sorumlu olabilmesi için eserin tamamlanarak işsahibine teslim edilmiş olması gerekir. Zira ayıplı eser, aynı zamanda ayıplı bir iş görme sonucudur[140].

Ayıp, eserin sözleşmeyle taahhüt edilen veya dürüstlük kuralı gereğince kendisinden beklenen vasıfları taşımamasıdır. Başka bir ifadeyle, ayıp, eserde sözleşme veya dürüstlük kuralına göre olması gereken vasıfla fiilen mevcut vasıf arasındaki farktır[141]. TBK m. 475'de yer alan "ayıp veya sözleşme şartlarına aykırılık" ayırımı hukuken önem taşımadığı gibi, ayıp kavramının birliğini de zedelemez, tek ve aynı kavramı ifade eder[142].

b) Ayıp işsahibine yüklenmemelidir

aa) Genel olarak

Yüklenicinin ayıptan dolayı sorumlu olabilmesi için eserdeki ayıbın işsahibine yüklenmemesi gerekir. Gerçekten, TBK m. 476'ya göre, "Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, işsahibinin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa işsahibi, eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz".

Satış sözleşmesinde mevcut olmayan TBK m. 476 hükmü, işsahibinin eserin meydana gelmesinde aktif bir rol oynadığı düşüncesine da-

---

[140] **Gauch**, N. 1359; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 2; **Tandoğan** II, sh. 160; **Pedrazzini**, sh. 28 vd; **Tercier**, N. 3497; BGE 117 II 263.

[141] **Gauch**, N. 1352 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 9; **Tercier**, N. 3489; **Klauser**, sh. 23; **Gautschi**, Art. 367, N. 14 c; **Honsell**, sh. 250-251; **Tandoğan** II, sh. 161 vd; BGE 117 II 259 vd; 114 II 214.

[142] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 10; **Tercier**, N. 3490; **Honsell**, sh. 250; BGE 100 II 32. Karş. **Gauch**, N. 1355.

yanmaktadır; zira eser sözleşmesinde, kural olarak plân ve projeleri temin eden, talimat veren ve bazen malzemeleri sağlayan işsahibidir[143].

TBK m. 476 hükmüne temel teşkil eden düşünce, TBK m. 52/I'inki ile aynıdır: İş sahibinin sorumlu olduğu durumlar zararın doğmasına veya artmasına sebep olmuş ise, onun ayıptan doğan hakları kısmen veya tamamen ortadan kalkabilir; bununla beraber TBK m. 476'nın bu etkisi, işsahibinin, tazminat talebinden başka, ayıptan sorumluluktan doğan diğer haklarını da kapsamaktadır[144].

bb) Şartları

aaa) Eserdeki ayıp işsahibinin talimatından veya ona isnadı kabil bir sebepten ileri gelmelidir

Buradaki talimattan amaç, işsahibinin eser sözleşmesi çerçevesinde verdiği bağlayıcı emirlerdir; bağlayıcı olmayan görüş ve tavsiyeler bu madde anlamında talimat sayılmaz[145]. Aynı şekilde, bu talimatlar, işin ifasına (yürütülmesine), usulüne, malzemeye veya işin bir alt yüklenici-ye devrine ilişkin olabilir[146]; talimatların bizzat işsahibi veya onun yetkili temsilcisi tarafından verilmiş olması önemli değildir[147].

TBK m. 476, işsahibinin verdiği talimatların yanında, ona isnadı kabil herhangi bir sebepten dolayı eserin ayıplı olması halinde de, ayıptan doğan hakların kullanılamayacağını öngörmektedir. Bu maddede yer alan "diğer herhangi bir sebeple" ibaresi genel bir kayıt (hüküm) (Generalklausel) niteliği taşımaktadır. İş sahibi tarafından sağlanan malzemenin veya arsanın ayıplı olması yüzünden eserin ayıplı olması halinde böyle bir durum söz konusu olur[148]. Ancak, yüklenicinin sorumluluktan kurtulabilmesi için, TBK m. 472/II ve III gereğince malzeme ve arsanın ayıplı olduğunu işsahibine derhal bildirmesi (bildirimde bulunması) gerekir[149]. Aynı şekilde, ayıbın göze çarpacak de-

---

[143] **Tercier**, N. 3504.

[144] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 1; **Gauch**, N. 1914; **Gautschi**, Art. 369, N. 2; **Pedrazzini**, sh. 33.

[145] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 6; **Eren**, İnşaat, sh. 79; **Bühler**, Art. 369, N. 27.

[146] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369. N.7; BGE 116 II 308.

[147] **Gauch**, N. 1921 vd; **Tercier**, N. 3508; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 12.

[148] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 21; **Gauch**, N. 1979; **Bühler**, Art. 369, N. 33 vd; **Tandoğan** II, sh. 208 ve 214; **Eren**, İnşaat, sh. 80.

[149] **Gauch**, N. 1986 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 22; **Bühler**, Art. 369, N. 38.

recede açık olması veya yükleniciden beklenebilecek bir inceleme sonunda anlaşılabilecek nitelikte olması hallerinde ayıbı bilmediği için bildirimde bulunmayan yüklenici sorumlu olur[150].

bbb) Yüklenici uyarma ve aydınlatma yükümünü yerine getirmiş olmalıdır

Yüklenicinin işsahibinin veya yetkili temsilcisinin verdiği emir ve talimatların yanlış olduğunu ve buna uyulması halinde eserin ayıplı olacağını, bunun sorumluluğunun kendisine ait olmayacağını işsahibine bildirmesi gerekir. Yüklenicinin bu yükümü, onun mesleğinde uzman kişi olduğu gerekçesiyle açıklanmaktadır[151].

Doktrin ve uygulamada, yüklenicinin bazı hallerde, uyarıda bulunmamasına rağmen sorumluluktan kurtulabileceği kabul edilmektedir. İş sahibinin kendisinin veya danışman yahut temsilcisinin verilen talimatlar bakımından uzman olmaları halinde böyle bir durum karşısında bulunulur. Bu durumda, yüklenicinin, gerekli uyarıların yapılması halinde dahi işsahibinin yanlışta ısrar edeceğini ve bunun sonunda ayıbın gerçekleşeceğini isbat etmesi gerekir[152]. Keza uzman kişi tarafından verilen talimatlarda, yüklenici, talimatın hatalı olduğunu bilmiyorsa veya bilecek durumda değilse sorumluluktan kurtulur[153].

ccc) Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı veya ona isnad edilebilen sebep arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır

Eserdeki ayıbın, münhasıran işsahibinin verdiği talimattan veya ona isnat edilebilen diğer bir hukukî sebepten doğması gerekir. Ayıbın meydana gelmesinde işsahibinin talimatının veya sorumlu olduğu diğer bir sebebin ortak bir sebep olarak belirli bir rol oynaması yeterli değildir[154]. Bu şartın gerçekleşmesi için, işsahibinin kanundan veya sözleşmeden doğan bir yükümünü ihlâl etmiş olması da gerekli değildir[155].

---

150 **Gauch**, N. 1993 vd, özellikle N. 1996-1997; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 22; **Bühler**, Art. 369, N. 38; **Gautschi**, Art. 369, N. 5a; **Tandoğan** II, sh. 215.

151 **Pedrazzini**, sh. 34; **Tercier**, N. 3511; **Gauch**, N. 1593.

152 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369; N. 14; **Gauch**, N. 1964.

153 **Gauch**, N. 1958 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 15; BGE 116 II 309 vd ve 456.

154 **Gauch**, N. 1918; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 3; **Bühler**, Art. 369, N. 56; **Eren**, İnşaat, sh. 81; BGE 116 II 458.

155 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 3; **Gauch**, N. 1917; **Eren**, İnşaat, sh. 81.

İş sahibinin yükleniciyi denetleme yükümü bulunmayıp, sadece koordinasyon yükümü vardır. Bu itibarla, işsahibinin yükleniciyi denetlemesi veya denetletmesi halinde önlenebilecek ayıplar TBK m. 476'nın kapsamına girmez[156]. Aynı şekilde, eser sözleşmesiyle kararlaştırılan bedelin düşük olması da işsahibinin ayıptan sorumlu olmasını gerektirmez[157].

c) İş sahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır

İş sahibi kendisine teslim edilen eseri açıkça veya zımnen kabul ederse, yüklenici ayıptan sorumluluktan dolayı sorumluluktan kurtulur; buna karşılık, yüklenicinin ayıbı kasten gizlemesi veya normal bir incelemeyle anlaşılamayacak gizli ayıpların bulunması halinde yüklenicinin sorumluluğu devam eder (TBK m. 477/I)[158]. İş sahibi, kanunda öngörülen inceleme ve bildirimi yerine getirmezse, eseri zımnen kabul etmiş sayılır (BK m. 477/II).

d) İş sahibi gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getirmiş olmalıdır

Yukarda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, işsahibinin ayıba karşı tekeffülden doğan haklarını kullanabilmesi için, onun eseri gözden geçirme (inceleme) ve bildirim külfetlerini yerine getirmesi gerekir. Bu külfetler yerine getirilmediği takdirde, eser işsahibi tarafından zımnen kabul edilmiş sayılır (TBK m. 477/II) ve yüklenici sorumluluktan kurtulur.

aa) Gözden geçirme (muayene) külfeti

TBK m. 474/I'e göre, "İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır". İşsahibinin gözden geçirme ve bildirimde bulunma külfetini

---

156 **Gauch**, N. 2057 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 4; **Eren**, İnşaat, sh. 82.

157 **Gauch**, N. 2056; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 369, N. 4.

158 Sözleşmeye konu parkelerin eserin tesliminden sonra bozulduğu, bu bozuklukların gizli ayıp niteliğinde olduğu, ayıplı ve kusurlu imalatın kullanım hatasından değil yüklenicinin kusurundan kaynaklandığı, gizli ayıbın giderilmesine ilişkin bedelin ayıbın ortaya çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla istenebileceği hakkında bkz. 15. HD. 14.1.2013 tarih E. 2012/7336 K. 2013/82 –Kazancı-.

yerine getirmezse eseri kabul etmiş sayılır (TBK m. 477/II)[159]. Eserin incelenebilmesi için, onun ifa amacıyla işsahibine teslim edilmesi gereklidir; teslim, kararlaştırılan işlerin tamamen yapılıp, eserin tamamlanmasını şart kılar[160].

TBK m. 474/I hükmü incelemenin zamanı konusunda, "işlerin olağan akışına göre imkânını bulur bulmaz" kriterini kullanmaktadır. Bu kriter, sadece incelemenin başlangıç anına ilişkin olmayıp, başlayan incelemenin bitim zamanının belirlenmesinde de kullanılır[161]. İşlerin olağan gidişine göre incelemenin yapılabileceği süre, eser sözleşmesine katılan (tacir olsun veya olmasın) kişiler arasında mevcut olan teamüle dayanarak tesbit edilir. İncelenecek eserin niteliği ve özellikleri göz önünde tutularak, makul ve özenli bir inceleme için gerekli bir sürenin işsahibine tanınması gerekir[162]. İnceleme süresinin tesbitinde mümkün olduğu kadar geniş davranılması gerekir; özellikle işsahibinin tacir olmadığı veya yeterli deneyime sahip olmadığı durumlarda böyle bir zaruret söz konusu olur[163].

Sözleşme veya teamül gerektirmedikçe işsahibi incelemeyi bir uzmana veya bilirkişiye yaptırmak zorunda değildir[164]. Bununla beraber, gerek yüklenicinin gerek işsahibinin, masrafı kendisine ait olmak üzere, eserin bir bilirkişiye incelettirilmesini ve sonucun bir raporla tesbitini isteme hakkı vardır (TBK m. 474/II).

bb) Ayıbı bildirme külfeti

İş sahibi farkına vardığı her türlü ayıbı yükleniciye bildirmek zorundadır (TBK m. 474/I); ayıpların inceleme sonunda ortaya çıkması veya sonradan öğrenilmiş olması bu hususta önemli değildir.

---

159 Bkz. 15. HD. 2014/2954 E. 2015/1463 K.; Mahkemece mahallinde keşif ve inceleme yapılmalı, tazminat konusu yapılan kalemler incelenmeli, bunların ayıp iş ya da eksik iş olup olmadığı, ayıplı iş ise açık ayıp ya da gizli ayıp olarak nitelenip nitelenemeyeceği değerlendirilmeli, açık ayıp ise gözten geçirme ve bildirim külfetlerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmalıdır (23. HD. 25.9.2014 tarih E. 2014/1106 K. 2014/5491) -Kazancı-.

160 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 2; BGE 115 II 458; 113 II 171 vd.

161 **Gauch**, N. 2112.

162 **Gauch**, N. 2113 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 6; **Tercier**, N. 3526; BGE 81 II 59

163 **Gauch**, N. 2118; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 7; **Klauser**, sh. 29, 31.

164 **Gauch**, N. 2124; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 10; **Tandoğan** II, sh. 170.

TBK m. 474/I'de "bildirme" kelimesi kullanılmış olmasına rağmen, burada bir tasavvur açıklaması değil, işsahibinin teslim edilen eseri sözleşmeye uygun olarak kabul etmediğini ve yükleniciyi sorumlu kılmak istediğini gösteren bir irade açıklaması söz konusudur[165].

Ayıp bildiriminde ayıbın cinsi ve kapsamı gösterilmelidir; eser ayıplıdır veya sözleşmeye uygun değildir şeklindeki genel ifadeler yeterli değildir[166].

Ayıp bildiriminin yapılması herhangi bir şekle bağlı değildir; sözlü olarak veya zımnî irade açıklamasıyla da yapılabilir[167]. TBK m. 474/I' de açıkça ifade edilmemiş olmakla beraber, ayıp bildiriminin normal olarak, incelemenin tamamlanmasından sonra hemen yapılması yeterlidir. Ancak, teknik açıdan karmaşık tesislerde olduğu gibi uzun süreyi gerektiren incelemelerde, ayıptan doğan veya ayıbı takip eden zararın artma tehlikesi varsa, ayıp bildiriminin inceleme süresinin bitimini beklemeden, ayıbın öğrenilmesinden sonra hemen, yani kısa bir süre içinde yapılması gerekir[168]. Aynı şekilde incelemeden önce veya incelemenin başlangıcında açıkça belli olan ayıplarda (meselâ, bir duvarda görülebilir çatlakların bulunması) da, incelemenin tamamlanması beklenilmeden ayıp bildirimi hemen yapılmalıdır[169].

---

165 **Gauch**, N. 2133 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 17; **Tandoğan** II, sh. 172.

166 **Gauch**, N. 2131; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 18; **Tandoğan** II, sh. 172.

167 **Gauch**, N. 2131; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 20; **Klauser**, sh. 32; **Tandoğan** II, sh. 173; Damlama sulama sisteminin kurulmasından bir gün sonra jeneratördeki arıza nedeni ile sistemin çalıştırılamadığı, jeneratörün tamir için davacıya götürüldüğü, davacının tamir için jeneratörün kendisinde olduğunu kabul ettiği anlaşılmakla ayıp ihbarının süresinde yapıldığı kabul edilmiştir 15. HD. 18.10.2012 tarih E. 2012/5503 K. 2012/6582 –Kazancı-; Fuarda stand dekoru yapılması işinde gönderilen bir fatura ödenmiş, diğeri iade edilmiştir. Davalı işin eksik bırakıldığını, ayıplı olduğunu ve süresinde yapılmadığını ileri sürmektedir. Eser sözleşmesinde ayıp ihbarının yapıldığı tanık delili dahil her türlü delille ispatlanması mümkündür. Davalı tarafından e-mail ile yapılan ayıp ihbarına yüklenicinin aynı tarihli ve bu gönderiye karşılık gelen e-mail ile cevap vermesi bildirim külfetinin yerine getirildiğini ispat etmektedir (15. HD. 31.10.2012 tarih E. 2012/6364 K. 2012/6664 –Kazancı-.

168 **Gauch**, N. 2142; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 20; **Pedrazzini**, sh. 32 vd; **Tandoğan** II, sh. 174.

169 **Gauch**, N. 2143; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 367, N. 20.

2. Ayıptan doğan haklar

a) Genel olarak

TBK m. 475, ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin yukarda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, işsahibine, sözleşmeden dönme, bedelin indirilmesi, eserin onarımı ve tazminat talep etme haklarını tanımaktadır. Bunlardan ilk üçü seçimlik talepler olup, işsahibi bunlardan birini kullanabilir; ancak, işsahibinin seçim yetkisi, bu imkânların herbiri için TBK m. 475'de öngörülen şartların gerçekleşmesi olgusuyla sınırlıdır[170].

Buna karşılık ayıbı takip eden zararlara ilişkin tazminat talebi, seçilen diğer imkânlarla (dönme, bedelin indirilmesi veya onarılma) birlikte ileri sürülebilir.

Ayıptan doğan dönme, bedelin indirilmesi veya onarım haklarının kullanılması için yüklenicinin kusurlu olması şart değildir; bunlardan dolayı yüklenici kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumludur. Buna karşılık yüklenici, ayıbı takip eden zararda, kusuru bulunduğu takdirde tazminat ödemekle yükümlüdür[171].

Eserin bizatihi kendisinin ayıplı olması nedeniyle oluşan zarar tazminatın kapsamına dahil değildir. Zira, bu tür zararlar bedelin indirilmesi veya eserin onarılması ile karşılanır. Ayıbı takip eden zarar bunların dışında ayıbın sonradan doğan sonucudur. Örneğin su akıtan çatının imal edilerek tesliminde, çatıdaki eksiklik ve bozukluk kusursuz sorumluluk esasına tabi olduğu halde, çatının akması sonucu evdeki eşyanın zarar göremesi takip eden zarar kapsamında olduğundan kusurlu sorumluluk esasına tabidir.

b) Sözleşmeden dönme hakkı

aa) Özel şartlar

TBK m. 475/I, b. 1'e gören işsahibi, "Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönebilir".

TBK m. 475/I, b. 1, işsahibinin sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesini, ayıptan doğan sorumluluk için gerekli olan genel şartlar-

---

[170] **Tercier**, N. 3561; **Gauch**, N. 1487; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 7.

[171] **Gauch**, N. 1504; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 8; BGE 116 II 307 vd.

dan başka, meydana getirilen eserin işsahibi için "kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı veya sözleşmeye aykırı olması" özel şartına bağlamıştır. Bu fıkrada geçen, eserin kullanılamazlığı ve işsahibinden kabulün beklenememesi alternatif şartlar olmayıp, eserin kullanılamazlığı, kabulün beklenemezliği şartının kanunda düzenlenmiş uygulama hallerinden biridir[172].

Somut olayda eserdeki ayıbın işsahibi için kabulü beklenemez (kabule zorlanamaz) derecede olup olmadığı, hakkaniyet esaslarına göre, çatışan çıkarların tartılması suretiyle belirlenir[173]. Bu konuda, bedelden indirme ve onarımın işsahibinin işine yarayıp yaramayacağı veya dönmenin yükleniciye vereceği kayıpla işsahibine sağlayacağı yarar arasında aşırı dengesizliğin bulunup bulunmadığı yahut ayıbın giderilmesi için gerekli zaman ve masraflar göz önünde tutulur[174].

TBK m. 475/III uyarınca, eserin işsahibinin arsası üzerinde yapılması halinde, onun kaldırılması veya yıkılması aşırı bir zararı gerektiriyorsa, işsahibi, ancak bedelin indirilmesini veya eserin onarılmasını isteyebilir. Böylece, ekonomik açıdan değerli malların imkân ölçüsünde korunması ve tahrip edilmemesi ilkesine uyulmaktadır[175].

bb) Dönmenin sonuçları

Hâkim fikre göre[176], işsahibi sözleşmeden dönme hakkını tek taraflı ve varması gereken yenilik doğuran bir irade beyanıyla kullanır; sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar ve sözleşmeye dayanan tasfiye ilişkisine dönüşür.

Sözleşmeden dönülmesi üzerine daha önce yerine getirilmiş edimlerin iadesi, sözleşmeye dayanan tasfiye yükümleri çerçevesinde gerçekleşir; aynı anda ifa (Zug um Zug) esasına uygun olarak yerine getirilir[177].

---

[172] **Gauch**, N. 1557; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 14; **Bühler**, Art. 368, N. 43. Aksi fikirde: **Gautschi**, Art. 368, N. 13 c; **Furrer**, sh. 109 vd.

[173] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 15; **Gauch**, N. 1559; BGE 98 II 122.

[174] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 15; **Oser/Schönenberger**, Art. 368, N. 7; **Becker**, Art. 368, N. 4.

[175] **Gauch**, N. 1573; **Tandoğan** II, sh. 183.

[176] **Gauch**, N. 1530 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 24; **Gautschi**, Art. 368, N. 10 a; **Klauser**, sh. 46. Feshin ileri etkili olduğu fikrinde: **Honsell**, sh. 253.

[177] **Gauch**, N. 1538; **Piotet**, BR, 1984, sh. 12; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 28; BGE 114 II 157 vd.

c) Bedelin indirilmesi hakkı

TBK m. 475/I, b. 2 uyarınca, meydana getirilen eserdeki ayıp sözleşmeden dönme hakkına imkân verecek derecede (TBK m. 475/I, b. 1) önemli olmadığı takdirde, işsahibi, eserin değerindeki eksiklik oranında bedelin indirilmesini talep edebilir[178].

Buna göre bedelden indirim yapılabilmesi için, ayıp sebebiyle eserin değerinde bir eksiklik meydana gelmiş olmalıdır; eserdeki değer eksikliği, ayıplı olarak teslim edilen eser ile ayıpsız olarak düşünülen eser arasındaki farktır. Başka bir ifadeyle, burada, ayıpsız olarak düşünülen eserin malvarlığı açısından ayıplı eserden daha değerli olması söz konusudur. Eserdeki değer eksikliği objektif değere, yani satış (piyasa) değerine göre belirlenir[179]. Bu konuda, tarafların sözleşmeyle kararlaştırdıkları bedel belirleyici değildir; işsahibi, eserin ayıplı değeri kararlaştırılan bedele eşit veya ondan fazla olsa dahi, bedelin indirilmesini talep edebilir[180].

İş sahibi, eserdeki ayıbın kendisine sözleşmeden dönme hakkı verecek derecede önemli olması halinde de bedelin indirilmesini talep edebilir; ancak, ayıplı eserin hiçbir objektif değerinin bulunmaması sebebiyle, indirilecek miktar bedele eşit ise, TBK m. 227/IV kıyasen uygulanarak, işsahibinin sadece sözleşmeden dönebileceğini kabul etmek gerekir[181].

Bedelden yapılacak indirim eserdeki değer eksikliği oranında yapılır; bedelden indirilecek miktarın hesabı, satış sözleşmesindeki nisbî

---

[178] Dava konusu olay yüklenicinin heyelan bölgesinden geçen doğalgaz nakil hattına fore kazık imalatına ilişkin eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. İşsahibi ayıp oranında bedel indirimi ve tazminat talep etmiştir. Bu durumda sevk sistemindeki ayıbın, yüklenicinin fen ve tekniğine ya da projesine aykırı imalatından mı, yoksa işsahibinin kendisi tarafından ikinci etabı güçlendirmek için proje dışı yaptığı imalattan mı kaynaklandığının belirlenmesi gerekir (15. HD. 20.3.2013 tarih E. 2012/1993 K. 2013/1868 –Kazancı-).

[179] **Gauch**, N. 1627-1628; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 36; **Tercier**, N. 3593; BGE 105 II 101.

[180] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 37; **Gauch**, N. 1632; **Tercier**, N. 3593.

[181] **Gauch**, N. 1639; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 39; **Tercier**, N. 3594; **Tandoğan** II, sh. 186.

metoda göre yapılır. Buna göre, eserin objektif ayıplı değeri ile ayıpsız objektif değeri arasındaki orana göre bedelin indirilmesi gerekir[182].

$$\text{Ödenecek indirilmiş ücret} = \frac{\text{kararlaştırılan ücret x ayıplı değer}}{\text{ayıpsız değer}}$$

Gauch'a göre bu formül şu şekilde ifade edilebilir[183]:

$$\frac{\text{indirim tutarı}}{\text{kararlaştırılan ücret}} = \frac{\text{Ayıp sebebiyle azalma tutarı}}{\text{Ayıpsız değer}}$$

$$\text{İndirim Tutarı} = \frac{\text{Kararlaştırılan ücret}}{\text{Ayıpsız değer}} \text{ x } \text{Ayıp sebebiyle değerdeki azalma tutarı}$$

d) Eserin bedelsiz onarılmasını talep hakkı

TBK m. 475/I, b. 3'e göre, işsahibi, "Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin bedelsiz onarılmasını isteme" hakkına sahiptir.

İş sahibinin eserin onarımı talep hakkını kullanabilmesi için, eserin onarımının objektif olarak mümkün olması ve onarımın aşırı masrafları gerektirmemesi (TBK m. 475/I, b. 3) şarttır[184].

Onarımın yüklenicinin aşırı masraflar yapmasını gerektirip gerektirmediğini tesbitte, onarımın işsahibine sağlayacağı yararla yapılacak masraf arasında aşırı ölçüde oransızlık bulunmaması hususu göz önünde tutulmalıdır[185].

Çok ender de olsa, yüklenicinin onarımı kabul etmemesi veya ayıbı giderebilecek durumda olmaması halinde, işsahibi, onarımı üçüncü bir şahsa yaptırabilir ve bunun masraflarını yükleniciden talep edebi-

---

182 **Gautschi**, Art. 368, N. 16; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 43; **Tercier**, N. 3597; **Tandoğan** II, sh. 191; **Bucher**, sh. 210; BGE 116 II 313; 111 II 163; 105 II 101; HGK 16.1.1971, E. 69-T-385/K. 14: "davalının yapıdan elini çektiği günde sözleşmeye uygun olarak yaptığı veya yapmadığı işler hesaplanmak,bu suretle yapının sözleşmeye uygun olarak hangi oranda yapılmış olduğu tesbit edilmek, bulunacak olan oran ile sözleşmede kararlaştırılan ücret tutarları çarpılarak davalının hak ettiği tutar belli edilmek gerekir" (İBD 1971, S. 7-8, sh. 659).

183 **Gauch**, N. 1664; **Bühler**, Art. 368, N. 94.

184 **Gauch**, N. 1745 vd.; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 47; **Tercier**, N. 3571 vd.

185 **Gauch**, N. 1749; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 48; **Tercier**, N. 3573; BGE 111 II 173 vd. yahut JdT 1986 I 77.

lir. Bunun için yüklenicinin temerrüde düşmüş olması gerekir. İşin başkasına yaptırılması için kural olarak hâkimden izin alınması gerekir (TBK m. 113/I). Bununla beraber Federal Mahkeme, TBK m. 473/II'yi kıyasen uygulayarak, bu hususta hâkimden izin alınmasına gerek olmadığı sonucuna varmıştır[186].

İş sahibi ayıbın giderilmesini isteyince, yüklenici derhal giderme çalışmalarına başlamak (TBK m. 90) ve normal bir yükleniciden objektif olarak beklenebilen bir süre içinde bu çalışmaları tamamlamak zorundadır[187].

Yüklenici bu süre içinde ayıbı gidermezse, işsahibi onu ihtarla temerrüde düşürebilir (TBK m. 117/II); şayet işsahibi ayıbın giderilmesi için yükleniciye bir süre tayin etmiş ise, TBK m. 117/II kıyasen uygulanarak, yüklenici bu süre sonunda ihtara gerek olmadan temerrüde düşer[188]. Yüklenici ayıbı giderme çalışmalarına zamanında başlamazsa veya geciktirirse veya işsahibinin kusuru olmaksızın bu çalışmanın zamanında bitirilemeyeceği anlaşılırsa, TBK m. 473/II kıyasen uygulanır; işsahibi ihtarla yükleniciyi sürenin dolmasından önce mütemerrit kılabilir[189].

İş sahibi, temerrüde düşen yükleniciye TBK m. 123/ gereğince uygun bir mehil verir ve bu mehilin sonunda TBK m. 125/II'deki seçimlik hakları eser sözleşmesine ait özellikleri göz önünde tutmak kaydıyla kullanabilir[190]: İş sahibi mehil tayinine gerek olmadan, her zaman aynen ifayı talep edebilir, yani onarımda ısrar edebilir. Bunun yanında TBK m. 125/II'de öngörülen aynen ifadan vazgeçip müsbet zararının tazminini isteme veya sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Ancak o, dönme hakkını TBK m. 475/I, b. 1 çerçevesinde kullanabilir. Aynı şekilde, yüklenici kusuru bulunmadığını kanıtlayarak müsbet zararın tazmininden kurtulabileceğinden, işsahibi tekrar bedelin indirilmesini isteme hakkını elde eder[191].

Diğer taraftan, yüklenici eseri ayıplı olarak onarırsa, işsahibi tekrar TBK m. 475'de öngörülen seçimlik hakları elde eder; bunun için ona-

---

186 BGE 107 II 55; 116 II 314.

187 **Gauch**, N. 1783; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 61; **Bühler**, Art. 368, N. 149; **Tandoğan** II, sh. 198.

188 **Gauch**, N. 1789-1790; **Bühler**, Art. 368, N. 149.

189 **Gauch**, N. 1791; **Tandoğan** II, sh. 198-199.

190 **Gauch**, N. 1795; **Tandoğan** II, sh. 199.

191 **Gauch**, N. 1796; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 362, N. 62; **Tandoğan** II, sh. 199.

rılan esere ait inceleme ve bildirim külfetini yerine getirmesi gerekir[192].

e) Tazminat talep etme hakkı

TBK m. 475/ I ve II işsahibine, dönme, bedelin indirilmesi veya onarım isteme haklarının yanında, yüklenicinin kusuru varsa tazminat talep etme hakkı da tanımaktadır. Bu maddede öngörülen tazminat talep etme hakkı, sözleşmeden dönme, bedelin indirilmesi veya onarımın yerine kullanılacak bir hak değildir; bu üç seçimlik hakka ek olarak ve onlarla birlikte kullanılabilen bir hukukî imkândır[193].

İş sahibinin TBK m. 475/II gereğince isteyeceği tazminat, onun ayıbı takip eden zararlarının (Mangelfolgeschaden) karşılığıdır. Ayıbı takip eden zarar, işsahibinin, ayıbın sonraki sonucu olarak ortaya çıkan ve ayıplı eserdeki değer eksikliği dışında kalan her türlü zarardır[194]. Buna göre, bizzat eserin kendisindeki ayıptan doğan zarar ayıbı takip eden zarar değildir; ayıbı takip eden zarar ayıbın sonraki sonucu olan ve işsahibinin ayıpsız edime ilişkin doğrudan doğruya menfaatinin dışında kalan zarardır[195]. Böylece aşağıdaki zararlar ayıbı takip eden zarar kategorisine girer: Yeni inşa edilen evin ayıbı giderilinceye kadar uğranılan kira kaybı; onarım esnasında işletmedeki üretimin durmasından doğan kâr kaybı; işsahibinin uzman bir kişiye eseri incelettirmek için yaptığı masraf (TBK m. 474/II); ayıplı evdeki ayıbın giderilmesine kadar ödenen kira kaybı; ayıplı bir duman borusunun yangına ve hasara sebep olması veya ayıplı tırmanma kayışının bunu kullananın bacağının kırılmasına ve tedavi masraflarına sebep olması; ayıp sebebiyle işsahibinin hammaddelerinin yanması; iyi bir şekilde onarılan şeyin piyasa (satış) değerinin azalması[196].

Buna karşılık, eserin geç teslim edilmesinden doğan zararlar, eserin imal veya teslimi vesilesiyle işsahibinin uğradığı diğer zararlar,

---

[192] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 64; **Gauch**, N. 1846; **Bühler**, Art. 368, N. 153; **Tercier**, N. 3578; BGE 109 II 42.

[193] **Gauch**, N. 1850 ve 1852; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 68; **Bühler**, Art. 368, N. 166; **Pally**, sh. 19; **Lenzlinger-Gadient**, sh. 122; **Tandoğan** II, sh. 204.

[194] **Gauch**, N. 1853 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 69; **Seliçi**, sh. 182-183; **Tandoğan**, II, sh. 204.

[195] **Gauch**, N. 1864.

[196] Bu örnekler için bk. **Gauch**, N. 1870-1873; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 70; **Bühler**, Art. 368, N. 175 vd; **Tandoğan** II, sh. 205.

eserin kullanılmasına ilişkin açıklamaların yapılmamasından doğan zararlar, bedelden indirilecek miktarı aşan onarım masrafları ayıbı takip eden zarar olarak kabul edilmemektedir[197].

Yüklenicinin ayıbı takip eden zararlardan sorumluluğunu, onun kusurlu olması şartına bağlayan TBK m. 475/ II, satış sözleşmesinden (TBK m. 229/I, b. 3 ve II) farklı olarak, bu hususta doğrudan zarar dolaylı zarar ayırımı yapmamıştır[198]. Ancak, ayıbı takip eden zararların yüklenicinin yardımcılarının davranışından ileri gelmesi halinde, TBK 116 uyarınca kusursuz sorumluluk söz konusu olur[199].

3. Ayıptan doğan hakların tabi olduğu zamanaşımı

Eser sözleşmesinde ayıplı bir eser meydana getirilmişse, bunan işsahibi lehine doğan hakların tabi olduğu zamanaşımı süreleri TBK m. 478'de düzenlenmiştir. Buna göre, yüklenici, ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden itibaren, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Buna karşılık taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar (TBK m. 478).

4. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'la getirilen özel sorumluluk

Bu Kanunun 3. maddesine göre, "Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı yükleniciyi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır" (f. II),

---

197 **Gauch**, N. 1857 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 70; **Bühler**, Art. 368, N. 173; **Pally**, sh. 44 vd.

198 **Gauch**, N. 1890; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 71; **Bühler**, Art. 368, N. 187 ve 190; **Pally**, sh. 36; **Klauser**, sh. 53 vd.

199 **Gauch**, N. 1893; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 72; **Bühler**, Art. 368, N. 192; BGE 116 II 367.

"Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir" (f.III),

"Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı yükleniciyi; bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur" (f. IV).

§ 27. ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI

I. Genel olarak

Türk Borçlar Kanunu işsahibinin borçları başlığı altında yer alan 479-481. maddelerinde sadece bedel ödeme borcunu düzenlemiş bulunmaktadır. Bedel ödeme borcu, eser sözleşmesinde işsahibinin aslî edim yükümünü teşkil eder. Bununla beraber, eser sözleşmesinde, işsahibinin bazı yan yükümleri, koruma yükümleri ve yerine getirmesi gereken külfetler bulunmaktadır. Bunların ihlâli, işsahibini alacaklının temerrüdüne düşürebilir (işbirliği veya sağlama yükümleri), bazı haklardan yoksun bırakılabilir (özellikle ayıba karşı tekeffülden doğanlar) veya yükleniciye tazminat ödeme (TBK m. 122 vd.) sonuçlarını doğurabilir[1].

II. Bedel ödeme borcu

1. Genel olarak

İş sahibinin aslî edim yükümünü ve eser sözleşmesinin zorunlu unsurunu teşkil eden bedel ödeme borcu, genellikle taraflarca eser sözleşmesinde tayin edilir. Taraflar arasında bedelin miktarı konusunda bir anlaşma bulunmadığı takdirde, TBK m. 481 gereğince, bedel işin değerine ve yüklenicinin yaptığı masraflara göre belirlenir.

Sözleşme dışında yapılan fazladan iş için caiz olan vekâletsiz iş görme ya da caiz olmayan vekâletsiz iş görme hükümlerine göre hesaplanacak miktar ödeme konusu yapılır[2]. Ancak vekâletsiz iş görme-

---

1 **Gauch**, N. 1320 vd; **Tercier**, N. 3758 vd.

2 Eser sözleşmesi kapsamı dışında imalatın yapılması ve işin idarece benimsenmesi halinde vekâletsiz iş görme hükümlerine göre bedelin ödenmesi gerekir. TBK m. 529 uyarınca zorunlu ve faydalı masrafları faiziyle ödemek, iş nedeniyle üstlendiği edimleri ifa etmek ve hakimin takdir edeceği zararı gidermekle yükümlüdür. İşgören, yapmış olduğu giderleri alamadığı takdirde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ayırıp alma hakkına da sahiptir (TBK m. 529/II). Fazla imalat, yapıldığı tarihteki –mahalli- piyasa fiyatları esas alınarak hesaplanmalıdır (HGK 2.10.2013 e. 2013/15-95 k. 2013/1431; İdari şartnamede ihale bedelinin %10 fazlasına kadar yapılan imalatın sözleşme fiyatıyla yaptırılacağı kabul

nin her iki türünde işsahibinin işi uygun bulması halinde vekâlet hükümleri uygulanır (TBK m. 531)[3]

Eser sözleşmesinde taraflar bedeli başlıca iki şekilde belirleyebilirler. Bunlardan birincisi götürü bedel, diğeri yaklaşık bedeldir. Bununla beraber, tarafların aynı sözleşmede bazı edimler için götürü bedel, diğerleri için yaklaşık bedel kararlaştırmaları da mümkündür.

2. Götürü (sabit) bedel

a) Kavram

Götürü (sabit) bedel, meydana getirilecek eser karşılığında ödenecek bedelin önceden ve kesin olarak belirlenmesidir. Taraflar bu bedeli sözleşmeyi kurarken önceden ve kesin olarak tesbit ederler[4].

Eser sözleşmesinde bu tür bir bedel kararlaştırılan hallerde kural olarak öngörülen bedelin riski yükleniciye ait olup, sonradan bedelin arttırılması istenemez; ancak TBK m. 480/II'de öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde uyarlama yoluyla bedelin arttırılması talep edilebilir; buna karşılık işsahibi, eserin tahmin edilenden daha az masrafla yapılması halinde, bedelden indirim yapılmasını isteyemez (TBK m. 480/III)[5].

b) Çeşitleri

aa) Toptan götürü (sabit) bedel (Pauschalpreis)

Anahtar teslimi sabit bedel olarak da adlandırılan bu bedel türünde, meydana getirilecek eserin tamamı için önceden tesbit edilen tek bir meblağ ödenmek zorundadır[6]. Kural olarak, tesbit edilen bu bedel

---

edilmiştir. Esasen fazla imalatın vekâletsiz işgörme hükümlerine göre yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre ödenmesi gerekir. Somut olayda fazla imalatın %10'unun sözleşme fiyatlarıyla, bunun üzerindeki işin ise piyasa rayicine göre belirlenmesi gerekir. Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre hesaplanması doğru değildir (15. HD. 24.6.2013 tarih E. 2012/1282 K. 2013/4107) -Kazancı-.

3 Eser sözleşmesinde fazla imalat karşılığı, bedelin götürü olarak belirlendiği hallerde dahi piyasa rayici üzerinden hesaplanarak ödenir (bkz. sözleşme kapsamında yapılan işin tamamlanmamış ancak fazla işin yapılmış olduğu halde ücretin hesaplanma usulü için 15. HD. 5.12.2012 tarih E. 2012/3812 K. 2012/7630 – Kazancı-).

4 **Tercier**, N. 3652-3653; **Tandoğan** II, sh. 234.

5 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 1 vd; **Corboz**, FjS Nr. 461, IV, sh. 2; **Honsell**, sh. 261

6 **Gauch**, N. 900 vd; **Tercier**, N. 3656 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 6.

eserin meydana getirilmesi için harcanan emek ve masraf miktarlarından bağımsızdır[7]. Meselâ, bir evin tamamının yapımı, bir çatının tamiri için belirli bir bedelin öngörülmesi.

bb) Sabit birim fiyatlarla belirlenen bedel (Einheitspreis)

Bu bedel türünde taraflar, eserin meydana getirilmesi için gerekli birimler için önceden sabit bir fiyat belirlemek suretiyle ödenecek bedeli tesbit ederler[8]. Meselâ, yapılacak işin metrekaresine, kilosuna veya parça sayısına göre önceden belirli bir bedelin tesbiti.

Bedelin yaklaşık olarak tesbitinden farklı olarak, burada ödenecek bedel, eserin meydana getirilmesi için zorunlu edimlere bağlı değildir; keza toptan götürü bedelden farklı olarak, bedel yapılan işlerin miktarına bağlıdır[9].

c) Götürü (sabit) bedelli sözleşmelerde olağanüstü haller dolayısıyla sözleşmenin uyarlanması

aa) Genel olarak

Bedelin götürü (sabit) fiyatlarla belirlendiği eser sözleşmelerinde, tesbit edilen bedelin değişmemesi asıldır. Bununla beraber, kanun koyucu, TBK m. 480/II'de yer alan şartların gerçekleşmesi halinde sözleşmeyle bağlılık (ahde vefa) ilkesinden ayrılınacağını ve sözleşmenin değişen şartlara uyarlanabileceğini kabul etmiştir. Gerçekten, bu fıkra hükmüne göre, "Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği tak-

---

7 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 6; **Tercier**, N. 3657; Toplam götürü bedelle yapımı kararlaştırılan betonarme binanın sözleşmede 1950 m2 olarak gösterildiği halde 2751 m2 olarak yapıldığı, fazla imalatın birim fiyat üzerinden hesaplanarak tazminine karar verilmiştir. Oysa, işin uzmanı sayılan yüklenicinin projedeki inşaat alanını bilmesi gerekir. Diğer yandan, sözleşme ile ihale dökümanı kapsamındaki proje arasında farklılık olması halinde ihale dökümanı esas alınır. Bu nedenlerle davanın reddine karar verilmelidir (15. HD. 19.3.2015 tarih E. 2014/49 K. 2015/1360 –Kazancı-).

8 **Gauch**, N. 915 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 7; **Tercier**, N. 3661; **Tandoğan** II, sh. 234-235; BGE 113 II 515.

9 **Tercier**, N. 3662.

dirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir".

Sabit (götürü) fiyatla bir eser meydana getirme borcunu üstlenen yüklenici, olayların normal akışına göre beklenilen şartları göz önünde tutmaktadır. Fakat sonradan ortaya çıkan, önceden öngörülemeyen olağanüstü hallerin sözleşmenin ifasını aşırı derecede güçleştirmesi veya imkânsız kılması, karşılıklı edimler arasındaki dengeyi esaslı bir şekilde bozar. TBK m. 480/II'nin amacı, böyle bir durumda aşırı ölçüde bozulan edimler arasındaki dengeyi düzeltmek için sözleşmeyi değiştirmek imkânının sağlanmasıdır; bu kural, sözleşmenin temelini teşkil eden şartlarda önemli değişikliklerin ortaya çıkması halinde hâkime dürüstlük kuralına (MK m. 2) dayanarak sözleşmeyi değiştirme imkânı veren clausula rebus sic stantibus kuralının uygulanmasını teşkil etmektedir[10].

bb) Şartları

aaa) Önceden tahmin edilemeyen veya öngörülüp de iki tarafın gerçekleşmeyeceğini kabul ettikleri olağanüstü hallerin ortaya çıkmış olması

Olağanüstü hal sayılacak olayların mutlak mücbir sebep niteliği taşıması şart değildir. Zira tarafların öngörebilecekleri fakat vukua gelmeyeceğini kabul ettikleri olağanüstü hallerin ortaya çıkması da yüklenicinin bedelin arttırılması veya fesih talebini haklı kılabilir[11]. Meselâ savaş, yangın, deprem, para değerinde beklenmedik büyük ölçüde düşüşler, malzeme fiyatlarının mutad olanın dışında aşırı derecede artması.

Olağanüstü durumun önceden tahmin edilemeyecek veya tahmin edilip de taraflarca göz önünde tutulamayan durumlar olması gerekir.

Bir durumun öngörülemez olup olmadığını tesbitte, işe yüklenici açısından bakmak ve onun konusunda uzman ve özenli bir kişi olarak kendisinden beklenen dikkati sarfedip sarfetmediğini araştırmak gerekir[12]. Ayrıca yükleniciye ait sübjektif unsurların, onun bilgisinin, yeteneklerinin de göz önünde tutulması gerekir[13].

---

[10] **Tercier**, N. 3681 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 2 ve 16; **Gauch**, N. 1047; **Honsell**, sh. 261-262; **Tandoğan** II, sh. 239; BGE 113 II 335.

[11] **Oser/Schönenberger**, Art. 373, N. 7; **Gauch**, N. 1080; **Tandoğan** II, sh. 239.

[12] **Gauch**, N. 1076; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 16; **Tercier**, N. 3691; BGE 109 II 333 yahut JdT 1984 I 209.

[13] **Gauch**, N. 1076; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 16.

Tarafların öngörüp de göz önünde tutmadığı durumlarda tarafların ortak tasavvurları, bu durumun gerçekleşmeyeceği veya gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı yönündedir[14].

bbb) Ortaya çıkan olağanüstü hallerin eserin tesbit edilen sabit (götürü) bedelle tamamlanmasını engellemesi veya aşırı derecede güçleştirmesi

TBK m. 480/II'de yer alan "eserin yapılmasına engel olur" deyimi yanıltıcı olup, bunu işin kararlaştırılan sabit (götürü) fiyatla yapılmasına engel olursa şeklinde anlamak gerekir[15].

İşin tamamlanmasına engel olma, işin tamamlanmasını aşırı derecede güçleştirmenin özel bir uygulama halini teşkil eder[16].

İşin ifasının aşırı güçleşmesi, işin tamamlanması için yüklenicinin yapacağı masrafların aşırı derecede artması anlamına gelir. Masraf artışının yüklenicinin yerine getireceği edimlerle ona ödenecek bedel arasında açık bir şekilde oransızlık yaratması halinde, TBK m. 480/II anlamında aşırı derecede güçleşme söz konusu olur; öyle ki, sözleşme uyarlanmadığı takdirde yüklenicinin borçlandığı edimleri ifa etmesi ondan beklenemez[17]. Bunun için, yüklenicinin karşılaştığı ifa yükünün onun iktisaden mahvını gerektirecek derecede olması şart değildir[18].

ccc) Olağanüstü hallerin ortaya çıkması yükleniciye isnad edilmemelidir

Olağanüstü veya aşırı masraf artmasını doğuran haller yüklenicinin sorumlu olduğu bir durumdan ileri gelmemelidir. Yüklenicinin işin organizasyonunda, malzemelerin temininde gerekli önlemleri almaması veya işin ifasında temerrüde düşmesi halinde, o, TBK m. 480/II'de öngörülen imkânlardan yararlanamaz[19].

---

[14] **Gauch**, N. 1093.

[15] **Gauch**, N. 1050; **Tercier**, N. 3686; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 22.

[16] **Gauch**, N. 1051; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 22.

[17] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 23; **Gauch**, N. 1058; BGE 104 II 317; 113 II 516.

[18] **Gauch**, N. 1065; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 23; **Bischoff**, sh. 196 vd; **Oser/Schönenberger**, Art. 373, N. 9; **Tandoğan** II, sh. 245.

[19] **Gauch**, N. 1109; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 363, N. 25; **Tandoğan** II, sh. 247; BGE 113 II 516; 104 II 316.

ddd) Taraflar fesih veya bedelin artırılması yoluna başvurulmayacağını kararlaştırmamış olmalıdır

TBK m. 480/II hükmü emredici nitelikte olmadığı için, taraflar bu hükmün uygulanmayacağını kararlaştırabilirler. Böyle bir kayıt, MK m. 23/II'deki sınırları aştığı takdirde geçersiz olur[20]. Aynı şekilde MK m.2'de öngörülen dürüstlük kuralına aykırı olarak ileri sürülemez.

cc) Sonuçları

Yukarıda belirtilen anlamda olağanüstü hallerin varlığı halinde, hâkim talep üzerine takdir hakkına dayanarak, ya kararlaştırılan sabit (götürü) bedelin arttırılmasına veya sözleşmeden dönmeye yahut onun feshine karar verir (TBK m. 480/II).

Bedelin arttırılmasına karar verilmesi halinde, artan tüm masrafların uyarlama yoluyla işsahibine yükletilmesi söz konusu olamaz; yükleniciye kâr sağlamayacak ve onun kayıplarını katlanılabilecek bir düzeye getirecek ölçüde bir bedel artışına karar vermek gerekir[21].

3. Değere göre bedel

TBK m. 481'e göre, "Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir". Bu madde hükmü, bedel miktarının hiç kararlaştırılmadığı veya yaklaşık olarak kararlaştırıldığı eser sözleşmelerinde, bedelin hesaplanmasına ilişkin bir yedek hukuk kuralı ihtiva etmektedir[22]. Bu madde BK m. 366'dan farklı olarak "yaklaşık bedel" deyimini kullanmış; TBK m. 482/I'de de "yaklaşık bedel"in aşırı ölçüde aşılması düzenlenmiştir[23].

---

20 **Gauch**, N. 1130; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 34.

21 **Gauch**, N. 1115; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 373, N. 28; BGE 104 II 317.

22 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 374, N. 1

23 818 sayılı Borçlar Kanununda aynı hususu düzenleyen 366 ve 367. maddelerde "yaklaşık ücret" ve "yaklaşık masraf tahmini" deyimleri kullanıldığından bu husus eser sözleşmesinin son derecede tartışmalı ve çözümü güç sorunlarından olduğu ifade ediliyordu. Bir fikre göre (**Gautschi**, Art. 374, N. 2 a, **Dürr**, Werkvertrag und Auftrag, 3. Aufl. 1983, sh. 93; BGE 98 II 301), bu iki deyimle ifade edilmek istenen bir ve aynı şeydir; ikisi arasında anlam farkı bulunmamaktadır. *Pedrazzini*'ye (sh. 46) göre ise, BK m. 366'daki ücretin yaklaşık olarak belirlenmesi sadece bağlayıcı olmayan masraf tahmini olduğu halde, BK m. 367/I gereğince yapılan masraf tahmini ise yüklenicinin aşırı ölçüde tecavüz

Uygulamada yaklaşık bedel tesbitine az rastlanmaktadır; daha çok muhtemel masraflara ilişkin keşif bedelinin yaklaşık olarak tayini yoluna gidilir ve bu takdirde işin sonunda bedel de TBK m. 481 uyarınca fiilen yapılmış masraflara göre tayin edilir. Uygulamada yaklaşık keşif bedelinin yaklaşık bedel olarak adlandırılmasının sebebi de budur[24].

Genellikle yükleniciler işi almak için yaklaşık keşif bedelini düşük tesbit ederler ve işsahibinin meslekten olan yüklenicilere olan güveninin boşa çıkması tehlikesi doğar.

İş sahibinin karşılaşacağı bu tehlikeye karşı korunması için TBK m. 482 hükmü sevkedilmiş bulunmaktadır. Buna göre, yaklaşık bedelin işsahibinin kusuru bulunmaksızın aşırı ölçüde aşılacağının anlaşılması halinde her aşamada sözleşmeden dönmek mümkündür.

4. Bedelin önceden kararlaştırılmamış olması

TBK m. 481, tarafların bedel miktarını önceden sözleşmeyle kararlaştırmamış olmaları halinde, ödenecek bedelin yapılan şeyin değerine ve yüklenicinin masraflarına göre belirleneceğini hükme bağlamıştır. Bu maddede, bedelin hiç belirlenmemiş olmasından başka, yaklaşık olarak tesbit edilmesi haline de yer verilmiştir. Yukarda da ifade edildiği gibi, yaklaşık bedel tesbiti halinde, TBK m. 481'de öngörülen kri-

---

edemiyeceği ve onu bağlıyan standart fiyattır (Richtpreis). *Gauch*'a (N. 936 vd.) göre, ücretin yaklaşık olarak kararlaştırılması ile muhtemel masrafların (keşif bedelinin) yaklaşık olarak tesbitini (ungefahre Kostenansatz) birbirinden ayırmak gerekir. BK m. 367 anlamında masrafların yaklaşık olarak tesbitinde eser için ödenecek ücret değil, yapılacak masraflar yaklaşık olarak tesbit edilmektedir; bu şekilde bir masraf belirlenmesi eser sözleşmesinin bir unsuru olmayıp, yüklenici için bağlayıcı değildir; sadece işsahibinin sözleşme kurma iradesine temel teşkil eder (Geschaeftsgrundlage) (**Gauch**, N. 937-938; **Tercier**, N. 3717; OR-**Zindel/Pulver**, N. 5). Buna karşılık, BK m. 366 anlamında yaklaşık ücrette, önceden tesbit edilen veya sözleşmenin yorumundan çıkartılan bir alt ve üst sınır vardır (meselâ, ± % 10 veya en fazla 10 milyar/en az 8 milyar TL gibi) ve yüklenici bu sınırla bağlıdır. Yüklenicinin masrafı ve işin değeri daha çok veya daha az da olsa, işsahibi bu sınır çerçevesinde bir ücret ödemekle yükümlüdür (**Gauch**, N. 940-941. Ayrıca bk. OR-**Zindel/Pulver**, Art. 368, N. 6). Somut olayda bunlardan hangisinin söz konusu olduğu güç bir yorum meselesidir; şüphe halinde ücret borçlusu işsahibi lehine olan yorum tercih edilmelidir (**Gauch**, N. 941).

[24] **Tandoğan** II, sh. 281.

terler, kararlaştırılan alt ve üst sınır içinde kalınmak kaydıyla uygulanabilir[25].

Gauch'a göre[26], TBK m. 481'de yer alan eserin değeri ve yüklenicinin giderleri deyimlerini "yüklenicinin giderleri" deyimi altında değerlendirmek gerekir; işin değeri, daha geniş olan masraf deyimine girer. Böylece TBK m. 481 gereğince yükleniciye ödenecek bedel, yüklenicinin eserin meydana getirilmesi için yaptığı masraflara ve genel giderlere uygun bir risk ve kâr ilâvesi yapılmak suretiyle tesbit edilir; bu tesbitte masraftan başka faktörlerin de etkili olduğu tamamlanmış eserin değeri nazara alınmaz.

Buna karşılık *Tandoğan*'a göre[27], "işin değeri" kavramından yüklenicinin yaptığı iş karşılığı elde edeceği kâr ve o işe düşen genel gider payları anlaşılır; yüklenicinin masrafı (giderleri) deyimi ise, işin görülmesi için başvurulan yardımcı şahıslara ve alt yüklenicilere ödenen bedeller ile işte kullanılan araç ve gereç giderleri ve yüklenicinin sağladığı malzemeler için yapılan harcamaları kapsar.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin içtihatları da *Tandoğan*'ın açıklamaları doğrultusundadır: "....yanlar arasında, davalıya ait evin elektrik tesisatının yapımını konu alan bir eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu ve davacının yüklendiği edimi yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, ücretin önceden belirlendiği yönü ispatsız kalmıştır. Öyleyse, eser ücretinin TBK m. 366 uyarınca çalışmanın (işin) değerine ve davacı yüklenicinin giderlerine göre saptanması gerekir... çalışmanın (işin) değeri kavramından, yüklenicinin yaptığı iş karşılığı elde edeceği kâr ve o işe düşen giderler payı anlaşılmalıdır. Yüklenicinin giderleri, sözleşmenin konusunu oluşturan eserin yaratılması için başvurulan yardımcı kişilere ve alt yüklenicilere eylemli olarak ödenmiş ücretleri, işte kullanılan araç ve âletler için yapılmış giderleri ve yüklenicinin sağladığı gereçler için giriştiği harcamaları kapsar. Ne var ki, yüklenicinin kötü niyetle yaptığı nesnel (objektif) yönden yararsız giderler ücretin hesaplanmasında hesaba katılmaz. Bu giderlerin eylemli olarak yapıldıkları zamandaki tutarının göz önünde bulundurulması gerekir. Buna karşılık çalışmanın (işin) değeri gerçek gider ve harcamaların

---

25 **Gauch**, N. 941 ve 968; **Tandoğan** II, sh.297.

26 **Gauch**, N. 947-948. Aynı yönde: OR-**Zindel/Pulver**, Art. 374, N. 12 vd. Ayrıca bk. **Pedrazzini**, sh. 46.

27 **Tandoğan** II, sh. 299.

belirli bir oranı olarak hesaben bulunacağına ve eser için gereken tüm gider ve harcamalar tamamlandıktan sonra bu hesap işlemine girişileceğine göre, çalışmanın değeri eserin teslim anındaki rayiçlere dayanılarak belirlenmelidir ki, çalışmanın (işin) değeri, yani yüklenicinin brüt kârı, yapılan gider ve harcamalara işletme ekonomisi esaslarına göre belli oranda eklenecek, hesaben bulunan bir tutardır. Meslek kuruluşlarının en az (asgarî) ücret tarifeleri, Bayındırlık Bakanlığı'nın birim fiyat listeleri, bunlar yoksa o meslekte yürüyen alışkanlıklar (teamüller) göz önünde tutularak yüklenicinin işinin değeri saptanmalıdır (Tandoğan, sh. 113/114)" (15. HD, 6.5.1980, E. 1017/K. 1169, Uygur, İnşaat, c. 1, sh. 1023); 15. HD, 31.5.1978, E. 1123/K. 1176 (Karahasan, İnşaat İmar İhale Hukuku, İstanbul 197, C. 1, sh. 1548-1549).

5. Bedel borcunun ifa zamanı, temerrüt ve sonuçları

Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, işsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur (TBK m. 479/I).

İş sahibi bedelin ödenmesinde temerrüde düşerse, yüklenici TBK m. 125'de öngörülen seçimlik haklardan birini kullanabilir.

Yüklenicinin yükümlerini ağır kusuruyla hiç veya gereği gibi ifa etmemesi dışında eser sözleşmesinden doğan alacakları, muacceliyet tarihinden itibaren beş yıl içinde zamanaşımına uğrar (TBK m. 147/ b. 6); BİGŞ'ne tâbi yapı işlerinde beş yıllık zamanaşımı süresi kesin hesabın çıkarılması gününden itibaren işlemeye başlar[28].

TBK m. 479/II gereğince, eser parça parça teslim edildikçe bedelin ödenmesi kararlaştırılmış ise, her kısmın bedeli o kısmın teslim edildiği tarihte muaccel olur.

---

[28] **Tandoğan** II, sh. 316 ve dipnot 192'deki 15. HD, 21.5.1973, E. 319/K. 167 sayılı karar.

§ 28. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Eser sözleşmesi, her sözleşme gibi, kendisinden doğan bütün borçların zamanında ve gereği gibi ifa edilmesiyle sona erer. Aşağıda ifa dışındaki sona erme sebepleri üzerinde durulmuştur.

I. Yaklaşık bedelin (keşif bedeli) aşırı ölçüde aşılması sebebiyle sözleşmeden dönme

1. Genel olarak

TBK m. 482/I, yüklenici ile önceden belirlenen yaklaşık bedelin (masraf tahmininin), işsahibinin kusuru olmadan aşırı ölçüde aşılması halinde, işsahibine gerek eserin meydana getirilmesi esnasında gerek meydana getirildikten sonra sözleşmeden dönme hakkı vermektedir. Böyle bir durumda, temel hatasının özel olarak düzenlenmiş bir şekli söz konusudur[1].

2. Şartları

a) Yaklaşık bedel tahmini olarak tesbit edilmiş olmalıdır

Tarafların tahmini bir yaklaşık bedel (masraf tahmini) üzerinde anlaşmış olmaları gerekir. Bu keşif bedeli veya masraf tahmini bağlayıcı nitelikte olmayan ve sözleşmenin muhtevasına girmeyen, sadece eserin muhtemel maliyeti veya bedel hakkında yapılmış bir tahmindir[2]. Böyle bir durumda yüklenicinin ücreti, TBK m. 481'de öngörülen esaslara göre belirlenir[3].

b) Yaklaşık bedel aşırı ölçüde aşılmış olmalıdır

Sözleşmede öngörülen edimler için ödenmesi gereken nihaî bedelin keşif bedelinden yüksek olması halinde aşılma gerçekleşmiş olur[4].

---

1 **Gauch**, N. 937, 938; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N. 1; **Tercier**, N. 3719; **Engel**, sh. 428; BGE 115 II 461; 109 II 335 vd. Bk. ve karş. **Merz**, ZBJV 1991, sh. 255 vd.

2 **Gauch**, N. 937-939; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N.4 ve 5; **Tercier**, N. 3717; **Engel**, sh. 428; **Eren**, İnşaat, sh. 90.

3 **Tercier**, N. 3718; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N. 5; **Gauch**, N. 938, 966 vd ve 973; **Bucher**, BT, sh. 213.

4 **Tercier**, N. 3722 ve 3725; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N. 8.

Aşmanın aşırı olup olmadığı iş hayatındaki dürüstlük kuralının gereklerine göre tesbit edilir; bu konuda % 10'luk bir tolerans sınırı kabul edilmektedir[5]. Hâkim, somut olayın özelliklerine göre, takdir hakkını (MK. m.4) kullanarak sorunu çözümler.

c) Yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmasına işsahibi sebep olmamalıdır

Aşırı ölçüde aşılmaya işsahibinin kendisinin veya davranışından sorumlu olduğu kişinin sebep olması halinde, onun TBK m. 482'ye dayanması dürüstlük kuralına aykırı olur[6].

3. Sonuçları

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde, işsahibi TBK m. 482/I gereğince sözleşmeden dönebilir; sözleşmeden dönme geriye etkili (ex tunc) olup, yerine getirilmiş edimlerin iadesi sözleşmeye dayanan tasfiye ilişkisi çerçevesinde gerçekleşir[7].

Buna karşılık, işsahibinin arsası üzerinde yapılmış inşaatlarda, yapılan iş mütemmim cüz'ü ilkesi (MK m. 648) gereğince arsa sahibinin mülkiyetine geçeceği için TBK m. 482/II iki seçimlik imkân öngörmektedir. Buna göre işsahibi, bedelden uygun bir miktar indirilmesini isteyebilir veya inşaat henüz tamamlanmamış ise, sözleşmeden dönebilir; dönme halinde işsahibi, yapmış olduğu kısım için yükleniciye hakkaniyete uygun bir bedel ödemek zorundadır. İnşa eserinin tamamlanması halinde, işsahibi sözleşmeden dönemez[8].

II. Yüklenicinin zararını tamamen tazmin suretiyle fesih

TBK m. 484'e göre, "İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir". İş sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için borçlanılan eserin tamamlanmamış olması yeterli olup, ayrıca onun haklı bir sebebe dayanması gerekli değildir.

---

5 **Gauch**, N. 985; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N. 10, 12; **Tercier**, N. 3725.

6 **Tercier**, N. 3724; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 375, N. 16.

7 **Gauch**, N. 976; **Tandoğan** II, sh. 289.

8 **Tercier**, N. 3730.

TBK m. 484'de geçen, "yüklenicinin bütün zararlarını gidermek" deyimi tam tazminatı, yani yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesine olan menfaatini karşılayan "müsbet zararın" tazminini ifade eder[9].

Müsbet zarar kavramına, fiilî zarar ile yoksun kalınan kâr unsurları dahildir. Fiilî zarar olarak, işsahibi, yüklenicinin sözleşmenin ifası için yaptığı bütün harcamaları tazmin etmek zorundadır[10]. TBK m. 484'de geçen "yapılmış olan kısmın bedelini ödemek" ibaresinin kapsamına, harcanan emek ve fiyata dahil edilmeyen her türlü masraflar (hazırlık çalışmaları ve yüklenicinin getirdiği malzemeler gibi) girer; bunların hesaplanmasında sözleşmede öngörülen fiyatlandırma hükümleri (meselâ birim fiyatları), böyle bir hüküm yoksa TBK m. 481 hükmü uygulanır[11].

İş sahibi, yüklenicinin yoksun kaldığı kârın tamamını tazmin etmek zorundadır. Zira TBK m. 484, yapılmış olan kısmın bedelinden başka, yüklenicinin bütün zararlarının giderilmesini de öngörmektedir[12]. Bununla beraber, yoksun kalınan kârın hesabında, yüklenicinin sözleşmenin feshinden sonra boş kalması yüzünden başka bir iş bularak fiilen elde ettiği kâr ile başka bir iş yapmaktan kasden kaçınarak kazanamadığı kâr düşülür[13]. Bunun için fesihle diğer işten elde edilen kâr arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır; yüklenicinin fesih olmadan da elde edeceği kâr düşülmez[14].

İş sahibinin yükleniciye ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında biri toplama metodu (müsbet metod), diğeri kesinti (tenzil) metodu olmak üzere başlıca iki metod vardır.

---

9 **Becker**, Art. 377, N. 6; **Oser/Schönenberger**, Art. 377, N. 3; **Gauch**, N. 542 vd; **Gautschi**, Art. 377, N. 13; **Pedrazzini**, sh. 52-53; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 15; **Tandoğan** II, sh. 347-348; BGE 117 II 277; 15.HD, 26.5.1983, E. 1033/K. 1419 (YKD 1984, sh. 1512-1513); 15. HD, 16.10.1989, E. 1623/K. 4247 (YKD 1990, sh. 583).

10 OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 13; **Gauch**, Baurecht 1991, sh. 97 vd.

11 **Gauch**, N. 529 vd; aynı yazar, FS für H.Locher, München 1990, sh. 37; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 13.

12 **Gauch**, N. 546; aynı yazar, FS für Locher, sh. 38; **Pedrazzini**, sh. 53, dn. 28'e ait metin; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 15; BGE 69 II 191; 15. HD, 16.10.1989, E. 1623/K. 9247 (YKD 1990, sh. 583).

13 **Gauch**, N. 546; aynı yazar FS für Locher, sh. 39; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 15; 15. HD, 25.10.1973, E. 230/K. 184 (**Tandoğan** II, sh. 348, dn. 95).

14 **Gauch**, FS für Locher, sh. 39.

Kesinti metodunda işsahibi, yükleniciye, işin tamamlanmamasından dolayı yaptığı tasarrufla, başka bir işten elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği kârın kararlaştırılan bedelden düşülmesi suretiyle bulunacak meblağı ödemek zorundadır[15]. Diğer bir ifade ile sözleşmenin feshi tarihinde eserin hiç yapılmamış olması halinde tüm iş bedeli, kısmen yapılmış ise imal edilmemiş kısmın bedeli belirlenir. Bu bedelden yüklenicinin işi tamamen veya kısmen tamamlamamamış olması nedeniyle yaptığı tasarruf ile bu süre içinde yaptığı başka bir işten elde ettiği kâr ya da kasıtlı olarak kaçırdığı kâr miktarı çıkarılır. Elde edilen meblağ fesih sebebiyle ödenmesi gereken tazminatı ifade etmektedir[16].

Toplama metodunda (müsbet metodda) ise, feshe kadar yapılan harcamalar ile işin tamamlanması halinde elde edilecek gayri sâfi (brüt) kârın toplamı işsahibi tarafından yükleniciye ödenecektir. Bu kârın, sözleşme, tarifeler, yüklenicinin defterleri ve diğer emarelere göre tesbit edilmesi esası kabul edilmektedir[17].

Doktrinde mevcut yeni temayüller, haklı olarak, toplama metodunun TBK m. 484 hükmüne uygun olduğunu kabul etmektedir[18]. İsviçre Federal Mahkemesi, önce toplama metodunu uyguladığı[19] halde, sonra[20] meseleyi kesin olarak çözümlemekten kaçınmıştır. Yargıtay 15. HD'ne göre[21], "Davalıların, inşaata başlamadan önce TBK m. 484 hükmü doğrultusunda sözleşmeyi feshettikleri anlaşılmaktadır. O halde anılan madde ile düzenlenen toplama sistemi uygulanarak davacının olumlu ve olumsuz tüm zararlarının ödettirilmesi gerekir. Toplama sisteminde uygulanacak usulde, yüklenicinin fesih anına kadar kâr un-

---

15 **Gauch**, N. 551; **Gautschi**, Art. 377, N. 15 a; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 16; **Tandoğan** II, sh. 348; BGE 96 II 198.

16 Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 356. maddesi delaletiyle 325. maddesine göre kesinti metodu uygulanıyordu. Bkz. 15. HD. 2.7.2014 tarih E. 2013/4839 K. 2014/4650 –Kazancı-.

17 **Gauch**, N. 546 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 16; **Pedrazzini**, sh. 52-53; **Tandoğan** II, sh. 348; BGE 96 II 198; 15. HD. 2.7.2014 tarih E. 2013/4839 K. 2014/4650 –Kazancı-..

18 **Gauch**, FS für Locher, sh. 39-40; **Pedrazzini**, sh. 52-53 ve dn. 27; **Tercier**, N. 2748; **Dessmontet**, sh. 198; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 377, N. 17.

19 BGE 69 II 145, cons. 5.

20 BGE 96 II 197.

21 15. HD, 16.10.1989, E. 1623/K. 4247 (YKD 1990, sh. 583).

suru hariç olmak üzere, yaptıkları gerçek giderlere eser bitmiş olsaydı sağlayabilecekleri net kâr eklenerek zararın tesbiti yapılır. Kâr oranı, her somut olayın özelliğine, yapılması kararlaştırılan inşaatın nitelik ve niceliğine, yöredeki piyasa rayiçlerine göre saptanmalıdır".

III. Eserin yok olması

Eser sözleşmesinde eserin yok olması, aşağıdaki üç sebepten ileri gelebilir.

1. Umulmayan bir olay sebebiyle eserin yok olması

a) Genel olarak

"Yapılan şeyin telefi = eserin yok olması" başlığını taşıyan TBK m. 483/I'e göre, eser teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu (kazara) yok olursa, işsahibi onu teslim almakta temerrüde düşmüş olmadıkça, yüklenici ne yaptığı işin bedelini ne de giderlerin ödenmesini isteyebilir. Bu durumda, telef olan malzeme kime ait ise, hasar da ona ait olur (TBK m. 483/I, son c.).

b) Şartları

aa) Eser kısmen veya tamamen yok olmalıdır

Umulmayan hal sonunda eser kısmen veya tamamen yok olmalıdır; TBK m. 483'ünn uygulanması açısından, yok olma anında eserin tamamlanmış olup olmaması önemli değildir[22].

bb) Eser umulmayan bir olay sonunda yok olmalıdır

Eser umulmayan bir olay sebebiyle yok olmalıdır. Eserin işsahibinin ve yüklenicinin sorumlu olmadığı bir sebep yüzünden yok olması halinde bu şart gerçekleşmiş olur; mücbir sebep de TBK m. 483 anlamında umulmayan bir olay sayılır[23].

cc) Eser teslim edilmemiş olmalıdır

Eserin teslimden önce yok olması gerekir; teslimden sonra umulmayan bir olayın sonuçlarına işsahibi katlanır.

---

[22] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 9; **Gauch**, N. 1184; **Koller**, sh. 3 vd; **Bühler**, Art. 376, N. 10; **Tercier**, N. 3795.

[23] **Gauch**, N. 1187; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 11; **Gautschi**, Art. 376, N. 3a, b; **Pedrazzini**, sh. 47, dn. 2; **Koller**, j., sh. 5 vd. ve 10; **Tercier**, N. 3796.

dd) İş sahibi mütemerrit olmamalıdır

İş sahibi, yüklenicinin sözleşmeye uygun bir şekilde ifa olarak arzettiği eseri, haklı bir sebep olmadan teslim almazsa alacaklının temerrüdüne düşer (TBK m. 106) ve eserin yok olma riski kendisine ait olur.

c) Sonuçları

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde bedele ilişkin hasar yükleniciye aittir; o, işin bedelini ve yaptığı masrafların ödenmesini işsahibinden talep edemediği gibi, daha önce kendisine yapılan ödemeleri de iade etmek zorundadır[24]. TBK m. 483/I, son c. gereğince yok olan malzemenin hasarı, onun ait olduğu, yani onu sağlayan tarafa aittir. Bu hüküm malzemenin işsahibi tarafından sağlandığı takdirde bir değer taşır; yüklenicinin malzemeyi bizzat sağlaması halinde TBK m. 483/I hükmü uygulanır[25]. Bedel (ücret) hasarının yükleniciye ait olması kuralının (TBK m. 483/I) iki istisnası vardır. Bunlardan birincisi işsahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi, diğeri ise TBK m. 483/II'de öngörülen durumdur[26].

Edim hasarını, bedel (ücret) hasarından ayırmak gerekir. Edim hasarı (Leistungsgefahr) kavramı eserin umulmayan bir olay sebebiyle yok olması halinde, yüklenicinin eser meydana getirme edimini yerine getirmekle yükümlü olup olmadığı sorusuna ilişkindir. Edim hasarı, bedel (ücret) hasarını taşıyan tarafa aittir. Buna göre, TBK m. 483/I'deki şartların bulunması halinde, yüklenici, eserin meydana getirilmesi objektif olarak mümkün oldukça, bunu yerine getirmekle yükümlüdür; bu yüküm, objektif imkânsızlık halinde sona erer[27]. Kısmen veya tamamen yok olan eseri tekrar meydana getiren yüklenici, kararlaştırılan veya TBK m. 481'e göre belirlenecek bedeli talep edebilir; ek masrafın tazminini isteyemez. Eseri yeniden meydana getirme veya sözleşmeye devam, dürüstlük kuralı gereğince yükleniciden beklenemiyorsa, o, önemli sebeplerden dolayı sözleşmeyi sona erdirebilir[28];

---

[24] **Koller**, j., sh. 18; **Gauch**, N. 1184; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 2; **Bühler**, Art. 376, N. 22; **Tercier**, N. 3800.

[25] **Tercier**, N. 3802.

[26] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 30; **Gauch**, N. 1191 ve 1194; **Koller**, j., sh. 37.

[27] **Koller**, j., sh. 80; **Gauch**, N. 1203 ve 718 vd.; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 32 ve 33; **Bühler**, Art. 376, N. 26.

[28] **Gauch**, N. 1205; **Koller**, J., sh. 82 vd; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 33.

bu hususta TBK m. 480/II'de öngörülen kriterlerden yararlanmak gerekir. Eserin kısmen veya tamamen yok olması yüzünden edimini ifa için ek masraf yapmak zorunda kalan yüklenici, şartları varsa TBK m. 480/II'ye dayanabilir[29].

Tamamlanınca ferdi ile belirli olan ve yenisinin yapılması mümkün olmayan bir eser bitirildikten sonra teslim edilmeden önce veya tamir için verilen ferdi ile belirli bir eser, geri verilmeden önce umulmayan bir olay yüzünden yok olursa, yüklenicinin borcu TBK m. 136/I gereğince sona erer[30].

Yukarda da ifade edildiği gibi, işsahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi (TBK m. 483/I) ve TBK m. 483/II'te öngörülen hususların gerçekleşmesi halinde bedel hasarı işsahibine aittir. Gerçekten TBK 483/II'ye göre, "Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır".

Bedel hasarının işsahibinde olduğu bu durumlarda, edim hasarı da ona ait olur; yüklenici kural olarak, yok olan eseri yeniden meydana getirmekle yükümlü değildir[31]. Eser sözleşmesi sona erer. TBK m. 483'de sona ermeden bahsedilmemekle beraber, bu madde sona ermeyi düzenleyen hükümler arasında yer almaktadır[32].

2. İş sahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması

TBK m. 485'e göre, "Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir (f. 1). İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır (f. 2)". Bu madde işsahibinin sorumlu olduğu durumlar sebebiyle eserin tamamlanmasının imkânsızlaşmasını düzenlemektedir.

---

29 **Koller**, J., sh. 48 vd.; **Gauch**, N. 1205; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 33.
30 **Tandoğan** II, sh. 317; **Koller**, J., sh. 43 vd.
31 **Gauch**, N. 1206; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 376, N. 32; **Koller**, J., sh. 78.
32 **Gauch**, N. 1206; **Koller**, J., sh. 78 ve dn. 190.

a) Şartları

aa) Eserin tamamlanması imkânsız olmalıdır

TBK m. 485'in uygulanabilmesi için, eserin tamamlanmasının imkânsız olması gerekir. Burada söz konusu olan imkânsızlık objektif veya mutlak imkânsızlık olup, eserin meydana getirilmesi herhangi bir yüklenici için mümkün olmamalıdır[33].

TBK m. 485 anlamında imkânsızlık, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan objektif ve sürekli bir imkânsızlıktır. Bu tür imkânsızlık, yapımına henüz başlanmamış eserin yapımına veya yapımına başlanmış eserin tamamlanmasına engel olan bir imkânsızlık şeklinde olabilir[34]. Aynı şekilde, tamamlanıp da teslimi imkânsızlaşan eserler hakkında da TBK m. 485 hükmü uygulanabilir[35].

bb) İmkânsızlık işsahibinin şahsında veya tehlike alanında gerçekleşen umulmayan bir halden doğmalıdır

Bu şart, TBK m. 485/I'de " işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla" şeklinde ifade edilmiştir. Bu ifadeyi geniş anlamda anlamak gerekir[36]. Buna göre, eserin tamamlanmasına engel olan imkânsızlık, işsahibinin şahsında veya onun tehlike alanında (ilişkileri çevresinde) gerçekleşen bir umulmayan olaydan ileri gelmelidir[37].

İş sahibinin şahsını ilgilendiren sebeplere, ölçü üzerine bir elbise veya takma diş ısmarlayan işsahibinin ölmesi sebebiyle gerekli provaların yapılamaması örnek olarak gösterilebilir[38]. İş sahibinin tehlike alanına veya ilişkileri çevresine giren haller için şu örnekler verilebilir: Üzerinde inşaat yapılacak ve işsahibine ait arsanın kamulaştırılması, deprem veya toprak kayması sonucu inşaat yapılamayacak duruma

---

33 **Koller**, j., sh. 65; **Gauch**, N. 723, 719; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 11; **Bühler**, Art. 378, N. 11; **Pedrazzini**, sh. 49; **Buz**, sh. 26. Aksi fikirde: **Gautschi**, Art. 378, N. 5 ve 7.

34 **Gauch**, N. 723; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 13.

35 **Koller**, j., sh. 66-67; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 12; **Oser/Schönenberger**, Art. 378, N. 4; **Tandoğan** II, sh. 327-328; **Buz**, sh. 27.

36 **Pedrazzini**, sh. 49; **Buz**, sh. 27 ve dn. 27.

37 **Gauch**, N. 724; **Koller**, j., sh. 67; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 16; **Pedrazzini**, sh. 49; **Bühler**, Art. 378, N. 21; **Honsell**, sh. 250; **Buz**, sh. 27; **Engel**, sh. 431.

38 **Koller**, j., sh. 66; **Pedrazzini**, sh. 49; **Tercier**, N. 3817; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 14; **Tandoğan** II, sh. 327; **Buz**, sh. 27.

gelmesi[39]; üzerinde inşaat yapılacak arsaya yetkili makamlarca inşaat yasağı konulması veya işsahibinin önerdiği projeye izin verilmemesi[40].

b) Sonuçları

aa) Sözleşmenin ileriye etkili olarak sona ermesi

Yukarıda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, eser sözleşmesi, bir fesih beyanına ihtiyaç olmadan kanundan dolayı (ipso jure), ileriye etkili olarak sona erer; tarafların, eserin henüz tamamlanmamış kısmına ilişkin karşılıklı talepleri sona erer[41].

bb) Yüklenicinin ileri sürebileceği talepler

TBK m. 485/I gereğince yüklenici, sözleşmenin sona ermesine kadar yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen masrafların ödenmesini işsahibinden talep edebilir. Yüklenicinin bu bedel talebi hesaplanırken tarafların önceden kararlaştırdıkları bedel esas alınır. Meselâ, sözleşmeyle götürü bir bedel kararlaştırılmış ise, yükleniciye, bu bedelin onun fiilen yaptığı işlere tekabül eden kısmı ödenir[42].

Eserin tamamlanmasının imkânsızlaşmasına işsahibi kusuru ile sebebiyet vermiş ise, yüklenici müsbet zararının tamamının tazminini talep edebilir[43]. Talep edilecek bu tazminattan, yüklenicinin edim yükümünden kurtulma sonucu yaptığı başka işlerden elde ettiği veya dürüstlük kuralına aykırı olarak (kasten) elde etmeyi ihmal ettiği kazançlar indirilir[44]. İmkânsızlığın işsahibinin yardımcılarının (TBK m. 116) davranışından kaynaklanması halinde de, işsahibi TBK m. 485/II açısından sorumlu olur[45].

---

39 **Gauch**, N. 725; **Koller**, j., sh. 66; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 14; **Tercier**, N. 3817; **Tandoğan** II, sh. 327.

40 **Gauch**, N. 725; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 14; **Koller**, j., sh. 66; **Tandoğan** II, sh. 327.

41 **Gauch**, N. 732-733; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 17; **Dürr**, sh. 102; **Bühler**, Art. 378, N. 22.

42 **Gauch**, N. 730; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 18; **Koller**, j. sh. 68.

43 **Gauch**, N. 735; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 21; **Bucher**, BT, sh. 207; **Koller**, j. sh. 70; **Buz**, sh. 32.

44 **Gauch**, N. 735; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 21; **Buz**, sh. 32.

45 **Gauch**, N. 736; **Koller**, j. sh. 69; **Pedrazzini**, sh. 51, dn. 17; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 378, N. 20.

3. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi

a) Genel olarak

TBK m. 486'ya göre, "Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür".

TBK m. 486, sözleşmenin kurulmasından sonra, yüklenicinin şahsında ortaya çıkan umulmayan bir olay sebebiyle, onun ediminin imkânsızlaşmasını düzenlemektedir.

b) Şartları

aa) Eser sözleşmesi yüklenicinin kişisel özellikleri gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır

Eser sözleşmesi yüklenicinin kişisel nitelik ve özellikleri gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır. Bu durum, yüklenicinin eseri şahsen veya kendi idaresi altında meydana getirmekle yükümlü olduğu eser sözleşmelerinde söz konusu olur[46]. Yüklenicinin şahsen ifa veya kendi yönetimi altında yaptırma yükümü, sözleşmeyle kararlaştırılabileceği gibi, sözleşme konusu işin niteliğinden de (TBK m. 471/II) çıkartılabilir[47]. Yüklenicinin kişisel nitelikleri, onun bilgi ve uzmanlığı (yeni ve güç bir yöntemle yapılacak bir yapı işinde uzman mühendis olması) veya san'at gücü (ressam, heykeltıraş, kuyumcu veya terzi) şeklinde kendini gösterebilir[48].

bb) İşin bitirilmesi yüklenicinin ölümü veya kusuru olmaksızın işi yapmaktan aciz kalması dolayısıyla mümkün olmamalıdır

Yüklenicinin şahsı ve kişisel nitelikleri gözönünde tutularak yapılan eser sözleşmelerinde, diğer şahısların ifa edebilme imkânı nazara

---

[46] **Gauch**, N. 753; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 11; BGE 103 II 55.

[47] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 11; **Gauch**, N. 753; **Bühler**, Art. 379, N. 9.

[48] **Becker**, Art. 379, N. 2; **Tandoğan** II, sh. 332. 15. HD, 21.11.1989, E. 1739/K. 4859: "Borçlar Kanunu'nun 371. maddesine göre eser sözleşmesinde yüklenicinin ölümü halinde sözleşme yüklenicinin kişiliği nazara alınarak yapılmışsa sözleşme münfesih olur, somut olayımızda böyle bir durum yoktur. Yapılacak inşaat işinin herkes tarafından yürütülmesi mümkündür. Ancak yüklenilen iş bir sanat eseri niteliğinde, örneğin resim ve heykel yapımı vs. olması halinde sözleşme sona erer" (**Uygur**, İnşaat, C.1, sh. 1075).

alınamayacağı için, yüklenicinin ölümü veya işi yapma yeteneğini kaybetmesi, objektif imkânsızlığa yol açar[49]. TBK m. 486 anlamında imkânsızlık, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan ve sürekli bir imkânsızlıktır[50].

İşi yapmaktan aciz kalmanın, sadece bedensel bir özürden kaynaklanması şart değildir. Bir Federal Mahkeme kararında, işletmesini dağıtarak mesleğine son veren yüklenicinin gerekli personele sahip olmaması TBK m. 486 anlamında imkânsızlık sayılmıştır[51].

c) Sonuçları

Yukarıdaki şartlar gerçekleşince, eser sözleşmesi kanundan dolayı ve ileriye etkili olarak sona erer[52]. Böylece, tarafların eserin tamamlanmamış kısmına ilişkin hak ve borçları sona erer. Buna karşılık, eserin daha önce tamamlanmış kısmının kullanılması işsahibi için mümkün ise, işsahibi bu kısmı kabule ve bedelini ödemeye mecburdur (TBK m. 486/son c.).

TBK m. 486'da tazmin yükümünden söz edilmemektedir. Buna rağmen, yüklenici işi tamamlama yeteneğini kusurlu bir şekilde kaybetmiş (TBK m. 112) veya bu durum onun temerrütte bulunduğu zaman gerçekleşmiş (TBK m. 118) ise, o, işsahibinin müsbet zararını tazminle yükümlüdür[53].

---

[49] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 5; **Gauch**, N. 754; **Aepli**, Art. 119, N. 48; **Buz**, sh. 35.

[50] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 5; **Gauch**, N. 756; **Buz**, sh. 35.

[51] BGE 103 II 58. Aynı yönde: **Gauch**, N. 757; OR-**Zindel/Pulver**, Art 379, N. 9; **Buz**, sh. 35-36.

[52] OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 13; **Gautschi**, Art. 379, N. 4, 15, 17; **Gauch**, N. 754; **Tercier**, N. 3823. Aksi fikirde: **Pedrazzini**, sh. 54, dn. 36.

[53] **Gauch**, N. 767; OR-**Zindel/Pulver**, Art. 379, N. 17, **Tercier**, N. 3822; **Buz**, sh. 37.

İKİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

§ 29. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, KURULMASI VE KAPSAMI

I. Tanımı ve özellikleri

1. Tanımı

TBK m. 502/I'e göre, "Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir". Buna göre, vekâlet sözleşmesi, vekilin başkasının menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği bir sözleşme olarak tanımlanabilir[1]. *Tandoğan*, vekâlet sözleşmesini şu şekilde tanımlamaktadır: "Vekâlet öyle bir akittir ki vekile vekâlet verenin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nisbeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona ait olmamak üzere yükler"[2].

Bununla beraber bazı yazarlar[3], vekâlet sözleşmesini, BK m. 386/II'de yer alan, "Diğer akitler hakkındaki kanunu hükümlere tâbi olmayan işlerde dahi, vekâlet hükümleri cari olur" hükümlerini göz önünde tutarak tanımlamaktaydılar. Bunun sonucu olarak da, yukarda verilen tanıma, başka bir sözleşmenin şartlarının gerçekleşmemesi ibaresini eklemekteydiler. Böyle bir ilaveyi, iş görme sözleşmelerinde numerus clausus'un bulunduğu sonucuna götüreceği için isabetli bulmamakta idik. Ancak TBK m. 502/II'de "Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır" hükmü yer aldığından bu tartışmaya gerek kalmamıştır. Bu soruna ilerde (III) ayrıca temas edilecektir.

---

1 **Oser/Schönenberger**, Art. 394, N. 1; **Honsell**, sh. 266; **Bucher**, BT, sh. 223; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 340; **Fellmann**, Art. 394, N. 15; **Zevkliler**, sh. 360.

2 **Tandoğan** II, sh. 356.

3 **Tercier**, N. 3923; **von Büren**, BT, sh. 121 vd; **Peyer**, sh. 28 vd, 84-85; **Yavuz**, sh. 522.

2. Özellikleri

Vekâlet sözleşmesi aşağıdaki özellikleri taşır:

a) Vekâlet sözleşmesi borç doğuran ve rızaî bir sözleşmedir.

b) Vekâlet sözleşmesinde, TBK m. 502/III gereğince, sözleşmeyle kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde, vekil ücret talep edebilir. Bu şekilde vekâlet verenin ücret ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, vekâlet sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır. Buna karşılık, vekâlet verenin ücret ödeme borcunun bulunmaması halinde, vekâlet sözleşmesi, eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğindedir. Meselâ vekil, yüklendiği işi görürken bazı masraflar yapmak zorunda kalmışsa, vekâlet verenin bu masrafları ödeme borcu doğar (TBK m. 510). Vekâlet verenin bu borcu, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden farklı olarak, vekilin iş görme aslî edimiyle bir değişim (mübadele) ilişkisi içinde bulunmaz; tâli nitelikte bir borçtur[4].

c) Belirli bir işin görülmesini amaçlayan vekâletler hariç, vekâlet sözleşmesiyle taraflar arasında devamlı borç ilişkisine benzer bir ilişki doğar[5].

II. Unsurları

1. Bir işin görülmesi veya işlemin yapılması

TBK m. 502/ I'de yapılan tanıma göre, vekâlet sözleşmesinin konusunu hukuki işlemlerin yanında sırf maddi fiillerin yapılması da teşkil edebilir[6]. Vekâlet sözleşmesinde vekilin üstlendiği edim, daima

---

4 **Fellmann**, Art. 394, N. 193; **Tercier**, N. 3929; **Honsell**, sh. 266-267.

5 **Tercier**, N. 3926. Ayrıca bk. ve karş. **Fellmann**, Art. 394, N. 198 vd; **Werro**, N. 371 vd; OR-**Weber**, Art. 394, N. 4; Sadece bir havale işlemi yapılmak için vekâlet verilmişse, somut bir amaç söz konusu olduğundan sürekli borç ilişkisinden söz edilemez. Buna karşılık bir malın yönetilmesi veya bir işin görülmesinde vekil bir zaman diliminde faaliyet göstereceğinden sürekli borç ilişkisi hükümleri göz önünde tutulmalıdır.

6 **Fellmann**, Art. 394, N. 32; **Gautschi**, Art. 394, N. 2-3; **Derendinger**, N. 25; **Tandoğan** II, sh. 356; **Yavuz**, sh. 563. **Werro**'ya göre (N. 45 vd, 49 vd) 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanununda (OR) temsil yetkisi vekâletten ayrılmış olmakla beraber, bu iki kavram arasındaki sıkı ilişki muhafaza edilmişti. 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu, vekili vekâlet veren ile vekil arasında bir aracı (ıntermediare) olarak, yani başkası hesabına hareket eden bir dolaylı temsilci olarak görmekteydi. 1911 tarihli değişiklikle vekâlet bir aracılık sözleşmesi olmaktan çıkarılmış, kendi nam ve hesabına hareket ederek, maddî fiilleri yapmakla yüküm-

olumlu ve yapmaya (Tun) ilişkin bir davranıştır; yapmama veya katlanma edimleri ancak bir yan yüküm olarak taahhüt edilebilir[7].

Bir hukukî işlemin (satış, kira gibi) veya hukukî işlem benzerinin (ihtar veya mehil tayini gibi) başkası adına veya hesabına yapılması "hukukî fiillere ilişkin vekâletin" (Rechtshandlungsauftrag) konusunu teşkil eder[8]. Bu tür vekâletin konusuna giren hukukî fiiller, doğrudan doğruya veya dolaylı temsil yoluyla yerine getirilir; vekil vekâlet verenin doğrudan doğruya veya dolaylı temsilcisi olarak hareket eder[9]. Kat Mülkiyeti Kanunun 38. Maddesine göre yönetici kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludur. Yöneticinin vekâletinin kapsamı ise TBK m. 504'e göre belirlenecektir[10].

Buna karşılık maddî fiillerin yapılmasına ilişkin vekâlette (Tathandlungsauftrag) vekil herhangi bir maddî fiilin, fiilî bir hizmetin ifasını taahhüt eder[11]. Bu tür vekâlete, bir doktorun hastayı muayene ve tedavi etmesi[12], bir veterinerin bir hayvanı muayene ve tedavi etmesi, bir mimarın yapıyı kontrol etmesi, özel ders verilmesi, bir hukukçunun mütalaa vermesi, bir muhasebecinin defter tutması misal olarak gösterilebilir[13].

---

lü (meselâ bir doktor veya çalışmaları kontrolle yükümlü bir mimar gibi) bir borçlunun yaptığı sözleşme haline gelmiştir. Böylece o tarihe kadar hizmet veya eser sözleşmesi olarak nitelendirilen sözleşmeler vekâlet olarak telakki edilmiştir (N. 50). Aynı yönde: **Tercier**, N. 3932, 3917.

7 OR-**Weber**, Art. 394; **Fellmann**, Art. 394, N. 25; **Becker**, Art. 394, N. 6; **Tercier**, N. 3931; **Oser/Schönenberger**, Art. 394, N. 3; **Tandoğan** II, sh. 356; **Yavuz**, sh. 564.

8 OR-**Weber**, Art. 394, N. 10; **Fellmann**, Art. 394, N. 35; **Gautschi**, Art. 394, N. 4; **Tandoğan** II, sh. 356-357; **Yavuz**, sh. 564.

9 **Derendinger**, N. 27 ve dn. 61; OR-**Weber**, Art. 394, N. 10; **Gautschi**, Art. 394, N. 7; **Fellmann**, Art. 394, N. 10; **Tandoğan** II, sh. 357.

10 Bu nedenle, yöneticiye kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmemişe senetten şahsen sorumlu olur (12. HD. 22.12.2014 tarih E. 2014/23189 K. 2014/31067 –Kazancı-).

11 OR-**Weber**, Art. 394, N. 9; **Fellmann**, Art. 394, N. 79; **Tandoğan** II, sh. 359; **Yavuz**, sh. 563.

12 Hekimin hastasını aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sağlıkla ilgili her türlü girişimsel muamele kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Aydınlatılmış onam konusunda ispat yükü hekim veya hastanededir (bkz 13. HD. 15.9.2014 tarih E. 2013/26330 K. 2014/27050 –Kazancı-).

13 OR-**Weber**, Art. 394, N. 9; **Fellmann**, Art. 394, N. 84; **Tandoğan** II, sh. 359-360; **Yavuz**, sh. 563; **Zevkliler**, sh. 360-361.

2. İşin başkasının menfaatine yapılması

Vekilin gördüğü işin başkasına ait olması ve onun menfaatine yapılması gerekir. Sırf vekilin menfaatine yapılan bir faaliyet vekâlet sözleşmesine konu olamaz[14]. Bununla beraber, hem vekil, hem vekâlet veren yararına vekâlet sözleşmesinin kurulması da mümkündür. Meselâ vekâlet verenin, vekile olan borcunu ödeyebilmesi için, kendisine ödünç para verecek bir kişi bulunması işini vekile gördürmesi[15].

Vekilin, vekâlet verenin görülen işten elde ettiği menfaate katılması da mümkündür. Böyle bir durumda tarafların menfaatleri farklı nitelikte olduğu için sözleşmeyi âdi şirket değil, vekâlet olarak nitelendirmek gerekir[16]. Meselâ bir artist menajerliği sözleşmesinde, artistin hem meslekî kariyer elde etmek, hem malî açıdan yararı olduğu halde, menajerin menfaati sadece malî açıdan fazla komisyon almaktır[17]. 1136 sayılı Avukatlık K m. 164/II'ye göre, "yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir". "İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz (f.III)[18].

Vekâlet verenin vekilin yaptığı iş için bir ücret ödemekle yükümlü olması (TBK m. 502/III), hem vekâlet veren, hem vekil yararına vekâletin bulunduğu anlamına gelmez. Bu durumda, vekilin ücrete ilişkin menfaati vekâlet verenin (başkasının) işin görülmesindeki menfaatine oranla tâli bir nitelik taşır; bu nedenle, vekil ücretini artırmak için yapacağı faaliyetlerini genişletmek imkânına sahip değildir[19].

---

[14] **Fellmann**, Art. 394, N. 105; **Hofstetter**, sh. 34 vd; **Derendinger**, N. 35-37; **Gautschi**, Art. 394, N. 44a; Art. 398, N. 3a; OR-**Weber**, Art. 394, N. 2; **Werro**, N. 154; **Engel**, sh. 449; **Tandoğan** II, sh. 360-361; **Yavuz**, sh. 567.

[15] **Hofstetter**, sh. 37; **Engel**, sh. 449; **Fellmann**, Art. 394, N. 106.

[16] **Werro**, N. 156; **Fellmann**, Art. 394, N. 106; **Gautschi**, Art. 394, N. 60 a vd; **Tandoğan** II, sh. 362.

[17] BGE 104 II 108 yahut JdT 1980 I, sh. 80-81.

[18] 13. HD, 13.9.1994, E. 6066/K. 7489: "...Buna göre, "hasılı" davaya iştirak niteliğinde olmamak, davada gösterilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmi beşi aşmamak üzere dava olunan veya hükmedilecek şeyin belli bir yüzdesi Avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilecektir" (**Tanrıver/Tercan/Deynekli**, Avukatlık Kanunu, Ankara 1996, sh. 88).

[19] **Fellmann**, Art. 394, N. 108; **Werro**, N. 155; **Derendinger**, N. 37 ve dn. 99, 154, 424; **Hofstetter**, sh. 34 ve 37. Bk. ve karş. OR-**Weber**, Art. 394, N. 8. Aksi fikirde: **Gautschi**, Art. 394, N. 45 a ve 73 a; **Tandoğan** II, sh. 361; **Yavuz**, sh. 568.

3. Vekilin edim sonucundan değil, edim fiilinden sorumlu olması ve bağımsız olarak iş görmesi

Vekil, kendisine bırakılan işi veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. O, vekâlet sözleşmesiyle, bir edim sonucunu değil, belirli bir sonuca yönelik edim fiilinde bulunmayı taahhüt etmektedir. Vekil yüklendiği iş görme edimini özenle yerine getirmekle yükümlü olup, istenen sonucun gerçekleşmemesinden sorumlu değildir[20]. Fransız hukukunda yerleşmiş olan bir deyimle burada bir sonuç borcunun (obligation de résultat) değil, vasıta borcunun (obligation de moyens) bulunduğu ifade edilmektedir[21].

Hizmet akdinde işçinin durumundan farklı olarak, vekil işin görülmesi bakımından bağımsız bir duruma sahiptir; işi görürken vekâlet verenin iş organizasyonuna dahil bir kişi olarak hareket etmez[22]. Vekilin bağımsızlığı sadece işin görülmesinde vekâlet verenin talimatlarına uyma (TBK m. 3505) açısından sınırlandırılmıştır. Bunun dışında vekil faaliyetlerini zaman, yer ve iş görme şartları açısından serbestçe düzenler (organize eder)[23].

4. Ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığında iş görme

Vekâlet sözleşmesinde vekile ücret ödenmesi bu sözleşmenin zorunlu ve kanunî bir unsuru değildir. Gerçekten, TBK m. 502/III'e göre, sözleşmede öngörülmüşse veya teamül varsa, vekil ücrete hak kazanır.

Vekâleti bir dostluk ve hatır işi, bir şeref hizmeti olarak gören Roma Hukukunun izlerini taşıyan bu hüküm[24], günümüzdeki uygulamayla paralellik arz etmemektedir. Günümüzde vekâletin daha çok ücretli olduğu hususunda fiilî bir karine mevcuttur[25].

Vekâletin ücretli olacağı genellikle sözleşmenin kurulması sırasında kararlaştırılır; fakat ücret anlaşmasının daha sonra kararlaştırılması

---

20 **Felmann**, Art. 394, N. 97 vd; OR-**Weber**, Art. 394, N. 2; **Tercier**, N. 3936; **Derendinger**, N. 91; **Engel**, sh. 449 ve 450; **Werro**, N. 91 vd; **Neuenschwander**, sh. 22 vd; **Tandoğan** II, sh. 364.

21 **Werro**, N. 88 vd; **Knoepfler/Guinand**, FjS, Nr. 327, sh. 2; **Tercier**, N. 3936; **Merz**, SPR VI/1, sh. 121.

22 **Hofstetter**, sh. 16 vd ve 34; **Derendinger**, N. 33; **Fellmann**, Art. 394, N. 113.

23 **Derendinger**, N. 33; **Fellmann**, Art. 394, N. 114 vd.

24 Bu konuda bk. **Fellmann**, Art. 394, N. 363 vd; **Gautschi**, Art. 394, N. 70-72; **Tandoğan** II, sh. 365.

25 OR-**Weber**, Art. 394, N. 366; **Fellmann**, Art. 394, N. 366.

da mümkündür[26]. Ücret anlaşmasının açık veya örtülü (zımnî) irade beyanıyla gerçekleşmesi mümkündür[27]. Anlaşmazlık halinde, ücret anlaşmasının bulunduğunu ispat vekile düşer[28].

Tarafların ücreti kararlaştırmamaları halinde, vekile ücret ödenmesi konusunda bir teamül varsa, vekâlet veren ücret ödemek zorundadır. Böyle bir teamül bulunduğu takdirde, tarafların ücret anlaşması yapmalarına veya teamülü sözleşmede zikretmelerine gerek olmadan ücret yükümü doğar[29].

İş görmenin bir serbest meslek olarak yapıldığı hallerde ücret ödenmesi teamülden sayılır[30]. Bu cümleden olarak, hekimlerin, mimarların, muhasebecilerin ve bankaların bir ücret karşılığında iş görmeleri teamüldendir[31].

Vekilin ücret isteme hakkı bazı özel kanunlarla da öngörülmüş olabilir: MK m. 550/IV (vasiyeti yerine getirme görevlisi); 1136 sayılı Avukatlık K. m. 163 ve 164; Noterlik K. m. 112 vd.

III. Vekâlete ilişkin hükümlerin tâli olarak uygulanması

TBK m. 502/II'ye göre, "Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır". Bu hüküm İsviçre Borçlar Kanununun Almanca metninde (OR Art. 394/II) şu şekilde ifade edilmiştir: "Bu kanunun (düzenlediği) özel sözleşme türlerinden hiçbirine tâbi olmayan iş görme sözleşmelerine vekâlete ilişkin hükümler uygulanır".

İsviçre Borçlar Kanunu'na 1911 yılında yapılan değişiklikle giren bu hükmün anlamı son derece tartışmalıdır.

---

26 **Fellmann**, Art. 394, N. 368; **Gautschi**, Art. 394, N. 74 a ve 74 b; **Tandoğan** II, sh. 365.

27 **Bucher**, BT, sh. 233; **Hofstetter**, sh. 58; **Fellmann**, Art. 394, N. 369; OR-**Weber**, Art. 394, N. 36; **Weber**, Praxis zum Auftragsrecht, sh. 69; **Derendinger**, N. 413; **Werro**, N. 712. Aksi fikirde olan **Gautschi**'ye göre (Art. 394, N. 74c), ücret ödenmesi teamülden değilse, tarafların susması vekâletin ücretsiz olduğuna karine teşkil eder.

28 **Werro**, N. 718; **Fellmann**, Art. 394, N. 372.

29 **Fellmann**, Art. 394, N. 373.

30 **Hofstetter**, sh. 59; **Knoepfler/Guinand**, FjS, Nr. 328, sh. 5; **Tercier**, N. 4118; **Fellmann**, Art. 394, N. 380.

31 **Tercier**, N. 4118; **Tandoğan** II, sh. 366.

Gautschi tarafından savunulan bir fikre göre[32], hizmet ve eser sözleşmesine konu olamayan her türlü iş görme sözleşmeleri TBK m. 502/II hükmü sebebiyle vekâlet sözleşmesi olarak nitelendirilir. Bu itibarla, iş görme sözleşmelerinde kendine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşme imkânı bulunmamaktadır. Böylece bu alanda kanunî tiplerin sınırlı sayıda olması (numerus clausus) kabul edilmiş olmaktadır[33]. İsviçre Federal Mahkemesi de bir ara içtihatlarını[34] Gautschi' nin görüşleri doğrultusunda değiştirdi[35].

Buna karşılık, bizim de katıldığımız hâkim fikre göre[36], TBK m. 502'ye eklenen II. fıkra hükmü iş görme sözleşmelerinde isimsiz sözleşmelerin kurulmasını engellememektedir. Nitekim, "bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmeleri" terkibi ile vekâlet dışında işgörme sözleşmeleri kurulabilecği açıkça düzenlenmiştir. Bu tür sözleşmelere ise vekâlete ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilecektir. Söz konusu düzenleme ile Türk Hukuku bakımından zikredilen tartışma konusu aydınlığa kavuşturulmuştur. Diğer yandan 818 sayılı Borçlar Kanunu bakımından, İsviçre Borçlar Kanununun 1911 yılında revizyonu esnasında yapılan çalışmalardan ve ileri sürülen fikirlerden de anlaşılacağı üzere, bu fıkra hükmünün kabulüyle vekâlet hukukunda maddî bir değişiklik yapılması amaçlanmamıştır; değişiklikle, vekâlet sözleşmesi ile hizmet ve eser sözleşmeleri arasında açık bir sınır tesbiti sağlamak ve serbest meslek faaliyetlerini vekâlet hükümlerine tâbi tutmak istenmiştir[37]. Doktrinde yapılan haklı tenkitler üzerine İsviçre Federal Mahkemesi de, *Gautschi*'nin etkisiyle verdiği kararları terkederek, eski içtihadına dönmüştür[38]. Bu durumda TBK m. 502/II hükmünün anlamını şu şekilde tesbit etmek uygun olur: Kanunda düzenlenen diğer sözleşme tiplerine uymayan ve tarafların açıkça isimsiz

---

32 Art. 394, N. 56; Art. 396, N. 66 a; **Yavuz**, sh. 566 vd.

33 **Peyer**, sh. 168; **Naef**, Temporaere Arbeit, Bern 1971, sh. 48.

34 BGE 60 II 336; 61 II 106; 63 II 177; 83 II 529.

35 BGE 104 II 110; 106 II 159.

36 **Bucher**, ZSR 1983/II, sh. 286 vd ve dn. 38, sh. 324; **Leuenberger**, sh. 26 vd, özellikle sh. 46 vd; **Fellmann** Art. 394, N. 285 vd, 293 vd; **Favre-Bulle**, sh. 353 vd; **Honsell**, sh. 273; **Hofstetter**, sh. 24;**Weber**, AjP 1992, S.2, sh. 178 vd; OR-**Weber**, Art. 394, N. 23; **Kramer**, Art. 19-20, N. 55; **Pedrazzini**, sh. 12, dn. 28; **Hatemi (Serozan/Arpacı)**, sh. 352 ve 390. Ayrıca bk. **Tercier**, N. 3939 vd.

37 **Leuenberger**, sh. 49; **Desmontet**, sh. 501; **Gessler**, sh. 36 vd.

38 BGE 109 II 465 vd; 112 II 46.

(sui generis) bir sözleşme şeklinde düzenlemedikleri iş görme sözleşmeleri vekâlet hükümlerine tâbi olur. Başka bir ifadeyle, TBK m. 502/II'de sınırlı kapsamda bir tâlilik söz konusu olup, tarafların hukuken yeterli açıklıkla düzenlemedikleri ve diğer kanunî sözleşme tiplerine veya isimsiz (sui generis) sözleşme kategorisine girip girmedikleri şüpheli olan iş görme edimlerine vekâlete ilişkin hükümler -kıyasen- uygulanır[39].

IV. Vekâlet ve temsil yetkisi

TBK m. 504/II gereğince, vekâlet, vekilin yapmayı kabul ettiği işlerin görülmesi için gerekli hukukî işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Böyle bir durumda dahi, vekâlet ile temsil yetkisini birbirinden ayırmak gerekir. Vekâlet ile temsil yetkisi arasında başlıca aşağıdaki farklılıklar mevcuttur[40]:

– Vekâlet iç ilişkiye; temsil dış ilişkiye ilişkindir.

– Vekâlet bir hukukî yüküm doğurur; temsil yetkisi ise bir hak bahşeder.

– Vekâlet illî bir işlemdir; temsil yetkisi ise hukukî sebepten bağımsızdır (soyuttur).

– Vekâlet eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir; temsil yetkisi tek taraflı bir işlemle verilir.

V. Kurulması

Vekâlet sözleşmesi rızaî bir sözleşme olarak, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulur. Zimnî kabule ilişkin TBK m. 503 hükmü saklı olmak üzere, sözleşmenin kurulmasına ilişkin genel kurallar (TBK m. 3 vd), vekâlet sözleşmesinde de uygulanır[41].

TBK m. 503'e göre, "Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır". Bu hüküm sadece gaipler (hazır olmayanlar) arasında

---

39 **Leuenberger**, sh. 52 ve 53.

40 **Honsell**, sh. 272-273.

41 OR-**Weber**, Art. 395, N. 2; **Tercier**, N. 3965; **Knoepfler/Guinand**, FJS, Nr. 327, sh. 2.

vekâlet sözleşmesinin kurulmasında uygulanır; hazırlar arasında, özellikle telefonla yapılan icaplarda (TBK m. 4/II) bu hüküm uygulanmaz[42].

Yapılan icabın derhal reddedilmedikçe kabul edilmiş sayılacağını öngören TBK m. 503 hükmü, TBK m. 6'da yer alan istisnaî kuralın özel olarak düzenlenmiş bir uygulama alanını teşkil eder[43]. TBK m. 6'ya göre, öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse uygun bir süre içinde öneri reddedilmemiş ise, sözleşme kurulmuş sayılır. TBK m. 503'ün uygulanabilmesi için, vekilin sözleşme konusu işi resmî bir sıfatı gereği [meselâ, mahkemece tayin edilen avukatlar (HMK m. 466/1ç ve Avukatlık K. m. 176 vd] veya bilirkişiler, bir anonim şirket yönetim kurulundaki kamu tüzel kişilerinin temsilcileri (TK m. 275), devlet memurlarının resmî görevleri gereği yaptıkları vekâlet sözleşmesi idare hukukuna girer) veya mesleğinin icabı (avukatlar, doktorlar, bankacılar) olarak görmesi veyahut vekilin bu işleri yapacağını alenen bildirmesi (ilân, tabela konulması) gerekir[44].

TBK m. 503'de kullanılan "kurulmuş sayılır" deyiminin anlamı tartışmalıdır. Bir fikre göre[45], burada aksi isbat edilerek çürütülemeyen bir karine (unwiderlegbare Vermutung) söz konusudur. Buna karşılık üstün tutulması gereken diğer bir fikre göre[46], TBK m. 503 hükmü çürütülemeyen kesin bir karine koymamakta, sadece zımnî kabul karinesi için dayanılabilecek bir temel sağlamaktadır; bu maddede söz konusu olan karine çürütülebilir bir karinedir. Bu görüş taraftarlarından *Fellmann*'a göre, kesin karine fikri bazı problemleri çözümsüz bırakacak niteliktedir. Meselâ, sınırlı ehliyetsizlere veya temyiz kudreti

---

42 **Becker**, Art. 395, N. 1; **Hofstetter**, sh. 44; **Gautschi**, Art. 395, N. 4a; **Fellmann**, Art. 395, N. 74 vd. Aksi fikirde: **Oser/Schönenberger**, Art. 395, N. 3.

43 **Fellmann**, Art. 395, N. 63; **Hofstetter**, sh. 44 vd; **Merz**, Vertrag, N. 221; **Schönenberger/Jaeggi**, Art. 6, N. 27; **Schmidlin**, Art. 6, N. 33 vd; **Gautschi**, Art. 395, N. 1; **Gauch/Schluep**, N. 457; **Kocayusufpaşaoğlu**, BH, sh. 186.

44 **Tercier**, N. 3975 vd; OR-**Weber**, Art. 395, N. 4; **Fellmann**, Art. 395, N. 101 vd.

45 **Hofstetter**, sh. 44 vd; **Keller/Schöbi**, Bd. I, sh. 37; **Oser/Schönenberger**, Art. 395, N. 2; **von Tuhr/Peter**, sh. 165/166; **Tercier**, N. 3973; **Kramer**, Art. 1, N. 13; **Tandoğan** II, sh. 387.

46 **Fellmann**, Art. 395, N. 69 vd; **Becker**, Art. 395, N. 2; **Oser/Schönenberger**, Art. 6, N. 27; **Schmidlin**, Art. 6, N. 34; **Gautschi**, Art. 395, N. 4a.

olmayanlara yapılan icaplarda sözleşmenin kurulmasına ilişkin fiksiyondan söz edilemez[47]. Aynı şekilde, doktrindeki yeni görüşler TBK m. 6 çerçevesinde susmanın beyan niteliğini beyanda bulunanın beyan bilincinden bağımsız olarak değerlendirmekte ve davranışa güven teorisine göre verilecek objektif anlamı esas almaktadır[48]. Böylece, susan kişinin davranışı, şayet onun bildiği veya bilebileceği durumlara göre beyan bilincine veya beyan iradesine sahip olması gerekiyorsa, irade beyanı olarak ona isnad edilebilir[49]. Bu itibarla TBK m. 6 ve 503'ü aksi isbat edilebilen bir yorum kuralı ve bunların ihtiva ettiği karinenin de çürütülebilir olduğunu kabul etmek gerekir[50].

Diğer taraftan TBK m. 503'de yer alan "hemen" deyimini somut olayın özelliklerine göre değerlendirmek gerekir. Meselâ, rayiçlerin çabuk değiştiği hallerde borsa komisyoncusu telefon ve teleksle icabı alır almaz cevap vermelidir. Buna karşılık, çok hacimli bir dosyayı alan avukattan aynı gün cevap vermesi istenemez[51]. Vekile en azından kısa bir düşünme süresi tanınmalıdır[52].

Vekâlet sözleşmesinin geçerliliği, kural olarak herhangi bir özel şekil şartına bağlı değildir. Buna karşılık, isbat açısından şeklin yararları bulunmaktadır[53]. Vekâlet sözleşmesinde şekil serbestisi ilkesinin, vekilin üçüncü kişilerle şekle bağlı bir sözleşme kurmayı taahhüt etmesi halinde de geçerli olduğu kabul edilmektedir[54].

Taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesini amaçlayan sözleşmelerin yapılmasına ilişkin vekâletin kapsamı, taşınmaz satışıyla ilgili kısımda

---

47 **Fellmann**, Art. 395, N. 70 ve onun yollamada bulunduğu **Seiler**, Münch. K, § 633, N. 11.

48 **Schmidlin**, Art. 6, N. 16; **Schönenberger/Jäggi**, Art. 1, N. 192; **Kramer**, Art. 1, N. 46 vd; **Larenz**, BR, sh. 320 vd; **Kocayusufpaşaoğlu**, BH, sh. 184-185.

49 **Schmidlin**, Art. 6, N. 16; **Kramer**, Art. 1, N. 50 vd; **Fellmann**, Art. 395, N. 71; **Kocayusufpaşaoğlu**, BH, sh. 136 vd, ve sh. 185.

50 **Fellmann**, Art. 395, N. 72; **Schmidlin**, Art. 6, N. 34 ve 65; **Schönenberger/Jäggi**, Art. 1, N. 205; Art. 6, N. 27.

51 **Fellmann**, Art. 395, N. 119; **Knoepfler/Guinand**, FjS, Nr. 327, sh. 2; **Tandoğan** II, sh. 368.

52 **Fellmann**, Art. 395, N. 119;**Weber**, Praxis zum Auftragsrecht, sh. 64.

53 **Bucher**, BT, sh. 223; **Hofstetter**, sh. 44; **Knoepfler/Guinand**, FjS, Nr. 327, sh. 3; **Fellmann**, Art. 395, N. 23; OR-**Weber**, Art. 395, N. 9 vd; **Tandoğan** II, sh. 390.

54 **Bucher**, BT, sh. 223; **Gautschi**, Art. 395, N. 49; **Fellmann**, Art. 395, N. 24; **Tercier**, N. 3969; BGE 57 II 504; 64 II 228; 65 II 163; 81 II 231; 86 II 40; 99 II 162.

incelenmiştir. Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının geçirilmesine ilişkin vekâlet sözleşmelerinin şekle bağlı olacağı konusunda Medeni Kanun'da ve Borçlar Kanunu'nda açık bir hüküm yoktur. Bununla beraber, Tapu Sicil Tüzüğü m. 13/IV'e göre, "İstem vekâleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanunu'na göre düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Vekil tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, ayrıca dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği karşılaştırılır".

VI. Vekâletin kapsamı

1. Vekâletin kapsamının belirlenmesi

TBK m. 504/I'e göre, "Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir". Bu hüküm ile, vekâletin kapsamının sözleşmeyle açıkça tespit edilmemesi halinde, bu kapsamın görülecek işin niteliğine göre belirleneceği ifade edilmektedir.

Vekâlet sözleşmesinin kapsamının açıkça ve ayrıntılı olarak belirlenmesi, özellikle maddî fillere ilişkin vekâlette çok nadir hallerde gerçekleşir[55]. Diğer taraftan, vekâlet veren genellikle bu kapsamı belirleyebilecek durumda değildir; bu hususta, çoğunlukla konusunda uzman olan vekilin yardımına ihtiyaç vardır. Bu itibarla, iş görme ile erişilecek amacın gerçekleşmesi için nelerin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiğini uzman olan vekilin belirlemesi gerekir[56].

TBK m. 504/I'de vekâletin kapsamını belirlemede kullanılacağı ifade edilen "işin niteliğine göre" kriteri oldukça genel bir kavramdır. Vekâletin kapsamını bu kritere göre belirlerken, vekâlet verenin, vekilin iş görme ediminin ifasıyla ulaşmak istediği amaçtan hareket etmek gerekir. Buna göre, vekil, vekâlet verenin bilinmesi gereken amacına uygun olarak faaliyette bulunmak ve onun menfaatlerini bu amaç doğrultusunda sadakat ve özenle değerlendirmek zorundadır. Kısaca, ve-

---

[55] OR-**Weber**, Art. 396, N. 2; **Fellmann**, Art. 396, N. 23; **Gautschi**, Art. 396, N. 2c; **Tandoğan** II, sh. 393.

[56] **Fellmann**, Art. 396, N. 24; **Gauschi**, Art. 396, N. 2c; OR-**Weber**, Art. 396, N. 2; **Tandoğan** II, sh. 393.

kil yapılması veya yapılmaması gerekenleri bu esaslara göre belirlemekle yükümlüdür[57].

2. Hukukî fiillere ilişkin vekâletin kapsamı ve temsil yetkisi

TBK m. 504/II'ye göre, "Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar". TBK m. 504/II hükmü sadece hukukî fiillere (işlemlere) ilişkin vekâletlerde uygulanır. Bu tür vekâlet sözleşmelerinde, vekilin taahhüt ettiği hukukî işlemleri yapabilmesi için vekilin temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Vekil, hukukî işlemleri, doğrudan doğruya temsilci sıfatıyla vekâlet veren adına veya dolaylı temsilci olarak kendi adına yapabilir[58]. Hangi çeşit temsil yetkisinin bulunduğu hususunda açıklık yoksa, bunun sözleşmenin yorumlanması suretiyle belirlenmesi gerekir[59].

Hukukî işlemlere ilişkin vekâlette, vekilin temsil yetkisinin bulunduğu hususunda bir kanunî karine (Rechtsvermutung) öngören[60] TBK m. 504/II, bu durumda vekilin hangi çeşit bir temsil yetkisine sahip olacağını açıkça düzenlememektedir. Bu durumda vekâlet sözleşmesinin yorumundan bir sonuç çıkarılamadığı takdirde, şüphe halinde vekilin gerekli hukukî filleri doğrudan doğruya temsilci olarak yapabileceğini kabul etmek gerekir[61]. Zira, sadece dolaylı temsilin bulunmadığının kanıtlanamamış olması sebebiyle vekâlet verenin vekilin ödeme güçsüzlüğü tehlikesine maruz kalması ve vekille yeniden devir işlemleri yapmaya zorlanması varsayılamaz[62].

Vekile verilen temsil yetkisi sadece belirli bir veya birkaç işlemle sınırlı olabileceği gibi (özel temsil yetkisi), vekilin vekâlet verenin her

---

57 **Gautschi**, Art. 396, N. 3a; OR-**Weber**, Art. 396, N. 3; **Fellmann**, Art. 396, N. 35-36; **Tandoğan** II, sh. 393 vd.

58 OR-**Weber**, Art. 396, N. 4; **Tercier**, N. 3986.

59 **Oser/Schönenberger**, Art. 396, N. 4; **Fellmann**, Art. 396, N. 47; **Tandoğan** II, sh. 395.

60 **Fellmann**, Art. 396, N. 50; OR-**Weber**, Art. 396, N. 9; **Tercier**, N. 3989.

61 **Fellmann**, Art. 396, N. 51; OR-**Weber**, Art. 396, N. 2 ve 9. Ayrıca bk. **Gautschi**, Art. 396, N. 27a ve c; **Tandoğan** II, sh. 395. **Becker**'e göre (Art. 396, N. 6) olayın özelliklerinden, bizzat borç altına girmenin vekilden beklenemeyeceği anlaşılıyorsa doğrudan doğruya temsil karinesi kabul edilmelidir. **Oser/Schönenberger**'e göre (Art. 396, N. 4) ise, açıkça yetki verilmemişse, dolaylı temsilin bulunduğu sonucuna varılmalıdır.

62 **Fellmann**, Art. 396, N. 51.

türlü işlerini yapabilmesine izin verecek şekilde (genel temsil yetkisi) de olabilir[63].

3. Özel temsil yetkisini gerektiren haller

Özel temsil yetkisini gerektiren haller TBK m. 504/III'te ve davaya vekâlet dolayısıyla da HMK m. 74'te düzenlenmiştir. Ayrıca bazı özel hükümlerde de belirli işlemler için özel yetki öngörülmüştür. TBK m. 504/III'te öngörülen sınırlamalar sadece doğrudan doğruya temsili içeren vekâlette uygulanır; dolaylı temsilde vekil tam hak sahibi olup, muhtemel sınırlamalar sadece iç ilişkide geçerli olur[64].

Aşağıdaki hallerde özel temsil yetkisinin bulunması gerekir:

a) Dava açmak, sulh olmak, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato talebinde bulunmak[65].

b) Kambiyo taahhüdünde bulunmak[66].

c) Vekâlet veren adına bağışlamada bulunmak.

d) Taşınmazların devri veya bir hakla sınırlandırılması.

e) Kefil olmak

f) Vekilin başkasını tevkil etmesi (Avukatlık K. m. 171/II), hâkimin reddi (HMK m. 76) ve Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması (44 sayılı K. m. 41).

---

63 **Fellmann**, Art. 396, N. 66; **von Tuhr/Peter**, sh. 361; **Tandoğan** II, sh. 395.

64 OR-**Weber**, Art. 396, N. 13.

65 Avukat takip ettiği dava ve işlerde noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya örneğini ibraz etmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları yetkili amirleri tarafından düzenlenen temsil belgesi ibraz edebilirler. Bu belgelerin noterce onaylanmasına gerek yoktur (HMK m. 76/I, II).

66 Ticari vekil özel yetki olmadıkça kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez (TBK m. 551/II). Ticari temsilci kambiyo taahhüdünde bulunmaya yetkilidir. Buna karşılık, açık yetki verilmedikçe taşınmazları devredemez veya bir hak ile sınırlandıramaz (TBK m. 548/I, II).

§ 30. VEKİLİN BORÇLARI

I. Sadakat ve özen borcu

TBK m. 506/II'ye göre, "Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür". Bu fıkra hükmü, vekilin sadakat ve özen borçlarını düzenlemektedir[1].

1. Sadakat borcu

Sadakat borcu vekilin her durumda vekâlet verenin menfaatine uygun hareket etmesini gerektirir; vekil, davranışlarını güven ilkesi gereğince gözönünde tutulması gereken edim amacına yönlendirmekle ve kendi menfaatini vekâlet vereninkine tâbi kılmakla yükümlüdür[2]. Başka bir ifadeyle, vekil, sadakat yükümü gereğince, vekâlet verenin yararına olacak davranışlarda bulunmak ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür[3].

Vekilin sadakat yükümü sadece işin görülmesiyle sınırlı olmayıp, vekâlet sözleşmesinin sona ermesinden sonra da devam eder[4]. Bu cümleden olmak üzere, vekil işin görülmesi esnasında kendisine tevdi edilen veya herhangi bir şekilde öğrendiği sırları saklamakla ve bunları başkalarının öğrenmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür[5]. Bundan başka, vekil sadakat yükümünün gereği olarak, sözleşmenin devamı veya işin görülmesi esnasında vekâlet verene bilgi

---

1 **Tercier/ Favre**, n. 5114 vd.; OR-**Weber**, Art. 398, N. 1.

2 **Fellmann**, Art. 398, N. 24; OR-**Weber**, Art. 398, N. 8; **Tercier/ Favre**, n. 5140; **Werro**, N. 505; **Tandoğan** II, sh. 407.

3 **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 4; **Bucher**, BT, sh. 230; **Gautschi**, Art. 398, N. 5a; **Fellmann**, Art. 398, N. 24; OR-**Weber**, Art. 398, N. 8; **Tercier/Favre**, N. 5140; **Tandoğan** II, sh. 407; BGE 115 II 64 vd.; Vekilin vekâlet görevini kötüye kullanması ve üçüncü kişinin bu vekil ile çıkar ve işbirliği içinde olmak suretiyle sözleşme yapması halinde, vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması TMK m. 2 de düzenlenen dürüstlük kuralının sonucudur (1. HD. 11.12.2014 tarih E. 2014/15740 K. 2014/19370 –Kazancı-).

4 OR-**Weber**, Art. 398, N.8.

5 **Tercier**, N. 4047; OR-**Weber**, Art. 398, N. 11; **Fellmann**, Art. 398, N. 40 vd; **Honsell**, sh. 274.

vermek, onu uyarmak veya dikkatini çekmek, koruma yükümlerini yerine getirmek zorundadır[6]. Aynı şekilde, vekâletin ifasının menfaat ihtilafına sebep olması halinde de sadakat yükümü önemli bir rol oynar. Böyle bir çıkar çatışması vekilin kendi kendisiyle sözleşme yapması veya çift temsil halinde ortaya çıkar. Taraflar arasında bir menfaat zıtlığı varsa, vekilin, vekâlet verenin menfaatiyle bağdaşmayan işi alması yasaktır. Bu yasak, tellâl bakımından TBK m. 523'de, avukatlar için de Avukatlık K. m. 38 (b)'de açıkça belirtilmiştir. Buna karşılık, tarafların menfaati arasında paralellik varsa, vekâlet veren açıkça izin vermişse veya vekâlet veren için herhangi bir zarar tehlikesi bulunmuyorsa, vekilin bu çeşit işleri yapması caizdir[7]. TBK m. 543 komisyoncular borsaya kayıtlı veya piyasada carî fiyatı olan kıymetli evrak veya mallar için bu imkânı tanımaktadır.

2. Özen borcu

Vekâlet sözleşmesinin unsurlarını incelerken de ifade edildiği gibi, vekil belirli bir sonuca yönelik edim fiilini özenle yerine getirmekle yükümlüdür.

Özen bir beşeri davranışın, özellikle beşerî bir fiilin kriteri olup, somut bir amaca, belirli bir sonuca erişmek için akıl ve iradenin kullanılmasıdır[8]. Vekâlet sözleşmesinde vekilin özen borcunun konusu, edim sonucunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hayat tecrübelerine ve işlerin normal akışına göre gerekli davranışlarda bulunmak ve bunu engelleyecek davranışlardan kaçınmaktır[9].

eBK m. 390/ I'de vekilin sorumluluğunun genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin hükümlere tabi olduğu ilkesi kabul edilmişti. Böylece vekilin özen yükümüne eBK m. 321'e göre belirleneceği kıstası (kriteri) öngörülmüştü. İsviçre Hukukunda da eleştirilen bu hüküm TBK m. 506/ III ile haklı olarak değiştirilmiştir. TBK m. 506/ III'e göre, "Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesin-

---

6 OR-**Weber**, Art. 398, N. 9; **Fellmann**, N. 132 vd, 143 vd; **Tercier**, N. 4039 vd.

7 OR-**Weber**, Art. 398, N. 15; **Hofstetter**, sh. 82 vd, 94 vd; **Fellmann**, Art. 398, N. 106 vd; **Tercier**, N. 4042 vd; **Tandoğan** II, sh. 408; BGE 95 II 452; 93 II 481; 89 II 324.

8 **Gautschi**, Art. 398, N. 21a. Ayrıca bk. **Derendinger**, N. 253.

9 **Gautschi**, Art. 398, N. 21 b ve c; OR-**Weber**, Art. 398, N. 24; **Fellmann**, Art. 398, N. 17; **Tandoğan** II, sh. 410.

de, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır".

Vekilin göstereceği özenin soyut özen ölçüsüne göre değerlendirilmesi gerekir; mesleğinde gerekli ortalama zihnî, bedenî ve manevî yeteneklere sahip ve hiçbir kaçınılabilen hatayı işlemeyen insan modeli esas alınır[10].

Bu model mesleğe göre değişeceği için, mesleğe has ortalama davranış ölçü olarak kabul edilmelidir[11]. Gösterilecek özenin ölçüsünü belirleyen objektif faktörler sözleşmeye uygun olarak yapılacak işin cinsine ve güçlüğüne ve vekilin bu hususta gerekli meslekî bilgisine bağlıdır; konusunda uzman olanlardan daha fazla özen beklenir[12].

Vekilin tam olarak yerine getirebileceği bir vekâleti kabul etmesi ve beceremeyeceği işleri reddetmesi gerekir; onun aşırı derecede yüklü ve zaman darlığı içinde olması mazeret teşkil etmez[13]. Özellikle serbest meslek icra edenlerin alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri bilmesi gerekir[14].

Bir fikre göre[15] ücretli vekâlette vekilin daha fazla özen göstermesi gerekir. Buna karşılık, bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre[16]

---

10 **Fellmann**, Art. 398, N. 486; **Derendinger**, N. 267; OR-**Weber**, Art. 398, N. 27; **Werro**, N. 562.

11 OR-**Weber**, Art. 398, N. 27; **Fellmann**, Art. 398, N. 486; **Derendinger**, N. 269.

12 OR-**Weber**, Art. 398, N. 27; **Fellmann**, Art. 398, N. 486; "...Doktor hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlarda bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta) mesleki bir iş gören doktor olan vekilden tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, TBK.nun 510/1. maddesi hükmü uyarınca vekaleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulmamalıdır (13. HD. 2.7.2014 tarih E. 2014/19545 K. 2014/22576 –Kazancı-).

13 **Tercier**, N. 4018; OR-**Weber**, Art. 398, N. 28; **Fellmann**, Art. 398, N. 358.

14 **Tercier**, N. 4019; OR-**Weber**, Art. 398, N. 28; **Fellmann**, Art. 398, N. 359.

15 **Hofstetter**, sh. 97 vd; **Gautschi**, Art. 398, N. 24a; **Becker**, Art. 398, N. 5; BGE 115 II 64, Erw. 3a.

vekâletin ücretsiz olması gösterilecek özenin derecesini etkilemez; sadece tazminatın belirlenmesinde (TBK m. 114/I) göz önünde tutulur.

II. İşi şahsen ifa borcu

1. Genel olarak

TBK m. 506/I gereğince, vekil, kural olarak sözleşme konusu işi şahsen (kendisi) ifa etmek zorundadır. Vekâlet sözleşmesine egemen olan güven ilişkisi sebebiyle, TBK m. 83'de öngörülen genel kuraldan ayrılınmıştır[17]. Bununla beraber, vekilin işi şahsen ifa zorunda olması, onun tek başına yapamayacağı veya tâli derecedeki işler için yardımcı şahıs kullanmasına engel teşkil etmez[18].

TBK m. 506/I hükmü, yukarıdaki kuralın istisnası olarak, aşağıdaki üç halde, vekile üstlendiği iş görme edimini başkasına yaptırma imkânı vermektedir:

a) Vekâlet verenin vekilin başkasını vekil tayin etmesine açıkça veya zımnen rıza göstermesi.

Vekilin işin yapılmasına yetkili kılınması tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanıyla gerçekleşir. Bu irade beyanı açık veya zımnî olabilir. İşin mahiyetine göre başkasını tevkilin hesaba katılması gerekiyorsa, başkasını tevkile zımnen razı olunduğunu kabul etmek gerekir. Meselâ, vekile ikametgâhından çok uzakta bulunan malların idaresi verilmişse böyle bir durum söz konusu olur[19].

b) Vekilin başkasını vekil tayin etmesine teamül gereği yetkili olması. Kıymetli evrak alım satışında başka bir borsadaki komisyoncunun, eşya taşımada ara taşıyıcının, bir senedi tahsil için alan bankanın kendi şubesi olmayan yerde başka bir bankayı tevkil etmesi, belgeli akredifte muhabir bankanın belge ibrazı karşılığı ödeme yapmakla görevlendirilmesi örf ve âdete uygundur[20]. Aynı şekilde malvarlığı yöne-

---

[16] **Derendinger**, N. 273-274; **Fellmann**, Art. 398, N. 497; **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 1; OR-**Weber**, Art. 398, N. 28; aynı yazar, AJP 1992, sh. 184.

[17] **Fellmann**, Art. 398, N. 527; **Tercier**, N. 3995; **Tandoğan** II, sh. 456.

[18] OR-**Weber**, Art. 398, N. 3; **Fellmann**, Art. 398, N. 529; **Tercier**, N. 3996; **Bucher**, BT, sh. 229; **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N.7.

[19] **Becker**, Art. 398, N. 13; **Fellmann**, Art. 398, N. 576; **Tandoğan** II, sh. 457.

[20] **Becker**, Art. 398, N. 13; **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 9; **Fellmann**, Art. 398, N. 580; **Tandoğan** II, sh. 457.

tenin, kıymetli evrakları bankaya tevdi etmeye ve faiz ve temettülerin tahsili işini bankaya yaptırmaya yetkili olduğu kabul edilir[21].

c) Vekilin başkasını vekil tayin etmesine halin gereklerine göre mecbur olması. Meselâ, aniden hastalanan vekilin gecikmesinde tehlike olan bir işin yapılması için başkasına vekâlet vermesi; yabancı memlekette takip edilecek bir davada, o memleket kanunlarına göre dava takibine yetkili olmayan avukatın oranın avukatlarından birini tevkil etmesi[22].

2. Vekilin yerine başkasını koymasının çeşitleri

a) Alt vekâlet

Alt vekâletin şartları ve sonuçları TBK m. 506/I ve 507'de düzenlenmiştir. Alt vekâlet (Unterauftrag), vekilin kendi adına yaptığı sözleşmeyle, vekâletten doğan borçlarının ifası için başkasını vekil tayin etmesidir[23]. Böylece vekil ile alt vekil arasında, vekille ilk vekâlet veren arasındaki sözleşmeden bağımsız bir vekâlet ilişkisi kurulur[24]. Alt vekâletin varlığı halinde, vekâlet veren ile ilk vekil arasındaki vekâlet sözleşmesi devam eder. Buna karşılık, vekâlet veren ile alt vekil arasında doğrudan doğruya bir akdî ilişki bulunmamaktadır; TBK m. 507/III uyarınca, vekâlet veren, vekilin alt vekile karşı sahip olduğu bütün hakları alt vekile karşı ileri sürebilir.

b) İkame vekâlet (Ersatzauftrag)

İkame vekâlet (Ersatzauftrag) kavramının anlamı konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bir fikre göre[25], ikame vekâlet, vekilin vekâlet veren adına yaptığı bir sözleşmeyle vekâletten doğan borçların ifasını başkasına bırakmasıdır; bunun için vekilin vekâlet vereni doğrudan doğruya temsil yetkisinin bulunması gerekir.

---

21 **Fellmann**, Art. 398, N. 580; **Becker**, Art. 398, N. 13; **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 9.

22 **Tandoğan** II, sh. 458.

23 **Becker**, Art. 398, N. 3; **Gautschi**, Art. 398, N. 40c; **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 5; OR-**Weber**, Art. 398, N. 6; **Fellmann**, Art. 398, N. 563 vd, N. 592 vd; **Tandoğan** II, sh. 459; **Tercier**, N. 3998.

24 OR-**Weber**, Art. 398, N. 6; **Fellmann**, Art. 398, N. 565; **Tercier**, N. 4009.

25 **Oser/Schönenberger**, Art. 399, N. 17; **Tandoğan** II, sh. 461.

Buna karşılık diğer bir fikre göre[26] ikame vekâlet, vekilin vekâleti kabul etmemesi veya herhangi bir sebepten dolayı hiç veya belirli bir süre içinde ifa etmemesi talikî şartına bağlı olarak başkasının vekil tayin edilmesidir.

3. İşin görülmesinin başkasına gördürülmesinde vekilin sorumluluğu

Yetkili olmadığı halde işi başkasını gördüren eden vekil, onun fiilinden kendi yapmış gibi sorumlu olur (TBK m. 507/I). Bu işi durumda, başkasına gördürme sözleşmenin ihlâli sayılır ve işi başkasına gördüren bunun sonuçlarından sorumlu olur. Hâkim fikre göre[27], bu durumda işi başkasına gördürme bizzat bir yüküm ihlâli olduğu için, işi gördürülenin verdiği her türlü zarardan, o kusursuz da olsa, vekil borcun ifa edilmemesini düzenleyen TBK m. 112 gereğince sorumlu olur. *Derendinger*'e göre[28], vekil TBK m. 112'nin yanında, yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğu düzenleyen TBK m. 116 gereğince de sorumlu olur ve vekilin mazur görülebilecek bir hata ile işi başkasına gördürmesi halinde TBK m. 116'ya göre sorumluluk önem kazanır. Buna karşılık son zamanlarda savunulan bir fikre göre[29], TBK m. 507/I'de yer alan açık sorumluluk kuralı mevcut iken, ek olarak TBK m. 112 veya 116'ya başvurmaya gerek yoktur; TBK m. 507/I hükmü sonuçta TBK m. 116'daki çözümle uygunluk arzetmekte ve onun özel bir uygulama alanını teşkil etmektedir; TBK m. 116'ya ilişkin görüş ve içtihatlardan TBK m. 507/I'in yorumunda da yararlanılabilir.

Buna karşılık, vekil işi başkasına gördürmede yetkili olduğu takdirde, sadece bu yetkisini kullanırken ve talimat verirken gerekli özeni göstermekle yükümlüdür (TBK m. 507/II).

Gerek caiz olan, gerek caiz olmayan alt vekâlet halinde, vekilin alt vekile karşı haiz olduğu bütün hakları vekâlet veren doğrudan doğruya alt vekile karşı ileri sürebilir (TBK m. 507/III).

---

[26] **Gautschi**, Art. 398, N. 44c; **Fellmann**, Art. 398, N. 547 vd; OR-**Weber**, Art. 398, N. 7.

[27] **Oser/Schönenberger**, Art. 398, N. 8; **von Tuhr/Escher**, sh. 124, dn. 15'e ait metin; OR-**Weber**, Art. 399, N. 8; **Jaussi**, sh. 29.

[28] **Derendinger**, N. 299.

[29] **Fellmann**, Art. 399, N. 12; **Cerutti**, N. 466. Ayrıca bk. **Hofstetter**, sh. 73; **Guhl/Merz/Koller**, 8. baskı, sh. 498.

III. Vekâlet verenin talimatına uygun olarak hareket yükümü

TBK m. 505/I'e göre, "Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir". Kanun koyucu, vekâlet sözleşmesinin konusunun vekâlet veren yararına bir iş görme olmasından hareketle, vekile vekâlet verenin talimatlarına uyma yükümü öngörmüştür.

1. Vekâlet verenin talimat hakkının niteliği ve kapsamı

Talimat, vekâlet verenin vekâlet sözleşmesinin kurulmasından sonra vekile kendisine tevdi edilen işi nasıl göreceğini belirten, tek taraflı ve varması gereken bir irade açıklamasıdır[30]. Talimat verme, bazı yazarların aksi görüşte olmasına[31] rağmen, yenilik doğuran bir hakkın kullanılması niteliği taşımaz[32]. Zira talimat, yerine getirilmeden önce geri alınabilir ve değiştirilebilir. Talimatın verilmesiyle sadece sözleşmenin konusu ile sözleşmenin ifa tarzı ve şekli somutlaştırılır, sübjektif hâkimiyet hakların varlığına müdahalede bulunulmaz[33]. Keza, yenilik doğuran hakların bir defa kullanılmakla tükenmesi olgusu talimatlarda mevcut değildir[34].

Sözleşmede kararlaştırılan hususların yeterince açık olmaması halinde, talimat sözleşmenin muhtevasının belirlenmesini ve vekâletin kapsamının sınırlanmasını sağlar[35]; böylece vekâletin icra edilme tarzı somutlaştırılmış olur. Meselâ, vekâlet verene ait bir malın en iyi şartlarla satılmasına ilişkin vekâlet sözleşmesinde, vekâlet veren satışın belirli bir tutarın altında yapılmamasını, belirli bir zaman içinde ya da belirli bir yerde yapılmasını talimatla bildirebilir[36].

---

30 OR-**Weber**, Art. 397, N. 6; **Fellmann**, Art. 397, N. 16 ve 20; **Hofstetter**, sh. 78; **Tercier**, N. 4026; **Tandoğan** II, sh. 436.

31 **Gautschi**, Art. 397, N. 2c; **Tandoğan** II, sh. 436; **Yavuz**, sh. 600.

32 **Hofstetter**, sh. 78; OR-**Weber**, Art. 397, N. 6; **Fellmann**, Art. 397, N. 18 vd.

33 **Merz**, SPR VI/1, sh. 72 vd; **Bucher**, AT, sh. 35 vd; **Fellmann**, Art. 397, N. 19.

34 **Bucher**, AT, sh. 36 vd; **Fellmann**, Art. 397, N. 19

35 OR-**Weber**, Art. 397, N. 5.

36 **Tandoğan** II, sh. 436-437.

Tarafların daha önce kararlaştırdığı sözleşme konusuna dahil olmayan hususlara ilişkin talimatı, yeni bir sözleşme kurulmasına ilişkin bir icap olarak görmek gerekir; vekil bunu kabul veya reddedebilir[37].

Vekil vekâlet verenin hukuka veya ahlâka aykırı talimatlarına uymak zorunda değildir; bu tür talimatlar hukuken geçersizdir[38]. Vekil, kendisine verilen talimatları dikkatle incelemeli ve bunların amaca uygun olmadığını veya faydasız olduğunu görünce, sadakat yükümü gereği bu hususta vekâlet verenin dikkatini çekmeli ve onu uyarmalıdır[39]. Buna rağmen vekâlet veren talimatında ısrar ederse, vekil buna uymak veya istifa etmek durumunda kalır. TBK m. 505/I/2. cümle aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde vekile vekâlet verenin talimatından ayrılma hakkı tanımaktadır:

– Vekâlet verenden sorup vaktinde ondan açık talimat alma imkânı bulunmamalıdır (haberleşme imkânı yoksa veya gecikmede tehlike varsa).

– İmkân olup da vekâlet verenden sorulabilseydi, onun talimattan ayrılmaya muvafakat edeceği kabul olunabilmelidir.

2. Talimata uymamanın sonuçları

Az önce açıklanan ve TBK m. 505/I, c.2'de öngörülen talimattan ayrılmanın caiz olduğu hallerin dışında, vekilin vekâlet verenin talimatından ayrılmasının sonuçları TBK m. 505/II'de düzenlenmiştir. Bu fıkra hükmüne göre, "Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz".

Vekilin vekâlet verenin talimatına caiz olmayan bir biçimde uymaması halinde, vekâlet veren talimata uygun ifada ısrar edebilir ve talimata uygun olmayan edimi kabul etmeyebilir. Edimin ifası imkânsız olduğu takdirde, tazminat talep edebilir. TBK m. 505/II vekile, vekâlet verenin zararını (meselâ, verilen satış fiyatına ilişkin sınıra uymama halinde fiyat farkını) üstlenme ve bu şekilde bir tazminat ödeme imkânı tanımaktadır. Bu takdirde vekâlet veren edimi gereği gibi ifa olarak kabul etmek zorunda olup, başka tazminat talep edemez[40].

---

37 OR-**Weber**, Art. 397, N. 5; **Fellmann**, Art. 397, N. 78; **Hofstetter**, sh. 78; **Gautschi**, Art. 397, N. 3a.

38 **Fellmann**, Art. 397, N. 97; OR-**Weber**, Art. 397, N. 7; **Hofstetter**, sh. 79.

39 **Gautschi**, Art. 397, N. 18; **Hofstetter**, sh. 80; OR-**Weber**, Art. 397, N. 8; **Fellmann**, Art. 397, N. 103.

40 **Hofstetter**, sh. 81; **Bucher**, BT, sh. 230.

Doğrudan doğruya temsil yoluyla yerine getirilen vekâlette, vekilin vekâlet verenin talimatlarına aykırı olarak, kötü niyetli üçüncü kişiyle yaptığı sözleşme vekâlet vereni bağlamaz; üçüncü kişi iyi niyetli ise yapılan sözleşme geçerli olur. Bu son ihtimalde, vekil vekâlet verenin zararını üstlenmedikçe (TBK m. 505/II) vekâlet sözleşmesi gereği gibi ifa edilmiş sayılmaz[41]. Buna karşılık, dolaylı temsili gerektiren vekâlette, talimata aykırılık sadece vekilin TBK m. 505/II ve TBK m. 527/II gereğince vekâletsiz iş görmeden sorumlu tutulmasına yol açabilir[42].

IV. Hesap verme borcu

Vekil, vekâlet verenin talebi üzerine, yapmış olduğu işin hesabını vermeğe mecburdur (TBK m. 508/I).

Vekil göreviyle ilgili malî konularda hesap vermek ve buna ait belgeleri vekâlet verene ibraz etmek zorundadır[43]. Aynı şekilde bilgi verme yükümü de hesap verme borcunun kapsamına dahildir. Bilgi verme borcu sadakat yükümünün de gereğidir; vekil talep edilmese dahi, sözleşme konusu işin gidişatı hakkında vekâlet verene bilgi vermelidir[44].

V. İade borcu

1. Genel olarak

Vekil, vekâlet sözleşmesinin ifası dolayısıyla almış olduğu şeyleri vekâlet verene iadeyle yükümlüdür (TBK m. 508/I). Bu yüküm vekilin başkası yararına iş görmesinin bir sonucudur. Bu fıkra metninde şey kelimesi yer almakla beraber, mal niteliğinde olmayanlar da iade borcunun kapsamına girer.

---

41 **Tandoğan** II, sh. 447; **Yavuz**, sh. 603.

42 **Tandoğan** II, sh. 450; **Yavuz**, sh. 602.

43 "...davacı vekilin, takip ettiği iş ve işlemlerde kullanılmak üzere 14 imzalı boş belge aldığı yazılı belge ile sabittir. Davacı, vekilin hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde, davalının savunması doğrultusunda, bu imzalı kağıtların nerelerde sarf edildiğini, belge asıllarının bulunduğu yerleri de bildirmek suretiyle, iade veya iptal edilmiş ise davalının da yer aldığı yazılı bir belge veya kesin delillerle ispatla mükelleftir..." (13. HD. 22.1.2015 tarih E. 2015/1004 K. 2014/9163 – Kazancı-).

44 OR-**Weber**, Art. 400, N. 2; **Tandoğan** II, sh. 480; BGE 110 II 181.

İade edilecek şeyler, bizzat vekâlet verenden alınmış olabileceği gibi (meselâ avanslar), üçüncü kişilerden de alınmış olabilir.

2. Hakların devri

Vekil, dolaylı temsil ilişkisi çerçevesinde, yani kendi adına ve vekâlet veren hesabına hareket ettiği takdirde, kazanmış olduğu hak ve şeylerin sahibi olur. Vekil bunları bilahare vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa etmesi halinde vekâlet verene devretmek zorundadır. Zira, borçların ifası ile bu haklar kendiliğinden vekâlet verene geçer (TBK m. 509/I). Vekâlet veren, bu konuda borçlar hukukuna dayanan bir iade davası açabilir. Bu durum, vekilin iflâsı halinde, vekâlet veren için bir tehlike teşkil eder. TBK m. 509, bu sakıncayı gidermek için, alacaklar ve menkul mallar bakımından vekâlet veren lehine bir kanunî temlik öngörmüştür[45].

a) TBK m. 509'un uygulanma şartları

– Alacak (TBK m. 509/I) ve taşınır mal (TBK m. 509/III) söz konusu olmalıdır. Taşınmazlar tapu siciline güven ilkesi dolayısiyle (MK m. 1023) kanunî temlikin (kendiliğinden vekâlet verene geçme) kapsamına girmez.

– Alacaklar ve taşınır mallar, vekâlet sözleşmesinin ifası sebebiyle üçüncü kişilerden iktisap edilmiş olmalıdır.

– Vekâlet veren vekile karşı borçlarını ifa etmiş olmalıdır. Aksi halde, ödemezlik def'i (TBK m. 97) ile karşılaşılır[46].

b) Sonuçları

Yukarıdaki şartlar gerçekleşince, vekâlet veren, taşınır eşyanın iflâs masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteyebilir. Alacaklarda, vekâlet veren lehine kanunî temlik gerçekleşir, yani vekâlet veren temlik sözleşmesi yapılmasına gerek olmadan alacağa kendiliğinden sahip olur; bununla beraber kanunî temlikin üçüncü kişilere etkisi bakımından, bunun üçüncü kişilere bildirilmesi gerekir. Böylece iyiniyetle vekile ödemede bulunmanın borçtan kurtarıcı etkisi (TBK m. 186) bertaraf edilmiş olur[47]. Buna karşılık, taşınırlarda, vekâlet veren,

---

45 **Tercier**, N. 4059-4061; OR-**Weber**, Art. 401, N. 2.

46 **Tercier**, N. 4067.

47 **Fellmann**, Art. 401, N. 71 vd; OR-**Weber**, Art. 401, N. 11; **Tercier**, 4069; BGE 112 II 90.

mülkiyet hakkını değil, mülkiyetin kendisine geçirilmesine ilişkin bir hak kazanır; açılacak dava sonunda verilecek hüküm bir edimin ifasına mahkumiyet şeklinde olacaktır[48].

[48] **Tercier**, N. 4070.

§ 31. MÜVEKKİLİN BORÇLARI

I. Ücret ödeme borcu

Vekâlet verenin borçlarını düzenleyen TBK m. 510'da ücret ödeme borcuna yer verilmemiştir. Bu eksiklik Roma hukukundan gelen, vekâletin ücret karşılığında yapılmayan, bir dostluk ve hatır işi olduğu görüşünün etkisine bağlanmaktadır[1]. Kanun koyucu ücretle ilgili düzenlemeyi, vekâletin kanunî tanımının yapıldığı TBK m. 502'nin III. fıkrasında yapmış bulunmaktadır. Buna göre, "Sözleşme veya teamül varsa vekil ücrete hak kazanır".

Vekilin ücret alacağı, aksine sözleşme ve teamül olmadıkça, vekâlet konusu işin tamamlanması ile muaccel olur[2].

II. Vekil tarafından yapılan masrafları ve verilen avansları ödeme borcu

Vekâlet veren, vekilin işin usulüne uygun olarak görülmesi için yaptığı masrafı ve verdiği avansları faiziyle beraber ödemek zorundadır (TBK m. 510/I).

TBK m. 510/I'de geçen avans deyimi vekilin para olarak yaptığı harcamaları ifade eder. Meselâ, seyahat masrafları, posta ücreti, vergi, resim ve harçlar, muhabir bankanın akreditif tutarını ödemesi[3]. Masraf kavramının dilimizde para harcamalarını da içine alan geniş bir anlamı bulunmakla beraber, burada para sarfetmeksizin bir eşyanın tüketilmesi (meselâ başkasına ait ata yem verilmesi) de masraf sayılır[4]. Bir eşyanın aşırı derecede yıpratılması ve eskitilmesi de tüketilme anlamına gelir ve TBK m. 510/I anlamında masraf olarak nitelendirilebilir[5].

---

1 **Gautschi**, Art. 402, N. 1a; **Fellmann**, Art. 402, N. 9.

2 **Becker**, Art. 394, N. 21; **Derendinger**, N. 417; **Weber**, Praxis, sh. 69; **Fellmann**, Art. 394, N. 469.

3 **Fellmann**, Art. 402, N. 15; **Oser/Schönenberger**, Art. 402, N. 2; **Gautschi**, Art. 402, N. 11a.

4 **Fellmann**, Art. 402, N. 16; OR-**Weber**, Art. 402, N. 4; **Oser/Schönenberger**, Art. 402, N. 2; **Gautschi**, Art. 402, N. 11b.

5 **Fellmann**, Art. 402, N. 17; **Becker**, Art. 402, N. 2; **Oser/Schönenberger**, Art. 402, N. 2.

Vekilin yaptığı masraf ve verdiği avansların vekâlet veren tarafından ödenebilmesi için, geçerli bir vekâlet sözleşmesinin bulunması ve vekâletin usulüne uygun olarak ifası için yapılması gerekir. Usulüne uygun ifa deyimi, vekâlet verenin talimatlarına uygun ve vekâletin ifası için objektif olarak zorunlu olma anlamına gelir[6]. Bu deyimin TBK m. 112 anlamında vekâletin gereği gibi ifası şeklinde anlaşılması[7] doğru değildir. Bu husus İsviçre Borçlar Kanunu'nun revizyonu esnasında uzmanlar komisyonunda (Expertenkommission) yapılan tekliflerden de anlaşılmaktadır[8].

III. Vekili vekâlet veren hesabına yüklendiği borçtan kurtarma yükümü

Vekâlet veren, vekili, onun vekâletin usulü dairesinde ifası için kendi adına üstlendiği borçlardan kurtarmakla yükümlüdür (TBK m. 510/I).

Borçtan kurtarma yükümünde de masraf ve avansın ödenmesi yükümündeki şartlar bulunmalıdır[9].

Vekilin yüklendiği borç başkası tarafından ifa edilebilir bir borç ise, vekâlet veren doğrudan doğruya üçüncü şahsa ifada bulunarak onu tatmin edebilir[10]. Vekilin borcu (henüz) ifa edilebilir bir borç değilse, vekâlet veren üçüncü kişiyle TBK m. 196 anlamında bir borcun dış yüklenilmesi sözleşmesi yaparak vekili borçtan kurtarabilir. Şayet alacaklı borcun yüklenilmesi sözleşmesini kurmayı reddederse, vekil, vekâlet verenden karşılık (Deckung), yani teminat sağlanmasını isteyebilir; şayet borç çok sonra muaccel olacaksa vekil vekâlet verenden sadece teminat sağlanmasını talep edebilir[11].

IV. Vekilin uğradığı zararı tazmin borcu

TBK m. 510/II'ye göre, "Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir. Ancak vekâlet ve-

---

6 **Becker**, Art. 402, N. 4; **Fellmann**, Art. 402, N. 37; **Werro**, N. 675; **Tercier**, N. 4102-4103; OR-**Weber**, Art. 402, N. 6.

7 Bu görüşte: **Gautschi**, Art. 402, N. 7a; **Tandoğan** II, sh. 581; **Yavuz**, sh. 613.

8 **Fellmann**, Art. 402, N. 35 ve 37; OR-**Weber**, Art. 402, N. 6.

9 OR-**Weber**, Art. 402, N. 8; **Fellmann**, Art. 402, N. 92 vd; **Tercier**, N. 4015.

10 **Tercier**, N. 4107; **Fellmann**, Art. 402, N. 98.

11 **Fellmann**, Art. 402, N. 99; **Tercier**, N. 4108; **Gautschi**, Art. 402, N. 18c ve 19; **Tandoğan** II, sh. 589-590; BGE 78 II 42.

ren, kusuru bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir".

Vekâlet verenin vekilin zararını tazminle yükümlü olabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

1) Bir zararın bulunması gerekir. Vekilin malvarlığında onun iradesine rağmen bir eksilme meydana gelmelidir. Buradaki zarar şahsa verilen zarar veya şeye verilen zarar şeklinde olabilir; seyahat masrafları veya boşa giden masraflar da TBK m. 510/II anlamında zarar kavramına girer[12].

2) Vekilin uğradığı zararla vekâletin ifası arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir.

3) Ücretli vekâlette, vekâlet verenin, kusurunun bulunmadığını isbat edememesi gerekir. Buna karşılık ücretsiz vekâlette, vekâlet veren, zararın doğmasında hiç kusuru olmasa dahi sorumlu olur; bu takdirde, vekâletsiz iş görmeye ilişkin TBK m. 527/I hükmü uygulanır. Buna göre vekâletsiz işgören her türlü ihmalinden sorumludur. İsviçre Federal Mahkemesi'nin MK m. 1'e dayanarak vardığı ve hakkaniyetin gereği olarak gördüğü bu sonuç[13], doktrin tarafından da kabul edilmektedir[14].

---

12 **Fellmann**, Art. 402. N. 149.

13 BGE 48 II 491 vd; 61 II 95.

14 **Becker**, Art. 402, N. 10; **Bucher**, BT, sh. 233; **von Büren**, BT, sh. 139, dn. 57; **Gautschi**, Art. 402, N. 23; **Hofstetter**, sh. 67 vd; **Honsell**, sh. 280; **Tercier**, N. 4113; **Knoepfler/Guinand**, FjS, Nr. 328, sh. 5; **Fellmann**, Art. 402, N. 139 vd, N. 179 vd; **Tandoğan** II, sh. 602. **Weber**'e göre (Art. 402, N. 14), meslekî bakımdan "işin esasını bilme" (berufliche Vertrautsein) kriterine dayanmak, yani meslekî risk alanına ağırlık vermek daha yerinde olur.

§ 32. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Borçlar Kanunu'nda vekâlet sözleşmesinin sona ermesine ilişkin olarak, üç maddeye (TBK m. 512-514) yer verilmiştir. Bunlardan 512. maddede tarafların tek taraflı irade beyanı (azil ve istifa) ile 513. maddede ölüm, ehliyetsizlik ve iflâs, sözleşmenin sona erme sebebi olarak düzenlenmiştir; TBK m. 514'te ise sona ermenin hükümleri tesbit edilmiştir. Burada genel hükümlerde düzenlenen borç ilişkisinin ve bu ilişkiden doğan münferit borçların sona ermesi nedenlerine değinmeden, sadece kanunda düzenlenen konuları inceleyeceğiz.

I. Tek taraflı sona erdirme (Azil ve istifa)

1. Hukukî niteliği ve kullanılması

TBK m. 512/c. 1'e göre, "Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir". İsviçre Borçlar Kanunu m. 404/I'de azil için geri alma (Widerruf); istifa için feshi bildirme (Kündigung) terimleri kullanılmaktadır. Kullanılan farklı terimlere rağmen, her iki halde de vekâlet sözleşmesinin, tek taraflı ve varması gereken bir irade beyanıyla ileriye etkili olarak (ex nunc) sona erdirilmesi söz konusudur[1]. Bu tek taraflı irade beyanı bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılması niteliğinde olup, bunun için tarafların haklı bir sebep göstermeleri gerekli değildir[2].

2. TBK m. 512/c. 1 hükmünün emredici nitelikte olup olmadığı

TBK m. 512/c. 1'de yer alan vekâlet veren ve vekilin istedikleri zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirmelerinin (vekâletten azil ve ondan istifanın) her zaman caiz olduğuna ilişkin hükmün emredici nitelikte olup olmadığı, yani bu haklardan önceden vazgeçilip geçilemeyeceği hususu tartışmalıdır.

---

1 **Tercier**, N. 4136; **Oser/Schönenberger**, Art. 404, N. 4; **Hofstetter**, sh. 47 vd; **Weber**, Praxis zum Auftragsrecht, sh. 126 vd; **Fellmann**, Art. 404, N. 16; **Gauch**, recht 1992, sh. 10; **Serozan**, Sözleşmeden Dönme, sh. 137 vd; **Tandoğan** II, sh. 620-621.

2 OR-**Weber**, Art. 404, N. 5; **Fellmann**, Art. 404, N. 16 ve 21; **Tercier**, N. 4136-4137; **von Tuhr/Escher**, sh. 167; **Gauch**, recht 1992, sh. 10; BGE 106 II 160.

Bir fikre göre[3], TBK m. 512/c. 1 hükmü emredici nitelikte olup, taraflar (vekâlet veren ve vekil) yenilik doğuran bu haktan önceden vazgeçemezler. Zira karşılıklı güven ilişkisinin egemen olduğu vekâlet ilişkisinde şahsî serbestinin sağlanması bu hükmün koruma amacının bir gereğidir; bu güvenin kaybolması halinde, kısa bir süre için de olsa, sözleşmeyle bağlı kalmak, MK m. 23 ile garanti edilen hareket serbestliğine aykırı olur[4]. Başka bir ifadeyle, sarsılan güven ilişkisine rağmen sözleşmenin devamının bir anlamı olmaz[5]. Diğer taraftan vekâlet sözleşmesinde işin görülmesinin vekâlet verenin iradesine ve menfaatine bağlı olması hususu, her zaman serbestçe geri alınabilirlikte (azilde) ifadesini bulur ve vekâletin temel özelliğini teşkil eder; bundan vazgeçildiği takdirde, çoğu zaman ücretli vekâlet ile hizmet sözleşmesi arasındaki fark ortadan kalkar[6].

Buna karşılık, son zamanlarda bir hayli taraftar bulan hakim fikre göre[7], bu hususta tipik ve atipik vekâlet arasında bir ayırım yapmak gerekir; ücretsiz veya ücretli olmakla beraber şahsa sıkı sıkıya bağlı nitelikte olan (meselâ doktor, avukat, inanılan) vekâletler tipik olup, bunlarda her zaman geri alınabilme emredici niteliktedir. Bu özelliklerin bulunmadığı vekâletler ise atipiktir; bunlarda her zaman sözleşmeyi tek taraflı bir irade beyanıyla sona erdirebilme hakkından önceden vazgeçilebilir.

3. Sonuçları

TBK m. 512/c. 2'ye göre, "Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür".

Haklı bir sebep olmaksızın diğer tarafa zarar verecek şekilde sözleşmenin tek taraflı bir irade beyanıyla sona erdirilmesi halinde, TBK

---

3 **Gautschi**, Art. 404, N. 10 vd ve 15; **Hofstetter**, sh. 48 vd, 52 vd; **Merz**, ZBJV 1985, sh. 216; aynı yazar, FS für Schluep, sh. 213; **Leuenberger**, sh. 42 vd; **Oser/Schönenberger**, Art. 404, N. 2; BGE 98 II 307 vd; 104 II 111 vd; 116 II 159; 109 II 467; 115 II 467 vd.

4 **Gautschi**, Art. 404, N. 10b.

5 BGE 104 II 115; 115 II 466.

6 **Gautschi**, Art. 404, N. 10 a.

7 **Bucher**, BT, sh. 228; **Tercier**, N. 4142 vd; **Honsell**, sh. 282; **Homburger**, SZW 1991, sh. 35; **Gauch**, recht 1992, sh. 15 vd; **Fellmann**, Art. 404, N. 115 vd; OR-**Weber**, Art. 404, N. 10; **Derendinger**, N. 60 vd; **Becker**, Art. 404, N. 8.

m. 512/c. 2 anlamında uygun olmayan bir zamanda azil ve istifa hali gerçekleşmiş olur; buna karşılık, karşı tarafın azil veya istifaya sebep olması halinde, sözleşmeyi zamansız sona erdirme söz konusu olmaz[8].

Uygun olmayan zamanda sözleşmenin sona erdirilmesi halinde tazminat ödenmesinin sebebi, sözleşmenin ihlâl edilmiş olması değildir; her zaman sözleşmeyi sona erdirme hakkının olumsuz sonuçlarını gidermeye yönelik, hakkaniyete dayanan bir tazminat söz konusudur[9].

TBK m. 512/c. 2 gereğince tazmini söz konusu olan zarar menfî zarardır. Bu zarara sözleşmenin kurulması sebebiyle yapılan masraflar, vekâletin ifası için alınan tedbirler ve girişilen masraflar, vekâlet verenin yeni bir vekil bulmak için yapacağı masraflar girer[10]. Bununla beraber, sözleşme ileriye etkili olarak sona ereceği için, ücret ödenmesi gereken hallerde, vekil, daha önce yaptığı işin ücretini talep edebilir[11].

II. Vekâlet sözleşmesinin taraflardan birinin ölümü, ehliyetin kaybedilmesi veya iflâsı sebebiyle sona ermesi

Aksi sözleşmeden veya işin mahiyetinden anlaşılmadıkça, vekâlet, gerek vekilin gerek vekâlet verenin ölümü, ehliyetinin kaybı[12] veya iflâsı ile sona erer (TBK m. 513/I). Ancak, vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi bizzat işlerini görebilecek hale gelinceye kadar,

---

8 OR-**Weber**, Art. 404, N. 16; **Werro**, N. 311; BGE 110 II 380; 109 II 469.

9 **Tercier**, N. 4151; **Gauch**, recht 1992, sh. 11 vd; OR-**Weber**, Art. 404, N. 16. Aksi fikirde: **Fellmann**, Art. 404, N. 67; **Werro**, N. 310; BGE 109 II 462; 110 II 380 vd.; "...vekil haksız azil halinde güvendiği vekalet ilişkisinin uygun olmayan zamanda ortadan kalkmasından dolayı uğradığı menfi zararı isteyebilecektir. Bu tazminatın dayanağı sözleşmenin ihlal edilmiş olması değildir. Her zaman sözleşmeyi sona erdirme hakkının olumsuz sonuçlarını gidermeye yöneliktir. Vekil, vekaletin devam edeceğine güvenerek fiilen yaptığı masraflar için belirtilen madde hükmüne dayalı olarak tazminat isteminde bulunabilir. Bu çeşit masrafın varlığını ve tutarını vekilin kanıtlaması gerekir. Zarar hesaplanırken vekilin bu masraflar dolayısıyla sağladığı yarar da mahsup edilmelidir (23. HD. 30..5.2013 tarih E. 2013/1342 K. 2013/3623 –Kazancı-).

10 OR-**Weber**. Art. 404, N. 17; **Tercier**, N. 4155; **Gauch**, recht 1992, sh. 11 vd; **Honsell**, sh. 282; BGE 110 II 386; 109 II 469 vd. Karş. **Fellmann**, Art. 404, N. 70 vd.

11 **Honsell**, sh. 282; BGE 109 II 331.

12 Tasfiye halinde şirketin tasfiyesinin tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edildiği tarihte tüzel kişiliği sona erdiğinden vekâlet sözleşmesi kendiliğinden son bulur (19. HD. 11.9.2014 tarih E. 2014/9507 K. 2014/13362 –Kazancı-).

vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi vekâleti ifaya devamla yükümlüdür (TBK m. 513/II)[13].

Vekilin vekâletin sona erdiğini öğrenmeden önce yaptığı işlerden, vekâlet veren veya mirasçıları, vekâlet devam ediyormuş gibi sorumludurlar (TBK m. 514).

[13] "...Görülmekte olan davada kendisini vekille temsil ettirdiği dosya kapsamından açıkça belli olmasına karşın, direnmeye ilişkin gerekçeli kararın "vekil" yerine "davacı asile" tebliğ edildiği anlaşılmaktadır... Davacı asilin, ölmesi kural olarak, vekil ile müvekkili arasındaki vekaletin sona ermesini gerektiren yasal bir neden ise de, vekalet ilişkisinin bu aşamada sona ermesi vekalet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürme ihtimali bulunması nedeniyle, vekilin vekaleti geçici olarak devam ettiğinin kabulü gerekir" (HGK 21.1.2015 tarih E. 2014/3-662 K. 2015/781 –Kazancı-).

DÖRDÜNCÜ KISIM
ŞAHSÎ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KEFALET SÖZLEŞMESİ

§ 33. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI

I. Tanımı

TBK m 581'e göre, "Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir". Bu madde hükmü isabetli olarak İsviçre TBK m. 492/ I'den alınmıştır. Bu bakımdan İsviçre doktrininde yapılan tanımla uyum taşımaktadır.

Kefalet bir sözleşme olup, bununla kefil, bir başka şahsın (asıl borçlunun) alacaklısına karşı, asıl borcun ifasından sorumlu olmayı taahhüt eder[1]. Yukardaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, kefalette üç türlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin tarafları, kefil, asıl alacaklı ve asıl borçludur; kefilin ifasından sorumlu olmayı taahhüt ettiği borca "asıl borç" denilmektedir.

Kefalet sözleşmesi kefil ile alacaklı arasında kurulur; kefilin borç altına girebilmesi için asıl borçlunun rızasına ve hatta bu konuda bilgi sahibi olmasına ihtiyaç yoktur[2]. Zira kefalet sözleşmesi asıl borçlunun sorumluluğu üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir; aksine, çok defa ona yarar sağlamaktadır[3]. Kefalet sözleşmesinin kurulmasıyla, kefil ile borçlu arasında herhangi bir borç ilişkisi meydana gelmez. Kefil alacaklının talebi üzerine, asıl borçlunun borcunu değil,

---

1 **Giovanoli**, Art. 492, N. 1; **Oser/Schönenberger**, Art. 492, N. 6; **Scyboz**, sh. 43; **Tercier**, N. 3646; **Engel**, sh. 590; **Honsell**, sh. 332; **Tandoğan** II, sh. 693; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 6; Ayrancı (Şekil Şartı), sh. 95.

2 İcra Dairesindeki kefaletler ilamların icrası hükmüne tabidir. Bu tür icra kefaleti müteselsil kefalet hükmündedir (İİK m. 38).

3 **Reisoğlu**, sh. 1.

kendi borcunu ifa etmiş olur[4]. Kefalet, kefil ile asıl borçlu arasındaki ilişkiden bağımsızdır[5]. Kefil ile asıl borçlu arasındaki ilişki, vekâlet, vekâletsiz iş görme veya bağışlama şeklinde olabilir[6]. Bununla beraber, asıl borçlu, kefil veya alacaklının temsilcisi olarak hareket edebilir[7].

II. Hukukî niteliği

1. Kefilin borcu fer'i (bağımlı) borçtur

a) Genel olarak

Kefalet sözleşmesinin en önemli özelliği, kefilin borcunun fer'i, yani asıl borca bağımlı bir borç olmasıdır. Buna göre, kefilin borcu doğuş, devam ve ifa mecburiyeti açısından asıl borca bağlıdır; asıl borç olmadan kefalet borcundan söz edilemez[8].

b) Fer'iliğin sonuçları

Kefilin borcunun fer'i (bağımlı) nitelik taşımasının başlıca sonuçları şunlardır[9]:

– Kefilin borcunun doğumu, geçerli bir asıl borcun bulunmasına bağlıdır. Bu husus, TBK m. 581/ I anlamından ve m. 582/ I, c. 1'de yer alan "kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir" ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.(TBK m. 598/ I).

– Kefilin borcu, kapsam ve muhteva bakımından asıl borca bağlıdır. Şu anlamdadır ki, kefil asıl borçludan daha fazla bir mükellefiyet yüklenemez ve onun sorumluluğu asıl borçludan daha ağır olmaz[10].

---

4 OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 5; BGE 70 II 273.

5 **Scyboz**, sh. 43-44.

6 **Honsell**, sh. 335; **Tandoğan** II, sh. 694; **Reisoğlu**, sh. 1, dn. 2a'daki karar.

7 OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 5; **Oser/Schönenberger**, Art. 492, N. 8 vd; BGE 45 II 172; 56 II 101 vd; 65 II 236.

8 **Giovanoli**, Art. 492, N. 2; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 29, 30; **Beck**, Art. 492, N. 88 vd; **Kleiner**, sh. 31; **Tandoğan** II, sh. 695; **Reisoğlu**, sh. 2; BGE 113 II 436; 111 II 279.

9 **Scyboz**, sh. 50 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 34 vd; **Tercier**, N. 3656; **Reisoğlu**, sh. 3-4; **Tandoğan** II, sh. 695-696.

10 Asıl borçluya karşı yürütülen takipte temerrüt faizi işletildikten sonra kefile müracaat halinde bu iki kalemin toplanarak oluşturulan yeni meblağ üzerinden faiz yürütülmesi TBK m.121/III gereğince temerrüt faizine temerrüt faizi yürütülümeyeceğinden kabul edilemez (bkz. 23. HD. 17.9.2013 tarih E. 2013/4723 K. 2013/5479 –Kazancı-).

– Asıl borç muaccel olmadan kefilin borcu muaccel olmaz. TBK m. 590/I ve III'e göre, asıl borcun muaccel olması, alacaklı veya borçlunun önceden süre içeren bildirimde bulunmasına bağlıysa, bu bildirimin kefile de yapılması gerekir; kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile yapıldığı tarihte işlemeye başlar. Böyle bir durumda, asıl borçluya ihbar yapılmadan kefile ihbarın yapılmış olması, asıl borcu muaccel kılmaz ve bunun sonucu olarak kefilin borcu da muaccel olmaz[11].

– Asıl borcun şarta bağlı olması halinde, kefilin kayıtsız ve şartsız borç altına girmesi geçersiz olur.

– Kefalet alacağı asıl alacaktan bağımsız olarak temlik edilemez. TBK m. 189/I gereğince, bir alacak temlik edilince ona bağlı (fer'i) haklar da yeni alacaklıya geçer. Bu itibarla, asıl alacağın temliki ile onun fer'i olan kefalet alacağı da, kanun gereğince asıl alacağı devralana geçer. Bununla beraber, tarafların kefalet alacağının yeni alacaklıya geçmeyeceğini, ilk alacaklıya ait olacağını kararlaştırmaları halinde, temlikle birlikte kefalet borcu sona erer[12].

Asıl borcun borçlusu değiştiği takdirde, kefil, borcun nakline rıza gösterirse, yeni alacaklıya karşı sorumlu olur (TBK m. 198, 140). Kefilin borcun nakline rıza göstermesi ile yeni bir kefalet sözleşmesi kurulmayıp, mevcut olan sözleşme ve bundan doğan kefalet borcu devam eder. Bunun için rızanın en geç borcu nakleden sözleşmenin kurulmasından önce gerçekleşmesi gerekir[13]. Kefilin, her türlü borçlu sıfatının değişmesine önceden muvafakat ettiğini bildirmesi geçersizdir[14].

– Kefil, borçlunun niteliği gereği hariç kalması gerekenler (meselâ asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğü) istisna olmak üzere, asıl borçluya ait bütün def'ileri alacaklıya karşı ileri sürebilir (TBK m. 591/I).

– Kefaletten doğan alacağını ileri sürmek isteyen alacaklı, sadece kefalet alacağını değil, asıl borcun varlığını da isbat etmek zorundadır[15].

---

11 **Tandoğan** II, sh. 695.

12 **Becker**, Art. 493, N. 3; **Giovanoli,** Art. 492, N. 24; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 39; BGE 78 II 57 vd yahut JdT 1953 I 318. Karş. **Schultess**, ZSR 1924, sh. 88; **Scyboz**, sh. 74.

13 **Scyboz**, sh. 74.

14 OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 39; BGE 67 II 130 vd, Erw. 3.

15 BGE 23 361; Ayrancı (Cari Hesaba Kefalet), sh. 109.

c) İstisnaları

Aşağıdaki hallerde fer'ilik ilkesinin istisnası söz konusu olur[16]:

– İflâsın açılmasından sonra asıl borçlu aleyhine faiz işlemediği halde (İİK m. 196), kefilin faizlerden sorumluluğu devam eder. Bunun sebebi, kefaletin asıl borçlunun ödeme gücünün bulunmamasına karşı, alacaklıyı korumaya yönelik bir müessese olmasıdır[17].

– Konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklı, konkordato tasdik edilse bile kefile karşı alacağının tamamını talep hakkını muhafaza eder (İİK m. 295/I). Alacaklı hem konkordatoya muvafakat etmek, hem de kefile karşı hakkını saklı tutmak istiyorsa, ona ödeme karşılığında alacağını temlik etmeyi teklif etmesi ve en az on gün önce alacaklılar toplantısının günü ve yeri hakkında bilgi vermesi gerekir (İİK m. 295/II).

– Asıl borçlunun ölümü üzerine mirasçıları mirası tutulan defter gereğince kabul etmişlerse, alacaklarını kaydettirmemiş olan alacaklılara karşı mirastan kendilerine düşen miktar ile sorumlu oldukları halde, kefil borcun tamamından sorumlu kalır[18]. Buna karşılık bizzat kefalet borcuna has sona erme sebeplerinin fer'ilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Kefilin ölümü halinde, onun mirasçılarının kefalet borcundan sorumluluğuna ilişkin MK m. 630 hükmünün uygulanmasında durum böyle olur[19].

2. Kefilin borcu tâli (ikinci derecede) borçtur

Fer'ilikten farklı olarak, tâlilik (ikinci derecede olma = subsidiarité) kefalet borcunun ileri sürülebilme şartlarına ilişkin bir kavram olup, asıl borçluya takip yapılıp bu takip semeresiz kalmadan ve rehne başvurulmadan kefile yönelmemeyi ifade eder[20].

Kefilin borcunun tâli niteliği âdi kefalette söz konusudur (TBK m. 585/I). Bazı yazarlar[21], müteselsil kefalette (TBK m. 586/I) de bu nite-

---

16 Bk. **Giovanoli**, Art. 492; N. 28 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 52 vd; **Reisoğlu**, sh. 4; **Tandoğan** II, sh. 696.

17 **Giovanoli**, Art. 492, N. 28.

18 MK m. 569 son cümle; **Schönenberger/Sungurbey**, Eski Kefillik, Art. 492, N. 39; **Tandoğan** II, sh. 696.

19 **Giovanoli**, Art. 492, N. 28. Aksi fikirde: **Lerch/Tuason**, sh. 19, 1. c.

20 **Giovanoli**, Art. 495, N. 4 vd; **Scyboz**, sh. 97 vd, 103; **Tandoğan** II, sh. 697; **Reisoğlu**, sh. 5.

21 **Reisoğlu**, sh. 5; **Yavuz**, sh. 780-781.

liğin mevcut olduğunu ifade etmektedirler. Buna gerekçe olarak da, asıl borç muaccel olmadan müteselsil kefilin borcunun muaccel hale gelmeyeceğini ve paradan başka borçlara kefalette, asıl borcun yerine getirilmediğinin tesbitinden sonra kefilin borcunun gerçekleşebileceğini ileri sürmektedirler. Kanaatimizce, muacceliyete ilişkin iddialar fer'ilik ilkesiyle ilgilidir. Uygulamada daha çok para borçlarına kefil olunmaktadır.

3. Kefaletin ivazsızlığı

Kefalet sözleşmesi, kural olarak tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, bununla sadece kefil borç altına girer. İsbat vasıtalarının teslimi (TBK m. 592/III) veya kefilin alacaklıya halef olması sözleşmeyle kararlaştırılmış olsa dahi karşı edim niteliği taşımazlar[22].

Asıl borçlunun kefaleti sağlamak için kefile bazı menfaatler sağlaması (kefil olacak bankaya bir komisyon vermesi), kefalet sözleşmesinin ivazsız olma niteliğini gidermez. Bu tür bir menfaat kefil ile asıl borçlu arasındaki iç ilişkiye dahil bir unsurdur[23].

III. Benzer sözleşmelerden farkları

1. Garanti sözleşmesinden farkları

TBK m. 128'deki düzenlemeye dahil bulunan garanti sözleşmesi başlıca iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi saf garanti (reiene Garantie) olup, bununla, garanti veren garanti alana belirli bir (somut) borç ilişkisinden bağımsız olarak bir sonucu garanti eder. Meselâ, bir banka veya bir belediye, bir teşebbüsün sonuçlarını, onun kayıplarını karşılamayı veya belirli bir kârını garanti edebilir; bu durumda üçüncü şahıslar, garanti alana karşı herhangi bir borç altına girmemektedir[24].

Garanti sözleşmesinin ikinci şeklinde, garanti taahhüdü kendisine taahhütte bulunulana, yani garanti alana üçüncü şahsın edimini talep hakkı veren herhangi bir borç ilişkisine (temel işleme) ilişkindir. Bununla beraber, söz konusu edim, fiilen borçlanılmış olup olmadığına bakılmaksızın garanti edilmektedir. Bu garanti üçüncü şahsın edimi

---

22 **Scyboz**, sh. 44; **Tercier**, N. 3649.

23 **Reisoğlu**, sh. 6; **Tandoğan** II, sh. 695.

24 **Scyboz**, sh. 13; **Guggenheim**, les contrats de la pratigue bancaire suisse, sh. 180; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 158; OR-**Pestalozzi**, Art. 41, N. 6; **Kleiner**, sh. 23 vd; BGE 113 II 436 yahut JdT 1988 I, sh. 187.

doğmasa, sona ermiş olsa veya dava edilebilir olmasa dahi geçerliliğini korumaktadır[25]. Uygulamada çok rastlanan bu tür garantiye, garanti verenin tazmin borcunun, temel ilişkide garanti alanın borçlusu olan üçüncü şahsın davranışına bağlı olması sebebiyle, kefalet benzeri garanti adı verilmektedir[26]. Kefalette olduğu gibi, burada da üçlü bir ilişki bulunmakta; garanti alanla üçüncü şahıs arasındaki temel ilişkiyi teminat altına almak amacıyla garanti sözleşmesi kurulmaktadır[27].

Aralarındaki bu benzerliğe rağmen, kefalet ile kefalet benzeri garanti arasında aşağıdaki farklar mevcuttur:

a) Kefaleti, kefalet benzeri garantiden ayıran en önemli kriter fer'iliktir (Akzessorietaet). Buna göre kefilin borcu fer'i, yani asıl borcun kaderini paylaşan bir borçtur. Oysa, garanti verenin borcu bağımsız bir borç olup, temel ilişkiden ve bu ilişki çerçevesinde üçüncü şahsın taahhüt ettiği edim yükümünden bağımsızdır[28]. Aynı şekilde, kefilin aksine, garanti veren esas borç ilişkisinden doğan def'i ve itirazları ileri süremez[29].

b) Kefalet sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına ve kefilin sorumlu olacağı azamî meblağın sözleşmede belirtilmesi şartına bağlıdır (TBK m. 583/I). Oysa garanti sözleşmesinde şekil serbestisi ilkesi (TBK m. 12/I) geçerli olup, garanti verenin borcunun sınırının sözleşme metninde gösterilmesi gerekli değildir; belirlenebilir olması yeterlidir. Buna karşılık TBK m. 603 gereğince, gerçek kişinin garanti vermesi halinde kefaletin şekline ve eşin rızasına ilişkin hükümler bu işleme de uygulanır.

c) Kefil ödemede bulunduğu oranda alacaklının haklarına halefolur ve borçluya rücu edebilir (TBK m. 596/I). Garanti veren ise, kanunî bir halefiyet hakkına sahip değildir.

---

[25] **Guggenheim**, sh. 180; **Kleiner**, sh. 27 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 6; **Scyboz**, sh. 14; BGE 113 I 436 yahut JdT 1988 I, sh. 187; 125 III 305.

[26] **Kleiner**, sh. 27 vd; **Scyboz**, sh. 14; **Guggenheim**, sh. 180, dn. 40'a ait metin; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 6; BGE 113 II 436.

[27] OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 31.

[28] **Kleiner**, sh. 30 vd; **Guhl/Merz/Kummer**, sh. 158; **Dohm**, sh. 58, N. 72 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 31; Art. 492, N. 32; **Giovanoli**, Art. 492, N. 13 vd; BGE 113 II 437; 125 III 305.

[29] **Kleiner**, sh. 31 vd; sh. 35-36, N. 5, 12; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 31; BGE 113 II 437.

2. Müteselsil borçluluk ve borca katılmadan farkları

Müteselsil borçlulukta (TBK m. 162-168) alacaklı, birden çok borçlunun her birinden borcun tamamının ifasını talep etme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu durum alacaklının tamamen tatmin edilmesine, yani müteselsil borcun tamamının ifa edilmesine kadar devam eder.

Müteselsil borçlulukta borçluların sorumluluğu tek ve aynı hukukî sebebe dayanmaktadır. Oysa kefalette kefilin borcunun hukukî sebebi, asıl borçlununkinden farklı olarak, teminat vermektir[30]. Bundan başka, müteselsil borçlulukta her borçlunun borcu aslî ve bağımsız nitelik taşıdığı halde, kefilin borcu fer'i ve tâli nitelik taşır. Müteselsil kefalette tâlilik niteliğinin bulunmaması dahi, ona müteselsil borçlu sıfatını vermez[31].

Borca katılma (Schuldbeitritt) (TBK m. 201) veya birlikte borç üstlenme (kumulative Schuldübernahme) halinde, üçüncü bir şahıs, alacaklıya karşı mevcut bir borcu asıl borçlunun yanında ve onunla birlikte müteselsil olarak sorumlu olmayı taahhüt etmektedir. Böylece borca katılan veya birlikte borç üstlenen kişi ile borçlu aynı sebebe binaen ve bağımsız aslî borçlu sıfatıyla sorumlu olmaktadır[32]. Kefaletin aksine, borca katılma sözleşmesi geçerlilik bakımından özel bir şekil şartına bağlı değildir ve fer'i bir nitelik taşımaz. Borca katılanın veya birlikte borç üstlenenin borcu, doğuş bakımından katılınan borcun geçerliliğine tâbidir; başkasının geçerli bir borcunun bulunmasını şart kılar. Fakat kefaletten farklı olarak, borca katılan, katılınan borcun akıbetinden ve sonradan mâruz kalacağı değişiklikten etkilenmeden bağımsız varlığını sürdürür. Borcun tamamen edasına kadar, borca katılanın sorumluluğu devam eder (TBK m. 163/II). Böylece kefalet borcu, her bakımdan asıl borca bağlı olma, yani fer'ilik bakımından, borca katılmadan ayrılmaktadır[33].

---

30 **Scyboz**, sh. 30

31 OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 32; **Giovanoli**, Art. 492, N. 17; **Scyboz**, sh. 31.

32 **Beck**, sh. 24 vd, Einl. N. 24; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 32; bkz. Ayrancı (Sözleşmelerin Devri), sh. 75; BGE 111 II 278 vd.

33 **Giovanoli**, Art. 492, N. 17; OR-**Pestalozzi**, Art. 111, N. 32; **Scyboz**, sh. 31; **Oser**, Art. 492, N. II, 1; **Oser/Schönenberger**, Art. 492, N. 49 vd; **Tandoğan** II, sh. 702, 706.

3. Avalden farkları

Aval, poliçe ve bonodan doğan bir borcun ticarî senetler hukukuna göre tekeffül edilmesidir (TTK m. 700-702). Kefalet fer'i bir nitelik taşıdığı halde, aval verenin borcu aslî ve bağımsız bir borçtur. Aval ve kefalet şekil açısından da birbirinden ayrılır. Aval şerhinin poliçe, bono veya alonj üzerine yapılması gerekir (TTK m. 701/1); kefaletin mutlaka asıl borç senedi üzerinde gösterilmesi şart değildir. Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere, bononun üzerine konan her imza aval şerhi sayılır (TTK m. 701/3).

Kefalette alacaklının haklarına halefiyet söz konusu olduğu halde, aval veren ödemede bulunmakla, aval verdiği kişi ve ona karşı sorumlu olanlar aleyhine bağımsız bir rücu hakkı kazanır ve halefiyetten yararlanamaz[34].

4. Kefalete ilişkin bazı hükümlerin kişisel güvence sağlayan diğer işlemlere uygulanması

TBK m. 603 "Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır" hükmünü amirdir.

Buna göre kanuni düzenlemenin kapsamına giren ilişkiler bakımından gerçek kişiler tarafından kişisel güvence verilmesi halinde kefaletin şekline, ehliyete ve eşin rızasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Kefaletin şekle ilişkin hükümleri TBK m. 583'te düzenlenmiştir. Kanuna yazılı şekil şartını geçerlilik şartı olarak kabul etmektedir. Bu yazılı şekil içinde kefilin sorumlu olduğu azami miktar ve kefalet tarihi zorunlu unsur olarak belirlenmiştir. Kefalet vermeye ilişkin temsil yetkisi de bu maddede belirtilen şartları içermelidir.

Diğer yandan kefil olma ehliyeti madde kapsamında kalan diğer ilişkilere de uygulanmaktadır. Yasal temsilcinin sınırlı ehliyetsiz adına kefalet verme yasağı böylece garanti sözleşmeleri için de öngörülmüştür. Aynı şekilde eşin rızası kişisel güvence verilmesine ilişkin işlemlerde aranmaktadır.

Kişisel güvence sağlayan işlemler kapsamına öncelikle teminat amaçlı garanti sözleşmeleri girmektedir. Kefaletten daha ağır sonuçlar

---

[34] **Tandoğan** II, sh. 715.

doğuran garanti sözleşmesinin herhangi bir şekil ve esasa ilişkin şarta tabi olmaksızın kurulması imkânı böylece engellenmiştir.

Bu hüküm gerçek kişilerin borca katılmak yoluyla müteselsil sorumluluğunu da şartlara bağlamaktadır. Diğer bazı hukuki ilişkilere TBK m. 603 hükmünün uygulanması bu işlemlerin kişisel güvence sağlaması ve kanunun düzenleme kapsamı içinde kalması şartlarının bulunması ile mümkün olmaktadır.

§ 34. KEFALETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

I. Geçerli bir asıl borcun bulunması

1. Genel olarak

Türk Borçlar Kanunu m. 582/ I'e göre, "Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir". Bu fıkranın 1. cümlesi biraz önce ifade edildiği gibi, kefaletin fer'iliği ilkesinin sonucudur[1]. Asıl borcun başlangıçtaki imkânsızlık, hukuka veya ahlâka aykırılık, şekil eksikliği, muvazaa gibi sebeplerle bâtıl veya hukuken mevcut olmaması halinde, kefalet sözleşmesi de geçersiz olur[2]. Kefil, asıl borcun mutlak butlan sebebiyle geçersiz olduğunu bilmeden yaptığı ödemeyi sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak geri alabilir (TBK m. 78/I). Bâtıl olan sözleşmenin yeniden geçerli bir şekilde yapılması halinde, yeni bir kefalet sözleşmesinin düzenlenmesi gerekir[3]. Ancak gelecekte doğacak veya şarta bağlı borç için de, bu borç doğduğunda veya şart gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir (TBK m. 582/c. 2). Kefalet sözleşmesinde asıl borcun, kefalet sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut olması gerekmez; kefalet borcunun ifasının talep edildiği anda mevcut bulunması yeterlidir[4]. Bu husus TBK m. 582/c.2'de düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümde yeralan "gelecekte doğacak" deyimi ile vadeye bağlı borç kastedilmektedir. Burada ifade edilmek istenen, kefalet sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut olan veya ilerde kurulacak

---

1 **Scyboz**, sh. 81; **Tercier**, N. 3706; **Giovanoli**, Art. 492, N. 2, 19; **Honsell**, sh. 336-337; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 29, 45; **Reisoğlu**, sh. 15; Ayrancı (Cari Hesaba Kefalet), sh. 108.

2 **Giovanoli**, Art. 492, N. 76; **Scyboz**, sh. 81; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 45; **Tercier**, 3710; **Tandoğan** II, sh. 721; **Reisoğlu**, sh. 15; 13. HD, 20.3.1984, E. 458/K. 2118, YKD 1984, sh. 1544.

3 **Scyboz**, sh. 53; **Oser/Schönenberger**, Art. 492, N. 30; **Tandoğan** II, sh. 721.

4 **Scyboz**, sh. 51; **Engel**, sh. 591; **Tercier**, N. 3707; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 48; **Tandoğan** II, sh. 719; **Reisoğlu**, sh. 17; **Grassinger**, sh. 65-66; ayrıntılı bilgi için bkz. Ayrancı (Cari Hesaba Kefalet), sh. 112 vd.

borç ilişkilerinden doğacak borçlardır. Meselâ, mevcut veya ilerde kurulacak kira ilişkisinden doğacak kira borçlarına kefil olunabilir. Uygulamada genellikle kredi açma veya carî hesap sözleşmeleri çerçevesinde bankaların verecekleri krediler ile memur ve müstahdemler için verilen kefalette, gelecekteki bir borç için kefalet sözleşmesi yapılmaktadır[5].

Gelecekte doğacak borçlar ile geciktirici şarta bağlı borçlar için kefalette, kefalet sözleşmesi, müstakbel borcun doğduğu veya geciktirici şartın gerçekleştiği andan itibaren hükümlerini doğurur (TBK m. 582/c. 2). Bozucu şarta bağlı kefalette ise, şartın gerçekleşmesiyle kefalet borcu sona erer.

2. İptal edilebilir bir borca kefalet

Türk Borçlar Kanunu m. 582/I'e göre, kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Asıl borcun gabin veya hata gibi sebeplerle iptal edilebilir bir işlemden doğması halinde, kefalet borcunun sonucu, asıl borçlunun iptal yetkisini kullanıp kullanmamasına bağlıdır. Asıl borçlu sahip olduğu iptal yetkisini kullanmadığı sürece, kefalet borcu varlığını korur; yenilik doğuran bir yetki olan iptal yetkisini ancak asıl borçlu kullanabilir. İptal yetkisinin kullanılmasıyla kefalet borcu da sona erer[6]. Asıl borçlunun TBK m. 39'da öngörülen bir yıllık süre içinde iptal yetkisini kullanmaması veya bu süre içinde kullanmaktan feragat etmesi halinde, akit geçmişe etkili olarak her türlü sakatlıktan uzak bir şekilde yapılmış sayılır[7].

Aynı şekilde, sınırlı ehliyetsizin taahhüt ettiği asıl borca kanunî temsilcisinin icazet vermesi halinde, bu borcu doğuran sözleşmedeki eksiklik tamamlanmış olur ve sonuçlarını başlangıçtan itibaren doğurur. Kanunî temsilcinin icazet vermediğini bildirmesi halinde ise, eksik sözleşme kesin olarak hükümsüz hale gelir ve kefalet borcu sona erer.

Buna karşılık, iptal veya icazet yetkisi kullanılıncaya kadar, kefil geçici olarak kefalet borcunu ifadan kaçınabilir. İsviçre Medeni Kanunu'nda 1941'de yapılan değişiklikle açıkça hükme bağlanan (İBK

---

5 **Engel**, sh. 591-592; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 50; **Tandoğan** II, sh. 720; **Reisoğlu**, sh. 17; BGE 65 II 30 vd.

6 OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 47; **Scyboz**, sh. 53; **Giovanoli**, Art. 492, N. 77; **Oser/Schönenberger**, Art. 492, N. 31; **Tandoğan** II, sh. 721 vd; **Reisoğlu**, sh. 18.

7 **Eren**, C. I, sh. 501.

m. 502/c. 2) bu sonucun, takasla ilgili olarak kefile ödemeden kaçınma hakkı veren TBK m. 140 hükmünün kıyas yoluyla uygulanması suretiyle elde edilebileceğini kabul etmek gerekir[8].

TBK m. 582/II'ye göre, "Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel güvence veren kişi, yükümlülük altına girdiği sırada, sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyorsa, kefaletle ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur. Aynı kural, borçlu yönünden zamanaşımına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır". Buna göre kefil, kefalet sözleşmesinin kurulduğu anda, asıl borca ilişkin sözleşmenin hata veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlu yönünden bağlayıcı olmadığını biliyorsa, kefaletle ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur (TBK m. 582/ II, c. 1).

Bu hükmün anlamını tayin konusunda iki ihtimal akla gelmektedir. Kefil ya asıl borçlunun TBK m. 39'daki süre içinde sözleşmeyi iptal etmeyeceği veya icazet vereceği veyahut kanunî temsilcinin icazet vereceği şartına bağlı olarak kefalet akdini kurmuştur. Bu takdirde taliki şarta bağlı kefalet sözleşmesi vardır[9]. Ancak, şarta bağlı borç için kefil olunabileceğini öngören TBK m. 582/II hükmü karşısında bu ihtimali kabul etmek güçtür[10]. Bu konudaki ikinci görüş, kefilin icazetin verilmemesi (MK m. 16) veya iptal yetkisinin kullanılması (TBK m. 39) ihtimalini gözönünde tutarak alacaklıya teminat vermesidir. Böyle bir taahhüt kefalet akdinin fer'iliği ilkesiyle bağdaşmadığı için, bu ihtimalde, kefalet hükümlerine tâbi bir garanti sözleşmesinin bulunduğu sonucuna varmak gerekir[11]. TBK m. 582/II, c. 2 gereğince, "aynı kural, borçlu yönünden zamanaşımına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır".

3. Bu haklardan önceden feragat

TBK m. 582/III'e göre, "Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez". Bu

---

8 **Aral**, Takas, sh. 86 ve dn. 8'de zikredilenler; BGE 45 II 568; **Grassinger**, sh. 41; sonuç olarak aynı yönde: **Tandoğan** II, sh. 722; **Reisoğlu**, sh. 18.

9 **Tobler**, sh. 23; **Lerch-Tuason**, sh. 20; **Scyboz**, sh. 55, dn. 17.

10 **Aral**, sh. 91. Ayrıca bk. **Reisoğlu**, sh. 19 vd; **Tandoğan** II, sh. 722.

11 **Becker**, Art. 494, N. 3; **OR- Pestalozzi,** Art. 492, N. 25- 26; **Oser**, Art. 494, N. 4; **von Tuhr**, SJZ 19/1922-1923, sh. 226; **Tandoğan** II, sh. 722; **Aral**, sh. 91; **Grassinger**, sh. 58 vd; BGE 56 II 381.

bölümde tanınan haklardan önceden feragat etmesi için kanunda açık bir hüküm bulunması gerekir.

II. Kefalette şekil

Türk Borçlar Kanunu m. 583'e göre, "Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır (f. I). Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler (f. II). Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz (f. III)".

Genel olarak, kefalet sözleşmesinin, geçerli olması için, yazılı şekilde yapılmış olması, kefilin sorumlu olacağı azami miktarın ve kefalet tarihinin belirtilmesi gerekir[12]. Kefil olunan azami miktar[13] ile kefalet tarihi veya müteselsil kefil olunması halinde bu sıfatla veya bu

---

12 "...Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde düzenlenmesi kefilin sorumlu olacağı miktarın ve azami hangi sürede sorumlu olacağının sözleşmede açıkça gösterilmesi şarttır. İcra takibine konu Kira sözleşmesinde belirtildiği üzere, kefillerin kefaleti müşterek borçlu ve müteselsil kefil olup akit kanun gereği yenilendiği takdirde kefalet akdi de aynı şartlarla aynı süre için yenilenmiş olacaktır. Sözleşmenin devam etmesi halinde azami 10 yıl ile kira parası, elektrik, su, ortak giderler yönetim giderleri, mecura verilecek hasar tazminini, tüm faizlerini bu kira sözleşmesi sebebiyle doğrudan kiracı aleyhine açılacak dava ve/veya icra takiplerini, vekalet ücretlerini, tüm ferileri karşılamak üzere azami 25.000 euro ya kadar müşterek ve müteselsil kefil olmayı kabul etmişlerdir." hükmüne yer verilmiştir. Kefillerin sorumluluklarının azami süre ve bedel yönünden sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır (6.hd. 5.6.2013 tarih E. 2013/7869 K. 2013/9913 –Kazancı-).

13 Kiralananın hor kullanılması sonucu doğan zarar kefalet sözleşmesinin düzenlendiği esnada bilinebiler ve belirlenebilir mahiyet taşımadığından kefilin tazminat miktarından sorumlu olması sözkonusu değildir (6. HD. 27.11.2014 E. 2014/3278 K. 2014/13173 –Kazancı-).

anlama gelen bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğinin kendi el yazısıyla belirtilmesi şarttır[14].

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunması da aynı şartlara bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlayabilirler.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu arttıran değişiklikler, kefil için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

III. Eşin rızası

TBK m. 584'e göre, "Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır" (f. I). Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez" (f. II).

Düzenlemeye göre eşlerden birinin bir borca kefalet vermesi için diğer eşin yazılı olarak bu işleme rıza vermesi gerekmektedir. Eşin rızası bir geçerlilik şartıdır. Aksi halde işlem hüküm ve sonuç doğurmaz. Rıza vermesi gereken eşin kadın veya erkek olması konusunda bir ayırım yapılmamıştır.

Eş tarafından kefalete verilen rızanın en geç sözleşmenin kurulması anında yapılması gerekmektedir. O halde eş kefalete ya önceden rızasını beyan ederek izin vermeli, ya da işlem esnasında rızasını beyan ederek işleme katılmak suretiyle rıza beyan etmelidir. Kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra diğer eşin işleme icazet (onay) vermesi geçersizlik sonucu doğurmaktadır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine

---

[14] "...Somut olayda 03.02.2014 tarihli icra kefalet tutanağında; sorumlu olunan azami miktarın ve kefalet tarihinin kefilin kendi el yazısı ile yazılmadığı görülmekte olup; bu haliyle, kefalet tutanağının, kefaletin şeklini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinde belirtilen şartlarda düzenlenmediği anlaşılmaktadır" (12. HD. 22.12.2014 tarih E. 2014/25766 K. 2014/31114, 8. HD. 23.9.2013 tarih E. 2013/14237 K. 2013/12865 –Kazancı-).

ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez

Kefalet sözleşmesinde kefil aleyhine sonuç doğurmayan bazı değişikliklerin diğer eşin rızası alınmadan yapılması mümkündür. Kefalet miktarının artmamış olması, adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmemiş olması, kefil yararına olan güvenceleri önemli oranda azaltmayan değişiklikler kanunda örnek olarak sayılmış bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunun 584. maddesine 28.3.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanun ile eklenen üçüncü fıkraya göre, ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibi veya ticaret şirketlerinin ortakları ya da yöneticisi eşlerinin rızasını almaksızın işletme veya şirketle ilgili olarak kefalet verebilirler. Aynı şekilde esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak verecekleri kefaletler, 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilere verilecek kefaletler, tarım kredi, tarım satış, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerince kullanılacak krediler için verilen kefaletler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilere verilecek kefaletler için eş rızası aranmamaktadır.

§ 35. KEFALETİN ÇEŞİTLERİ

I. Âdi kefalet

1. Genel olarak

Âdi kefalet Borçlar Kanunu'nun sistemine göre asıl olan bir kefalet tipidir; kefilin müteselsil olarak borç altına girmediği her kefalet âdi kefalettir.

Âdi kefalette kefilin borcu tamamen tâli bir nitelik taşır; alacaklı, asıl borçluya karşı haklarını ileri sürmeden kefile karşı talepte bulunamaz. O, ancak alacağını asıl borçludan tahsil edemediği veya tahsil etme imkânının bulunmadığı hallerde kefile başvurabilir. Aksi takdirde, kefil, alacaklıya karşı tartışma def'i ile rehnin paraya çevrilmesi def'ini ileri sürebilir. Kefil bu iki def'i birlikte (kümülatif olarak) ileri sürebilir. Meselâ kefil, rehnin paraya çevrilmesinden sonra alacağının tamamına kavuşamayan alacaklıya karşı, tartışma def'ini ileri sürebilir[1]. Kefil bu iki çeşit def'iden başlangıçta veya sonradan feragat edebilir.

2. Tartışma def'i

Alacaklı asıl borçluya karşı talepte bulunmadan kefile başvurduğu takdirde, kefil, önce asıl borçluya karşı talepte bulunma def'ini ileri sürebilir (TBK m.585/I). Kefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği bu def'iye tartışma veya peşin dava def'i denilmektedir. Âdi kefaletin esasını teşkil eden bu def'i sebebiyle, alacaklı, alacağını asıl borçludan elde etmek için kendisinden beklenen her şeyi yapmak zorundadır[2].

Âdi kefalette, kefile karşı takibat yapabilmenin şartlarının mevcut olduğunu, yani tartışma definin şartlarının bulunmadığını ispat yükü alacaklıya aittir[3].

---

1 **Giovanoli**, Art. 495, N. 7; **Becker**, Art. 495, N. 13; **Tandoğan** II, sh. 762; **Reisoğlu**, sh. 115.

2 **Scyboz**, sh. 100; **Tercier**, N. 3570.

3 **Giovanoli**, Art. 495, N. 9; **Scyboz**, sh. 99; OR-**Pestalozzi**, Art. 495, N. 2; **Becker**, Art. 495, N. 7; **Grassinger**, sh. 206; 13. HD, 3.12.1991, E. 7229/ K. 10997 (YKD 1992, sh. 397).

TBK m. 582/II hükmüne dayalı olarak TBK m. 591/I gereğince kefalet sözleşmesi hükümlerine tâbi bulunan garanti sözleşmelerinde, garanti verenin tartışma veya peşin dava def'i hakkı bulunmamaktadır[4].

TBK m. 585/I'e göre, kefalet akdinin kurulmasından sonra asıl borçlunun iflâs etmesi, konkordato mehli verilmiş olması, hakkında yapılan takibin semeresiz kalması sonucunda kesin aciz belgesi alınması, aleyhine Türkiye'de takibat icrasının imkânsız olması veya önemli ölçüde güçleşmesi hallerinde, kefil tartışma def'ini ileri süremez. Bu haller kefalet sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut ve kefil tarafından biliniyorsa, kefil tartışma def'inden önceden feragat etmiş sayılır[5].

Kefalet sadece açığın kapatılması için verilmişse takibin kesin aciz belgesi ile sonuçlanması, icra takibinin ülkede imkânsız hale gelmesi veya konkardatonun kesinleşmesi hallerinde kefile doğrudan doğruya başvurulabilir. Ancak bu sayılan durumlarda öncelikle asıl borçluya başvurulması sözleşme ile kararlaştırılabilir.

Şimdi tartışma def'inin ileri sürülemeyeceği halleri yakından inceleyelim:

a) Asıl borçlunun iflâs etmesi veya borçluya konkardato mehli verilmiş olması

Alacaklının kefile başvurabilmesi için, asıl borçlu hakkında iflâs kararı verilmesi yeterli olup, iflâs prosedürünün sonuçlanması ve kesin bir borç ödemeden aciz belgesinin verilmesi gerekli değildir. Bununla beraber, asıl borç iflâs sebebiyle vadeden önce muacceliyet kazansa bile, kefil asıl borç için tayin olunun vadeden önce borcu ifaya zorlanamaz (TBK m. 590/I).

TBK m. 594/II gereğince alacaklının iflasına karar verilmiş veya borçlu için konkordato istenmişse alacaklı alacağını kaydettirmeye, haklarını korumak için gerekenleri yapmaya ve asıl borçlunun iflâsını veya borçluya konkardato mehli verildiğini öğrenir öğrenmez bundan kefili haberdar etmeye mecburdur. Alacaklı bu külfetleri yerine getirmezse, kefilin bu yüzden uğradığı zararlar (meselâ kefilin rücu alaca-

---

4 **Scyboz**, sh. 101; **Beck**, Art. 495, N. 24; **Grassinger**, sh. 206.

5 **Scyboz**, sh. 101; **Schönenberger**, Art. 495, N. 15; **Beck**, Art. 495, N. 21; **Grassinger**, sh. 207. **Giovanoli** (Art. 495, N. 15), bu durumda âdi kefaletin bulunmadığı görüşündedir.

ğını masaya kaydettirememesinden doğan zararları) oranında, ona karşı olan haklarını kaybeder (TBK m. 594/III)[6].

b) Borçlu hakkındaki takibin semeresiz kalması

Alacaklı, takibin semeresiz kaldığını İİK m. 105/I veya İİK m. 143 uyarınca alacağı kat'i aciz vesikasıyla isbat edecektir. Buna karşılık, geçici aciz vesikası (İİK m. 105/II) veya rehin açığı belgesi (İİK m. 152) tartışma def'ini önlemez[7].

c) Asıl borçlu hakkında Türkiye'de takibin imkânsız olması veya önemli ölçüde güçleşmesi

Asıl borçlu, kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra ikametgâhını yurt dışına nakletmiş ve aleyhine Türkiye'de takip imkânsız hale gelmişse, alacaklı kefile başvurabilir; ona karşı tartışma def'i ileri sürülemez. Aynı şekilde borçlunun ülkede icra takibinin önemli ölçüde güçleşmesi halinde de tartışma def'i ileri sürülememektedir.

3. Rehnin paraya çevrilmesi def'i

TBK m. 585/II'ye göre, adi kefalette alacaklının asıl borçludan olan alacağı, kefalet işleminden önce veya onunla aynı zamanda rehinle teminat altına alınmış ise, kefil borcun önce rehin konusundan tahsil edilmesini talep edebilir. Rehin kefaletten sonra verilmiş ise rehnin paraya çevrilmesi def'i ileri sürülemez. Burada geçen "rehinle temin olunmuş" deyiminin kapsamına akdî rehin haklarının yanında hapis hakkı gibi kanunî rehin hakları da girer. Zira hapis hakkının TBK m. 585/II kapsamına girmediği iddiası[8], alacaklının ilk önce mevcut başka teminatlara başvurmasını öngören ve böylece kefili korumak isteyen bu hükmün amaçlarına aykırıdır[9].

---

6 **Tandoğan** II, sh. 764.

7 **Becker**, Art. 495, N. 4; **Giovanoli**, Art. 495, N. 17; OR-**Pestalozzi**, Art. 495, N. 6; **Beck**, Art. 495, N. 18; **Tandoğan** II, sh. 764-765; **Scyboz**, sh. 101; **Grassinger**, sh. 211. Eski BK m. 486/I'de geçen "alacaklının kusuru (hatası) olmaksızın" ibaresi, alacaklının asıl borluya karşı yapacağı takibin sonuçlanması için kendisinden beklenen özeni göstermesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktaydı (Beck, Art. 495, N. 20; OR-Pestalozzi, Art. 495, N. 6; Scyboz, sh. 101; Tandoğan II, sh. 765; Granssinger, sh. 212).

8 **Bilge**, sh. 376.

9 **Reisoğlu**, sh. 119; **Tandoğan** II, sh. 766; **Grassinger**, sh. 215.

Rehnin kefalet sözleşmesinin kurulmasından önce veya onunla aynı anda tesis edilmiş olması şartı, sadece rehnin üçüncü şahıslar tarafından verilmesi halinde söz konusu olur. Rehnin bizzat asıl borçlu tarafından verilmiş olduğu takdirde bu şart aranmaz. Zira âdi kefalette alacaklı önce asıl borçluya karşı talepte bulunmak zorunda olduğu için, ona ait merhun da takibe uğrayacaktır[10].

Asıl borçlunun iflâs etmesi veya konkordato mehli verilmesi halinde, kefil, önce rehnin paraya çevrilmesi def'ini ileri süremez. Eski BK m. 486/II, c. 2'de borçlunun iflâsından başka, "borçlunun iflâsı ilân olunmadıkça rehnin nakde tahvili kabil olmazsa" ibaresine de yer verilmişti. İİK m. 45 gereğince alacaklı asıl borçlunun iflâsına bağlı olmadan her zaman rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurabileceğinden, bu ibare gereksizdi[11]. Buna karşılık, asıl borçlunun iflâs etmemiş olması şartı, sadece rehnin asıl borçlu tarafından verilmesi halinde aranmıştır. Rehin üçüncü şahıs tarafından verilmiş ise, asıl borçlu iflâs etsin veya etmesin, kefil rehnin paraya çevrilmesi def'ini ileri sürebilir[12].

II. Müteselsil kefalet

Kefalet sözleşmesinde tarafların müteselsil kefil veya bu anlama gelen başka bir ifade kullanmak suretiyle yükümlülük altına girmesi halinde müteselsil kefalet söz konusu olur (TBK m. 586/I).

Müteselsil kefalette alacaklı, asıl borçluya başvurmadan ve taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluna gitmeden doğrudan doğruya kefile müracaat edebilir (TBK m. 586/I). Ancak, alacaklının doğrudan doğruya kefile başvurması için borçlunun ifada gecikmiş olması ve ihtarın sonuçsuz kalması ya da borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir. Bu şartlar altında müteselsil kefil tartışma def'inden ve belirli durumlarda önce rehnin paraya çevrilmesi def'inden yoksun bulunmaktadır[13]. Buna göre, müteselsil kefalette kefilin

---

10 **Reisoğlu**, sh. 119; **Tandoğan** II, sh. 767; **Arpacı**, sh. 526; **Grassinger**, sh. 216.

11 **Reisoğlu**, sh. 119; **Tandoğan** II, sh. 767; **Bilge**, sh. 376; **Grassinger**, sh. 217.

12 **Reisoğlu**, sh. 120; **Tandoğan** II, sh. 767; **Grassinger**, sh. 217.

13 HGK 14.10.1972, E. 215/K. 841 (RKD 1973, S. 1, sh. 101): "Rehinle temin edilmiş alacakta, rehnin paraya çevrilmesinden önce, müteselsil kefile karşı haciz yoluyla takip yapabilir; asıl borçlu için sevkedilmiş olan İİK m. 45 bu takibe engel olmaz". Teyiden: 11. HD, 24.10.1985, E. 5355/K. 5583 (**Reisoğlu**, sh. 122, dn. 42).

borcu tâli nitelik taşımamaktadır. Buna karşılık, kefaletin fer'i niteliği müteselsil kefalette de mevcuttur. Bu itibarla, müteselsil kefalet asıl borcun varlığına ve muhtevasına bağımlı olduğu gibi, müteselsil kefil de âdi kefil gibi yukarda belirtilenlerin dışında kalan diğer def'ilerden yararlanabilir[14].

Kefalet sözleşmesinden, kefilin müteselsil kefil sıfatıyla borçlanma iradesinin anlaşılması gerekir. Bununla beraber, sözleşme metninde mutlaka "müteselsil kefil" deyiminin kullanılması şart değildir; kullanılan kelimelerden müteselsil kefalet iradesinin anlaşılması yeterlidir. TBK m. 586/I'de "müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse" denmek suretiyle bu husus ifade edilmiştir. Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 487/I'de kefilin, "borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhte" etmesi gerektiği ifade edilmişti. bu fıkrada yer alan "müşterek müteselsil borçlu" deyimi, kaynak kanunun pek isabetli olmayan metninin yanlış tercümesinin sonucudur. Uygulamada kanundaki bu kötü ifade biçimine aynen yer verilmesinin doğuracağı tereddüt, bu gibi durumlarda müteselsil kefaletin kabulü suretiyle giderilmelidir[15]. Bu hususta kullanılan yanlış ifadelere değil, tarafların gerçek iradelerine bakmak gerekir[16].

Müteselsil kefalette alacak, taşınmaz rehni dışında teslime bağlı taşınır rehni ile veya alacak rehni ile teminat altına alınmışsa önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulması zorunludur. Bununla birlikte, borçlunun iflası ya da konkordato mehli verilmesi veya alacak rehni verilmişse bu rehnin paraya çevrilmesinin alacağın tamamını karşılayamayacağı hakim tarafından önceden belirlenmiş olması halinde rehine başvurmadan kefile gidilmesi mümkündür (TBK m. 586/II)[17].

---

[14] **Tercier**, N. 3668; **Becker**, Art. 496, N. 1; **Reisoğlu**, sh. 122; **Tandoğan** II, sh. 770.

[15] **Tandoğan** II, sh. 770; **Reisoğlu**, sh. 122-123; 13. HD, 11.6.1985, E.2636/K. 4163 (YKD 1987, sh. 577); 11. HD, 16.12.1991, E. 4438/K. 6660 (**Eriş**, Ticari İşletme 1992, sh. 118).

[16] **Giovanoli**, Art. 496, N. 10 ve 14; OR-**Pestalozzi**, Art. 496, N. 8; BGE 64 II 350 yahut JdT 1939 I 171.

[17] Menkul rehninin borcun bir kısmını karşıladığı hallerde rehin miktarı kadar kefile başvurulamaz; aşan miktar bakımından kefile başvurulabilir (11. HD. 3.2.2014 tarih E. 2014/585 K. 2014/1842 –Kazancı-).

Ticarî borçlara kefalette, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, gerek asıl borçlu ile kefil, gerek kefiller arasındaki ilişkilerde teselsül hükmü carî olur (TTK m. 7/II). Ancak, asıl borçlunun borcunu ödemediği kefile ihbar edilmeden kefile karşı temerrüt faizi yürütülememektedir (TTK m. 7/I). İcra zabtına geçirilen kefaletler de müteselsil kefalet hükmündedir (İİK m. 38/c. 2).

III. Toplu kefalet (cautionnement plural; pluralite des cautions)

Toplu kefalette, birden çok kefil bir ve aynı borç için kefil olmaktadırlar. Toplu kefalet şekillerini başlıca dört gruba ayırmak gerekir[18].

1. Bağımsız kefalet (Nebenbürgschaft; cautionnement indépendant)

TBK m. 587/IV'te öngörülen bağımsız kefalette, birden çok kefil aynı borca birbirinden bağımsız ve habersiz olarak kefil olmaktadırlar. Gerçek olmayan kefalet olarak da anılan bu tür kefalette, kefillerden her biri asıl borcun tamamından alacaklıya karşı sorumludur. Bağımsız kefalet âdi veya müteselsil kefalet şeklinde kurulabilir[19].

TBK m. 587/IV'de aksine anlaşma olmadıkça, alacaklıya ödemede bulunan bağımsız kefilin diğerlerine karşı payları oranında rücu edebileceği hükme bağlanmıştır. Böyle bir durumda ödemede bulunan kefilin diğer kefillere karşı sebepsiz zenginleşme davası açabileceğini hakkaniyet düşüncesiyle kabul etmek gerekir[20].

2. Kısmî kefalet (Teilbürgschaft)

Kısmî kefalette, kefillerden herbiri asıl borcun belirli bir kısmından sorumlu olmayı taahhüt etmektedir. Bu tür kefalette kefiller arasında herhangi bir ilişki bulunmamakta ve her kefilin sorumluluğu yan yana getirilmiş bulunmaktadır[21]. Kısmî kefalet ne Borçlar Kanunu'muzda, ne İsviçre Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir.

3. Birlikte kefalet (Mitbürgschaft; cautionnement conjoint)

Birlikte kefalet, kefillerin aynı ve bölünebilir tek bir asıl borç için birlikte (müştereken) kefil olmalarıdır (TBK m. 587/II). Bunun için

---

18 Bk. **Tercier**, N. 3676 vd. Bazı farklarla: **Scyboz**, sh. 105 vd; **Yavuz**, sh. 794 vd.

19 **Scyboz**, sh. 107; **Tercier**, N. 3677; OR-**Pestalozzi**, Art. 497, N. 27; **Engel**, sh. 17; **Giovanoli**, Art. 497, N. 30.

20 **von Tuhr/Escher** § 90 IX, 2.

21 **Tercier**, N. 3678; **Yavuz**, sh. 794; **Giovanoli**, Art. 497, N. 5.

asıl borç ve onun borçlusunun aynı olması gerekir; bir alacaklının aynı asıl borçluya karşı sahip olduğu çeşitli alacaklarına kefil olunması halinde, birlikte kefalet söz konusu olmaz[22]. Bir ve aynı borcun birden çok müteselsil borçlusu varsa, kefilin bunların tamamı için kefil olması gerekir; aksi takdirde aynı borç için kefil olma şartı gerçekleşmemiş olur[23]. Müteselsil borçlulardan herbiri, sadece kendi borcu için birden çok kefil temin etmişse, birlikte kefaletten bahsedilemez[24].

Diğer taraftan birlikte kefalet için, kefilin, aynı asıl borç için, kendisinin yanında başka kefilin veya kefillerin sorumlu olduğunu ya da olacağını bilerek ve gözönünde tutarak borç altına girmesi gerekir. Kefilin aynı borç için başka kefaletlerin verileceği varsayımı ile hareket ettiğini alacaklının bilmesi ancak bu varsayım sonradan gerçekleşmemesi halinde kefil bu borcundan kurtulur. Alacaklı tarafından kefillerden birinin kefalet borcundan kurtarılması veya kefaletin hükümsüzlüğüne karar verilmesi hallerinde de aynı durum söz konusu olur (TBK m. 587/III). Bununla beraber, birlikte kefillerin aynı anda ve aynı şartlarla kefil olmaları zorunlu değildir[25].

Birlikte kefalet âdi veya müteselsil kefalet şeklinde olabilir.

a) Âdi birlikte kefalet

Âdi birlikte kefalette, birden çok kişi aynı borca birlikte kefil olurlar. Bu kefillerden herbiri kendi payları için âdi kefil, diğer kefillerin payları için kefile kefil gibi sorumludurlar (TBK m. 587/I). Kefile kefil gibi sorumlu olmaları kefalet borcu için adi kefil gibi sorumluluk doğurur (TBK m. 588/I). Bu durumda, alacaklı asıl kefile başvurmadan kefile kefil hakkında takipte bulunamaz. Adi birlikte kefalette her

---

22 **Giovanoli**, Art. 497, N. 2; **Schönenberger**, Art. 497, N. 14; OR-**Pestalozzi**, Art. 492, N. 2.

23 **Tercier**, N. 3741; **Scyboz**, sh. 107-108.

24 **Becker**, Art. 497, N. 2; **Giovanoli**, Art. 497, N. 2; OR-**Pestalozzi**, Art. 497, N. 2; **Reisoğlu**, sh. 128.

25 **Giovanoli**, Art. 497, N. 3; **Scyboz**, sh. 108; **Tercier**, N. 3743; **Becker**, Art. 497, N. 4; **Reisoğlu**, sh. 127; 11. HD, 14.6.1985, E. 2643/K. 3880 (YKD 1985, sh. 1490 vd). Mülga BK m. 488/c. 1'de yer alan "bölünebilir bir borç" şartı, kefilin borcu her zaman bir para borcu, dolayısıyla bölünebilir bir borç olduğu için, pratik bir değer taşımamaktaydı (**Tercier**, N. 3744; **Schönenberger**, Art. 497, N. 16).

kefilin payına düşen sorumluluk önceden açıkça tesbit edilmemiş ise, her biri eşit paylarla sorumlu olurlar[26].

Âdi birlikte kefiller alacaklıya önce bölme def'ini ileri sürebilirler. Kefillerden biri hakkında yapılan takip sonunda borç ödemeden aczi tesbit edilmişse, diğer kefiller onun payını kefile kefil sıfatıyla ve yine paylarıyla orantılı olarak ödemek zorundadırlar[27].

b) Müteselsil birlikte kefalet

Müteselsil birlikte kefalet iki şekilde kurulabilir (TBK m. 587/II). Bunlardan birincisi, kefillerin kendi aralarında müteselsil kefil olmayı kabul etmeleri halidir. Bu takdirde, kefil en geç kendi kefalet anında kefil olmuş ülkede takibi mümkün tüm kefilleri karşı takibin yapılmasını aksi durumda kendi payından fazlasını ödemeyeceğini ileri sürebilir. Diğer kefillerin kendi üzerine düşen payı ödemeleri veya kefalet borcu için ayni teminat vermeleri halinde de durum değişmemektedir. Bu durumda bölme def'i yanında tartışma ve önce rehnin paraya çevrilmesi def'ileri varlığını korur.

Kefalet borcunu ödeyen kefil diğer kefillere rucu hakkına sahiptir. Bu hak asıl borçluya rucudan önce de kullanılabilir. Ancak kefiller önceden kendi üzerine düşen payı ödemişse rucu imkânı bulunmamaktadır. Bu durumun aksi taraflarca sözleşmeyle kararlaştırılabilmektedir.

Müteselsil kefaletin ikinci şeklinde ise, kefiller hem kendi aralarında, hem de borçlu ile birlikte müteselsilen borç altına girerler. Bu ikinci halde hem tartışma ve önce rehnin paraya çevrilmesi, hem bölme def'inden feragat söz konusu olur. Bununla beraber taraflar, kefalet sözleşmesinde sadece tartışma ve önce rehnin paraya çevrilmesi def'inden feragat ettiklerini kararlaştırabilirler[28].

Payına düşenden fazla ödeyen kefil, diğerlerine rücu edebilir (BK m. 488/c.2).

---

[26] Kredi sözleşmesinde altı kişi kefil olmuştur. TBK m. 587 uyarınca bu durumda rücu ilişkisinde kefiller birbirlerine karşı kefalet oranında sorumludurlar (23. HD. 17.9.2013 tarih E. 2013/4723 K. 2013/5479 –Kazancı-).

[27] **Tandoğan** II, sh. 773.

[28] OR-**Pestalozzi**, Art. 497, N. 6; **Tandoğan** II, sh. 774; **Reisoğlu**, sh. 136; **Yavuz**, sh. 796.

4. Kefile kefalet

Kefile kefil, alacaklıya karşı asıl kefilin borcuna kefil olan kişidir. Bununla, kefile kefil, asıl borçluya karşı mevcut kefalet borcunun ifasından sorumlu olmayı taahhüt etmektedir. Kefile kefil ile asıl kefilin alacaklıya karşı sorumlulukları âdi kefil ile asıl borçlununki gibidir; alacaklı asıl kefile başvurmadan kefile kefil hakkında takibat yapamaz (TBK m. 588/I).

IV. Rücua ve açığa (zarara) kefalet

1. Rücua kefalet

Rücua kefil, kefilin asıl borçluya karşı rücu alacağını tekeffül eder (TBK m. 588/II). Rücua kefalet sözleşmesi, kefil ile rücua kefil arasında kurulur.

Rücua kefalet, genellikle âdi kefalet şeklinde yapılır; ancak, rücua kefilin rücu alacağı için asıl borçlu ile müteselsilen borç altına girmesine bir engel bulunmamaktadır[29].

2. Açığa (zarara) kefalet

Açığa kefil, alacaklının asıl borçludan tahsil edemediği alacak miktarı için âdi kefil sıfatıyla sorumlu olmayı taahhüt eden kişidir. Borçlar Kanunu'nda düzenlenmemiştir; İsviçre Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle açıkça hükme bağlanmıştır (m. 495/III).

---

[29] **Beck**, Art. 497, N. 10 vd; **Schönenberger**, Art. 497, N. 10; **Tercier**, N. 3675; **Scyboz**, sh. 106; OR-**Pestalozzi**, Art. 497, N. 7; **Tandoğan** II, sh. 769; BGE 61 II 99 yahut JdT 1935 I 546; 70 II 276 yahut JdT 1945 I 268.

§ 36. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

I. Kefilin sorumlu olduğu azamî tutar

TBK m. 589 gereğince kefil kefalet sözleşmesinde kabul edilen azami miktara kadar sorumludur. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, kefilin sorumluluğuna giren alacaklar gösterilmiştir. Yukarda da belirtildiği gibi[1] TBK m. 589'da sorumluluk tutarının kefilin sorumlu olacağı azamî tutar olduğu açıkça düzenlenmiştir[2]. Buna göre, TBK m. 589/II'de zikredilen alacaklar toplamı, kefalet sözleşmesinde öngörülen miktarı aştığı takdirde, kefil ancak sözleşmede yer alan miktarla sorumlu olacaktır. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları da bu yöndedir[3]. Ancak Kanun bu hususu da "belirtilen azami miktarla sınırlı olmak üzere, aşağıdakilerden sorumludur" demek suretiyle düzenlemiştir. İsviçre BK m. 499'a 1942 yılında yapılan değişiklikle eklenen I. fıkra hükmüne göre de, kefilin sorumluluğu her durumda kefalet sözleşmesinde öngörülen azamî tutarı geçememektedir.

Taraflar düzenlemenin birinci fıkrasında belirtilen azami miktara kadar sorumluluğu genişletebilirler. Buna göre taraflar azami miktarla sınırlı olmak üzere kanunda sayılan kefilin sorumlu olduğu alacaklardan sorumlu olmayı kararlaştırabilirler (TBK m. 589/II).

II. Kefilin sorumlu olduğu alacaklar

Kefalet sözleşmesinde kararlaştırılan en yüksek sınır içinde kalmak şartıyla, kefilin sorumlu olduğu alacaklar TBK m. 589/II'de öngörülmüştür.

Kefil kural olarak kefalet sözleşmesinden sonra doğan borçlardan sorumludur. Ancak kefalet sözleşmesi ile bunun aksi kararlaştırılabilir (TBK m. 589/III).

---

1 Bk. yuk. sh. 405.

2 **Tandoğan** II, sh. 780; **Reisoğlu**, sh. 153; **Yavuz**, sh. 799.

3 11. HD, 15.5.1986, E. 1715/K. 3508 (**Reisoğlu**, sh. 153-154, dn. 2); 11. HD, 8.5.1986, E. 2111/K. 2772 (YKD. 1987, sh. 569 vd); 15. HD, 25.5.1990, E. 2264/K. 2367 (**Karahasan**, C. 6, sh. 942)

1. Asıl borç

Kefil her şeyden önce asıl borcun ifasından sorumludur. Asıl borç, kefilin sorumluluğunu belirleyici bir fonksiyona sahiptir; kefil ancak asıl borç için takip edilebilir. Kefil, asıl borcun genişlemesinden, kanun veya kefalet sözleşmesiyle öngörülen veya işin niteliğinin gerektirdiği hallerde sorumlu olur. Ancak, kefil kefalet sözleşmesinde belirtilen azami miktar kadar sorumlu olur (TBK m. 589/I). Çalışanlara kefalet işin niteliği gereği genişlemeye; carî hesap kredisi kefaleti ise, sözleşmeyle öngörülen genişlemeye örnek teşkil eder[4].

2. Asıl borçlunun kusur veya temerrüdünün kanunî sonuçları

Kefil, asıl borçlunun borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesinin veyahut temerrüdünün kanunî sonuçlarından sorumludur (TBK m.589/II/1). Burada kefilin alacaklının müsbet zararından sorumluluğu söz konusudur. Kefil dönme veya iptal sonucu doğan menfî zarardan sorumlu değildir. Zira menfî zarar asıl borçtan sorumlu olmakla ilgili bir olgu değildir[5]. Kefil cezaî şarttan da sorumlu değildir. Bu hususlar kanunda emredici surette düzenlenmiş ve aksine yapılan sözleşmeler kesin hükümsüzlük müeyyidesine tabi tutulmuştur (TBK m. 589/IV). Nitekim, cezai şart bakımından cezaî şartın kefalet sözleşmesinde öngörülmesi asıl borcun hukukî işlemle genişletilmesi sayılmaktadır[6].

Kefil, borçlunun temerrüdünün kanunî sonuçlarından olan temerrüt faizinden de sorumludur.

3. Dava ve takip masrafları

Kefil, kendisine alacaklıyı tatmin ederek dava açılmasını önleme fırsatı verildiği ölçüde, asıl borçluya karşı açılan davanın masraflarından sorumludur (TBK m. 589/II/2). Bunun için, alacaklının kefili bu durumdan haberdar etmesi ve ödemede bulunup bulunmama kararı vermesi için ona uygun bir süre tayin etmesi gerekir[7]. Borç kefile karşı

---

4 **Beck**, Art. 499, N. 14; **Giovanoli**, Art. 499, N. 10; OR-**Pestalozzi**, Art. 499, N.9.

5 **Giovanoli**, Art. 499, N. 12; **Beck**, Art. 499, N. 20 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 499, N. 11; **Becker**, Art. 492, N. 21; **Tandoğan** II, sh. 775-776.

6 **Giovanoli**, Art. 499, N. 12; OR-**Pestalozzi**, Art. 499, N.11.

7 **Schönenberger**, Art. 499, N. 32; **Beck**, Art. 499, N. 32; OR-**Pestalozzi**, Art. 499, N. 15.

henüz muaccel değilse, kefil, borcu muaccel olunca ödeyeceğini alacaklıya bildirmelidir[8].

TBK m. 589/II/2'de açıkça ifade edildiği gibi, kefil, icra yoluyla takip masraflarından da sorumludur[9]. Diğer yandan, kefil aynı düzenlemeye göre rehinlerin kefile teslimi ve rehin haklarının devri nedeniyle meydana gelen masraflardan da sorumlu sayılmıştır.

4. Akdî faizler

TBK m. 589/II/3'e göre, "İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri" ödemekle sorumludur. Bu fıkrada asıl borç için sözleşmeyle kararlaştırılan faizler düzenlenmiş olup, temerrüt faizleri I. fıkra anlamında temerrüdün kanunî sonuçlarındandır. Bu itibarla, temerrüt faizleri bir yıllık sınırlamaya tâbi değildir[10]. Akdî faizler, temerrüt tarihinden itibaren temerrüt faizine dönüşür[11].

İşlemiş ve işlemekte olan akdî faizlerin başlangıç tarihi kanunda belirtilmemiş bulunmaktadır. Yargıtay eski kararlarında temerrüt tarihini esas almakta iken[12], daha sonraki içtihatlarında bir senelik faizin hesaplanmasında dava tarihinden hareket etmektedir[13]. Genellikle mütemerrit borçlular hakkında dava açılacağı için, dava tarihinden sonra işleyen faiz temerrüt faizidir. Diğer taraftan, temerrüt tarihinden itibaren akdî faizin temerrüt faizine dönüşmesi sebebiyle, Yargıtay'ın görüşü kabul edilirse TBK m. 589/II/3'teki "işlemekte olan faiz" deyiminin bir anlamı kalmaz[14]. Bu itibarla kefil, vadeden bir yıl öncesine kadar işlemiş ve vadeden temerrüt tarihine kadar işlemekte olan akdî faizden sorumludur[15]. Ancak akdî faize ilişkin III. fıkra hükmü emre-

---

8 **Tandoğan** II, sh. 777.

9 **Tandoğan** II, sh. 776.

10 **Beck**, Art. 499, N. 26; **Giovanoli**, Art. 499, N. 14 vd; **Schönenberger**, Art. 499, N. 36 vd; OR-**Pestalozzi**, Art. 499, N. 19; **Tandoğan** II, sh. 777-778; **Reisoğlu**, sh. 163-164; BGE 105 II 233 vd.

11 **Tandoğan** II, sh. 778; **Reisoğlu**, sh. 164.

12 4. HD, 28.4.1932, E. 386/K. 801 (**Tepeci**, sh. 784).

13 **Reisoğlu**, sh. 164, dn. 38'deki kararlar ve 15. HD, 11.6.1979, E. 1255/K. 1417 (YKD 1979, sh. 1342).

14 **Reisoğlu**, sh. 164; **Tandoğan** II, sh. 778.

15 **Scyboz**, sh. 65; **Tandoğan** II, sh. 778; **Reisoğlu**, sh. 165.

dici nitelikte olmadığı için, bu sınırlama sözleşmeyle kaldırılabilir[16]. Carî hesap sözleşmesinde ise, işlemiş faizler asıl borca eklenmek suretiyle bakiye tesbit edileceğinden, bir yıllık sınırlama bulunmamakta ve kefil işlemiş bütün faizlerden sorumlu olmaktadır[17].

Nihayet, tahvil karşılığı ödünç verilen anapara bakımından işlemiş bir yıl ve işlemekte olan yıla ait faizler kefilin sorumlu olacağı kalemlerden sayılmıştır (TBK m. 589/II/3).

---

[16] 15. HD, 16.6.1980, E. 1509/K. 1522 (YKD 1980, sh. 1631); 15. HD, 5.3.1982, E. 409/K. 507 (YKD 1982, sh. 841); 11. HD, 17.10.1985, E. 5056/K. 5349.

[17] **Beck**, Art. 499, N. 25; **Becker**, Art. 499, N. 7; **Schönenberger**, Art. 499, N. 38; **Tandoğan** II, sh. 778; **Reisoğlu**, sh. 165; 11. HD, 23.12.1991, E. 4735/K. 6823 (**Eriş**, Ticari İşletme 1992, sh. 119).

§ 37. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kefil ile alacaklı arasındaki ilişkide kefilin alacaklıya karşı sahip olduğu imkânlar (def'iler) ile alacaklının yüküm ve külfetleri önem taşımaktadır.

I. Kefilin alacaklıya karşı savunma imkânları (def'iler)

1. Genel olarak

TBK m. 591/I'e göre, "Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün def'ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunları ileri sürmek zorundadır. Yanılma veya sözleşme yapma ehliyetsizliği ya da zamanaşımına uğramış bir borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek kefalet hâli bu hükmün dışındadır.". Bu fıkrada yer alan def'i deyimi dar ve teknik anlamda def'i, yani borçlunun edimi yerine getirmekten kaçınma hakkı anlamında kullanılmamıştır. Bu kavram ile kanun koyucu, itirazları da içine alan geniş anlamda def'i veya savunma imkânlarını ifade etmek istemektedir[1].

Kanun hata, ehliyetsizlik ve zamanaşımı nedeniyle ifa yükümlülüğü bulunmayan hallerde bu durumun bilinerek kefalet verilmesinde bir istisna getirmektedir. Buna göre, söz konusu durumlarda kefil bilerek bu tür bir borca kefil olduğundan esas borç ilişkisinden kaynaklanan defileri ileri süremez.

2. Asıl borç ilişkisine ait savunma imkânları

Kefilin asıl borçluya ait def'i ve itirazları ileri sürebilmesi (TBK m. 591/I) kefalet sözleşmesinin fer'iliğinin, yani asıl borca bağımlılığının tabiî bir sonucudur. Kefil, bunları kendine ait bir hak olarak ileri sürer. Bu itibarla, asıl borçlunun kendisine ait bu savunma imkânlarından feragat etmesi kefili etkilemez[2]. İsviçre Borçlar Kanunu'nun

---

1 **Beck**, Art. 502, N. 9; **Becker**, Art. 506, N. 21; **Schönenberger**, Art. 502, N. 9; OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 8; **Scyboz**, sh. 68; **Reisoğlu**, sh. 168 vd; **Grassinger**, sh. 17 vd.

2 **Schönenberger**, Art. 502, N. 2; **Tercier**, N. 3795; OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 7; **Reisoğlu**, sh. 169, 170/171.

1942 tarihli değişikliğinde kanun metnine (OR Art. 502/II) dahil edilen bu esas, asıl borçlunun zamanaşımından feragatının kefile karşı ileri sürülemeyeceğini öngören TBK m. 160/IV hükmünde de ifadesini bulmaktadır[3]. Bu husus, asıl borçlunun kendi davranışlarıyla kefilin durumunu ağırlaştıramayacağı ilkesinin de sonucudur[4].

Kefilin borçluya ait savunma imkânlarını (def'i ve itirazları) kullanması onun için sadece bir hak olmayıp, aynı zamanda külfet (Obligenheit) teşkil eder; bu külfetleri yerine getirmeyen kefil, kusuru olmadan bunlara vâkıf olmadığını isbat etmedikçe, asıl borçluya ait rücu hakkını kaybeder (TBK m. 591/III)[5].

Kefilin ileri sürebileceği, asıl borca ait def'i ve itirazları, başlıca üç grupta toplamak mümkündür[6].

a) Asıl borcun doğumuna ilişkin olanlar: Fiil ehliyetinin bulunmaması; şekil noksanı, hukuka, ahlâka ve kişilik haklarına aykırılık.

b) Asıl borcun kapsam ve hükümlerine ilişkin olanlar: Muacceliyet, ödemezlik def'i.

c) Asıl borcun sona ermesine ilişkin olanlar: Asıl borcun sona ermesi itirazının kefili sorumluluktan kurtardığı hususu TBK m. 598/I'de açıkça ifade edilmiştir. Aynı şekilde TBK m. 131/I'e göre, "Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur.". Böylece asıl borcun ibra, tecdit (istisna: TBK m. 133/II, ve m. 134/III), alacak ve borçlu sıfatının birleşmesi (istisna: TBK m. 135/III), takas veya borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık hallerinde asıl borç sona erer.

Asıl borcun zamanaşımına uğraması halinde, kefil TBK m. 591/I anlamında asıl borçluya ait bir def'i olarak, bunu alacaklıya karşı ileri sürebilir[7]. TBK m. 155/II gereğince asıl borçluya karşı zamanaşımının kesilmesi durumunda, kefile karşı da kesilmiş olur. Buna karşılık, kefile karşı zamanaşımının kesilmesi asıl borçluya karşı etki etmez

---

3 **Beck**, Art. 502, N. 44; **Scyboz**, sh. 68; **Tercier**, N. 3795.

4 **Oser**, Art. 499, N. 2b; **Becker**, Art. 506, N. 4; **Tobler**, sh. 76; **Beck**, Art. 502, N. 44, **Tandoğan** II, sh. 782.

5 **Tercier**, N. 3904; **Scyboz**, sh. 41, dn. 10; **Grassinger**, sh. 18-19.

6 **Giovanolli**, Art. 502, N. 4; OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 6 vd.

7 **Beck**, Art. 502, N. 15; OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 14; **Reisoğlu**, sh. 173; **Grassinger**, sh. 34.

(TBK m. 155/III); kefalet borcu için zamanaşımı kesilmiş olsa bile kefil asıl borçluya ait zaman aşımını ileri sürebilir[8].

Buna karşılık yenilik doğuran haklar ancak bu hakka sahip olanlar tarafından kullanılabileceği için, kefil, asıl borçluya ait yenilik doğuran hakları kullanamaz; asıl borçlunun sahip olduğu yenilik doğuran haklar TBK m. 591/I'in kapsamına girmez[9]. TBK m. 140'da, takas bakımından, asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı oldukça, kefilin alacaklıya ödemeden kaçınma hakkının bulunduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Bu hükmün kıyasen uygulanması suretiyle, BGB § 770'de olduğu gibi, asıl borçlunun sahip olduğu diğer yenilik doğuran haklar bakımından (meselâ irade sakatlığı halinde iptal hakkı), kefile geciktirici def'i hakkı tanımak gerekir[10].

TBK m. 591/I'e göre, kefil "...asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün def'ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip..."tir., yani kefil bu def'ileri alacaklıya karşı ileri süremez. Bu cümleden olarak kefil, asıl borçlunun ifa gücünün bulunmadığını ileri süremez. Zira kefaletin amacı bu ihtimale karşı alacaklıyı korumaktır. Aynı şekilde borçlunun ödeme gücüyle ilgili olması sebebiyle, İİK m. 295'te öngörülen hallerde -alacaklının konkordatoya red oyu kullanması ve haklarını kefile temlik etmeyi teklif etmesi- borçlu konkordatoda belirlenen miktar ile sorumlu olmasına rağmen, kefil borcun tamamından sorumlu olur[11].

TBK m. 582/II'ye göre, hata yahut ehliyetsizlik sebebiyle asıl borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel güvence veren kişi, yükümlülük altına girme anında bu durumu biliyor ise, kefalete ilişkin hükümlere göre sorumlu olur. Böyle bir durumda kefalet hükümlerine tâbi garanti sözleşmesi söz konusudur. TBK m. 582/II/c.2 bu sorumluluğun zamanaşımına uğramış borçlar bakımından da uygulanacağını hükme bağlamıştır.

---

8 **Reisoğlu**, sh. 173; **Grassinger**, sh. 34.

9 OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 9; **Reisoğlu**, sh. 177; **Aral**, Takas, sh. 85 ve dn. 7'de zikredilenler; **Grassinger**, sh. 35-36. **Peter**, Art. 121, N.1; **Giovanoli**, Art. 502, N.5; **Becker**, Art. 121 N.2; **Scyboz**, sh.69; BGE 126 III 28, Erw. 3b

10 **Aral**, Takas, sh. 86 ve dn. 8'de zikredilen yazarlar.

11 OR-**Pestalozzi**, Art. 502, N. 19; **Giovanoli**, Art. 502, N. 16.

3. Kefalet sözleşmesine ait savunma imkânları

Kefil, asıl borçluya ait def'ilerden başka kefalet sözleşmesine ilişkin veya şahsına ait def'ileri de ileri sürebilir.

Kefil, kefalet akdinin geçerli olarak doğmadığını veya kısmen yahut tamamen sona erdiğini (TBK m. 600-601) ileri sürebilir. Aynı şekilde kefil âdi kefalette tartışma ve önce rehnin paraya çevrilmesi; âdi birlikte kefalette bölme def'ilerini ileri sürebilir.

Kefaletin fer'iliği ilkesi gereğince, alacaklı, asıl borç muaccel olmadan kefile karşı takibe geçemez. Kefalet borcunun asıl borçtan evvel muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar fer'ilik ilkesi sebebiyle geçersiz olur[12]. Aksine bir anlaşma olmadıkça, kefalet borcu asıl borçla aynı anda muaccel olur (TBK m. 90). Ancak TBK m. 590 gereğince, asıl borç borçlunun iflâsı sebebiyle daha önce muaccel hale gelse bile, kefil asıl borç için öngörülen vadeden önce ifaya zorlanamaz; asıl borcun muaccel olması alacaklının ihbarına bağlı ise, bu ihbarın kefile de yapılması gerekir. Kefil hakkında asıl borcun muacceliyet kazanması, ihbar gününden başlar (TBK m. 590/III).

II. Alacaklının yükümleri ve külfetleri

1. Borçlunun anaparayı veya faizi ödememesi ya da iflası halinde masaya başvurma ve kefile ihbar yükümü

TBK m.594/I'e göre borçlunun anaparayı veya yarım yıllık döneme ilişkin faizi ödememesi halinde alacaklının durumu kefile bildirmesi gerekmektedir. Aynı şekilde anaparanın yıldan yıla yapılması gereken ödemelerinin altı ay gecikmesi halinde bu bildirim yapılmalıdır. Diğer yandan, kefilin isteği halinde alacaklı her zaman asıl borcun kapsamını bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

TBK m. 594/II uyarınca alacaklı, borçlu iflâs ederse veya konkordato talebinde bulunursa alacağını iflâs masasına kaydettirmekle ve iflâsın açıldığını veya konkordato mehli verildiğini öğrenir öğrenmez kefile ihbar etmekle yükümlüdür. Alacaklı bunları yerine getirmediği takdirde, kefilin bu yüzden uğradığı zararı tazminle yükümlü olur. TBK m. 594/III'te "uğradığı zarar miktarınca ona karşı haklarını kaybeder" ibaresine rağmen, burada bir kusur sorumluluğu söz konusudur[13].

---

[12] **Beck**, Art. 501, N. 5; **Reisoğlu**, sh. 182; **Grassinger**, sh. 187.

[13] Bk. **Oser**, Art. 511, N. 3; **Tobler**, sh. 146; **Beck**, Art. 505, N. 32 ve 33; **Giovanoli**, Art. 505, N. 19; **Reisoğlu**, sh. 187.

2. Ödemeyi kabul külfeti

TBK m. 593'e göre, asıl borç muaccel olunca, kefil her zaman alacaklıyı yapacağı ifayı kabul etmeye zorlayabilir. Alacaklının ödemeyi haklı bir sebep olmaksızın kabul etmemesi halinde, kefil kefalet borcundan kurtulur.

Alacaklının kefalet esnasında bulunan veya daha sonra asıl borçludan alacağı teminat altına almak için temin ettiği rehin hakkını, güvenceyi ve rüçhan hakkını kefilin zararına azaltamaz. Aksi takdirde azalma miktarı kadar kefilin sorumluluğu kalkar (TBK m. 592/I)[14]. Benzer şekilde, alacaklının haklı bir sebep olmaksızın ağır kusuru ile rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri elinden çıkarması halinde kefil borcundan kurtulur. Alacaklının diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ağır kusuruyla mevcut belgeleri elden çıkarması halinde de aynı hüküm uygulanır. Bu tür durumlar kefil önceden ödediği miktarın geri verilmesini ve doğmuşsa ek zararlarının giderilmesini talep edebilir (TBK m. 593/IV).

Kefalet konusu borca birden fazla kişinin kefil olması halinde kefillerden birinin kendi payına düşen kısmi ödemesini kabul etmek zorundadır (TBK m. 593/c.2).

Alacaklının temerrüdüne ilişkin genel hükümlerden (TBK m. 106-111) farklı olarak, kefile kefalet borcundan kurtulma imkânının tanınmasının sebebi, asıl borçlunun durumunun kötüleşmeye başlaması üzerine kefile rücu ve temerrüdün sonuçları ile dava ve takip masraflarından tasarruf etme imkânlarını sağlamaktır[15].

TBK m. 593/III'e göre kefilin asıl borcu muaccel olmadan önce ödemesi alacaklının rızasına bağlıdır. Bu durumda kefilin asıl borçluya rucu etmesi borcun muaccel olmasını gerektirir. Esasen, TBK m. 96 gereğince asıl borçlu, sözleşme hükümlerinden veya işin mahiyetinden tarafların aksini kastettikleri anlaşılmadıkça, vadeden önce ifada bulunabilir. Bu hakkı kefile de tanımak gerekir[16].

---

[14] Bankanın asıl borçlunun aracı üzerindeki rehni ve banka hesabındaki blokeyi kaldırmasına rağmen kefilin parası üzerine bloke koyması bu hükme aykırılık teşkil etmektedir.

[15] **Giovanoli**, Art. 504, N. 1; OR-**Pestalozzi**, Art. 504, N. 1; **Beck**, Art. 504, N. 4; **Reisoğlu**, sh. 188; **Tandoğan** II, sh. 787.

[16] **Oser**, Art. 510, N. 2; **Becker**, Art. 510, N. 2; **Reisoğlu**, sh. 188, **Tandoğan** II, sh. 787.

3. Teminatları ve isbat vasıtalarını saklama ve kefile nakil ve tevdi yükümü

Alacaklı, kendisine ödemede bulunan kefile, borç senetlerini teslim etmek ve gerekli bilgileri vermek zorundadır; ayrıca mevcut taşınmaz rehninin kefile devri için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür (TBK m. 592/III).

Alacaklının yükümlülüklerini yerine getirmemesi, asıl borcun temini için, kefalet akdinin kurulmasından önce veya sonra verilen her türlü teminatı veya elindeki belgeleri elden çıkarırsa kefil borcundan kurtulur (TBK m. 592/IV).

§ 38. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. Kefilin ödemeyi ihbar yükümü

Kefil, mükerrer ödemeyi önlemek için, alacaklıya yaptığı ödemeyi asıl borçluya bildirmekle yükümlüdür. Kefilin bu ihbar yükümünü yerine getirmemesi sebebiyle, asıl borçlu alacaklıya ikinci defa ödemede bulunursa, kefil ona rücu hakkını kaybeder (TBK m. 597). Bu durumda kefil, alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilir (TBK m. 597/III). Alacaklının icra takibinden sonra ödemede bulunan kefil, İİK m. 72 çerçevesinde alacaklıya karşı istirdat davası açabilir[1].

II. Kefilin asıl borçludan teminat verilmesini veya borçtan kurtarılmasını isteme hakkı

Asıl borçlu kefalet sözleşmesinin tarafı olmamasına rağmen kefil, alacaklıya ödemede bulunmadan önce asıl borçluya karşı, muhtemel rücu talebinin teminat altına alınmasını veya kefalet borcundan kurtarılmasını isteme hakkı bulunmaktadır (TBK m. 595). Bu madde hükmünün uygulanması için, kefilin muhtemel bir rücu hakkının bulunması şarttır[2]. Burada kefilin rücu hakkının ön sonuçları söz konusudur[3].

Kefil, TBK m. 595/b. 1-3'te sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde asıl borçludan teminat vermesini talep edebilir:

1) Asıl borçlunun kefile karşı olan taahhütlerine aykırı davranması (b. 1). Asıl borçlu, kendisine kefil olunmasını talep ederken kefile, kefalet süresince spekülatif davranışlara girmeyeceğini, taşınmazlarını başkalarına rehnetmeyeceğini, kefalet borcu altına girmeyeceğini, işlemlerinde defter tutacağını ve kefile bu defterleri kontrol yetkisi vereceğini taahhüt etmesine rağmen bu taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kefil kendisinden teminat verilmesini isteyebilir[4].

---

1 **Schönenberger**, Art. 509, N. 6; **Beck**, Art. 509, N. 7; OR-**Pestalozzi**, Art. 508, N. 4.

2 **Giovanoli**, Art. 506, N. 1; **Becker**, Art. 512, N. 1; **Oser**, Art. 512, N. 1a, bb; **Beck**, Art. 506, N. 3.

3 **Giovanoli**, Art. 506, N. 1; OR-**Pestalozzi**, Art. 506, N. 1.

4 **Giovanoli**, Art. 506, N. 7; **Reisoğlu**, sh. 206; **Tandoğan** II, sh. 788.

Asıl borçlunun özellikle kefili belirli bir süre içinde borçtan kurtarma vaadini yerine getirmemesi asıl borçludan teminat istenmesi sebebi olarak sayılmıştır (TBK m. 595/b.1).

2) Asıl borçlunun temerrüde düşmesi veya yerleşim yerini başka bir ülkeye nakletmesi nedeniyle takibin önemli ölçüde zorlaşmış bulunması (b.2).

3) Kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonra kefilin üstlendiği tehlikenin önemli derecede artması (b.3). Asıl borçlunun mali durumunun kötüleşmesi, teminatların değer kaybetmiş olması ya da borçlunun kusuru nedeniyle kefile ilişkin tehlikenin kefaletin yapıldığı tarihe göre önemli surette artmış olması bu kapsamda sayılmaktadır.

TBK m. 595/b. 1-3'teki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde kefil, asıl borç muaccel ise, asıl borçludan kendisini kefalet borcundan kurtarmasını talep edebilir.

III. Kefilin rücu hakkı

1. Genel olarak

TBK m. 596, alacaklıya ödemede bulunan kefile, asıl borçluya rücu edebilmek için iki imkân vermektedir. Bunlardan birincisi, alacaklının haklarına halef olmak suretiyle asıl borçluya rücu imkânıdır. Gerçekten TBK m. 596/I'e göre, "Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur". Bu hükümde öngörülen kanunî halefiyet olgusuyla alacaklının sahip olduğu bütün haklar, ifa ile birlikte kanundan dolayı, onu tatmin eden kefile geçer. Bu şekilde gerçekleşen kanunî halefiyetin amacı, rücu hakkını teminat altına almak üzere, alacaklının sahip olduğu fer'i hakların (rehin, hapis hakkı, birlikte kefillere karşı olan haklar gibi) kefile geçmesini sağlamaktır[5].

Kefalet yanında alacak için rehin tesis edilmiş veya diğer teminatlar verilmişse kefil borcu ifadan sonra rehin hakkına ve diğer teminatlara halef olur. Rehin ile verilen diğer teminatlar bakımından halefiyet, kefalet anında bu teminatların bulunmasına bağıldır. Asıl borçlunun sonradan bu kefalet konusu borç için özellikle verdiği teminatlara halefiyet de mümkündür. Ancak bu ihtimallerin tamamında aksinin taraflarca kararlaştırılmamış olması gerekir.

Kefil kısmi ifada bulunmuşsa rehin hakkının buna ilişkin kısmına halef olabilir. Alacaklının rehin üzerinde kefilin halef olduğu miktar-

---

[5] **Giovanoli**, Art. 507, N. 2; OR-**Pestalozzi**, Art. 500, N. 3; **Becker**, Art. 505, N.1.

dan fazla bir alacak hakkı var ise bu hak kefilin rehin hakkından önceliklidir.

Kefilin sahip olduğu ikinci ve özel rücu imkânı ise, onunla asıl borçlu arasındaki hukukî ilişkiye dayanır. Vekâlet veya vekâletsiz iş görmeden doğan veyahut sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bu iç ilişkiye dayanan rücu imkânı, TBK m. 596/III'te, "Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan istem ve def'iler saklıdır" şeklinde ifade olunmuştur.

Kefalet konusu alacak rehin ile teminat altına alınmış ve borcun ifa edilmemesi nedeniyle rehin paraya çevrilmiş veya rehin veren tarafından borç ödenmişse rehin konusu şeyin maliki kefile karşı rucu hakkını kullanamaz. Ancak, kefil ile rehin maliki arasında rucu imkânını düzenleyen bir anlaşma var ise rehin malikinin kefile rucu etmesi mümkündür. Aynı şekilde kefalet konusu alacak rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse, rehin hakkı sahibi kefile rucu edebilir (TBK m. 596/IV).

Kefilin ifa anında rücu hakkına ilişkin zamanaşımı süresi işlemeye başlar (TBK m.596/V).

2. Şartları

Kefilin asıl borçluya karşı rücu hakkını kullanabilmesi için şu şartların bulunması gerekir[6]:

a) Geçerli bir kefalet sözleşmesi bulunmalıdır

Kefalet sözleşmesi geçersiz ise, kefil alacaklıya yaptığı ödemeyi ondan sebepsiz zenginleşme veya asıl borçludan vekâlet veya vekâletsiz iş görme hükümlerine göre talep edebilir[7].

Kefil yanılma veya ehliyetsizlik nedeniyle geçerli olmayan bir borca kefalet vermiş ve bu borca ilişkin ifada bulunmuşsa asıl borçluya karşı rucu etme imkânı yoktur. Eksik bir borca kefalet gibi dava hakkı vermeyen borca kefalet halinde de aynı durum söz konusudur. Buna karşılık zamanaşımına uğramış borç bakımından bir istisna bulunmaktadır. Buna göre, kefil kefaletine konu borçtan sorumlu olmayı borçlunun vekili sıfatı ile üstlenmişse alacak zamanaşımına uğramış

---

6 OR-**Pestalozzi**, Art. 507, N. 5 vd; **Tercier**, N. 3892 vd; **Scyboz**, sh. 131-132; **Grassinger**, İHFM, C. LV, S. 1-2, sh. 403. vd.

7 **Beck**, Art. 507, N. 16; OR-**Pestalozzi**, Art. 507, N. 5; **Lerch-Tuason**, sh. 74.

olsa bile asıl borçlu kefile karşı vekâlet hükümlerine göre sorumlu olmaktadır (TBK m.596/VI)

b) Kefil alacaklıya olan borcunu ifa etmelidir

Kefilin alacaklıya olan borcunu ifa etmesi veya kefalet borcunun takas veya ifa yerine geçen edim gibi bir sebeple sona ermesi gerekir. Buna karşılık, alacaklının bağışlama kastıyla kefili ibra etmesi halinde, kefilin asıl borçluya karşı rücu hakkı söz konusu olamaz[8]. Kefilin alacaklıya olan kefalet borcunu kısmen ifa etmesi halinde de rücu mümkündür. TBK m. 596/I'de geçen "ifada bulunduğu ölçüde" deyimi ile bu husus ifade edilmiş bulunmaktadır[9].

c) Asıl borç muaccel olmalıdır

Kefilin asıl borçluya rücu edebilmesi için, asıl borcun muaccel olması gerekir; aksi takdirde, asıl borçlu kefil üzerinden dolanılmak suretiyle, muacceliyetten önce ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Diğer taraftan, kefil asıl borçluya ait muacceliyet def'ini ileri sürmek zorundadır (TBK m. 591/I); bunu ileri sürmezse rücu hakkını kaybeder (TBK m. 591/III). Ancak, def'ilerin varlığı bilinmeksizin ifa gerçekleşmişse rücu hakkı varlığını devam ettirir. Asıl borçlu kefilin bu def'ileri bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat etmesi halinde def'ilerin ileri sürülmüş olması halinde kefilin ifa etmek zorunda kalmayacağı miktar ölçüsünde rücu hakkının kapsamı daralır (TBK m. 591/III).

Kumar ve bahisten doğan borçlara kefalet halinde kefil borcun kaynağını bilse dahi asıl borçlunun sahip olduğu def'ileri ileri sürme hakkı bulunmaktadır (TBK m. 591/IV).

---

[8] **Giovanoli**, Art. 507, N. 4; OR-**Pestalozzi**, Art. 507, N. 5; **Grassinger**, agm. sh. 404.

[9] Bk. **Beck**, Art. 507, N. 20; OR-**Pestalozzi**, Art. 507, N. 5.

§ 39. KEFALETİN SONA ERMESİ

I. Asıl borca bağlı sona erme sebepleri

1. Genel olarak

TBK m. 598'e göre, "Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur.". Kefalet borcunun fer'i bir borç olması sebebiyle, bu hüküm TBK m. 131/I hükmünü bütün kefalet türleri açısından teyit etmektedir[1]. Bu sonuç, alacaklının tatmin edilip edilmemesine bakılmaksızın gerçekleşir; burada TBK m. 166/II hükmü uygulanmaz[2]. Böylece asıl borçlunun ifası, ibra, borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık (TBK m. 136) ve takas (TBK m. 139) sebepleriyle asıl borç sona erince, kefalet borcu da sona erer. Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi (TBK m. 135) halinde alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar varlığını devam ettirir (TBK m. 598/II).

Takas işlemi bakımından özel bir durum bulunmaktadır. Buna göre asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulunuyorsa kefil de alacaklıya ifadan kaçınma hakına sahiptir (TBK m. 140/II).

2. Tecdit (borcun yenilenmesi)

Tecdit halinde kural olarak asıl borçla birlikte kefalet borcu da sona erer; kefil tecdide muvafakat etse bile, kefalet yenilenen borcu temin etmez. Bununla beraber, taraflar yenilenen borç için yeni bir kefalet sözleşmesi kurabilirler. Sadece TBK m. 134/III carî hesap sözleşmesi bakımından bu kurala istisna getirmiştir: "

Kalemlerden birinin güvencesi varsa, aksi kararlaştırılmadıkça, hesap kesilip sonucun kabul edilmiş olması, güvenceyi sona erdirmez.". Kefilin, kefil olduğu alacak bir carî hesap kalemi teşkil etmese dahi bu hüküm uygulanacak ve kefil zamanla sorumlu olmayı hiç düşünmediği bir borçtan dolayı sorumlu olacaktır[3].

---

1 OR-**Pestalozzi**, Art. 509, N. 2.

2 **Beck**, Art. 509, N. 13; **Schönenberger**, Art. 509, N. 3; OR-**Pestalozzi**, Art. 509, N. 3, **Engel**, sh. 609; **Tercier**, N. 3925.

3 **von Tuhr/Escher**, sh. 76, dn. 42; **Reisoğlu**, sh. 228; **Tandoğan** II, sh. 793.

3. Dış borç üstlenme

Bu takdirde kefilin sorumluluğu borcun nakline yazılı olarak rıza göstermesi halinde devam eder (TBK m. 198/II).

II. Kefalet sözleşmesine özgü sona erme sebepleri

1. Belirli süreli kefaletin sona ermesi

TBK m. 600 gereğince, belirli bir süre için kefalet halinde, kefil sözleşme süresinin sonunda borcundan kurtulmaktadır.

2. Süresiz kefaletin sona ermesi

Süresiz kefalet halinde, asıl borç vadeye bağlı ise kefil adi kefalette her zaman borçluya dava ve icra takibi haklarını kullanmasını, alacak rehin ile teminat altına alınmışsa rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmesini ve takibe ara vermeden devam etmesini isteyebilme hakkına sahiptir. Müteselsil kefalette ise kefil bu hakkını asıl borcun muaccel olduğu tarihten itibaren bir ay içinde kullanması mümkündür (TBK m. 601/I).

Buna karşılık asıl borcun vadeye bağlı olmayıp, onun muaccel olması borçluya bir ihtar yapılmasına bağlı ise, kefil, kefil olduğu tarihten bir yıl sonra bu ihtarın yapılmasını ve böylece borç muaccel olduktan sonra kefaletin adi ya da müteselsil olmasına göre her zaman veya bir ay içindeicraya veya mahkemeye başvurarak asıl borçluya karşı hakkını talep etmesini ve bu takibe ara vermemesini alacaklıdan talep edebilir (TBK m. 601/II).

Alacaklı, her iki halde de kefilin bu talebini yerine getirmez ise, kefil kefaletten kurtulur (TBK m. 601/III).

3. Gerçek kişinin verdiği kefaletin on yıl sonra sona ermesi

TBK m. 598/III'e göre gerçek bir kişi tarafından verilen kefalet, hangi türe mensup olursa olsun, kefalet sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren on yılın geçmesiyle kendiliğinden sona erer.

Taraflar kefaleti on yıldan fazla bir süre için kararlaştırmışsa kefaletin uzatılmış olması ya da yeni bir kefalet sözleşmesinin kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde bu kefalet de on yıllık sürenin sonunda hüküm ve sonuç doğurmaz (TBK m. 598/IV). Kefaletin bu surette uzatılması kefaletin sona ermesinden en erken bir yıl önce tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Bu anlaşma kefalet sözleşmesinin şekline uygun olarak ve yazılı yapılmalıdır. Uzatma ile en fazla on yıllık yeni

bir kefalet dönemi için kefilin sorumluluğu söz konusu edilebilir (TBK m. 598/V. Bu sürenin tekrar uzatılması mümkün değildir.

4. Kefaletten dönme

TBK m. 599'a göre gelecekte doğacak bir borca kefalet verilmiş ve borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu kefaletten sonra önemli ölçüde bozulmuşsa borç doğmadan kefil, alacaklıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kefaletten dönebilir. Aynı durum asıl borçlunun mali durumunun kefilin iyiniyetle kefalet esnasında varsaydığından çok daha kötü olduğunun ortaya çıkması için de söz konusudur.

Ancak, bu durumlarda kefil alacaklının kefalet sözleşmesine güveni nedeniyle uğradığı zararı gidermekle yükümlü tutulmuştur (TBK m. 599/II).

5. Çalışanlara kefalet verilmesi halinde özel sona erme hali

Çalışanlar lehine belirli süreli olmayan kefalet verilmesi halinde kefil her üç yılda bir sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir. Fesih kullanıldığı yılı takip eden yıl sonunda geçerlilik kazanmaktadır (TBK m. 602).

6. Alacaklının ödemeyi kabulden kaçınması

TBK m. 593/I'e göre borcun muaccel olması halinde kefil alacaklıdan ödemenin kabulünü talep edebilmektedir. Alacaklının haklı bir sebep bulunmaksızın bu ödemeyi kabul etmemesi kefilin borcundan kurtulmasına yol açmaktadır. Birlikte müteselsil kefalette ödeme talebi kabul edilmeyen kefilin sorumluluğu kendi üzerine düşen oranda azalmaktadır (TBK m. 593/II).

Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur (TBK m. 587/III).

7. Kefalete ilişkin hükümlerin uygulama alanı

TBK m. 603 "Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır" hükmünü amirdir.

Buna göre kanuni düzenlemenin kapsamına giren ilişkiler bakımından gerçek kişiler tarafından kişisel güvence verilmesi halinde kefaletin şekline, ehliyete ve eşin rızasına ilişkin hükümler uygulanacaktır[4].

Kefaletin şekle ilişkin hükümleri TBK m. 583'te düzenlenmiştir. Kanuna yazılı şekil şartını geçerlilik şartı olarak kabul etmektedir. Bu yazılı şekil içinde kefilin sorumlu olduğu azami miktar ve kefalet tarihi zorunlu unsur olarak belirlenmiştir. Kefalet vermeye ilişkin temsil yetkisi de bu maddede belirtilen şartları içermelidir. Diğer yandan kefil olma ehliyeti madde kapsamında kalan diğer ilişkilere de uygulanmaktadır. Yasal temsilcinin sınırlı ehliyetsiz adına kefalet verme yasağı böylece garanti sözleşmeleri için de öngörülmüştür. Aynı şekilde eşin rızası kişisel güvence verilmesine ilişkin işlemlerde aranmaktadır. Kefalete eşin rızası TBK m. 584'te düzenlemektedir. Mahkemece ayrılık kararı verilmemişse ya da kanunen eşlerden birinin ayrı yaşama hakkı bulunmuyorsa diğer eşin yazılı rızası olmadan kefil olunamamaktadır. Eşin söz konusu rızayı en geç sözleşmenin kurulması anında vermiş olması gerekmektedir.

Kişisel güvence sağlayan işlemler kapsamına öncelikle teminat amaçlı garanti sözleşmeleri girmektedir. Kefaletten daha ağır sonuçlar doğuran garanti sözleşmesinin herhangi bir şekil ve esasa ilişkin şarta tabi olmaksızın kurulması imkânı böylece engellenmiştir.

Bu hüküm, gerçek kişilerin borca katılmak yoluyla müteselsil sorumluluk üstlenmelerini de aynı şartlara bağlamaktadır. Diğer bazı hukuki ilişkilere TBK m. 603 hükmünün uygulanması bu işlemlerin kişisel güvence sağlaması ve kanunun düzenleme kapsamı içinde kalması şartlarının bulunması ile mümkün olmaktadır.

---

[4] Kıymetli evrak ticari iş olup TTK'da taahhüt altına girmek için eşin rızası gerekmediğinden ve TTK, TBK karşısında özel hüküm sayıldığından TBK m. 584 şartları aval için aranamaz (12. HD. 4.7.2013 tarih E. 2013/16400 K. 2013/25100 - Kazancı-); Çeke aval verilmesinde, avalin sözleşme niteliği taşımayan tek taraflı bir irade beyanıyla verilmesi, kafalet ile avalin önemli mahiyet farklılığı bulunması nedeniyle TBK m. 603'ün avale uygulanamayacağı; aksinin kabulü halinde avalin ticari senetlerin tedavülünü kolaylaştırma fonksiyonunun icra edemeyeceği, eşin rızasını alma şartının kabul edilmesi halinde de aynı durumun meydana geleceği, bu nedenlerle itiraza konu kanun maddelerini başvuran mahkemenin eldeki olaya uygulayamayacağı, bu hususa dayalı olarak Anayasaya aykırılık iddiasının ilk incelemede reddedilmesi gerektiği hakkında Emin Kuz'a ait karşı oy yazısı için bkz. Anayasa Mahkemesi 26.12.2014 tarih E. 2013/57 K. 2014/162.

KAVRAM FİHRİSTİ

A

Âdi kefalet, 480
Âdi kira sözleşmesi, 256-258
Ağır kusur, 157
Ahlâkî borcun yerine getirilmesi, 239
Aile konutu, 262, 327
Alıcının temerrüdü, 222, 228
Alım hakkı, 202
Alt kira ve kullanım hakkının devri, 316
Alt vekâlet, 451
Alt yüklenici, 372, 373
Arazi, 78
Ard arda teslimli satış, 105
Ardiye, 51, 268
Aslî edim yükümü, 50
Aval, 472
Ayıba karşı tekeffül, 50, 70, 74, 81, 95, 118, 125, 126, 133, 152-155, 272, 354, 362, 375, 379, 383, 400, 403, 414
Ayıbı bildirme külfeti, 404
Ayıbın giderilmesini (tamirini) isteme hakkı, 279
Ayıptan sorumluluk, 116
Ayırt etme gücü, 221, 238
Aynı anda ifa, 169
Azil ve istifa, 461

B

Bağımsız kefalet, 485
Bağışlama sözleşmesi, 235, 236, 239, 249
Bağışlama taahhüdü, 241, 251, 252
Bağışlama, 51, 59, 109, 208, 209, 235-247, 249-251, 252, 256, 287, 466, 502
Banka tasarruf hesabı, 350
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 376, 378
Bedel hasarı, 85, 86, 429
Bedel ödeme borcu, 366, 414
Beğenme koşuluyla satış, 218
Belediye, 290, 319, 332, 367
Belirli süreli kira sözleşmesi, 264, 265
Belirsiz süreli kira sözleşmesi, 266
Bileşik sözleşme, 56, 60, 64
Birleştirme, 162, 298, 397
Birlikte kefalet, 485, 486
Borca katılma, 471
Borç ilişkisi, 208
Borç kaynağı, 47, 48
Borçlunun temerrüdü, 101, 389
Bozucu şart, 475
Bozucu yenilik doğuran hak, 284
Bölünemeyen borç, 261

C, Ç

CISG, 67, 68, 77, 87, 90, 95, 102-104, 107, 111, 117, 123, 128, 130, 132, 169, 177, 178
Çatılı işyeri, 268
Çifte tipli sözleşmeler, 58

D

Dava ve takip masrafları, 490
Devir borcu, 51, 91, 107, 216, 258, 296, 345, 368
Devlet İhale Kanunu, 264, 265, 367, 376

Devlet İhale Kanunu, 81
Devre mülk, 257
Dış borç üstlenme, 504
Doğrudan doğruya temsil, 455
Dönme, 113, 140, 143, 144, 153
Dönme, 391, 392, 461
Dürüstlük kuralı, 123
Dürüstlük kuralı, 199

E

Edim, 50, 51, 58-60, 65, 70, 71, 79, 84-86, 94, 101, 116, 117, 148, 161, 167, 182, 188, 189, 200, 240, 243, 244, 253, 258, 259, 272, 296, 303, 345, 352, 359-361, 371, 383, 390, 397, 414, 428, 429, 431, 435, 438, 447, 448, 469, 470, 502
Edim, 84, 101
Ekonomik ayıp, 119
Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşme, 345, 441
Elbirliği mülkiyeti, 262
Elden bağışlama, 240, 241, 247
Enerji, 57, 61, 79
Eser meydana getirme, 359, 360, 369
Eser sözleşmesi, 50, 59, 359, 360, 361, 365-369, 380, 383, 394, 395, 400, 405, 412, 414, 415, 423, 427, 429, 432
Eşin rızası, 478

F

Faiz, 112, 175, 176, 347, 356, 479
Faize faiz yürütülmesi, 349
Faizi aşan zarar, 228
Fark teorisi, 101
Feragat, 211
Fiil ehliyeti, 261, 262, 494
Fiilî bir karine, 438
Fiilî zarar, 425
Fiyatların aşırı derecede artması, 417

G

Garanti sözleşmesi, 120, 469
Garanti taahhüdü, 121
Garanti, 120, 121, 140, 469, 470
Gecikme tazminatı, 396
Gelecekte doğacak borçlar, 475
Gelecekteki bir şeyin satışı, 76
Gelecekteki eşya ve haklar, 76
Gemi sicili, 80
Genel hüküm, 47, 48, 49, 50, 94, 253, 254, 264, 290, 354
Genel işlem koşulları, 67
Geniş anlamda karma sözleşmeler, 57
Geri alma hakkı, 250, 251
Gönderme borcu, 91
Götürü (sabit) bedel, 415, 416
Güvence olarak para veya kıymetli evrak, 313

H

Hak düşürücü süre, 133, 210, 211, 215
Hak düşürücü süre, 211
Hakimin sözleşmeye müdahalesi, 305
Hâkimin sözleşmeyi tamamlaması, 259
Haklı sebep, 318, 325
Haksız fiiller, 48
Hapis hakkı, 313, 314
Hastaneye kabul sözleşmesi, 58
Hata, 50, 161, 162, 238, 452, 475, 476, 493, 495
Havale, 47, 167, 239, 298, 351, 435
Hizmet sözleşmesi, 361
Hizmet, 51, 158, 361, 438
Hukukî ayıp, 119
Hukukî birlik, 75

Hukukî fiil, 445
Hukukî fiillere ilişkin vekâlet, 445

İ

İfa, 70, 86, 90, 146, 167, 168, 297, 398, 429
İfanın aşırı güçleşmesi, 418
İfaya hazırlık hareketleri, 183
İflâs, 228
İhale bedeli, 230
İhale, 81, 230, 319, 368, 371, 376, 398, 422
İkame alım, 102
İkame vekâlet, 451
İki haklı ihtar sebebiyle tahliye, 335
İllî işlem, 441
İptal edilebilir borca kefalet, 475
İptal, 475
İrat, 52
İsbat, 469
İsimsiz sözleşmeler, 56, 61, 62
İsteğe bağlı açık artırma, 229
İsteğe bağlı artırmalar, 228
İsteğe bağlı özel artırma, 229, 230
İşe zamanında başlama ve devam borcu, 390
İşgörme sözleşmeleri, 51, 55
İşin başkasına yaptırılması, 410
İşlem temeli, 301, 303
İştira sözleşmeleri, 187

K

Kabul, 125, 126, 134, 388
Kamu ihale sözleşmeleri, 368
Kamulaştırma, 288
Kapıcılık sözleşmesi, 58
Kâra katılmalı ödünç sözleşmesi, 352
Karma bağışlama, 240
Karma sözleşme, 56-58, 62, 63
Karşılıksız kazandırma, 235
Kat mülkiyeti, 78
Kaydı hayatla irat, 52
Kaza, 167
Kefaletin şekli, 472, 505
Kefilin rücu hakkı, 500
Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler, 57
Kesinti metodu, 426
Kısmî kefalet, 485
Kıyas, 63
Kira bedeli, 259, 284, 296, 297, 298, 299, 300, 311, 335
Kira ilişkisinin devri, 317
Kira sözleşmesinde ayıp, 273
Kira sözleşmesinin uyarlanması, 300
Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşme, 268
Kira, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 62, 88, 200, 207, 253, 255-264, 268, 269, 273, 274, 281, 282, 284, 286-291, 295-302, 311-321, 324, 327, 329, 332, 333, 335-338, 346, 396, 411, 436, 475, 477
Kiracının iflası, 326
Kiracının ölümü, 326, 328
Kiralananı geri verme, 315
Kiralananın kullanılmasının devri, 258
Kiralayan, 258, 261, 273
Kombine sözleşmeler, 58
Komşulara saygı gösterme borcu, 293
Konut ve çatılı işyeri kiraları, 254, 260, 266, 267, 320, 327
Kötü ifa, 165, 249
Kullandırma sözleşmeleri, 51
Kullanım ödüncü, 51, 239, 258, 339-344
Kullanımı etkileyen ayıp, 284

Kuralların yarışması, 50
Kusur karinesi, 50, 285
Kusur sorumluluğu, 114
Kusurlu imkânsızlık, 245

M

Maddî edim hasarı, 84
Maden, 78, 185
Mahkeme masrafları, 113
Malzemeleri özenle kullanma yükümü, 380
Malzemelerin sağlanması borcu, 377
Mehil, 50, 100, 105, 170, 344, 357, 389, 396, 410, 436
Mesafe satışı, 87
Mesafeli sözleşme, 48, 87, 231
Mevsuf susma, 142
Miktar eksikliği, 118
Milletlerarası mal satışı (CISG), 67
Mimari bir proje, 363
Mirasın reddi, 239
Mücbir sebep, 83
Mükellefiyetli bağışlama, 237, 240
Mütemmim cüz, 79
Müteselsil borçluluk, 471
Müteselsil kefalet, 471, 483, 484, 487, 504
Müteselsilen sorumluluk, 138, 140, 262, 263, 372, 388

O

Olağanüstü masraflar, 342
Ön sözleşme, 193, 194, 201
Önalım hakkı, 187, 201-217
Önemli ayıp, 279
Örnek üzerine satış, 218
Özel hüküm, 49, 50, 95
Özel temsil yetkisi, 446
Özen borcu, 399, 448

P, R

Pansiyon sözleşmesi, 58
Parça eşya, 73
Portföy yönetim sözleşmesi, 58
Rehnin paraya çevrilmesi def'i, 482
Rızaî sözleşme, 70, 256, 257, 339, 345, 356, 360, 366, 435, 441
Rücua kefalet, 488

S

Saklama sözleşmeleri, 51
Satıcının temerrüdü, 96, 101
Satılanı koruma (muhafaza) yükümü, 135
Satış parası, 150
Satış sözleşmesi, 49, 65-73, 76, 96, 104, 109, 161, 169, 200, 209, 367, 400
Satış vaadi, 193, 196, 198
Satış, 185-214, 217-232
Satış, 188, 189, 193, 194, 196, 198-200, 209, 212, 215, 220, 222, 224, 226-228, 231, 232
Satış, 48, 49, 51, 53, 57-59, 65-89, 91, 92, 95-98, 101-114, 117, 120-125, 129, 133-138, 140, 143-145, 148-151, 154, 158-161, 165, 167-170, 172, 177, 179, 183, 256, 276, 277, 284, 286-288, 292, 295, 352, 354, 367, 368, 379, 400, 408, 411, 412, 436, 454, 479
Satma yetkisi, 136
Sebepsiz zenginleşme, 238, 247, 250, 282, 342, 414, 474, 485, 499, 501
Sebepsiz zenginleşme, 47, 48, 109, 113
Seçim hakkı, 136-140
Semenin tenzili, 375

Seyahat düzenleme (global seyahat) sözleşmesi, 58
Soğurma (imtisas) teorisi, 62
Sözleşme özgürlüğü, 54
Sözleşmenin devri, 318
Süre vermenin faydasız olması, 296, 322
Şahsen ifa, 369
Şartlı bağışlama, 244
Şekil özgürlüğü, 54

T

Tahliye davası, 328
Takas hakkından feragat, 313
Takas, 157, 313, 350, 351, 476, 495, 503
Taksitle satış, 219, 220, 221, 224
Tâli borç, 468
Talimat, 453
Tam zapt, 112
Tamir, 282
Tapu sicili, 215, 289
Tapu siciline şerh, 215, 289
Tapusuz taşınmaz, 186, 195
Tartışma def'i, 480
Tasarruf işlemi, 51, 74, 144, 192, 193, 195, 240, 241
Tasavvur açıklaması, 120, 405
Taşınır satışı, 77, 78, 82
Taşınmaz kirası, 283, 289
Taşınmaz satış vaadi, 193-199, 215
Taşınmaz satışı, 61, 72, 78, 189, 192
Taşınmaz satışının konusu, 78
Taşınmazların açık arttırma yoluyla satışı, 230
Tazminat, 146, 285, 411
Teferruat, 80
Tehlikenin üstlenilmesi, 51
Tek tarafa borç yükleyen sözleşme, 84, 235, 249, 469
Temerrüt faizi, 174, 177, 178
Temerrüt, 396
Teminatları ve isbat vasıtalarını saklama yükümü, 498
Temizlik ve bakım giderleri, 294
Temlik borcu doğuran sözleşmeler, 51
Terkip (kombinezon) teorisi, 63
Teslim borcu, 271, 272, 359, 393-396
Teslim, 99, 123, 135, 218, 249, 271, 272, 359, 393, 394, 395, 396
Ticarî iş, 347
Ticari satış, 66, 96, 97, 101, 133
Ticari temsilcilik, 47
Ticari vekâlet, 47
Toplama metodu, 426
Toplu kefalet, 485
Toptan götürü, 416
Trafik sicili, 82
Trampa, 51, 59, 79, 167, 209, 287
Tüketici satışı, 66
Tüketici, 66, 68, 94, 128, 133, 139, 146, 155, 158, 159, 231, 234, 354, 358
Tüketim ödüncü, 345-352, 355-357

U, Ü

Umulmayan hal, 427
Usulsüz tevdi, 51, 349-351
Usulüne uygun ifa, 459
Uyarma yükümü, 402
Uzun süreli eser sözleşmesi, 360
Ücretsiz onarım, 158
Üst hakkı, 289

V

Vasiyet, 246
Vedia, 51
Vefa sözleşmeleri, 187
Vekâlet sözleşmeleri, 51, 444, 445
Vekâlet sözleşmesi, 434, 435, 438, 441, 443, 444, 448, 450, 463
Vekâlet, 58, 434, 435, 437, 438, 441, 443-446, 448, 450, 453, 454, 456, 458-461, 463, 501
Vekâletsiz işgörme, 47, 282, 342, 415
Vekilin özen borcu, 448
Vekilin sadakat yükümü, 447
Veresiye satış, 170
Vergileri ödeme borcu, 290

Y

Yabancı para birimine endeksli kira bedelleri, 306
Yabancı para, 167, 258, 356
Yan edim, 60
Yan yükümler, 93
Yapı denetim kuruluşu, 413
Yaratma teorisi, 63
Yasal temsilci, 472, 506
Yatılı okul sözleşmesi, 58
Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle dava açması, 332
Yeniden kiralama yasağı, 328
Yüklenicinin özen ve sadakat borcu, 380

Z

Zamanaşımı, 154, 157, 191, 353
Zamanaşımının durması, 154
Zamanaşımının kesilmesi, 154
Zapttan sorumluluk, 108
Zilyetlik, 271
Zorunlu masraflar, 113, 146, 414